

RENATO BENEDUZI

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

II

ARTIGOS 70 AO 187

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

REVISTA DOS
TRIBUNAIS™

2019 - 06 - 11

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A.M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Linotec

Controle de qualidade da diagramação: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastrorosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

Analista de Produção Gráfica: Aline Ferrarezi Regis

2019 - 06 - 11

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

DEDICATÓRIA

Dedicatória

À memória de minhas avós Tita e Nira.

© desta edição [2018]

2019 - 06 - 11

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE O AUTOR

Sobre o autor

Doutor em Direito pela *Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg*. Mestre em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Professor de Direito Processual Civil, na Graduação e na Pós-graduação, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO). *Visiting Fellow* na Universidade de Oxford (*academic visitor; Institute of European and Comparative Law*), em 2014. *Ricercatore post-dottorato* na *Università degli Studi di Firenze*, em 2016. Advogado.

© desta edição [2018]

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a Glosa e logo em seguida com os Comentários. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os Comentários tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de Comentários ao Código de 1973 (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes Comentários, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes Comentários estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de Comentários ao Código de Processo Civil de 2015, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

PARTE GERAL

LIVRO III - DOS SUJEITOS DO PROCESSO

TÍTULO I - Das Partes e dos Procuradores [Art. 70 a 112]

CAPÍTULO I - Da Capacidade Processual [Art. 70 a 76]

CAPÍTULO II - Dos Deveres das Partes e de Seus Procuradores [Art. 77 a 102]

CAPÍTULO III - Dos Procuradores [Art. 103 a 107]

CAPÍTULO IV - Da Sucessão das Partes e dos Procuradores [Art. 108 a 112]

TÍTULO II - Do Litisconsórcio [Art. 113 a 118]

TÍTULO III - Da Intervenção de Terceiros [Art. 119 a 138]

CAPÍTULO I - Da Assistência [Art. 119 a 124]

CAPÍTULO II - Da Denúnciação da Lide [Art. 125 a 129]

CAPÍTULO III - Do Chamamento ao Processo [Art. 130 a 132]

CAPÍTULO IV - Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica [Art. 133 a 137]

CAPÍTULO V - Do *Amicus Curiae* [Art. 138]

TÍTULO IV - Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça [Art. 139 a 175]

CAPÍTULO I - Dos Poderes, dos Deveres e da Responsabilidade do Juiz [Art. 139 a 143]

CAPÍTULO II - Dos Impedimentos e da Suspeição [Art. 144 a 148]

CAPÍTULO III - Dos Auxiliares da Justiça [Art. 149 a 175]

TÍTULO V - Do Ministério Público [Art. 176 a 181]

TÍTULO VI - Da Advocacia Pública [Art. 182 a 184]

TÍTULO VII - Da Defensoria Pública [Art. 185 a 187]

PARTE GERAL – LIVRO III - Dos SUJEITOS DO PROCESSO

1. ¹Sujeito do processo é todo aquele que, no processo, pratica um ato processual (um ato destinado a produzir efeitos no processo)². Todo sujeito do processo realiza atos processuais (mais de um, ou mesmo apenas um³), mas nem todo ato processual é praticado por um sujeito do processo (quando um ato, embora processual, é realizado fora do processo – por exemplo, na eleição de foro⁴).

2. Daí por que são sujeitos o juiz (mas não o juízo, porque o juízo é órgão, não sujeito)⁵, as partes, seus procuradores, o Ministério Público (quando ele intervir no processo na qualidade de *custos iuris* ⁶), terceiros (nas diversas modalidades de intervenção de terceiros), os auxiliares da justiça (quando realizam atos processuais) e as testemunhas (a testemunha, que têm direitos e deveres processuais, é também sujeito do processo porque seus atos – dar seu testemunho, por exemplo – destinam-se a produzir efeitos no processo⁷⁸).

3. No livro III de sua parte geral, o Código de Processo Civil trata das partes e dos seus procuradores (título I – arts. 70 a 112), do litisconsórcio (título II – arts. 113 a 118), das diversas modalidades de intervenção de terceiros (título III – arts. 119 a 138), do juiz e dos auxiliares da justiça (título IV – arts. 139 a 175), do Ministério Público (título V – arts. 176 a 181), da Advocacia Pública (título VI – arts. 182 a 184) e, por fim, da Defensoria Pública (título VII – arts. 185 a 187).

NOTAS DE RODAPÉ

¹

Registro aqui o meu agradecimento a Lorrane Nogueira de Carvalho e Lucas de Sousa Amaral por sua valiosa ajuda na atualização deste livro para sua 2ª edição.

²

“Handlungen, die auf das Verfahren einwirken, nennt man Prozesshandlungen” (*Jauernig/Hess, Zivilprozessrecht*, p. 124). Também *Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht*, p. 328.

³

O autor pratica inúmeros atos, a começar pela demanda. O juiz substituto, que profere apenas uma única decisão nas férias do titular, pratica apenas um ato processual.

4

Na eleição de foro, o agente só se tornará sujeito do processo se depois vier a existir um, mas a eleição de foro é um ato – *rectius*, um negócio – genuinamente processual porque seus efeitos destinam-se a se produzir em um processo, ainda que futuro e eventual. A parte do contrato que contém uma cláusula de eleição de foro não será, necessariamente, parte do eventual processo. Suponha-se que, dos três contratantes, apenas dois litiguem entre si. O terceiro terá realizado o ato processual, mas não será sujeito do processo.

5

Sobre o ponto confirmam-se os comentários aos arts. 139 a 143.

6

O Código de Processo Civil de 2015 define o Ministério Público não mais como apenas o fiscal da lei (*custos legis*), mas como fiscal da ordem jurídica (*custos iuris*). Sobre o ponto confirmam-se os comentários ao art. 176.

7

Equívocada a opinião, por isso, segundo a qual a testemunha não passaria de uma mera fonte de prova. Ela tem direitos e deveres de natureza processual e seus atos destinam-se a produzir efeitos no processo. Quando a testemunha, por exemplo, dá seu testemunho, serve este ato processual para relatar *no processo* fatos dos quais ela tenha conhecimento (*Rosenberg/Schwab/Gottwald*, Zivilprozessrecht, p. 681). Também Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 3, p. 636.

8

Também Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 120.

TÍTULO I - DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Partes do processo (e, assim, da relação jurídica processual¹) são o sujeito parcial² do processo que pede a tutela jurisdicional (demandante, que deduz uma pretensão processual) e, após sua citação, aquele contra quem esta tutela é pedida (demandado, contra quem é deduzida uma pretensão processual), independentemente de quem sejam os sujeitos da relação jurídica material que possa existir, ou não, entre eles³. Parte, deste modo, é quem efetivamente integra a relação jurídica processual, não quem deveria integrá-la. Com isto se quer dizer, por exemplo, que o demandado a quem faltar legitimidade passiva não deixará de ser parte, ainda que não devesse sê-lo⁴. Trata-se, enfim, de um conceito processual (ou formal) de parte, não material⁵.

1. O conceito de parte no processo não se confunde com o de parte na demanda (enquanto um de seus três elementos constitutivos, ao lado da causa de pedir e do pedido⁶), que é o “ato pelo qual alguém pede ao Estado a prestação da atividade jurisdicional”⁷. A relação jurídica processual nasce com a demanda, mas o demandado só passa a integrá-la após sua citação⁸. O demandante, por isso, será sempre parte da demanda e, ao mesmo tempo, do processo. O demandado, no entanto, até sua citação, será parte apenas da demanda, não do processo. A distinção é relevante na determinação dos efeitos da litispendência (art. 240 do CPC). O procurador da parte, por fim, que a representa em juízo, embora sujeito do processo, não é parte dele.

NOTAS DE RODAPÉ

1

O Estado, por um de seus órgãos (o juízo) e apresentado por um juiz, é o terceiro sujeito da relação jurídica processual. A questão, no entanto, é controversa. Sobre o ponto: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 334. Sobre o desenvolvimento histórico do conceito de relação jurídica processual: Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 421. Também Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 10.

2

Sobre a distinção entre sujeitos parciais e imparciais do processo, confirmam-se as notas introdutórias ao art. 139.

3

“L’idea di parte è data dunque alla lite stessa, dal rapporto processuale, dalla domanda: non occorre

cercala fuori della lite e in particolare nel rapporto sostanziale che è oggetto di controversia” (Giuseppe Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile*, p. 579).

4

Sobre o ponto, detalhadamente: Silas Silva Santos, *Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo*, p. 11.

5

A doutrina alemã prefere a expressão *formeller Parteibegriff* (conceito *formal* de parte). Por exemplo: Musielak; Voit, *Grundkurs ZPO*, p. 147. Na doutrina italiana mais recente: Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 304.

6

Sobre o ponto: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 116.

7

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 11.

8

Este fato leva a doutrina alemã a diferenciar conceitualmente a pendência do processo antes da citação do réu (*Anhängigkeit*) de sua pendência após a citação (*Rechtshängigkeit*). Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 86.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I - DAS PARTES E DOS PROCURADORES

CAPÍTULO I - DA CAPACIDADE PROCESSUAL

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Direito anterior – art. 7.º do CPC/1973.

Direito comparado – § 52 da ZPO alemã, art. 75 do CPC italiano, art. 117 do CPC francês, art. 7.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 9.º do CPC português.

1. Existência das partes

Para praticar atos processuais válida e eficazmente, é preciso que as partes em litígio existam, que possam ser concretamente identificadas, que tenham capacidade de ser parte, capacidade processual e, ainda, capacidade postulatória¹. Existir, neste contexto, significa não ser uma invenção (Erdichtung), como uma personagem literária ou mítica, nem ser uma pessoa (física ou jurídica) que tenha deixado de existir². Com a morte, o falecido deixa de existir³. Por isso ele não pode mais ser parte⁴, embora seu espólio e seus sucessores possam, conforme o caso, virem a sê-lo. Também não poderá ser parte a pessoa jurídica extinta⁵, embora sua massa falida possa vir a sê-lo. Mas aquele que não existe, em suma, não pode ser parte. A questão relativa à existência é, deste modo, logicamente anterior àquela relativa à capacidade de ser parte.

2. Identificação das partes

As partes precisam ser também individualmente determinadas e identificadas. Não se pode demandar, assim, em princípio⁶, contra um desconhecido, ou contra “aquele que deve dinheiro ao autor”. É necessário, em outras palavras, litigar contra alguém especificamente, e é também necessário que o autor se descreva e também ao réu para que ambos saibam contra quem exatamente litigam. Esta é uma decorrência da exigência que faz o disposto no art. 319, II, do CPC, segundo o qual a petição inicial deverá indicar “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”.

Esta exigência decompõe-se, com efeito, em duas. Se uma pessoa pretende cobrar uma dívida de que se entende credor, ela precisa cobrá-la especificamente de alguém e precisa ainda descrever este alguém de modo a que não seja possível confundi-lo com outra pessoa. Não basta ao autor, em outras palavras, dizer que deduz a demanda contra seu “devedor”. Ele precisa apresentar-se apropriadamente, para que o réu saiba contra quem litiga, e precisa também dizer que devedor é este, para evitar que ele venha a ser confundido com outra pessoa. Na dúvida, o juiz deve determinar ao autor, indicando precisamente qual informação deve ser complementada, que a esclareça (conforme art. 321 do CPC)⁷. Se não as tiver, o próprio autor pode, “na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção” (art. 319, § 1.º, CPC).

3. Partes desconhecidas ou não identificadas

Excepcionalmente, admite-se que se demande contra um desconhecido ou contra uma pessoa específica cuja identidade completa não se conhece. Suponha-se, por exemplo, que determinada pessoa se torne vítima de uma campanha difamatória anônima através da internet

(cyberbullying). O bully pode ser parte em uma demanda mediante a qual se pede a sua condenação a se abster, inclusive liminarmente, de postar comentários depreciativos contra o autor, ainda que não se tenha a menor ideia de quem se trata. A falta de identificação não tornaria inútil a decisão, porque terceiros podem dar cumprimento à decisão (por exemplo, através da suspensão do perfil anônimo do ofensor em uma rede social). Nada impede, naturalmente, que a identidade do desconhecido venha a ser revelada durante o processo.

Em *Bloomsbury Publishing Group Ltd v News Group Newspaper Ltd* [2003] WLR 1633, por exemplo, a High Court inglesa (Chancery Division) decidiu, acertadamente, que a identificação nominal do demandado pode ser dispensada quando a exigência de identificação puder causar grave prejuízo ao demandante e, ao mesmo tempo, quando a sua descrição for suficientemente detalhada de modo a deixar claro contra quem se litiga e contra quem não se litiga, mesmo que não se conheça sua identidade⁸. A causa dizia respeito à proteção dos direitos autorais da obra literária *Harry Potter* após o vazamento dos originais do livro antes de sua publicação e da tentativa de venda deles a órgãos da imprensa⁹.

A falta de identificação nominal pressupõe, deste modo, impossibilidade ou ao menos dificuldade considerável de se fazê-lo. É também o caso, por exemplo, da tutela possessória contra um invasor cuja identidade não se conhece e que, por razões óbvias, se recusa a revelá-la¹⁰. Basta ao autor descrevê-lo suficientemente na petição inicial ao pedir a reintegração judicial da posse, mesmo que não o qualifique conforme exige o art. 319, II, do CPC. É por este motivo que, segundo o art. 319, § 2.º, do CPC, “a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”. Também por isso, segundo o art. 319, § 3.º, do CPC, “a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.” Esta, aliás, é uma das utilidades do uso no processo – frequente no direito americano – de nomes fictícios (como Joe Doe ou Jane Doe)¹¹⁻¹². O que a Constituição brasileira não permite, no entanto, é o uso de pseudônimos ou de nomes de guerra (noms de guerre), de modo que uma das partes não saiba contra quem está litigando. O anonimato comprometeria gravemente o direito de defesa da parte contrária, mesmo que servisse para proteger a intimidade ou mesmo a segurança do autor.

4. Capacidade de ser parte

Capacidade de ser parte é a capacidade abstrata de ser sujeito de uma relação jurídica processual¹³. Diz-se abstrata porque esta capacidade decorre apenas dos atributos pessoais da parte, independentemente dos elementos concretos da demanda. Ou se é capaz de ser parte em qualquer processo, ou em nenhum¹⁴. Terá capacidade de ser parte todo aquele que tiver, nos termos da legislação civil, personalidade jurídica (capacidade de direito), que nada mais é do que a “aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres”¹⁵. Pessoa natural (ou física)¹⁶ ou moral (ou jurídica, de direito público ou privado)¹⁷. Mas os conceitos não se confundem. Nem todo aquele que detém capacidade de ser parte terá personalidade jurídica. Também terá capacidade de ser parte aquele que, embora sem personalidade, a lei disser que a tem (o art. 75 do CPC é a *sedes materiae*, embora seu rol não seja exaustivo)¹⁸. O Superior Tribunal de Justiça se refere à capacidade de ser parte, frequentemente, como personalidade judiciária¹⁹.

O nascituro, com efeito, não tem personalidade jurídica, mas tem capacidade de ser parte para pedir em juízo, ainda que representado por alguém, a tutela de um dos direitos que a lei lhe resguarda desde a concepção²⁰⁻²¹. Também, por exemplo, o condomínio, o espólio, os órgãos públicos²². Nada impediria que os animais, embora sem personalidade jurídica (concebível embora o reconhecimento de que animais possam ser titulares de direitos, faltar-lhes-á sempre a aptidão para contrair obrigações e para serem titulares de deveres; daí por que lhes faltar-á sempre personalidade jurídica)²³, possam ter também – como o condomínio ou o nascituro – capacidade de ser parte. Para tanto, todavia, é necessária a prévia autorização legal que ainda falta no ordenamento jurídico brasileiro.

5. Capacidade processual

Capacidade processual é a capacidade abstrata de conduzir o processo e de realizar atos processuais por si próprio ou através de um representante escolhido pelo próprio representado²⁴. Diz-se abstrata porque esta capacidade decorre apenas dos atributos pessoais da parte, independentemente dos elementos concretos da demanda²⁵. O art. 70 do CPC, segundo o qual “toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo”, vincula o conceito processual de capacidade processual ao conceito material de capacidade de fato (que não se confunde com a capacidade de direito, equivalente material do conceito processual de capacidade de ser parte)²⁶. Esta identificação, frequente no direito comparado²⁷, comporta exceções. O interditado, a quem falta em regra capacidade processual (art. 71, do CPC), por exemplo, terá excepcionalmente capacidade processual para pedir o levantamento da interdição (e apenas e especificamente para pedi-lo – art. 756, § 1.º, CPC)²⁸. Não são incapazes, no entanto, o réu preso revel e o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado (art. 72, II, do CPC)²⁹. Não lhes falta, a rigor, nada. A nomeação do curador é apenas um instrumento de proteção de alguém que se encontra em uma determinada situação de fragilidade, não necessariamente de incapacidade. Tanto que, com a constituição de advogado, cessa a necessidade de proteção. Como resume Pontes de Miranda, “nem todos os protegidos pela lei, em justiça, são incapazes”³⁰. Neste caso, a situação de fragilidade é de natureza processual, não um atributo pessoal da parte. O representante daquele a que falta capacidade processual, por fim, não se confunde com o representante da pessoa jurídica. A distinção será tratada nos comentários ao artigo 75.

6. Falta de capacidade de ser parte ou de capacidade processual

A capacidade de ser parte do demandante e do demandado é condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Sem ela, o processo deve ser extinto sem o julgamento de seu mérito (art. 485, IV, do CPC). Trata-se de um vício insanável. A capacidade processual, por seu turno, é requisito de validade dos atos processuais praticados pelas partes. Sua falta será sempre um vício sanável (art. 76 do CPC). A capacidade processual do demandante é também uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Sem sua correção, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito (art. 76, § 1.º, I, do CPC). A capacidade processual do demandado, no entanto, não será nunca condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. De sua falta decorre a revelia do demandado, nunca a extinção do processo (art. 76, II, do CPC). Para mais detalhes, confirmam-se os Comentários ao art. 76.

7. Distinção entre capacidade (de ser parte e processual) e legitimidade processual

Capacidade de ser parte e capacidade processual são qualidades que podem ser definidas como estáticas, no sentido de que sua verificação independe dos elementos concretos da demanda. A legitimidade processual, diferentemente, é uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito (art. 337, XI, do CPC) que se pode definir como dinâmica, porque depende das características específicas da pretensão processual concretamente deduzida³¹. Ela é, com efeito, o direito de conduzir em nome próprio, como demandante ou demandado, um determinado e concreto processo (Prozessführungsbefugnis)³². Em regra, a titularidade deste direito será daquele que alega ser também o titular do direito cuja tutela se pede (legitimidade ordinária); em outros casos, excepcionais, não (legitimidade extraordinária)³³. Embora toda pessoa tenha o direito de pedir em juízo a tutela de um direito que alega ser seu (legitimidade ordinária), apenas aquele a quem a lei ou o próprio titular do alegado direito lhe dá o poder de pedir sua tutela poderá fazê-lo (legitimidade extraordinária)³⁴⁻³⁵. Se determinada pessoa, conquanto processualmente capaz, pede a tutela de um alegado direito de que reconhece não ser o titular, o mérito de sua demanda não deverá ser julgado se lhe faltar legitimidade extraordinária. A pessoa processualmente incapaz, diferentemente, precisa ser representada ou assistida para que possa agir em juízo (art. 71 do CPC).

Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na

forma da lei.

Direito anterior – art. 8.º do CPC/1973.

Direito comparado – § 51 da ZPO alemã, art. 75 do CPC italiano, art. 7.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 10 do CPC português.

1. Representação e assistência

A capacidade processual, como se viu nos comentários ao artigo anterior, é um conceito, embora de natureza processual, que a lei expressamente vincula à legislação civil³⁶. Faltará capacidade processual, em outras palavras, a quem faltar capacidade de fato. Processualmente incapazes, portanto, serão aqueles que o Código Civil define como absolutamente ou relativamente incapazes, “sendo essencialmente de gradação, ou quantitativa, a diferença anunciada”³⁷. Os absolutamente incapazes serão representados em juízo, enquanto os relativamente incapazes serão apenas assistidos em juízo. A diferença entre representação e assistência consiste em que, no primeiro caso, a vontade do representado é manifestada por seu representante. No segundo, é o próprio assistido que manifesta sua vontade, que só se torna eficaz, no entanto, se consentir o assistente³⁸.

Segundo o art. 3.º do Código Civil, na redação que lhe foi dada em 2015, serão absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis anos. Já segundo o art. 4.º, com redação também de 2015, serão relativamente incapazes os “maiores de dezesseis e menores de dezoito anos” (I), os “ébrio habitual e os viciados em tóxico” (II), aqueles “que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (III) e os pródigos (IV). Os incisos que faziam referência aos que “por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido” e aos “excepcionais, sem desenvolvimento mental completo”, ao tratar da incapacidade absoluta, foram revogados pela reforma de 2015 (Lei 13.146/2015 – Estatuto da pessoa com deficiência – EPA)³⁹. As alterações são problemáticas. A lei, ao pretender de modo bem-intencionado embora desestigmatizar as pessoas que sofrem de doenças mentais⁴⁰, acabou inadvertidamente por retirar-lhes a proteção que a incapacidade absoluta lhes conferia⁴¹.

De todo modo, a exclusão da pessoa com deficiência do rol dos incapazes não eliminou a possibilidade de sua interdição com a nomeação de curador (art. 84 do EPA⁴²), na forma prevista nos arts. 747 e ss. do CPC, ainda que admissível apenas em caráter extraordinário (art. 84, § 3.º, do EPA⁴³). No que interessa ao direito processual, o deficiente precisará de seu curador para praticar atos em todo e qualquer processo, independentemente da natureza jurídica da pretensão nele deduzida. Esta regra vale para todo e qualquer processo, com efeito, mesmo à luz do que dispõe o art. 85 do EPA⁴⁴, porque seu escopo é a tutela de uma pessoa em estado de fragilidade. E se presume que o deficiente está em estado de fragilidade se tiver de agir em juízo, em razão da complexidade inerente a todo litígio judicial, realidade esta que mesmo as boas intenções do legislador não conseguem ignorar. Esta exigência não impede o curatelado, em todo caso, de pedir em nome próprio o suprimimento judicial da vontade de seu curador quando estiver em conflito com ele, ou mesmo a sua remoção. Dificuldade semelhante ocorre em relação a certos casos de assistência. Como aquele que não pode exprimir sua vontade (uma pessoa em coma, por exemplo) deve ser assistido, por caso de incapacidade relativa (art. 4.º, III, do CC)⁴⁵, se a assistência pressupõe exatamente a manifestação de vontade do assistido (manifestação esta com a qual o assistente apenas deve concordar, ou não)⁴⁶? Caberá à doutrina e à jurisprudência aparar estas arestas⁴⁷.

Quando relativa à incapacidade, é preciso analisar, caso a caso, se ela atinge a prática de atos processuais e se necessária, além dela, expressa autorização judicial para sua realização. Os pródigos, por exemplo, estão sujeitos à curatela (art. 1.767, V, do CC). Não é caso de representação, mas de assistência, porque o prodígio é apenas relativamente incapaz (art. 4.º do CC). Mas como a interdição do prodígio não lhe priva de toda capacidade de fato é preciso verificar se a prática de atos processuais encontra-se ou não abrangida pela restrição. E está, com fundamento no disposto no art. 1.782 do CC, segundo o qual “a interdição do prodígio só o privará de, sem curador,

emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração”. O pródigo precisa da assistência de seu curador para manifestar eficazmente sua vontade no processo, e esta assistência é necessária para cada ato que a lei processual exige que seja pessoalmente praticado. Uma vez outorgada procuração a um advogado, ele não precisará de nova concordância do curador para realizar atos que a procuração lhe permite fazer.

Mas há um complicador. O curador, ao contrário do que acontece com os pais, depende de expressa autorização judicial para assistir ao curatelado a “propor em juízo as ações, ou nelas assistir o menor, e promover todas as diligências a bem deste, assim como defendê-lo nos pleitos contra ele movidos” (art. 1.748, V, do CC)⁴⁸. A exigência de autorização judicial não se renova, no entanto, a cada ato processual que o assistido deve praticar. Basta uma única autorização para litigar nesta demanda específica, como demandante ou demandado (não se admite a autorização genérica para litigar em qualquer processo). Uma vez outorgado poderes para um advogado, com a assistência do curador, a prática por ele de atos processuais independe de qualquer nova autorização⁴⁹. A falta de autorização, de todo modo, é sanável (art. 1.748, parágrafo único⁵⁰, do CC).

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I – incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II – réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Direito anterior – art. 9.º do CPC/1973.

Direito comparado – § 57 da ZPO alemã, art. 78 do CPC italiano, art. 8.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 11 do CPC português.

1. Função da curatela especial

A curatela especial é um instituto de natureza puramente processual (daí por que ela se chama também curatela ad litem), que serve à proteção em um determinado processo de pessoas em situação de fragilidade. Esta fragilidade pode ser tanto de natureza material, quando se tratar de pessoas incapazes, absoluta ou relativamente, à luz do direito civil (por exemplo, o menor de dezesesseis anos), quanto de natureza processual (por exemplo, o réu revel citado por edital ou com hora certa. Embora plenamente capaz, à luz do direito civil, a citação ficta deixa-o em situação de fragilidade no processo). Como diz Pontes de Miranda, com efeito, “nem todos os protegidos pela lei, em justiça, são incapazes”⁵¹. Também o art. 245 do CPC, ao disciplinar o incidente inicial de insanidade do citando, estabelece hipótese em que é necessária a nomeação de curador ad litem para a representação processual do citando⁵².

2. Natureza jurídica do curador especial

O curador especial não se torna, para os fins do disposto na legislação civil, curador do incapaz (inciso I), do réu preso revel (inciso II) ou do réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado (inciso III), nem tampouco do citando sem condições físicas ou psíquicas de receber a citação (art. 245)⁵³. Os poderes do curador especial restringem-se à prática de atos processuais naquele processo específico em que ele foi nomeado. Enquanto durar a situação de fragilidade, a curatela especial continua. Ela cessará, na hipótese do inciso I, se cessar a causa da incapacidade (por exemplo, com a maioridade), e com a constituição de advogado pela própria parte, na hipótese do inciso II. A curatela especial deve ser exercida, como quer explicitamente a lei, preferencialmente pela Defensoria Pública⁵⁴. A nomeação de advogado dativo é excepcional⁵⁵ e a de pessoa sem formação jurídica ainda mais⁵⁶. Nesse último caso, o curador

deve constituir advogado⁵⁷. Com sua nomeação, por fim, o curador torna-se um *representante* da parte, não seu substituto processual.⁵⁸

3. Particularidades do processo quando ocorrer a nomeação de curador especial

Não incidem os efeitos da revelia, embora esta hipótese não conste do rol do art. 345 do CPC, “quando oferecida contestação pelo curador especial do revel citado por edital ou com hora certa”⁵⁹. Ao curador especial se dispensa na contestação, ainda, o ônus da impugnação específica (art. 341, parágrafo único, do CPC). Sua função é de defender o demandado em situação de fragilidade. Por isso não se lhe permite reconvir⁶⁰ - ⁶¹ ou reconhecer a procedência dos pedidos.⁶² Não tem ele, todavia, o “dever de recorrer”⁶³. A nomeação de curador especial não torna desnecessária a intervenção do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, quando o processo envolver “interesse de incapaz” (art. 178, II, do CPC). Incapaz, nesta acepção, é o incapaz, absoluta ou relativamente, à luz da legislação civil. Com isto se quer dizer que, embora se encontre em situação de fragilidade no processo o réu preso revel, esta situação não justifica por si só a intervenção do Ministério Público porque ele não é, do ponto de vista do direito material, incapaz.

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§ 1.º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação:

I – que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens;

II – resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;

III – fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família;

IV – que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.

§ 2.º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composses ou de ato por ambos praticado.

§ 3.º Aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos.

Direito anterior – art. 10 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 7.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 18 do CPC português (dispositivo revogado em 1996).

1. Patrimônio comum e as limitações materiais impostas aos cônjuges

O casamento, salvo quando no regime da separação absoluta de bens⁶⁴, tem por efeito patrimonial a formação de uma massa patrimonial comum (Gesamtgut)⁶⁵ - ⁶⁶ cuja administração incumbe aos cônjuges em absoluta igualdade⁶⁷. Por este motivo, proíbe-se que um deles realize, sem a autorização do outro, determinados atos que a lei considera potencialmente danosos a este patrimônio comum (art. 1.647 do CC)⁶⁸. Por exemplo, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis e prestar fiança ou aval⁶⁹. A falta da outorga conjugal – uxória (da mulher) ou marital (do marido)⁷⁰ – torna o negócio jurídico, assim, anulável (art. 1.649 do CC)⁷¹. Esta autorização, que pode ser dada mesmo após a celebração⁷², pode ser suprida também judicialmente “quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível concedê-la” (art. 1.648 do CC)⁷³.

No que interessa ao processo, o art. 1.647 do CC, ao se referir ao inciso anterior⁷⁴, proíbe também o cônjuge de “pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos”. O art. 73 do

Código de Processo Civil serve, exatamente, para concretizar no processo esta limitação imposta pelo direito material.

2. Cônjuge como demandante e outorga conjugal: caso de legitimidade ativa extraordinária

A plena igualdade no casamento entre marido e mulher é uma conquista relativamente recente. Em sua redação original, o art. 6.º, II, do CC/1916 definia como relativamente incapaz a mulher casada, enquanto subsistisse a sociedade conjugal. O marido, por seu turno, era entendido como o “chefe da sociedade conjugal” (art. 233 do CC/1916)⁷⁵. Cabia apenas a ele “a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir administrar, em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto, antenupcial” (art. 233, II, do CC/1916). Para a prática de certos atos, no entanto, a lei exigia o consentimento da mulher (outorga uxória), entre eles “alienar, hipotecar ou gravar de ônus real os bens imóveis, ou seus direitos reais sobre imóveis alheios” e “pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens e direitos” (art. 235, I e II, do CC/1916). Esta a explicação histórica por que a doutrina, tradicionalmente, costuma tratar a exigência de outorga conjugal no contexto da capacidade do cônjuge demandante⁷⁶.

Capacidade processual, no entanto, ou se tem ou não se tem. Ela decorre apenas dos atributos pessoais da parte, independentemente dos elementos concretos da demanda⁷⁷. Daí por que não é possível tê-la para certos processos e não para outros. Por isso também não é possível integrá-la. A exigência de outorga conjugal não diz respeito, deste modo, à capacidade, material ou processual, do cônjuge demandante⁷⁸, mas sim à sua legitimidade (processual) para pedir em juízo a tutela de um direito do qual ele não é o único titular⁷⁹.

O cônjuge pode fazer com seus bens, sem a autorização do outro, tudo aquilo que a lei não veda expressamente (art. 1.642 do CC), mesmo quando o resultado de algum destes atos possa vir a comprometer o patrimônio comum (nas hipóteses, obviamente, em que o regime de bens ocasionar a constituição de um patrimônio comum). Um dos atos em que a lei exige expressamente a autorização do cônjuge é o de “propor ação que verse sobre direito real imobiliário”. Não se exige, com efeito, que o cônjuge cuja autorização é necessária participe do processo como litisconsorte ativo (por isso não se trata de hipótese de litisconsórcio ativo necessário, diferentemente, como se verá mais adiante, do que ocorre quando se tratar de composses). Anuir ao ajuizamento da demanda não equivale, evidentemente, a codemandar. Não que o cônjuge não possa fazê-lo. Mas aí será um litisconsórcio ativo facultativo, não necessário⁸⁰. Indispensável será apenas o seu consentimento: a autorização para que seu esposo peça em juízo a tutela de um direito sobre o qual ele, em razão da existência de um patrimônio comum, tem também interesse jurídico. A lei não estabelece forma específica para a prestação do consentimento⁸¹. Esta exigência, todavia, não atinge as ações que versem sobre bens particulares do demandante, porque aí faltará ao seu cônjuge interesse jurídico em dar o seu consentimento. A lógica da exigência, que não faria sentido se aplicada aos bens particulares, é justamente a de que ela “decorre da necessidade de garantir a ambos os cônjuges meio de controle da gestão patrimonial, tendo em vista que, em eventual dissolução do vínculo matrimonial, os consortes terão interesse na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento”^{82 - 83}. Normas que restringem direitos (entre eles o de demandar) devem ser interpretadas restritivamente.

Legitimidade processual, como se viu nos comentários ao artigo 70, é o direito de conduzir em nome próprio, como demandante ou demandado, um determinado e concreto processo (Prozessführungsbefugnis)⁸⁴. Em regra, a titularidade deste direito será daquele que alega ser também o titular do direito cuja tutela se pede (legitimidade ordinária); em outros casos, excepcionais, não (legitimidade extraordinária)⁸⁵. Embora toda pessoa tenha o direito de pedir em juízo a tutela de um direito que alega ser seu (legitimidade ordinária), apenas aquele a quem a lei ou o próprio titular do alegado direito lhe dá o poder de pedir sua tutela poderá fazê-lo (legitimidade extraordinária)^{86 - 87}. A outorga conjugal é justamente a autorização necessária para que alguém peça em juízo a tutela de um direito que não é apenas seu numa hipótese em que a lei, expressamente, exige esta autorização (legitimidade ativa extraordinária). Sem esta autorização, o

processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, exatamente por faltar uma das condições de admissibilidade do julgamento do mérito⁸⁸⁻⁸⁹.

O termo separação absoluta, que repete neste particular o texto do Código Civil, deve ser interpretado apenas no sentido de englobar a separação convencional, não a separação obrigatória. Isso porque, como entendeu com razão o Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses de casamento sob o regime da separação legal, os consortes, por força da Súmula 377/STF, possuem o interesse pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento, razão por que é de rigor garantir-lhes o mecanismo de controle de outorga uxória/marital para os negócios jurídicos previstos no art. 1647 da lei civil”⁹⁰⁻⁹¹. O raciocínio, desenvolvido embora à luz do direito material, vale também no plano processual. Com isto se quer dizer, em outras palavras, que a outorga conjugal não é necessária quando casados os esposos no regime da separação obrigatória de bens⁹²⁻⁹³. Sempre que existirem bens comuns, e em relação a estes bens comuns e apenas a eles, o consentimento é indispensável.

O consentimento do cônjuge será necessário, nos termos do caput do art. 73, quando a demanda versar “sobre direito real imobiliário”. Direito real, com abstração das vivas discussões doutrinárias sobre sua natureza⁹⁴, é o direito que a lei define, taxativamente, como real (Typenzwang)⁹⁵⁻⁹⁶. O art. 1.225 do CC é a sedes materiae⁹⁷. Direito real imobiliário é o direito real que incide sobre bem imóvel, não sobre bem móvel⁹⁸. A exigência de consentimento é necessária independentemente se este direito incide sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. Versam sobre direitos reais imobiliários, por exemplo, as ações demolitória e de nunciação de obra nova⁹⁹. Também a ação divisória (actio communi dividundo), cuja finalidade é justamente a divisão da coisa comum e, assim, a extinção da copropriedade (isso, obviamente, apenas quando se tratar de bem imóvel)¹⁰⁰. Mas não a ação de despejo, porque a locação é um direito pessoal sobre o bem¹⁰¹, nem tampouco a imissão na posse, “que não é ação fundada em direito real e nem possessória, mesmo sendo uma ação real”¹⁰².

3. Cônjuges como litisconsortes passivos necessários

O parágrafo primeiro do art. 73, ao dispor que “ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação” nas hipóteses de que tratam os seus incisos, estabelece casos de litisconsórcio passivo necessário entre eles¹⁰³. As consequências processuais desta falta – inclusive a possibilidade de suprimimento judicial – são tratadas nos comentários ao próximo artigo.

Segundo o inciso I, o litisconsórcio passivo é necessário quando a ação versar “sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens”. A disposição repete aquela constante do caput sobre a necessidade de consentimento do cônjuge para que o outro proponha a demanda. Direito real, como já se explicou no item anterior dos comentários a este artigo, é o direito que a lei define, taxativamente, como real (Typenzwang)¹⁰⁴⁻¹⁰⁵. Direito real imobiliário é o direito real que incide sobre bem imóvel, não sobre bem móvel¹⁰⁶. O litisconsórcio é necessário independentemente se este direito incide sobre coisa própria ou sobre coisa alheia. Versam sobre direitos reais imobiliários, por exemplo, as ações demolitória e de nunciação de obra nova¹⁰⁷. Também a ação divisória (actio communi dividundo), cuja finalidade é justamente a divisão da coisa comum e, assim, a extinção da copropriedade (isso, obviamente, apenas quando se tratar de bem imóvel)¹⁰⁸. Mas não a ação de despejo, porque a locação é um direito pessoal sobre o bem¹⁰⁹, nem tampouco a imissão na posse, “que não é ação fundada em direito real e nem possessória, mesmo sendo uma ação real”¹¹⁰. O termo separação absoluta, como também já se explicou com mais detalhes no item anterior, deve ser interpretado apenas no sentido de englobar a separação convencional, não a separação obrigatória¹¹¹. Sempre que existirem bens comuns, e em demandas que versarem sobre direitos reais imobiliários relativos a estes bens comuns e apenas a eles, o litisconsórcio passivo entre os cônjuges é necessário.

Segundo o inciso II, repete-se a exigência quando a ação for “resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles”. O legislador brasileiro andou mal em repetir no CPC de 2015 a mesma expressão, vaga e imprecisa, empregada no CPC/1973 em seu

art. 10, II. Distinguir teoricamente as duas partes do dispositivo é difícil, e o resultado pode revelar-se insatisfatório¹¹²⁻¹¹³. A jurisprudência sobre o tema é escassa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, entendeu, em 1987, que a circunstância de que ambos os cônjuges o celebraram em conjunto faz incidir a exigência quando a demanda tiver por fundamento o cumprimento de um contrato¹¹⁴. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, em 2004, que “tendo em vista que o contrato de financiamento habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) foi assinado pelo apelante e por sua mulher, há litisconsórcio necessário por disposição de lei e pela natureza da relação jurídica, uma vez que se verifica hipótese prevista no art. 10, § 1.º, II, do CPC, ou seja, de ação resultante de fatos que digam respeito a ambos os cônjuges ou de atos praticados por eles”¹¹⁵.

Um esboço de distinção, sem a pretensão de apresentar-se como definitivo, poderia consistir em associar a responsabilidade civil dos cônjuges, independentemente da existência de patrimônio comum e do regime de bens, às duas partes do inciso II. Ação “resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges” corresponderia às demandas nas quais se deduz contra os cônjuges pretensão fundada na sua responsabilidade extracontratual indireta, por fatos que eles não praticaram (por exemplo, a responsabilidade dos pais por danos causados por seus filhos¹¹⁶). Já a pretensão decorrente “de ato praticado por eles” equivaleria à responsabilidade extracontratual por ato praticado pelos próprios cônjuges em conjunto (por exemplo, o dano moral causado a um vizinho pela difusão de boatos sobre sua vida privada) e à responsabilidade contratual fundada em negócios jurídicos de que ambos são partes (por exemplo, o contrato de financiamento imobiliário de que tratou o precedente do TRF2). Em todos estes casos não se deveria exigir, em princípio, o litisconsórcio necessário. Mas o disposto no art. 73, § 1.º, II, torna este litisconsórcio, excepcionalmente, necessário. A vítima de um dano causado por uma criança não deveria ser obrigada, necessariamente, a litigar contra ambos os pais. Ao menos à luz do direito material. A necessidade, no entanto, é processualmente imposta pelo disposto no art. 73, § 1.º, II. Suponha-se ainda que determinado contrato estipule solidariedade passiva entre os cônjuges, bastaria ao credor à luz do direito civil, se assim preferisse, demandar contra apenas um dos devedores solidários¹¹⁷. Mas deve fazê-lo contra os dois, por força da regra processual aplicável¹¹⁸.

O inciso III, por seu turno, trata da ação “fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família”. Esta regra, que independe também do regime de bens escolhido, deriva do disposto nos arts. 1.643 e 1.644 do CC. Segundo estes dispositivos, permite-se a um cônjuge (qualquer deles, não apenas o marido, porque não incumbe mais apenas a ele a administração dos bens da família) “comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica” (art. 1.643, I, do CC) e “obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir” (art. 1.643, II, do CC). Nestes dois casos, as dívidas contraídas “obrigam solidariamente ambos os cônjuges” (art. 1.643, I, do CC). A solidariedade, do mesmo modo como se passa nas hipóteses do art. 73, § 1.º, II do CPC, não exime o credor de demandar contra ambos os cônjuges. Trata-se de uma exceção processual à regra material segundo a qual o credor pode litigar contra apenas um dos devedores solidários. Não é toda dívida contraída por um cônjuge, no entanto, que torna necessário o litisconsórcio, mas apenas aquela contraída a bem da família. Ocorre que a expressão “a bem da família” é mais ampla do que “coisas necessárias à economia doméstica”. Nem toda despesa realizada “a bem da família”, com efeito, pode ser considerada como dizendo respeito a “coisas necessárias à economia doméstica”. É o caso, por exemplo, de despesas suntuárias ou supérfluas¹¹⁹. Esta diferença acaba por criar um descompasso entre as normas material e processual aplicáveis. Com isto se quer dizer, em síntese, que o conceito processual de “a bem da família” deve prevalecer na solução da questão processual relativa à necessidade do litisconsórcio, sem vincular o juiz quanto ao direito material aplicável ao julgamento do mérito.

Já o inciso IV, por fim, alude à ação “que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges”. A hipótese é diversa daquela prevista no inciso II (demanda que verse sobre direito real imobiliário) porque ônus real não é um direito real¹²⁰. Como resume Pontes de Miranda, “o ônus real é direito de crédito que coincide em direito a prestações ligadas ao bem, semelhantemente – identicamente – ao direito hipotecário. Semelhança não é identidade (...). Não há direito real de garantia nos ônus reais (...). O ônus real não é real como os direitos reais limitados: também grava o bem, mas apenas porque se liga à

titularidade da propriedade ou dos direitos reais limitados ou da posse, para que dificilmente possam ser frustrados os adimplementos (= para que mais facilmente e eficientemente se executem as dívidas)”¹²¹ -¹²² . Esta regra incide independentemente do regime de bens aplicável, porque o dispositivo não excetua, como faz no inciso I, o caso de separação absoluta¹²³ . Exemplo de ônus real são os encargos condominiais¹²⁴ .

4. Cônjuges e as ações possessórias

Segundo o § 2.º, “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composses ou de ato por ambos praticado”. A referência expressa à posse é salutar, a fim de evitar a contaminação da maneira como o dispositivo é interpretado pelas intermináveis querelas doutrinárias sobre a natureza jurídica da posse (se um fato ou se um direito; se direito, um direito real ou pessoal)¹²⁵ -¹²⁶ . Não é relevante, assim, no que interessa à participação do cônjuge, se a posse estaria ou não englobada na expressão “sobre direito real imobiliário” de que trata o caput. E isso, em síntese, porque há dispositivo específico que trata dela.

O art. 73 trata a tutela possessória de modo diverso do que trata as ações que versem “sobre direito real imobiliário”. Quanto a elas, exige-se o “consentimento do outro para propor ação”. O parágrafo segundo deste artigo não fala, no entanto, de consentimento, mas sim de participação. Participar é mais do que consentir. Participar significa tornar-se litisconsorte ativo do seu cônjuge, quando ele demandar, ou seu litisconsorte passivo, quando ele for demandado¹²⁷ . Daí por que, nas ações possessórias imobiliárias (a restrição decorre de uma interpretação sistemática do art. 73, cuja ratio é a tutela do patrimônio imobiliário comum do casal), os esposos devem litigar conjuntamente, em litisconsórcio ativo ou passivo necessário¹²⁸ .

Haverá composses sempre que, em razão do regime de bens vigente, o imóvel possuído integrar o patrimônio comum do casal¹²⁹ . Se não integrar, é necessário investigar a origem e a natureza da posse para se saber se ambos a possuem em conjunto. Um cônjuge, por exemplo, pode dar a outro em comodato a posse de um imóvel que não integra o patrimônio comum (não haverá, assim, composses). Mas ambos podem ter recebido em comodato a posse do imóvel de um terceiro (aí haverá composses). O “ato por ambos praticado”, por seu turno, diz respeito às hipóteses em que os cônjuges, em conjunto, praticam atos de turbação, de ameaça de turbação ou de esbulho.

5. União estável e necessidade de outorga conjugal

Segundo o § 3.º, “aplica-se o disposto neste artigo à união estável comprovada nos autos”. A aplicação deste dispositivo exige, entretanto, cuidado, de modo a não se tornar excessivamente gravosa para o terceiro contra quem um dos companheiros litiga. Facultativo o registro da união estável, com efeito, como seria possível a este terceiro saber de sua existência e, assim, por exemplo, demandar também contra o companheiro? Daí por que, para se beneficiarem da proteção legal que lhes confere a legislação processual, devem os companheiros registrar a união estável de modo a lhe dar a necessária publicidade (publicidade análoga a que se dá ao casamento). O registro, com efeito, não deixa de ser facultativo, do ponto de vista do direito material. São apenas os seus efeitos processuais que dependem da publicidade que decorre do registro¹³⁰ -¹³¹ .

Art. 74. O consentimento previsto no art. 73 pode ser suprido judicialmente quando for negado por um dos cônjuges sem justo motivo, ou quando lhe seja impossível concedê-lo.

Parágrafo único. A falta de consentimento, quando necessário e não suprido pelo juiz, invalida o processo.

Direito anterior – art. 11 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 7.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 19 do CPC português (dispositivo revogado em 1996).

1. Justo motivo ou impossibilidade

A exigência de consentimento para que um cônjuge possa propor uma demanda que verse sobre direito real imobiliário é um autêntico direito de seu esposo que serve para proteger o patrimônio imobiliário comum de aventuras judiciais capitaneadas por um sem a autorização do outro. Como direito que é, esta exigência não pode ser exercida por seu titular de modo abusivo. Se lhe faltar justo motivo, admite-se seu suprimento judicial. A recusa será justificada quando temerária, frívola ou manifestamente infundada a demanda¹³² (por exemplo, quando o valor da causa for elevado e as chances de êxito parecerem remotas; neste caso, os riscos da sucumbência ameaçam a integridade do patrimônio comum). O suprimento judicial é também admissível quando o cônjuge estiver por qualquer motivo legítimo impossibilitado de dar seu consentimento (gravemente doente, por exemplo).

2. Procedimento autônomo de jurisdição voluntária ou questão incidental

O pedido de suprimento judicial do consentimento deverá ser formulado, em regra, em procedimento próprio de jurisdição voluntária. Não existindo procedimento típico, aplicam-se as regras gerais constantes do art. 719 e ss. do CPC¹³³. O cônjuge que se recusa a dar seu consentimento deve ser citado na qualidade de interessado para, em 15 dias, manifestar-se sobre o pedido (art. 721, CPC). Admite-se a concessão de tutela de urgência¹³⁴. O pedido deve ser deferido se o juiz se convencer de que injusta a recusa (recusa sem justo motivo), questão cuja solução dependerá, na maioria dos casos, do resultado da instrução probatória¹³⁵. A situação é um pouco diversa, no entanto, quando o cônjuge estiver impossibilitado de dar o seu consentimento. Nesta hipótese, o suprimento judicial pode ser dado no processo da própria demanda para cujo ajuizamento ele é necessário mesmo quando o juízo não for materialmente competente para decidir sobre o pedido se ele tivesse sido deduzido em caráter principal. Nada proíbe o interessado, obviamente, de se valer do processo autônomo de jurisdição voluntária, se assim preferir. Mas é razoável e fiel à exigência de economia processual permitir o julgamento incidental da questão quando ele não envolver alta indagação (ou seja, quando não depender de instrução probatória que possa vir a comprometer a fluidez do processo)¹³⁶.

3. Consentimento como condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda

O consentimento do cônjuge é uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito, não um requisito de validade do processo (como inadvertidamente sugere a redação do parágrafo único). Se ele faltar, e não vier a ser suprido judicialmente, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, V, do CPC. Faltará ao demandante, neste caso, legitimidade para pedir, em nome próprio, a tutela de direito que não é apenas seu (o bem que integra o patrimônio comum do casal – Gesamtgut – pertence a ambos, como se viu nos comentários ao art. 73), numa hipótese em que a lei, expressamente, exige a autorização de seu cônjuge. Faltar-lhe-á, em outras palavras, legitimidade ativa extraordinária.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

- I – a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;
- II – o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;
- III – o Município, por seu prefeito ou procurador;
- IV – a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar;
- V – a massa falida, pelo administrador judicial;
- VI – a herança jacente ou vacante, por seu curador;
- VII – o espólio, pelo inventariante;

VIII – a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;

X – a pessoa jurídica estrangeira, pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil;

XI – o condomínio, pelo administrador ou síndico.

§ 1.º Quando o inventariante for dativo, os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte.

§ 2.º A sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada.

§ 3.º O gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo.

§ 4.º Os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias.

Direito anterior – art. 12 do CPC/1973.

Direito comparado – § 51 da ZPO alemã, art. 75 do CPC italiano, art. 7.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e arts. 20 a 22 do CPC português.

1. Capacidade de ser parte

Capacidade de ser parte¹³⁷, como se viu nos comentários ao art. 70, é a capacidade abstrata de ser sujeito de uma relação jurídica processual¹³⁸. Diz-se abstrata porque esta capacidade decorre apenas dos atributos pessoais da parte, independentemente dos elementos concretos da demanda. Ou se é capaz de ser parte em qualquer processo, ou em nenhum¹³⁹. Terá capacidade de ser parte todo aquele que tiver, nos termos da legislação civil, personalidade jurídica (capacidade de direito), que nada mais é do que a “aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres”¹⁴⁰. Mas os conceitos não se confundem. Nem todo aquele que detém capacidade de ser parte terá personalidade jurídica. Também terá capacidade de ser parte aquele que, embora sem personalidade, a lei disser que a tem¹⁴¹. Esta é, deste modo, a primeira função exercida pelo art. 75: atribuir capacidade de ser parte, sem embora pretender fazê-lo de modo exaustivo, a certos entes não dotados de personalidade jurídica (por exemplo, o condomínio ou o espólio).

2. Representação e apresentação

A segunda função exercida pelo artigo 75 é esclarecer (também sem a pretensão de fazê-lo taxativamente) quem exatamente deve representar ou apresentar em juízo os entes a que a lei reconhece a capacidade de ser parte¹⁴². Em alguns casos, ocorrerá representação (quando uma pessoa recebe poderes – da lei ou do próprio representado – para agir em juízo em nome de outra¹⁴³). Em outros, apresentação, que ocorre quando alguém é autorizado a “estar presente para dar presença à entidade de que é órgão”¹⁴⁴.

3. Poder público em juízo, estados estrangeiros e organismos internacionais

A administração pública, em todos os níveis (federal, estadual ou municipal), é constituída de “órgãos a serviço do Estado, na gestão de bens e interesses qualificados da comunidade”¹⁴⁵. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias, as empresas públicas, as

sociedades de economia mista e as fundações governamentais, por serem dotados de personalidade jurídica, têm também capacidade de ser parte¹⁴⁶. Mas também a certos órgãos públicos, ainda que não dotados de personalidade, pode ser excepcionalmente reconhecida a capacidade de ser parte. O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, já reconheceu à sua Corte Especial¹⁴⁷, à Câmara dos Deputados¹⁴⁸, às assembleias estaduais¹⁴⁹ e às câmaras municipais¹⁵⁰ a capacidade de se parte. Segundo definido pela Corte em julgamento repetitivo, no entanto, a capacidade de ser parte vem acompanhada de uma restrição parcial à legitimidade processual (não à capacidade, porque capacidade ou se tem ou não se tem)¹⁵¹: o órgão “somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, à autonomia e independência do órgão. Para se aferir a legitimação ativa dos órgãos legislativos, é necessário qualificar a pretensão em análise para se concluir se está, ou não, relacionada a interesses e prerrogativas institucionais”¹⁵². Também o Estado estrangeiro, mesmo o não reconhecido¹⁵³, e os organismos internacionais, têm capacidade de ser parte. O art. 109, II, da CF, ao atribuir competência à Justiça Federal para julgar “as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País”, concretiza esta regra geral que deriva do direito internacional público.

A União deve ser apresentada em juízo pela Advocacia-Geral da União (AGU), conforme expresse mandamento constitucional (art. 131, caput)¹⁵⁴. Diz-se apresentada, com efeito, não representada, porque “a Procuradoria Judicial e seus procuradores constituem um órgão da Fazenda Pública”¹⁵⁵. Então, o advogado público quando atua perante os órgãos do Poder Judiciário é a Fazenda pública presente em juízo¹⁵⁶. A esta regra, reproduzida ainda no art. 1.º da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União (LOAGU), dá cumprimento o art. 75, I, do CPC¹⁵⁷. O parágrafo 3.º do art. 131 da Constituição excetua apenas a execução da dívida ativa de natureza tributária. Neste caso, a apresentação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). O art. 12 da LOAGU vai além, atribuindo à PGFN competência para apresentar a União “nas causas de natureza fiscal”¹⁵⁸. A competência da AGU, no entanto, não lhe é privativa: “mesmo institucionalizada a Advocacia Pública, isso não exclui a possibilidade de o Estado constituir mandatário ad judicia para causas específicas”¹⁵⁹. Mas a questão é controversa¹⁶⁰ e será mais detalhadamente debatida nos comentários ao artigo 182.

Nos estados e no Distrito Federal, a apresentação judicial é de competência das respectivas procuradorias, conforme exige o artigo 132 da Constituição¹⁶¹. É também controverso se aos estados se permite a contratação de advogados¹⁶². Os municípios serão apresentados por seus procuradores (independentemente de mandato¹⁶³), ou pelo próprio prefeito, desde que ele esteja regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil¹⁶⁴. O Superior Tribunal de Justiça permite a contratação de advogados pelos municípios, mediante inexigibilidade de licitação¹⁶⁵. Neste caso, o mandato é indispensável¹⁶⁶.

As autarquias e as fundações públicas de direito público deverão ser apresentadas “por quem a lei do ente federado designar”. Em regra, por seus respectivos procuradores autárquicos ou fundacionais. Mas também é possível, especialmente nos estados e nos municípios, que a apresentação delas seja atribuída aos respectivos procuradores do estado ou do município (no âmbito da União, apenas excepcionalmente)¹⁶⁷. Nos estados e no Distrito Federal, é também controverso se as autarquias e fundações autárquicas podem ser representadas por advogados¹⁶⁸. Se a lei, por qualquer motivo, não fizer a designação, a apresentação incumbe “ao dirigente máximo”¹⁶⁹. Empresas públicas, sociedades de economia mista¹⁷⁰ e fundações públicas de direito privado¹⁷¹, no entanto, não são apresentadas em juízo por procuradores, mas representadas por advogados (ainda que de seu próprio quadro de funcionários). Nestes casos, a exibição da procuração é indispensável¹⁷².

O estado estrangeiro, por fim, deve ser apresentado em juízo pelo chefe de sua missão diplomática no país, nos termos do art. 3.º, a e b, da Convenção de Viena, de 1961¹⁷³, nunca por um de seus cônsules¹⁷⁴. Os organismos internacionais, por seu turno, devem ser apresentados conforme os seus estatutos, salvo quando o Brasil tiver assumido a obrigação de fazê-lo. É o caso, por exemplo, dos organismos ligados à Organização das Nações Unidas. Nesta hipótese, a apresentação

incumbe à Advocacia-Geral da União¹⁷⁵.

4. Entes despersonalizados

Massa falida, massa do devedor insolvente, herança jacente ou vacante, espólio, condomínio, sociedade e associação irregulares são entes sem personalidade jurídica a que a lei atribui expressamente a capacidade de ser parte, definindo também quem deve representá-los em juízo. A enumeração, no entanto, não é taxativa. O inciso IX, com efeito, anda melhor do que o art. 12 do CPC/1973, ao aludir textualmente a “outros entes organizados sem personalidade jurídica”. A inovação é boa, porque não deixa dúvidas de que o rol constante deste artigo de entes despersonalizados a que se reconhece capacidade é apenas exemplificativo. O consórcio, por exemplo, “constituído sob o regime da Lei 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (art. 278, § 1.º, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do art. 12, VII, do CPC”¹⁷⁶. Se poderia haver alguma dúvida antes, não há mais na vigência do CPC de 2015.

A massa falida deve ser representada em juízo pelo administrador judicial (art. 22, III, n, da Lei 11.101/2005). Na recuperação judicial, porém, a empresa continua a ser apresentada conforme seus atos constitutivos, desde que não ocorra a destituição de seus administradores (art. 64 da Lei 11.101/2005). Destituídos os administradores, a representação judicial da empresa deverá ser transferida para um gestor judicial, “que assumirá a administração das atividades do devedor” (art. 65 da Lei 11.101/2005), com a ressalva de que, nos atos relativos ao próprio processo de recuperação judicial, “a sociedade devedora continuará sendo representada nos termos de seus atos constitutivos”¹⁷⁷. No intervalo de tempo entre a destituição dos administradores e a nomeação do gestor, a representação judicial caberá ao administrador judicial (art. 65, § 1.º, da Lei 11.101/2005)¹⁷⁸. A massa de bens do devedor civil insolvente, no mesmo sentido, deve ser representada em juízo por um administrador da massa, a quem incumbe, segundo o art. 766, II, do CPC/1973, aplicável por força do disposto no art. 1.052 do CPC, “representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial”¹⁷⁹.

Segundo o art. 1.819 do CC, “falecendo alguém sem deixar testamento nem herdeiro legítimo notoriamente conhecido, os bens da herança, depois de arrecadados, ficarão sob a guarda e administração de um curador, até a sua entrega ao sucessor devidamente habilitado ou à declaração de sua vacância”. Herança jacente, deste modo, é a herança à espera de um herdeiro¹⁸⁰, ao passo que vacante é aquela para a qual se reconhece não haver herdeiro¹⁸¹. Em ambos os casos, sua representação judicial será feita pelo curador de que trata o art. 739 do CPC, segundo o qual, em seu parágrafo primeiro, incumbe ao curador “representar a herança em juízo ou fora dele, com intervenção do Ministério Público”. Estas disposições aplicam-se também, analogicamente, ao curador de bens dos ausentes (art. 744 do CPC)¹⁸². Se o curador, por fim, “não é advogado inscrito na respectiva Ordem, deverá contratar um profissional com esses requisitos, a quem conferirá poderes para praticar pessoalmente os atos processuais”¹⁸³.

O inciso VII deste artigo, de acordo com o qual incumbe ao inventariante a representação judicial do espólio, nada mais faz do que concretizar no processo a regra, constante do art. 1.991 do CC, de que “desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, a administração da herança será exercida pelo inventariante”. Este o motivo por que os herdeiros não têm, individual ou conjuntamente, poderes para representar o espólio em juízo¹⁸⁴. Com a ressalva de que, se dativo o inventariante, “os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte” (parágrafo primeiro). Nesta hipótese, não se tornarão eles correpresentantes do espólio ou litisconsortes nas demandas em que o espólio for parte. A função desta intimação é de lhes servir apenas como instrumento de fiscalização¹⁸⁵. Até que o inventariante preste compromisso, entretanto, a representação judicial do espólio deve caber a seu administrador provisório com fundamento no disposto no art. 614 do CPC, segundo o qual “o administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa”. Se este administrador

provisório for cônjuge ou herdeiro, representará o espólio do mesmo modo que o inventariante. Mas se for um estranho, sofrerá as restrições impostas ao inventariante dativo¹⁸⁶.

A sociedade e a associação¹⁸⁷ -¹⁸⁸ irregulares, bem como os demais entes despersonalizados (esta última referência, como se viu acima, serve para tornar aberto o rol daqueles a quem, embora sem personalidade jurídica, a legislação reconhece capacidade de ser parte)¹⁸⁹, serão apresentados em juízo pela pessoa a quem couber a administração de seus bens¹⁹⁰. Por irregular a lei quer dizer, a rigor, a sociedade comum em suas duas espécies, a sociedade de fato e a sociedade irregular¹⁹¹. A mesma lógica se aplica às associações. A falta de regular personalidade jurídica não pode servir ainda de escudo às sociedades e associações comuns para impedir ou dificultar que contra elas se litigue. Daí por que, segundo o parágrafo único do art. 75, “sociedade ou associação sem personalidade jurídica não poderá opor a irregularidade de sua constituição quando demandada”. A regra é especialmente relevante, por exemplo, quando se tratar de sociedade irregular. Neste caso, embora possa haver ajuste escrito entre os sócios sobre quem deveria administrar a sociedade e representá-la em juízo, este acerto não é oponível ao terceiro que pretende litigar contra ela.

Ao tratar da representação processual do condomínio, o inciso XI faz referência primeiro ao condomínio voluntário e depois ao condomínio edilício. Isso porque a representação processual do condomínio voluntário é realizada por um administrador, escolhido pelos condôminos ou mesmo presumido em função do exercício da administração sem a oposição dos demais¹⁹², enquanto a representação processual do condomínio edilício compete a seu síndico eleito pelos condôminos em assembleia¹⁹³.

5. Pessoa jurídica nacional e pessoa jurídica estrangeira

A pessoa jurídica, na tradicional lição de Pontes de Miranda, é apresentada em juízo por um de seus órgãos, não representada¹⁹⁴. A lei reconhece à vontade social liberdade para definir a quem caberá a apresentação judicial da pessoa jurídica (de direito privado, não de direito público)¹⁹⁵. No silêncio dos atos constitutivos, o presentante ex lege são os seus diretores (inciso VIII).

A pessoa jurídica estrangeira, por seu turno, e se entende por pessoa jurídica estrangeira aquela constituída fora do Brasil (teoria da constituição)¹⁹⁶, deve ser apresentada “pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil” (inciso X), independentemente da nacionalidade de seus sócios¹⁹⁷. Este dispositivo, entretanto, deve “receber interpretação extensiva, pois quando a legislação menciona a perspectiva de citação de pessoa jurídica estabelecida por meio de agência, filial ou sucursal, está se referindo à existência de estabelecimento de pessoa jurídica estrangeira no Brasil, qualquer que seja o nome e a situação jurídica desse estabelecimento”¹⁹⁸. Segundo o parágrafo terceiro do art. 75, ademais, “o gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo”. O que ocorre é que a lei se vale de uma presunção absoluta para proteger o adversário da pessoa jurídica estrangeira de eventuais discussões sobre a regularidade de sua apresentação processual. E faz isso presumindo que aqueles que ela menciona têm poderes para apresentar a pessoa jurídica (não importando se a lei estrangeira do lugar de sua constituição ou os seus documentos societários dispuserem de outra forma).

6. Convênio entre procuradorias

Inova o CPC ao estipular, no parágrafo quarto do art. 75, que “os Estados e o Distrito Federal poderão ajustar compromisso recíproco para prática de ato processual por seus procuradores em favor de outro ente federado, mediante convênio firmado pelas respectivas procuradorias”. A novidade é positiva, e contribui para racionalizar e tornar mais eficiente, inclusive economicamente, a representação do Estado em juízo¹⁹⁹. A cooperação ocorre mediante a celebração de convênio, nos termos do art. 116 da Lei 8.666/1993, entre as procuradorias interessadas, independentemente de lei específica que regulamente este dispositivo²⁰⁰. Basta o ato administrativo, que deverá regular também a responsabilidade patrimonial dos contratantes pela

distribuição dos custos do processo (por exemplo, em relação ao pagamento de honorários de sucumbência²⁰¹). O convênio, processualmente falando, é um negócio jurídico processual, porque se destina a produzir efeitos no processo (atribuição da apresentação judicial de um ente público a determinado órgão que não aquele originariamente competente). A regularidade dos atos praticados por um procurador no lugar de outro depende da regularidade do convênio, embora o defeito na apresentação do ente público possa ser sempre, e de modo retroativo, corrigido pelo interessado.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1.º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2.º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Direito anterior – art. 13 do CPC/1973.

Direito comparado – § 51 da ZPO alemã, art. 182 do CPC italiano, art. 9.º da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 23 do CPC português.

1. Falta de capacidade de ser parte

A capacidade de ser parte do demandante e do demandado é condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Sem ela, o processo deve ser extinto sem o julgamento de seu mérito (art. 485, IV, CPC). Trata-se de um vício insanável. Com isto não se quer dizer, obviamente, que o autor não possa emendar a petição inicial, de modo a alterar o polo passivo da demanda, quando faltar ao réu capacidade de ser parte. Mas aí a primeira demanda será substituída por uma nova (porque uma das partes será diferente). O juiz é mesmo obrigado, aliás, a lhe dar oportunidade de fazer a alteração com fundamento no disposto no art. 321 do CPC, segundo o qual “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Apenas depois, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (parágrafo único do art. 321 do CPC).

O juiz só poderá extinguir o processo, com fundamento na falta de capacidade de uma das partes (autor ou réu), se der antes a elas oportunidade de se manifestarem sobre a questão. Esta exigência decorre do disposto nos arts. 9.º e 10 do CPC, segundo os quais, respectivamente, “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”²⁰² e “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Este dever de consultar, do qual decorre a proibição da surpresa (*Überraschungsverbot*)²⁰³, não exige do juiz que ouça primeiro as partes antes de decidir apenas quando lhe parecer sanável o vício. Também deve fazê-lo mesmo quando o vício lhe parecer insanável, até mesmo porque o vício aparentemente incorrigível à primeira vista pode depois provar-se sanável. Mas não importa, enfim, se sanável ou não. As partes têm o direito de se

pronunciar previamente sobre todos os pontos sobre os quais o juiz possa apoiar sua decisão²⁰⁴, mesmo aqueles sobre os quais ele possa decidir de ofício²⁰⁵ e mesmo quando o vício pareça insanável. É neste sentido que alude a doutrina alemã, à luz do disposto no § 139 (3) ZPO, a um *Pflicht zum Hinweis auf Zulässigkeitsbedenken* (o dever de consulta sobre pontos – todos – que digam respeito à admissibilidade da demanda ou de recursos)²⁰⁶.

A parte, de quem se impugnar sua capacidade de ser parte, terá sempre capacidade de ser parte para debater em juízo a questão da sua capacidade de ser parte. Se interpor recurso da decisão que julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, por exemplo, seu recurso não poderá deixar de ser conhecido com fundamento na falta de capacidade. O acórdão que confirma a sentença terminativa fundada na falta de capacidade de ser parte do recorrente é um acórdão que julga o mérito do recurso, ainda que para confirmar a extinção do processo sem julgamento do mérito²⁰⁷.

2. Falta de capacidade processual

A capacidade processual é requisito de validade dos atos processuais praticados pelas partes. Sua falta será sempre um vício sanável. Daí por que, segundo o disposto no art. 76, caput, do CPC, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Este dispositivo dá concretude à regra geral, enunciada nos arts. 9.º e 10 do CPC, segundo os quais, respectivamente, “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”²⁰⁸ e “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

O juiz só poderá sancionar a falta de capacidade processual ou a capacidade processual defeituosa, em outras palavras, após dar às partes não apenas a oportunidade de se manifestar sobre a questão, mas também, à parte prejudicada, a chance efetiva de corrigir o vício. O prazo, a que alude o caput do art. 76, é judicial, mas deve ser determinado de modo razoável. A fixação de um prazo excessivamente curto equivale à violação da garantia do contraditório. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, por fim, a intimação do interessado para que corrija o vício deve ser pessoal, não através de seu advogado²⁰⁹.

Proíbe-se também ao juiz, e esta é também uma decorrência da garantia do contraditório, de determinar a correção do vício sem esclarecer a que vício exatamente ele alude e de qual modo ele pode ser sanado. Esta exigência é expressa no art. 321 do CPC, segundo o qual o juiz deve indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Esta regra, exposta embora no contexto da emenda à petição inicial, é aplicável para todo e qualquer caso de vício que impeça o julgamento do mérito de uma demanda ou de um recurso. A determinação de correção do vício deve ser, em outras palavras, construtiva e precisa, não vaga ou obscura²¹⁰.

A parte, de quem se impugnar sua capacidade processual, terá sempre capacidade processual para debater em juízo a questão da sua capacidade processual²¹¹. Se interpor recurso da decisão que julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, por exemplo, seu recurso não poderá deixar de ser conhecido com fundamento na falta de capacidade. O acórdão que confirma a sentença terminativa fundada na falta de capacidade de ser parte do recorrente é um acórdão que julga o mérito do recurso, ainda que para confirmar a extinção do processo sem julgamento do mérito²¹².

3. Consequências da falta de capacidade processual

A capacidade processual do demandante é uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Sem sua correção, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito (art. 76, § 1.º, I, do CPC). Em caso de litisconsórcio ativo, apenas em relação àquele a que faltar a capacidade. A capacidade processual do demandado, no entanto, não será nunca condição de

admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. De sua falta decorre a revelia do demandado, nunca a extinção do processo (art. 76, § 1.º, II, do CPC). Isso, naturalmente, apenas se não for caso de nomeação de curador ad litem conforme o disposto no art. 72 do CPC. O terceiro, por fim, dependendo do polo do processo em que se encontre, “será considerado revel ou excluído do processo” (art. 76, § 1.º, III, do CPC). Na assistência, por exemplo, o terceiro será excluído do processo. No chamamento ao processo, diferentemente, também, por exemplo, será considerado revel.

Descumprida a determinação de correção da falta ou defeito de capacidade em grau de recurso, é preciso distinguir entre duas situações: “Uma é o vício estar na representação/incapacidade/legitimidade no âmbito do recurso – e não haver vício em primeiro grau de jurisdição. Outra é ser percebido o vício do processo, que já existia em primeiro grau, e não foi nem alegado pelas partes, nem percebido pelo juiz, que poderia (*rectius*, deveria) ter determinado a sua correção e, se não tivesse havido, ter ou extinto o processo sem julgamento de mérito, ou considerado o réu revel”²¹³. Nas duas hipóteses o vício será sanável²¹⁴, mas com a diferença de que, se não corrigido, a turma julgadora, na primeira, “não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente” (inciso I) ou “determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido” (inciso II)²¹⁵. Na segunda, a turma julgadora deverá julgar extinto o próprio processo (e não apenas o recurso), sem julgamento do mérito²¹⁶.

4. Primazia do julgamento do mérito

O Código de Processo Civil de 2015, em uma de suas mais interessantes inovações, dispõe em seu art. 488 que “desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”. A existência desta regra é fiel ao princípio do processo que a doutrina vem chamando de princípio da primazia da decisão de mérito²¹⁷, aplicável também no julgamento dos recursos²¹⁸.

O tema é debatido na doutrina alemã há décadas, e é ainda controvertido, embora os processualistas alemães tenham se inclinado a reconhecer que o mérito da demanda só deve ser julgado se preenchidas as condições de admissibilidade do seu julgamento mesmo quando for possível decidir em favor do adversário de quem tenha dado causa ao vício²¹⁹. Ainda melhor o processo civil brasileiro ao permiti-lo, mas é preciso ter-se cuidado para que o julgamento não viole a garantia da parte prejudicada ao contraditório. Daí por que acertada a lei ao dizer que este julgamento deve ser feito “desde que possível”.

Por “desde que possível” quer-se dizer, em primeiro lugar, que a demanda deve poder ser julgada independentemente de qualquer instrução probatória suplementar. Mas também que o prejudicado teve a efetiva oportunidade de defender seu ponto de vista. Este será o caso, por exemplo, se o juiz julgar extinto o processo com julgamento do mérito, com fundamento na prescrição da pretensão, mesmo se o demandante deixar de recolher as custas incidentes (na vigência do CPC/1973, o juiz deveria julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, mesmo que pudesse decidir a questão da prescrição). Suponha-se, no entanto, que um menor de idade ajuíze uma demanda representada por sua avó (e não por seus representantes legais). Mesmo que a pretensão lhe pareça prescrita, o juiz não deve julgar o mérito contra o autor, que não teve o direito de defender-se adequadamente em juízo (por seu legítimo representante). Situação análoga ocorrerá se um cônjuge ajuizar uma demanda para a qual deveria ter obtido o consentimento do outro. Se esta autorização faltar, mesmo que a pretensão pareça prescrita, não deve o juiz julgar o mérito em respeito ao cônjuge cuja autorização não se obteve. Neste caso, o processo deverá ser extinto por falta de legitimidade processual do autor.

1

As exceções a esta regra geral serão abordadas oportunamente.

2

Este o problema da *Nichtexistenz einer Partei* (Rosenberg; Schwab; Gottwald; *Zivilprozessrecht*, p. 206).

3

José Carlos Barbosa Moreira, *Sobre pressupostos processuais*. In: *Temas de direito processual* (4a série), p. 91.

4

Sergio Bermudes, *Capacidade processual e citação de réu morto*. In: *Direito processual civil* (estudos e pareceres, 2a série, p. 125).

5

Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Código de Processo Civil comentado*, art. 70.

6

Diz-se *em princípio*, porque, como se verá, esta regra comporta exceções.

7

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, emende-a ou complete-a, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

8

“The crucial point, as it seems to me, is that the description used must be sufficiently certain as to identify both those who are included and those who are not. If that test is satisfied, then it does not seem to me to matter that the description may apply to no one or to more than one person nor that there is no further element of subsequent identification whether by service or otherwise. I can see no injustice to anyone if I make an order in the form sought but considerable potential for injustice to the claimants if I do not. For these reasons I will make the order”.

9

“On 7th May 2003 Laddie J made an order against ‘the person or persons who have offered the publishers of the Sun, the Daily Mail, and the Daily Mirror newspapers a copy of the book *Harry Potter and the order of the Phoenix* by J.K. Rowling’ requiring them to deliver up all copies of the book, any notes recording any part of it or any information derived from it and restraining them from disclosing to any person all or any

part of the book or any information derived from it. In his judgment he explained the unusual nature of the order against defendants so described and recognised the need in due course to address the issue in more detail”.

10

Norbert Kleffmann, *Unbekannt als Parteibezeichnung*, p. 36.

11

Hazard; Leubsdorf; Bassett, *Civil Procedure*, p. 264.

13

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 222.

14

Diferentemente do que ocorre, como se verá mais adiante, na legitimidade processual. Como bem resume Hélio Tornaghi, esta capacidade “existe em abstrato, independente das circunstâncias de qualquer caso concreto” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 105).

15

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 181.

16

Todas as pessoas naturais, homens e mulheres, nacionais ou estrangeiros, independentemente de qualquer critério de distinção entre elas que se possa conceber, têm personalidade jurídica. Basta ser humano, conforme enuncia o art. 1.º do CC, segundo o qual “toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”.

17

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 100.

18

O ponto é bem resumido pelo Superior Tribunal de Justiça no seguinte acórdão: “A ciência processual, em face dos fenômenos contemporâneos que a cercam, tem evoluído a fim de considerar como legitimados para estar em juízo, portanto, com capacidade de ser parte, entes sem personalidade jurídica, quer dizer, possuidores, apenas, de personalidade judiciária. No rol de tais entidades estão, além do condomínio de apartamentos, da massa falida, do espólio, da herança jacente ou vacante e das sociedades sem personalidade própria e legal, todos por disposição de lei, hão de ser incluídos a massa insolvente, o grupo, classe ou categoria de pessoas titulares de direitos coletivos, o PROCON ou órgão oficial do consumidor, o consórcio de automóveis, as Câmaras Municipais, as Assembleias Legislativas, a Câmara

dos Deputados, o Poder Judiciário, quando defenderem, exclusivamente, os direitos relativos ao seu funcionamento e prerrogativas” (RMS 8.967/SP, 1.a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, rel. p/ Acórdão Min. José Delgado, j. 19.11.1998, *DJ* 22.03.1999, p. 54).

19

Por exemplo: AgRg no AREsp 703.654/MS, 4.a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.09.2015, *DJe* 09.09.2015.

20

Art. 2.º, do CC: A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.

22

Para mais detalhes, confirmam-se os Comentários ao artigo 75.

23

Por isso, a comparação entre o estatuto jurídico do escravo no século XIX e o dos animais nos dias de hoje não é um bom argumento. Os animais não poderão nunca contrair obrigações nem nunca lhes será possível impor o cumprimento de deveres.

24

“Enquanto a capacidade de ser parte se prende à titularidade da pretensão à tutela jurídica, a capacidade processual ou de estar em juízo diz respeito à prática e à recepção eficazes dos atos processuais, a começar pela petição e a citação, isto é, ao pedir e ao ser citado. É a capacidade de exercício, para que nasça e seja eficaz a relação jurídica processual e se prossiga no processo” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 238).

25

Diferentemente do que ocorre, como se verá mais adiante, na legitimidade processual.

26

“A esta aptidão oriunda da personalidade, para adquirir os direitos na vida civil, dá-se o nome de capacidade de direito, e se distingue da capacidade de fato, que é a aptidão para utilizá-los e exercê-los por si mesmo” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 225).

27

Stein; Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1010; Francesco Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 208. Também Cadet; Normand; Mekki, *Théorie générale du procès*, p. 740.

28

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 317.

29

Contra: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 317.

30

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 242.

31

Sobre a capacidade de ser parte: “Trata-se de conceito do tipo intransitivo, ou seja, que prescinde de complemento. Pode-se dizer que A é capaz, sem que se explique para quê, já que a capacidade confere a A a aptidão absolutamente genérica. Como se verá logo abaixo, diferentemente ocorre com a legitimidade, que é conceito por excelência transitivo e reclama um complemento. Isso significa que, quando se diz que B tem legitimidade, essa sentença carece de sentido se não se esclarece para quê” (Wambier; Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. 1, p. 321).

32

No processo alemão, por exemplo: Musielak; Voit, *Grundkurs ZPO* (12a ed. 2014), p. 84. No processo italiano, por exemplo: Francesco Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 214.

33

Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 75.

34

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC).

36

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 109.

37

Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 1, p. 11.

38

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 252.

Como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir” (REsp 1.694.984/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4.^a Turma, j. 14.11.2017, DJe 01.02.2018). Para mais detalhes: Maurício Requião, *Estatuto da pessoa com deficiência, incapacidades e interdição*, p. 163; e Carlos Alberto de Salles, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 1, p. 400.

“Em verdade, o que o Estatuto pretendeu foi, homenageando o princípio da dignidade da pessoa humana, fazer com que a pessoa com deficiência deixasse de ser ‘rotulada’ como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil” (Pablo Stolze, O Estatuto da pessoa com deficiência e o sistema jurídico de incapacidade civil, *Revista Síntese de Direito Civil*, 99, p. 19).

Para mais detalhes: Daneluzzi; Mathias, Repercussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) nas legislações civil e processual civil, *Revista de Direito Privado* 66, p. 65.

“A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1.º Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei”.

“A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.”

“A curatela afetarão tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. § 1.º A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto”.

Não mais de incapacidade absoluta, como reconhecia o Código Civil (art. 3.º, III) até 2015.

“A alteração tem por consequência que, com a vigência do Estatuto, aquele que não puder exprimir sua vontade passa a ser assistido, ou seja, participa do ato juntamente com seu representante legal. Pergunto: se uma pessoa estiver em coma induzido por questões médicas e, portanto, temporariamente sem discernimento algum, como pode ela realizar o ato com a assistência ou auxílio? A interdição que, por fim, declarar a pessoa relativamente incapaz será inútil em termos fáticos, pois o incapaz não poderá participar dos atos da vida civil. O equívoco do Estatuto, neste tema, é evidente. A mudança legislativa é extremamente prejudicial àquele que necessita de representação e não de assistência e acarreta danos graves àquele que o Estatuto deveria proteger” (José Fernando Simão, *Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade* (Parte 2). Disponível em: [<http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-traz-mudancas#author>]. Acesso em 09.01.2016.

47

Também Robson Godinho, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral/Cramer), p. 125.

Para mais detalhes, confirmem-se os Comentários ao art. 75.

48

Esta norma, relativa à tutela, é aplicada também à curatela por força do disposto no art. 1.774 do Código Civil.

49

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 252.

50

“No caso de falta de autorização, a eficácia de ato do tutor depende da aprovação ulterior do juiz” (art. 1.748, parágrafo único).

51

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 242.

52

“Dos cuidados postos pelo Código de Processo Civil quanto à citação por mandado, o único realmente relevante é o que está em seu art. 218 [atual 245]. Suspeitando seriamente o oficial de justiça de que o citando não tenha condições físicas ou psíquicas para receber utilmente a citação, ele não realizará o ato e disso passará certidão no mandado. Suspende-se o processo, instaurando-se um incidente inicial de insanidade em que o juiz faz realizar a prova pericial conveniente por médico especializado, para depois decidir. Ou ele conclui pela sanidade do citando e a citação realiza-se normalmente; ou, na hipótese contrária, nomeia curador *ad hoc* com o encargo de ser citado e responder pela defesa do réu no processo” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 3, p. 433).

53

Para Araken de Assis, embora sem previsão legal expressa que o autorize, o juiz deveria também resolver, ao nomear o curador especial, a questão da curatela geral (e não apenas da *ad litem*). A ideia é interessante, mas controversa porque: a) a nomeação de curador exige um procedimento especial típico (art. 747, CPC); b) o juiz da interdição deve ter competência material para fazê-lo. (Para mais detalhes: Araken de Assis, Suprimento da incapacidade processual e da incapacidade postulatória, *Revista Forense* 354, p. 42). Também Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 82.

54

Sobre esta questão: Maurilio Casas Maia, Defensoria Pública no novo Código de Processo Civil (NCP): primeira análise, *Revista de Processo* 265 (2017), item 2.5.

55

“Tal curadoria será exercida preferencialmente pela Defensoria Pública, mas, na ausência ou desaparecimento desta na localidade, tal mister poderá ser desempenhado por advogado dativo, cujos honorários, consequentemente, serão pagos pelo ente estatal. Ocorre que não está em questão a suficiência econômica do réu, e sim o trabalho do advogado dativo, o qual não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de defensor público na localidade” (AgRg no REsp 1453363/MG, 2.a Turma, rel. Min. Humberto Martins, j. 05.06.2014, *DJe* 13.06.2014).

56

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 114.

57

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 255.

58

Sobre o ponto: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 25.

59

José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 98.

60

E isso porque a reconvenção é uma *resposta* do demandado, mas não uma *defesa*.

61

Em sentido contrário, por exemplo: Luis Guilherme Aidar Bondioli, *Reconvenção no processo civil*, p. 105-106. Também o seguinte acórdão do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o curador especial tem

legitimidade para propor reconvenção em favor de réu revel citado por edital (art. 9.º, II, do CPC/1973), poder que se encontra inserido no amplo conceito de defesa” (REsp 1.088.068/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.08.2017, DJe 09.10.2017).

62

Para Araken de Assis, diferentemente, “os poderes do curador especial não se distinguem dos conferidos à parte por ele representada” (Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, vol. 2, item 535).

63

Arruda Alvim Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 143.

64

O termo separação absoluta deve ser interpretado apenas no sentido de englobar a separação convencional, não a separação obrigatória. Isso porque “considera-se que apenas a separação convencional é de fato absoluta, pois, no caso da obrigatória, existe o risco de comunicabilidade, por força da Súmula 377 do STF – para aqueles que a entendem vigente – de modo que não se poderia dispensar a outorga conjugal” (Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 4, p. 280). Neste mesmo sentido: “Embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial” (REsp 1171820/PR, 3.a Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2010, DJe 27.04.2011).

65

“Realmente, a comunhão de bens unifica os patrimônios dos cônjuges, ou totalmente, formando com eles um acervo, sob a propriedade e posse indivisas de ambos, quando é universal, ou limitadamente, abrangendo somente certa classe de bens, quando é parcial” (Clóvis Beviláqua, *Direito da família*, p. 186).

67

Segundo mandamento constitucional expresso em seu art. 226, § 5.º, de acordo com o qual “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”.

68

“A ‘gestão unilateral do patrimônio comum’ tem os seus limites fixados em lei. Assim, excluído o regime de separação total de bens, os atos de alienação de imóveis ou o seu gravame com ônus reais dependem da participação conjunta do casal, assim como as ações judiciais correspondentes, atuando como autor e réu. A outorga é necessária inclusive nas alienações de bens particulares porque referem-se à segurança dos bens da família – o que representa materialmente a segurança da mesma” (Paulo Nader, *Curso de direito civil*, vol. 5, p. 410).

69

“Os poderes de gerência, que são atribuídos por igual a ambos os cônjuges, compreendem todos os atos de administração. Excluem-se os de disposição. O inciso tem em vista os bens imóveis, que constituem a parte mais sólida do patrimônio. Sem embargo do desenvolvimento que adquire o acervo mobiliário, como o investimento em papéis de renda, em ações, em operações de mercado aberto e tantas outras modalidades rentáveis, o imóvel, posto que proporcione menores rendimentos, é revestido da segurança indispensável à estabilidade econômica. Estabelece, portanto, que a alienação e o gravame incidente sobre os bens imóveis, requerem a participação de ambos os cônjuges. Ressalva-se, contudo, o suprimento judicial, quando a recusa é ilegítima” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 5, p. 207).

70

O adjetivo *marital* é empregado também em sentido mais amplo para se referir a cônjuges em geral, não apenas ao marido.

71

“A falta de autorização, não suprida pelo juiz, quando necessária (art. 1.647), tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação, até dois anos depois de terminada a sociedade conjugal”.

72

“A outorga do cônjuge pode ser dada antes da celebração do negócio jurídico, ou durante a sua realização. Se dada posteriormente, terá a natureza de confirmação ou ratificação, fazendo desaparecer o vício de anulabilidade desde o momento de sua celebração” (Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 4, p. 280).

73

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 5, p. 208.

74

O inciso I do art. 1.647 proíbe o cônjuge, sem autorização do outro, de “alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis”.

75

Em sua redação original, por exemplo, o art. 213 do Código Civil francês estatuiu que “le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari”. Para mais detalhes: Eduardo Espínola, *A família no direito civil brasileiro*, p. 234.

76

Por exemplo: “Trata-se de norma que tem o objetivo de integrar a capacidade processual ativa do cônjuge demandante” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 322).

77

Como se viu nos comentários ao artigo 70, capacidade processual é a capacidade abstrata de conduzir o processo e de realizar atos processuais por si próprio ou através de um representante escolhido pelo próprio representado. Diz-se abstrata porque esta capacidade decorre apenas dos atributos pessoais da parte, independentemente dos elementos concretos da demanda.

78

Neste sentido: “Destaca-se que todos os dispositivos citados, tanto materiais como processuais, cingem-se a regular a legitimidade dos cônjuges para a prática de certos atos. O casamento, de forma alguma, interfere em suas capacidades, pois já foi o tempo em que a esposa era considerada relativamente incapaz” (Ravi Peixoto, As restrições à atuação processual dos cônjuges previstas no art. 73 do CPC e as influências operadas pelo Código Civil. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 703). Contra, por exemplo: Araken de Assis, Suprimento da incapacidade processual e da incapacidade postulatória, *Revista Forense* 354, p. 38.

79

Sobre esta questão, também Robson Godinho, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral/Cramer), p. 129. Para mais detalhes, confirmam-se os Comentários ao art. 75.

80

Sobre o ponto: Ravi Peixoto, As restrições à atuação processual dos cônjuges previstas no art. 73 do CPC e as influências operadas pelo Código Civil. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 708.

81

O consentimento, com efeito, “independente de forma expressa, podendo se dar por instrumento público ou particular, pela outorga de procuração etc.” (Arruda Alvim; Araken de Assis; Eduardo Arruda Alvim, *Comentários ao Código de Processo Civil*, p. 24).

82

REsp 1163074/PB, 3.a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.12.2009, *DJe* 04.02.2010.

84

No processo alemão, por exemplo: Musielak; Voit, *Grundkurs ZPO* (12a ed., 2014), p. 84. No processo italiano, por exemplo: Francesco Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 214.

85

Para mais detalhes, Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 75.

86

“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18, CPC).

88

Para mais detalhes confirmam-se os Comentários ao próximo artigo.

90

REsp 1163074/PB, 3.a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.12.2009, *DJe* 04.02.2010.

91

Também Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 4, p. 280.

92

Neste mesmo sentido: “Embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial” (REsp 1171820/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.a Turma, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 07.12.2010, *DJe* 27.04.2011).

94

Sobre elas: Orlando Gomes, *Direitos reais*, p. 10.

95

Die im Sachenrecht möglichen dinglichen Berechtigungen müssen grundsätzlich im Gesetz fixiert sein; es gilt also der sog. numerus clausus der Sachenrechte (Typenzwang) (*Baur/Stürner*, Sachenrecht, p. 3).

97

Art. 1.225. São direitos reais: I – a propriedade; II – a superfície; III – as servidões; IV – o usufruto; V – o uso; VI – a habitação; VII – o direito do promitente comprador do imóvel; VIII – o penhor; IX – a hipoteca; X – a anticrese; XI – a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei 11.481/2007); XII – a concessão de direito real de uso; e (Redação dada pela Medida Provisória 700, de 2015); XIII – os direitos oriundos da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas e respectiva cessão e promessa de cessão. Incluído pela Medida Provisória 700, de 2015.

“Conforme seu objeto, dividem-se os direitos reais em mobiliários e imobiliários, e recaem, respectivamente, em coisas móveis ou imóveis. A distinção é importante, porque os direitos reais imobiliários estão sujeitos a registro público. Somente a propriedade, o usufruto e o penhor podem ter por objeto bens móveis, sendo que este último direito real só em casos especiais incide em imóveis. Todos os outros direitos reais são essencialmente imobiliários” (Orlando Gomes, *Direito reais*, p. 18). Também Baur; Stürner, *Sachenrecht*, p. 12.

“A Ação Demolitória visa à demolição de: a) prédio em ruína (art. 1.280 do CC); b) construção prejudicial a imóvel vizinho, às suas servidões ou aos fins a que é destinado (art. 934, I, do CPC); c) obra executada por um dos condôminos que importe prejuízo ou alteração de coisa comum por (art. 934, II, do CPC); d) construção em contravenção da lei, do regulamento ou de postura estabelecidos pelo Município. No sistema do Código Civil, a construção é tratada como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel (arts. 1.253 a 1.259). Por outro lado, o direito de exigir a demolição de prédio vizinho encontra-se previsto no capítulo que trata dos direitos de vizinhança e está associado ao uso anormal da propriedade (Seção I do Capítulo V do Título III do *Livro dos Direitos das Coisas*). A Ação Demolitória tem a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova e se distingue desta em razão do estado em que se encontra a obra (REsp 311.507/AL, 4.a Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 05.11.2001, p. 118). Assentada a premissa de que a Ação Demolitória e a Ação de Nunciação de Obra Nova se equivalem, o art. 95 do CPC corrobora a tese sobre a natureza real de ambas (...). Para o Código de Processo Civil, portanto, a Ação de Nunciação de Obra Nova se insere entre aquelas fundadas em direito real imobiliário. A mesma conclusão deve alcançar a Ação Demolitória. Em precedente de relatoria do saudoso Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, o STJ assentou entendimento pela nulidade de processo em que pleiteada a demolição de bem, por ausência de citação de condômino litisconsorte necessário (REsp 147.769/SP, 4.a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 14.02.2000, p. 34)” (REsp 1374593/SC, 2.a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.03.2015, DJe 01.07.2015).

“Extinção de Condomínio. Inobservância a litisconsórcio necessário. Direito real imobiliário. Necessidade de citação de ambos os cônjuges, independentemente do regime de bens do matrimônio. Nulidade no feito por imperfeição manifesta na formação da relação processual o que compromete a eficácia da sentença. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento 0046098-63.2011.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Des. rel. Piva Rodrigues, j. 09.08.2011, p. 22.08.2011).

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 117.

Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 90.

103

Essa a opinião majoritária na doutrina. Recentemente, por exemplo: Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 63, Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 322 e José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 193.

104

Baur; Stürner; Sachenrecht, p. 3.

106

Orlando Gomes, *Direito reais*, p. 18. Também Baur; Stürner, Sachenrecht, p. 12.

107

“A Ação Demolitória visa à demolição de: a) prédio em ruína (art. 1.280 do CC); b) construção prejudicial a imóvel vizinho, às suas servidões ou aos fins a que é destinado (art. 934, I, do CPC); c) obra executada por um dos condôminos que importe prejuízo ou alteração de coisa comum por (art. 934, II, do CPC); d) construção em contravenção da lei, do regulamento ou de postura estabelecidos pelo Município. No sistema do Código Civil, a construção é tratada como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel (arts. 1.253 a 1.259). Por outro lado, o direito de exigir a demolição de prédio vizinho encontra-se previsto no capítulo que trata dos direitos de vizinhança e está associado ao uso anormal da propriedade (Seção I do Capítulo V do Título III do Livro dos Direitos das Coisas). A Ação Demolitória tem a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova e se distingue desta em razão do estado em que se encontra a obra (REsp 311.507/AL, 4.a Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 05.11.2001, p. 118). Assentada a premissa de que a Ação Demolitória e a Ação de Nunciação de Obra Nova se equivalem, o art. 95 do CPC corrobora a tese sobre a natureza real de ambas (...). Para o Código de Processo Civil, portanto, a Ação de Nunciação de Obra Nova se insere entre aquelas fundadas em direito real imobiliário. A mesma conclusão deve alcançar a Ação Demolitória. Em precedente de relatoria do saudoso Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, o STJ assentou entendimento pela nulidade de processo em que pleiteada a demolição de bem, por ausência de citação de condômino litisconsorte necessário (REsp 147.769/SP, 4.a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 14.02.2000, p. 34)” (REsp 1374593/SC, 2.a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 05.03.2015, DJe 01.07.2015).

108

“Extinção de Condomínio. Inobservância a litisconsórcio necessário. Direito real imobiliário. Necessidade de citação de ambos os cônjuges, independentemente do regime de bens do matrimônio. Nulidade no feito por imperfeição manifesta na formação da relação processual o que compromete a eficácia da sentença. Recurso provido.” (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 0046098-63.2011.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Des. rel. Piva Rodrigues, j. 09.08.2011, p. 22.08.2011).

109

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 117.

110

Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 90.

111

Isso porque, como entendeu com razão o Superior Tribunal de Justiça, “nas hipóteses de casamento sob o regime da separação legal, os consortes, por força da Súmula 377/STF, possuem o interesse pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento, razão por que é de rigor garantir-lhes o mecanismo de controle de outorga uxória/marital para os negócios jurídicos previstos no artigo 1647 da lei civil” (REsp 1163074/PB, 3.a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, j. 15.12.2009, *DJe* 04.02.2010). O raciocínio, desenvolvido embora à luz do direito material, vale também no plano processual. Com isso se quer dizer, em outras palavras, que a outorga conjugal não é necessária quando casados os esposos no regime da separação obrigatória de bens.

112

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 281.

114

TJSP – Ap 120.184-2 – 11ª Câmara – j. 28.12.1987– rel. Des. Salles Penteado.

115

TRF-2.ª Reg. – Ag 2004.02.01.005306-3 – 3.ª Turma – j. 21.09.2004 – rel. Des. Tania Heine – *DJU* 06.10.2004.

116

Código Civil: art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I – os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II – o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III – o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV – os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V – os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.

117

Código Civil: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores.

118

José Roberto dos Santos Bedaque, *Código de Processo Civil interpretado* (Marcato), p. 38.

119

Paulo Luiz Netto Lôbo, *Código Civil comentado*, vol. 16, p. 252.

120

Por isso é equivocado chamar o usufruto, por exemplo, de um ônus real. Usufruto é, a rigor, um *direito real*. Esta confusão é visível no REsp 1232074/RS, 2.a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2011, DJe 04.03.2011.

121

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 283.

123

Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 63.

124

Neste sentido: AgRg no Ag 667.222/SP, 3.a Turma, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 17.11.2005, DJ 24.04.2006, p. 394.

125

Para um resumo destas divergências doutrinárias: Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 4, p. 13.

127

Sobre ponto: Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 89.

128

É frequente na doutrina a crítica à figura do litisconsórcio ativo necessário, porque “ninguém pode ser obrigado a demandar em juízo somente se outrem também assim o desejar” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 322). Neste sentido também Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 364. Sem razão. A questão não é se alguém deve litigar ou não contra sua própria vontade, mas sim a circunstância de que a formação do litisconsórcio ativo pode ser definida pela lei como uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Este tema é abordado longamente nos comentários ao art. 114.

129

“Uma vez que a posse é a exteriorização do comportamento do *dominus*, admite-se como corolário natural a *composse*, em todos os casos em que ocorre o condomínio, compossuidores os condôminos. Nas suas relações externas, isto é, nas relações com terceiros, os compossuidores procedem como se fossem um

único sujeito, não interessando aos estranhos à relação compossessória indagar do estado de comunhão, ou sua causa, nem apurar o valor da quota de cada comunheiro” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 4, p. 28).

130

Neste mesmo sentido: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 324.

132

O consentimento deve ser suprido judicialmente, em outras palavras, quando se “recusa a outorga sem motivo razoável, por mero capricho, prepotência, paixão, malícia ou qualquer outra razão inaceitável” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 121).

133

Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 63.

134

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 325.

135

Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 95.

136

Aplica-se, por analogia, a regra prevista para o julgamento de certas questões no processo de inventário: “Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres. Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC” (REsp 1459192/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.a Turma, rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, j. 23.06.2015, *DJe* 12.08.2015). Embora o art. 612 do CPC não tenha repetido *ipsis litteris* a redação do art. 984 do CPC/1973, a *ratio* permanece a mesma.

137

O Superior Tribunal de Justiça chama a capacidade de ser parte, frequentemente, de *personalidade judiciária*. Por exemplo: AgRg no AREsp 703.654/MS, 4.a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.09.2015, *DJe* 09.09.2015.

138

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 222.

139

Como bem resume Hélio Tornaghi, esta capacidade “existe em abstrato, independente das circunstâncias de qualquer caso concreto” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 105).

140

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 181.

141

O ponto é bem resumido pelo Superior Tribunal de Justiça no seguinte acórdão: “A ciência processual, em face dos fenômenos contemporâneos que a cercam, tem evoluído a fim de considerar como legitimados para estar em juízo, portanto, com capacidade de ser parte, entes sem personalidade jurídica, quer dizer, possuidores, apenas, de personalidade judiciária. No rol de tais entidades estão, além do condomínio de apartamentos, da massa falida, do espólio, da herança jacente ou vacante e das sociedades sem personalidade própria e legal, todos por disposição de lei, não de ser incluídos a massa insolvente, o grupo, classe ou categoria de pessoas titulares de direitos coletivos, o PROCON ou órgão oficial do consumidor, o consórcio de automóveis, as Câmaras Municipais, as Assembleias Legislativas, a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário, quando defenderem, exclusivamente, os direitos relativos ao seu funcionamento e prerrogativas” (RMS 8.967/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1.a Turma, rel. p/ Acórdão Min. José Delgado, j. 19.11.1998, DJ 22.03.1999, p. 54).

142

A representação processual do absolutamente incapaz, por exemplo, não é regulada pelo art. 75, mas sim pelo art. 71.

143

Der Stellvertreter im Prozess ist, wer offen im Namen einer Partei Handlungen der Prozessführung vornimmt oder entgegennimmt. Die Wirkungen des stellvertretenden Handelns treten unmittelbar für und gegen den Vertretenen ein (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 274).

144

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 288.

145

Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 826.

146

Neste sentido: José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 1108.

147

AgRg no MS 21.371/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.03.2015, *DJe* 27.04.2015.

148

AgRg no MS 21.371/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.03.2015, *DJe* 27.04.2015.

149

AgRg no AREsp 44.971/GO, 1.a Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2012, *DJe* 05.06.2012.

150

AgRg no REsp 1486651/PE, 2.a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 09.12.2014, *DJe* 15.12.2014.

151

Para mais detalhes, confirmam-se os Comentários ao art. 70.

152

REsp 1164017/PI, rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, j. 24.03.2010, *DJe* 06.04.2010.

153

Como consequência da superação, no direito internacional público, da Superação da doutrina Eldon, segundo a qual apenas se reconhecia o “poder de demandar em juízo o governo estrangeiro que fosse reconhecido” (Celso Duvivier de Albuquerque Mello, *Curso de direito internacional público*, vol. 1, p. 397).

154

“A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo”.

155

O termo Fazenda Pública é aqui empregado em sentido lato, para designar “as pessoas jurídicas de direito público que figurem em ações judiciais, mesmo que a demanda não verse sobre matéria estritamente fiscal ou financeira” (Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 15). Para Carvalho Filho, no entanto, aludindo ao emprego do termo Fazenda Pública, “trata-se de mera praxe forense, usualmente explicada pelo fato de que o dispêndio com a demanda é debitado ao erário da respectiva pessoa” (José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 1108). Sobre a questão, também Marco Antonio Rodrigues, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 2.

156

157

As competências do Advogado-Geral da União (art. 3.º), da Procuradoria-Geral e das procuradorias regionais (art. 9.º) são disciplinadas pela Lei Orgânica da AGU.

158

Segundo o parágrafo do art. 12, são consideradas causas de natureza fiscal aquelas que versem sobre: I – tributos de competência da União, inclusive infrações à legislação tributária; II – empréstimos compulsórios; III – apreensão de mercadorias, nacionais ou estrangeiras; IV – decisões de órgãos do contencioso administrativo fiscal; V – benefícios e isenções fiscais; VI – créditos e estímulos fiscais à exportação; VII – responsabilidade tributária de transportadores e agentes marítimos; VIII – incidentes processuais suscitados em ações de natureza fiscal.

159

Ferreira Mendes; Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 1037.

160

O Supremo Tribunal Federal tem um precedente antigo sobre o assunto: “Advocacia de Estado (cf. arts. 131 e 132): representação judicial não excludente da constituição de mandatário *ad judicia* para causa específica. Ao conferir aos procuradores dos estados e do distrito federal a sua representação judicial, o artigo 132 da constituição veicula norma de organização administrativa, sem tolher a capacidade de tais entidades federativas para conferir mandato *ad judicia* a outros advogados para causas especiais” (Pet 409 AgR, relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 18.04.1990, DJ 29.06.1990 p. 6219, ementa, vol. 01587-0, p. 127).

161

“Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas”.

162

Em sentido favorável: “Pode eventualmente o Estado contratar advogado especializado para representá-lo judicialmente; nada o impede. Contudo, enquanto os Procuradores titulares de cargos de carreira dispensam a prova do mandato através de procuração, os advogados autônomos contratados devem comprovar a outorga de poderes para atuar no processo” (José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 1114). Contra: “Nos Estados e no Distrito Federal, estabelece a Constituição, toda a representação judicial das unidades e consultoria ao Poder Executivo compete às respectivas Procuradorias-Gerais (art. 131, § 3.º), as quais têm por chefe o Procurador-Geral do Estado” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 724).

163

“A representação processual de município independe de instrumento de mandato, desde que seus procuradores estejam investidos na condição de servidores municipais, por se presumir conhecido o mandato pelo seu título de nomeação ao cargo” (AgRg no Ag 790.516/RS, 2.a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 05.12.2006, *DJ* 15.12.2006, p. 346).

164

“Curiosamente, o CPC, ao declinar os representantes judiciais da União, dos Estados e do Distrito Federal somente se referiu aos procuradores. Para os Municípios, reiterou a representação pelos procuradores e acrescentou a exercida pelo Prefeito. Assim, só o Chefe do Executivo Municipal, desde que seja advogado, pode representar judicialmente o Município, deferência que não foi estendida aos demais Chefes do Executivo” (José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 1114).

165

“Nos termos do art. 13, V c/c art. 25, II, § 1.º, da Lei 8.666/1993 é possível a contratação de serviços relativos ao patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas sem procedimento licitatório. Contudo, para tanto, deve haver a notória especialização do prestador de serviço e a singularidade deste. A inexigibilidade é medida de exceção que deve ser interpretada restritivamente. A singularidade envolve casos incomuns e anômalos que demandam mais do que a especialização, pois apresentam complexidades que impedem sua resolução por qualquer profissional, ainda que especializado” (REsp 1444874/MG, 2.a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.02.2015, *DJe* 31.03.2015).

166

AgRg no AREsp 763.333/SP, 2.a Turma, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 03.11.2015, *DJe* 17.11.2015.

167

Para mais detalhes: Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 27.

168

José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 1114.

169

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 109.

170

“Embora sejam de categorias jurídicas diversas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista devem ser estudadas em conjunto, tanto são os pontos comuns que nelas aparecem. Como veremos, estas entidades são dotadas de personalidade jurídica de direito privado e delas se vale o Estado para

possibilitar a execução de alguma atividade de seu interesse com maior flexibilidade, sem as travas do emperramento burocrático indissociáveis das pessoas de direito público” (José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 495).

171

Para quem admite a existência desta figura. Sobre a polêmica confirmam-se José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 520 e Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, p. 183.

172

Para as empresas públicas, por exemplo: AgRg no Ag 104.674/RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4.a Turma, j. 12.08.1996, *DJ* 16.09.1996, p. 33751. Para as sociedades de economia mista, por exemplo: REsp 853.964/SE, rel. Min. José Delgado, 1.a Turma, j. 15.08.2006, *DJ* 14.09.2006, p. 294, REP *DJ* 07.11.2006, p. 272.

173

As funções de uma Missão diplomática consistem, entre outras, em: a) representar o Estado acreditante perante o Estado acreditado; b) proteger no Estado acreditado os interesses do Estado acreditante e de seus nacionais, dentro dos limites permitidos pelo direito internacional.

174

Neste sentido: “ESTADO ESTRANGEIRO. REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. ATRIBUIÇÕES DOS CÔNSULES. CONVENÇÕES DE VIENA. CASO DO ART. 105, II, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Nos termos da convenção de Viena de 1961, sobre relações diplomáticas, cabe ao embaixador representar o estado acreditante perante o estado acreditado; não ao cônsul, cujas atribuições limitam-se, de regra, aos planos administrativo, comercial e notarial. Não pode o cônsul, pois, outorgar mandado judicial em representação do estado estrangeiro, visando ajuizar demanda perante a justiça brasileira. Falta de legitimação para o processo. Aplicação do art. 13 do CPC” (Ag 11.771/RS, 4.a Turma, rel. Min. Bueno de Souza, rel. p/ Acórdão Min. Athos Carneiro, j. 20.04.1993, *DJ* 14.06.1993, p. 11785).

175

“O entendimento sedimentado por esta Corte é no sentido de que a Advocacia Geral da União (AGU) detém legitimidade para representar processualmente organismos internacionais. Isso porque a República Federativa do Brasil subscreveu acordo básico de assistência técnica com a Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do Decreto 59.308/1966, o qual enuncia que o governo brasileiro se responsabiliza pelas demandas em cujo polo passivo figurem os organismos internacionais” (RR – 2081-69.2010.5.10.0000, 6.a Turma, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, j. 05.06.2012, Data de Publicação: DEJT 15.06.2012).

176

As referências legislativas são ao CPC/1973, mas a ideia é a mesma: AgRg no REsp 703.654/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.a Turma, j. 01.09.2015, *DJe* 09.09.2015.

177

“O gestor não se torna, porém, o representante da sociedade em recuperação para todos os fins. Nos atos relativos à tramitação do processo de recuperação judicial, a sociedade devedora continuará sendo representada nos termos de seus atos constitutivos. Assim, destituídos, por exemplo, todos os diretores, caberá aos sócios da limitada ou ao órgão competente da anônima (Assembleia geral dos acionistas ou Conselho de Administração) a eleição dos substitutos. A esses competirá, por exemplo, apresentar o plano de recuperação (se ainda não havia sido apresentado), prestar informações ao administrador judicial ou ao juiz, apresentar os relatórios etc.” (Fábio Ulhoa Coelho, *Comentários à nova lei de falências e de recuperação judicial*, p. 176).

178

Jorge Lobo, *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*, p. 247.

179

“Com o desapossamento geral dos bens penhoráveis do devedor, presentes e futuros, forma-se a massa ativa do insolvente, que, como complexo de relações jurídicas, será administrada pelo órgão judicial denominado ‘administrador da massa’. Para atuar no cumprimento de obrigações do devedor ou na exigência de direitos dele, o administrador recebe da lei a outorga de uma representação legal da massa, que pode ser utilizada em juízo ou fora dele” (Humberto Theodoro Júnior, *A insolvência civil*, p. 326).

180

“Trata-se de um patrimônio sem titular atual, que deve ser administrado para devolver-se ao herdeiro que apareça, ou ao Estado” (Orlando Gomes, *Sucessões*, p. 77).

181

“Se não se apresentarem herdeiros, cônjuge ou companheiro no prazo de um ano, contado da primeira publicação do edital, a herança é, por sentença, declarada vacante” (Orlando Gomes, *Sucessões*, p. 78).

182

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 130.

183

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 112.

184

“Esta regra, já existente no direito anterior, é acertada, porque é de toda conveniência centralizar a representação em uma única pessoa, em vez de deixá-la diluída no conjunto de herdeiros. A não ser assim, seria extremamente difícil reunir todos os herdeiros, como autores, ou fazer citar todos eles como réus, nas ações referentes ao espólio. Essa regra se justifica também porque, normalmente, o

inventariante é meeiro ou herdeiro no espólio, e tem, portanto, interesse direto na defesa dos bens” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 110).

185

“A ressalva merece uma explicação: nos casos de inventariante dativo, os herdeiros são intimados para poder acompanhar o andamento do processo e, assim, poder fiscalizar a atuação do inventariante, que é pessoa estranha à família” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 318).

186

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 111.

187

“Antes de o Código Civil de 2002 entrar em vigor, o tratamento jurídico da sociedade civil e da associação era comum, o que fez com que uma parte da doutrina sustentasse não existir critério legal para a separação entre elas. Agora, a distinção legal é nítida não permitindo mais essa discussão. A associação é uma entidade sem fins econômicos (CC, art. 53) e a sociedade é destinada, precipuamente, ao exercício de uma atividade econômica (CC, art. 981). Sociedade sem fins lucrativos não é mais sociedade, mas associação” (Alfredo de Assis Gonçalves Neto, *Direito de empresas*, p. 143).

189

Neste sentido: “A ciência processual, em face dos fenômenos contemporâneos que a cercam, tem evoluído a fim de considerar como legitimados para estar em juízo, portanto, com capacidade de ser parte, entes sem personalidade jurídica, quer dizer, possuidores, apenas, de personalidade judiciária. No rol de tais entidades estão, além do condomínio de apartamentos, da massa falida, do espólio, da herança jacente ou vacante e das sociedades sem personalidade própria e legal, todos por disposição de lei, hão de ser incluídos a massa insolvente, o grupo, a classe ou a categoria de pessoas titulares de direitos coletivos, o PROCON ou órgão oficial do consumidor, o consórcio de automóveis, as Câmaras Municipais, as Assembleias Legislativas, a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário, quando defenderem, exclusivamente, os direitos relativos ao seu funcionamento e prerrogativas” (RMS 8.967/SP, 1.a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, rel. p/ Acórdão Min. José Delgado, j. 19.11.1998, DJ 22.03.1999, p. 54).

190

“Os entes despersonalizados, que são admitidos como parte, mas que não constam do rol do artigo. 75, serão representados ou apresentados em juízo por aquela pessoa que exerça as funções de administração, gerência, direção, liderança, conforme se constate no caso concreto. Exemplos: a Câmara de Vereadores será apresentada por seu presidente; a faculdade, por seu diretor; a tribo ou grupo tribal por seu cacique etc.” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 319).

191

“A partir do art. 987 pode-se dizer que a sociedade em comum insuscetível de comprovação escrita é uma sociedade de fato, que se caracteriza pela circunstância de os sócios não terem como invocar as relações

jurídicas que possam ter ajustado entre si ou com terceiros. Dela diferencia-se a sociedade irregular, também sociedade em comum, porque sem registro, em que há prova escrita de sua existência (contrato ou qualquer outro documento que revele o ajuste), que faculta aos sócios invocar as relações jurídicas documentadas entre si ou havidas com terceiro” (Alfredo de Assis Gonçalves Neto, *Direito de empresas*, p. 143).

192

“A regra é ser o condomínio administrado por todos os condôminos. Se alguém administra sem oposição dos outros, administrador é, por presunção. Supõem-se, aí, atos do condômino que revelam estar administrando e, da parte dos outros, carência de qualquer ato, positivo ou negativo, que se interprete como contrário a esses atos. De modo nenhum se permitiu ao condômino assumir, a seu talante, a administração” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 318).

193

Compete ao síndico, com efeito, “representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns” (art. 1.348, Código Civil).

194

“Trata-se de apresentação, não de representação, salvo se os estatutos atribuam aos órgãos poderes de outorgar representação, ou se, não podendo exercer a função de órgão na propositura e na defesa em ações, é de entender-se que têm de outorgar tais poderes. Aí, o órgão que apresenta faz alguém representar” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 304).

195

Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 64.

196

“Daí propendermos para a teoria da constituição: se a nacionalidade da pessoa moral traduz a sua subordinação a uma ordem jurídica determinada, ou a sua dependência originária a um ordenamento legal, o que se tem a examinar é a sua articulação com a ordem jurídica que presidiu a sua criação” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 283).

197

“Sendo predominante o critério do lugar da constituição, não tem influência a nacionalidade dos membros componentes, nem o controle financeiro, pois que, se indivíduos de nacionalidades diferentes associam-se para criar uma pessoa jurídica, com igualdade de participação nos haveres sociais, o critério do local da constituição afasta o problema, totalmente insolúvel, dos indivíduos ou da predominância daquele que detém a maioria do capital” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 284).

198

REsp 1168547/RJ, 4.a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.05.2010, *DJe* 07.02.2011.

199

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 123.

200

Neste sentido, com mais detalhes: Cesar Pereira, *Convênio para representação judicial entre os entes da Federação* (art. 75, § 4.º, do CPC. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 10, p. 82).

201

Qual procuradoria receberá os honorários? Qual erário irá pagá-los, se perder a Fazenda? Haverá algum sistema de compensação etc.?

202

Salvo, obviamente, em hipóteses excepcionais como a de deferimento de tutela de urgência. Mas não é este o caso.

203

“Exigir-se que o pronunciamento jurisdicional tenha apoio tão somente em elementos sobre os quais as partes tenham tido a oportunidade de manifestarem-se significa evitar a decisão surpresa no processo” (Daniel Mitidiero, *Colaboração no processo civil*, p. 146).

204

“Die Partei müssen sich zu den rechtlichen Gesichtspunkten, auf die das Gericht seine Entscheidung stützen will, äußern können. Überraschungsentscheidungen sollen auf diese Weise vermieden werden” (Jauernig; Hess, *Zivilprozessrecht*, p. 100).

205

Daniel Mitidiero, *Colaboração no processo civil*, p. 145.

206

“Die Pflicht zum Hinweis auf Zulässigkeitsbedenken (III) bezieht sich auf Prozess- und Rechtsmittelvoraussetzungen. Sie soll ebenfalls Überraschungsentscheidungen vermeiden und belegt, dass das Gericht diesbezüglich nicht eigene Untersuchungen und Nachforschungen anzustellen, sondern den Parteien Gelegenheit zu geben hat, ggf. den Zulässigkeitsmangel zu beheben (BGH MDR 2006, 1250/1) und die erforderliche Nachweise zu erbringen (BGH NJW 89, 2064/5)” (Reinhart Greger, *Zivilprozessordnung* (Zöller), p. 663).

207

“Die Partei, deren Parteifähigkeit im Streit ist, ist zur Erledigung dieses Streits und namentlich zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen das Urteil, mag dieses ihre Parteifähigkeit bejaht oder verneint haben, parteifähig. Daher darf das von ihr eingelegte Rechtsmittel, selbst wenn erst die höhere Instanz die Parteifähigkeit verneinen will, nicht wegen des Mangels der Parteifähigkeit als unzulässig verworfen werden. Verneint das Rechtsmittelgericht die Parteifähigkeit wie die Vorinstanz, ist das Rechtsmittel unbegründet; verneint es sie erstmals, wird die Sachentscheidung aufgehoben und die klage durch Prozessurteil abgewiesen” (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 217).

208

Salvo, obviamente, em hipóteses excepcionais como a de deferimento de tutela de urgência. Mas não é este o caso.

209

Por exemplo: “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a intimação para sanar vício de representação deve ser feita em nome da parte, pessoalmente, e não em nome do advogado, que não se sabe, até então, se realmente a representa. Precedentes. A intimação por órgão da imprensa oficial não tem o condão de validar o despacho proferido pelo juiz para a regularização do defeito, inclusive, para o efeito de tornar preclusa a oportunidade não observada pela parte interessada” (AgRg no REsp 1119836/PR, 3.a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 07.08.2012, *DJe* 13.08.2012).

210

Belehrung. Wie in Abs. 1 klar zum Ausdruck kommt, muss auch der Hinweis nach Abs. 2 konstruktiv sein. Deshalb ist der Richter bei behebbaren Mängeln der Prozess-oder Rechtsbehelfsvoraussetzungen verpflichtet, der Partei die Möglichkeit zur Abhilfe aufzuzeigen (Claus Wagner, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1075).

211

Namentlich ist auch hier die Prozessfähigkeit prozessfähig, nicht auch zur Verhandlung in der Sache selbst (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 223).

212

Die Partei, deren Parteifähigkeit im Streit ist, ist zur Erledigung dieses Streits und namentlich zur Einlegung von Rechtsmitteln gegen das Urteil, mag dieses ihre Parteifähigkeit bejaht oder verneint haben, parteifähig. Daher darf das von ihr eingelegte Rechtsmittel, selbst wenn erst die höhere Instanz die Parteifähigkeit verneinen will, nicht wegen des Mangels der Parteifähigkeit als unzulässig verworfen werden. Verneint das Rechtsmittelgericht die Parteifähigkeit wie die Vorinstanz, ist das Rechtsmittel unbegründet; verneint es sie erstmals, wird die Sachentscheidung aufgehoben und die klage durch Prozessurteil abgewiesen (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 217).

213

Arruda Alvim Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 152.

214

Daí por que superados o enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, e, de modo geral, o entendimento de que “inaplicável, nesta instância [especial], a providência prevista no art. 13 do CPC [de 1973], considerando-se não sanável tal vício por juntada posterior de mandato ou substabelecimento, pois a regularidade da representação processual é aferida no momento da interposição do recurso especial” (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 636.058/MT, 3.a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.02.2016, DJe 12.02.2016).

215

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 124.

216

Teresa Arruda Alvim Wambier, *Os agravos no CPC brasileiro*, p. 340.

217

Por exemplo: “O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada – seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 137).

218

“No âmbito do sistema recursal o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal tem aplicação ainda mais contundente. Está arraigado no espírito do CPC...” (Pedro Miranda de Oliveira, *Novíssimo sistema recursal conforme o CPC*, p. 84).

219

Por exemplo, mais recentemente: Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 514; Musielak; Voit, *Grundkurs ZPO*, p. 94; e Eberhard Schilken, *Zivilprozessrecht*, p. 156.

12

No famoso caso *Roe vs. Wade*, de 1973, julgado pela Suprema Corte americana, “Roe” é um nome fictício, o que se fez para preservar a real identidade da autora.

21

Para mais detalhes: Robson Godinho, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral/Cramer), p. 120.

35

Sobre a legitimidade extraordinária, especialmente a convencional: Renato Beneduzi, Legitimidade extraordinária convencional, *Revista Brasileira de Direito Processual*, vol. 86, p. 134. Também Fredie Didier Jr., Fonte normativa da legitimação extraordinária no Novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 167 e Daniela Santos Bonfim, A legitimidade extraordinária de origem negocial. In: *Coleção Grandes Temas do Novo CPC* (negócios processuais), p. 335.

66

De 1931 para cá o direito de família mudou radicalmente na Alemanha, por óbvio (hoje a regra, conforme § 1.414 BGB, é a separação de bens – *Gütertrennung*). Mas a definição que Kipp; Wolff dão ao patrimônio comum (*Gesamtgut*) é ainda eloquente: “Ihr Grundgedanke ist der Parallelismus innigster Lebensverbindung und vollster Vermögensverbindung: Leib an Leib, Gut an Gut’. Alles Vermögen, das ein Gatte in die Ehe eingebracht hat oder das er in der Ehe erwirbt, wird gemeinschaftliches Vermögen beider Ehegatten zur gesamten Hand (Vermögen des Ehepaars), Gesamtgut” (Kipp; Wolff, *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*, vol. 4, p. 238).

83

Ou mesmo a título gratuito, se a comunhão for universal. Mas o ponto é que a exigência de consentimento perde sentido se a ação disser respeito a um bem que não integra o patrimônio comum.

87

Sobre a legitimidade extraordinária, especialmente a convencional: Renato Beneduzi, Legitimidade extraordinária convencional, *Revista Brasileira de Direito Processual* 86 (2014), p. 134. Também Fredie Didier Jr., Fonte normativa da legitimação extraordinária no Novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 167 e Daniela Santos Bonfim, A legitimidade extraordinária de origem negocial. In: *Coleção Grandes Temas do Novo CPC* (negócios processuais), p. 335.

89

Sobre o ponto, com razão: Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 62 e Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 123.

93

Em sentido contrário: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 321.

96

“O sistema do *numerus clausus* se manifesta de dois modos. De um lado, significa a taxatividade das figuras típicas, isto é, a reserva legal para a criação dos direitos subjetivos. De outro, revela-se no princípio da tipicidade propriamente dito, analisado sob o prisma de seu conteúdo, no sentido de que a estrutura do direito subjetivo deva corresponder à previsão legislativa típica” (Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 3, p. 488).

105

Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 3, p. 488.

113

Ovídio Baptista chega a dizer que “ante a incontornável ambiguidade da proposição legal, não vemos como possa o intérprete fixar abstratamente o campo de sua abrangência, tarefa que deverá ser confiada ao juiz, que a estabelecerá segundo as circunstâncias do caso concreto” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 90).

122

Neste sentido, também Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 93.

126

Sobre os reflexos deste debate para o direito processual: Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 88.

131

Sobre a liceidade do tratamento distinto, em certos casos, do casamento e da união estável: “Mostra-se de extrema relevância para a construção de uma jurisprudência consistente acerca da disciplina do casamento e da união estável saber, diante das naturais diferenças entre os dois institutos, quais os limites e possibilidades de tratamento jurídico diferenciado entre eles. Toda e qualquer diferença entre casamento e união estável deve ser analisada a partir da dupla concepção do que seja casamento – por um lado, ato jurídico solene do qual decorre uma relação jurídica com efeitos tipificados pelo ordenamento jurídico, e, por outro, uma entidade familiar, dentre várias outras protegidas pela Constituição. Assim, o casamento, tido por entidade familiar, não se difere em nenhum aspecto da união estável – também uma entidade familiar –, porquanto não há famílias timbradas como de ‘segunda classe’ pela Constituição Federal de 1988, diferentemente do que ocorria nos diplomas constitucionais e legais superados. Apenas quando se analisa o casamento como ato jurídico formal e solene é que as diferenças entre este e a união estável se fazem visíveis, e somente em razão dessas diferenças entre casamento – ato jurídico – e união estável é que o tratamento legal ou jurisprudencial diferenciado se justifica” (REsp 1299866/DF, 4.a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25.02.2014, *DJe* 21.03.2014).

188

A distinção, aliás, à luz do critério da finalidade econômica precípua (não exclusiva, porque se admite que a associação desenvolva *atividades econômicas acessórias* – wirtschaftlicher Nebenbetrieb), é tradicional

no direito alemão (§ 21 do BGB). Por exemplo: Bei den inländischen Vereinen wird danach unterschieden, ob ihr Zweck auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist oder nicht (*Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB*, p. 454). Medicus dá o exemplo da cantina administrada por uma associação esportiva para ilustrar a prática de atividade econômica acessória por associações (Idealverein, em contraposição à Wirtschaftsverein) (*Dieter Medicus, Allgemeiner Teil des BGB*, p. 455).

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I - DAS PARTES E DOS PROCURADORES

CAPÍTULO II - DOS DEVERES DAS PARTES E DE SEUS PROCURADORES

Seção I Dos deveres

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I – expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II – não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III – não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV – cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V – declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI – não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

§ 1.º Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2.º A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3.º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2.º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97.

§ 4.º A multa estabelecida no § 2.º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1.º, e 536, § 1.º.

§ 5.º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2.º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 6.º Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2.º a 5.º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará.

§ 7.º Reconhecida violação ao disposto no inciso VI, o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior, podendo, ainda, proibir a parte de falar nos autos até a purgação do atentado, sem prejuízo da aplicação do § 2.º.

§ 8.º O representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar.

Direito anterior – art. 14 do CPC/1973.

Direito comparado – § 139 da ZPO alemã, § 242 do BGB alemão, art. 88 do c.p.c. italiano, art. 247 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 266-a do CPC português.

1. Dignidade da justiça, boa-fé processual objetiva e litigância de má-fé. A maneira relativamente confusa e assistemática com que o Código de Processo Civil trata os deveres das partes e dos demais sujeitos do processo reflete o ecletismo com que o direito processual brasileiro bebeu de fontes estrangeiras para regular a matéria. Enquanto a repressão tradicional à litigância de má-fé *subjetiva* ¹ deve-se à influência lusitana ² e a tutela *objetiva* da boa-fé processual (*Treu und Glauben im Zivilprozess* ³) à alemã, filia-se a proibição da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça à tradição do *common law* (*contempt of court* ⁴). Neste último caso, a preocupação central da lei é garantir o bom andamento do processo e preservar a própria autoridade do juiz (tutela do interesse público), ao passo que nos dois primeiros é proteger a parte prejudicada de uma conduta processual antijurídica, culposa *lato sensu* ou independentemente de culpa, conforme o caso (tutela do interesse privado das partes). A diversidade de funções justifica o tratamento diferenciado que a lei dá, ainda que de modo um tanto quanto desorganizado, a cada um destes institutos, explica também por que grassa tanta confusão na doutrina e na jurisprudência sobre o assunto.

2. O ato atentatório à dignidade da justiça (*contempt of court*) ⁵. A tutela processual da dignidade da justiça serve ao juiz como instrumento que lhe permite dissuadir ou punir condutas que de algum modo obstruam, tumultuem ou prejudiquem o bom andamento do processo. Seu escopo é, por isso, a tutela de um interesse público (a administração da justiça ⁶). A repressão ao ato atentatório à dignidade da justiça no processo civil brasileiro tem, assim, natureza apenas *coercitivo-punitiva*, sem a dimensão criminal ou compensatória que caracterizam o *punitive contempt* e o *compensatory contempt* norte-americanos. ⁷

Os sujeitos do processo têm, em outras palavras, o *dever* de não obstruir, tumultuar ou prejudicar o bom andamento do processo. A violação deste dever – o ato atentatório à dignidade da justiça – é tipificada pelo CPC em diversas de suas passagens, não apenas nos incs. IV e VI do art. 77, para os quais são “*deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo*”, respectivamente, o de “*cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação*” e o de “*não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso*” (atentado). ⁸ Segundo o art. 334, § 8.º, por exemplo, também “*o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado*”, enquanto o art. 161, parágrafo único, dispõe que “*o depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça*”. Algumas das hipóteses de litigância de má-fé tipificadas no art. 80 são também casos de atos atentatórios à dignidade da justiça.

Mas é preciso ter sempre em mente que os atos atentatórios à dignidade da justiça não se esgotam nas hipóteses expressamente tipificadas pela lei. Qualquer conduta que de algum modo obstrua, tumultue ou prejudique o bom andamento do processo pode vir a ser enquadrada pelo juiz como *contempt of court*, independentemente do dano que esta conduta possa vir ou não a causar. Mas o dolo, a vontade consciente de obstruir, tumultuar ou prejudicar o bom andamento do processo, será *sempre* indispensável para a configuração do ato atentatório à dignidade da justiça. ⁹ É exatamente o seu elemento subjetivo, com efeito, que torna o *contempt* reprovável e merecedor de censura judicial e é exatamente para que não parem dúvidas sobre o dolo do *contemnor* (daquele que pratica o *contempt*) que o juiz deve, quando esta advertência fizer sentido, adverti-lo de que deve *parar* o que estiver fazendo antes de impor a multa (parágrafo primeiro). Se a parte emprega uma expressão ofensiva em audiência, por exemplo, não está imediatamente em *contempt*, necessariamente. Mas se, mesmo advertida, insistir em repeti-la, estará. Mas tudo depende, obviamente, da gravidade da ofensa. Em certos casos mais extremos, nada impede o juiz de reconhecer logo o caráter atentatório do ato. ¹⁰ É esta dimensão essencialmente subjetiva que

justifica, ademais, a existência da regra segundo a qual “o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir decisão em seu lugar” (parágrafo oitavo).

A autonomia da tutela da dignidade da justiça é evidenciada pela circunstância de que a lei determina a imposição da multa “sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis” (parágrafo segundo) e “independentemente da incidência das [multas] previstas nos arts. 523, § 1.º, e 536, § 1.º” (parágrafo quarto).¹¹ A multa deve ser fixada pelo juiz em “até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta” (parágrafo segundo), com a ressalva de que “quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2.º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo” (parágrafo quinto) sempre à luz de sua função coercitivo-punitiva. O destinatário da multa não será nunca a parte eventualmente prejudicada pela conduta (diferentemente do que acontece na litigância de má-fé), mas sempre o Estado. Daí por que “não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2.º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97” (parágrafo terceiro).¹²

Observe-se que a multa torna-se exigível quando do trânsito em julgado da decisão que a fixou, não do trânsito em julgado da sentença que julgar a demanda em cujo processo esta decisão vier a ser deferida.¹³ Mas a reforma posterior da decisão que fixou a multa com fundamento na prática de ato atentatório não retira necessariamente sua exigibilidade. Será o caso, obviamente, se se entender no julgamento do recurso que o próprio *contempt of court* não se materializou. Aquele que descumpre uma ordem judicial de não fazer alguma coisa, por exemplo, ainda que depois esta ordem deixe de subsistir porque cassada em grau de recurso, não terá deixado de estar em *contempt* enquanto a ordem esteve em vigor. Como a preocupação aqui é a tutela da dignidade da justiça e do bom andamento do processo, e não a reparação de um prejuízo que a outra parte possa ter sofrido, a multa continuará exigível.¹⁴ O contrário significaria estimular o *contemnor* a não cumprir a ordem na esperança de eventualmente reformá-la, o que não seria razoável. Sobre as consequências da imposição desta multa aos beneficiários de gratuidade de justiça, por fim, confirmam-se os comentários ao art. 99.

Ao contrário do que se passa na Inglaterra e nos Estados Unidos, a tutela da dignidade da justiça não permite também ao juiz brasileiro determinar a prisão do *contemnor*. Falta-lhe em primeiro lugar (e este motivo já basta) expressa autorização legal para fazê-lo. *De lege ferenda*, entretanto, sua adoção poderia revelar-se benfazeja, especialmente à luz da notória ineficiência dos instrumentos hoje à disposição do juiz para assegurar o respeito à dignidade da justiça. A mera ameaça de prisão seria muitíssimo mais eficaz contra a *rebeldia* do *contemnor* do que a vaga possibilidade de execução fiscal de uma multa quando do trânsito em julgado da decisão que a tiver fixado. Sua adoção seria constitucional, ademais, porque não seria caso nem de prisão por dívida, o que a Constituição proíbe em seu art. 5.º, LXVII, nem tampouco de prisão-sanção decretada por juiz sem competência criminal e sem a observância das garantias de que desfruta o réu no processo penal. Sua natureza seria puramente coercitiva e ela deveria durar apenas o tempo necessário para que se fizesse cumprir a ordem descumprida. O que a ordem constitucional proíbe, em outras palavras, é a *punitive contempt*,¹⁵ não a prisão fundada na *coercive contempt*.¹⁶

É também de se lamentar, *de lege ferenda*, a previsão expressa de que “aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2.º a 5.º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará” (inc. VI). A exclusão não faz sentido, até porque os deveres de que trata o art. 77 “são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo”. Não raro, o dolo de cometer o ato atentatório à dignidade da justiça não é da parte, mas de seu representante ou representante legal. A censura à violação dos deveres processuais seria muitíssimo mais eficaz se também aqueles responsáveis diretamente pelo andamento do processo, mesmo que instruídos ou supervisionados por seus clientes ou por instâncias superiores nos órgãos que apresentam, pudessem vir a ser por ela atingidos quando tiverem dado causa dolosamente à violação de um dever processual.

Viola o dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação” (inc. IV) aquele que, deliberadamente, deixa de dar cumprimento a uma ordem judicial qualquer. Por deliberadamente se quer dizer que o reconhecimento do ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a falta de justa causa, que nada mais é do que a inexistência de algum motivo razoável que possa justificar por que a decisão não pôde ser cumprida.¹⁷ A razoabilidade da escusa deve ser aferida casuisticamente. Mas o dever de cumprir as decisões judiciais – a que estão obrigados todos os sujeitos do processo, não apenas as partes (como o terceiro a que se determinou, por exemplo, que removesse de sua rede social determinado conteúdo ofensivo a alguém) – não abrangerá nunca o cumprimento de obrigação pecuniária (quantia certa). Seria arbitrário exigi-lo, porque aí o interesse tutelado é inteiramente privado (da parte prejudicada). Quem não cumpre uma obrigação pecuniária está em mora, e deve sofrer apenas as sanções decorrentes desta mora.

Ocorre atentado quando se viola o dever de “não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso” (inc. VI). Atentado, com efeito, é “a criação de situação nova, ou a mudança de status quo, pendente a lide, lesiva à parte e sem razão de direito”.¹⁸ O art. 879 do CPC/1973, embora não reproduzido no código atual, dá dois exemplos ainda atuais de atentado: quando “se viola penhora, arresto, seqüestro ou imissão na posse” (inc. I) e quando se “prossegue em obra embargada” (inc. II). Como ilustra Pontes de Miranda, com a ressalva de que as remissões legislativas que ele faz se referem ao CPC/1973, “comete atentado, por exemplo: a parte que retira do depositário a coisa constrita (arrestada, sequestrada, penhorada); a parte que, embora continue com ela o bem arrestado, sequestrado, ou penhorado (arts. 664, 666, 821 e 823), dele dispõe, ou a respeito dele pratica ato ou atos que não podia praticar; a parte, na ação de demarcação ou de divisão, se procede como se não tivesse de aguardar a sentença (e.g., corta árvores, devasta mata); a parte que, em ação de nunciação de obra nova, desobedece ao embargo extrajudicial (art. 935), ou ao embargo judicial, liminar (art. 937), ou não (art. 938)”.¹⁹ Reconhecido o atentado, “o juiz determinará o restabelecimento do estado anterior” (parágrafo sétimo), sem prejuízo da imposição de multa nos termos do parágrafo segundo. A proibição de “a parte de falar nos autos até a purgação do atentado”, no entanto, é uma relíquia de outros tempos²⁰ que não é mais compatível com a garantia constitucional do contraditório.

3. A boa-fé processual objetiva e a litigância de má-fé. O processo civil brasileiro reprime a litigância de má-fé, tradicionalmente, à luz da responsabilidade subjetiva do agente.²¹ Neste aspecto, manteve-se fiel a suas origens lusitanas.²² O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, consagra em seu art. 5.º expressamente, o que não fazia o de 1973, um dever processual *objetivo* de boa-fé, à moda alemã (*Treu und Glauben im Zivilprozess*),²³ a cujo respeito *todos* os sujeitos do processo estão obrigados, mesmo o próprio juiz.²⁴ A observância deste dever diz respeito essencialmente ao interesse privado das partes, não ao interesse público que o *contempt of court* serve para tutelar.

A adoção pelo processo civil brasileiro desta cláusula geral (*Generalklausel*) processual de boa-fé²⁵ revoluciona o tratamento tradicionalmente dado à violação pelos sujeitos do processo de deveres processuais. No âmbito da tutela da boa-fé processual, que não se confunde com a tutela da dignidade da justiça de que se falou no item anterior, a regra tornou-se a responsabilização objetiva,²⁶ ²⁷ salvo quando alguma razão especial justificar o tratamento diferenciado de determinada hipótese (por exemplo, no dever de falar a verdade de que se tratará mais adiante). E isso pelo mesmo motivo que explicou a evolução da responsabilidade civil no direito privado: “campo fértil aos debates e aos litígios, a responsabilidade civil tem procurado libertar-se do conceito tradicional de culpa. Esta é, às vezes, constritora e embaraça com frequência a expansão da solidariedade humana. A vítima não consegue, muitas vezes, vencer a barreira processual, e não logra convencer a Justiça dos extremos da imputabilidade do agente. Desta sorte, continuando, embora, vítima, não logra o ressarcimento”.²⁸ Sem falar no caráter também dissuasório da responsabilidade civil objetiva. A boa-fé objetiva é, assim, uma norma de conduta, que “impõe e proíbe condutas, além de criar situações jurídicas ativas e passivas”,²⁹ independentemente de qualquer tipificação legal. “Em verdade, não seria necessária qualquer enumeração das condutas desleais: o art. 5.º do CPC é bastante, exatamente por tratar-se de uma cláusula geral”.³⁰

A tutela da boa-fé processual manifesta-se fundamentalmente de dois modos: mediante a repressão da violação de deveres expressamente tipificados pela lei (nos incs. I, I e III do art. 77, por exemplo, ou ainda no art. 80) e também através da punição do exercício abusivo de direitos processuais, “*posto que em si mesmos legítimos*”³¹ estes direitos (por exemplo, na proibição do *venire contra factum proprium* ou da *Verwirkung* no processo³²) e mesmo sem expressa previsão legal que a determine.³³ O mais importante, de todo modo, é a consciência de que o reconhecimento da violação da boa-fé não depende de um enquadramento análogo ao que se faz no direito penal da conduta do sujeito em um determinado tipo legal. É preciso, em síntese, eliminar todos os resquícios *criminóides*, se se permite o neologismo, do regramento legal da tutela processual da boa-fé. O que se exige dos sujeitos do processo é a obediência “*a um padrão de conduta que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e contrária à equidade*”, como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.³⁴

4. Dever de falar a verdade. O primeiro dever a que alude o art. 77 é o de expor os fatos (apenas os fatos, não o direito) em juízo conforme a verdade (*Wahrheitspflicht*).³⁵ Sua função é a de proibir a mentira consciente e deliberada (*Lügeverbot* ³⁶), razão pela qual sua tipificação dependerá sempre da comprovação da *vontade de enganar* (má-fé, subjetiva). “*A regra é a de que o litigante deve, subjetivamente, crer no que afirma*”.³⁷ Esta é uma exceção à regra segundo a qual deve ser *objetiva* a tutela da boa-fé processual. Pode-se mentir afirmando-se verdadeiro algo que se sabe que é falso, falso algo que se sabe verdadeiro. Mas viola o dever de falar a verdade também aquele que conta apenas uma parte da verdade. Não se permite, assim, narrar os detalhes favoráveis e, *em relação ao mesmo fato*, esconder os desfavoráveis. Este o dever de completude (*Pflicht zur Vollständigkeit* ³⁸) ou ainda a proibição da meia-verdade (*Verbot der Halbwahrheit* ³⁹).

Mas dizer a verdade não equivale a exigir o “dever de acertar, de não cometer equívocos ou ainda de conhecer a verdade objetiva, de saber dos fatos tais como realmente são”,⁴⁰ nem equivale tampouco ao dever de revelar a existência de fatos que lhe possam ser contrários (nos moldes da *discovery* norte-americana⁴¹). “Por outro lado, não se exige que a falsa alegação seja feita com algum propósito específico; a alteração reputa-se ‘intencional’ desde que o litigante a faça consciente e voluntariamente”.⁴² O processo civil brasileiro continua fiel, e deve continuar assim, à máxima de que “*nemo tenetur edere contra se*” (ninguém é obrigado no processo a ir contra si mesmo, da qual decorre, por exemplo, o princípio de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si próprio).

5. Abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual⁴³). Demandar e defender-se (e todos os direitos processuais daí decorrentes, como o de recorrer, de falar em juízo, de produzir provas etc.) são direitos cujo exercício a cláusula geral da boa-fé processual não permite ser *abusivo*.⁴⁴ Esta ideia – de que não se admite o exercício abusivo de direitos – permeia, com efeito, todo o ordenamento jurídico.⁴⁵ O art. 77, em seus incs. II e III, dá dois exemplos⁴⁶ deste exercício abusivo de posições processuais ao enunciar os deveres de “*não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento*” (inc. II) e de “*não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito*” (inc. III).

O reconhecimento da chicana processual (abuso do direito de demanda ou de defesa) não pressupõe, com efeito, a demonstração subjetiva de má-fé, da vontade consciente de cometer o abuso (*animus nocendi* ⁴⁷). Basta que a conduta da parte possa ser *objetivamente* definida como processualmente *abusiva* porque contrária à boa-fé objetiva. E isso porque “*a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional*”.⁴⁸ O mero equívoco ou a ignorância sobre as regras processuais e materiais aplicáveis, no entanto, não se confundem com o exercício abusivo de uma posição processual. Demandar uma pretensão prescrita, porque o prazo prescricional correto é de três anos, não de dez, por exemplo, pode ser entendido como incompetência do advogado que instruiu mal seu cliente. Mas não é chicana. Também “*litigar contra a ratio decidendi do precedente vinculante, sem ressalva alguma*”,⁴⁹ ou interpor um recurso

especial inadmissível, por exemplo, em razão da falta de “esgotamento de instância”.⁵⁰ Consistem em erro técnico, cuja reparação a parte prejudicada pode reclamar de seu advogado, mas também não é chicana.

Se a parte pede insistentemente, ao contrário, a juntada aos autos de novos documentos, com a nítida finalidade (objetivamente considerada) de tumultuar o trâmite do processo, será o caso de chicana. Se insistir em recolocar em discussão questões processuais preclusas, ao argumento de que se trata de questões de ordem pública, será o caso de chicana. Se opuser sucessivos embargos de declaração manifestamente infundados da mesma decisão, será o caso de chicana. Mas tudo depende de uma análise casuística, porque a conduta só pode ser definida com segurança como abusiva em um determinado caso concreto, nunca em tese. De todo modo, esta verificação independerá da demonstração de má-fé. Basta a transgressão *objetivamente* considerada daquilo “que legitimamente é esperado de cada parte”,⁵¹ exatamente porque o que se exige dos sujeitos do processo, como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é a obediência “a um padrão de conduta que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e contrária à equidade”.⁵²

6. Endereço para intimações. O art. 77 estabelece também, em seu inc. V, o dever de “declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”. Este dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 246, § 1.º, segundo o qual “com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. São inovações que contribuirão decisivamente para tornar mais eficiente a administração da justiça e eliminar alguns dos gargalos que comprometem a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 5.º, LXVIII, da CF).

Art. 78. É vedado às partes, a seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados.

§ 1.º Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra.

§ 2.º De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas e, a requerimento do ofendido, determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada.

Direito anterior – art. 15 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 89 do c.p.c. italiano e art. 266-b do CPC português.

1. Dever de urbanidade. Os sujeitos do processo, todos eles (partes, juiz etc.), têm o dever de tratar os demais com *urbanidade*. Neste contexto, urbanidade significa cortesia, civilidade, respeito. Daí por que a lei proíbe o emprego de “*expressões ou condutas ofensivas*” ao longo de todo o processo, por escrito ou verbalmente. A urbanidade não deve ser compreendida, no entanto, à luz dos conceitos pertencentes ao direito criminal de “*calúnia, injúria ou difamação*”.⁵³ Andou bem assim o CPC em se referir a “*expressões ofensivas*”, não mais a “*expressões injuriosas*” como fazia o art. 15 do CPC/1973. São coisas diferentes. Dizer-se que o réu é *desonesto*, que a testemunha *mentiu*, ou que a autora *traiu* seu marido é fazer afirmações ofensivas, mas que não violam o dever de urbanidade. O problema não é a *ofensa* em si, mas o uso de *expressões ofensivas*. Diferente seria dizer que o réu é um “*safado*”, que a testemunha é um “*picareta*” ou que a autora é uma “*vagabunda*” ou algo pior. Mesmo agressões não verbais podem enquadrar-se no conceito de “*expressões ofensivas*”. É o caso, por exemplo, do uso de gestos ofensivos em audiência.

O processo, em síntese, deve ser conduzido com *fair play*, mas a urbanidade não pode se tornar um pretexto para impedir a parte de expor seus argumentos em juízo da maneira e com a

extensão que entende apropriado. Deve apenas fazê-lo com civilidade. Daí por que a urbanidade não diz respeito, a rigor, ao conteúdo, mas sim à forma com que se expressa o sujeito do processo.

O emprego de expressões ofensivas é também uma agressão à parte ofendida, mas, acima de tudo, um ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77). Por isso pode o juiz repreendê-lo mesmo *de ofício* (parágrafo segundo). Se as expressões ofensivas forem proferidas por escrito, o juiz deve determinar que elas sejam *riscadas* dos autos do processo. “A *riscadura* há de ser completa e eficiente, isto é, do todo e sem que permaneça qualquer parte do enunciado ou dos enunciados ofensivos”.⁵⁴ Se eletrônicos os autos, os sistemas informatizados dos tribunais devem permitir a *redaction* do trecho em questão.⁵⁵ Se proferidas oralmente, “o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra” (parágrafo primeiro). A cassação da palavra, de todo modo, é medida de que deve se valer o juiz apenas em circunstâncias excepcionais. Ela se justificará, por exemplo, quando o ofensor insistir na ofensa, séria (um palavrão, por exemplo, não apenas um comentário irônico ou mordaz), a despeito de expressamente advertido de que deveria cessar a agressão. Mas não há nada de inconstitucional, em si, na possibilidade de cassação⁵⁶. Tudo isso, ademais, sem prejuízo da imposição de multa por *contempt of court*, nos termos do disposto no art. 77, se o juiz também a entender justificável à luz da gravidade da conduta do *contemnor*. Como o uso da expressão ofensiva pode constituir também um ilícito civil ou mesmo criminal, a parte prejudicada tem o direito de obter “*certidão com inteiro teor das expressões ofensivas*” (parágrafo segundo). Este dispositivo é especialmente útil se proferidas as ofensas oralmente ou apenas por gestos.

Seção II Da responsabilidade das partes por dano processual

Art. 79. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente.

Direito anterior – art. 16 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 96 do CPC italiano, art. 247 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 457 do CPC português.

1. Responsabilidade civil processual

Segundo dispõe o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Quando subjetiva a responsabilidade civil, são seus elementos “i) conduta dolosa ou culposa contrária à norma jurídica, ii) dano; e iii) nexo de causalidade entre a conduta e o dano”⁵⁷. Na responsabilidade objetiva, diferentemente, o dever de reparar nasce “com a abstração da ideia de culpa, estabelecendo-se *ex lege* a obrigação de reparar o dano, desde que fique positivada a autoria de um comportamento, sem necessidade de se indagar se foi ou não foi contrário à predeterminação de uma norma”.⁵⁸ São esses mesmos princípios que regem a responsabilidade civil de uma parte pelos danos que causar a outra *no processo*. Daí se falar em responsabilidade civil processual. Nela, a preocupação da lei não é garantir o bom andamento do processo e preservar a autoridade do juiz (tutela do interesse público na boa administração da justiça), como na repressão ao ato atentatório à dignidade da justiça (sobre ele, confirmam-se os comentários ao art. 77), mas sim o interesse privado da parte lesada na reparação do dano processual sofrido.

2. A boa-fé processual objetiva

O processo civil brasileiro reprime a litigância de má-fé, tradicionalmente, à luz da responsabilidade subjetiva do agente.⁵⁹ Nesse aspecto, tem se mantido fiel a suas origens lusitanas.⁶⁰ O Código de Processo Civil de 2015, no entanto, consagra em seu art. 5.º, expressamente, o que não fazia o de 1973, um dever processual *objetivo* de boa-fé, à moda alemã (*Treu und Glauben im Zivilprozess*)⁶¹, a cujo respeito todos os sujeitos do processo estão obrigados, mesmo o próprio juiz.⁶² A adoção pelo processo civil brasileiro desta cláusula geral

(*Generalklausel*) processual de boa-fé⁶³ revoluciona o tratamento tradicionalmente dado à violação pelos sujeitos do processo de deveres processuais. No âmbito da tutela da boa-fé processual, que não se confunde com a tutela da dignidade da justiça, a regra tornou-se a responsabilização objetiva^{64 - 65}, salvo quando alguma razão especial justificar o tratamento diferenciado de determinada hipótese (por exemplo, no dever de falar a verdade). E isso pelo mesmo motivo que explicou a evolução da responsabilidade civil no direito privado: “campo fértil aos debates e aos litígios, a responsabilidade civil tem procurado libertar-se do conceito tradicional de culpa. Esta é, às vezes, constritora e embaraça com frequência a expansão da solidariedade humana. A vítima não consegue, muitas vezes, vencer a barreira processual, e não logra convencer a Justiça dos extremos da imputabilidade do agente. Desta sorte, continuando, embora, vítima, não logra o ressarcimento”.⁶⁶ Sem falar no caráter também dissuasório da responsabilidade civil objetiva. A boa-fé objetiva é, assim, uma norma de conduta, que “impõe e proíbe condutas, além de criar situações jurídicas ativas e passivas”⁶⁷, independentemente de qualquer tipificação legal. “Em verdade, não seria necessária qualquer enumeração das condutas desleais: o art. 5.º do CPC é bastante, exatamente por tratar-se de uma cláusula geral”.^{68 - 69}.

A tutela da boa-fé processual manifesta-se fundamentalmente de dois modos: mediante a repressão da violação de deveres expressamente tipificados pela lei (nos incs. I, I e III do art. 77, por exemplo, ou ainda no art. 80) e também por meio da punição do exercício abusivo de direitos processuais, “posto que em si mesmos legítimos”⁷⁰ estes direitos (por exemplo, na proibição do *venire contra factum proprium* ou da *Verwirkung* no processo⁷¹) e mesmo sem expressa previsão legal que a determine. O mais importante é a consciência de que o reconhecimento da violação da boa-fé não depende de um enquadramento análogo ao que se faz no direito penal da conduta do sujeito em um determinado tipo legal. É preciso, em síntese, eliminar todos os resquícios *criminóides*, se se permite o neologismo, do regramento legal da tutela processual da boa-fé. Basta a transgressão *objetivamente* considerada daquilo “que legitimamente é esperado de cada parte”,⁷² exatamente porque o que se exige dos sujeitos do processo, como resume a jurisprudência do STJ, é a obediência “a um padrão de conduta que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e contrária à equidade”.⁷³

A litigância de má-fé (a violação da boa-fé processual) faz, em síntese, com que o causador do dano tenha de indenizar a vítima pelos prejuízos que sua conduta lesiva tenha causado. A responsabilidade civil processual, conseqüentemente, pressupõe: (a) uma conduta lesiva (o art. 80 tipifica alguns de seus casos, sem a pretensão de ser exaustivo; basta a violação da boa-fé processual); (b) ocorrência de um dano processual; (c) nexo causal entre este dano e a conduta lesiva; e (d) excepcionalmente, a prova da culpa do agente; em regra, a responsabilização será objetiva.

Não há responsabilidade civil sem dano.⁷⁴ A questão é controversa na jurisprudência, no entanto, em razão precisamente da confusão conceitual entre punição do ato atentatório à dignidade da justiça e responsabilidade civil processual (e a conseqüente confusão entre tutela do interesse público na boa administração da justiça e a tutela do interesse privado da parte na reparação do dano processual por ela sofrido). A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com efeito, decidiu exatamente o contrário, ao fundamento de que “a prevalecer a tese quanto à necessidade de comprovação do prejuízo causado pelo dano processual, isso impossibilitaria, muitas vezes, que o próprio juiz pudesse – como de fato pode – decretar a litigância de má-fé *ex officio*, ou seja, sem pedido da parte, já que o prejuízo não estaria efetivamente comprovado nos autos”.⁷⁵ Este precedente parte da premissa, equivocada, de que o dano sofrido pela parte deveria ser encontrado *fora do processo*, o que dificultaria ou mesmo inviabilizaria a repressão da litigância de má-fé. Não é o caso. O dano, para a configuração da litigância de má-fé, é o dano processual. Nas hipóteses, por exemplo, em que a parte “provoca incidente manifestamente infundado” (art. 80, VI) ou interpõe “recurso com intuito manifestamente protelatório” (art. 80, VII), dano processual é o tumulto e o retardamento que a prática destes atos causa. Difícil é apenas estimar a reparação exata que o causador do dano deve à vítima. Mas é exatamente por isso que o art. 81 do CPC preestima as perdas e os danos, analogamente ao que faz a cláusula penal no direito civil. Sobre a quantificação desta reparação e a maneira processual de se exigí-la, confirmam-se os comentários ao art. 81.

A reparação do prejuízo na litigância de má-fé independente, por fim, da sanção imposta pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. O juiz pode cominá-la cumulativamente, se entender o caso, com a diferença de que a multa devida a título de *contempt* deve ser cobrada em execução fiscal (art. 77, § 3.º) e seu produto irá para o Estado (para o fundo de “modernização do Poder Judiciário” a que alude o art. 97), enquanto a quantia paga a título de reparação pela litigância de má-fé deve reverter-se *integralmente* para o prejudicado.

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II – alterar a verdade dos fatos;

III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI – provocar incidente manifestamente infundado;

VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Direito anterior – art. 17 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 247 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 456 do CPC português.

1. Rol meramente exemplificativo

Como se explicou nos comentários ao art. 79, o Código de Processo Civil consagra em seu art. 5.º, expressamente, um dever processual de boa-fé a cujo respeito todos os sujeitos do processo estão obrigados (em regra objetivo, excepcionalmente subjetivo). A cláusula geral processual da boa-fé torna possível a repressão da sua violação (litigância de má-fé), assim, independentemente de qualquer tipificação legal. Com isto se quer dizer que os incisos do art. 80 dão apenas *exemplos* de condutas que violam o dever processual de boa-fé, sem a pretensão de conformar um rol exaustivo de condutas puníveis e sem exigir um enquadramento análogo ao que se faz no direito penal da conduta do agente em um determinado tipo legal-⁷⁶. Sempre que se violar a boa-fé processual haverá litigância de má-fé.⁷⁷

2. Litigância de má-fé e simultaneamente ato atentatório à dignidade da justiça

A repressão da litigância de má-fé independe ainda da sanção eventualmente imposta pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Nada impede, com efeito, que o juiz reconheça a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, cominando multa ao *contemnitor*, e, ao mesmo tempo, reconheça-o como litigante de má-fé. Mas a multa devida pela prática de *contempt* deve ser cobrada em execução fiscal (art. 77, § 3.º) e destinada aos cofres públicos (ao fundo de “modernização do Poder Judiciário” a que alude o art. 97), enquanto a quantia paga a título de reparação pela litigância de má-fé deve reverter-se *integralmente* para o prejudicado.

3. Abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual⁷⁸)

Demandar e defender-se (e todos os direitos processuais daí decorrentes, como o de recorrer, de falar em juízo, de produzir provas etc.) são direitos cujo exercício a cláusula geral da boa-fé processual não permite ser *abusivo*.⁷⁹ Esta ideia – de que não se admite o exercício abusivo de direitos – permeia, com efeito, todo o ordenamento jurídico.⁸⁰ É à luz desta *proibição da chicana* que os incisos do art. 80 devem ser analisados. O reconhecimento do abuso do direito de demanda

ou de defesa (chicana) não exige, no entanto, a demonstração subjetiva de má-fé, da vontade consciente de cometer o abuso (*animus nocendi* ⁸¹). Basta que a conduta da parte possa ser *objetivamente* definida como abusiva, que viole aquilo “que legitimamente é esperado de cada parte”⁸². E isso porque “a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional”.⁸³ O que se exige dos sujeitos do processo, como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é justamente a obediência “a um padrão de conduta que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e contrária à equidade”.⁸⁴

4. Pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso

Demandar e defender-se são direitos, como quaisquer outros, que não devem ser exercidos de modo abusivo. A litispendência, com efeito, é em si algo muito gravoso para as partes, independentemente do resultado do litígio judicial (cuja solução, aliás, costuma demorar anos). Basta lembrar dos prejuízos que a mera existência de um processo em que se discute a propriedade de um imóvel pode causar a seu proprietário (especialmente se ele pretender neste ínterim vendê-lo) ou dos danos que o simples pedido judicial de falência, por mais despropositado que seja, pode causar à reputação de um empresário. “Deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso” significa assim *abusar* do direito de demandar ou de defender-se por quem “pretende algo a que sabe não ter direito”.⁸⁵ O critério de avaliação, no entanto, é objetivo. A lei “preferiu lançar mão do *standard* da razoabilidade. Assim, deferiu ao juiz a discricionariedade para avaliar se o litigante estava colocado em situação tal que poderia conhecer a falta de fundamento de sua pretensão ou defesa”.⁸⁶ Com a ressalva de que “não se pode confundir essa situação com a do advogado despreparado, que invoca textos legais evidentemente inaplicáveis aos fatos que alega, ou que ignora qual a jurisprudência dominante”.⁸⁷

5. Dever de falar a verdade

O inc. II, segundo o qual se considera litigante de má-fé aquele que “alterar a verdade dos fatos”, repete o dever de falar a verdade de que trata o art. 77, I (*Wahrheitspflicht*).⁸⁸ Sua função é a de proibir a mentira consciente e deliberada (*Lügeverbot* ⁸⁹), razão pela qual sua tipificação dependerá sempre da comprovação da *vontade de enganar* (má-fé, subjetiva). “A regra é a de que o litigante deve, subjetivamente, crer no que afirma”.⁹⁰ Esta é uma exceção à regra segundo a qual deve ser *objetiva* a tutela da boa-fé processual. Pode-se mentir afirmando-se verdadeiro algo que se sabe que é falso, falso algo que se sabe verdadeiro. Mas viola o dever de falar a verdade também aquele que conta apenas uma parte da verdade. Não se permite, assim, narrar os detalhes favoráveis e, *em relação ao mesmo fato*, esconder os desfavoráveis. Este o dever de completude (*Pflicht zur Vollständigkeit* ⁹¹) ou ainda a proibição da meia-verdade (*Verbot der Halbwahrheit* ⁹²). Mas dizer a verdade não equivale a exigir o “dever de acertar, de não cometer equívocos ou ainda de conhecer a verdade objetiva, de saber dos fatos tais como realmente são”,⁹³ nem equivale tampouco ao dever de revelar a existência de fatos que lhe possam ser contrários (nos moldes da *discovery* norte-americana⁹⁴). “Por outro lado, não se exige que a falsa alegação seja feita com algum propósito específico; a alteração reputa-se ‘intencional’ desde que o litigante a faça consciente e voluntariamente”.⁹⁵ O processo civil brasileiro continua fiel, e deve continuar assim, à máxima de que “*nemo tenetur edere contra se*” (ninguém é obrigado no processo a ir contra si mesmo, da qual decorre, por exemplo, o princípio de que ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si próprio).

6. Processo e objetivo ilegal

Pratica também litigância de má-fé quem “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” (inc. III). Esta também é uma exceção à regra segundo a qual deve ser objetiva a tutela da boa-fé processual exatamente porque o que se reprime aqui não é a conduta em si, mas a *intenção*

perversa do agente. O objetivo ilegal consiste em pedir algo em juízo quando o que se pede não é aquilo que realmente se pretende com a demanda. Neste caso “o que lesa a outro litigante é o próprio uso do processo”.⁹⁶ Se se pede contra uma pessoa pública indenização por danos morais, por exemplo, quando o objetivo ulterior do autor é apenas humilhá-lo ou execrá-lo publicamente, usa-se o processo para conseguir objetivo ilegal. Mesma coisa em certos litígios de família, como quando uma demanda recheada de acusações contra um dos genitores se torna para o outro um mero instrumento de alienação parental.

7. Resistência injustificada ao andamento do processo, agir temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocação de incidente manifestamente infundado e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório (chicana processual)

Os incs. IV, V, VI e VII descrevem hipóteses de abuso do direito de demanda ou de defesa (proibição da chicana processual). Demandar e defender-se (e todos os direitos processuais daí decorrentes, como o de recorrer, de falar em juízo, de produzir provas etc.) são direitos, como já se disse antes, cujo exercício a cláusula geral da boa-fé processual não permite ser abusivo.⁹⁷ Esses incisos, em outras palavras, dão apenas *exemplos* de chicana processual, sem a pretensão de ser exaustivo. O reconhecimento do abuso não depende, assim, de um enquadramento análogo ao que se faz no direito penal da conduta do sujeito em um determinado tipo legal.⁹⁸ O que se espera das partes no processo é a obediência “a um padrão de conduta que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e contrária à equidade”,⁹⁹ de modo que o reconhecimento da chicana processual (abuso do direito de demanda ou de defesa) não pressupõe a vontade consciente de cometer o abuso (*animus nocendi* ¹⁰⁰). Basta que a conduta da parte possa ser *objetivamente* definida como abusiva.¹⁰¹

A interposição de um recurso especial inadmissível, por exemplo, em razão da falta de “esgotamento de instância”,¹⁰² pode ser definida como um erro técnico, cuja reparação a parte prejudicada pode reclamar de seu advogado. Mas não é chicana. Se a parte pede insistentemente, ao contrário, a juntada aos autos de novos documentos, com a nítida finalidade (objetivamente considerada) de tumultuar o trâmite do processo e postergar o seu andamento, será o caso de chicana porque haverá aí a oposição de “resistência injustificada ao andamento do processo” (inc. IV). Também será o caso se se proceder “de modo temerário” (inc. IV).¹⁰³ Se a parte opõe exceção de impedimento do juiz em hipótese flagrantemente estranha àquelas descritas no art. 144, com o nítido propósito (objetivamente considerado) de ganhar tempo, provoca “incidente manifestamente infundado” (inc. VI).¹⁰⁴ Se opuser sucessivos embargos de declaração manifestamente infundados da mesma decisão, será o caso de interposição de “recurso com intuito manifestamente protelatório” (inc. VII).¹⁰⁵ Mas tudo depende de uma análise casuística, porque o abuso do direito de demandar e de defender-se só pode ser reconhecido com segurança em um determinado caso concreto, à luz de suas particularidades, nunca em tese.¹⁰⁶

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1.º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2.º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3.º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Direito anterior – art. 18 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 96 do CPC italiano, art. 247 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 457 do CPC português.

1. Responsabilidade civil processual e condenação pela litigância de má-fé

Reconhecida a litigância de má-fé, de acordo com os critérios explicados nos artigos anteriores, deve o agente reparar a vítima *no mesmo processo* pelos prejuízos que lhe causou, ainda que beneficiário ele de gratuidade de justiça (art. 99). Esta condenação independe do resultado final do litígio, porque mesmo quem ganha ao final pode ter agido ao longo do litígio de modo contrário à boa-fé processual.¹⁰⁷ E isso ao fundamento de que “mesmo quem tem o direito a seu favor deve agir corretamente em juízo para a sua defesa”.¹⁰⁸ O fato de que o litigante de má-fé é beneficiário de justiça gratuita não o exime também de sua responsabilidade. “Do contrário, a pobreza constituiria imunidade inadmissível”.¹⁰⁹

A confusão conceitual entre punição do ato atentatório à dignidade da justiça e responsabilidade civil processual (e a consequente confusão entre tutela do interesse público na boa administração da justiça e a tutela do interesse privado da parte na reparação do dano processual por ela sofrido) levou o legislador, equivocadamente, a permitir ao juiz que condenasse *ex officio* o litigante de má-fé. Essa permissão faz sentido no *contempt*, mas não na responsabilidade civil processual exatamente porque ela tutela fundamentalmente um interesse privado (a *reparação* de um dano¹¹⁰) e porque ela pressupõe uma autêntica *condenação* (a própria lei usa o termo “condenar”). Para que se possa condenar, com efeito, é preciso que alguém peça a condenação (princípio da demanda). Diversas suas funções, ademais, a cominação da multa por ato atentatório e a condenação por litigância de má-fé são inteiramente independentes uma da outra, como se explicou nos comentários ao artigo anterior.

Atenta às dificuldades inerentes à quantificação das perdas e danos sofridos pela vítima, que não se confundem com a comprovação da ocorrência do *dano* enquanto elemento da responsabilidade civil por ela sofrido em decorrência da litigância de má-fé,¹¹¹ a lei optou por *estimar* uma indenização mínima ao dispor que “o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou” (*caput*). É algo análogo ao que faz a cláusula penal no direito privado quando “a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente” (art. 416, parágrafo único, do CC).¹¹² A utilidade desta “pré-liquidação do *id quod interest*”¹¹³ é especialmente visível em casos em que a comprovação dos prejuízos possa ser de difícil realização para o credor.¹¹⁴ Isso com a ressalva de que “quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo” (§ 2.º).

2. Procedimento para a quantificação da reparação

Segundo dispõe o § 3.º, “o valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos”. Esse dispositivo é reforçado pelo art. 777, segundo o qual “a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo”. Nada impede a vítima, de todo modo, de pedir a condenação do litigante de má-fé em demanda própria.¹¹⁵ A liquidação *nos próprios autos*, no entanto, lhe é muito mais conveniente. “Mas é evidente que a propositura frutífera de ação autônoma fica preexcluída se a questão houver sido objeto de pronunciamento, em qualquer sentido, no primeiro processo: haverá o óbice da coisa julgada material”.¹¹⁶ A modalidade de liquidação nos próprios autos dependerá da complexidade probatória. A cobrança de multa, honorários e reembolso de despesas, por exemplo, dispensa em regra a realização de perícia. A comprovação dos prejuízos extraprocessuais, por outro lado, exige a realização de instrução probatória, por arbitramento ou por artigos “quando houver necessidade de alegar e provar fato novo” (art. 509).

3. Pluralidade de litigantes de má-fé

Para o parágrafo primeiro, “quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária”. O critério, aqui, é o da causalidade. Se os litigantes de má-fé deram causa *em conjunto* ao ato reputado de má-fé, responderão solidariamente.¹¹⁷ Independentemente dos atos, a responsabilidade pelo pagamento da reparação é individual.

Seção III Das despesas, dos honorários advocatícios e das multas

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1.º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2.º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Direito anterior – art. 20 do CPC/1973

Direito comparado – § 91 da ZPO alemã, arts. 90 e 91 do CPC italiano, art. 241 da ley De Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 447-d do CPC português.

1. Alocação do custo financeiro do processo. Litigar é algo custoso, para as partes envolvidas e também para o Estado, responsável pela prestação deste serviço público que é a administração da justiça. Por isso o processo tem um custo financeiro para as partes, que são as *despesas judiciais*¹¹⁸ (v.g., custas judiciais, remuneração dos auxiliares da justiça¹¹⁹) e as *despesas extrajudiciais* (v.g., remuneração de assistentes técnicos, honorários advocatícios¹²⁰). Mas quem deve pagar pelo quê? Este o problema da *alocação dos custos do processo*¹²¹. A lei distingue o *ônus* de adiantar o pagamento dos custos do processo ao longo de seu trâmite da *obrigação* que a parte vencida tem ao final do processo de “*pagar ao Estado ou aos auxiliares algum valor ainda não recolhido*”, de reembolsar o “*vencedor pelo que ele tiver adiantado*”¹²² e pelas despesas extrajudiciais que ele *razoavelmente*¹²³ tiver realizado e, ainda, de pagar *honorários de sucumbência* aos advogados da parte vencedora (princípio da sucumbência)¹²⁴.

As regras gerais sobre a alocação dos custos do processo serão explicadas nos comentários a este artigo, enquanto a situação particular em que a parte é beneficiária de gratuidade de justiça será tratada nos comentários ao art. 98 e a da Fazenda Pública, do Ministério Público e da Defensoria Pública nos comentários ao art. 91. A obrigação da parte vencida de pagar honorários de sucumbência diretamente aos advogados da parte vencedora será tratada nos comentários ao art. 86. Mas a ideia que deve nortear a interpretação de todos estes dispositivos é a de que *o processo não deve valer a pena para quem não tem razão* e, ao mesmo tempo, que ele não deve *onerar aquele que não deu causa ao processo*.

2. Ônus de adiantamento de despesas. Adiantar despesas não é uma obrigação, mas um ônus da parte interessada na realização de determinado ato processual. É por isso, por exemplo, que o autor deve adiantar as custas para a distribuição de petição inicial. Se não o fizer, ela deverá ser indeferida, com o cancelamento da sua distribuição¹²⁵. A não realização do ato é, assim, a *sanção* pelo descumprimento do ônus de adiantamento, que não se confunde com a obrigação da parte perdedora de, ao fim do processo, pagar as despesas faltantes e de reembolsar a vencedora por aquelas que ela antecipou. Neste exemplo, vencedor o autor, deverá o réu reembolsá-lo ao final pelo que antecipou a título de custas para a distribuição da petição inicial. Tem o ônus de adiantar, em outras palavras, aquele que tem *interesse* na realização do ato processual.

O interesse enquanto critério para a distribuição do ônus de adiantamento explica por que,

quando mais de uma parte tiver pedido a realização de determinado ato (uma perícia, por exemplo), os custos desta realização devem ser rateados entre elas. Mas não é razoável se atribuir apenas ao autor o ônus de adiantar as “*despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício*” (§ 1.º). A aplicação deste dispositivo, em sua literalidade, violaria o princípio da paridade de armas (*Waffengleichheit*)¹²⁶ expresso no art. 7.º do CPC, segundo o qual “*é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório*”^{127, 128}. Sua incidência revelar-se-ia especialmente absurda quando a prova, cuja realização se determinasse de ofício, viesse a interessar apenas ao réu. Neste caso, o autor não teria vontade alguma em vê-la realizada, razão pela qual não faria sentido exigir dele o adiantamento. Por isso, a solução mais equânime é a de que, também neste caso, os custos devem ser rateados entre as partes. Não é por outro motivo, aliás, que dispõe o art. 95 que a remuneração do perito deve ser “*adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes*”¹²⁹. Esta regra, enunciada pelo art. 95 especificamente para a remuneração do perito, deve ser aplicada a todas as despesas. Se uma das partes se recusar a adiantar a sua quota-parte da despesa, a outra poderá fazê-lo em seu lugar a fim de evitar a não realização do ato processual. Mas esta recusa deverá ser interpretada pelo juiz ao menos com um *indício* de ato atentatório à dignidade da justiça e, ao mesmo tempo, de litigância de má-fé. Ao final, obviamente, nada muda. A responsabilidade pelo pagamento será do perdedor.

Se a realização do ato processual é determinada a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica, incide a mesma regra de quando determinada *ex officio*: rateio entre as partes. Mas se o Ministério Público a requerer na qualidade de parte – e, portanto, de parte *interessada* – o ônus de adiantamento é dele¹³⁰ nas condições explicadas nos comentários ao art. 91.

3. Obrigação de pagar as despesas faltantes e reembolsar as já realizadas. Segundo disposto no parágrafo único do art. 82, “*a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou*” (princípio da sucumbência). Essa obrigação, de natureza processual¹³¹ e independente de qualquer investigação sobre culpa^{132 -133}, que a parte vencida tem ao final do processo¹³⁴ de “*pagar ao Estado ou aos auxiliares algum valor ainda não recolhido*” e de reembolsar o “*vencedor pelo que ele tiver adiantado*”¹³⁵ (despesas judiciais) e pelas despesas extrajudiciais que ele *razoavelmente*¹³⁶ tiver realizado (princípio da sucumbência).¹³⁷ Nem toda despesa extrajudicial, deste modo, será reembolsável, mas apenas aquela que *razoavelmente* relacionar-se ao processo.¹³⁸ É neste sentido que fala Yussef Said Cahali em “*despesas repetíveis e não repetíveis*”.¹³⁹

O princípio da sucumbência deve ser interpretado, no entanto, à luz de outro, o princípio da causalidade,¹⁴⁰ “segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo”^{141 -142}. Esta uma questão, essencialmente, de *fairness*,¹⁴³ exatamente porque “*a person should not be out of pocket as a result of having to seek court adjudication to vindicate his rights*”¹⁴⁴. Esta a regra geral sobre a alocação dos custos do processo. Situação particular será aquela em que se reconhecer a gratuidade de justiça, conforme se explicará nos comentários ao art. 98, e a de sucumbência parcial nos comentários ao art. 86. Sobre a condenação do vencido a pagar aos advogados do vencedor honorários de sucumbência, confirmam-se os comentários ao art. 85.

4. Obrigação de reembolsar honorários advocatícios contratuais. O pagamento de honorários advocatícios a seus próprios advogados (honorários contratuais) é obviamente uma *despesa* da parte vencedora. Quem vence, aliás, costuma pagar mais a seus advogados do que pagaria se tivesse perdido (honorários contratuais de êxito). Por isso é razoável que aquele que perde reembolse também o vencedor pelas despesas que ele *razoavelmente*¹⁴⁵ teve com seus advogados (English Rule)^{146 -147}. E isso porque, como resume o Superior Tribunal de Justiça, “*o Código Civil de 2002 – nos termos dos arts. 389, 395 e 404 – determina, de forma expressa, que os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos. Os honorários mencionados pelos referidos artigos são os honorários contratuais, pois os sucumbenciais, por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam em decréscimo patrimonial do vencedor*”

da demanda. Assim, como os honorários convencionais são retirados do patrimônio da parte lesada – para que haja reparação integral do dano sofrido – aquele que deu causa ao processo deve restituir os valores despendidos com os honorários contratuais. Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da justiça”¹⁴⁸.

O critério para a quantificação dos honorários contratuais a serem reembolsados pela parte perdedora deve, no entanto, para que se evitem abusos e para dar previsibilidade e transparência aos cálculos que as partes devem fazer ao optar por litigar, ser objetivo¹⁴⁹. Não a tabela de honorários da OAB, porque aí se trata apenas de *honorários mínimos* (art. 22, § 2.º, do Estatuto da Ordem), mas, analogicamente, as regras previstas no art. 85 para os honorários de sucumbência com os quais o reembolso dos honorários contratuais não se confunde. Ao argumento de que esta *dupla condenação* (honorários de sucumbência mais reembolso dos honorários contratuais) tornar-se-ia excessivamente gravosa para o perdedor se responde que *o processo não deve valer a pena – também financeiramente – para quem não tem razão*. Trata-se, antes, de um desestímulo às “*bad or spurious claims*” a que aludiu Neil Andrews¹⁵⁰ e à litigiosidade excessiva e também um estímulo à solução do litígio através de métodos outros como a mediação.

5. Distribuição dos custos financeiros do processo e negócio jurídico processual. Nada impede as partes, por fim, de *convencionarem* sobre a distribuição dos custos financeiros do processo, com fundamento no disposto no art. 190 (negócio jurídico processual)¹⁵¹, de modo diverso da *default rule*¹⁵² (as regras descritas no art. 82), inclusive sobre o reembolso de honorários contratuais. Mas não sobre honorários de sucumbência, porque não se permite às partes dispor sobre direito do qual não são titulares (mas sim os advogados da parte vencedora, como titulares exclusivos deles, como se explicará nos comentários ao art. 85)¹⁵³.

Art. 83. O autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser, se não tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento.

§ 1.º Não se exigirá a caução de que trata o *caput*:

I – quando houver dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte;

II – na execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença;

III – na reconvenção.

§ 2.º Verificando-se no trâmite do processo que se desfalcou a garantia, poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter.

Direito anterior – art. 835 do CPC/1973

Direito comparado – § 110 da ZPO alemã e art. 98 do CPC italiano (dispositivo teve a sua *illegittimità costituzionale* reconhecida pela Corte Constitucional em 1960).

1. *Cautio pro expensis*. Aquele que lhe deu causa, como se viu nos comentários ao artigo anterior, tem a obrigação, ao final do processo, de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça valores porventura ainda não recolhidos, de reembolsar a parte inocente pelas despesas processuais que ela tiver antecipado e pelos honorários que ela razoavelmente tiver pago a seus próprios advogados e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados dela (princípios da sucumbência e da causalidade). Aquele que perde responde com seu patrimônio pelo cumprimento desta obrigação. Ocorre que, presume a lei, quem não reside no Brasil (independentemente de sua nacionalidade) tem *menos patrimônio* no país, o que torna potencialmente mais difícil a cobrança deste reembolso ao final do processo. Este o motivo por que “o autor, brasileiro ou estrangeiro, que residir fora do Brasil ou deixar de residir no país ao longo da

tramitação de processo prestará caução suficiente ao pagamento das custas e dos honorários de advogado da parte contrária nas ações que propuser” (caput).

Trata-se da *cautio pro expensis* (também *Auländersicherheitsleistung*¹⁵⁴), que é “a garantia real ou fidejussória que o autor [não o réu] presta para que se assegure o pagamento das custas e honorários do advogado da parte contrária, no caso de perder, totalmente ou em parte, a ação, e penas relativas a custas”¹⁵⁵. Esta garantia deve ser prestada, com efeito, apenas por quem demanda, nunca por aquele contra quem se demanda. Daí por que a garantia é necessária também em algumas modalidades de intervenção de terceiros em que uma parte deduz autêntica pretensão processual. Por exemplo, na denunciação da lide contra terceiro em que o réu é autor da denunciação.

A garantia – real ou fidejussória – será suficiente e idônea quando seu valor *razoavelmente* parecer cobrir os custos estimados das despesas e honorários. Mas se trata de uma conta aproximada. Cálculos precisos sobre o valor exato da garantia ou dos custos financeiros do processo não são necessários neste momento. É por isso que a parte final do *caput* dispõe que se dispensa a garantia se o autor “*tiver no Brasil bens imóveis que lhes assegurem o pagamento*”. Não é preciso avaliar neste momento cada um dos imóveis com exatidão, mas o emprego do plural “imóveis” sugere que o juiz deve estar atento à possibilidade de que um imóvel único possa ser impenhorável (bem de família). Tudo depende, em síntese, de uma análise casuística.

2. Outras hipóteses de dispensa da garantia. A lei dispensa a prestação de garantia quando houver “dispensa prevista em acordo ou tratado internacional de que o Brasil faz parte” (inc. I), na “execução fundada em título extrajudicial e no cumprimento de sentença” (inc. II) e “na reconvenção” (inc. III). No âmbito do Mercosul, por exemplo, dispensa-se a garantia por força do disposto no art. 4.º do Protocolo de Las Leñas, segundo o qual “nenhuma caução ou depósito, qualquer que seja sua denominação, poderá ser imposto em razão da qualidade de cidadão ou residente permanente de outro Estado Parte. O parágrafo precedente se aplicará às pessoas jurídicas constituídas, autorizadas ou registradas conforme as leis de qualquer dos Estados Partes”^{156 -157}. Na execução, presume a lei ter o demandante um direito mais seguro, o que justificaria a dispensa. Na reconvenção, por fim, a ideia é de que não foi o demandante (réu/reconvinte) quem deu início ao processo como um todo, mas o próprio demandado (autor/reconvindo), que já teria optado por litigar de todo modo. Além destes três casos, dispensa-se a garantia também quando beneficiário o autor de gratuidade de justiça (art. 98, VIII). O “alto grau de probabilidade do direito reclamado”¹⁵⁸ em termos genéricos, entretanto, não justifica a dispensa.

3. Condição de admissibilidade do julgamento do mérito e coisa julgada material. A prestação da garantia é condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Sem ela, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 337, XII e 485, IV. Por força do disposto no § 5.º deste mesmo artigo, que não excepciona a *cautio pro expensis*, trata-se de matéria sobre a qual o juiz deve conhecer de ofício, independentemente de provocação do réu. Equivocou-se a lei neste particular, no entanto, porque, como resume Lopes da Costa, “a caução às custas é exceção em que ao interesse, todo particular, do réu, não se ajunta interesse público algum”¹⁵⁹. Não é por outro motivo que, em ordenamentos jurídicos estrangeiros, como o alemão, a exigência desta garantia é tratada como uma exceção (*Prozesshindernis*), não uma objeção (*Prozessvoraussetzung*)¹⁶⁰.

O caráter eminentemente privado do interesse do réu na prestação da garantia torna possível, por isso, com fundamento na cláusula geral da boa-fé processual (*Verwirkung*, ou *suppressio*), que o autor deixe de poder suscitar depois a objeção se não o fizer no início do processo¹⁶¹. Nada impede, de todo modo, o suprimento *superveniente* (ao longo do processo, até o momento da sentença) da falta desta condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda¹⁶². Se o valor do bem dado em garantia se depreciar no curso do processo, por fim, *desfalcando a garantia*, na expressão empregada pela lei, “*poderá o interessado exigir reforço da caução, justificando seu pedido com a indicação da depreciação do bem dado em garantia e a importância do reforço que pretende obter*” (§ 2.º).

A sentença, que julga extinto o processo com fundamento na falta da caução, é uma sentença terminativa (arts. 337, XII e 485, IV). Apesar disso, a repropositura da demanda “*depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito*” (art. 486, § 1.º). Esta estabilidade, porque se manifesta para fora do processo, é exatamente a coisa julgada material. “*Há, aqui, coisa julgada quanto à questão da admissibilidade*”¹⁶³. A referência à possibilidade de “*correção do vício*”, com efeito, não faz com que a sentença terminativa deixe de ser imutável, mas apenas a submete aos *limites temporais* da coisa julgada¹⁶⁴. A imutabilidade da coisa julgada material não impede o demandante, assim, de ajuizar mais uma vez a demanda, corrigindo o defeito que havia dado causa à extinção. Mas desde que este defeito *possa ser corrigido* (é o caso). Se não o puder, a decisão permanece imutável *para fora do processo*, exatamente porque a função da coisa julgada material é servir a que “*o juiz, quando do ajuizamento de uma nova demanda, não tenha de decidir, mais uma vez, a mesma questão jurídica processual (Prozessfrage) que deu causa à extinção do primeiro processo*”¹⁶⁵. Esta imutabilidade, no entanto, limita-se “*à questão explicitamente decidida (e não se estende a outras questões processuais, que não tenham sido objeto de decisão, ou, a fortiori, ao próprio mérito da demanda*”¹⁶⁶) e só incide se a mesma questão for posta a julgamento, ainda que noutro processo, entre as mesmas partes”¹⁶⁷. Com isto se quer dizer que, embora o autor possa prestar a caução na segunda demanda mesmo se a primeira tiver sido extinta por sua falta, ele não pode *insistir* na tese de que a caução é dispensável se se decidiu na primeira que ela é necessária¹⁶⁸.

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

Direito anterior – art. 20, § 2.º, do CPC/1973

Direito comparado – § 91 da ZPO alemã, art. 91 do CPC italiano, art. 241 da ley De Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 447-d do CPC português.

1. Conceito de despesas (processuais e extraprocessuais). Litigar é algo custoso, para as partes envolvidas e também para o Estado, responsável pela prestação deste serviço público que é a administração da justiça. Por isso o processo tem um custo financeiro para as partes, que são as *despesas judiciais (ou processuais)* e as *despesas extrajudiciais*. Enquanto a expressão *despesas processuais* “*abrange todos os itens do custo do processo que de algum modo e em algum momento serão devidos aos agentes estatais*”¹⁶⁹, como as custas judiciais (taxa judiciária enquanto espécie de tributo¹⁷⁰) e a remuneração dos auxiliares da justiça (v.g. perito, intérprete), *despesas extrajudiciais* são aquelas que, embora relacionadas ao processo, não se destinam ao pagamento do Estado ou de agentes estatais, como os honorários (contratuais ou de sucumbência), a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha¹⁷¹. O rol do art. 84, de todo modo, é meramente *exemplificativo*. Os honorários contratuais, por exemplo, embora também *despesas extrajudiciais*, não são expressamente mencionados neste artigo¹⁷².

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1.º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2.º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

- I – o grau de zelo do profissional;
- II – o lugar de prestação do serviço;
- III – a natureza e a importância da causa;
- IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3.º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2.º e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4.º Em qualquer das hipóteses do § 3.º:

I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV – será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5.º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3.º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6.º Os limites e critérios previstos nos §§ 2.º e 3.º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7.º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8.º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º.

§ 9.º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10 Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2.º a 6.º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º para a fase

de conhecimento.

§ 12 Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77.

§ 13 As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14 Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15 O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16 Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17 Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18 Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19 Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Direito anterior – art. 20 do CPC/1973

Direito comparado – § 91 da ZPO alemã, art. 91 do CPC italiano, art. 241 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 447-d do CPC português.

1. Princípio da sucumbência (e da causalidade). “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, conforme dispõe o *caput* do art. 85. Esta a obrigação, de natureza processual¹⁷³ e independente de qualquer investigação sobre culpa, que a parte vencida tem ao final do processo de pagar *honorários de sucumbência* aos advogados da parte vencedora (princípio da sucumbência).¹⁷⁴ Também aos advogados empregados (art. 21 do Estatuto da OAB)¹⁷⁵ e aos advogados públicos (parágrafo dezenove).¹⁷⁶ Este princípio deve ser interpretado, no entanto, à luz de outro, o princípio da causalidade,¹⁷⁷ “segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo”¹⁷⁸. É exatamente por força deste princípio, aliás, que “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo” (parágrafo décimo).¹⁷⁹

2. Momento para a fixação dos honorários de sucumbência – Os honorários de sucumbência devem ser pagos pelo *vencido* ao advogado do *vencedor*, como esclarece o *caput*. Será perdedor, neste sentido, aquele que, *em relação ao mérito ou às condições de admissibilidade de seu julgamento*, tiver perdido. Isso ocorrerá, mais frequentemente, quando a sentença julgar a demanda, mas pode também ocorrer quando parte dela vier a ser antecipadamente julgada mediante uma decisão interlocutória (com ou sem julgamento do mérito). Por exemplo, quando da exclusão no início do processo de um dos litisconsortes passivos com fundamento em sua ilegitimidade ou quando o juiz julgar antecipadamente o pedido de condenação em danos morais, deixando o de danos materiais para depois da instrução probatória. Nesses casos, os honorários de sucumbência, *em relação à parcela da demanda que já tiver sido julgada*, deverão ser logo fixados.¹⁸⁰ Porque os honorários de sucumbência dizem sempre respeito à vitória em relação à demanda, assim, a parte que perde em um mero incidente processual não deve ser condenada ao pagamento de honorários (por exemplo, ao ver indeferido o seu requerimento para a realização de uma prova), mas deve sê-lo se vier a perder “ações incidentes, como medidas cautelares e a arguição de falsidade de documento, se a parte requerer que seja decidida como questão principal

(art. 430, parágrafo único)”.¹⁸¹

3. Natureza jurídica e titularidade exclusiva dos advogados. O credor da obrigação de pagar honorários de sucumbência são os *advogados* da parte vencedora, a quem a lei atribui a *titularidade exclusiva* sobre eles. Este o motivo por que as partes não podem convencionar sobre honorários de sucumbência (por exemplo, estipulando em um contrato que *não serão devidos* honorários de sucumbência em um eventual litígio entre elas) com fundamento no disposto no art. 190 (negócio jurídico processual¹⁸²). Daí também por que este crédito, conforme o parágrafo doze, não se confunde e nem é prejudicado pela cobrança de qualquer sanção que possa ser exigida das partes por ato atentatório à dignidade da justiça, por litigância de má-fé, etc. Este direito tem natureza *alimentar* para todos os fins (parágrafo quatorze), razão pela qual os honorários são relativamente impenhoráveis¹⁸³, equiparam-se ao crédito trabalhistas no concurso de credores¹⁸⁴ e detêm preferência na ordem de pagamento de precatórios¹⁸⁵. A circunstância de que o crédito pertence aos advogados do vencedor não lhes impede, no entanto, de “*requerer que o pagamento dos honorários que lhe[s] caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra[m] na qualidade de sócio*” sem que com isso a obrigação perca seu caráter alimentar (parágrafo quinze)¹⁸⁶.

Os honorários de sucumbência são também devidos “*quando o advogado atuar em causa própria*” (parágrafo dezessete). Sua fixação deve ser feita pelo juiz, independentemente da existência de pedido expresso na petição inicial a respeito¹⁸⁷, em um capítulo da decisão que julgar a demanda, com ou sem mérito e ainda que parcialmente.¹⁸⁸ Para evitar alguns dos debates frequentes na vigência do CPC/1973 sobre a extensão de seu cabimento, esclarece a lei textualmente serem “*devidos honorários advocatícios na reconvenção* [demanda de natureza cognitiva], *no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não* [demandas de natureza executiva, independentemente se resistidas ou não e se definitivo ou não o título executivo], *e nos recursos interpostos* [demanda recursal], *cumulativamente* [observados os limites previstos neste mesmo artigo]” (§ 1.º). Exceção a esta regra geral é apenas a de que “*não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada*” (parágrafo sétimo).

Da decisão que fixa os honorários têm os advogados legitimidade *concorrente* para interpor recurso, mesmo contra a vontade de seu constituinte¹⁸⁹ -¹⁹⁰ (a parte, ao fazê-lo, é substituto processual *ex lege* de seus advogados, porque pede em juízo a tutela de um direito de que não é titular¹⁹¹). Omissa a decisão sobre eles, não há condenação (não se permite condenação *implícita* em honorários de sucumbência¹⁹²). Mas “*é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança*” (parágrafo dezoito).¹⁹³ A parte final do parágrafo quatorze, segundo o qual é “*vedada a compensação em caso de sucumbência parcial*”, reforça a ideia de que se trata de um direito exclusivo dos advogados da parte vencedora. Não se permite a compensação dos honorários de sucumbência, com efeito, porque a compensação pressupõe exatamente *reciprocidade* entre credor e devedor, o que não ocorre na sucumbência parcial; credores são os advogados e devedores as partes, razão pela qual o crédito do advogado não pode ser compensado por uma dívida que é de seu constituinte, não dele.¹⁹⁴

4. Parâmetros de fixação. Os honorários de sucumbência “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (parágrafo segundo). Segundo define a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o proveito econômico corresponde à expressão monetária do pedido”.¹⁹⁵ Mas isso com a ressalva de que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa” (parágrafo oitavo).

Ao dizer que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte a lei não dá ao juiz *discrecionariade*. Ao contrário, deixa claro que ele deve respeitar estes limites “*independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito*” (parágrafo sexto)¹⁹⁶ -¹⁹⁷ e lista quatro balizas que devem nortear a fixação: “I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a

natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (parágrafo segundo). Por isso, como resume Pontes de Miranda, a lei “limitou, quantitativamente, e encheu, qualitativamente, o âmbito de competência do juiz ou tribunal para a fixação dos honorários”.¹⁹⁸ O que o juiz deve fazer, com efeito, é fundamentar a fixação à luz dos elementos e dos fatos concretos da causa, sem empregar para justificá-la platitudes e expressões vagas e imprecisas que de concreto nada tenham a ver com a demanda.¹⁹⁹ Lembre-se, neste ponto, que o art. 489 define como não fundamentada exatamente a decisão que “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida” (inc. I), “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (inc. II) e “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão” (inc. III).

Também no espírito de *positivar* certas soluções sobre as quais a lei anterior não era suficientemente clara, dispõem os § 9.º, § 13, e § 16, respectivamente, que “na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”, sem incluir o capital constituído para assegurar o pensionamento em sua base de cálculo²⁰⁰ -²⁰¹, que “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”²⁰² e que “quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.²⁰³

5. Honorários recursais. A enorme quantidade de recursos interpostos ano a ano no Brasil, e a percepção generalizada de que este excesso é uma das principais causas da morosidade da Justiça no país, levou o legislador a criar no CPC a figura dos *honorários de sucumbência recursal*²⁰⁴. Sua função, no entanto, é controversa. Argumenta-se também ser ela exclusivamente a de remunerar adequadamente os advogados da parte vencedora pelo trabalho suplementar desenvolvido em grau recursal, mas é inegável que ela serve também para desestimular a interposição de recursos (natureza sancionatória)²⁰⁵. A distinção não tem relevância apenas teórica. Por servir *também* para remunerar o trabalho suplementar dos advogados, incidem honorários de sucumbência recursal também no reexame necessário (art. 496). Mas o tribunal deve levar em conta, ao fixá-los, o fato de que a Fazenda *não quis*, a rigor, recorrer da sentença.

A ideia é de que o tribunal (colegiada ou monocraticamente²⁰⁶), ao *negar provimento* a um recurso interposto de uma decisão que *tenha* fixado honorários²⁰⁷ - ²⁰⁸, independentemente de terem ou não sido apresentadas contrarrazões²⁰⁹, “majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal” (§ 11). O acréscimo não pode, no entanto, fazer com que o resultado supere os limites máximos estabelecidos pela lei nos § 2.º (para as causas em geral, de 20%) e § 3.º (nas causas em que parte a Fazenda Pública). Se se *der provimento* ao recurso, diferentemente, não será a rigor caso de majoração, mas sim de nova fixação, devendo-se apenas “ser considerado no arbitramento da verba o trabalho realizado pelo advogado no decorrer de todo o processo, inclusive na fase recursal”²¹⁰. Nesse caso, como o perdedor não recorreu, não é razoável sancioná-lo por aquilo que ele não fez. O tribunal deve levar essa circunstância em conta ao fixar os honorários. Omissa a decisão sobre a fixação dos honorários recursais, ademais, a parte prejudicada deverá denunciar a omissão na primeira oportunidade que tiver para fazê-lo, sob pena de preclusão.²¹¹

6. Honorários nos processos em que a Fazenda Pública for parte. Eram frequentes, na vigência do CPC/1973, as críticas às regras previstas na lei sobre a fixação de honorários de sucumbência nas demandas em que parte a Fazenda Pública. Parcela da doutrina chegou mesmo a defini-las como *uma violação à garantia do tratamento igualitário das partes no processo*.²¹² Daí por que preferiu o legislador de 2015 abandonar a *pífia regra equivalente do CPC/1973*²¹³ ao regulamentar a matéria no atual art. 85.

Os critérios para a fixação dos honorários de sucumbência *nas causas em que a Fazenda Pública for parte*, diz o parágrafo terceiro (e, por isso, não apenas nas hipóteses em que é ela a devedora dos honorários, mas em todos os casos em que ela for *parte*, vencendo ou perdendo²¹⁴ -²¹⁵), são

aqueles mesmos constantes do § 2.º, mas os limites mínimo e máximos são escalonados de acordo com o valor da condenação ou do proveito econômico: “I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos” (§ 3.º). Estes parâmetros aplicam-se “independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito” (§ 3.º). Nas causas, no entanto, “em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º” (§ 8.º).

É relevante também lembrar que “quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3.º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente” (§ 5.º). Trata-se de um critério regressivo para a fixação dos honorários, análogo àquele que se pratica na definição das faixas de tributação no imposto de renda: se o contribuinte é isento do IRPF quando ganhar, por hipótese, menos de dois mil reais mensalmente, a base de cálculo sobre o qual incidirá o imposto, se ele passar a ganhar um salário de dois mil e quinhentos reais, será de quinhentos reais (o tributo incidirá apenas sobre a parcela que sobejar a faixa, não sobre todo o seu rendimento). Mesmo raciocínio se aplica à definição dos honorários de sucumbência. O novo percentual, em outras palavras, só será aplicado ao valor que ultrapassar os limites da banda anterior²¹⁶.

Preocupou-se a lei em detalhar também a definição da base de cálculo sobre a qual incidem os honorários de sucumbência nas diversas *bandas* previstas no § 3.º. Se líquida a sentença, os percentuais devem ser aplicados sobre o valor certo e líquido (§ 4.º, I). Se ilíquida, a definição do percentual só *ocorrerá* no momento da liquidação (§ 4.º, II). Sem que seja possível “*mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa*” (§ 4.º, III). A definição em salários-mínimos dos limites mínimo e máximo das bandas torna também oportuno o esclarecimento de que “*será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação*” (§ 4.º, IV). Em uma exceção à regra geral prevista no § 1.º, por fim, “*não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada*” (§ 7.º).

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Direito anterior – art. 21 do CPC/1973.

Direito comparado – § 92 da ZPO alemã, art. 92 do CPC italiano e art. 447-d do CPC português.

1. Sucumbência parcial (ou recíproca). A parte vencida (*rectius*, aquela que deu causa ao processo), tem ao seu final a obrigação, de natureza processual²¹⁷ e independente de qualquer investigação sobre culpa,²¹⁸ ²¹⁹ de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado²²⁰ e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente²²¹ tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora (princípios da sucumbência e da causalidade). Esta a regra geral (*default rule*), que não impede as partes, como se explicou nos comentários ao art. 82, de dispor sobre a distribuição dos custos do processo de modo diverso (mediante negócio

jurídico processual, conforme art. 190).²²²

Situação particular, no entanto, é aquela em que “cada litigante for, em parte, vencedor e vencido”. Nesta hipótese, os custos serão então proporcionalmente distribuídos entre as partes. “Para ilustrar com um exemplo que reduz o problema à expressão mais simples: se o autor pede mil e o juiz concede setecentos e cinquenta, o réu terá de arcar com três quartos do total das despesas e honorários dos advogados [apenas os contratuais, porque os de sucumbência não entram na conta e não se compensam, porque titular deles os advogados, não as partes, como se explicou nos comentários ao art. 85] e o autor com um quarto. Distribuição proporcional. Se o autor pagou todas as custas e honorários, o réu terá de indenizá-lo de três quartas partes. Se o autor pagou metade, o réu terá de entregar-lhe uma quarta parte. Se o réu pagou três quartos (improvável, mas possível), nada terá de pagar”.²²³

Será o caso, em outras palavras, na *cumulação de pedidos* ou nas demandas em que o pedido for *decomponível* (pedido em dinheiro, coisas fungíveis²²⁴), quando ocorrer procedência parcial (quando, por exemplo, apenas um de três pedidos for julgado procedente, ou quando apenas parte do pedido pecuniário vier a sê-lo). Quantificáveis em dinheiro ou de algum outro modo os pedidos, mais fácil será a aferição da *proporção* em que parcial a sucumbência (se se pede a condenação do réu a entregar ao autor quinhentas sacas de café, mas ele só é condenado a entregar quatrocentas, a conta é fácil: a proporção da vitória do autor é de 4/5). Não sendo possível a mensuração, o juiz deve arbitrar de maneira *razoável* uma proporção. Como resume Pontes de Miranda, “quanto à correspondência entre a distribuição e as vitórias das partes, há de ser exato e preciso o ato do juiz”.²²⁵ Arbitrada a proporção, verifica-se quanto cada uma das partes antecipou e calcula-se quanto falta a ser pago, compensando-se o que puder ser compensado: não os honorários de sucumbência, como se explicou, mas as despesas judiciais e extrajudiciais (sobre o conceito de despesas judiciais e extrajudiciais, confirmam-se os comentários ao art. 84).

2. Sucumbência em parte mínima. A distribuição proporcional das despesas não seria razoável, no entanto, quando uma das partes perde apenas “em parte mínima do pedido”.²²⁶ Parte mínima, aí, “é a parte do pedido, que se há de considerar sem relevância, quer pelo lado jurídico, quer pelo lado econômico”.²²⁷ Nestes casos, a parte *virtualmente* perdedora, embora a rigor não integralmente perdedora, “responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários” (parágrafo único)²²⁸. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exemplo de sucumbência em parte mínima é aquele em que “a Fazenda Nacional apenas foi vencedora quanto à forma de restituição dos valores indevidamente recolhidos pelo contribuinte, ao passo que este foi vencedor quanto ao reconhecimento da denúncia espontânea, bem como quanto ao direito de repetição do indébito”.²²⁹

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1.º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no *caput*.

§ 2.º Se a distribuição de que trata o § 1.º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

Direito anterior – art. 23 do CPC/1973.

Direito comparado – § 100 da ZPO alemã e art. 446 do CPC português.

1. Litisconsórcio e distribuição proporcional dos custos do processo. A parte vencida (*rectius*, aquela que deu causa ao processo)²³⁰, tem ao seu final a obrigação, de natureza processual²³¹ e independente de qualquer investigação sobre culpa²³²⁻²³³, de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado²³⁴ e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente²³⁵ tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora (princípios da sucumbência e da causalidade). Esta a regra geral (*default rule*), que não impede as partes, como também se explicou

nos comentários ao art. 82, de dispor sobre a distribuição dos custos do processo de modo diverso (mediante negócio jurídico processual, conforme art. 190).²³⁶ Situação particular, no entanto, é aquela em que, do lado vencedor ou do vencido, existir uma pluralidade de partes (litisconsórcio).

Se existir litisconsórcio entre os vencedores, mas apenas um vencido, será ele responsável pelo reembolso de todas as despesas judiciais antecipadas pelos vencedores e pelo pagamento das ainda em aberto. Mas a obrigação de reembolsar honorários contratuais e de pagar honorários de sucumbência não é cumulativa. Fixado o percentual conforme os critérios estipulados pelo art. 85, os vencedores (no caso dos honorários contratuais) e seus advogados (no caso dos honorários de sucumbência) deverão *repartir* o percentual definido pelo juiz a título, respectivamente, de reembolso de honorários contratuais e de honorário de sucumbência, não somá-los. Suponha-se, por exemplo, que os honorários tenham sido fixados em 20% do valor da condenação. Permitir o somatório dos percentuais *por cabeça* faria com que, cinco os litisconsortes vencedores, seus advogados recebessem ao todo 100% do valor da condenação em honorários de sucumbência. Não seria, obviamente, algo razoável. Os cinco advogados, neste exemplo, deverão dividir os 20%. Mas o juiz deve levar esta circunstância em consideração ao fixar os honorários à luz dos critérios estabelecidos pelo art. 85.

Se existir litisconsórcio entre os vencidos, serão eles, por seu turno, responsáveis “*proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários*” (caput). Quantificáveis em dinheiro ou de algum outro modo os pedidos, mais fácil será a aferição da *proporção* em que deve ser distribuída a sucumbência entre os litisconsortes. Se o primeiro réu é condenado a entregar ao autor quatrocentas sacas de café, por exemplo, enquanto o segundo a entregar cem sacas, a conta é fácil: a proporção é de 4/5 para o primeiro réu e de 1/5 para o segundo. Mas a obrigação de pagar pelas despesas e pelos honorários de sucumbência, em razão de sua natureza processual e de sua autonomia em relação à relação jurídica material porventura existente entre as partes, não será solidária quando for “*caso de solidariedade no direito em litígio*”²³⁷. A distribuição deve ser sempre *proporcional* à sucumbência, salvo na exceção de que se tratará no próximo item. Não sendo possível a mensuração, o juiz deve arbitrar de maneira *razoável* uma proporção.

2. Omissão sobre a distribuição e solidariedade. O juiz tem o *dever* de determinar expressamente a proporção quando fixar a responsabilidade pelas despesas e honorários (§ 1.º). A solução desta questão não pode, por este motivo, ser deixada para a fase de execução. Se a distribuição não for feita, por qualquer motivo, “*os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários*”. Daí o interesse dos responsáveis em opor embargos de declaração da decisão para verem suprida a omissão. Nesta hipótese, de *solidariedade legal*, o devedor solidário que paga a dívida por inteiro pode exigir dos demais devedores a *quota-parte* que lhes cabe (art. 283 do Código Civil²³⁸).

Art. 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados.

Direito anterior – art. 24 do CPC/1973

1. Jurisdição voluntária e administração pública de interesses privados. A jurisdição voluntária, na tradicional lição de Zanobini, popularizada no Brasil por Frederico Marques, é “*administração pública de interesses privados*”.²³⁹ Sua natureza é administrativa, não jurisdicional, embora a competência para desempenhá-la se atribua a um órgão jurisdicional por razões de política legislativa.²⁴⁰ A jurisdição voluntária, em outras palavras, “*pur essendo, come ora si dirà, funzione sostanzialmente amministrativa, è soggettivamente esercitata da organi giudiziari*”.²⁴¹ Nada de estranho, considerando-se que nem todas as competências de um juiz têm mesmo natureza jurisdicional. Lembre-se, por exemplo, de sua competência *administrativa* para fiscalizar o trabalho dos serventuários sob sua autoridade. O que se faz é simplesmente escolher certos interesses privados que, na perspectiva do legislador, recomendem sua administração pública²⁴² e atribuir a competência para administrá-lo a um órgão judicial. Foi o caso do divórcio, por exemplo, quando de sua introdução no direito brasileiro. Embora o divórcio consensual continue um procedimento de jurisdição voluntária (art. 731), a lei permite expressamente a sua realização

extrajudicial, observadas certas condições (art. 733). A dissolução amigável da sociedade conjugal não é mais hoje, assim, entendida como socialmente sensível o suficiente para justificar a competência judicial exclusiva. Daí por que a administração pública deste interesse privado, em outras palavras, deixou de ser sempre indispensável.

A circunstância de que sua natureza não é jurisdicional não faz *necessariamente* com que não possa haver litígio sobre como este interesse privado deve ser administrado. E por litígio se deve entender qualquer *conflito* ou *controvérsia*, não apenas lide em sentido técnico.²⁴³ A interdição, com efeito, pode ser amigável ou litigiosa. Mas a litigiosidade é apenas uma *possibilidade*, um acidente que pode ou não ocorrer. Na jurisdição contenciosa, ao contrário, o conflito é seu elemento *essencial* ²⁴⁴. Este *Charakteristikum* da jurisdição voluntária acaba por ter consequências também para a distribuição dos custos do processo, reguladas em relação a ela de modo diverso das regras gerais estabelecidas nos arts. 82 e 85.

2. Distribuição dos custos do processo na jurisdição voluntária. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, “*as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados*”. Por *despesas* se entende apenas as despesas judiciais. Despesas extrajudiciais não são rateáveis, nem há lugar, obviamente, para o pagamento de honorários de sucumbência (a rigor, não há sequer sucumbência). Este rateio deve ser feito, ademais, *por cabeça*, independentemente da medida do interesse de cada um no processo. Mas não se esqueça de que, em certos casos, o requerente pode não ter interesse algum, razão pela qual ele não participará do rateio das despesas ao final. Pense-se no exemplo do testamenteiro ou mesmo do terceiro detentor do testamento, que não é ao mesmo tempo herdeiro ou legatário, que pede – trata-se de um procedimento especial – a confirmação judicial de testamento particular (art. 737). Se o processo tiver início por iniciativa do Ministério Público (na interdição, por exemplo, conforme arts. 747, IV e 748) ou mesmo *ex officio* (na herança jacente, por exemplo, conforme art. 738), as despesas deverão ser logo rateadas pelos interessados. Tudo muda, no entanto, se ocorrer litígio entre os interessados, porque a *litigiosidade* torna inaplicáveis as regras previstas neste artigo²⁴⁵, devendo o juiz fixar a distribuição dos custos do processo, neles incluídos honorários, de acordo com as regras gerais previstas nos arts. 82 e 85²⁴⁶.

Art. 89. Nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões.

Direito anterior – art. 25 do CPC/1973

1. Juízos divisórios. São tradicionalmente definidos como juízos divisórios, desde o direito romano²⁴⁷, a *actio communi dividundo* (divisória – art. 588), a *finium regundorum* (de demarcação – art. 574) e a *familiae erciscundae* (inventário e partilha da herança – art. 610). Eram consideradas ações mistas (*tam in rem quam in personam*)²⁴⁸ e são hoje entendidas como juízos “*discriminativos, operam simples transformação da relação jurídica entre os interessados*” ²⁴⁹. A elas se junta a assim chamada *ação discriminatória*, destinada à demarcação de terras públicas (prevista em diversos diplomas legais, a começar pela Lei de Terras de 1850). Estes diversos exemplos de juízos divisórios dividem-se fundamentalmente em dois grupos.

2. Casos em que o litígio torna necessário o processo judicial. No primeiro grupo, a demanda judicial só é necessária *porque* há litígio entre os interessados. E por litígio se deve entender qualquer *conflito* ou *controvérsia*, não apenas lide em sentido técnico²⁵⁰. É o caso, por exemplo, da ação divisória e da ação de demarcação. Se estivessem de acordo, os interessados poderiam fazer a divisão ou a demarcação *amigavelmente*, sem passar pelo Poder Judiciário. Por isso estas demandam dividem-se em duas fases. Na primeira fase, controverte-se, nestes dois exemplos, sobre o *direito de dividir* ou o *direito de demarcar* ²⁵¹. Nesta fase, os custos do processo devem ser distribuídos de acordo com os critérios gerais estabelecidos pelos arts. 82 e 85. Apenas as despesas da segunda fase – de divisão ou demarcação, respectivamente, neste mesmo exemplo – é que deverão ser pagas pelos interessados “*proporcionalmente a seus quinhões*”. Se cada um dos condôminos for proprietário de metade do imóvel, as despesas da segunda fase deverão ser repartidas entre eles em igual proporção. Mas isso apenas se a segunda fase não for também

litigiosa. Caso contrário, aplicam-se as regras gerais de distribuição dos custos do processo também nela, de modo que aquele que der causa ao prolongamento do litígio (mesmo se for aquele que tiver vencido na primeira fase) torna-se responsável pelo pagamento das despesas da segunda fase.

3. Casos em que o processo judicial é indispensável, independentemente de existir ou não litígio entre os interessados. No segundo grupo de juízos divisórios, ao contrário do que acontece com os do primeiro, a demanda judicial é necessária *independentemente* de haver ou não litígio entre os interessados. É o caso, por exemplo, do inventário quando o *de cujus* tiver deixado testamento ou herdeiros incapazes (art. 610). Aqui, “*não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões*”. Tudo muda, no entanto, se ocorrer litígio entre eles, porque a *litigiosidade* torna inaplicáveis as regras previstas neste artigo, devendo o juiz fixar a distribuição dos custos do processo, neles incluídos honorários, de acordo com as regras gerais previstas nos arts. 82 e 85.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1.º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2.º Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3.º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4.º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Direito anterior – art. 26 do CPC/1973

Direito comparado – §§ 91a, 93 e 98 da ZPO alemã e art. 451 do CPC português.

1. Extinção do processo com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido. A parte vencida (*rectius*, aquela que deu causa ao processo)²⁵², tem ao seu final a obrigação, de natureza processual²⁵³ e independente de qualquer investigação sobre culpa,²⁵⁴ ²⁵⁵ de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado²⁵⁶ e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente²⁵⁷ tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora (princípios da sucumbência e da causalidade). Esta a regra geral (*default rule*), que não impede as partes, como também se explicou nos comentários ao art. 82, de dispor sobre a distribuição dos custos do processo de modo diverso (mediante negócio jurídico processual, conforme art. 190)²⁵⁸. O que faz o *caput* do art. 90 é justamente reforçar a ideia de que a distribuição dos custos do processo deve obedecer ao princípio da causalidade, “*segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo*”²⁵⁹.

Se a desistência ocorrer antes da citação do réu, o que pode ser feito independentemente de seu consentimento (art. 485, § 4.º), o autor será responsável pelo pagamento das despesas judiciais, mas não de despesas extrajudiciais tais como honorários contratuais ou de sucumbência. Obviamente, aliás, porque o réu sequer foi citado. Se a desistência for posterior à citação, diferentemente, mesmo antes de apresentação formal de defesa, ou quando o autor renunciar ao direito em que se funda a demanda, também depois da citação, será ele responsável pelo pagamento das despesas judiciais e extrajudiciais (nelas incluídas honorários contratuais e de sucumbência). Mesma coisa se o réu reconhecer a procedência do pedido, porque ele terá dado neste caso causa ao processo. Mas isso com a ressalva de que “*se o réu reconhecer a procedência do*

pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários [contratuais e de sucumbência] serão reduzidos pela metade” (§ 4.º). Trata-se de um estímulo benfazejo a que o réu satisfaça espontaneamente a obrigação cujo cumprimento lhe é reclamado, e sensato porque o processo terá dado menos trabalho e aborrecimentos ao autor do que teria se tivesse continuado adiante (menos trabalho, mas *não* nenhum trabalho, porque o autor terá de todo modo preparado, redigido e distribuído a petição inicial, o que não é pouca coisa).

Mas não se deve confundir a confissão, enquanto ato mediante a qual *“a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”* (art. 389), com a desistência, a renúncia ou o reconhecimento. Quem confessa pode, a despeito de sua confissão, vencer (com fundamento, por hipótese, na prescrição da pretensão do autor), o que não acontece nos três outros casos.²⁶⁰ Por isso a confissão não consta, nem deveria constar, das hipóteses versadas neste artigo. Nada mais razoável, por fim, que *“sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu”* (§ 1.º).

2. Transação e divisão paritária das despesas. Na transação, diferentemente do que se passa na desistência, na renúncia ou no reconhecimento, as partes decidem encerrar o litígio *“mediante concessões mútuas”* (art. 840 do Código Civil). Não há neste caso, a rigor, vencedor ou vencido, ainda que uma parte possa ter cedido mais do que a outra. Daí o tratamento especial dispensado pela lei, para a qual *“havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente”* (§ 2.º). A disposição é salutar, porque estimula a solução amigável do litígio. A lei vai ainda mais longe, fiel ao espírito de valorização das diversas maneiras de solução consensual dos conflitos conforme enuncia o art. 3.º, § 3.º, ao dispor que *“se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver”* (§ 3.º). Trata-se de mais um estímulo concreto e elogiável à solução amigável do litígio.

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1.º As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2.º Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público.

Direito anterior – art. 27 do CPC/1973.

1. Despesas de atos praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público (na qualidade de parte) ou da Defensoria Pública. A Fazenda Pública, o Ministério Público (quando atua na qualidade de parte) e a Defensoria Pública²⁶¹ são dispensados do ônus de adiantar despesas de que se falou nos comentários ao art. 82.²⁶² Mas eles deverão pagar ao final, em caso de derrota, estas despesas *não adiantadas*. Este dever abrange as despesas judiciais que não tenham natureza tributária, como o pagamento da remuneração dos auxiliares da justiça. Custas e emolumentos, consequentemente, não devem ser pagos²⁶³, apenas reembolsados (se o adversário os tiver adiantado, como se viu nos comentários ao art. 82). Se a Defensoria Pública atuar na qualidade de representante da parte, terá ela (a parte) a obrigação de pagar todas despesas não adiantadas, mesmo as de natureza tributária (ressalvadas as disposições sobre gratuidade de justiça tratadas nos comentários ao art. 98).

2. Remuneração do perito. Caso especial é da remuneração do perito. Com o evidente objetivo de esvaziar o enunciado 232 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual *“a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito”*, o CPC estabelece no § 1.º que as perícias *“requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova”*. Não havendo previsão

orçamentária no mesmo exercício financeiro, no entanto, “eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público”. A inovação alivia os cofres públicos, mas torna mais difícil que algum perito experiente e de boa formação técnica arrisque-se a trabalhar (não raro em perícias complexas) sem saber se e quando irá receber sua remuneração. Trata-se de disposição que, *de lege ferenda*, merece revisão²⁶⁴. O Superior Tribunal de Justiça, de todo modo, entendeu que este dispositivo não se aplica às ações civis públicas.²⁶⁵

Art. 92. Quando, a requerimento do réu, o juiz proferir sentença sem resolver o mérito, o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado.

Direito anterior – art. 28 do CPC/1973

1. Pagamentos das despesas como condição de admissibilidade do julgamento da demanda. Extinto o processo sem julgamento do mérito, a repropositura da mesma demanda “depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito” (art. 486, § 1.º). Esta estabilidade, porque se manifesta para fora do processo, é exatamente a coisa julgada material. “Há, aqui, coisa julgada quanto à questão da admissibilidade”.²⁶⁶ A referência à possibilidade de “correção do vício”, com efeito, não faz com que a sentença terminativa deixe de ser imutável, mas apenas a submete aos limites temporais da coisa julgada.²⁶⁷

A imutabilidade da coisa julgada material não impede o demandante, assim, de ajuizar mais uma vez a demanda, corrigindo o defeito que havia dado causa à extinção. Mas desde que este defeito possa ser corrigido. Se não o puder, a decisão permanece imutável para fora do processo, exatamente porque a função da coisa julgada material é servir a que “o juiz, quando do ajuizamento de uma nova demanda, não tenha de decidir, mais uma vez, a mesma questão jurídica processual (*Prozessfrage*) que deu causa à extinção do primeiro processo”²⁶⁸. Esta imutabilidade, no entanto, limita-se “à questão explicitamente decidida (e não se estende a outras questões processuais, que não tenham sido objeto de decisão, ou, a fortiori, ao próprio mérito da demanda²⁶⁹) e só incide se a mesma questão for posta a julgamento, ainda que noutro processo, entre as mesmas partes”.^{270 _271}

Para que o mérito da demanda reproposta possa ser julgado neste segundo processo, no entanto, não basta apenas a correção do vício que tenha dado causa à extinção do primeiro sem julgamento do mérito. É preciso também que o autor tenha pago *inteiramente* as despesas judiciais e extrajudiciais a que condenado a pagar no primeiro processo (sobre despesas, confirmam-se os comentários ao art. 84). Esta regra é enunciada neste artigo, quando se determina que “o autor não poderá propor novamente a ação sem pagar ou depositar em cartório as despesas e os honorários a que foi condenado” e reafirmada no art. 486, § 2.º, segundo o qual “a petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado”. Basta ao autor depositar em juízo a quantia integral de que é devedor, mas o reconhecimento posterior (no primeiro processo) de que o depósito é insuficiente faz com que o juiz do segundo deva extingui-lo, mesmo que tenha inicialmente aceitado o argumento de que suficiente o depósito.

Não socorre ao autor, para se eximir do ônus de comprovar no segundo processo o pagamento das despesas do primeiro, o argumento de que “não poderá arcar com o depósito”²⁷². E isso porque a atribuição dos custos do processo a quem lhe deu causa e a vinculação da admissibilidade do julgamento da demanda reproposta a seu pagamento é compatível com a garantia constitucional do acesso à justiça e, ao mesmo tempo, um desestímulo razoável ao exercício abusivo do direito de repetir a mesma demanda. O direito, aliás, vê com maus olhos aquele que *repropõe* uma mesma demanda, tanto que confere eficácia extintiva à preempção (art. 337, 485, V e a 485, § 3.º)²⁷³.

Art. 93. As despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição.

Direito anterior – art. 29 do CPC/1973.

Direito comparado – § 95 e 102 da ZPO alemã e art. 448 do CPC português.

1. Responsabilidade subjetiva pelo pagamento de despesas pelo adiamento ou repetição de ato processual. A parte vencida (*rectius*, aquela que deu causa ao processo),²⁷⁴ tem ao seu final a obrigação, de natureza processual²⁷⁵ e independente de qualquer investigação sobre culpa,²⁷⁶ de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado²⁷⁸ e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente²⁷⁹ tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora (princípios da sucumbência e da causalidade). Esta a regra geral (*default rule*), que não impede as partes, como também se explicou nos comentários ao art. 82, de dispor sobre a distribuição dos custos do processo de modo diverso (mediante negócio jurídico processual, conforme art. 190)²⁸⁰.

O que faz o art. 93 é criar uma *exceção* a esta regra geral. Se algum ato do processo tiver de ser adiado ou repetido em razão de conduta *culposa* de um dos sujeitos do processo – qualquer deles, “*parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz*” – a responsabilidade pelo pagamento das despesas relativa a este ato deverá caber a quem lhe deu causa, não ao *vencido* ao final do processo. Esta atribuição específica de responsabilidade, com efeito, é *subjetiva*²⁸¹, não objetiva como na regra geral.

Suponha-se que a audiência não se realize, porque o serventuário esqueceu-se de intimar, como deveria ter feito, as testemunhas. Ou que o juiz, neste exemplo, tenha se esquecido de que havia marcado a audiência e deixado de ir trabalhar neste dia para fazer outra coisa qualquer. Ou ainda que o perito tenha deixado culposamente de comparecer à inspeção *in loco* de uma obra por ele próprio agendada com as partes e seus advogados. Nestes exemplos, independentemente da prática de *ato atentatório à dignidade da justiça* ou de *ilícito processual* que estas condutas possam também porventura significar (confirmam-se, respectivamente, os comentários aos arts. 77 e 79), as despesas pelo adiamento e pela repetição devem ser suportadas por quem lhes deu causa culposamente.

Art. 94. Se o assistido for vencido, o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo.

Direito anterior – art. 32 do CPC/1973

Direito comparado – § 101 da ZPO alemã e art. 452 do CPC português.

1. Assistência e a distribuição dos custos do processo. A parte vencida (*rectius*, aquela que deu causa ao processo)²⁸², tem ao seu final a obrigação, de natureza processual²⁸³ e independente de qualquer investigação sobre culpa²⁸⁴ -²⁸⁵, de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado²⁸⁶ e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente²⁸⁷ tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora (princípios da sucumbência e da causalidade). Esta a regra geral (*default rule*), que não impede as partes, como também se explicou nos comentários ao art. 82, de dispor sobre a distribuição dos custos do processo de modo diverso (mediante negócio jurídico processual, conforme art. 190).²⁸⁸

Situação particular é aquela em que a parte *vencida* é assistida por terceiro que intervém no processo na qualidade de *assistente simples*, e apenas como assistente simples, não quando se tratar de assistência litisconsorcial²⁸⁹ -²⁹⁰. Neste caso, “*o assistente será condenado ao pagamento das custas em proporção à atividade que houver exercido no processo*”. Esta condenação abrange *apenas* as custas, não as demais despesas judiciais e extrajudiciais (sobre o conceito de despesas, confirmam-se os comentários ao art. 84).

A condenação proporcional de assistido e assistente ao pagamento das custas não é, entretanto, solidária. Este ponto, de *lege ferenda*, merece revisão²⁹¹. De todo modo, o juiz deve arbitrar a proporção entre assistente e assistido de modo *razoável*. A distribuição da responsabilidade pelo

pagamento das custas deve assim “*levar em conta não a simples proporcionalidade matemática, mas sim a extensão da ‘atividade que houver exercido o assistido’*. Se a perícia, por exemplo, for realizada a requerimento do assistente, a ele caberá o reembolso do que houver desembolsado o adversário do assistido” ²⁹².

A obrigação que assistente e assistido têm ao final de pagar as despesas não se confunde com o ônus de adiantamento que incumbe ao interessado para a prática de determinado ato processual. Se o ato é praticado *individualmente* por assistente ou assistido, ou requerido por *apenas* um deles, cada um é responsável pelo adiantamento da respectiva despesa. Na interposição de recurso, por exemplo, cada um deve realizar o preparo de seu próprio recurso, e apenas dele. Mesma coisa se apenas um deles pedir a realização de determinada prova. Apenas o requerente terá o ônus de adiantar (o assistente na *omissão não negocial* do assistido²⁹³). Se assistente e assistido requererem, em conjunto ou separadamente, no entanto, a realização de um mesmo ato comum, a responsabilidade pelo adiantamento é apenas do assistido. Será o caso, por exemplo, se os dois pedirem a realização de uma perícia. E isso porque o assistente é *apenas* assistente, sujeito do processo que não deduz e contra quem não se deduz a demanda. O *predomínio* do interesse do assistido no julgamento explica por que apenas ele é responsável pelo adiantamento das despesas referentes a atos comuns cuja realização tenha sido pedida por ambos.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

§ 1.º O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.

§ 2.º A quantia recolhida em depósito bancário à ordem do juízo será corrigida monetariamente e paga de acordo com o art. 465, § 4.º.

§ 3.º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

§ 4.º Na hipótese do § 3.º, o juiz, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade da justiça, o disposto no art. 98, § 2.º.

§ 5.º Para fins de aplicação do § 3.º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.

Direito anterior – art. 33 do CPC/1973

1. Ônus de adiantamento de despesas e o critério do interesse. Adiantar despesas não é uma obrigação, mas um ônus da parte interessada na realização de determinado ato processual. A não realização do ato é, assim, a *sanção* pelo descumprimento do ônus de adiantamento, que não se confunde com a obrigação da parte perdedora de, ao fim do processo, pagar as despesas faltantes e de reembolsar a vencedora por aquelas que ela antecipou. Tem o ônus de adiantar, em outras palavras, aquele que tem *interesse* na realização do ato processual, conforme se explicou nos comentários ao art. 82.

2. Adiantamento da remuneração do perito e dos assistentes técnicos.²⁹⁴ É por este motivo que a

parte que requer a realização de uma perícia tem o ônus de adiantar a remuneração do perito e também por que cada uma das partes tem o ônus de adiantar a remuneração de seus assistentes técnicos. Trata-se, aqui, apenas do ônus de adiantar. A obrigação de pagar ao final será da parte perdedora (de acordo com os princípios da sucumbência e da causalidade, conforme se explicou nos comentários ao art. 82). É também por força do critério do interesse que a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, quando ambas tiverem requerido a realização da perícia. Esta despesa deve ser também rateada entre as partes quando determinada de ofício pelo juiz ou requerida pelo Ministério Público na qualidade de *custos iuris* ²⁹⁵. O ônus, neste caso, não será mais apenas do autor conforme determinava o art. 33 do CPC/1973²⁹⁶. A novidade é salutar, porque a única compatível com o princípio da paridade de armas (*Waffengleichheit*)²⁹⁷ expresso no art. 7.º do CPC, segundo o qual “*é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório*”. Se uma das partes se recusar a adiantar a sua quota-parte dos honorários do perito, a outra poderá fazê-lo em seu lugar a fim de evitar a não realização do ato processual. Mas esta recusa deverá ser interpretada pelo juiz ao menos com um *indício* de ato atentatório à dignidade da justiça e, ao mesmo tempo, de litigância de má-fé.²⁹⁸ Ao final, obviamente, nada muda. A responsabilidade pelo pagamento será do perdedor.

O perito, auxiliar da justiça, deve ser devidamente remunerado por seu trabalho. Não é razoável exigir que trabalhe gratuitamente ou mesmo que o faça em um contexto em que se revele improvável que seu trabalho venha a ser pago depois de concluído (por exemplo, em razão da insolvência das partes) ou que a cobrança de seus honorários se mostre excessivamente penosa (em razão da resistência do obrigado a cumprir a obrigação de pagar). É exatamente por isso que a lei permite ao “*juiz determinar que a parte responsável pelo pagamento [rectius, pelo adiantamento, porque a responsabilidade pelo pagamento é do perdedor ao final] dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente*” (§ 1.º). O depósito, sobre o qual incidirá sempre atualização monetária (§ 2.º), serve ao perito como uma garantia de que não trabalhará em vão.

Consciente de que o início da perícia pode exigir do *expert* o desembolso imediato de algumas despesas, permite-se também ao juiz “*autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos*” (art. 465, § 4.º). O juiz deverá fazê-lo apenas quando as circunstâncias concretas do caso justificarem o levantamento antecipado, mas o remanescente só poderá ser “*pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários*” (art. 465, § 4.º).

Situação particular é aquela em que o ônus de adiantamento é de parte beneficiária de gratuidade de justiça. Neste caso, a perícia deverá ser “*I – custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado*” ou “*II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça*” (§ 3.º)²⁹⁹. Após o trânsito em julgado da decisão que fixar a responsabilidade sobre as despesas, o juiz deverá oficiar a Fazenda Pública para que ajuíze contra o devedor “*a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público*”. Lembre-se que o benefício da gratuidade de justiça não exime o perdedor, ao final do processo, do pagamento (que não se confunde com o adiantamento) das despesas judiciais e extrajudiciais (art. 98, § 2.º). Mas com a ressalva de que “*vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário*” (art. 98, § 3.º).

Art. 96. O valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União.

Direito anterior – art. 35 do CPC/1973

Direito comparado – art. 456 do CPC português.

1. Litigância de má-fé e a reparação à vítima do dano por ela causado. A litigância de má-fé, como se viu nos comentários aos arts. 79 a 81, é o ato mediante o qual um sujeito do processo causa dano a outro ao violar o dever processual de boa-fé (nas hipóteses tipificadas em lei ou também enquanto violação atípica da cláusula geral de boa-fé processual). Por isso, o causador do dano tem o dever de *reparar* a vítima pelo dano que lhe causou. Este o motivo por que não é das mais felizes a redação do art. 96, segundo o qual “*o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União*”. E isso porque a indenização pela litigância de má-fé deve destinar-se *sempre* à vítima do dano, independentemente de quem tenha causado este dano e, por isso, de quem seja responsável por repará-lo. Se a vítima for uma das partes, a ela se destinará a reparação. Se algum serventuário, ao Estado.

2. *Contempt of court* e a tutela da dignidade da justiça. Na tutela da dignidade da justiça, ao contrário, o destinatário da multa será *sempre* o Estado, porque ela é um instrumento que permite ao juiz dissuadir ou punir condutas que de algum modo obstruam, tumultuem ou prejudiquem o bom andamento do processo. Seu escopo é, por isso, a tutela de um interesse público (a administração da justiça³⁰⁰) e é por isso que esta multa tem natureza *coercitivo-punitiva*, como se explicou nos comentários ao art. 77, não reparatória como a indenização devida à vítima com fundamento na repressão da litigância de má-fé.

3. Confusão entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. A confusão entre estes dois institutos, tutela da boa-fé processual e da dignidade da justiça, é antes causada, conforme também se explicou nos comentários ao art. 77, pelo ecletismo com que o direito processual brasileiro bebeu de fontes estrangeiras para regular a matéria. Enquanto a repressão tradicional à litigância de má-fé subjetiva³⁰¹ deve-se à influência lusitana³⁰² e a tutela objetiva da boa-fé processual (*Treu und Glauben im Zivilprozess*³⁰³) à alemã, filia-se a proibição da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça à tradição do *common law* (*contempt of court*³⁰⁴).

A repressão da litigância de má-fé independe, assim, da sanção eventualmente imposta pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Nada impede, com efeito, que o juiz reconheça a prática de ato atentatório à dignidade da justiça, cominando multa ao *contemnor*, e, ao mesmo tempo, reconheça-o como litigante de má-fé. Mas a multa devida pela prática de *contempt* deve ser cobrada em execução fiscal (art. 77, § 3.º) e destinada aos cofres públicos (ao fundo de “*modernização do Poder Judiciário*” a que alude o art. 97), enquanto a quantia paga a título de reparação pela litigância de má-fé deve reverter-se *integralmente* para o prejudicado.

Art. 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e outras verbas previstas em lei.

Direito anterior – sem correspondência

1. O destino da multa fixada pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (*contempt of court*).³⁰⁵ Os sujeitos do processo têm, como se explicou nos comentários ao art. 77, o *dever* de não obstruir, tumultuar ou prejudicar o bom andamento do processo. A violação deste dever consiste no ato atentatório à dignidade da justiça, cuja repressão mediante a cominação de multa ao *contemnor* serve à tutela de um interesse público (a boa administração da justiça³⁰⁶). Na tutela da dignidade da justiça, por isso, o destinatário da multa será *sempre* o Estado, diferentemente do que se passa na litigância de má-fé, porque esta multa tem natureza *coercitivo-punitiva*, não reparatória como a indenização devida à vítima com fundamento na repressão da litigância de má-fé. Os fundos de modernização do Poder Judiciário devem ser criados pela União e pelos estados justamente para receber e administrar os valores recebidos pelo *Estado* a título de sanção, mas também “*outras verbas previstas em lei*”. Este dispositivo, obviamente, carece de regulamentação. Como observa Cássio Scarpinella Bueno, “*a locução verbal empregada pelo dispositivo ‘serão revertidos’ é imperativa e, como tal, enseja a interpretação de que a destinação das verbas é verdadeiro dever*”³⁰⁷.

Seção IV Da gratuidade da justiça

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1.º A gratuidade da justiça compreende:

I – as taxas ou as custas judiciais;

II – os selos postais;

III – as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV – a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V – as despesas com a realização de exame de código genético – DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII – os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

§ 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

§ 4.º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

§ 5.º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 6.º Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7.º Aplica-se o disposto no art. 95, §§ 3.º a 5.º, ao custeio dos emolumentos previstos no § 1.º, inciso IX, do presente artigo, observada a tabela e as condições da lei estadual ou distrital respectiva.

§ 8.º Na hipótese do § 1.º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual

dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer, ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrais, a revogação total ou parcial do benefício ou a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6.º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento.

Direito anterior – art. 35 do CPC/1973.

Direito comparado – § 114 da ZPO alemã e arts. 7.º e seguintes da Lei de Assistência Judiciária portuguesa.

1. Assistência judiciária e gratuidade de justiça. A administração da justiça, como se viu com mais detalhes nos comentários aos arts. 82 e 84, é um serviço público custoso. Embora em tese concebível que pudesse ser *gratuito* para todos, não é razoável que o seja. É por isso que, em regra, o interessado na realização de um ato processual tem o ônus de lhe adiantar as despesas e o perdedor a obrigação, ao final do processo, de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora, conforme se viu nos comentários ao art. 82 (princípios da sucumbência e da causalidade).

Mas algumas pessoas³⁰⁸ – muitas, infelizmente – não têm recursos suficientes para suportar com dignidade os custos financeiros do processo. A aplicação a elas das regras gerais sobre antecipação e pagamento das despesas do processo equivaleria, deste modo, a frustrar-lhes na prática seu direito de acesso à Justiça.³⁰⁹ Por este motivo, segundo o art. 5.º, LXXIV, da Constituição, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Não se trata, a rigor, de um direito dos pobres (*Armenrecht*),³¹⁰ expressão preconceituosa que o direito alemão abandonou no início da década de 1980, mas sim de um direito daqueles que não têm condições financeiras para litigar em juízo sem que ao fazê-lo venham a comprometer a sua própria dignidade (*Prozesskostenhilfe*),³¹¹ Mas a definição do que se deve entender por “comprometer a sua própria dignidade” é casuística, e não deve ser encarada de um ponto de vista exclusivamente econômico. Nem todo insolvente, neste sentido, faz jus *automaticamente* à gratuidade.³¹²

A gratuidade de justiça, de todo modo, é apenas *uma* das manifestações possíveis da “assistência jurídica integral”, não a única.³¹³ Pense-se, por exemplo, no direito à orientação jurídica “extrajudicial” dos necessitados pela Defensoria Pública, conforme art. 108 da Lei Orgânica da Defensoria Pública. Como bem observou Barbosa Moreira no início da década de 1990, assistência jurídica integral quer dizer muito mais do que assistência judiciária.³¹⁴

2. Quem tem direito à gratuidade de justiça. Segundo dispõe o *caput* deste artigo, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O detalhamento serve para esclarecer dúvidas sobre quem pode ter direito à gratuidade de justiça que existiam na vigência da legislação anterior. Hoje, a rigor, “qualquer pessoa” pode ser beneficiária da gratuidade de justiça, física ou jurídica, dotada ou não de personalidade jurídica,³¹⁵ desde que lhe falte recursos para suportar os custos do processo sem comprometer a sua própria dignidade e independentemente da *posição* que ocupa na relação jurídica processual (autor, réu, terceiro interveniente). Sobre a *presunção* de necessidade e os requisitos para seu deferimento, confirmam-se os comentários ao art. 99.

3. Abrangência da gratuidade de justiça. Segundo o parágrafo primeiro, a gratuidade de justiça compreende: “I – as taxas ou as custas judiciais; II – os selos postais; III – as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios; IV – a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse; V – as despesas com a realização de exame de código genético – DNA e de

outros exames considerados essenciais; VI – os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; VII – o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; VIII – os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX – os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. Embora bastante detalhado, trata-se de rol meramente exemplificativo. O caso do adiantamento de despesas relativas à perícia, por exemplo, é regulado no art. 95, § 3.º. A sistemática das despesas com a perícia aplica-se também à hipótese do inciso IX (§ 7.º).³¹⁶ O Supremo Tribunal Federal já entendeu também, em uma ocasião, que a gratuidade de justiça abrange a “reprodução gratuita de cópias para formação do agravo”.³¹⁷ Mas a ideia geral que deve nortear a interpretação deste dispositivo é de que se deve isentar o beneficiário de gratuidade de justiça do ônus do adiantamento das despesas processuais “em geral”, não apenas nas hipóteses expressamente tipificadas pela lei.³¹⁸

A gratuidade, ao contrário do que acontecia na vigência do Código de Processo Civil de 1973, pode hoje ser concedida em relação a apenas um ato processual, ou a alguns, não necessariamente a todos, (§ 5.º). Nada mais razoável, considerando que o beneficiário pode ter recursos para suportar algumas despesas do processo sem comprometer sua própria dignidade, mas não outras. Por exemplo, uma perícia complexa e custosa. Permite-se também que a gratuidade de justiça seja também parcial, no sentido de atingir apenas um *percentual* das despesas (§ 5.º), ou que consista apenas na autorização para o seu parcelamento (§ 6.º). São disposições elogiáveis, porque entre os dois extremos (situação em que o sujeito pode suportar todos os custos do processo ou situação em que não pode suportar nenhum) existe toda uma gama de possibilidades. A lei dá ao juiz flexibilidade para *dosar* a gratuidade de justiça de acordo com a situação financeira concreta do beneficiário, contribuindo também para evitar o uso abusivo deste instituto por pessoas que não fazem realmente jus a ele.³¹⁹

4. Responsabilidade do beneficiário de gratuidade de justiça ao final do processo pelo pagamento das despesas. A gratuidade de justiça isenta o seu beneficiário, em princípio, apenas do *ônus de adiantamento de despesas*, não da obrigação ao final do processo de pagar ao Estado e aos auxiliares da justiça algum valor ainda não saldado, de reembolsar o vencedor pelo que ele tiver adiantado e pelas despesas extrajudiciais que ele razoavelmente tiver realizado e, ainda, de pagar honorários de sucumbência aos advogados da parte vencedora (§ 2.º). A lógica é de que a lei dá à parte carente de recursos a chance de ter seu *day in court*, mediante a dispensa do ônus de adiantamento, mas lhe exige sensatez e prudência na hora de decidir se irá ou não litigar ao deixá-la responsável pela obrigação de pagar pelas despesas se perder. Por isso a decisão deve *sempre* condenar o beneficiário vencido ao pagamento das despesas, nelas incluídas honorários de sucumbência (mas a exigibilidade desta condenação está submetida à condição explicada no próximo parágrafo). Eis um *meio-termo* entre a garantia do acesso à justiça e o desestímulo a demandas temerárias.

É por este mesmo motivo, aliás, que “a concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas” (§ 4.º). Nada mais natural, porque a gratuidade de justiça não pode se transformar numa *licença* para a litigância de má-fé ou para a prática de condutas que de algum modo obstruam, tumultuem ou prejudiquem o bom andamento do processo (*contempt of court*). Reprime-se, deste modo, o *exercício abusivo* por seu beneficiário do direito à gratuidade de justiça, excluindo da isenção os valores por ele devidos a este título.

A exigibilidade da obrigação de pagar ao final as despesas (inclusive honorários)³²⁰ submete-se à condição de “nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade” (§ 3.º). A dívida pode ser cobrada, com efeito em *até* cinco anos do trânsito em julgado da decisão que fixar as despesas (prazo prescricional), não *após* o escoamento

deste prazo. Para tanto, o credor precisará demonstrar – a ele incumbe o ônus desta prova – que o vencido passou a ter condições financeiras de suportar o pagamento das despesas. Não lhe será permitido *recolocar* em discussão a questão relativa ao acerto da decisão que havia deferido a gratuidade, mas sim demonstrar que um *fato novo* – nunca a reavaliação de fatos antigos – alterou as bases fáticas sobre os quais se sustenta a gratuidade. Esta exigência, como se explicou, não se aplica à cobrança de indenização por litigância de má-fé ou de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Mas se a situação financeira do beneficiário se tornou neste ínterim apenas um pouco melhor, mas não melhor o suficiente para lhe permitir pagar *todas as despesas à vista*, permite-se ao juiz, por analogia, reconhecer a exigibilidade de apenas um percentual da dívida total ou mesmo determinar o seu pagamento parcelado. Faz-se, assim, uma ponderação mais equilibrada entre a garantia do acesso à justiça e a necessidade de desestimular demandas temerárias.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1.º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2.º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3.º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4.º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5.º Na hipótese do § 4.º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6.º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7.º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Direito anterior – art. 35 do CPC/1973.

Direito comparado – § 117 da ZPO alemã e art. 18 da Lei de Assistência Judiciária portuguesa.

1. Requerimento de gratuidade de justiça. Qualquer pessoa, como se viu nos comentários ao art. 98, pode ser beneficiária de gratuidade de justiça, física ou jurídica, dotada ou não de personalidade jurídica,³²¹ desde que lhe falte recursos para suportar os custos do processo sem comprometer a sua própria dignidade e independentemente da posição que ocupa na relação jurídica processual (autor, réu, terceiro interveniente).

Este pedido, de que não decorre a suspensão do processo, pode ser feito em qualquer momento de seu trâmite (§ 1.º)³²² e sem forma especial, mesmo em grau de recurso (*caput*). O interessado não perde o direito à gratuidade, assim, se deixar de pedi-la na primeira oportunidade que tiver para se manifestar, mas se o requerimento vier a ser indeferido, ele só poderá ser renovado com fundamento na ocorrência de fatos novos (posteriores à decisão de indeferimento). A concessão “tardia” da gratuidade, de todo modo, terá efeitos apenas *ex nunc*.³²³ Se formulado o requerimento nas razões de um recurso, “o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento” (§ 7.º).

A gratuidade de justiça só pode ser deferida mediante provocação do interessado,³²⁴ mas pode ser revogada *ex officio* se se convencer o juiz de que algum *fato novo* justifica a revogação (apenas o fato novo, não a reavaliação dos fatos conhecidos pelo juiz quando do deferimento). A lei presume verdadeira a declaração da pessoa física de que não tem recursos (presunção relativa – § 3.º),^{325 - 326} mas a pessoa jurídica tem o ônus de provar³²⁷ a insuficiência.³²⁸ “A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (§ 4.º), embora esta circunstância deva ser levada em consideração pelo juiz quando decidir sobre o pedido à luz das particularidades do caso concreto (por exemplo, advocacia *pro bono*, honorários apenas de êxito, honorários módicos, *third party funding* etc).

O juiz deve decidir *logo* se defere ou não a gratuidade, sem deixar este julgamento para a sentença ao final. Embora não precise ouvir a parte contrária antes de decidir (contraditório diferido, conforme art. 100), deverá ele evitar indeferir o pedido sem antes dar ao interessado a possibilidade de melhor se explicar (§ 2.º) por força do princípio da cooperação que permeia o Código de Processo Civil de 2015. Mas não se trata de uma *obrigatoriedade*. Tudo depende das circunstâncias concretas do caso. Se absurdo o pedido, nada proíbe o indeferimento de plano.³²⁹ Omissis o juiz, ademais, *presume-se o deferimento* (deferimento tácito, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).³³⁰

O direito à gratuidade é *pessoal*, no sentido de que não se estende aos litisconsortes ou sucessores do beneficiário (§ 6.º) nem tampouco a seus advogados (§ 5.º). Cada um deve, em nome próprio, formular o requerimento. A pessoalidade deste direito é visível quando a pretensão deduzida em um determinado recurso interessa “exclusivamente” aos advogados do beneficiário – caso da fixação de honorários de sucumbência. Ainda que recorrente o beneficiário, ele o fará na qualidade de substituto processual de seus advogados quando o recurso versar *exclusivamente* sobre os honorários. Neste caso, não se dispensa o preparo, salvo, naturalmente, se os próprios advogados demonstrarem seu direito à gratuidade (§ 5.º).

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.

Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.

Direito anterior – art. 35 do CPC/1973.

Direito comparado – § 118 da ZPO alemã e arts. 10, 12, 27 e 28 da Lei de Assistência Judiciária portuguesa.

1. Impugnação do requerimento de gratuidade de justiça. O deferimento da gratuidade de justiça, como se viu nos comentários ao art. 99, não exige a prévia oitiva da parte contrária (contraditório diferido), o que não impede o juiz de, se entender conveniente, ouvir a ela ou ao próprio requerente antes de decidir.³³¹ Deferida a gratuidade, no entanto, o adversário deverá *sempre* poder oferecer impugnação, perante o próprio juízo que a deferiu, no mesmo processo e sem suspensão de seu trâmite (sem a autuação em apartado característica do regime anterior).³³² Sobre o cabimento de recurso da decisão que deferir, indeferir ou revogar a gratuidade, confirmam-se os comentários ao art. 101.

O adversário do beneficiário tem o *ônus* de impugnar tempestivamente a *concessão*, não o mero requerimento, sob pena de preclusão. O prazo para a impugnação, portanto, não é do *pedido* de gratuidade, mas da *decisão* que a defere.³³³ O impugnante terá em regra quinze dias para oferecer a impugnação, contados de sua intimação do deferimento, independentemente se parte originária ou terceiro interveniente o beneficiário. Mas se a intimação do deferimento for anterior à contestação, o prazo será o da própria contestação. Se anterior à réplica, e beneficiário da

gratuidade o réu, o prazo será – a lógica é a mesma – o da própria réplica. Se intimado o recorrido do deferimento antes ou ao mesmo tempo em que é intimado para contrarrazoar um recurso, o prazo será o das contrarrazões. O juiz *deve* decidir logo a impugnação, sem deixar seu julgamento para a sentença ao final, ainda que da decisão que *mantém* a gratuidade não caiba agravo de instrumento.³³⁴ Recorde-se, por fim, que o ônus de provar a insuficiência de recursos é do requerente, se pessoa jurídica, ou de seu adversário, se pessoa física, conforme se explicou nos comentários ao art. 99.

2. Efeitos da revogação da gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, embora só possa ser deferida mediante provocação do interessado, pode vir a ser revogada *ex officio* se o juiz se convencer de que algum *fato novo* justifica a revogação (apenas o fato novo, não a reavaliação dos fatos conhecidos pelo juiz quando do deferimento original). Mas este fato deve se relacionar à própria insuficiência de recursos do beneficiário, não ao seu comportamento no curso do processo.³³⁵ A revogação tem efeitos *ex tunc*, e não apenas *ex nunc* como o deferimento tardio, razão pela qual, nesta hipótese, “a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa” (parágrafo único). Sobre as consequências do não pagamento destas despesas, confirmam-se os comentários ao art. 102.

A norma serve, evidentemente, para desestimular a formulação abusiva de pedidos de gratuidade de justiça. Esta multa é aquela devida a título de ato atentatório à dignidade da justiça, não de litigância de má-fé. Mas o *contempt of court* não decorre *automaticamente* da revogação da gratuidade de justiça, sendo preciso investigar se estão presentes os requisitos específicos para o seu reconhecimento.³³⁶ Como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a simples negativa na concessão da assistência não conduz automaticamente à incidência da multa do art. 4.º, § 1.º, da Lei 1.060/1950,³³⁷ devendo ser cabalmente demonstrada a intenção da parte de induzir o Poder Judiciário a erro, se aproveitando indevidamente do benefício”.³³⁸ Por se tratar de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, o destinatário de seu pagamento é a Fazenda Pública, não o adversário prejudicado (o que não impede a condenação do requerente *também* por litigância de má-fé, considerando-se a independência entre as duas espécies de sanção, desde que verificados os requisitos para sua configuração).³³⁹ Não paga espontaneamente, a multa de que trata o parágrafo único “deverá”, por fim, ser inscrita em dívida ativa (do respectivo estado, se se tratar de processo em curso perante a Justiça Estadual; da União, se estiver em curso perante uma das justiças federais).

Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1.º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

§ 2.º Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Direito anterior – art. 35 do CPC/1973.

Direito comparado – § 127 da ZPO alemã e art. 26 da Lei de Assistência Judiciária portuguesa.

1. Recurso da decisão que defere o pedido de gratuidade de justiça. A decisão que *defer* a gratuidade de justiça, proferida na fase de conhecimento do processo, não é imediatamente recorrível, aplicando-se a ela o disposto no art. 1.009, § 1.º, segundo o qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Se o deferimento, ao contrário, for proferido na “fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de

execução e no processo de inventário”, o agravo de instrumento é o recurso cabível (art. 1.115, parágrafo único).³⁴⁰

2. Recurso da decisão que indefere ou revoga o pedido de gratuidade de justiça. Da decisão que *indefere* ou que *revoga* a gratuidade e justiça, “caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação” (*caput*). Dispensa-se de preparo este recurso (§ 1.º), tanto se se tratar de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória quanto de apelação através da qual se impugna também [mas não obrigatoriamente apenas ele] o capítulo da sentença relativo à gratuidade de justiça. Incide também esta regra mesmo quando *parcial* o indeferimento ou a revogação.³⁴¹ Em todos estes casos, o relator deverá decidir a questão de gratuidade *liminarmente* (em regra, antes de julgar, com mérito, ou sem ele, o próprio recurso). Diz-se em regra porque, se o relator nega seguimento monocraticamente ao recurso, ele decidirá *simultaneamente* a questão da gratuidade. Mantida a decisão recorrida, o recorrente deverá intimado para, no prazo de cinco dias, fazer o preparo sob pena de não-conhecimento do recurso (§ 2.º).

Art. 102. Sobrevindo o trânsito em julgado de decisão que revoga a gratuidade, a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Não efetuado o recolhimento, o processo será extinto sem resolução de mérito, tratando-se do autor, e, nos demais casos, não poderá ser deferida a realização de nenhum ato ou diligência requerida pela parte enquanto não efetuado o depósito.

Direito anterior – art. 35 do CPC/1973.

Direito comparado – § 124 da ZPO alemã e art. 10 da Lei de Assistência Judiciária portuguesa.

1. Efeitos da decisão que revoga a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça, como se viu nos comentários ao art. 100, embora só possa ser deferida mediante provocação do interessado, pode vir a ser revogada *ex officio* se o juiz se convencer de que algum *fato novo* justifica a revogação (apenas o fato novo, não a reavaliação dos fatos conhecidos pelo juiz quando do deferimento original). A revogação tem efeitos *ex tunc*, e não apenas *ex nunc* como o deferimento tardio, razão pela qual, nesta hipótese, “a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa” (art. 100, parágrafo único).

A decisão que revoga a gratuidade de justiça, no entanto, produzirá efeitos apenas quando *ela* transitar em julgado. Sua eficácia não se vincula, assim, ao trânsito em julgado da sentença final, que extinguir o processo com ou sem julgamento de seu mérito. Com o trânsito em julgado da decisão que revoga a gratuidade, restabelece-se *ex tunc* o ônus de adiantamento de despesas de que dispensado o beneficiário pela decisão revogada, razão pela qual “a parte deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas de cujo adiantamento foi dispensada, inclusive as relativas ao recurso interposto, se houver, no prazo fixado pelo juiz, sem prejuízo de aplicação das sanções previstas em lei” (*caput*). O juiz deve fixar este prazo com razoabilidade. Não efetuado o recolhimento tempestivo destas despesas, o processo será extinto, sem julgamento do mérito, se beneficiário o autor. Se outro sujeito, nenhum ato processual por ele realizado será eficaz até a regularização das despesas (parágrafo único). O dispositivo pode parecer rigoroso à primeira vista, mas sua função é exatamente a de desestimular a formulação abusiva de pedidos de gratuidade de justiça.

1

A dimensão subjetiva da litigância de má-fé é repetidamente sublinhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção...” (AgRg no REsp 1374761/MS, 4.^a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 20.02.2014, *DJe* 26.03.2014).

2

“O instituto da litigância de má fé é tipicamente nacional (...). A litigância de má fé surge, por quanto foi apontado, como um instituto processual, de tipo público e que visa o imediato policiamento do processo. Não se trata de uma manifestação de responsabilidade civil, que pretenda suprimir danos, ilícita e culposamente causados a outrem, através de auctuações processuais. Antes corresponde a um subsistema sancionatório próprio, de âmbito limitado e com objectivos muito práticos e restritos (...). Quanto à culpa e na sequência da evolução acima retratada, são hoje penalizadas, como litigância, de má fé e determinadas condutas especialmente tipificadas, desde que cometidas: – com dolo; com negligência grave” (*Antonio Menezes Cordeiro*, Litigância de má fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’, p. 14, 26 e 28).

3

Monograficamente: Walter Zeiss, *Die arglistige Prozesspartei*, p. 203. Também Horst Konzen, *Rechtsverhältnisse zwischen Prozessparteien*, p. 79, Max Vollkomer, *Zivilprozessordnung (Zöller)*, p. 9 e Walter Zimmermann, *Zivilprozessordnung*, p. 25.

4

“In the English system of administration of justice, civil and criminal, the doctrine of contempt of court plays a central, fundamental part. It is as ancient as the common law. It is deeply embedded in the English legal system and operates to this day wherever the common law has taken root (...). The doctrine applies to the whole machinery of justice, and is not limited to the civil enforcement process. Its underlying objective is to empower the court to prevent or punish conduct which may tend to obstruct, prejudice or abuse the administration of justice either generally or in relation to a particular case (...). A civil contempt is therefore essentially concerned with the enforcement of judgments and orders of the court, but it is also concerned to uphold the authority of the law and to maintain the rule of law” (Jack Jacob, *The fabric of English civil justice*, p. 206). Mais recentemente, Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 507. Sobre o seu desenvolvimento histórico: John Fox, *The history of contempt of court*, p. 1. Nos Estados Unidos: Hazard, Leubsdorf, Bassett, *Civil Procedure*, p. 399.

5

Para mais detalhe de sua história no Brasil: Luiz Rodrigues Wambier, *O contempt of court na recente experiência brasileira – anotações a respeito da necessidade premente de se garantir efetividade às decisões judiciais*, *Revista dos Tribunais*, vol. 119, p. 35.

6

“Its underlying objective is to empower the court to prevent or punish conduct which may tend to obstruct, prejudice or abuse the administration of justice” (Jack Jacob, *The fabric of English civil justice*,

7

“Setting aside contempt proceedings for courtroom misconduct, these fall into three categories. Coercive contempt sanctions impose accumulating fines or imprisonment until the contemnor complies. Compliance is thus the goal, and at any time the contemnor can avoid all further sanctions by compiling. Compensatory contempt sanctions recompense the injured party for the damage that contempt caused, which in the case of discovery disputes usually means assessing attorney fees and other litigation expenses. Punitive contempt sanctions impose fines or imprisonment as punishment for the contemnor’s violation” (Hazard, Leubsdorf, Bassett, *Civil Procedure*, p. 399).

8

“Constitui atentado, no processo civil de conhecimento, a prática de atos capazes de alterar os meios instrumentais pertinentes à causa, como são os bens os quais deva incidir ou haja incidido alguma medida determinada pelo juiz (...) ou as provas pertinentes ao caso (...). Como a alteração desses elementos externos pode influir no julgamento da causa ou frustrar-lhe os efeitos, o atentado é sancionado severamente pela lei...” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 3, p. 178).

9

Em sentido contrário: “In these various situations, non-compliance need not be deliberate or calculated. It is normally enough that the act or omission is not accidental” (Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 508).

10

Sobre este ponto: “A multa do art. 601 do CPC pode ser aplicada de imediato, prescindindo da prévia advertência do devedor de que a sua conduta constitui ato atentatório à dignidade da justiça. A regra do art. 599, II, do CPC fica a critério do Juiz, podendo ser adotada quando este considerar que será de fato proveitosa” (REsp 1.101.500/RJ, 3.^a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 27.05.2011)” (AgRg no REsp 1192155/MG, 4.^a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 12.08.2014, *DJe* 01.09.2014).

11

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1.º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1.º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

12

Segundo o art. 97, com efeito, “a União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União e aos Estados, e outras verbas previstas em lei”.

13

Arruda Alvim Wambier, Lins Conceição, Silva Ribeiro, Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 155.

14

“A party who disobeys an injunction will be guilty of contempt even if he later persuades the court to set aside the relevant order or injunction” (Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 509).

15

“A contempt proceeding leading to punitive sanctions is known as criminal contempt, and is subject to many of the safeguards attending criminal prosecutions” (Hazard, Leubsdorf, Bassett, *Civil Procedure*, p. 399).

16

“Coercive contempt imposes accumulating fines or imprisonment until the contemnor can avoid all further sanctions by complying” (Hazard, Leubsdorf, Bassett, *Civil Procedure*, p. 399).

17

“Coercive imprisonment is remedial, of course, only when the defendant is able to comply. As the Supreme Court has said, “to jail one for contempt for omitting an act he is powerless to perform would make the proceeding purely punitive, to describe it charitably” (The Coercive Function of Civil Contempt, *The University of Chicago Law Review*, vol. 33, p. 131).

18

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 12, p. 278.

19

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 12, p. 279.

20

Segundo o art. 712 do Código de Processo Civil de 1939, por exemplo, “a parte que, no correr do processo, se reputar lesada por inovação contra direito, poderá requerer que a lide volte ao estado anterior e fique

interdita a audiência da parte adversa até a purgação do atentado, quando reconhecido”. Para o art. 881 do CPC/1973, “a sentença, que julgar procedente a ação, ordenará o restabelecimento do estado anterior, a suspensão da causa principal e a proibição de o réu falar nos autos até a purgação do atentado”. Jorge Americano via esta proibição em 1960, por exemplo, com bons olhos (Jorge Americano, *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*, vol. 3, p. 97).

21

A dimensão subjetiva da litigância de má-fé é repetitivamente sublinhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção...” (AgRg no REsp 1374761/MS, 4.^a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.02.2014, *DJe* 26.03.2014).

22

“O instituto da litigância de má fé é tipicamente nacional (...). A litigância de má fé surge, por quanto foi apontado, como um instituto processual, de tipo público e que visa o imediato policiamento do processo. Não se trata de uma manifestação de responsabilidade civil, que pretenda suprimir danos, ilícita e culposamente causados a outrem, através de auctuações processuais. Antes corresponde a um subsistema sancionatório próprio, de âmbito limitado e com objectivos muito práticos e restritos (...). Quanto à culpa e na sequência da evolução acima retratada, são hoje penalizadas, como litigância, de má fé e determinadas condutas especialmente tipificadas, desde que cometidas: – com dolo; com negligência grave” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’*, p. 14, 26 e 28).

23

Monograficamente: Walter Zeiss, *Die arglistige Prozesspartei*, p. 203. Também Horst Konzen, *Rechtsverhältnisse zwischen Prozessparteien*, p. 79, Max Vollkomer, *Zivilprozessordnung (Zöller)*, p. 9 e Walter Zimmermann, *Zivilprozessordnung*, p. 25.

24

Marinoni, Arenhart, Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 82.

25

Este tema merece ser tratado também monograficamente. Neste sentido, por exemplo: Brunela Vieira de Vincenzi, *A boa-fé no processo civil*, p. 157. Também Viana e Gagliano, Boa-fé objetiva processual – reflexões quanto ao atual CPC e ao projeto do novo Código, *Revista Forense*, vol. 416, p. 521.

26

“Permite-se, portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores. Vale dizer, desnecessária é a aferição subjetiva do conhecimento da parte acerca da ilicitude de sua conduta, subjetivismo que, além de implicar em dificuldades no campo probatório, pode, ao mesmo tempo, tornar iníquas as normas repressoras da má-fé processual e perpetuar a utilização do

processo para fins escusos. Dessa forma, permite-se a punição de quaisquer condutas contrárias à boa-fé processual e não apenas os comportamentos dolosos” (Antonio do Passo Cabral, O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, *Revista de Processo*, vol. 126, p. 79).

28

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 3, p. 491.

29

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 104.

30

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 104.

31

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 267.

32

Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no processo moderno*, p. 314.

33

Fernando da Fonseca Gajardoni, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini, Dantas), p. 492.

34

AgRg no REsp 709.372/RJ, 3.^a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.05.2011, *DJe* 03.06.2011.

35

O tema é polêmico e popular na Alemanha ao menos desde a entrada em vigor da novela de 1933 e da publicação, em 1939, do seminal *Wahrheitspflicht und Aufklärungspflicht der Parteien im Zivilprozess* de Fritz von Hippel. Esta novela é entendida como um dos símbolos do fim da fase liberal do processo civil alemão (Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 22) e encarado este dever com enorme desconfiança por processualistas mais liberais. Por exemplo: Juan Montero Aroca, *El Proceso Civil. Los Procesos Ordinarios de Declaración y de Ejecución (Tratados, Comentarios y Practicas Procesales)*, p. 188. Para uma análise da dimensão ideológica do tema: Joan Picó I Junoy, El principio de la buena fe procesal y su fundamento constitucional, *Revista de Processo*, vol. 196, p. 137. Recomenda-se também a leitura de Luiz Machado Guimarães, Processo autoritário e regime liberal, *Estudos de direito processual civil*, p. 128).

Claus Wagner, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1075.

José Manoel de Arruda Alvim Netto, Deveres das partes e dos procuradores, no direito processual civil brasileiro (a lealdade no processo), *Revista de Processo*, vol. 69, p. 20.

Rosenberg, Schwab, Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 328.

Baumbach, Lauterbach, Albers, Hartmann, *Zivilprozessordnung*, p. 684.

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 144.

Sobre a *discovery*: Renato Beneduzi, Substantiierung, Notice-Pleading e Fact-Pleading: A relação entre escopo das postulações e função da prova nos processos alemão, americano e inglês, *Revista dos Tribunais*, vol. 245, p. 454.

José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, *Temas de direito processual*, p. 27.

A expressão “proibição da chicana” é aqui empregado no sentido *processual* que lhe dá a língua portuguesa, não no de “Schikaneverbot” de que trata o § 226 BGB, segundo o qual o exercício de um direito é inadmissível quando ele só possa ter por objetivo causar dano a outrem. Para o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, “o abuso do direito de recorrer é patente! Não pode o STJ coadunar com a *chicana processual* do recorrente, que mais uma vez apresenta recurso completamente infundado” (RCDESP na Pet 6.212/SP, 1.^a Seção, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 27.08.2008, DJe 08.09.2008).

“A aplicação geral do instituto do abuso do direito no campo do Direito processual civil surge, hoje, indiscutível. Nenhuma posição jurídico-subjectiva está imune a uma sindicância, no momento do seu exercício, feita à luz dos valores fundamentais do ordenamento em causa. Não há alternativa: o direito subjectivo imune ao sistema – e, como tal, susceptível de um exercício ilimitado – acabaria por se colocar fora do próprio ordenamento, tornando-se irreconhecível” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má*

45

“O abuso do direito constitui uma fórmula tradicional para exprimir a ideia do exercício disfuncional de posições jurídicas, isto é: do exercício concreto de posições jurídicas que, embora correcto em si, acabe por contundir com o sistema jurídico na sua totalidade. Antecipamos pois que, mau grado o seu alcance vocabular imediato, não há, no abuso do direito, nem ‘abuso’ nem, necessariamente, um direito subjectivo: apenas uma auctuação humana estritamente conforme com as normas imediatamente aplicáveis, mas que, tudo visto, se apresenta ilícita por contrariedade ao sistema, na sua globalidade” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má fé, abuso do direito de acção e culpa 'in agendo', p. 33).*

46

Outros casos de exercício abusivo de posições processuais podem ser encontrados esparsamente em todo o CPC. Segundo o art. 311, por exemplo, a tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando “ficar caracterizado o *abuso do direito de defesa* ou o manifesto propósito protelatório da parte” (inc. I). Outros podem ser construídos sem qualquer previsão legislativa expressa à luz apenas da cláusula geral da boa-fé, como a proibição do *venire contra factum proprium* ou da *Verwirkung* no processo. Sobre o ponto: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 104.

47

“Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito a deliberação de mal-fazer – *animus nocendi*” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 578).

48

Tepedino, Barboza, Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 1, p. 346.

49

Em sentido contrário: Fernando da Fonseca Gajardoni, *No novo CPC, demandar contra precedente é litigância de má-fé?* Disponível em: [<http://jota.uol.com.br/no-novo-cpc-demandar-contraprecedente-e-litigancia-de-ma-fe>]. Acesso em: 15.02.2016.

50

Por exemplo: “Descabe a interposição de recurso especial contra o acórdão que, examinando embargos de declaração opostos na origem, decide pela ausência de vícios em decisão monocrática proferida pelo relator. Essa situação configura ausência de esgotamento de instância, atraindo o óbice da Súmula 281/STF” (AgRg no REsp 1527836/RR, 2.^a Turma, Rel. Ministro OG Fernandes, j. 27.10.2015, DJe 16.11.2015).

51

“Por outro lado, a chamada boa-fé objetiva é baseada em padrões de conduta social, voltada para a

proteção às expectativas de que os demais membros do conjunto social nutrem de todos nós. Vale dizer, protegem-se os interesses do alter, a confiança de que todos pautem suas condutas de acordo com as convenções sociais, aquilo que legitimamente é esperado de cada parte. É a idéia de um “arquétipo moral”, passando a proteção processual da boa-fé, nos dias de hoje, da tradicional e insuficiente tutela subjetiva da vontade para a necessária tutela objetiva da confiança. Permite-se, portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores” (Antonio do Passo Cabral, O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, *Revista de Processo*, vol. 126, p. 79).

52

AgRg no REsp 709.372/RJ, 3.^a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.05.2011, *DJe* 03.06.2011.

53

Arruda Alvim Wambier, Lins Conceição, Silva Ribeiro, Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 156.

54

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 347.

55

Sobre as dificuldades para sua implementação: Lamy, Reschke, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral, Cramer), p. 144.

56

Neste sentido: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 70.

57

Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código Civil interpretado*, vol. 1, p. 337.

58

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 3, p. 491.

59

A dimensão subjetiva da litigância de má-fé é repetidamente sublinhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção...” (AgRg no [REsp 1.374.761/MS](#), 4.^a Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.02.2014,

DJe 26.03.2014). Também na vigência do CPC de 2015: “Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII e 18, § 2.º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1.236.192/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, 1.ª Turma, j. 22.05.2018, DJe 01.06.2018).

60

“O instituto da litigância de má-fé é tipicamente nacional (...). A litigância de má-fé surge, por quanto foi apontado, como um instituto processual, de tipo público e que visa o imediato policiamento do processo. Não se trata de uma manifestação de responsabilidade civil, que pretenda suprimir danos, ilícita e culposamente causados a outrem, através de actuações processuais. Antes corresponde a um subsistema sancionatório próprio, de âmbito limitado e com objectivos muito práticos e restritos (...). Quanto à culpa e na sequência da evolução acima retratada, são hoje penalizadas, como litigância, de má-fé e determinadas condutas especialmente tipificadas, desde que cometidas: com dolo; com negligência grave” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má-fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’*, p. 14, 26 e 28).

61

Monograficamente: Walter Zeiss, *Die arglistige Prozesspartei*, p. 203. Também Horst Konzen, *Rechtsverhältnisse zwischen Prozessparteien*, p. 79; Max Vollkomer, *Zivilprozessordnung (Zöller)*, p. 9 e Walter Zimmermann, *Zivilprozessordnung*, p. 25.

62

Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 82.

63

Este tema merece ser tratado também monograficamente. Neste sentido, por exemplo: Brunela Vieira de Vincenzi, *A boa-fé no processo civil*, p. 157. Também Viana; Gagliano, Boa-fé objetiva processual – reflexões quanto ao atual CPC e ao projeto do novo Código, *Revista Forense*, vol. 416, p. 521.

64

“Permite-se, portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores. Vale dizer, desnecessária é a aferição subjetiva do conhecimento da parte acerca da ilicitude de sua conduta, subjetivismo que, além de implicar em dificuldades no campo probatório, pode, ao mesmo tempo, tornar iníquas as normas repressoras da má-fé processual e perpetuar a utilização do processo para fins escusos. Dessa forma, permite-se a punição de quaisquer condutas contrárias à boa-fé processual e não apenas os comportamentos dolosos” (Antonio do Passo Cabral, O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, *Revista de Processo*, vol. 126, p. 79).

66

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 3, p. 491.

67

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 104.

68

Idem, *ibidem*.

69

Neste sentido, também Fernando da Fonseca Gajardoni, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 303. Em sentido contrário: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civi* (Scarpinella Bueno), I, vol. 2, p. 72; Carlos Alberto de Salles (Scarpinella Bueno), *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 436, Kleber Clazzaro, in: Cunha, *Código de Processo Civil comentado*, p. 208 e Lamy; Reschke, in: Cabral; Cramer, *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 146.

70

Cândido Rangel Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 267.

71

Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no processo moderno*, p. 314.

72

“Por outro lado, a chamada boa-fé objetiva é baseada em padrões de conduta social, voltada para a proteção às expectativas de que os demais membros do conjunto social nutrem de todos nós. Vale dizer, protegem-se os interesses do alter, a confiança de que todos pautem suas condutas de acordo com as convenções sociais, aquilo que legitimamente é esperado de cada parte. É a ideia de um ‘arquétipo moral’, passando a proteção processual da boa-fé, nos dias de hoje, da tradicional e insuficiente tutela subjetiva da vontade para a necessária tutela objetiva da confiança. Permite-se, portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores” (Antonio do Passo Cabral, O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, *Revista de Processo*, vol. 126, p. 79).

73

AgRg no REsp 709.372/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.^a Turma, j. 24.05.2011, *DJe* 03.06.2011.

74

Por isso, também a responsabilidade civil processual. Neste sentido, com remissões legislativas ainda ao Código de Processo Civil de 1973: “É imprescindível a demonstração do prejuízo sofrido pela parte contrária para que o litigante de má-fé seja condenado a pagar-lhe a indenização do artigo 18, *caput* e § 2.º, do CPC” (EDcl no AgRg no AREsp 532.563/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4.^a Turma, j. 10.02.2015,

75

EREsp 1133262/ES, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.06.2015, DJe 04.08.2015.

76

Em sentido contrário, por exemplo: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 72; Carlos Alberto de Salles, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 436; e Kleber Clazzaro, *Código de Processo Civil comentado*, p. 208.

77

Neste sentido, também Fernando da Fonseca Gajardoni, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 303. Em sentido contrário: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 72; Carlos Alberto de Salles, in: Scarpinella Bueno, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 436, Kleber Clazzaro, in: Cunha, *Código de Processo Civil comentado*, p. 208; e Lamy; Reschke, in: Cabral; Cramer, *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*, p. 146.

78

A expressão “proibição da chicana” é aqui empregado no sentido *processual* que lhe dá a língua portuguesa, não no “Schikaneverbot” de que trata o § 226 BGB, segundo o qual o exercício de um direito é inadmissível quando ele só possa ter por objetivo causar dano a outrem. Para o Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, “o abuso do direito de recorrer é patente! Não pode o STJ coadunar com a *chicana processual* do recorrente, que mais uma vez apresenta recurso completamente infundado” (RCDESP na Pet 6.212/SP, rel. Min. Humberto Martins, 1.^a Seção, j. 27.08.2008, DJe 08.09.2008).

79

“A aplicação geral do instituto do abuso do direito no campo do Direito processual civil surge, hoje, indiscutível. Nenhuma posição jurídico-subjectiva está imune a uma sindicância, no momento do seu exercício, feita à luz dos valores fundamentais do ordenamento em causa. Não há alternativa: o direito subjectivo imune ao sistema – e, como tal, susceptível de um exercício ilimitado – acabaria por se colocar fora do próprio ordenamento, tornando-se irreconhecível” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má-fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’*, p. 85).

80

“O abuso do direito constitui uma fórmula tradicional para exprimir a ideia do exercício disfuncional de posições jurídicas, isto é: do exercício concreto de posições jurídicas que, embora correcto em si, acabe por contundir com o sistema jurídico na sua globalidade. Antecipamos pois que, mau grado o seu alcance vocabular imediato, não há, no abuso do direito, nem ‘abuso’ nem, necessariamente, um direito subjectivo: apenas uma actuação humana estritamente conforme as normas imediatamente aplicáveis, mas que, tudo visto, se apresenta ilícita por contrariedade ao sistema, na sua globalidade” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má-fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’*, p. 33).

81

“Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito a deliberação de mal-fazer – animus nocendi” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 578).

82

“Por outro lado, a chamada boa-fé objetiva é baseada em padrões de conduta social, voltada para a proteção às expectativas de que os demais membros do conjunto social nutrem de todos nós. Vale dizer, protegem-se os interesses do alter, a confiança de que todos pautem suas condutas de acordo com as convenções sociais, aquilo que legitimamente é esperado de cada parte. É a ideia de um ‘arquétipo moral’, passando a proteção processual da boa-fé, nos dias de hoje, da tradicional e insuficiente tutela subjetiva da vontade para a necessária tutela objetiva da confiança. Permite-se, portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores” (Antonio do Passo Cabral, O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, *Revista de Processo*, vol. 126, p. 79).

83

Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 1, p. 346.

84

AgRg no REsp 709.372/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.^a Turma, j. 24.05.2011, *DJe* 03.06.2011.

85

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 152.

86

Idem, p. 153.

87

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 126.

88

O tema é polêmico e popular na Alemanha ao menos desde a entrada em vigor da novela de 1933 e da publicação, em 1939, do seminal *Wahrheitspflicht und Aufklärungspflicht der Parteien im Zivilprozess* de Fritz von Hippel. Esta novela é entendida como um dos símbolos do fim da fase liberal do processo civil alemão (Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 22) e encarado este dever com enorme desconfiança por processualistas mais liberais. Por exemplo: Juan Montero Aroca, *El Proceso Civil. Los Procesos Ordinarios de Declaración y de Ejecución* (Tratados, Comentarios y Practicas Procesales), p. 161. Para uma análise da dimensão ideológica do tema: Joan Picó I Junoy, El principio de la buena fe procesal y

su fundamento constitucional, *Revista de Processo*, vol. 196, p. 132.

89

Claus Wagner, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1075.

90

José Manoel de Arruda Alvim Netto, Deveres das partes e dos procuradores no direito processual civil brasileiro (a lealdade no processo), *Revista de Processo*, vol. 69, p. 20.

91

Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 328.

92

Baumbach; Lauterbach; Albers; Hartmann, *Zivilprozessordnung*, p. 684.

93

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 144.

94

Sobre a discovery: Renato Beneduzi, *Substantiierung, Notice-Pleading e Fact-Pleading*: A relação entre escopo das postulações e função da prova nos processos alemão, americano e inglês, *Revista dos Tribunais*, vol. 245, p. 454.

95

José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, in: _____, *Temas de direito processual*, p. 27.

96

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 375.

97

“A aplicação geral do instituto do abuso do direito no campo do Direito processual civil surge, hoje, indiscutível. Nenhuma posição jurídico-subjectiva está imune a uma sindicância, no momento do seu exercício, feita à luz dos valores fundamentais do ordenamento em causa. Não há alternativa: o direito subjectivo imune ao sistema – e, como tal, susceptível de um exercício ilimitado – acabaria por se colocar fora do próprio ordenamento, tornando-se irreconhecível” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má-fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’*, p. 85).

É preciso, em síntese, eliminar todos os resquícios *criminóides*, se se permite o neologismo, do regramento legal da tutela processual da boa-fé.

AgRg no REsp 709.372/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3.^a Turma, j. 24.05.2011, *DJe* 03.06.2011.

“Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito a deliberação de mal-fazer – *animus nocendi*” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 578).

E isso porque “a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional” (Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 1, p. 346).

Por exemplo: “Descabe a interposição de recurso especial contra o acórdão que, examinando embargos de declaração opostos na origem, decide pela ausência de vícios em decisão monocrática proferida pelo relator. Essa situação configura ausência de esgotamento de instância, atraindo o óbice da Súmula 281/STF” (AgRg no REsp 1527836/RR, rel. Min. OG Fernandes, 2.^a Turma, j. 27.10.2015, *DJe* 16.11.2015).

Este exemplo de “proceder de modo temerário” é do TRF da 3a Região: “Na hipótese dos autos, conforme consta do ato impugnado, pela análise dos documentos constantes dos autos de embargos de terceiro, interpostos por BRUNA RAFAELA VARELAS SOARES, verificou que os bens ofertados para garantia da execução são de propriedade desta, sendo que a representante legal da pessoa jurídica executada e depositária dos bens, CLAUDIA ALAÍDE VARELAS SOARES, tinha pleno conhecimento do fato, vez que seu estabelecimento comercial (academia de ginástica) situa-se no mesmo endereço da pessoa jurídica de propriedade de sua filha, com o mesmo objeto (academia de ginástica), constituída em 2012, após a oferta de bens à penhora, em setembro de 2011. Assim, conclui-se que, realmente, a representante legal da executada procedeu de forma maliciosa e temerária, tendo em vista que ofereceu bens à penhora pertencentes a sua filha, o que, por sua vez, opôs embargos de terceiro, visando obstar o prosseguimento da execução e consequentemente, impedir a realização do leilão, designado para o dia 23 de outubro de 2012, sob o fundamento de que os bens ofertados para garantia da execução são de sua propriedade, violando o princípio da lealdade processual e ofendendo a dignidade da justiça (TRF-3.^a Reg. – 0031169-63.2012.4.03.0000/SP, 5.^a Turma, rel. Des. Paulo Fontes, *DJU* 11.12.2014). Para Barbosa Moreira, “é ‘temerário’ o procedimento inconsiderado, afoito, imprudente, precipitado, como o da parte que procura frustrar o normal desenvolvimento do contraditório, impedindo ou cerceando a manifestação do adversário; promove o cumprimento ou a execução de providência a seu favor antes do momento

oportuno, ou *in genere* sem a cabal satisfação dos pressupostos legais; escolhe o meio mais vexatório e danoso para o outro litigante, a despeito de poder atingir por forma diversa o mesmo resultado” (José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, in: ____, *Temas de direito processual*, p. 28).

104

Para Barbosa Moreira, trata-se de “hipótese de incidente suscitado necessariamente sem razão, ou, em termos mais exatos, com manifesta falta dela, isto é, sem o mínimo de elementos objetivos que possam ao menos fazer supor no litigante a convicção sincera, conquanto errônea, de ter razão” (José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, in: ____, *Temas de direito processual*, p. 28).

105

Com numerosos outros exemplos: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 77.

106

Neste sentido: “O conceito de ‘resistência injustificada’, à semelhança de outros do que se utiliza a lei, é *conceito indeterminado*, cabendo ao juiz precisá-lo à vista das circunstâncias do caso concreto” (José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, in: ____, *Temas de direito processual*, p. 28).

107

José Roberto dos Santos Bedaque, in: Marcato, *Código de Processo Civil interpretado*, p. 64.

108

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 129.

109

Idem, *ibidem*.

110

“A menos que se queira dar à palavra acepção atécnica, não parece próprio qualificar de ‘verdadeira pena’ a sanção imponible ao litigante de má-fé; trata-se de ressarcimento de dano, isto é, de satisfação de um crédito, que o titular (a parte lesada) pode não querer exercer, ou reservar-se para exercer noutra oportunidade” (José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, in: ____, *Temas de direito processual*, p. 30).

111

Dano é o dano processual (o tumulto e o retardamento que a prática destes atos causa ao trâmite do processo, que não se confunde com o *quantum* das perdas e danos devidos a título de reparação.

112

Judith Martins-Costa, *Comentários ao Novo Código Civil*, vol. 5, t. 2, p. 728.

113

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 2, p. 142.

114

Medicus; Lorenz, *Schuldrecht I*, p. 274.

115

José Carlos Barbosa Moreira, A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro, in: *Temas de direito processual*, p. 30.

116

Idem, *ibidem*.

117

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 158.

118

Ou ainda despesas *processuais*.

119

A expressão *despesas processuais* (despesas judiciais) “abrange todos os itens do custo do processo que de algum modo e em algum momento serão devidos aos agentes estatais (Poder Judiciário, auxiliares da Justiça)” (Cândido Dinamarco, *Instituições de Direito Processual Civil*, vol. 2, p. 651). Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 84.

120

Despesas extraprocessuais são aquelas que, embora *relacionadas* ao processo, não se destinam ao pagamento do Estado ou de agentes estatais, como os honorários (contratuais ou de sucumbência), a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 84.

121

Sobre a questão, em linhas gerais: Wilson Fernandes Pimentel, *Acesso responsável à Justiça: o impacto dos custos na decisão de litigar*, p. 16.

122

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

123

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

124

O princípio da sucumbência, como se explicará mais adiante, deverá ser interpretado à luz de outro, o princípio da causalidade.

125

O art. 290, com efeito, dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

126

Max Vollkommer, *Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess*, FS Schwab, p. 503.

127

Sobre este princípio: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 97.

128

Contra: REsp 845.601/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4.^a Turma, j. 06.03.2007, DJ 02.04.2007, p. 290.

129

Neste sentido: “na hipótese em que a realização da perícia é determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes, a nova legislação determina o rateio das respectivas despesas entre as partes, diferentemente do antigo CPC, no qual respondia somente a parte autora por tal incumbência” (REsp 1.548.758/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.^a Turma, j. 10.05.2016, DJe 17.05.2016).

130

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 127.

131

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

132

Ovídio Baptista descreve a condenação nas despesas, corretamente, “*como decorrência pura e simples da derrota*” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 164).

134

“A ‘sentença final’ referida no caput do art. 82 deve ser entendida como a decisão que encerra (por completo) a fase de cognição na primeira instância, sendo indiferente, portanto, o proferimento de eventuais decisões de julgamento parcial de mérito, o que pode ocorrer com fundamento no art. 356” (Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 127).

135

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

136

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

137

Sobre a obrigação de reembolsar os honorários *contratuais*, independentemente do pagamento de honorários *sucumbenciais*, confira-se o próximo item.

138

Neste exemplo do Superior Tribunal de Justiça: “O art. 20, caput e § 2.º, do Código de Processo Civil (atual art. 84 do CPC) enumera apenas as consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as “despesas” que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles “endoprocessuais” ou em razão do processo, quais sejam, “custas dos atos do processo”, “a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico”. Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência, de valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua confiança” (REsp 955.134/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 16.08.2012, *DJe* 29.08.2012).

139

Yussef Said Cahali, *Honorários advocatícios*, p. 285. Também Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, vol. 2, item 627.2.

140

Sobre o princípio da causalidade, também Heitor Vitor Mendonça Sica, O advogado e os honorários sucumbenciais no novo CPC, *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 2, p. 18.

141

REsp 724.341/MG, rel. Ministra Denise Arruda, 1.^a Turma, j. 02.10.2007, *DJ* 12.11.2007, p. 158.

143

“The English costs-shifting rule is rooted both in the public policy of deterring bad or spurious claims and defences and in the basic fairness of indemnifying the victorious party at the conclusion of litigation” (Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526). No processo alemão: Rosenberg, Schwab, Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 442.

144

Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 1324.

145

A razoabilidade é um elemento ressaltado por Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 1347.

146

“Almost all civil litigation systems, except in the United States and Japan, reject the American Rule and follow the ‘English Rule’, under which a prevailing party recovers all or most of its attorney’s fees from the loser” (Hazard, Leubsdorf, Bassett, *Civil Procedure*, p. 26).

148

REsp 1134725/MG, rel. Ministra Nancy Andrigli, 3.^a Turma, j. 14.06.2011, *DJe* 24.06.2011.

149

Jauernig, Hess, *Zivilprozessrecht*, p. 124.

150

Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526.

151

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes, estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo,

recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

152

Default rule é a regra “que rege a situação na ausência de escolha expressa das partes” (Guilherme Recena Costa, *Partes e terceiros na arbitragem*, p. 51).

153

Para mais detalhes sobre a questão: Júlio Guilherme Müller, Bruno Garcia Redondo, Negócios processuais relativos a honorários advocatícios, in: Luis Henrique Volpe Camargo, Marcus Vinícius Furtado. *Coleção Grandes Temas do novo CPC (honorários advocatícios)*, vol. 2, p. 120.

154

Rosenberg, Schwab, Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 459. Também Thomas, Putzo, *Zivilprozessordnung*, p. 251.

155

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 12, p. 156.

156

Nádia de Araújo, Medidas de cooperação interjurisdicional no Mercosul, *Revista de Processo*, vol. 123, p. 108.

158

Contra: *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 163.

159

Alfredo de Araújo Lopes da Costa, *Direito processual civil brasileiro*, vol. 3, p. 30.

160

Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 72.

161

Sem ir tão longe, todavia: REsp 848.424/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, j. 07.08.2008, *DJe* 18.08.2008.

162

Neste sentido: “O autor estrangeiro prestará, nas ações que intentar, caução suficiente às custas e honorários de advogado da parte contrária, se não tiver no Brasil imóveis que lhes assegurem o pagamento. Tal exigência constitui pressuposto processual que, por isso, deve ser satisfeito ao início da relação jurídico processual. Nada impede, porém, que seja ela suprida no decorrer da demanda, não havendo falar em nulidade processual sem que haja prejuízo, especialmente em caso no qual a pessoa jurídica estrangeira já veio pagando adequadamente todas as despesas processuais incorridas e possui filial no país” (REsp 1027165/ES, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.^a Turma, j. 07.06.2011, *DJe* 14.06.2011).

163

“O legislador torna a decisão de inadmissibilidade estável: reputa indiscutível a solução da questão processual que levou à extinção do primeiro processo. Essa estabilidade extrapola o âmbito do processo em que a decisão foi proferida. Reproposta a demanda, o juiz desse segundo processo fica vinculado à decisão sobre a questão processual: se o defeito não for corrigido, a nova demanda não será examinada. Há, aqui, coisa julgada quanto à questão da admissibilidade” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 710).

164

Renato Beneduzi, Prozessurteile e materielle Rechtskraft: sentenças terminativas e coisa julgada material no processo civil alemão, *Revista de Processo*, vol. 229, p. 371.

165

Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão* (2015), p. 92

166

“Prozessurteile, die die Klage wegen Fehlens einer Sachentscheidungsvoraussetzung oder wegen eines entsprechenden Hindernisses als unzulässig abweisen, bewirken zwar materielle Rechtskraft, die sich aber auf den Unzulässigkeitsausspruch beschränkt. Das bedeutet, dass über denselben prozessualen Mangel wegen der materiellen Rechtskraft nicht nochmals gestritten werden kann (Wiederholungsverbot), während das Urteil hinsichtlich anderer prozessualer Merkmale und vor allem hinsichtlich des materiellen Rechts nicht bindet” (Eberhard Schilken, *Zivilprozessrecht*, p. 454).

167

Renato Beneduzi, Prozessurteile e materielle Rechtskraft: sentenças terminativas e coisa julgada material no processo civil alemão, *Revista de Processo*, vol. 229, p. 364.

168

“Mas e se não há este vício? Como rediscutir? Por meio da ação rescisória, desde que ocorra uma das hipóteses do art. 966, I a VIII.” (Teresa Arruda Alvim Wambier, Da ação rescisória, in: Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier. *Temas essenciais do novo CPC*, p. 618).

Lembre-se que “a taxa é um tributo contraprestacional, posto que vinculado a uma prestação específica em favor do contribuinte. É cobrada pela prestação de serviços públicos ou pelo exercício do poder de polícia” (Ricardo Lobo Torres, *Curso de direito financeiro e tributário*, p. 406). Por isso “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da anterioridade” (ADI 1378 MC, rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, j. 30.11.1995), j. 30.11.1995).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao se referir às despesas judiciais e extrajudiciais conjuntamente, emprega o termo despesas “endoprocessuais”: “O art. 20, *caput* e § 2.º, do Código de Processo Civil (atual art. 84 do CPC) enumera apenas as consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as “despesas” que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles “endoprocessuais” ou em razão do processo, quais sejam, “custas dos atos do processo”, “a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico”. Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência, de valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua confiança” (REsp 955.134/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 16.08.2012, *DJe* 29.08.2012).

Sobre o dever da parte vencida de reembolsar os honorários contratuais pagos pela parte vencedora a seus advogados, confirmam-se os comentários ao art. 82.

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

Sobre a obrigação de reembolsar os honorários *contratuais*, independentemente do pagamento de honorários sucumbenciais, confirmam-se os comentários ao art. 83.

“A Lei 8.906/1994 – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (EAOAB), em seus arts. 21 e 23, estabelece que os honorários fixados na condenação pertencem aos advogados empregados. A lei emprega o termo plural “advogados empregados”, certamente admitindo que o empregador, normalmente, terá mais de um advogado empregado e estes, ao longo do processo, terão oportunidade de atuar, ora em conjunto, ora isoladamente, de modo que o êxito, acaso obtido pelo empregador na demanda, será atribuído à equipe de advogados empregados. Confirmando esse entendimento, o Regulamento Geral do EAOAB, explicitando o alcance das referidas normas legais para os advogados empregados, estabelece em seu art. 14, parágrafo único, que: “os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes.” Nada obsta, assim, que, existindo uma associação regularmente criada para representar os interesses dos advogados empregados de determinado empregador, possa essa entidade associativa, mediante autorização estatutária, ser legitimada a executar os honorários sucumbenciais pertencentes aos “advogados empregados”, seus associados, o que apenas facilita a formação, administração e rateio dos recursos do fundo único comum, destinado à divisão proporcional entre todos os associados” (REsp 634.096/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4.^a Turma, j. 20.08.2013, *DJe* 29.08.2013).

176

Mas a eficácia deste dispositivo é contida. Para mais detalhes: Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 131 e Luiz Henrique Volpe Camargo, in: Wambier; Didier Jr; Talamini; Dantas. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 355.

177

Sobre o princípio da causalidade, também Heitor Vitor Mendonça Sica, O advogado e os honorários sucumbenciais no novo CPC, in: Didier Jr. *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 2, p. 18.

178

REsp 724.341/MG, rel. Ministra Denise Arruda, 1.^a Turma, j. 02.10.2007, *DJ* 12.11.2007, p. 158.

179

Como exemplifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A aquisição, pelo locatário, da propriedade do imóvel cuja posse o locador busca reaver mediante a anulação do respectivo contrato de locação importa na superveniente perda do interesse de agir deste último, nos termos dos arts. 462 do CC. 267, VI, do CPC. Em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa. Precedente do STJ. Hipótese em que, quando do ajuizamento da demanda, efetivamente existia o legítimo interesse de agir dos recorridos, sendo certo, ademais, que a perda do objeto da ação se deu por motivo superveniente causado pela recorrente, ao arrematar o imóvel que antes ocupava na condição de locatária” (REsp 1090165/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5.^a Turma, j. 11.05.2010, *DJe* 02.08.2010).

180

Neste sentido: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 152.

181

Leonardo Greco, *Instituições de processo civil*, vol. 1, p. 428.

182

Porque não se permite às partes dispor sobre direito do qual não são titulares (mas sim os advogados da parte vencedora, titulares exclusivos deles). Para mais detalhes: Müller; Redondo, *Negócios processuais relativos a honorários advocatícios*, in: Camargo; Furtado. *Coleção Grandes Temas do novo CPC (honorários advocatícios)*, vol. 2, p. 120.

183

“Os honorários advocatícios, tanto os contratuais quanto os sucumbenciais, têm natureza alimentar e destinam-se ao sustento do advogado e de sua família, portanto são insuscetíveis de penhora (art. 649, IV do CPC). “Todavia a regra disposta no art. 649, inc. IV, do CPC não pode ser interpretada de forma literal. Em determinadas circunstâncias é possível a sua relativização, como ocorre nos casos em que os honorários advocatícios recebidos em montantes exorbitantes ultrapassam os valores que seriam considerados razoáveis para sustento próprio e de sua família. Nesses casos, a verba perde a sua natureza alimentar e a finalidade de sustento.” (REsp 1264358/SC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.11.2014, *DJe* 05.12.2014). Em igual sentido: REsp 1356404/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.06.2013, *DJe* 23.08.2013” (AgRg no REsp 1557137/SC, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.ª Turma, j. 27.10.2015, *DJe* 09.11.2015).

184

“A Corte Especial adotou o novel entendimento de que os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal” (AgRg no REsp 1539760/PR, rel. Min. Herman Benjamin, 2.ª Turma, j. 22.09.2015, *DJe* 11.11.2015).

185

Também Paulo Henrique dos Santos Lucon, *A advocacia no CPC*, in: Cianci; Didier Jr.; Redondo; Dantas; Cunha; Volpe Camargo; Delfino. *Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar*, p. 254.

186

Neste sentido: Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 85, item 53.

187

188

Para mais detalhes: Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, Decisão interlocutória de mérito e honorários advocatícios, in: Volpe Camargo; Furtado. *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 208.

189

“A verba relativa à sucumbência, a despeito de constituir direito autônomo do advogado, não exclui a legitimidade concorrente da parte para discuti-la” (AgRg no AREsp 637.405/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.^a Turma, j. 19.03.2015, *DJe* 26.03.2015).

191

Também Flávio Cheim Jorge, Os honorários advocatícios e o recurso de apelação: um enfoque especial nos honorários recursais, in: Luiz Henrique Volpe Camargo, Marcus Vinícius Furtado. *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 685.

192

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 504.

193

Este dispositivo esvazia o enunciado 453 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, publicado ainda na vigência do CPC/1973, segundo o qual “os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria”. Para mais detalhes: Paulo Henrique dos Santos Lucon, Honorários no novo Código de Processo Civil e as Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, in: Volpe Camargo; Furtado. *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 236.

194

Para mais detalhes: Luciano Vianna Araújo, Sucumbência parcial: o fim da anômala compensação entre credores distintos, in: *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 513. Também Paulo Henrique dos Santos Lucon, A advocacia no CPC, in: Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar, p. 260.

195

REsp 1522102/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.^a Turma, j. 15.09.2015, *DJe* 25.09.2015.

196

Neste sentido: “Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3.º e 8.º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da

nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2.º do referido dispositivo legal. Segundo dispõe o § 6.º do art. 85 do CPC/2015, “[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2.º e 3.º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito” (REsp 1.731.617/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4.ª Turma, j. 17.04.2018, DJe 15.05.2018).

198

Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 1, p. 395.

199

Luiz Henrique Volpe Camargo, in: Wambier; Didier Jr; Talamini; Dantas. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 492.

200

Na vigência do CPC/1973: “A Corte Especial decidiu, no julgamento dos EREsp n. 109.675/RJ, tendo por Relator para o acórdão o Min. Cesar Asfor Rocha, que a verba honorária sucumbencial, devida em percentual sobre o somatório dos valores das prestações vencidas, mais um ano das vincendas, não incide sobre o capital constituído para assegurar o pensionamento, devendo ser arbitrada observando-se os critérios do (§ 4.º do art. 20 do Código de Processo Civil” (REsp 933.937/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 12.06.2012, DJe 16.08.2012).

202

“Nesse caso, é correto entender que não se aplica o § 11, incidindo, em sua plenitude, a regra da ‘cumulação’ constante do § 1.º, todos do art. 85” (Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 130).

203

“De acordo com o § 16, os honorários fixados em quantia certa serão acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado. A correção monetária, por sua vez, incidirá da data de seu arbitramento. Quando, porém, os honorários forem fixados em percentual a correção monetária incidirá a partir do ajuizamento da ação. Já se decidiu que, também nessa hipótese (honorários fixados em percentual), os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, momento em que se configurou a mora” (Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 169).

204

“Tem-se, aí, pois, uma grande novidade, que muito poderá contribuir para a melhoria do sistema, não só por permitir uma remuneração mais adequada do trabalho do advogado, mas também por exercer a função de filtro recursal, desestimulando recursos protelatórios” (Alexandre Freitas Câmara, Honorários de sucumbência recursal, *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p 587).

205

Neste sentido: Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, Os honorários recursais no novo Código de Processo Civil, *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 596.

206

Sobre o ponto: Luiz Henrique Volpe Camargo, Os honorários advocatícios pela sucumbência recursal, *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 726.

207

“De fato, o [art. 85, § 11, do CPC/2015](#), ao prescrever que ‘O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal’, estabeleceu uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais” (EDcl nos EDcl no [REsp 1.644.080/RS](#), Rel. Ministro Herman Benjamin, 2.^a Turma, j. 12.12.2017, *DJe* 19.12.2017).

208

Ou que *devesse* tê-los fixados, como se explicou no item 2, *supra*, quando se falou do momento adequado para a fixação de honorários de sucumbência.

209

“A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do [art. 85, § 11, do CPC/2015](#)” (AO 2.063 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO *DJe*-208 DIVULG 13.09.2017 PUBLIC 14.09.2017).

210

Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, Os honorários recursais no novo Código de Processo Civil, *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 596.

211

“A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a parte deve alegar na primeira oportunidade eventual omissão sobre a fixação de honorários recursais, nos casos em que cabíveis, não sendo suficiente a elaboração do pedido em contrarrazões ao agravo interno interposto pela parte contrária, sob pena de preclusão consumativa” (EDcl no AgInt no [REsp 1.667.976/SC](#), Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2.^a Turma, j. 21.06.2018, *DJe* 27.06.2018).

212

213

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 128.

214

“No que diz respeito às causas *em que for parte* a Fazenda Pública, o [art. 85, § 3.º, I a V, do CPC/2015](#) estabeleceu critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para tal apuração” ([REsp 1.644.846/RS](#), Rel. Ministro Gurgel De Faria, 1.^a Turma, j. 27.06.2017, *DJe* 31.08.2017).

216

“Seja permitido um exemplo para que se tenha claro o alcance da regra. Imagine-se que a Fazenda Pública tenha sido condenada a pagar a alguém valor equivalente a duzentos salários mínimos. Neste caso, por força do disposto no inc. I do art. 85, § 3.º, os honorários serão fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação (isto é, entre vinte e quarenta salários mínimos). Figure-se, agora, a hipótese de condenação da Fazenda a pagar o equivalente a duzentos e um salários mínimos. Neste caso, incidiria o disposto no inc. II do art. 85, § 3.º, de modo que os honorários seriam fixados entre oito e dez por cento (isto é, entre 16,08 e 20,1 salários mínimos). Perceba-se, aqui, que o valor máximo dos honorários seria 0,1 salário mínimo superior ao valor mínimo dos honorários fixados segundo a regra anterior. Facilmente se percebe que seria mais vantajoso para o advogado da parte vencedora que seu cliente obtivesse um proveito econômico menor. Isto, à toda evidência, não faz sentido. Não é assim, porém, que se promove o cálculo dos honorários. Diante da regressividade dos percentuais, o juiz deverá, na sentença, estabelecer que o advogado receberá (no mínimo) dez por cento de duzentos salários mínimos mais oito por cento do salário mínimo excedente. Significa isto dizer que o valor mínimo dos honorários, neste caso, será de 20,08 salários mínimos” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 70).

217

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

218

Ovídio Baptista descreve a condenação nas despesas, corretamente, “*como decorrência pura e simples da derrota*” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 164).

220

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

221

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

222

Exceto em relação aos honorários sucumbenciais, porque as partes não são titulares deste direito.

223

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 171.

224

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 668.

225

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 399.

226

“A obrigação de uma parte infinitesimal das despesas e honorários será até ridícula, irrisória e incompatível com a relevância do processo” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 172).

227

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 399.

228

Com a ressalva de que “importante destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes são questões que não comportam exame no âmbito do recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios” (AgInt no [REsp 1.652.552/MT](#), Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3.^a Turma, j. 26.06.2018, *DJe* 29.06.2018).

229

EDcl no REsp 783.815/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.^a Turma, j. 15.09.2009, *DJe* 28.09.2009.

230

Confirmam-se os comentários aos arts. 82 e 85.

231

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

232

Ovídio Baptista descreve a condenação nas despesas, corretamente, “*como decorrência pura e simples da derrota*” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 164).

234

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

235

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

236

Exceto em relação aos honorários sucumbenciais, porque as partes não são titulares deste direito.

237

Em sentido contrário: Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 154.

238

“O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores”.

239

José Frederico Marques, *Ensaio sobre a jurisdição voluntária*, p. 74.

240

“Accanto all’area delle funzioni giurisdizionali costituzionalmente necessarie, si pone l’area delle funzioni giurisdizionali non necessarie, ossia quelle che il legislatore ordinario è libero di attribuire o meno al giudice. Si tratta di un’area che concerne funzioni ulteriori rispetto a quella della tutela giurisdizionale dei diritti e degli status, che pertanto il legislatore ordinario potrebbe legittimamente rimettere, nella sua discrezionalità, anche in toto ai poteri privati o alla potestà amministrativa (salvi i controlli giurisdizionali a tutela dei diritti o interessi legittimi che eventualmente vengano colpiti)” (Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 667).

241

Piero Calamandrei, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, *Opere Giuridici*, vol. 4 p. 83.

242

“i provvedimenti in discorso servono ad assistere, a controllare, a integrare attività di privati in materia in cui è ravvisabile anche un interesse generale” (Elio Fazzalari, *Istituzioni di diritto processuale*, p. 525).

243

Em sentido contrário: Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 141.

244

Sobre o ponto: Gian Franco Ricci, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 21.

245

AgRg no AREsp 62.801/SP, rel. Min. Marco Buzzi, 4.^a Turma, j. 20.08.2013, *DJe* 30.08.2013.

246

Sergio Bermudes, *CPC de 2015: inovações*, vol. 1, p. 85.

247

“A indivisão decorre da co-propriedade: 1) entre herdeiros; 2) entre condôminos de um mesmo bem; 3) entre vizinhos, quando as respectivas propriedades ainda não foram convenientemente demarcadas. Para cada uma destas categorias acima indicadas, havia, no Direito Romano, desde épocas mais recuadas, ações próprias: 1) actio familiae erciscundae; 2) actio communi dividundo; 3) actio finium regundorum” (Sílvio Meira, *Instituições de direito romano*, p. 401).

248

“...certaines actions ont une nature mixte, en ce sens que, quoique leur *intentio* soit conçue *in personam*, elles conduisent ou peuvent conduire au même résultat qu’une actio *in rem*, c’est-à-dire à une déclaration de propriété au profit du demandeur”. (L.B. Bonjean, *Traité des actions*, vol. 2, p. 241).

249

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 222.

250

Em sentido contrário: Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 141.

251

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 156.

252

Confiram-se os comentários aos arts. 82 e 85.

253

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

254

Ovídio Baptista descreve a condenação nas despesas, corretamente, “*como decorrência pura e simples da derrota*” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 164).

256

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

257

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

258

Exceto em relação aos honorários sucumbenciais, porque titulares deles os advogados das partes, não elas próprias.

259

REsp 724.341/MG, rel. Ministra Denise Arruda, 1.ª Turma, j. 02.10.2007, *DJ* 12.11.2007, p. 158.

260

Marinoni; Arenhart; Mitidiero. *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 339.

261

Por Defensoria Pública se quer dizer tanto a Defensoria Pública em nome próprio, quanto a parte por ela representada.

262

Mas se o Ministério Público atuar na qualidade de *custos iuris*, conforme também se explicou nos comentários ao art. 82, o ônus de antecipar as despesas deve ser dividido em partes iguais entre as partes do processo.

263

Para mais detalhes: Diogo Albaneze Gomes Ribeiro, O pagamento dos atos processuais requeridos pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública – art. 91 do novo CPC, *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 10, p. 93.

264

Sobre o ponto: Diogo Albaneze Gomes Ribeiro, O pagamento dos atos processuais requeridos pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública – art. 91 do novo CPC, *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 10, p. 99.

265

“Não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no [art. 91 do Novo CPC](#), as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a [Lei 7.347/1985](#) dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil” ([RMS 55.476/SP](#), Rel. Ministro Herman Benjamin, 2.^a Turma, j. 21.11.2017, *DJe* 19.12.2017).

266

“O legislador torna a decisão de inadmissibilidade estável: reputa indiscutível a solução da questão processual que levou à extinção do primeiro processo. Essa estabilidade extrapola o âmbito do processo em que a decisão foi proferida. Reproposta a demanda, o juiz desse segundo processo fica vinculado à decisão sobre a questão processual: se o defeito não for corrigido, a nova demanda não será examinada. Há, aqui, coisa julgada quanto à questão da admissibilidade” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 710).

267

Renato Beneduzi, Prozessurteile e materielle Rechtskraft: sentenças terminativas e coisa julgada material no processo civil alemão, *Revista de Processo*, vol. 229, p. 371.

268

Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão* (2015), p. 92

269

“Prozessurteile, die die Klage wegen Fehlens einer Sachenentscheidungsvoraussetzung oder wegen eines entsprechenden Hindernisses als unzulässig abweisen, bewirken zwar materielle Rechtskraft, die sich aber auf den Unzulässigkeitsausspruch beschränkt. Das bedeutet, dass über denselben prozessualen

Mangel wegen der materiellen Rechtskraft nicht nochmals gestritten werden kann (Wiederholungsverbot), während das Urteil hinsichtlich anderer prozessualer Merkmale und vor allem hinsichtlich des materiellen Rechts nicht bindet” (Eberhard Schilken, *Zivilprozessrecht*, p. 454).

270

Renato Beneduzi, Prozessurteile e materielle Rechtskraft: sentenças terminativas e coisa julgada material no processo civil alemão, *Revista de Processo*, vol. 229, p. 364.

272

Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 175.

273

O art. 485, § 3.º, define perempção: “Se o autor der causa, por 3 (três) vezes, a sentença fundada em abandono da causa, não poderá propor nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito”.

274

Confirmam-se os comentários aos arts. 82 e 85.

275

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

276

Ovídio Baptista descreve a condenação nas despesas, corretamente, “*como decorrência pura e simples da derrota*” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 164).

278

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

279

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

280

Exceto em relação aos honorários sucumbenciais, porque titulares deles os advogados das partes, não elas próprias.

281

“Todas as vezes em que a omissão ou negligência de alguém acarretar aumento de despesas, porque necessário o adiamento ou a repetição de um ato, estas serão imputadas ao responsável. Poderá ele isentar-se do pagamento se demonstrar a ocorrência de justo motivo, o que, em última análise, confunde-se com a ausência de culpa. Caso fortuito e força maior constituem fundamentos a afastar a responsabilidade imposta pelo dispositivo em questão. Mas não são os únicos, pois justo motivo é expressão mais ampla, que compreende todos os óbices legítimos à realização correta e tempestiva do ato” (José Roberto dos Santos Bedaque, in: Antonio Carlos Marcato. *Código de Processo Civil interpretado*, p. 92).

282

Confirmam-se os comentários aos arts. 82 e 85.

283

No sentido que não é a relação jurídica material porventura existente entre as partes que torna o perdedor responsável pelo pagamento, mas a lei processual.

284

Ovídio Baptista descreve a condenação nas despesas, corretamente, “*como decorrência pura e simples da derrota*” (Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 164).

286

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 655.

287

Para que deva ser reembolsada, a despesa extrajudicial deve decorrer razoável e diretamente do processo.

288

Exceto em relação aos honorários sucumbenciais, porque titulares deles os advogados das partes, não elas próprias.

289

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 167.

291

E *de lege ferenda*, porque a solidariedade decorre apenas da lei ou da vontade das partes. Neste sentido: “Se Tício move ação contra Caio e vence, deve ter direito a receber desse o total das despesas. Se essas tiverem de ser repartidas entre Caio, o réu, e seus eventuais assistentes, Tício passa pelo risco de algum

deles ser insolvente, e então não receberá por inteiro o que despendeu. O certo, nesse caso, seria considerar assistidos e assistentes devedores solidários.” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 182).

292

Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 159.

293

Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 121.

294

Sobre a distribuição do ônus de adiantamento entre assistido e assistente, confirmam-se os comentários ao art. 94.

295

Mas se o Ministério Público a requerer na qualidade de parte – e, portanto, de parte *interessada* – o ônus de adiantamento é dele, nas condições explicadas nos comentários ao art. 91.

296

“Percebe-se, portanto, que, na hipótese em que a realização da perícia é determinada de ofício pelo juiz ou requerida por ambas as partes, a nova legislação determina o rateio das respectivas despesas entre as partes, diferentemente do antigo CPC, no qual respondia somente a parte autora por tal incumbência” (REsp 1.548.758/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.^a Turma, j. 10.05.2016, DJe 17.05.2016).

297

Max Vollkommer, Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess, in: FS Schwab, p. 503.

298

Alexandre Câmara dá outro enfoque ao problema: “É que pode acontecer de o juízo determinar de ofício a produção de uma prova pericial em caso em que o ônus da prova incumba a uma das partes, somente. Pois neste caso nada haverá – muito ao contrário – que estimule a parte contrária a participar do rateio dos honorários do perito. Afinal, a ausência de prova a beneficiará. Muito mais correto teria sido, data venia, impor o ônus de adiantar os honorários periciais àquele que tenha o ônus da prova daquilo que com a perícia se pretende demonstrar” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 74).

299

Com a ressalva de que, “para fins de aplicação do § 3.º, é vedada a utilização de recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública” (§ 5.º).

300

“Its underlying objective is to empower the court to prevent or punish conduct which may tend to obstruct, prejudice or abuse the administration of justice” (Jack Jacob, *The fabric of English civil justice*, p. 206).

301

A dimensão subjetiva da litigância de má-fé é repetidamente sublinhada pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido: “A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção...” (AgRg no REsp 1374761/MS, rel. Min. Raul Araújo, 4.^a Turma, j. 20.02.2014, *DJe* 26.03.2014).

302

“O instituto da litigância de má fé é tipicamente nacional (...). A litigância de má fé surge, por quanto foi apontado, como um instituto processual, de tipo público e que visa o imediato policiamento do processo. Não se trata de uma manifestação de responsabilidade civil, que pretenda suprimir danos, ilícita e culposamente causados a outrem, através de auctuações processuais. Antes corresponde a um subsistema sancionatório próprio, de âmbito limitado e com objectivos muito práticos e restritos (...). Quanto à culpa e na sequência da evolução acima retratada, são hoje penalizadas, como litigância, de má fé e determinadas condutas especialmente tipificadas, desde que cometidas: – com dolo; com negligência grave” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má fé, abuso do direito de acção e culpa ‘in agendo’*, p. 14, 26 e 28).

303

Monograficamente: Walter Zeiss, *Die arglistige Prozesspartei*, p. 203. Também Horst Konzen, *Rechtsverhältnisse zwischen Prozessparteien*, p. 79, Max Vollkomer, *Zivilprozessordnung* (Zöller), p. 9 e Walter Zimmermann, *Zivilprozessordnung*, p. 25.

304

“In the English system of administration of justice, civil and criminal, the doctrine of contempt of court plays a central, fundamental part. It is as ancient as the common law. It is deeply embedded in the English legal system and operates to this day wherever the common law has taken root (...). The doctrine applies to the whole machinery of justice, and is not limited to the civil enforcement process. Its underlying objective is to empower the court to prevent or punish conduct which may tend to obstruct, prejudice or abuse the administration of justice either generally or in relation to a particular case (...). A civil contempt is therefore essentially concerned with the enforcement of judgments and orders of the court, but it is also concerned to uphold the authority of the law and to maintain the rule of law” (Jack Jacob, *The fabric of English civil justice*, p. 206). Mais recentemente, Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 507. Sobre o seu desenvolvimento histórico: John Fox, *The history of contempt of court*, p. 1. Nos Estados Unidos: Hazard; Leubsdorf; Bassett. *Civil Procedure*, p. 399.

305

Para mais detalhe de sua história no Brasil: Luiz Rodrigues Wambier, *O contempt of court na recente*

experiência brasileira – anotações a respeito da necessidade premente de se garantir efetividade às decisões judiciais, *Revista dos Tribunais*, vol. 119, p. 35.

306

“Its underlying objective is to empower the court to prevent or punish conduct which may tend to obstruct, prejudice or abuse the administration of justice” (Jack Jacob, *The fabric of English civil justice*, p. 206).

307

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 133.

308

As pessoas jurídicas podem ser também beneficiárias da gratuidade de justiça, embora não exatamente nas mesmas condições que as pessoas físicas, como se explicará mais adiante.

309

“Não há dúvidas de que para certos indivíduos desfavorecidos economicamente, o direito à tutela dos direitos pode tornar-se uma promessa vazia e sem significado se o ordenamento não predispuer instrumentos que possibilitem a defesa de seus direitos em juízo. A problemática envolvendo os custos do processo assume relevo na medida em que esses podem constituir um óbice à efetivação de direitos, especialmente se constituírem um fator de desequilíbrio no acesso ao processo” (Rafael Sirangelo de Abreu, O problema dos custos do processo e sua regulamentação pelo novo CPC, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 788).

310

Superada, portanto, a ideia de que “a assistência judiciária integra o ideário do *Armenrecht*, que sem sentido global é um sistema destinado a minimizar as dificuldades dos pobres perante o direito e para o exercício de seus direitos” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 695).

311

Rosenberg;Schwab;Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 464.

312

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 698.

313

José Augusto Garcia de Sousa, in: Cabral; Cramer, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 161.

314

“A grande novidade trazida pela Carta de 1988 consiste em que, para ambas as ordens de providências, o campo de atuação já não se delimita em função do atributo ‘judiciário’, mas passa a compreender tudo que seja ‘jurídico’. A mudança do adjetivo qualificador da ‘assistência’, reforçada pelo acréscimo do ‘integral’, importa notável ampliação do universo que se quer cobrir. Os necessitados fazem jus agora à dispensa de pagamentos e à prestação de serviços não apenas na esfera judicial, mas em todo o campo dos atos jurídicos” (José Carlos Barbosa Moreira, *O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo*, in: *Temas de direito processual* (quinta série), p. 58).

315

“Embora a lei se refira à ‘pessoa’, parece intuitivo que também os entes despersonalizados, que possuem apenas personalidade no plano processual, podem gozar da gratuidade de justiça. A negativa, neste caso, se admitida, atingiria, em última análise, o direito fundamental à justiça gratuita das próprias pessoas vinculadas a esses entes” (Ticiano Alves e Silva, *O benefício da justiça gratuita no novo Código de Processo Civil*, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 808).

316

Com a ressalva de que, na hipótese do § 1.º, inciso IX, havendo dúvida fundada quanto ao preenchimento atual dos pressupostos para a concessão de gratuidade, o notário ou registrador, após praticar o ato, pode requerer ao juízo competente para decidir questões notariais ou registrares, a revogação total ou parcial do benefício, ou, a sua substituição pelo parcelamento de que trata o § 6.º deste artigo, caso em que o beneficiário será citado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre esse requerimento” (§ 8.º).

317

AI 573444 AgRg, j. 08.09.2009, 2.ª Turma, rel. Min. Cezar Peluso.

318

Sobre a sua obrigação ao final do processo, confira-se próximo item.

319

Sobre o problema do uso abusivo da gratuidade de justiça: Tartuce/Dellore, *Gratuidade de justiça no novo CPC*, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 770.

320

“A gratuidade de justiça não impede a condenação em honorários advocatícios, apenas suspende a sua exigibilidade (Lei 1.060/1950, art. 12) [dispositivo corresponde ao atual art. 99, § 3.º, do CPC]” (AgRg no Ag 911.836/RJ, j. em 12.11.2013, 3.ª Turma, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 25.11.2013). Neste mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 424.428/RS, j. em 19.08.2014, 3.ª Turma, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, *DJe* 25.08.2014.

321

“Embora a lei se refira à ‘pessoa’, parece intuitivo que também os entes despersonalizados, que possuem apenas personalidade no plano processual, podem gozar da gratuidade de justiça. A negativa, neste caso, se admitida, atingiria, em última análise, o direito fundamental à justiça gratuita das próprias pessoas vinculadas a esses entes” (Ticiano Alves e Silva, O benefício da justiça gratuita no novo Código de Processo Civil, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 808).

322

Sem autuação em separado, como ocorria na vigência do art. 6.º da Lei 1.060/1950.

323

“A eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos *ex nunc*, não podendo, pois, retroagir à data de interposição do recurso de apelação, sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido o benefício, que, no caso, não foi requerido simultaneamente à interposição do recurso” (EDcl no REsp 1211041/SC, j. em 24.06.2014, 4.ª Turma, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, *DJe* 01.08.2014).

324

José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 254.

325

Rafael Alexandria de Oliveira, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 492.

326

Neste sentido: “Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que ‘as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência’ (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, *DJe* 04.04.2017)” (AgInt no AREsp 793.487/PR, Rel. Ministro Gurgel De Faria, 1.ª Turma, j. 22.08.2017, *DJe* 04.10.2017).

327

“É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente” (AgRg no AREsp 642.623/PR, j. em 20.10.2015, 3.ª Turma, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, *DJe* 27.10.2015).

328

“As pessoas jurídicas de direito privado são entes coletivos constituídos voluntariamente por pessoas físicas, com o objetivo de obter determinados resultados na ordem econômica, cultural, esportiva, religiosa, etc. e, como tais, são projeções dos próprios sujeitos que as compõem. Os sucessos ou fracassos ocorrentes na vida desses entes coletivos repercutem econômica, social ou moralmente na vida dos sócios ou associados. Por isso, fechar as portas da Justiça a elas significaria, em *ultima ratio*, fechá-las a seus próprios integrantes. A situação é ainda mais crítica quando se trata de entidades associativas de pequeno porte, especialmente as microempresas, cuja vida e situação patrimonial praticamente coincidem com a do titular” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 699).

329

Em sentido contrário, por exemplo: Tartuce; Dellore, Gratuidade de justiça no novo CPC, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 778.

330

“Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária” (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, j. em 03.02.2016, Corte Especial, rel. Ministro Raul Araújo, *DJe* 17.03.2016).

331

Lembre-se que, omissa a decisão do juiz sobre o pedido, como se explicou nos comentários ao art. 99, presume-se o deferimento conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

332

“A iniciativa é coerente com diversos outros dispositivos do CPC de 2015, que extinguem maiores formalidades, apensos, apartados e coisas que tais para as manifestações ao longo do processo” (Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 133).

333

Em sentido contrário: Ticiano Alves e Silva, O benefício da justiça gratuita no novo Código de Processo Civil, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 819.

334

Para mais detalhes sobre os recursos na gratuidade de justiça, confirmam-se os comentários ao art. 101.

335

Neste sentido: “Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. Nos termos do [art. 98, § 4.º, do CPC/2015](#), a concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em decorrência da litigância de má-fé” (REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra Nancy Andriighi, 3.ª Turma, j. 20.02.2018, *DJe* 23.02.2018).

336

Sobre estes requisitos, confirmam-se os comentários aos arts. 77 a 81.

337

A referência legislativa é ainda à antiga lei, mas o sentido é o mesmo.

338

REsp 1125169/SP, j. em 17.05.2011, 3.ª Turma, rel. Ministra Nancy Andriighi, *DJe* 23.05.2011.

339

Sobre estas duas espécies e suas relações, confirmam-se os comentários aos arts. 77 a 81.

340

“No novo Código, porém, o recurso de apelação serve não apenas para impugnar as questões decididas na sentença, mas também se presta para impugnar todas as questões decididas ao longo do procedimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1.º). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado, o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da *final decision* do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano clássico é notórias” (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 527).

341

“Tendo sido deferido o benefício apenas parcialmente (como se dá, por exemplo, no caso de se ter requerido a isenção total do ônus de adiantar as despesas e ter sido deferido tão somente uma redução percentual), também se deve admitir o agravo de instrumento contra o pronunciamento judicial em relação à parte não deferida” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 77).

Sobre o ponto: Maria Carolina Silveira Beraldo, Litigância de má-fé no novo Código de Processo Civil, *Coleção novo CPC (doutrina selecionada)*, vol. 1, p. 721. Contra: Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 66.

65

Sobre o ponto: Maria Carolina Silveira Beraldo, Litigância de má-fé no novo Código de Processo Civil, in: *Coleção novo CPC (doutrina selecionada)*, vol. 1, p. 721. Contra: Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 66.

133

Sobre o ponto: Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526. Também Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 312.

142

Por exemplo: “Em nome do princípio da causalidade, a condenação nos ônus da sucumbência deve ser imposta a quem deu causa à instauração do incidente processual. No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que a parte exequente teria dado causa ao ajuizamento da ação de embargos de terceiro, razão pela qual se mostra consentânea a condenação desta ao pagamento do ônus de sucumbência” (AgRg no REsp 1218868/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4.^a Turma, j. 10.11.2015, *DJe* 07.12.2015).

147

Também Paulo Henrique dos Santos Lucon, A advocacia no CPC, in: Fredie Didier Junior. *Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar*, p. 253 e Monteiro Barbosa, Albuquerque Magnani, *Coleção Grandes Temas do novo CPC (honorários advocatícios)*, vol. 2, p. 275.

157

“...como é o caso, por exemplo, de tratados neste sentido entre Brasil e Itália – Dec. 1.476/1995 – e Brasil e França – Dec. 3.598/2000)” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 69).

190

Para mais detalhes: Luiz Guilherme da Costa Wagner Junior, Da apelação para majoração dos honorários advocatícios, in: Luiz Henrique Volpe Camargo, Marcus Vinícius Furtado. *Coleção Grandes Temas do novo CPC (honorários advocatícios)*, vol. 2, p. 710.

197

Ao contrário do que se fazia na vigência do CPC/1973. Por exemplo: EDcl nos EDcl no REsp 981.544/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, 3.^a Turma, j. 16.12.2014, *DJe* 04.02.2015.

201

Para mais detalhes: Luiz Antonio Ferrari Neto, Honorários advocatícios nas ações de indenização por ato ilícito, *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 213.

215

“A mudança de eixo subentende reciprocidade das consequências produzidas pelo risco da demanda judicial, com a prevalência do princípio da isonomia não apenas para diminuir bastante o poder discricionário do magistrado de fixá-los por critério de equidade, mas para garantir à parte adversa o mesmo tratamento conferido à Fazenda Pública, no que diz respeito aos critérios de fixação da verba honorária de sucumbência. Com o § 3.º será aplicado às causas em que a Fazenda Pública é parte, e não necessariamente sucumbente, o escalonamento valerá tanto para o particular, quando vencedor, como para a Fazenda, quando bem-sucedida no processo” (Marcello Terto e Silva, Honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte, *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios), vol. 2, p. 422).

219

Sobre o ponto: Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526. Também Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 312.

233

Sobre o ponto: Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526. Também Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 312.

255

Sobre o ponto: Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526. Também Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 312.

271

“O legislador tornou rescindíveis estas sentenças. Esta sentença, segundo diz expressamente o NCPC, impede a repropositura da ação, salvo se o vício for corrigido. Mas e se não há este vício? Como rediscutir? Por meio da ação rescisória, desde que ocorra uma das hipóteses do art. 966, I a VIII” (Teresa Arruda Alvim Wambier, Da ação rescisória, in: Wambier, Alvim Wambier *Temas essenciais do novo CPC*, p. 618).

277

Sobre o ponto: Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526. Também Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 312.

285

Sobre o ponto: Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 526. Também Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 312.

Na assistência litisconsorcial, com efeito, em que parte o assistente, os custos são distribuídos conforme a regra aplicável aos litisconsortes vencidos. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 87.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I - DAS PARTES E DOS PROCURADORES

CAPÍTULO III - DOS PROCURADORES

Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.

Direito anterior – art. 36 do CPC/1973.

Direito comparado – § 78 da ZPO alemã, art. 82 do CPC italiano, art. 31 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 32 do CPC português.

1. Capacidade postulatória

Para praticar atos processuais válida e eficazmente, como se viu nos comentários ao art. 70, é preciso que as partes em litígio *existam*, e que possam ser *concretamente identificadas*, e que tenham *capacidade de ser parte* e também *capacidade processual*. A estes requisitos soma-se um último, a capacidade *postulatória*, que é a capacidade *técnica* para a prática do ato¹. Ela decorre da representação processual da parte por advogado (bacharel em direito regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil) ou por defensor público² e, ainda, quando parte o Estado³ ou o Ministério Público⁴, de sua apresentação judicial por um de seus órgãos⁵. Ao advogado se permite postular em causa própria, dispensando-se a representação por terceiro (parágrafo único)⁶.

A exigência de representação judicial é a regra (*Anwaltsprozess*), sua dispensa a exceção (*Parteiprozess*)⁷. Esta presunção de obrigatoriedade de representação (*Anwaltszwang*⁸), salvo nos casos expressamente previstos em lei (no processo civil, por exemplo, nas causas perante juizados especiais cujo valor não ultrapasse vinte salários mínimos, conforme art. 9.º da Lei 9.099/1995), é compatível com o mandamento constitucional segundo o qual “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei” (art. 133, CF). A lógica deste dispositivo não é a de proteção de mercado, mas de assegurar às partes a defesa *técnica* que apenas a formação jurídica proporciona adequadamente⁹. É pelo mesmíssimo motivo que apenas um médico pode receitar um remédio ou realizar uma cirurgia.

A capacidade processual da parte é necessária apenas quando se tratar de atos *postulatórios* (atos mediante os quais *se pede* alguma ou *se resiste* a um pedido). Nos demais casos, o ato pode ser válida, e eficazmente, praticado pela própria parte independentemente de representação por procurador¹⁰. Quando a parte depõe em juízo, por exemplo, é ela que responde diretamente ao que lhe perguntam, não o seu advogado. Aos estagiários (estudantes de direito regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil), permite-se, em geral, a prática de atos *em conjunto* (mas apenas *em conjunto*) com o advogado responsável, conforme art. 2.º, § 2.º do Estatuto da OAB, como o de subscrever um recurso, ou mesmo de formular perguntas em audiência. Para a prática de *alguns* atos processuais de menor complexidade, admite-se, também, que o estagiário os pratique *isoladamente*, embora sempre sob a supervisão, e responsabilidade, de um advogado (art. 2.º, § 2º, do Estatuto da OAB). São aqueles aludidos no art. 29 do Regulamento Geral do estatuto da OAB¹¹. Não se encontra entre eles, no entanto, o de ser intimado de decisões¹².

2. Consequências da falta de capacidade postulatória

A falta de capacidade postulatória *do autor* é uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda, mas apenas a dele. Se ela faltar, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV. Se a do réu, a falta ocasionará a sua *revelia*, nunca a extinção do processo. Se de terceiro, ele será considerado revel ou deverá ser excluído do processo, a depender do polo da relação jurídica processual em que se encontre. Se do recorrente, o recurso será inadmissível. Se do recorrido, suas contrarrazões deverão ser desentranhadas dos autos. Mas, antes de sancionar a falta de capacidade postulatória, o juiz deve *sempre* dar ao interessado a possibilidade de explicar-se e de corrigir o vício, mesmo no caso de se tratar de recurso excepcional, porque o defeito de representação será *sempre* um vício sanável. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 76.

Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1.º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exhibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2.º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.

Direito anterior – art. 37 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 83 do CPC italiano e art. 41 do CPC português.

1. Mandato e procuração

Mandato é uma modalidade de contrato, regido pelo direito civil, mediante o qual alguém, o mandatário, recebe de outrem, o mandante, poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses (art. 653 do Código Civil). Espécie particular de mandato é o *mandato judicial* (art. 692 do Código Civil), mediante o qual uma pessoa, física ou jurídica, contrata um advogado (bacharel em direito, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil) ou uma sociedade de advogados para representá-la em juízo¹³⁻¹⁴ de acordo com determinadas condições estabelecidas no contrato¹⁵.

O mandato, em outras palavras, instituto de direito privado, estipula os direitos e obrigações das partes contratantes, mas não se confunde com a *procuração*¹⁶, instituto de direito público, instrumento mediante o qual o advogado (nunca a sociedade de advogados) recebe poderes de seu constituinte para representá-lo em determinado processo (representação judicial). É neste sentido que é concebível se falar em *mandato sem poderes*, quando existe contrato entre as partes, embora o constituinte não tenha dado procuração a seu advogado, e em *poderes sem mandato*, quando o constituinte deu procuração a um advogado, embora não exista contrato entre eles a regular se e em que condições se prestarão os serviços de advocacia. Neste último caso, como se explicará nos comentários ao art. 112, o advogado poderá *recusar* a representação judicial. A regular representação judicial, que decorre da outorga de poderes pelo constituinte a seu advogado mediante procuração para representá-lo em um determinado processo, enfim, é que atesta a capacidade postulatória da parte.

2. Representação judicial sem procuração

Sem regular procuração, faltarà à parte capacidade postulatória, o que faz incidir as mesmas consequências explicadas nos comentários ao art. 76. Se faltar a procuração do autor, o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, IV. Se a do réu, a falta ocasionará a sua *revelia*, nunca a extinção do processo. Se de terceiro, ele será considerado revel ou deverá ser excluído do processo, a depender do polo da relação jurídica processual em que se encontre. Se do recorrente, o recurso será inadmissível. Se do recorrido, suas contrarrazões deverão ser desentranhadas dos autos. Mas, antes de sancionar a falta de

capacidade postulatória, o juiz deve *sempre* dar ao interessado a possibilidade de explicar-se e de corrigir o vício, mesmo no caso de se tratar de recurso excepcional, porque o defeito de representação será *sempre* um vício sanável.¹⁷

Permite a legislação processual, no entanto, excepcionalmente, a representação judicial sem procuração, “para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente” (*caput*). Este dispositivo deve ser interpretado com liberalidade, porque a lógica que lhe é subjacente é a de evitar a consumação de prejuízo jurídico à parte. Bastam a pressa ou a preocupação em se evitar delongas desnecessárias, não, obrigatoriamente, a urgência¹⁸. Suponha-se, por exemplo, que o constituinte esteja fora do Brasil, hipótese em que o recebimento pelos correios do instrumento original da procuração pode durar dias, mesmo semanas. Pode não haver, a rigor, urgência, mas não é razoável exigir que se espere a chegada do documento para que possa ser possível a prática do ato processual.

Praticado o ato processual sem poderes, o advogado *deve* protestar pela posterior juntada da procuração. Neste caso, “o advogado deverá, independentemente de caução¹⁹, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz” (parágrafo único). Se o advogado não cumprir esta determinação, responderá “pelas despesas e por perdas e danos” que causar às partes (parágrafo segundo). Afora as consequências processuais previstas no art. 76. Em tempos de *internet*, e de processo eletrônico, de todo modo, convém ao advogado pedir a seu cliente que lhe encaminhe, eletronicamente, a procuração, que pode ser imediatamente levada aos autos do processo (art. 105, § 1.º). Evitam-se, assim, possíveis dúvidas futuras sobre a outorga de poderes e de seus limites. Os atos processuais praticados por advogado sem procuração serão, desde logo, eficazes, embora esta eficácia se subordine à condição da ratificação tempestiva. Sem ela, ficam *retroativamente* sem efeito todos os atos praticados²⁰, sem prejuízo da responsabilidade do advogado pelo pagamento de despesas e pelos prejuízos que causar²¹.

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1.º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2.º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3.º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4.º Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.

Direito anterior – art. 38 do CPC/1973.

Direito comparado – § 81 da ZPO alemã, art. 84 do CPC italiano e arts. 36 e 37 do CPC português.

1. Procuração

A procuração, como se viu nos comentários ao artigo anterior, é o instrumento mediante o qual o advogado (nunca a sociedade de advogados) recebe poderes de seu constituinte para representá-lo em determinado processo (representação judicial). Trata-se de um de instituto de direito público, que não se confunde com o contrato de direito privado porventura existente entre advogado ou sociedade de advogados e seu cliente (mandato judicial), motivo pelo qual da invalidade ou ineficácia de um não decorre, automaticamente, a de outro.²² A procuração pode ser

outorgada mediante instrumento público, privado (*caput*) ou mesmo digitalmente (*parágrafo primeiro*). Dispensa-se, em qualquer caso, autenticação ou reconhecimento de firma. Mas nada impede a outorga também *oral* de procuração em audiência. Se estagiário um dos outorgados, não é necessária qualquer providência suplementar para que ele possa, ao ser admitido depois de formado nos quadros da OAB, representar seu constituinte na qualidade de advogado.²³

A procuração deve indicar o nome do advogado a que se conferem os poderes, seu número de registro na OAB e seu endereço profissional completo (*parágrafo terceiro*). Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a sua qualificação será também necessária (*parágrafo terceiro*). O que não se permite no Brasil, ao contrário do que se passa em países como a Alemanha, é a outorga da procuração diretamente à sociedade de advogados.²⁴ Esta circunstância não impede, entretanto, que os advogados requeiram ao juiz “que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil” (art. 272, § 1.º).

A procuração deve também indicar exatamente quais são os poderes outorgados. A cláusula *ad judicia* confere ao advogado *poderes gerais para o foro*: todos, exceto aqueles especiais aludidos no *caput*: “receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica”²⁵. Estes poderes especiais não são outorgados ao advogado salvo se o forem *expressamente*, razão pela qual “a interpretação destas cláusulas especiais deve ser restritiva (art. 114 do Código Civil)”²⁶. Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, ademais, “a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença” (*parágrafo quarto*). Permite-se o substabelecimento dos poderes recebidos, salvo se existir vedação expressa na procuração.²⁷ A procuração e o substabelecimento permanecerão *processualmente* válidos, mesmo se vencida a procuração.²⁸ As consequências jurídicas do vencimento do termo interessam apenas à relação contratual existente entre cliente e seu advogado, não à representação judicial. Sobre a revogação dos poderes pelo constituinte, por fim, confirmam-se os comentários ao art. 111. Sobre a renúncia do advogado a ele, os comentários ao art. 112.

Art. 106. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado:

I – declarar, na petição inicial ou na contestação, o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações;

II – comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço.

§ 1.º Se o advogado descumprir o disposto no inciso I, o juiz ordenará que se supra a omissão, no prazo de 5 (cinco) dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento da petição.

§ 2.º Se o advogado infringir o previsto no inciso II, serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos.

Direito anterior – art. 36 do CPC/1973.

Direito comparado – § 78 da ZPO alemã.

1. Advocacia em causa própria

Ao advogado, como se viu nos comentários ao art. 103, permite-se postular em causa própria dispensando-se a sua representação por terceiro.²⁹ Neste caso, deve ele, na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, indicar “o endereço, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e o nome da sociedade de advogados da qual participa, para o recebimento de intimações” (inciso I). A primeira oportunidade será a petição inicial, se autor o advogado, ou a contestação, se réu, mas nem sempre (na assistência, por exemplo). O descumprimento desta regra

torna *defeituosa* a representação, razão pela qual incidem as consequências previstas no art. 76.

O defeito na representação, se autor o advogado, faz com que o processo deva ser extinto, sem julgamento do mérito, conforme o art. 76. Se réu o advogado, a falta ocasionará a sua revelia, não a extinção do processo. Se terceiro, o advogado, em causa própria, será considerado revel ou deverá ser excluído do processo, a depender da natureza de sua intervenção. Antes de sancionar o defeito, no entanto, o juiz deve dar ao advogado a chance de corrigi-lo no prazo de cinco dias (parágrafo primeiro). Quando postular em causa própria, deve também o advogado informar ao juiz qualquer mudança de endereço (parágrafo segundo). Se não o fizer, “serão consideradas válidas as intimações enviadas por carta registrada ou meio eletrônico ao endereço constante dos autos” (parágrafo segundo). O dispositivo é de pouca aplicação prática, considerando-se a crescente informatização do processo (a intimação eletrônica é hoje o modo *preferencial* de intimação, conforme o art. 270).

Art. 107. O advogado tem direito a:

I – examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos;

II – requerer, como procurador, vista dos autos de qualquer processo, pelo prazo de 5 (cinco) dias;

III – retirar os autos do cartório ou da secretaria, pelo prazo legal, sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz, nos casos previstos em lei.

§ 1.º Ao receber os autos, o advogado assinará carga em livro ou documento próprio.

§ 2.º Sendo o prazo comum às partes, os procuradores poderão retirar os autos somente em conjunto ou mediante prévio ajuste, por petição nos autos.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º, é lícito ao procurador retirar os autos para obtenção de cópias, pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo.

§ 4.º O procurador perderá no mesmo processo o direito a que se refere o § 3.º se não devolver os autos tempestivamente, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz.

Direito anterior – art. 40 do CPC/1973.

Direito comparado – arts. 167 e 168 do CPC português.

1. Prerrogativas dos advogados e autos do processo

São variados os direitos e prerrogativas dos advogados. A eles dedica o art. 7º do Estatuto da OAB minucioso tratamento. Em seu art. 107, o Código de Processo Civil trata, mais especificamente, dos direitos que dizem respeito à consulta (independentemente se físicos ou eletrônicos) e carga (apenas se físicos) dos autos de processo judicial.³⁰

2. Vista dos autos

O primeiro destes direitos que dizem respeito aos autos do processo é o de examiná-los livremente, salvo em caso de segredo de justiça³¹ (inciso I). A vista dos autos independe, com efeito, da exibição de procuração, de cadastro, de preenchimento de fichas, de requerimento escrito, de motivação, de assinatura em livro, de autorização de serventuário ou de juiz. Físicos ou virtuais, todo advogado tem o direito de examinar os autos do processo e de tirar-lhes cópia, independentemente de em que fase se encontre, quando bem entender. Se físicos os autos,

obviamente, apenas durante o expediente forense, mas mesmo quando os autos estiverem “na digitação”, “no processamento”, “na conclusão”, “aguardando conclusão” ou em qualquer outro escaninho da serventia judicial. Da mera vista dos autos, por fim, não decorrem a ciência e a intimação das decisões e demais atos praticados no processo.

3. Carga dos autos

Físicos os autos, o advogado que tem poderes para representar uma das partes ou terceiro interveniente³² pode, também, retirá-los do cartório (fazer carga), quando não houver prazo em curso para alguma das partes, por cinco dias (inciso II). Poderá fazê-lo pelo prazo que tiver para realizar determinado ato processual, “sempre que neles lhe couber falar por determinação do juiz” (inciso III). Sendo comum o prazo, não se permite a carga senão se convencionado pelas partes (parágrafo segundo). A proibição de carga não equivale, no entanto, à proibição de retirada temporária dos autos do cartório para a obtenção de cópias. Esta retirada será admitida, sendo comum o prazo para as partes, “pelo prazo de 2 (duas) a 6 (seis) horas, independentemente de ajuste e sem prejuízo da continuidade do prazo” (parágrafo terceiro). Descumprido este prazo, o advogado perderá o direito de, neste mesmo processo (e apenas nele, não em todos em curso naquela serventia), retirar os autos para cópia com fundamento no parágrafo terceiro, salvo se o prazo for prorrogado pelo juiz. Ao contrário do que ocorre no simples exame de autos em cartório, na carga são necessários o registro e a assinatura do advogado (parágrafo primeiro). A exigência é razoável, porque contribui para evitar o extravio dos autos. Ao contrário do que ocorre na mera vista dos autos, a sua carga implica ciência inequívoca, no dia em que retirados os autos do cartório, dos atos processuais praticados até este momento (inclusive de decisões ainda não publicadas). Mas apenas quando a carga for realizada por advogado, não por estagiário, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça³³.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Sobre o conceito de mandato e de procuração, confirmam-se os comentários ao art. 104.

2

Segundo o § 6.º da Lei Complementar 132/2009, “a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público”, independentemente de registro na Ordem dos Advogados do Brasil. Mas a constitucionalidade desta norma é objeto de impugnação na ADI 4636, relator o Min. Gilmar Mendes, ainda não julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

3

Sobre a capacidade de ser parte do Poder Público, confirmam-se os comentários ao art. 75.

4

Sobre a apresentação judicial do Ministério Público, confirmam-se os comentários ao art. 176 e ss.

5

Ocorre *presença* quando alguém é autorizado a “estar presente para dar presença à entidade de que é órgão” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 288). Neste sentido, “a Procuradoria Judicial e seus procuradores constituem um órgão da Fazenda Pública. Então, o advogado público quando atua perante os órgãos do Poder Judiciário é a Fazenda pública presente em juízo” (Leonardo Carneiro da Cunha, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 27).

6

“Quando parte também é advogado, legalmente habilitado, em vez de haver representante e representado, há uma só pessoa, que é parte e exerce a atividade postulacional. Uma vez que ela está inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, legalmente habilitada está. Ela é que escolhe em ser parte e advogado, ou ser parte e constitui advogado, a despeito de estar em situação suficiente para postular. Se ela é estagiária ou provisionada [a figura do provisionado não existe mais no direito brasileiro], somente pode praticar o que estagiário ou provisionado pode fazer, inclusive no tocante às limitações territoriais” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 428).

7

Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 60.

8

Rosenberg/Schwab/Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 225.

9

“Sendo as regras de direito de natureza técnica, notadamente as de direito processual, a atuação das partes em juízo, pessoalmente, acarretará, em geral, defesa insuficiente do seu direito, dificultando também a atividade do juiz. Esse é o motivo pelo qual, modernamente, as partes que não tiverem preparo jurídico suficiente deverão ter pessoa especializada em assuntos dessa natureza, para defender o seu direito” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 172).

10

A representação por advogado não se confunde com a representação daquele a quem falta capacidade processual de que se falou nos comentários ao art. 71.

11

§ 1.º O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade do advogado: I – retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga; II – obter junto aos escrivães e chefes de secretarias certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos; III – assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Mas isso com a ressalva de que “a jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a carga dos autos feita por estagiário não implica a intimação do advogado acerca da decisão proferida” (AgRg no REsp 1452467/DF, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 18.06.2015, *DJe* 06.08.2015).

12

“A retirada dos autos processuais de cartório por estagiário não configura intimação de decisão neles contida, por não deter o acadêmico os poderes necessários para a prática desse ato processual desacompanhado de advogado. Precedentes” (STJ, AgRg no AREsp 282.000/DF, 4ª Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16.02.2016. *DJe* 19.02.2016).

13

“Mandato judicial é o conferido a advogado, lato sensu, para a defesa de interesses em juízo. É ao mesmo tempo mandato e locação de serviços (locatio operis)” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 188).

15

“É da relação jurídico-substancial de mandato que decorrem as obrigações do advogado perante o cliente, nos limites que o contrato estabelecer (consultoria extrajudicial, assessoria judicial ou extra, patrocínio em todas as causas do cliente, propositura de determinada demanda ou defesa em dado processo, realização de atos somente em primeira instância ou até ao fim, incluído ou excluído patrocínio ou defesa em futura execução, em possível ação rescisória, etc.)” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 713).

16

Sobre os requisitos e características da procuração, confirmam-se os comentários ao art. 105.

17

Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 76.

18

Em sentido contrário: Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 169.

19

“Não há necessidade de caução, isto é, de qualquer garantia para a intervenção autorizada nos termos do dispositivo” (Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 138).

20

Trata-se de um problema de eficácia, não de existência ou validade do ato processual. Ele, simplesmente, não será eficaz em relação à parte em cujo nome ele foi praticado. Neste sentido: Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 435, e Sergio Bermudes, *CPC de 2015: inovações*, vol. 1, p. 94.

21

A eficácia dos atos praticados não se subordina, desta maneira, a uma *condição suspensiva* (ratificação). E isso porque eles serão desde logo eficazes. Ocorre apenas que, sem a ratificação, ficam *retroativamente* sem efeito estes atos. Em sentido contrário: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 335.

22

“Die Vollmacht zur Prozessvertretung ist in der Regel von ihm Grundverhältnis, das die Pflicht zur Vertretung begründet, unabhängig und erlischt nicht zugleich mit ihm. Die Wirksamkeit der erteilten Vollmacht ist daher unabhängig vom Zustandekommen und von der Wirksamkeit des Anwaltsvertrages“ (Rosenberg/Schwab/Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 328).

23

“Esta Corte tem reafirmado que o estagiário constituído como procurador judicial que venha a obter o diploma de bacharel em Direito e o registro na OAB, no curso do processo, pode praticar todos os atos judiciais posteriores independentemente da outorga de novo mandato” (EDcl no REsp 1035493/DF, 2ª Turma, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 17.06.2008, *DJe* 26.06.2008.).

24

Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 60.

25

Por isso, não são necessários poderes especiais para a celebração de negócios jurídicos processuais. Contra: Ronaldo Cramer, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral/Cramer), p. 177.

26

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 338.

27

Mas com a ressalva de que “esta Corte Superior consagrou o entendimento de que a vedação ao substabelecimento não invalida a transmissão de poderes, mas apenas torna o substabelecimento responsável pelos atos praticados pelo substabelecido” (AgRg no REsp 1052866/MS, 3ª Turma, rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), julgado em 23.11.2010, *DJe* 03.12.2010).

28

“Quanto à nulidade do substabelecimento, este Superior Tribunal a considera descabida ao argumento de estar vencido o instrumento procuratório do advogado substabelecimento, mormente porque já decidiu que a cláusula ad judicium é preservada mesmo que o mandato esteja vencido” (EREsp 789.978/DF, Corte Especial, rel. Min. João Otávio de Noronha, *DJe* 30.11.2009.).

“Quando parte também é advogado, legalmente habilitado, em vez de haver representante e representado, há uma só pessoa, que é parte e exerce a atividade postulacional. Uma vez que ela está inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, legalmente habilitada está. Ela é que escolhe em ser parte e advogado, ou ser parte e constitui advogado, a despeito de estar em situação suficiente para postular. Se ela é estagiária ou provisionada [a figura do provisionado não existe mais no direito brasileiro], somente pode praticar o que estagiário ou provisionado pode fazer, inclusive no tocante às limitações territoriais” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 428).

O art. 7º, XIV, do Estatuto da OAB, dispõe, por exemplo, na redação que lhe foi dada em 2016, que é direito do advogado “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”. Mas o art. 107 do CPC diz respeito apenas à vista dos autos de processo judicial.

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I – em que o exija o interesse público ou social; II – que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III – em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV – que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. § 1º O direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. § 2º O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença, bem como de inventário e de partilha resultantes de divórcio ou separação.

Com a ressalva de que todo advogado tem direito a fazer carga de “autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de dez dias” (art. 7º, XVI, do Estatuto da OAB).

“A retirada dos autos processuais de cartório por estagiário não configura intimação de decisão neles contida, por não deter o acadêmico os poderes necessários para a prática desse ato processual desacompanhado de advogado. Precedentes” (STJ, AgRg no AREsp 282.000/DF, 4ª Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 16.02.2016., *DJe* 19.02.2016.).

“O contrato entre cliente e advogado e advogado tem duas notas que o diferenciam claramente dos demais mandatos. Ele é necessário e a escolha é limitada. É necessário, porque só o advogado tem capacidade postulatória e a parte que não seja também habilitada na Ordem dos Advogados do Brasil não é autorizada a postular em causa própria (CPC, art. 37). A liberdade de escolha do advogado é limitada,

porque deve recair exclusivamente em profissionais habilitados como tais” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 713).

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO I - DAS PARTES E DOS PROCURADORES

CAPÍTULO IV - DA SUCESSÃO DAS PARTES E DOS PROCURADORES

Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei.

Direito anterior – art. 41 do CPC/1973.

Direito comparado – § 265 da ZPO alemã, art. 111 do CPC italiano e art. 271 do CPC português.

1. Estabilização rígida da demanda

O direito processual civil brasileiro, em tradição mantida pelo Código de Processo Civil de 2015, é fiel à regra da *estabilização rígida da demanda*, com a qual se combina a exigência de *substanciação* pelas partes da demanda e da defesa.¹ Diz-se *estabilização rígida* da demanda porque só é permitido ao autor modificar algum de seus elementos (partes, causa de pedir ou pedido), sem a anuência do réu, até a sua citação (art. 329, I), e com sua anuência até o saneamento (art. 329, II). Esse o sistema brasileiro de postulações,² diverso, por exemplo, do alemão, do inglês e do norte-americano.³ A estabilização rígida, como deixa claro o art. 108, vale também para o elemento subjetivo da demanda (as partes). Com a citação válida, assim, “verifica-se a *perpetuatio legitimationis* processual”⁴.

Salvo nos casos *expressos em lei*, deste modo, proíbe-se a alteração voluntária das partes da demanda estabilizada. A ideia subjacente a esta restrição é a de que o autor tem o direito de litigar contra quem bem entender – com a ressalva de que a ilegitimidade passiva autoriza a extinção prematura do processo – e o réu, após sua citação, o direito de continuar litigando contra o autor mesmo que ele próprio não queira mais fazê-lo – também com a ressalva de que o direito do réu ao julgamento do mérito pressupõe presentes as condições de admissibilidade do seu julgamento. Salvo, como se disse, se a lei autorizar ou determinar expressamente a sucessão processual.

O art. 338 do CPC dá um exemplo de autorização expressa para a alteração das partes da demanda mesmo após a citação do réu. Alegada a ilegitimidade passiva na contestação, permite-se ao autor a “alteração da petição inicial para substituição do réu”. Presume-se desta alegação do réu, com efeito, sua anuência à sucessão processual, se com ela concordar o autor.⁵ O réu não tem assim o *direito* à extinção do processo em relação ele sem julgamento do mérito. Também o art. 109, que trata da alienação da coisa ou do direito litigioso por ato *inter vivos*, dá um exemplo de expressa autorização legal, observadas certas condições descritas nos comentários a este artigo, para a alteração voluntária das partes da demanda mesmo após a citação do réu e mesmo após o saneamento.

A sucessão das partes – situação em que uma parte dá lugar a outra no processo (o sucessor passa a ocupar a posição que o sucedido ocupava até deixar a relação jurídica processual para lhe dar lugar) – não se confunde, por fim, com a substituição processual – situação em que alguém recebe da lei ou do alegado titular de um direito poderes para defender em juízo este direito alheio em seu próprio nome (legitimidade extraordinária, conforme explicado nos comentários ao art. 70⁶). Frequentemente embora a confusão, é preciso evitar o uso de um termo para se referir ao outro (situação em que esta confusão é especialmente problemática é aquela tratada nos comentários ao próximo artigo).

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não

altera a legitimidade das partes.

§ 1.º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2.º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3.º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Direito anterior – art. 42 do CPC/1973.

Direito comparado – § 265 da ZPO alemã, art. 111 do CPC italiano e art. 271 do CPC português.

1. *Litispêndência e litigiosidade*

A relação jurídica processual nasce com a demanda, mas o demandado só passa a integrá-la após sua citação.⁷ O demandante, por isso, será sempre parte da demanda e, ao mesmo tempo, do processo. O demandado, no entanto, até sua citação, será parte apenas da demanda, não do processo.⁸ Enquanto para o réu o início da litispêndência coincide, assim, com sua citação, mesmo quando ordenada por juiz incompetente,⁹ o processo torna-se *pendente* para o autor já com a demanda (art. 312 do CPC).¹⁰ A distinção é relevante porque *tornar litigiosa a coisa* não é tecnicamente um dos efeitos da citação válida, como equivocadamente sugere o art. 240 do CPC, mas sim um dos efeitos da *litispêndência*, que se inicia *em momentos diferentes* para autor e réu.

Litigiosidade (*Streitbefangenheit*) é o estado processual de sujeição aos efeitos do julgamento da demanda.¹¹ Coisa, por seu turno, não é apenas a *coisa* dos direitos reais, mas tudo aquilo que pode ser objeto de uma pretensão processual: coisas corpóreas ou incorpóreas, créditos, interesses juridicamente tuteláveis etc.¹² Daí por que *coisa litigiosa* (tradução literal do latim *res litigiosa*, pelo alemão *Streitsache*) é o objeto sobre o qual litigam as partes em determinado processo (o “objeto da controvérsia”, como sintetiza Fredie Didier Jr.¹³). Numa ação reivindicatória de um apartamento, por exemplo, coisa litigiosa será o bem imóvel. Numa ação de cobrança, coisa litigiosa será o crédito reclamado pelo autor.

2. *Alienação da coisa litigiosa no curso do processo*

A legislação brasileira permite a alienação da coisa litigiosa, na pendência do processo,¹⁴ ao contrário do que faziam, por exemplo, o direito romano¹⁵ e o direito alemão até a entrada em vigor da ZPO em 1879. Esta solução é acertada, exatamente porque “se não fosse possível negociar ‘direitos litigiosos’, o tráfego jurídico ficaria sensivelmente engessado. Bastaria que alguém propusesse uma demanda para discutir a titularidade de determinada coisa para que ela saísse do comércio jurídico, por mais infundada que fosse a sua pretensão”.¹⁶ O proprietário de um imóvel litigioso, por exemplo, réu numa ação reivindicatória, pode aliená-lo livremente a um terceiro. O terceiro passa com a alienação a ser o proprietário, independentemente da pendência do processo. Válida e eficaz, embora no plano do direito material, esta alienação será, no entanto, processualmente ineficaz em relação ao adversário do alienante, como se verá detalhadamente mais adiante.

A alienação de que trata este artigo é aquela realizada por ato entre vivos (sobre a sucessão *causa mortis*, confirmam-se os comentários ao art. 110) e a título particular (art. 109, *caput*). A lei disse menos, quanto a este último ponto, do que queria (*minus dixit quam voluit*). Nada impede a alienação a título universal, com efeito, “dos direitos hereditários, postulados numa ação de petição de herança”.¹⁷ Proíbem-se apenas as “alienações que importem o desaparecimento do alienante e sua substituição pelo adquirente ou cessionário, como ocorre nos casos de fusão ou incorporação da empresa litigante”.¹⁸ -¹⁹ Essa hipótese não se confunde com a sucessão *mortis*

causa de que trata o art. 110, porque este artigo trata exclusivamente da morte das pessoas naturais, que não se confunde com o desaparecimento das pessoas morais de que trata o *caput* do art. 109.

3. Substituição processual

A alienação da coisa litigiosa, em princípio,²⁰ “não altera a legitimidade das partes” (*caput*). Embora não mais o pretense titular da coisa litigiosa,²¹ em outras palavras, o alienante continua a ser *parte*, continua a ser a parte processualmente *legitimada* para litigar sobre este direito em juízo²². Essa é uma decorrência da *estabilização rígida da demanda* de que se falou nos comentários ao artigo anterior. É por isso que o alienante se torna *substituto processual* do adquirente.²³ Sua legitimidade deixa, assim, de ser ordinária, e passa a ser extraordinária (legitimidade extraordinária legal, não voluntária). Ao substituto, por este motivo, aplicam-se as limitações impostas em geral a todos os substitutos processuais para a prática de atos dispositivos.²⁴

Embora válida e eficaz *no plano material*, a alienação é *processualmente* ineficaz em relação ao adversário do alienante (§ 3.º). Com isso se quer dizer que a sentença será eficaz também contra o adquirente, que não é parte do processo, e poderá ser contra ele executada. Mais do que isso, a coisa julgada material formada neste processo atingirá também a esfera jurídica deste terceiro, numa exceção à regra geral segundo a qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506 do CPC).²⁵ É por este exato motivo que se permite ao terceiro adquirente intervir no processo na qualidade de assistente litisconsorcial de seu substituto (§ 2.º). Sobre a assistência litisconsorcial, confirmam-se os comentários ao art. 124.

No exemplo da reivindicação, o adquirente da coisa litigiosa perderá a propriedade para o adversário do alienante se seu pedido vier a ser julgado procedente, ainda que não tenha sido parte do processo em que o seu direito foi defendido por seu próprio titular, até o momento de sua alienação, e depois, pelo substituto processual *ex lege*. A extensão ao terceiro da eficácia e da coisa julgada material tem por fundamento a própria substituição processual.²⁶ Isso com a ressalva, entretanto, de que “se a pendência do processo for sujeita a registro ou averbação e o autor não o tiver providenciado, a extensão da coisa julgada não ocorrerá”²⁷. Tutela-se, desta maneira, a boa-fé do terceiro adquirente. Mas se trata de uma presunção apenas *relativa* de boa-fé, não absoluta. Comprovada de qualquer outro modo a ciência pelo adquirente no momento da alienação da litigiosidade, estendem-se a ele os efeitos da sentença e a própria coisa julgada material.

4. Sucessão processual

Situação inteiramente diversa é aquela em que o terceiro adquirente suceda ao alienante na relação jurídica processual (caso de sucessão voluntária²⁸), o que se permite apenas quando assim o desejarem alienante e adquirente com o consentimento do adversário (§ 1.º). Trata-se, a rigor, de um negócio jurídico processual para o qual concorrem três manifestações de vontade.²⁹ Mas não é apenas ao adversário do alienante que se permite recusar a sucessão, como poderia sugerir à primeira vista a redação do § 1.º. Também o alienante não está *obrigado* a concordar com ela. Se preferir, poderá optar por continuar litigando na qualidade de substituto processual do adquirente. Por exemplo, se acreditar que está em melhores condições de fazê-lo do que ele. Lembre-se ainda que o consentimento do adversário é exigido apenas na fase de conhecimento do processo, não na execução, conforme art. 778, § 2.º.

O adquirente, em síntese, assume com a regular sucessão processual a posição antes ocupada no processo pelo alienante, para defender em juízo um direito do qual ele passou, com a alienação, a ser o pretense titular. Diz-se *pretense* titular porque, como se explicou, a alienação pode se revelar ao final *a non domino*. Não se trata, assim, de substituição processual, mas sim de autêntica sucessão processual.

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1.º e 2.º.

Direito anterior – art. 43 do CPC/1973.

Direito comparado – § 239 da ZPO alemã, arts. 110 do CPC italiano, art. 16 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 371 do CPC português.

1. Sucessão causa mortis

Falecendo uma das partes (apenas pessoas naturais, nunca jurídicas), seus bens transmitem-se imediatamente para seus herdeiros (*droit de saisine*).³⁰ Ao morto, faltando-lhe capacidade de ser parte,³¹ não se permite a realização de qualquer ato processual (nem por si próprio, obviamente, nem por seu advogado), motivo pela qual da morte da parte decorre *ipso iure* a suspensão do processo (art. 313, I)³² até a habilitação do espólio ou, excepcionalmente, dos próprios sucessores (art. 689).³³⁻³⁴

Enquanto perdurar o inventário, o espólio, massa patrimonial dos bens e dívida deixados pelo *de cuius*, deve ser representado em juízo por inventariante ou administrador provisório, conforme se explicou nos comentários ao art. 75. Se dativo o inventariante, “os sucessores do falecido serão intimados no processo no qual o espólio seja parte” (art. 75, § 1.º). Nesta hipótese, não se tornarão eles *correpresentantes* do espólio ou *litisconsortes* nas demandas em que o espólio for parte, diferentemente do que ocorria na vigência do Código de Processo Civil de 1973.³⁵ A função desta intimação é de lhes servir apenas como instrumento de *fiscalização*.³⁶ Com o encerramento do inventário, antes do fim do processo de que parte o espólio, opera-se uma segunda sucessão, agora do espólio para os herdeiros, aos quais a partilha atribuir a coisa litigiosa.³⁷

Lembre-se apenas que a habilitação do espólio ou dos herdeiros só é admissível quando transmissível o direito ou o dever de que titular o falecido (não, a rigor, a *ação*, como frequentemente se lê), conforme se explicará nos comentários ao art. 689. Colhem-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça alguns exemplos de direitos e deveres intransmissíveis. No mandado de segurança, porque “não é cabível a sucessão de partes, ante o caráter mandamental e a natureza personalíssima da demanda, admitindo-se a habilitação, todavia, caso o feito esteja na fase de execução”;³⁸ na obrigação de pagar alimentos, que consiste em “obrigação, de natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo devedor quando em vida. Fica ressalvada a irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada”;³⁹ também em relação ao dever de prestação de contas, porque “a disposição do art. 914, II, do CPC, de que a ação de prestação de contas compete a quem tiver a obrigação de prestá-las, deve ser lida e interpretada no sentido de competir somente àquele que administra os bens e interesses de terceiros (obrigação personalíssima), porque é a pessoa capaz de informar quais providências e despesas foram feitas, como foram feitas e por que o foram. Os herdeiros não podem ser obrigados a prestar contas relativas a atos de gestão praticados por terceiro, realizados sem a anuência ou qualquer participação deles, mormente se considerado o ônus que a inércia lhes impõe, de o Juiz, eventualmente, acolher aquelas que o autor apresentar (art. 915, §§ 2.º e 3.º, do CPC)”.⁴⁰⁻⁴¹

Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assumo o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76.

Direito anterior – art. 44 do CPC/1973.

Direito comparado – § 87 da ZPO alemã, art. 85 do CPC italiano, art. 30 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 39 do CPC português.

1. Mandato e procuração

Mandato judicial, como se viu nos comentários ao art. 104, é um *contrato* mediante o qual uma pessoa, física ou jurídica, contrata um advogado (bacharel em direito regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) ou uma sociedade de advogados para representá-la em juízo de acordo com determinadas condições estabelecidas no contrato. Ele não se confunde, como também se viu, com a *procuração*,⁴² instrumento mediante o qual o advogado (nunca a sociedade de advogados) recebe poderes de seu constituinte para representá-lo em determinado processo (representação judicial). É neste sentido que é concebível se falar em *mandato sem poderes*, quando existe contrato entre as partes, embora o constituinte não tenha dado procuração a seu advogado, e em *poderes sem mandato*, quando o constituinte deu procuração a um advogado, embora não exista contrato entre eles a regular se e em que condições se prestarão os serviços de advocacia.

2. Revogação pelo constituinte da representação judicial

Independentemente das consequências que esta revogação puder ter para a relação contratual existente entre eles (multa, antecipação de honorários de êxito etc.), a parte poderá a qualquer momento revogar os poderes conferidos a seu advogado para lhe representar em juízo (revogação da representação judicial).⁴³ A revogação pode ser tanto expressa, quando a parte informa ao juiz que revogou os poderes outorgados a seu advogado, quanto tácita, porque “a procuração juntada aos autos, sem ressalva expressa quanto à permanência dos mandatos outorgados anteriormente, acarreta a revogação tácita destes”.⁴⁴

A revogação, com efeito, deve ser entendida como um fenômeno *processual*, autônomo embora conexo à extinção *no plano material* do contrato de mandato, que pode ocorrer mediante resolução (com fundamento, por exemplo, no inadimplemento do cliente – art. 475 do CC) ou por rescisão (unilateral, denúncia, art. 473 do CC, ou bilateral, distrato – art. 472 do CC).⁴⁵ Mas são fenômenos diversos. Aquilo que se revoga não é, a rigor, o mandato (modalidade de contrato), mas a representação judicial de que instrumento a procuração. É por este motivo que a revogação da representação processual é eficaz mesmo quando por qualquer motivo não o for a resolução ou a rescisão.

No mesmo momento em que comunica ao juiz a revogação dos poderes conferidos a seu advogado, a parte deve constituir um outro; no mesmo momento, mas não obrigatoriamente por meio do mesmo instrumento. “A norma visa a evitar retardamento do processo, porque, à falta de procuração nos autos, as intimações teriam de ser feitas à parte”.⁴⁶ Não o fazendo, ela terá 15 (quinze) dias para regularizar a sua capacidade postulatória (parágrafo único). Mas a revogação é sempre eficaz, *independentemente* da constituição ou não de novos advogados.⁴⁷ As consequências processuais da falta de capacidade postulatória (porque *sem representação judicial* a parte que revoga os poderes conferidos a um advogado sem outorgá-los a outros) são aquelas previstas no art. 76. A capacidade postulatória do demandante é, assim, uma condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Sem sua correção, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito (art. 76, § 1.º, I). Em caso de litisconsórcio ativo, apenas em relação àquele a que faltar a capacidade. A capacidade postulatória do demandado, diferentemente, não será nunca condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. De sua falta decorre a revelia do demandado, nunca a extinção do processo (art. 76, § 1.º, II). O terceiro, dependendo do polo do processo em que se encontre, “será considerado revel ou excluído do processo” (art. 76, § 1.º, III). Na assistência, por exemplo, o terceiro será *excluído* do processo. No chamamento ao processo, diferentemente, também, por exemplo, será considerado revel.

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1.º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

§ 2.º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Direito anterior – art. 45 do CPC/1973.

Direito comparado – § 87 da ZPO alemã, art. 85 do CPC italiano, art. 30 da ley de Enjuiciamiento Civil espanhola e art. 39 do CPC português.

1. Mandato e procuração

Mandato judicial, como se viu nos comentários ao art. 104, é um *contrato* mediante o qual uma pessoa, física ou jurídica, contrata um advogado (bacharel em direito regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB) ou uma sociedade de advogados para representá-la em juízo de acordo com determinadas condições estabelecidas no contrato. Ele não se confunde, como também se viu, com a *procuração*,⁴⁸ instrumento mediante o qual o advogado (nunca a sociedade de advogados) recebe poderes de seu constituinte para representá-lo em determinado processo (representação judicial). É neste sentido que é concebível se falar em *mandato sem poderes*, quando existe contrato entre as partes, embora o constituinte não tenha dado procuração a seu advogado, e em *poderes sem mandato*, quando o constituinte deu procuração a um advogado, embora não exista contrato entre eles a regular se e em que condições se prestarão os serviços de advocacia neste processo específico.

2. Recusa pelo advogado da procuração

Na hipótese de procuração sem mandato, diferentemente do que ocorre na *renúncia* à representação, permite-se ao advogado a *recusa à representação* (recusa do patrocínio), porque nenhum advogado é obrigado, salvo excepcionalmente,⁴⁹ a representar alguém em juízo se não quiser, por qualquer motivo, fazê-lo.⁵⁰ Como observa Pontes de Miranda, “recusa quem não aceita. Quem denuncia já aceitara”.⁵¹ O advogado que recusa (que nunca aceitou, portanto, representar o outorgante), não tem qualquer obrigação em relação ao outorgante, nem, obviamente, o dever de respeitar o prazo de dez dias de que trata o § 1.º ao comunicar ao juízo a sua recusa.

3. Renúncia pelo advogado à representação judicial

Independentemente das consequências que esta renúncia puder ter para a relação contratual existente entre eles (multa, perda de honorários de êxito etc.), o advogado poderá a qualquer momento renunciar aos poderes a ele conferidos por seu constituinte (renúncia à representação judicial),⁵² desde que comprove ter-lhe comunicado a renúncia (*caput*).⁵³ Fará isso dando ciência ao juiz da causa que não mais representa seu constituinte.⁵⁴ Mas isso com a ressalva de que “dispensa-se a comunicação referida no *caput* [mas não a comunicação ao juízo] quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia” (§ 2.º).

A renúncia deve ser entendida, com efeito, como um fenômeno *processual*, autônomo embora conexo à extinção *no plano material* do contrato de mandato, que pode ocorrer mediante resolução (com fundamento, por exemplo, no inadimplemento do cliente – art. 475 do CC) ou por resilição (unilateral, denúncia, art. 473 do CC, ou bilateral, distrato – art. 472 do CC).⁵⁵ Mas são fenômenos diversos. Aquilo a que se renuncia não é, a rigor, o mandato (modalidade de contrato), mas a representação judicial de que instrumento a procuração. É por este motivo que a renúncia à representação processual é eficaz mesmo quando por qualquer motivo não o for a resolução ou a resilição.

Durante os dez dias seguintes à *notificação do constituinte* ou à *juntada aos autos da petição de renúncia*, conforme o caso, o advogado continuará a representar judicialmente o seu constituinte (§ 1.º). Mas desde que, de sua renúncia, possa decorrer efetivo prejuízo a seu cliente. Não será o caso quando, constituído mais de um advogado, apenas um ou alguns deles (mas não todos) renunciarem.⁵⁶ Também não será o caso se neste íterim, mesmo quando a renúncia tiver sido feita por todos os advogados constituídos, a parte nomear um novo para representá-la. “O advogado, portanto, pode renunciar, mas não pode desertar”.⁵⁷ Não é por outro motivo que o

art. 34, XI, do Estatuto da OAB, dispõe constituir infração disciplinar “abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos dez dias da comunicação da renúncia”. Situação particular é aquela em que a renúncia ocorre *na fluência de prazo* (para contestar, para recorrer etc.). Neste caso, o advogado renunciante é responsável pela redação e protocolo da petição mesmo quando o seu prazo encerrar-se após o fim dos dez dias.^{58 - 59} Nada mais razoável, porque faltaria tempo hábil a seu constituinte para nomear outro advogado que pudesse desincumbir-se deste prazo adequadamente. Decorridos os dez dias sem a nomeação de novo advogado, por fim, o juiz deve lidar com a falta de capacidade postulatória da parte nos termos do disposto no art. 76.

NOTAS DE RODAPÉ

1

“Para que a petição inicial seja válida, no processo brasileiro, é preciso que o autor identifique precisamente os elementos constitutivos da demanda de que a petição inicial é o instrumento (partes, causa de pedir e pedido). Não basta, com efeito, que o autor nela exponha “a short and plain statement of the claim showing that the pleader is entitled to relief” [como exige a Rule 8 das Federal Rules of Civil Procedure americanas], mas se exige que ele indique, com precisão, o que pede, contra quem pede e com fundamento em que ele pede. A mesma precisão se espera do réu, de quem se exige, na contestação, que alegue toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor (art. 336 do CPC)” (Renato Beneduzi, *Substantiierung, Notice-Pleading e Fact-Pleading: A relação entre escopo das postulações e função da prova nos processos alemão, americano e inglês*, *Revista de Processo*, vol. 245, p. 446).

2

“A função precípua da fase postulatória no processo civil brasileiro é, desta maneira, identificar (com precisão) e estabilizar (com rigidez) demanda e defesa (a demanda ainda mais que a defesa). Mas não apenas isso. Somente ao final das postulações será possível saber quais alegações das partes, relativas a fatos relevantes para o julgamento da demanda, se tornaram controvertidas. As postulações, assim, antecedem e delinham o objeto da prova, que não serve, conseqüentemente, para auxiliar autor e réu na construção da demanda e da defesa. Muito ao contrário. A definição precisa do objeto da prova pressupõe, exatamente, a prévia estabilização da demanda e da defesa” (Renato Beneduzi, *Substantiierung, Notice-Pleading e Fact-Pleading: A relação entre escopo das postulações e função da prova nos processos alemão, americano e inglês*, *Revista de Processo*, vol. 245, p. 446).

3

Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Substantiierung, Notice-Pleading e Fact-Pleading: A relação entre escopo das postulações e função da prova nos processos alemão, americano e inglês*, *Revista de Processo*, vol. 245, p. 445.

4

Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 108, item 2.

5

Com a ressalva de que “realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8.º” (art. 338, parágrafo único).

6

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

7

Sobre o conceito de citação: Renato Beneduzi, Notificação e citação na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, in: *Improbidade administrativa* (aspectos processuais da Lei n. 8.429/92), p. 378.

8

Este fato leva a doutrina alemã a diferenciar conceitualmente a pendência do processo antes da citação do réu (*Anhängigkeit*) de sua pendência após a citação (*Rechtshängigkeit*). Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 86.

9

José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 386.

10

Como resume Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, fazendo referência embora ao Código de Processo Civil de 1973: “Assim se posicionando, o Código de 1973 nada mais fez do que dar roupagem legal à teoria da relação jurídica processual, que, explicando a natureza do processo, é hoje dominante na doutrina brasileira. Essa relação jurídica, como já ensinava Oskar von Bülow, é contínua e progressiva, desenvolvendo-se passo a passo, por meio de seriação ordenada de atos. A realidade repele a noção de que a relação jurídica processual possa se formar de um jacto com a citação. Ao contrário, primeiro há a formação da relação jurídica entre o autor e o Estado (juiz), que o art. 263 põe no despacho inicial ou na distribuição, e só depois dá-se a angularização Estado (juiz) – réu, com a citação. Por isso, para o demandante é com a propositura da ação que se estabelece a litispendência e, pois, para ele, esse é o marco inicial da litigiosidade” (*Alienação da coisa litigiosa*, p. 102).

11

Para mais detalhes: Becker-Eberhard, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1594.

12

Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 552.

13

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 541.

14

Mesmo a alienação realizada em fraude à execução (art. 792 do CPC).

15

Para mais detalhes: Max Kaser, *Zivilprozessrecht*, p. 227.

16

Paula Costa e Silva, *A transmissão da coisa ou direito em litígio*. Contributo para o estudo da substituição processual, p. 93.

17

Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 185.

18

Idem, *ibidem*.

20

Salvo na hipótese tratada no próximo item.

21

Diz-se *pretensio* porque é possível que, à luz do direito material, o alienante não seja o verdadeiro titular; só a sentença ao final o dirá.

22

Luciano Vianna Araújo, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 1, p. 487.

23

Na legitimidade processual extraordinária, alguém recebe da lei ou do alegado titular de um direito poderes para defender em juízo este direito alheio em seu próprio nome, conforme explicado nos comentários ao art. 70.

24

25

“Trata-se, aqui, de um fenômeno de extensão subjetiva da eficácia da sentença, e até se poderia dizer, creio eu, de um fenômeno de extensão subjetiva da própria autoridade da coisa julgada. O adquirente, ainda que não ingresse no processo, nem mesmo a título de assistente, ficará sujeito aos efeitos da sentença que for proferida entre as partes primitivas, e ficará também vinculado pela autoridade da coisa julgada” (José Carlos Barbosa Moreira, *Estudos sobre o novo Código de Processo Civil*, p. 70).

26

“... sarebbe assurdo che la legge autorizzasse taluno a far valere in giudizio i diritti altrui, e insieme non riconoscesse alla sua attività piena efficacia rispetto ai diritti fatti valere” (Giuseppe Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, vol. II, p. 230).

27

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 543.

28

Confirmam-se os comentários ao art. 108.

29

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 544.

30

“A teoria da coincidência de momentos remonta ao antigo Direito francês, que consagra a *saisine* como instituto pelo qual a transmissão hereditária se verifica *ipso jure* segundo o princípio: *le mort saisit le vif* (...). O direito pátrio filiou-se à doutrina da *saisine*. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários” (Orlando Gomes, *Sucessões*, p. 20).

31

Confirmam-se os comentários ao art. 75.

32

Com a ressalva de que “a eventual não observância da regra prevista no art. 265, I, do CPC [atual art. 313, I, do CPC], que determina a suspensão do processo com a morte de qualquer das partes, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo para os interessados. (AgRg no AREsp 759.411/DF, rel. Min. Humberto Martins, 2.^a Turma, j. 27.10.2015, *DJe* 12.11.2015) e ainda de que “esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade

processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do *de cujus*” (REsp 1328760/MG, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1.ª Turma, j. 26.02.2013, *DJe* 12.03.2013).

33

“Apesar do art. 43 do CPC referir que a substituição possa ocorrer alternativamente „pelo espólio ou pelos seus sucessores”, entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, ocorrendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário” (AgRg no REsp 1051443/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5.ª Turma, j. 23.06.2015, *DJe* 29.06.2015).

35

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 205.

36

“A ressalva merece uma explicação: nos casos de inventariante dativo, os herdeiros são intimados para poder acompanhar o andamento do processo e, assim, poder fiscalizar a atuação do inventariante, que é pessoa estranha à família” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 318).

37

“Se, durante o curso da demanda, terminar o inventário, e for feita a partilha de bens, desaparece a figura do espólio. Este será substituído na ação pelo herdeiro a quem coube, na partilha, a coisa ou direito objeto da causa. Poderá, portanto, ocorrer mais de uma substituição [*rectius*, sucessão processual], sucessivamente: a da parte falecida pelo espólio e a deste pelo herdeiro a quem couber a coisa ou direito” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 191).

38

AgRg no ExeMS 115/DF, rel. Min. Humberto Martins, 1.ª Seção, j. 08.04.2015, *DJe* 15.04.2015.

39

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, 2.ª Seção, j. 26.11.2014, *DJe* 20.02.2015.

40

REsp 1354347/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 06.05.2014, *DJe* 20.05.2014.

42

Sobre os requisitos e características da procuração, confirmam-se os comentários ao art. 105.

43

“Tanto a revogação da procuração pela parte quanto a denúncia pelo procurador são declarações de vontade receptíveis” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 461).

44

EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1140539/CE, rel. Min. Regina Helena Costa, 5.^a Turma, j. 13.05.2014, *DJe* 19.05.2014.

45

Embora possa o mandato ainda se extinguir pelo fim de seu prazo de vigência (termo) ou pelo cumprimento integral das obrigações nele pactuadas.

46

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 192.

47

Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 192.

48

Sobre os requisitos e características da procuração, confirmam-se os comentários ao art. 105.

49

Segundo o art. 15 da Lei 1.060/1950, por exemplo: São motivos para a recusa do mandato pelo advogado designado ou nomeado: § 1.^o – estar impedido de exercer a advocacia. § 2.^o – ser procurador constituído pela parte contrária ou ter com ela relações profissionais de interesse atual; § 3.^o – ter necessidade de se ausentar da sede do juízo para atender a outro mandato anteriormente outorgado ou para defender interesses próprios inadiáveis; § 4.^o – já haver manifestado por escrito sua opinião contrária ao direito que o necessitado pretende pleitear; § 5.^o – haver dada à parte contrária parecer escrito sobre a contenda.

50

Neste sentido o disposto no art. 4.^o do Código de Ética e Disciplina da OAB: “O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico, ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Parágrafo único. É legítima a recusa, pelo advogado, do patrocínio de causa e de manifestação, no âmbito consultivo, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente.

51

52

“Tanto a revogação da procuração pela parte quanto a denúncia pelo procurador são declarações de vontade receptíveis” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 461).

53

“Não há forma específica para a comunicação (termo que substituiu o anterior, “ciência” – art. 45 CPC/73. Outorgante do mandato poderá ser comunicado através de e-mail, fax, carta, telegrama, etc.” (Arruda Alvim Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 203).

54

Segundo o art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB, “a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento da causa, uma vez decorrido o prazo previsto em lei”.

55

Embora possa o mandato ainda se extinguir pelo fim de seu prazo de vigência (termo) ou pelo cumprimento integral das obrigações nele pactuadas.

56

E isso ao fundamento de que “na parte final, o artigo expressa a finalidade dessa disposição, que é evitar prejuízo à parte. Essa cláusula é da maior importância para a interpretação do artigo. Dela se deduz que, se a parte tiver outro procurador, que permaneça no exercício do mandato, a continuação do renunciante não tem mais justificativa” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 193).

57

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 207.

58

Sobre esta questão: Ovídio Baptista, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 193.

59

Para Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, diferentemente, “se o prazo de dez dias findar antes do decurso do prazo de quinze dias, não há um prejuízo a ser evitado e, portanto, não cabe ao advogado que denunciou o mandato cumprir o prazo” (Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 296).

A regra não se aplica, portanto, “à sucessão universal das pessoas jurídicas” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 202).

“Nos termos do art. 43 do CPC, havendo falecimento da parte, dar-se-á a substituição pelo seu espólio. No caso, tendo ocorrido a habilitação do espólio, não há falar em ingresso concomitante do herdeiro, pois o espólio representa, em juízo, a comunidade de herdeiros” (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1179851/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4.^a Turma, j. 23.04.2013, *DJe* 29.04.2013).

As referências legislativas são ainda ao Código de Processo Civil de 1973, mas o princípio é o mesmo.

TÍTULO II - DO LITISCONSÓRCIO

Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;

II – entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir;

III – ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito.

§ 1.º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

§ 2.º O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar.

Direito anterior – art. 46 do CPC/1973.

Direito comparado – §§ 59 e 60 da ZPO alemã, art. 103 do CPC italiano, art. 12 da ley de enjuiciamiento civil espanhola, art. 27 do CPC português, Part 19 das CPR inglesas e Rule 18 dos FRCP norte-americanos.

1. Litisconsórcio facultativo e economia processual. Litisconsórcio (cumulação subjetiva de demandas)¹ é a situação processual em que duas ou mais pessoas (litisconsortes) litigam em juízo, lado a lado,² como demandantes (litisconsórcio ativo) ou demandados (litisconsórcio passivo).³ Por *demandas* não se quer aludir apenas à demanda principal, mediante a qual o autor deduz sua pretensão processual contra o réu, mas também a eventuais demandas incidentais (por exemplo, uma demanda recursal *incidental* ao processo).⁴ Se ocorrerem simultaneamente os litisconsórcio ativo e passivo, diz-se se tratar de litisconsórcio misto (ou bilateral).⁵

O litisconsórcio será facultativo se o julgamento do mérito da demanda não depender de sua formação. Daí por que dispõe o *caput* que duas ou mais pessoas *podem* litigar em conjunto no mesmo processo, não que elas *devem* fazê-lo. As demandas, com efeito, poderiam ter sido deduzidas em processos diversos, sem óbice algum, mas *se optou* pela cumulação.⁶ Se obrigatória sua formação, ao contrário, o litisconsórcio será necessário, como melhor se explicará nos comentários ao próximo artigo⁷. No litisconsórcio necessário, a cumulação subjetiva, ativa ou passiva, é condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda, diferentemente do que ocorre no litisconsórcio facultativo. Sem ela, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito.

A escolha sobre a extensão do litisconsórcio facultativo cabe, fundamentalmente, ao próprio demandante. É ele quem deve decidir livremente se se associa a um outro demandante ou se deduz a demanda contra mais de um demandado.⁸ Mas esta cumulação subjetiva facultativa de demandas deve ser permitida pelo juiz apenas se ela não for processualmente *inconveniente*.⁹

Tanto que a lei permite expressamente ao juiz *limitar* o litisconsórcio facultativo (em qualquer de suas hipóteses, não apenas no caso de litisconsórcio fundado na afinidade de interesses) “quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença” (§ 1.º).¹⁰ Sua admissão tem por fundamento, deste modo, a *economia processual*, a utilidade prática desta reunião.¹¹ Como resume Luiso, “la funzione del litisconsorzio facoltativo è duplice: di economia processuale, anzitutto; e poi di armonizzazione delle decisioni”.¹²⁻¹³⁻¹⁴

2. As três figuras do litisconsórcio facultativo. São três, na tradicional expressão de Machado Guimarães,¹⁵ as figuras do litisconsórcio facultativo. São elas, em ordem decrescente de intensidade, a *comunhão* de interesses (inciso I),¹⁶ a *conexão* de interesses (inciso II)¹⁷ e a *afinidade* de interesses (inciso III).¹⁸⁻¹⁹ A cumulação subjetiva é permitida, não obrigatória (mesmo no caso de comunhão de interesses; o coproprietário que reivindica o bem e o credor solidário que cobra a dívida, por exemplo, estão em comunhão de interesses com o outro coproprietário e o outro credor solidário, mas a formação do litisconsórcio ativo entre eles não é necessária²⁰), em todas estas figuras, mas com algumas diferenças relevantes.

Na comunhão de interesses, o litisconsórcio permitirá sempre a prorrogação da competência relativa. O juízo relativamente incompetente para julgar a demanda em relação a apenas um litisconsorte, deste modo, torna-se competente para o julgamento em relação também ao outro com fundamento na prorrogação (art. 46, § 4.º).²¹ Na conexão de interesses, por seu turno, permitem-se a formação do litisconsórcio e a consequente prorrogação da competência relativa *desde* que não abusiva ou inconveniente a escolha do demandante (*forum non conveniens*).²² Na afinidade de interesses, diferentemente, espécie de *conexidade degradada* na qual ténue a relação entre os litisconsortes,²³ não se admite em princípio a prorrogação da competência relativa salvo quando o juiz entender existirem razões convincentes que justifiquem a reunião à luz do disposto no art. 55, § 3.º, também do CPC.²⁴

3. Limitação do litisconsórcio facultativo. Não sendo ele necessário, no sentido de não ser indispensável para o julgamento do mérito da demanda, a admissibilidade do litisconsórcio facultativo tem por fundamento a *utilidade prática* da reunião das demandas. Por isso, quando sua formação ou mesmo sua continuação parecer “*comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença*”, deverá o juiz, de ofício ou a requerimento, em qualquer fase do processo (“*na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução*”, na expressão equivalente empregada pela lei) limitar o litisconsórcio mediante a determinação de desmembramento do processo (§ 1.º). Este dispositivo se refere, em sua primeira parte, à *conveniência-adequação*, e na segunda ao *abuso* na formação do litisconsórcio (*forum non conveniens*).²⁵

A distinção é relevante porque se tutela, no primeiro caso, o interesse público na boa administração da justiça, razão pela qual o juiz pode determinar de ofício, por este fundamento e a qualquer tempo no trâmite do processo, o desmembramento. No segundo caso, diferentemente, em que predomina o interesse da parte prejudicada, o juiz só poderá decidir se provocado e o interessado terá o ônus de fazer o requerimento de desmembramento na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos sob pena de preclusão. Nas duas hipóteses, de todo modo, o pedido de limitação “interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar” (§ 2.º). O incidente de desmembramento é decidido mediante decisão interlocutória, sem extinguir o processo mesmo em relação ao litisconsorte desmembrado (excluído *deste* processo), da qual cabe, em caso de indeferimento, agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VIII e, em caso de deferimento, com fundamento no art. 1.015, VII.²⁶

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Direito anterior – art. 47 do CPC/1973.

Direito comparado – § 62 da ZPO alemã, art. 102 do CPC italiano, art. 12 da ley de

enjuiciamiento civil espanhola, art. 28 do CPC português, Part 19 das CPR inglesas e Rule 18 dos FRCP norte-americanos.

1. Litisconsórcio necessário. Litisconsórcio (cumulação subjetiva de demandas)²⁷ é a situação processual em que duas ou mais pessoas (litisconsortes) litigam em juízo, lado a lado,²⁸ como demandantes (litisconsórcio ativo) ou demandados (litisconsórcio passivo).²⁹ Por *demand* não se quer aludir apenas à demanda principal, mediante a qual o autor deduz sua pretensão processual contra o réu, mas também a eventuais demandas incidentais (por exemplo, uma demanda recursal *incidental* ao processo)³⁰. Se ocorrerem simultaneamente os litisconsórcios ativo e passivo, diz-se se tratar de litisconsórcio misto (ou bilateral).³¹

O litisconsórcio será facultativo, como se explicou nos comentários ao artigo anterior, se o julgamento do mérito da demanda não depender de sua formação. As demandas, neste caso, poderiam ter sido deduzidas em processos diversos, sem óbice algum, mas se optou pela cumulação.³² Se *obrigatória* sua formação, ao contrário, o litisconsórcio será necessário³³. A parte só terá legitimidade processual (ativa ou passiva, conforme o caso) se acompanhada de seu litisconsorte necessário. No litisconsórcio necessário, assim, a cumulação subjetiva é condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda, diferentemente do que ocorre no litisconsórcio facultativo. Sem o preenchimento desta condição, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI (como se verá melhor nos comentários ao art. 115, o juiz deve dar ao demandante a possibilidade de sanar a falta do litisconsórcio antes de extinguir o processo). Mas isso com a ressalva de que o litisconsórcio será necessário apenas se a parte não puder ser considerada, por qualquer razão, *substituto processual* do litisconsorte omitido (legitimidade extraordinária legal ou mesmo convencional).³⁴

O litisconsórcio *passivo* necessário é seguramente o mais comum.³⁵ Por exemplo, “nas demandas movidas pelo Ministério Público, onde se objetiva a anulação de contrato administrativo, pela incindibilidade da relação jurídica objeto da demanda, é necessário que todos os integrantes da relação contratual figurem no processo, caracterizando hipótese de litisconsórcio passivo necessário”³⁶ ou ainda entre os cônjuges “nas ações que versem sobre direitos reais imobiliários”.³⁷ Mais raramente, no entanto, vê-se também o litisconsórcio *ativo* necessário, caso em que o mérito da demanda deve ser julgado apenas se *todos* os legitimados ativos forem parte. Nada há de *a priori* inconstitucional nesta exigência, desde que ela decorra *razoavelmente* da natureza jurídica da relação jurídica material controvertida.³⁸ Não existe uma *garantia constitucional ao julgamento do mérito*. A lei pode perfeitamente condicionar o seu julgamento à formação do litisconsórcio ativo, desde que o faça sem exageros (*Übermaßverbot* ³⁹). É o caso, por exemplo, das ações *possessórias* imobiliárias quando compossuidores os cônjuges, das demandas revisionais propostas pelos mutuários em relação a contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH)⁴⁰ e dos adquirentes de determinada coisa na ação redibitória. Um cotitular tem o *direito* de não querer, respectivamente, a tutela da composesse, a revisão do contrato e a resolução do contrato de compra e venda. Litigar, ademais, embute sempre um *risco* que, ao cotitular de uma determinada posição jurídica, em certas hipóteses, reconhece-se o direito de se recusar a assumir.⁴¹

2. Litisconsórcio necessário por força de lei. O litisconsórcio será necessário, ativo ou passivo, por expressa disposição de lei, desde que observada a restrição constitucional ao exagero (*Übermaßverbot*) de que se tratou no item anterior. É o caso, por exemplo, do litisconsórcio ativo ou passivo entre cônjuges por força do disposto no art. 73, § 2.º, segundo o qual “nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composesse ou de ato por ambos praticado” ou do litisconsórcio passivo na ação demarcatória com fundamento no disposto no art. 574, segundo o qual “na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha demarcanda”.

3. Litisconsórcio necessário por força da natureza da relação jurídica controvertida. O litisconsórcio será também necessário, ativo ou passivo, quando a natureza jurídica da relação

jurídica controvertida o exigir, desde que também observada a restrição constitucional ao exagero (*Übermaßverbot*). Não pura e simplesmente quando “a causa versar um objeto incindível”,⁴² porque a incindibilidade torna o litisconsórcio unitário, como se verá nos comentários ao art. 116, mas não inexoravelmente necessário. Na demanda ajuizada por um dos sócios para pedir a anulação de assembleia, por exemplo, o litisconsórcio ativo será unitário, mas não necessário. Mesma coisa na ação reivindicatória ajuizada por um dos coproprietários.

A necessidade decorre, a rigor, do *grave inconveniente* de se deixar alguém de fora, grave o suficiente a justificar a exigência do litisconsórcio em detrimento do direito da parte de escolher com quem e contra quem vai litigar. No litisconsórcio passivo, a violação da garantia do litisconsorte necessário ao contraditório. No litisconsórcio ativo, o direito do litisconsorte de não querer que se peça a tutela de determinada posição jurídica do qual ele é cotitular. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dá um bom exemplo de litisconsórcio necessário quando trata das “demandas revisionais atinentes ao SFH e as consequências do ajuizamento de ação por somente um daqueles que figurem no contrato de mútuo na qualidade de contratante. A natureza do negócio jurídico realizado pelos mutuários e a possibilidade de modificação da relação jurídica de direito material subjacente determinam, no caso dos autos, a formação do litisconsórcio ativo necessário. O litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários em questão é fenômeno que busca preservar a harmonização dos julgados e o princípio da segurança jurídica. Além disso, promove a economia processual, que é um dos fins a que se presta o próprio instituto em evidência, na linha do moderno processo civil que prima por resultados”.⁴³ Ao contrário do que se passa com os coproprietários na reivindicação, em que cada um deles pode pedir sem a participação do outro a tutela da propriedade comum, embora não possa decidir o juiz de modo diverso para cada um deles (litisconsórcio ativo unitário facultativo), o litisconsórcio será necessário (e unitário), por exemplo, na ação redibitória, demanda mediante a qual o comprador pede a resolução de uma compra e venda em razão da existência de defeito oculto quando mais de um os adquirentes. Quando o bem tiver sido comprado “pro indiviso e em comunhão, é lícito a cada um deles externar preferência pela manutenção do status quo, optando então por não demandar (até porque pode considerar prejudicial a resolução contratual). Como perante o direito material a resolução consensual dependeria sempre do concurso da vontade de todos esses adquirentes – porque a ninguém é lícito dispor de direitos alheios – segue-se a indispensabilidade do litisconsórcio ativo nesse caso”.⁴⁴

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Direito anterior – art. 47 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 416 da ley de enjuiciamiento civil espanhola e art. 197 do CPC português.

1. Litisconsórcio enquanto condição de admissibilidade do julgamento do mérito. No litisconsórcio necessário, a cumulação subjetiva, ativa ou passiva, é condição de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda, diferentemente do que ocorre no litisconsórcio facultativo.⁴⁵ A parte só terá legitimidade processual (ativa ou passiva, conforme o caso) se acompanhada de seu litisconsorte necessário. Sem o preenchimento desta condição, o processo deve ser extinto, sem julgamento do mérito, com fundamento no disposto no art. 485, VI. Antes de extinguir o processo, no entanto, deve o juiz, quando lhe parecer omitido algum dos litisconsortes necessários, determinar ao autor que providencie a correção do vício em prazo razoável (parágrafo único). Esta regra vale tanto para o litisconsórcio necessário ativo, situação em que o

autor deve convencer o litisconsorte omitido a com ele litigar, quanto para o passivo, com a ampliação subjetiva da demanda mediante o seu aditamento pelo autor. Em ambos os casos, a *integração do contraditório* é igualmente possível, motivo pelo qual *dixit minus quam voluit* a lei ao aludir à possibilidade de correção apenas em relação ao litisconsórcio necessário passivo.⁴⁶

O juiz, a rigor, quando omitido um litisconsorte passivo necessário, não deve determinar *de ofício* a sua citação (formação do litisconsórcio *iussu iudicis*)⁴⁷⁻⁴⁸. Esta figura não existe no processo brasileiro por força do princípio da demanda, com fundamento no qual cabe ao autor, e exclusivamente a ele, escolher contra quem quer litigar. O que faz o juiz é apenas, à luz do princípio da cooperação, dar ao interessado a possibilidade de corrigir um vício, que é sanável, antes de extinguir o processo. Excepcional, neste caso, é a circunstância de que a ampliação subjetiva da demanda poderá ocorrer até o saneamento e mesmo se com ela não concordar o adversário já citado. Trata-se de exceção à regra geral de que, após a citação, o aditamento da demanda exige sempre o consentimento do réu (art. 329, I).⁴⁹ Esta exceção é razoável, porque atende ao princípio da primazia do mérito consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015⁵⁰ sem, ao mesmo tempo, tumultuar o andamento do processo. É melhor e mais eficiente permitir a integração tardia do litisconsorte omitido neste caso particular (litisconsorte necessário omitido), embora apenas até o fim da fase de saneamento, do que *forçar* a extinção do processo e aguardar a repropositura da demanda. Com razão Zuckerman ao elogiar, no contexto da *addition of parties*, a “long standing preference for completeness in adjudication” característica do direito inglês.⁵¹

2. Litisconsórcio necessário unitário e a nulidade da sentença. Omitido um dos litisconsortes necessários, no polo ativo ou passivo da demanda, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito. Mas e se, embora isso não devesse ocorrer, o mérito da demanda vier a ser julgado? Se unitário o litisconsórcio necessário,⁵² a sentença será nula *como um todo* (inciso I).⁵³ Este *error in procedendo* autoriza a sua reforma em grau de recurso e também sua desconstituição em ação rescisória, se vier a transitar em julgado, com fundamento no disposto no art. 966, VI. Mas ela será também *ineficaz*, mesmo antes e independentemente de sua reforma ou rescisão, em relação ao litisconsorte omitido. Dele não se exige a *iniciativa* de impugnar a sentença; basta que alegue em sua defesa, se assim preferir, a ineficácia.

3. Litisconsórcio necessário simples e a ineficácia da sentença apenas em relação ao litisconsorte omitido. Se simples, não unitário, o litisconsórcio, o tratamento dado pela lei é mais brando. A omissão do litisconsórcio necessário, neste caso, continua a ser um defeito que torna o seu consorte parte ilegítima para figurar no processo e, conseqüentemente, um defeito sobre o qual o juiz deve decidir mesmo de ofício “em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado” (art. 485, § 3.º). Mas este defeito não sobrevive à eficácia preclusiva da coisa julgada. O tratamento mais rigoroso que se dá à sentença defeituosa quando unitário o litisconsórcio é justificável porque, neste caso, a “conveniência da decisão simultânea”⁵⁴ exerce um papel maior do que quando se trata de litisconsórcio simples, caso em que ela deve “ceder o passo à conveniência do aproveitamento da atividade processual realizada”.⁵⁵ No litisconsórcio simples, a sentença será ineficaz *apenas* em relação ao litisconsorte omitido (inciso II),⁵⁶ de quem não se exige a *iniciativa* de impugná-la. Basta-lhe alegar em sua defesa a qualquer tempo e em qualquer processo, se precisar e assim preferir, a ineficácia. Em relação às partes do processo, no entanto, a sentença é eficaz até que venha, eventualmente, a ser reformada em grau de recurso.

Art. 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Direito anterior – art. 47 do CPC/1973.

Direito comparado – § 62 da ZPO alemã.

1. Litisconsórcio unitário e litisconsórcio simples. Litisconsórcio (cumulação subjetiva de demandas)⁵⁷ é a situação processual em que duas ou mais pessoas (litisconsortes) litigam em juízo, lado a lado,⁵⁸ como demandantes (litisconsórcio ativo) ou demandados (litisconsórcio passivo).⁵⁹ Por *demand* não se quer aludir apenas à demanda principal, mediante a qual o autor deduz sua

pretensão processual contra o réu, mas também a eventuais demandas incidentais (por exemplo, uma demanda recursal *incidental* ao processo).⁶⁰ Se ocorrerem simultaneamente os litisconsórcio ativo e passivo, diz-se se tratar de litisconsórcio misto (ou bilateral).⁶¹

O litisconsórcio será unitário se “pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes” (*caput*). Se não, será simples, caso em que o juiz *não* tem de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.⁶² Esta definição de litisconsórcio unitário, que não se confunde conceitualmente com a de litisconsórcio necessário, embora o litisconsórcio unitário frequentemente seja também necessário (mas nem sempre), ecoa a “obrigatoriedade de regulamentação homogênea da situação litigiosa”⁶³ de que falou Barbosa Moreira.⁶⁴ No litisconsórcio unitário, a decisão deve ser *única* para os litisconsortes porque *incindível* a relação jurídica de direito material controvertida.⁶⁵ Decidir uniformemente (*einheitlich*) significa, com efeito, decidir concorde e simultaneamente em relação a todos os litisconsortes (“allen gegenüber übereinstimmend und gleichzeitig”⁶⁶).⁶⁷ No litisconsórcio simples, *a contrario sensu*, o mérito da demanda pode ser decidido (mas não, obviamente, que necessariamente deva sê-lo) de modo diverso para cada um dos litisconsortes.

Se um terceiro alegadamente prejudicado pede a declaração de nulidade de um negócio jurídico (uma doação, por exemplo), o litisconsórcio passivo é unitário porque incindível a relação jurídica controvertida; o juiz não poderá decretar nulo o negócio para um dos contratantes e não para outro. Ou ele é nulo, e nulo para todos, ou não é nulo (a dimensão objetiva precede, *logicamente*, a subjetiva). Neste caso, ademais, o litisconsórcio será também necessário por força da “*natureza da relação jurídica controvertida*” (art. 114). Os litisconsortes não terão, por isso, legitimidade passiva para defender em juízo *individualmente* a posição jurídica de que são cotitulares. E isso porque ocorreria violação da garantia do litisconsorte necessário omitido ao contraditório se a relação jurídica de que ele é parte viesse a ser declarada nula sem que ele pudesse se defender eficazmente. Mas isso com a ressalva de que o litisconsórcio unitário será também necessário apenas se a parte não puder ser considerada *substituto processual* do litisconsorte omitido (legitimidade extraordinária legal ou mesmo convencional).⁶⁸

O litisconsórcio unitário pode ser também facultativo. Por exemplo, na demanda ajuizada por um dos sócios para pedir a anulação de assembleia ou na ação reivindicatória ajuizada por um dos coproprietários (litisconsórcio ativo unitário facultativo). Nestes casos, embora incindível a relação jurídica de direito material controvertida, não é obrigatória a participação do litisconsorte. Cada um deles é legitimado *individualmente* para pedir em juízo a tutela de uma posição jurídica do qual é apenas cotitular.

Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar.

Direito anterior – art. 48 do CPC/1973.

Direito comparado – § 61 da ZPO alemã e art. 29 do CPC português.

1. Litisconsortes enquanto litigantes distintos. Litisconsórcio (cumulação subjetiva de demandas)⁶⁹ é a situação processual em que duas ou mais pessoas (litisconsortes) litigam em juízo, lado a lado,⁷⁰ como demandantes (litisconsórcio ativo) ou demandados (litisconsórcio passivo).⁷¹ Por *demand* não se quer aludir apenas à demanda principal, mediante a qual o autor deduz sua pretensão processual contra o réu, mas também a eventuais demandas incidentais (por exemplo, uma demanda recursal *incidental* ao processo).⁷² Se ocorrerem simultaneamente os litisconsórcio ativo e passivo, diz-se se tratar de litisconsórcio misto (ou bilateral).⁷³

Os litisconsortes litigam lado a lado (*nebeneinander*), em qualquer de suas modalidades, sem perder em razão do litisconsórcio sua individualidade. No litisconsórcio unitário, entretanto, a proximidade entre os litisconsortes é mais intensa do que no litisconsórcio simples, o que justifica o tratamento diferenciado que dá a lei a cada um deles. A análise das diferenças existentes entre

estes regimes pressupõe a distinção entre *atos potencialmente desfavoráveis ao outro litisconsorte* (por exemplo, o reconhecimento da procedência do pedido ou a renúncia ao direito em que se funda a demanda) e *atos potencialmente benéficos ao outro litisconsorte* (por exemplo, a interposição de recurso ou a apresentação de contestação).⁷⁴⁻⁷⁵

No litisconsórcio unitário, os atos potencialmente desfavoráveis só serão eficazes (não apenas em relação ao outro litisconsorte, mas também para o próprio agente) se todos os litisconsortes consentirem. O reconhecimento da procedência do pedido por um dos réus, por exemplo, será *inteiramente* ineficaz a não ser que com ele estejam todos os litisconsortes de acordo.⁷⁶ No litisconsórcio simples, os atos potencialmente desfavoráveis só são eficazes em relação ao próprio agente, mas esta eficácia independe da anuência dos demais. No litisconsórcio unitário, os atos potencialmente favoráveis praticados por um dos litisconsortes beneficiam os demais. Se apenas um dos litisconsortes interpuser recurso de determinada decisão, por exemplo, dá-se a extensão subjetiva dos efeitos do recurso interposto ao outro (art. 1.005).⁷⁷ No litisconsórcio simples, não. Conhecido o recurso de apenas um dos litisconsortes, por exemplo, os efeitos de seu julgamento não atingem a situação jurídica do outro. Se apenas um apelar da sentença, a sentença terá transitado para o outro independentemente da sorte que tiver o julgamento o recurso.

Sobre a distribuição dos custos do processo entre os litisconsortes, confirmam-se os comentários ao art. 87. Sobre litisconsórcio e gratuidade de justiça, os comentários ao art. 99. Sobre litisconsórcio e as hipóteses em que se deve realizar audiência de conciliação ou de mediação, os comentários ao art. 334. Sobre litisconsórcio e a contagem do prazo para o protocolo de contestação, por fim, os comentários ao art. 335.

Art. 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo, e todos devem ser intimados dos respectivos atos.

Direito anterior – art. 49 do CPC/1973.

Direito comparado – § 63 da ZPO alemã.

1. Litisconsórcio e o andamento do processo. Os litisconsortes litigam lado a lado (*nebeneinander*), como se explicou nos comentários ao art. 117, sem perder em razão do litisconsórcio sua individualidade, mesmo que, no litisconsórcio unitário, a proximidade entre eles seja mais intensa do que no litisconsórcio simples. Por não se fundirem, em *hipótese alguma*, por não se tornarem nunca uma única parte, os litisconsortes deverão ser sempre *individualmente* identificados na autuação do processo e *individualmente* intimados de todos os atos processuais nele realizados. Por este motivo, “a falta de intimação de qualquer dos litisconsortes dá-lhe o direito de pedir a invalidação do ato de impulso e dos que dele derivaram”,⁷⁸ observado o disposto no art. 278, segundo o qual “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Sobre a contagem dos prazos processuais quando existir litisconsórcio, confirmam-se os comentários ao art. 229.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Mas a cumulação subjetiva é sempre acompanhada de uma cumulação objetiva, porque cada litisconsorte deduz ou contra ele é deduzido uma pretensão processual própria, ainda que idêntica a outra que é deduzida por seu litisconsorte ou contra ele. Sobre o ponto: Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 241 e Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, vol. 2, item 581.3.

2

A expressão “lado a lado” traduz o *nebeneinander* empregado por Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 240.

3

Stein; Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1059; Marco Tullio Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 293; Hazard; Leubsdorf; Bassett, *Civil Procedure*, p. 228; e Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 655.

4

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 449.

5

Sobre a questão terminológica: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 339.

6

Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 84.

7

Sobre a conveniência de classificar o litisconsórcio também em eventual, alternativo e sucessivo, confira-se Silas Silva Santos, *Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo*, p. 315. Também Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 298.

8

Fux/Fux, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas), p. 417.

9

Sobre este conceito: Renato Beneduzi, *Forum non conveniens*, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 802.

10

Para mais detalhes, confira-se o próximo item dos comentários a este artigo.

11

A preocupação em se evitarem repetições desnecessárias, em reduzir custos e em assegurar maior segurança jurídica (Hans-Jörg Schultes, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol 1, p. 453).

Francesco Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 306.

No Brasil, por exemplo: Lia Carolina Batista Cintra, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 1, p. 492.

“A divisão tripartida abrange, efetivamente, as modalidades típicas do litisconsórcio e se abona em modelo autorizado – a lei processual alemã, de 1877” (Luiz Machado Guimarães, *As três figuras do litisconsórcio*, in: *Estudos de direito processual civil*, p. 201).

Poderá haver litisconsórcio quando “entre elas [duas ou mais pessoas] houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide”.

Poderá haver litisconsórcio quando “entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir”.

Poderá haver litisconsórcio quando “ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito”.

“Haverá litisconsórcio por comunhão de direitos ou obrigações quando os demandantes ou demandados forem titulares do mesmo direito ou devedores da mesma obrigação. É o que se dá, por exemplo, quando cônjuges, casados pelo regime da comunhão universal de bens e, por isso, cotitulares da propriedade de um imóvel, o reivindicam de outrem. Existirá litisconsórcio por conexão de causas quando os litisconsortes cumulare (ou quando em face deles forem cumuladas) demandas conexas pelo objeto ou pela causa de pedir. Figure-se o seguinte exemplo: dois acionistas de uma companhia, por motivos diferentes, pretendem a anulação de uma assembleia geral de acionistas, e formulam suas demandas em um só processo (conexão pelo pedido). Por fim, haverá litisconsórcio por afinidade de questões quando duas ou mais pessoas se litisconsorciarem para ajuizar demandas cumuladas (ou quando em face delas forem ajuizadas tais demandas cumuladas) com base em um elemento de fato ou de direito que lhes seja afim (como, por exemplo, se tem na hipótese de servidores públicos que, em litisconsórcio, postulam a inclusão em suas remunerações de certa gratificação devida em função de alguma atiaidade que exercem – as chamadas gratificações pro labore faciendo – tendo por fundamento um mesmo dispositivo que prevê tal verba” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 80).

O litisconsórcio será necessário apenas “por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes” (art. 114).

21

“Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”.

22

Sobre a prorrogação abusiva da competência relativa: Renato Beneduzi, *Forum non conveniens*, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 807.

23

“Afinidade é uma conexidade degradada, ou seja, reduzida a um patamar inferior de intensidade. Nessa locução, o vocábulo questões é empregado no sentido de ponto controvertido de fato ou de direito (Carnelutti). Existe uma semelhança entre as demandas, suficiente para produzir a admissibilidade do litisconsórcio, ainda quando coincida (a) apenas um elemento abstrato das causas de pedir, que é o fundamento jurídico substancial de ambas as demandas, sendo o réu um só (dois ou mais contribuintes litigando contra o Estado por determinada vantagem tributária, todos trazendo por fundamento o mesmo dispositivo da lei material ou da Constituição) ou (b) quando somente um fato-base é alegado por duas ou mais pessoas, diferindo no mais o contexto dos fatos narrados por um ou por outro (consumidores que se dizem lesados pelo mesmo produto defeituoso, mas cada um deles tendo uma história própria que envolve a natureza do dano sofrido, sua intensidade, etc.)” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 345).

24

“O § 3.º do art. 55 do CPC vai ainda mais longe, ao consagrar a relevância da discricionariedade do juiz (forum judicial) para a determinação da reunião das demandas. E faz isso ao dispensar, pura e simplesmente, o requisito da conexão. Diz o dispositivo: ‘serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles’. Esta parte final, segundo a qual se permite a reunião ‘mesmo sem conexão’ entre os processos, significa a expressa adoção, pelo processo civil brasileiro, da teoria do *forum non conveniens*” (Renato Beneduzi, *Forum non conveniens*, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 803).

25

Sobre a diferença entre as duas espécies de *forum non conveniens*: Renato Beneduzi, *Forum non conveniens*, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 802.

26

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 142.

27

Mas a cumulação subjetiva é sempre acompanhada de uma cumulação objetiva, porque cada litisconsorte deduz ou contra ele é deduzido uma pretensão processual própria, ainda que idêntica a outra que é deduzida por seu litisconsorte ou contra ele (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 241).

28

A expressão “lado a lado” traduz o *nebeneinander* empregado por Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 240.

29

Stein; Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1059; Marco Tullio Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 293; Hazard; Leubsdorf; Bassett, *Civil Procedure*, p. 228; e Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 655.

30

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 449.

31

Sobre a questão terminológica: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 339.

32

Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 84.

33

Sobre a conveniência de classificar o litisconsórcio também em eventual, alternativo e sucessivo. Confira-se Silas Silva Santos, *Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo*, p. 315. Também Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 298.

34

Sobre a legitimidade processual, confirmam-se os comentários ao art. 70.

35

“O litisconsórcio necessário é uma projeção infraconstitucional do direito fundamental ao contraditório (art. 5.º, LV, da CF). Sua violação importa, portanto, em violação do direito ao contraditório e, por consequência, violação do direito fundamental ao processo justo (art. 5.º, LV, da CF)” (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 88).

36

AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1003278/SP, 1.^a Turma, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.12.2015, *DJe* 04.02.2016.

37

REsp 1250804/MS, 1.^a Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03.12.2015, *DJe* 26.02.2016.

38

“Por essa razão, a admissibilidade do litisconsórcio ativo confina-se no campo rigorosamente restrito das situações em que, *segundo o direito material*, cada um dos legitimados tenha o poder de opor-se aos resultados desejados pelos outros. Da legitimidade conjunta para a realização do negócio jurídico decorre a legitimidade conjunta para postular em juízo os mesmos resultados que este produziria” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 365).

39

Ferreira Mendes; Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 225.

40

“Cinge-se a controvérsia a examinar a existência de litisconsórcio necessário em demandas revisionais atinentes ao SFH e as consequências do ajuizamento de ação por somente um daqueles que figurem no contrato de mútuo na qualidade de contratante. A natureza do negócio jurídico realizado pelos mutuários e a possibilidade de modificação da relação jurídica de direito material subjacente determinam, no caso dos autos, a formação do litisconsórcio ativo necessário. O litisconsórcio ativo necessário entre os mutuários em questão é fenômeno que busca preservar a harmonização dos julgados e o princípio da segurança jurídica. Além disso, promove a economia processual, que é um dos fins a que se presta o próprio instituto em evidência, na linha do moderno processo civil que prima por resultados” (REsp 1222822/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.09.2014, *DJe* 30.09.2014).

41

Confira-se também Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 306.

42

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 361.

43

REsp 1222822/PR, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.09.2014, *DJe* 30.09.2014.

44

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 365.

45

Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 114.

46

Exatamente por este motivo disse o parágrafo único do art. 115 *minus quam voluit*.

47

O tema é objeto da clássica monografia de Moacyr Lobo da Costa, *A intervenção iussu iudicis no processo civil brasileiro*, p. 121. Na vigência do CPC, por exemplo: José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 212 e Daniel Amorim Assumpção Neves, *Manual de direito processual civil*, p. 256.

49

Não sendo assim necessária a “concordância geral” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 351.

50

Por exemplo: “O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada – seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 137).

51

Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 655.

52

Sobre a diferença entre os litisconsórcios simples e unitário, confirmam-se os comentários ao próximo artigo.

53

Para mais detalhes: José Carlos Barbosa Moreira, *Litisconsórcio unitário*, p. 232, e Leonardo Greco, *Instituições de processo civil*, vol. 1, p. 471.

54

Idem, p. 233.

55

Idem, ibidem.

56

Idem, ibidem.

57

Mas a cumulação subjetiva é sempre acompanhada de uma cumulação objetiva, porque cada litisconsorte deduz ou contra ele é deduzido uma pretensão processual própria, ainda que idêntica a outra que é deduzida por seu litisconsorte ou contra ele (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 241).

58

A expressão “lado a lado” traduz o *nebeneinander* empregado por Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 240.

59

Stein; Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1059; Marco Tullio Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 293; Hazard; Leubsdorf; Bassett, *Civil Procedure*, p. 228; e Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 655.

60

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 449.

61

Sobre a questão terminológica: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 339.

62

O litisconsórcio pode ser também classificado em independente eventual, alternativo e sucessivo, embora a lei não trate explicitamente deste problema. Sobre o ponto, confirmam-se Silas Silva Santos, *Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo*, p. 315; Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, vol. 2, item 580.5; e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 298.

63

José Carlos Barbosa Moreira, *Litisconsórcio unitário*, p. 227.

64

Para ele, “quando a situação jurídica substancial é pluri-subjetiva, isto é, abrange mais de duas posições jurídicas individuais, e a seu respeito se litiga em juízo, o resultado a que se visa no feito não pode às vezes

deixar de produzir-se a um tempo e de modo igual para todos os titulares situados do mesmo lado. Isso decorre da maneira pela qual essas posições jurídicas individuais se inserem na situação global. Semelhante inserção é uniforme e tem de manter-se uniforme sob pena de tornar impossível a subsistência da própria situação global. Daí haver entre as várias posições individuais uma vinculação tão íntima que qualquer evolução ou será homogênea ou impraticável” (José Carlos Barbosa Moreira, *ibidem*, p. 227).

65

“A exigência decorre da própria incindibilidade da relação jurídica de direito material, que exclui a possibilidade de haver duas situações jurídicas diversas a respeito do mesmo objeto, ainda que exista uma pluralidade de co-legitimados” (Guilherme Recena Costa, *Partes e terceiros na arbitragem*, p. 208).

66

Jauernig; Hess, *Zivilprozessrecht*, p. 332.

67

Para mais detalhes sobre o litisconsórcio no processo civil alemão: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 113.

68

Sobre a legitimidade processual, confirmam-se os comentários ao art. 70.

69

Mas a cumulação subjetiva é sempre acompanhada de uma cumulação objetiva, porque cada litisconsorte deduz ou contra ele é deduzido uma pretensão processual própria, ainda que idêntica a outra que é deduzida por seu litisconsorte ou contra ele (Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 241).

70

A expressão “lado a lado” traduz o *nebeneinander* empregado por Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 240.

71

Stein; Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 1059; Marco Tullio Zanzucchi, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 293; Hazard; Leubsdorf; Bassett, *Civil Procedure*, p. 228; e Adrian Zuckerman, *On civil procedure*, p. 655.

72

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 449.

Sobre a questão terminológica: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 339.

Fredie Didier Jr. chama-os, respectivamente, de *condutas determinantes* e de *condutas alternativas* (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 474).

Esta regra não vale, no entanto, para a confissão: “No tocante à confissão, é falsa a aparente restrição de sua eficácia, pretendida pelo art. 350 do Código de Processo Civil [art. 391 do CPC] ao dizer que ela ‘faz prova contra o confitente, não prejudicando todavia os litisconsortes’. Lido no contexto do sistema do Código, esse dispositivo mostra-se inócuo, porque ao juiz é dado o poder de formar livremente seu convencimento sobre fatos (art. 131) [art. 371 do CPC; sem a alusão expressa ao “livremente”, embora esta alteração não desnature o princípio do livre convencimento motivado] e não tem importância alguma a origem dos elementos de convicção em que se fundamenta; é indiferente que a prova haja sido feita por uma das partes, por outra, ou que tenha vindo ao processo de qualquer outro modo (princípio da aquisição da prova). Por isso, as conclusões a que chegar serão eficazes perante todos, sem importar se houve confissão de um, de outro ou de nenhum, até porque seria um absurdo mandar que o juiz cindisse seu julgamento em dois, reconhecendo a ocorrência de dado fato em relação a um dos litisconsortes (o confitente) e negando-o quanto aos demais. A confissão, que não passa de uma declaração de conhecimento de fatos adversos, feita por uma das partes, será apreciada pelo juiz, com eficácia para o julgamento da causa como um todo, a partir do seu poder de livremente convencimento” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 355).

Para mais detalhes: José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 5, p. 384.

Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 221.

A perspectiva norte-americana é também interessante: “Modern party-joinder practice seeks to maximize the ability of the court to meet the distinctive needs of particular controversies” (Friedenthal; Kane; Miller, *Civil procedure*, p. 334).

Em sentido contrário: José Carlos Barbosa Moreira, *Litisconsórcio unitário*, p. 232.

Sobre o ponto, detalhadamente, também Elie Pierre Eid, *Litisconsórcio unitário: fundamentos, estrutura e*

regime (dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da USP em 2016), p. 158.

© desta edição [2018]

TÍTULO III - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

1. Partes do processo (e, assim, da relação jurídica processual¹) são aquelas que pedem a tutela jurisdicional (demandante, que deduz uma pretensão processual) e, após sua citação, aquelas contra quem essa tutela é pedida (demandado, contra quem é deduzida uma pretensão processual), independentemente de quem sejam os sujeitos da relação jurídica material que possa existir, ou não, entre eles.² Parte, deste modo, é quem *efetivamente* integra a relação jurídica processual, não quem *deveria* integrá-la. Com isto se quer dizer, por exemplo, que o demandado a quem faltar legitimidade passiva não deixará de ser parte, ainda que não devesse sê-lo. Trata-se, enfim, de um conceito *processual* (ou formal) de parte, não material.³ Toda parte, assim, será um sujeito do processo (sujeito do processo é todo aquele que, no processo, pratica um ato processual – um ato destinado a produzir efeitos no processo),⁴ mas nem todo sujeito do processo será parte (por exemplo, o perito ou o juiz, porque eles não a pedem nem contra eles é pedida tutela jurisdicional).

2. Terceiro, em princípio, é aquele que não é sujeito do processo. É por isso, por exemplo, que a testemunha, terceiro estranho ao processo, deixa de ser terceiro e torna-se um de seus sujeitos ao dar em audiência seu testemunho. Mas o tornar-se sujeito do processo não faz da testemunha também parte. No que interessa ao estudo das modalidades de intervenção de terceiros, o conceito de terceiro é empregado em sentido mais restrito, sem se contrapor ao de sujeito do processo, e *“determina-se por exclusão em confronto com o de parte: é terceiro quem não seja parte, quer nunca o tenha sido, quer haja deixado de sê-lo em momento anterior...”*.⁵

3. Intervenção de terceiros, conseqüentemente, é o ingresso de um terceiro (de alguém que não é parte) em um processo pendente, voluntária ou coativamente⁶, na forma de uma de suas modalidades previstas em lei (assistência, denúncia da lide, chamamento ao processo etc.).⁷ Cabível em regra, a intervenção de terceiros é vedada, no entanto, em certos casos, a depender da natureza jurídica da controvérsia (por exemplo, se de consumo a relação jurídica litigiosa) ou do procedimento (por exemplo, no procedimento previsto na Lei dos Juizados Especiais, cujo art. 10 dispõe que *“não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”*).⁸

4. Embora também frequente a aquisição pelo interveniente da qualidade de parte (por exemplo, no chamamento ao processo ou na denúncia), não será este *sempre* o caso.⁹ O *amicus curiae*, por exemplo, torna-se sujeito do processo ao intervir, mas não parte, porque ele a rigor não deduz uma pretensão processual contra alguém nem contra ele uma pretensão processual é deduzida. A circunstância de que este terceiro pode ter interesse em que uma das partes vença torna-o *interessado*, mas não faz dele, necessariamente, parte. Ainda que cada modalidade de intervenção de terceiros, por fim, tenha sua razão de ser particular, da qual decorrem requisitos específicos de admissibilidade que serão analisados nos comentários aos próximos artigos, compartilham todas elas uma nota comum: o interesse do terceiro em intervir, ou o interesse de uma parte em que o terceiro intervenha, e a utilidade prática de seu ingresso no processo pendente. Este interesse deve, em regra, ser jurídico, mas poderá excepcionalmente ser apenas econômico.

NOTAS DE RODAPÉ

1

O Estado, por um de seus órgãos (o juízo) e apresentado por um juiz, é o terceiro sujeito da relação jurídica processual. A questão, no entanto, é controversa. Sobre o ponto: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 334. Sobre o desenvolvimento histórico do conceito de relação jurídica processual: Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 421. Também Rosenberg, Schwab, Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 10.

2

“L’idea di parte è data dunque alla lite stessa, dal rapporto processuale, dalla domanda: non occorre cercala fuori della lite e in particolare nel rapporto sostanziale che è oggetto di controversia” (Giuseppe Chiovenda, *Principii di diritto processuale civile*, p. 579).

3

A doutrina alemã prefere a expressão *formeller Parteibegriff* (conceito *formal* de parte). Por exemplo: Musielak e Voit, *Grundkurs ZPO*, p.147. Na doutrina italiana mais recente: Andrea Proto Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, p. 304.

4

“Handlungen, die auf das Verfahren einwirken, nennt man Prozesshandlungen“ (Jauernig e Hess, *Zivilprozessrecht*, p. 124). Também Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 328.

5

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 5, p. 294.

6

Mas nunca *ex officio*, i.e. sem pedido do terceiro ou da parte que pretende sua intervenção (com fundamento no princípio da demanda). Em sentido contrário, no sentido de admiti-la em algumas situações: Lia Carolina Batista Cintra, *Intervenção de terceiro por ordem do juiz*, p. 225.

7

Embora seja concebível sustentar que, mediante a celebração de negócios jurídicos processuais, possa ocorrer a “quebra da tipicidade da intervenção de terceiros” (Marília Siqueira da Costa, *Convenções processuais sobre intervenção de terceiros*, p. 239). De todo modo, nada impede “às partes pactuarem entre si, antes ou depois do processo, como exercerão ou deixarão de exercer) sua própria iniciativa (seus próprios ônus, poderes, faculdades e deveres, portanto) quanto a convocar algum terceiro para intervir no processo” (Cássio Scarpinella Bueno, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p.

528).

8

Sobre a possível especial do *amicus curiae*, confirmam-se os comentários ao art. 138.

9

Em sentido contrário, por exemplo: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 377.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

CAPÍTULO I - DA ASSISTÊNCIA

Seção I

Disposições comuns

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Direito anterior – art. 50 do CPC/1973.

Direito comparado – §66 da ZPO alemã, art. 335 do CPC português e Rule 24 das FRCP norte-americanas.

1. Assistência simples ou litisconsorcial. Na assistência, um terceiro¹ (assistente) intervém, voluntariamente, em um processo pendente, em seu próprio interesse (em regra jurídico, excepcionalmente não), com a finalidade de auxiliar uma das partes (assistido).² “O ingresso do assistente tem dupla finalidade: coadjuvar o assistido e fiscalizar a conduta das partes em juízo (para evitar conluio ou desídia)”.³ São duas as suas espécies. Na assistência litisconsorcial, assistente e adversário do assistido são (alegadamente) partes de uma mesma relação jurídica material; existe entre eles um vínculo jurídico direto. Na assistência simples, diferentemente, o vínculo jurídico existe (alegadamente) apenas entre assistente e assistido e entre assistido e seu adversário, não entre assistente e adversário do assistido (ainda que o assistente tenha interesse em que o assistido vença).⁴ Por isso o tratamento que a lei dá a cada caso, como se verá mais adiante, é diferente.

O sublocatário de um imóvel, por exemplo, tem interesse jurídico em auxiliar o locatário-sublocador que é demandado em uma ação de despejo. E isso porque sua posição jurídica depende da vitória do assistido. Mas nenhum vínculo jurídico existe entre ele e o locador originário⁵. Esta é a assistência simples. Se o credor cobra judicialmente o pagamento de uma dívida apenas do fiador, ao contrário, a intervenção voluntária do devedor principal será caso de assistência litisconsorcial, porque ele é parte de uma relação jurídica de que também é titular o credor. Existirá entre assistente e adversário do assistido um vínculo jurídico direto que não existe na assistência simples. Para mais detalhes sobre estas duas espécies, confirmam-se os comentários aos arts. 121 e 124, respectivamente.

2. Momento para o ingresso do assistente. A assistência é admissível “em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição” (parágrafo único), salvo exceção prevista em lei (como nos juizados especiais, conforme art. 10 da Lei 9.099/1995), independentemente da fase em que se encontre o processo (mesmo, por exemplo, no julgamento de recurso excepcionais). Em contrapartida, o assistente recebe “o processo no estado em que se encontre” (parágrafo único). Com isto se quer dizer que o ingresso do assistente não autoriza a repetição de atos processuais já praticados ou a realização de atos que poderiam ter sido realizados, mas não o foram oportunamente.⁶ Ao assistente, por exemplo, permite-se que requeira a produção de provas, desde que o faça tempestivamente. Mas se sua intervenção ocorrer no julgamento de recurso especial, interposto de acórdão que julga a apelação, não lhe será mais possível fazer este requerimento.⁷

Art. 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido do assistente será

deferido, salvo se for caso de rejeição liminar.

Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente, sem suspensão do processo.

Direito anterior – art. 51 do CPC/1973.

Direito comparado – §71 da ZPO alemã, art. 336 do CPC português e Rule 24 das FRCP norte-americanas.

1. Procedimento para a admissão do assistente. A assistência é uma modalidade *voluntária* de intervenção de terceiros. Daí por que o assistente intervém mediante um *requerimento* de assistência, por ele próprio formulado,⁸ que deve esclarecer a que título ele pretende intervir, se simples ou litisconsorcial a assistência, e por qual fundamento o faz.⁹ Permite-se a realização de prova para a solução do pedido de assistência, em regra documental.¹⁰ Embora possa rejeitar liminarmente o pedido de ingresso (*caput*), em caso de manifesta inadmissibilidade, convém que o juiz, antes de decidir, ouça assistido e seu adversário, dando-lhes prazo de quinze para manifestarem-se. Com ou sem impugnação, o juiz deve decidir *fundamentadamente* se admissível ou não a assistência. Deverá fazer isso sem suspender o curso do processo (parágrafo único).¹¹ Não se permite a admissão tácita, motivo pelo qual os atos do terceiro serão ineficazes até que sua intervenção venha a ser explicitamente autorizada. Deferido o ingresso, é necessário que a decisão esclareça também de que modalidade de assistência se trata.

Da decisão proferida em 1ª instância que defere ou indefere o ingresso do assistente cabe agravo de instrumento (art. 1.015, IX), exceto se ela consistir em capítulo de sentença, caso em que o recurso cabível será a apelação (art. 1.009, § 3.º). Se não recorrer desta decisão, o terceiro não poderá, em razão da preclusão, renovar em outro momento do processo (mesmo em grau de recurso) o pedido de intervenção.¹² Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, ademais, é lícito às partes convencionarem mediante negócio jurídico processual critérios outros para a admissão do assistente (art. 190).¹³

Seção II Da assistência simples

Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido.

Parágrafo único. Sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissa a parte assistida, o assistente será considerado seu substituto processual.

Direito anterior – art. 52 do CPC/1973.

Direito comparado – § 67 da ZPO alemã, art. 337 do CPC português e Rule 24 das FRCP norte-americanas.

1. Assistência simples ou litisconsorcial. Na assistência, um terceiro¹⁴ (assistente) intervém, voluntariamente, em um processo pendente, em seu próprio interesse (em regra jurídico, excepcionalmente não), com a finalidade de auxiliar uma das partes (assistido).¹⁵ “O ingresso do assistente tem dupla finalidade: coadjuvar o assistido e fiscalizar a conduta das partes em juízo (para evitar conluio ou desídia)”.¹⁶ São duas as suas espécies. Na assistência litisconsorcial, assistente e adversário do assistido são (alegadamente) partes de uma mesma relação jurídica material; existe entre eles um vínculo jurídico direto. Na assistência simples, diferentemente, o vínculo jurídico existe (alegadamente) apenas entre assistente e assistido e entre assistido e seu adversário, não entre assistente e adversário do assistido (ainda que o assistente tenha interesse em que o assistido vença).¹⁷ Por isso o tratamento que a lei dá a cada caso é diferente.

2. Assistência simples e interesse. A intervenção do assistente simples exige a demonstração de seu interesse *jurídico* (salvo excepcionalmente, como se verá mais adiante) na vitória do assistido. Haverá interesse jurídico quando alguma posição jurídica de que o assistente é titular puder ser

reflexamente atingida pela eficácia do julgamento do mérito da demanda de que partes o assistido e seu adversário.¹⁸ Será o caso do sublocatário na ação de despejo, porque seu direito ao imóvel tem por fundamento a posse do locatário-sublocador ameaçada pelo despejo, e do tabelião na demanda em que se pede a anulação de escritura por defeito de forma, porque a vitória do demandado evitaria o surgimento de eventual pretensão reparatória contra o tabelião em razão dos prejuízos causados pela desconstituição do negócio jurídico com fundamento no defeito de forma.¹⁹

Se meramente econômico, se exclusivamente moral ou ideológico o interesse do terceiro, se fundado apenas na relação de parentesco ou amizade entre ele e a parte, não se admitirá a intervenção.²⁰ A diferença entre interesse genuinamente jurídico e interesse não jurídico revela-se, no entanto, frequentemente movediça ou mesmo arbitrária; não raro, a distinção deve-se mais a uma opção por restringir ou ampliar o cabimento da assistência em determinados casos do que, propriamente, à análise da natureza *em si* do interesse do terceiro. Pense-se na hipótese de um credor, quando seu devedor é demandado por outro credor. A potencial redução patrimonial do devedor não deixa de ter para ele também uma dimensão *jurídica* (risco de insolvência). Mas este interesse deve autorizar a intervenção, ou seria ele demasiadamente tênue? Compensaria os inconvenientes decorrentes, como o tumulto processual que o ingresso de um sem número de potenciais credores inevitavelmente causaria, ou não?

Não é possível qualificar o interesse do terceiro sem considerar ao mesmo tempo, enfim, a utilidade prática da intervenção (ou sua inconveniência). Não sua utilidade prática *em tese*, se se permite o oximoro, mas sim sua utilidade prática naquele determinado caso concreto. O pragmatismo americano, neste aspecto, oferece uma solução menos artificial do que o conceptualismo alemão, ao confessar a impossibilidade de uma definição geral e *a priori* de qual interesse deve ser considerado apto a justificar o ingresso do assistente:²¹ “*Yet no universal catalogue of acceptable interests is possible. The interests that should count depend in part of what the action is about*”.²² O prejuízo potencial a que o terceiro está exposto, em síntese, compensa os inconvenientes procedimentais que de sua intervenção decorreriam, ou não?²³ Se compensar, justifica-se a intervenção.

O art. 5.º da Lei 9.469/1997 estabelece uma exceção à regra de que o interesse, na assistência, deve ser sempre jurídico. Segundo o *caput* deste dispositivo, com efeito, “*a União poderá intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais*”. Como esclarece o parágrafo único, “*as pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes*”. Este caso particular de intervenção, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chama de *anódina* ou *anômala*,²⁴ evoca o *statutory right of intervention* americano de que trata a Rule 24(a) das Federal Rules of Civil Procedure.²⁵ Permite-se a intervenção, a rigor, independentemente da demonstração de qualquer interesse. Basta que o assistente *queira* fazê-lo. Daí por que não é preciso falar-se que o fundamento desta espécie anômala de intervenção é o interesse econômico do Poder Público. Em verdade, o fundamento é apenas a sua *vontade* de intervir.

3. Posição jurídica do assistente simples. Seu interesse na vitória do assistido não transforma o terceiro, que intervém na qualidade de assistente, em parte. E isso porque ele, embora sujeito interessado, ou parcial, do processo, não demanda contra alguém nem contra ele se demanda. Admitida a assistência, o terceiro torna-se *assistente* de uma parte, não parte.²⁶ Ele defende em juízo um *interesse próprio*, ainda que mediatamente, e é por isso que a lei lhe reconhece certos poderes processuais dos quais se falarão nos comentários ao art. 122.²⁷

Porque apenas coadjuvante do assistido, não se permite ao assistente agir contra a sua vontade *expressa*. Se o assistido renunciar ao direito de recorrer de determinada decisão, por exemplo, nada há que o assistente possa fazer. Vincula-se também o assistente aos negócios jurídicos

processuais celebrados pelo assistido. Em caso de omissão do assistido, diferentemente, a lei reconhece ao assistente legitimidade (extraordinária) para agir em seu nome.²⁸ Daí, segundo o parágrafo único, por que “*sendo revel ou, de qualquer outro modo, omissa o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual*”. Se o assistido deixar de pedir tempestivamente a realização de uma perícia, por exemplo, o assistente poderá fazê-lo em seu lugar. A manifestação de vontade do assistente não será eficaz, no entanto, se de natureza negocial a omissão do assistido.²⁹ Por exemplo, no caso de prorrogação da competência relativa (o juízo originariamente incompetente torna-se competente em razão da omissão do demandado em alegar tempestivamente a incompetência relativa – art. 65). Mas não na não interposição de recurso pelo assistido. Nesta hipótese, a sua omissão não tem natureza negocial e, portanto, não pode ser equiparada à vontade expressa de não recorrer.³⁰

Art. 122. A assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

Direito anterior – art. 53 do CPC/1973.

Direito comparado – § 67 da ZPO alemã, art. 340 do CPC português e Rule 24 das FRCP norte-americanas.

1. Poderes do assistente simples. Admitida a assistência, o terceiro torna-se *assistente* de uma parte, não parte. Ele defende em juízo um *interesse próprio*, ainda que mediatamente, e é por isso que a lei lhe reconhece o exercício no processo dos “*mesmos poderes*” que o assistido (art. 121). A expressão “*mesmos poderes*” deve ser interpretada extensivamente, observadas apenas as ressalvas explicadas no item seguinte, para incluir o direito de ser intimado a falar nos autos eficaz e oportunamente sempre que o assistido também o for, o de requerer a produção de provas (o próprio assistente, aliás, pode ser ouvido na qualidade de testemunha, não interrogado, porque ele, embora interessado, não é parte), o de suscitar incidentes (por exemplo, a arguição de impedimento ou de suspensão) e o de interpor recursos.³¹ Por isso será nula, por violar o contraditório, a decisão proferida sem a intimação prévia do assistente, mesmo que o assistido o tenha sido regularmente (salvo nas hipóteses, naturalmente, em que se dispensa a oitiva prévia da própria parte assistida; por exemplo, no deferimento de tutela antecipada).

Ao assistente impõem-se também os “*mesmos ônus*” que ao assistido (art. 121), entre eles, por exemplo, o de adiantar custas (sobre a distribuição dos ônus do processo entre assistente e assistido, confirmam-se os comentários ao art. 94) e o de ter de recorrer tempestivamente, sob pena de preclusão. Lembre-se, com efeito, que o assistente recebe o *processo no estado em ele que se encontra*, motivo pelo qual seu ingresso não autoriza a repetição de atos processuais já praticados ou a realização de atos que poderiam ter sido realizados, mas não o foram oportunamente, como se explicou nos comentários ao art. 119.

2. Limites dos poderes do assistente simples. Porque apenas coadjuvante do assistido, não se permite ao assistente agir contra a sua vontade expressa, como se explicou nos comentários ao art. 121. Se o assistido renunciar ao direito de recorrer de determinada decisão, por exemplo, nada há que o assistente possa fazer. Vincula-se também o assistente aos negócios jurídicos processuais celebrados pelo assistido. Em caso de omissão do assistido, diferentemente, a lei reconhece ao assistente legitimidade (extraordinária) para agir em seu nome, como também se explicou nos comentários ao art. 121, com a ressalva de que a manifestação de vontade do assistente não será eficaz se de natureza negocial a omissão.³² Por exemplo, no caso de prorrogação da competência relativa (o juízo originariamente incompetente torna-se competente em razão da omissão do demandado em alegar tempestivamente a incompetência relativa – art. 65). Mas não na não interposição de recurso pelo assistido. Nesta hipótese, a omissão não tem natureza negocial e, portanto, não pode ser equiparada à vontade expressa de não recorrer.³³

O assistente não terá nunca legitimidade, no entanto, para resistir à prática pelo assistido de algum ato dispositivo (reconhecimento da procedência do pedido, desistência da demanda, transação etc.)³⁴ ou para dispor em nome dele, mesmo se omissa o assistido, sobre o *mérito* da

demanda.³⁵ Por isso dispõe o *caput* que “a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”. Este dispositivo deve ser interpretado, com efeito, de dois ângulos diversos: ele não apenas permite ao assistido a prática de atos dispositivos independentemente da vontade do assistente, até mesmo contra ela, mas também proíbe o assistente de praticá-los ainda que no silêncio do assistido. E isso porque a titularidade da relação jurídica material litigiosa é do assistido, não do assistente. Esta regra não proíbe o assistente, obviamente, de dispor no processo sobre *os seus próprios direitos* (por exemplo, mediante transação); só não lhe permite dispor sobre *direito alheio*. Sobre os poderes do assistente litisconsorcial, confirmam-se os comentários ao art. 124.

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que:

I – pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença;

II – desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.

Direito anterior – art. 55 do CPC/1973.

Direito comparado – §68 da ZPO alemã, art. 341 do CPC português e Rule 24 das FRCP norte-americanas.

1. Justiça da decisão. Com o trânsito em julgado da sentença proferida entre assistido e seu adversário, vincula-se o assistente à *justiça da decisão*, conceito este tradicionalmente associado pela doutrina brasileira à *Interventionswirkung* do processo alemão (eficácia da intervenção).³⁶ Esta a opinião dominante na vigência do CPC/1973. A maneira radicalmente nova com que o CPC trata os limites objetivos da coisa julgada permite, no entanto, que se enfrente a questão da natureza da vinculação do assistente de um outro ângulo.³⁷ A justiça da decisão deve ser entendida, com efeito, como a extensão autorizada pela lei a um terceiro (o assistente, simples ou litisconsorcial), *pro et contra*,³⁸ da coisa julgada material formada no processo entre assistido e seu adversário em que ele interveio.³⁹ Para tanto se exige apenas, como se explicará melhor no próximo item, o exercício efetivo do contraditório pelo assistente.

A extensão não é a rigor a da imutabilidade do dispositivo da decisão que julga o mérito, porque o assistente não é parte da demanda, mas sim a da solução dada pelo juiz no processo a algumas questões nele expressamente decididas (art. 503). Não a todas, com efeito, mas somente àquelas que digam respeito à “*existência, [à] inexistência ou [ao] modo de ser de uma relação jurídica*” (art. 19, I)⁴⁰ e ainda à “*autenticidade ou [à] falsidade de documento*” (art. 19, II).⁴¹ Àquelas, em outras palavras, que poderiam ser objeto de um pedido declaratório, mas que tenham sido decididas incidentalmente, e também àquelas, objeto de pedido declaratório, que tenham sido decididas em caráter principal. Isso com a ressalva de que esta imutabilidade não atinge “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” (art. 504, I), a “*verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença*” (art. 504, II) nem tampouco a *ratio decidendi*, porque ela “*não é questão prejudicial – a ratio é a tese jurídica que sustenta a decisão; como tese jurídica, não poderia se tornar indiscutível pela coisa julgada*”.⁴²

Será o caso do sublocatário na ação de despejo, que não poderá debater futuramente, por exemplo, a questão do inadimplemento do locatário-sublocador (se culposos ou não) a justificar o seu despejo. Ou do tabelião que intervém em favor do demandado contra quem se pede a anulação de escritura por defeito de forma; reconhecido o defeito neste primeiro processo, vincula-se o tabelião à solução dada à questão da existência ou não do defeito em um eventual processo futuro contra o assistido. A eles se estende, em outras palavras, a coisa julgada material incidente sobre estas questões decididas no processo entre assistido e seu adversário.

2. Exceções à regra da extensão da coisa julgada ao assistente. Ao permitir a extensão da coisa

julgada material a um terceiro, o art. 123 excepciona assim a regra geral expressa no art. 506, segundo o qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. E isso porque, se participou ativamente do processo em auxílio de uma das partes, é razoável que o assistente se vincule ao seu resultado. O fundamento da extensão subjetiva da coisa julgada material ao assistente é justamente o exercício efetivo do contraditório pelo assistente. É exatamente por este motivo que a lei excepciona dois casos em que esta extensão da coisa julgada material *contra o assistente* (e apenas contra o assistente, nunca contra o assistido) não ocorre (casos em que comprometido o exercício, pelo assistente, do contraditório): se o assistente provar que, “pelo estado em que recebeu o processo⁴³ ou pelas declarações e pelos atos do assistido⁴⁴, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença⁴⁵” (inc. I) ou ainda que “desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu” (inc. II).⁴⁶

Seção III Da assistência litisconsorcial

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

Direito anterior – art. 54 do CPC/1973.

Direito comparado – § 69 da ZPO alemã, art. 320 do CPC português e Rule 24 das FRCP norte-americanas.

1. Assistência simples ou litisconsorcial. Na assistência, um terceiro⁴⁷ (assistente) intervém, voluntariamente, em um processo pendente, em seu próprio interesse (em regra jurídico, excepcionalmente não), com a finalidade de auxiliar uma das partes (assistido).⁴⁸ “O ingresso do assistente tem dupla finalidade: coadjuvar o assistido e fiscalizar a conduta das partes em juízo (para evitar conluio ou desídia)”.⁴⁹ São duas as suas espécies. Na assistência litisconsorcial, assistente e adversário do assistido são (alegadamente) partes de uma mesma relação jurídica material; existe entre eles um vínculo jurídico direto. Na assistência simples, diferentemente, o vínculo jurídico existe (alegadamente) apenas entre assistente e assistido e entre assistido e seu adversário, não entre assistente e adversário do assistido (ainda que o assistente tenha interesse em que o assistido vença).⁵⁰ Por isso o tratamento que a lei dá a cada caso é diferente.

2. Posição e poderes do assistente litisconsorcial. O assistente litisconsorcial não é um *litisconsorte* assistente, mas um *assistente* litisconsorcial. O substantivo *assistente* predomina sobre o adjetivo *litisconsorcial*, porque a assistência litisconsorcial é uma das duas espécies de assistência, não uma modalidade de litisconsórcio.⁵¹ Contra ele nada a rigor se pede, e ele a rigor nada pede. Sua função continua a ser a de *coadjuvar* uma das partes, sem com isso deixar de ser um terceiro. Sua maior proximidade em relação à *res in iudicio deducta* faz apenas com que a lei lhe confira *maiores poderes* do que aqueles que reconhece ao assistente simples. O assistente litisconsorcial, assim, como o assistente simples, “exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido” (art. 121), mas sem a restrição imposta ao assistente simples de que ele não pode contrariar a vontade expressa do assistido (art. 122).⁵²

Embora não seja verdadeiramente um litisconsorte, o assistente litisconsorcial é tratado em certos aspectos de sua atuação no processo como se o fosse; mais precisamente, como se se tratasse de um litisconsórcio unitário. É neste sentido que se deve interpretar a expressão “considera-se litisconsorte” utilizada pela lei. É exatamente este motivo, da mesma maneira como se explicou nos comentários ao art. 117, que os atos potencialmente desfavoráveis praticados pelo assistente ou pelo assistido só serão eficazes (não apenas em relação ao outro, mas também para o próprio agente) se o outro consentir. O reconhecimento da procedência do pedido por um deles, por exemplo, será *inteiramente* ineficaz a não ser que com ele estejam todos de acordo.⁵³ Este o motivo por que não se aplica na relação entre assistente litisconsorcial e assistido o disposto no art. 122, segundo o qual “a assistência simples não obsta a que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”. A regra é exatamente aquela aplicável entre litisconsortes unitários, porque, neste

aspecto, o assistente é tratado como se litisconsorte fosse. Já os atos potencialmente favoráveis praticados por um, diferentemente, também como no litisconsórcio unitário, beneficiam o outro. Se apenas um deles interpuser recurso de determinada decisão, por exemplo, dá-se a extensão subjetiva dos efeitos do recurso interposto ao outro (art. 1.005).⁵⁴ O assistente litisconsorcial vincula-se também à justiça da decisão, do mesmo modo como explicado nos comentários ao art. 123. Embora não tenha sido parte da demanda, a extensão ao assistente litisconsorcial da coisa julgada material (justiça da decisão) permite assim que ele execute, em nome próprio, a decisão que constitui o título executivo judicial e que contra ele a decisão seja executada, a depender do polo da demanda em que figurou seu assistido. Reconhece-se a um dos coproprietários, por exemplo, que intervém na qualidade de assistência litisconsorcial em demanda reivindicatória ajuizada pelo outro, legitimidade para executar a sentença em seu próprio nome. Da mesma forma, agora do lado passivo, permite-se ao credor executar a sentença condenatória contra o devedor solidário que interveio na qualidade de assistente litisconsorcial do outro, mesmo que contra ele o credor comum não tenha também demandado.

3. Casos de assistência litisconsorcial. O assistente litisconsorcial, ao intervir, pode afirmar-se *titular* da relação jurídica material controversa; fará isso quando o assistido tiver legitimidade processual extraordinária para, na qualidade de substituto processual, pedir a tutela de um direito de que ele, o assistente substituído, é o titular.⁵⁵ E isso ao fundamento de que, conforme reconhece expressamente o parágrafo único do art. 18, “*havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial*”. É a este título, por exemplo, que intervém o adquirente da coisa litigiosa em assistência do alienante legitimado extraordinário, após a alienação, para conduzir o processo em seu próprio nome.⁵⁶ O assistente litisconsorcial pode também afirmar-se *cotitular* da relação jurídica material controversa; fará isso, por exemplo, ao intervir na demanda ajuizada por um dos sócios para pedir a anulação de assembleia ou na ação reivindicatória ajuizada por um dos coproprietários com o objetivo de lhes coadjuvar. O assistente litisconsorcial, por fim, poder ser apenas um colegitimado extraordinário para pedir a tutela do direito controvertido, sem ser nem seu titular nem cotitular dele. É o que acontece, como exemplifica Fredie Didier Jr., “*na intervenção de um legitimado à tutela coletiva, em processo proposto por outro legitimado*”.⁵⁷

4. Intervenção litisconsorcial voluntária. A assistência litisconsorcial não deve ser confundida, no entanto, com a intervenção litisconsorcial voluntária. Polêmica embora, e mesmo sem expressa previsão legal que a regule, “*a figura não deve ser descartada aprioristicamente, cabendo ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, admiti-la ou não*”.⁵⁸ Trata-se de demanda deduzida incidentalmente pelo interveniente, na fase de conhecimento de processo pendente, contra o mesmo réu, quando conexas as demandas (a originária e a ulterior). Neste caso, o novo demandante “*assumirá a condição de parte principal, dando origem a um litisconsórcio ativo (ulterior) ou ampliando o que já existia*”,⁵⁹ diferentemente do que ocorre na assistência litisconsorcial, porque o interveniente *torna-se* litisconsorte, não assistente de uma parte, ao deduzir contra o mesmo réu uma demanda *própria*. Não é por outro motivo que, segundo dispõe o art. 286, II, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza “*quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada*”. O juiz deve permitir a distribuição por dependência da demanda incidental desde que não abusiva ou processualmente inconveniente (*forum non conveniens*).⁶⁰ -⁶¹ Como resume Luiso, “*la funzione del litisconsorzio facoltativo* [e a intervenção litisconsorcial voluntária dá origem, exatamente, a um litisconsórcio, ainda que ulterior] *è duplice: di economia processuale, anzitutto; e poi di armonizzazione delle decisioni*”.⁶² -⁶³ Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 113.

Sobre o conceito de terceiro, confirmam-se as notas introdutórias a este título.

2

„Nebenintervention ist die Beteiligung eines Dritten an der Führung eines fremden Rechtsstreits im eigenen Interesse zur Unterstützung einer partei, der sogenannten Hauptpartei“ (Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 252); “Intervention means essentially what the term implies in ordinary language – a procedure by which one who was not originally a party to an action can enter into litigation commenced between others. By doing so, interveners can protect their interests against the possible adverse effect of a judgment” (Hazard, Leubsdorf e Bassett, *Civil Procedure*, p. 296).

3

Guilherme Recena Costa, *Partes e terceiros na arbitragem* (tese de doutorado apresentada à Faculdade de Direito da USP em 2016), p. 198.

4

A assistência não se confunde ainda com a intervenção do *amicus curiae*, como se verá mais adiante.

5

Arruda Alvim, *Manual de direito processual civil*, p. 483.

6

“Decorre a regra do princípio que o processo deve andar para a frente, não se justificando recuo para atender a interesse de terceiro. A adoção de regra diferente levaria a verdadeiro tumulto no processo, especialmente quando este já estiver em fase adiantada” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 222).

7

“O assistente recebe o processo no estado em que se encontra, razão pela qual não pode praticar atos em relação aos quais já se operou a preclusão” (AgRg no REsp 1265322/AM, 3.^a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.02.2015, *DJe* 19.02.2015). Daí, conseqüentemente, por que “manifestamente intempestivo o recurso interposto [pelo assistente retardatário] após o trânsito em julgado do processo” (AgRg no REsp 928.980/PE, 4.^a Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05.10.2010, *DJe* 03.11.2010).

8

Este requerimento não é nunca iniciativa de uma das partes.

9

Sobre o conceito de interesse, no que interessa à admissão da assistência, confirmam-se os comentários ao art. 121.

10

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 223.

11

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 148.

12

Arruda Alvim Wambier, Lins Conceição, Silva Ribeiro, Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 217.

13

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 489.

14

Sobre o conceito de terceiro, confirmam-se as notas introdutórias a este título.

15

„Nebenintervention ist die Beteiligung eines Dritten an der Führung eines fremden Rechtsstreits im eigenen Interesse zur Unterstützung einer partei, der sogenannten Hauptpartei“ (Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 252); “Intervention means essentially what the term implies in ordinary language – a procedure by which one who was not originally a party to an action can enter into litigation commenced between others. By doing so, interveners can protect their interests against the possible adverse effect of a judgment” (Hazard, Leubsdorf e Bassett, *Civil Procedure*, p. 296).

16

Guilherme Recena Costa, *Partes e terceiros na arbitragem*, p. 198.

17

A assistência não se confunde ainda com a intervenção do *amicus curiae*, como se verá mais adiante.

18

Quando a posição jurídica de que o assistente é titular puder ser *diretamente* atingida pela eficácia do julgamento, tratar-se-á de assistência litisconsorcial.

19

Guilherme Recena Costa, *Partes e terceiros na arbitragem*, p. 199.

“A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples é necessária a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo” (AgRg no AREsp 392.006/PR, 2.^a Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 05.11.2013, *DJe* 12.11.2013).

Confira-se, por exemplo, a dificuldade com que o BGH define interesse jurídico em termos abstratos, no que interessa à assistência: “Der Begriff des rechtlichen Interesses in § 66 Abs. 1 ZPO ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs weit auszulegen (vgl. BGH, Beschlüsse vom 10. Februar 2011 I ZB 63/09, NJW-RR 2011, 907 Rn. 10; vom 17. Januar 2006 X ZR 236/01, BGHZ 166, 18 Rn. 7). Aus dem Erfordernis eines rechtlichen Interesses folgt jedoch, dass ein rein wirtschaftliches oder tatsächliches Interesse für die Zulässigkeit einer Nebenintervention nicht ausreicht. Es ist erforderlich, dass der Nebenintervenient zu der unterstützten Partei oder zu dem Gegenstand des Rechtsstreits in einem Rechtsverhältnis steht, auf das die Entscheidung des Rechtsstreits durch ihren Inhalt oder ihre Vollstreckung unmittelbar oder auch nur mittelbar rechtlich einwirkt (BGH, Beschlüsse vom 10. Februar 2011 I ZB 63/09, NJW-RR 2011, 907 Rn. 10; vom 24. April 2006 II ZB 16/05, WM 2006, 1252 Rn. 8; vom 17. Januar 2006 X ZR 236/01, BGHZ 166, 18 Rn. 7). Der bloße Wunsch eines Nebenintervenienten, der Rechtsstreit möge zugunsten einer Partei entschieden werden, und die Erwartung, dass die damit befassten Gerichte auch in einem künftigen eigenen Rechtsstreit mit einer Partei an einem einmal eingenommenen Standpunkt festhalten und zu einer ihm günstigen Entscheidung gelangen, stellen lediglich Umstände dar, die ein tatsächliches Interesse am Obsiegen einer Partei zu erklären vermögen. Das genügt ebenso wenig wie der denkbare Umstand, dass in beiden Fällen dieselben Ermittlungen angestellt werden müssen oder über gleichgelagerte Rechtsfragen zu entscheiden ist (BGH, Beschlüsse vom 10. Februar 2011 I ZB 63/09, aaO; vom 24. April 2006 II ZB 16/05, aaO Rn. 12)” (BGH, Beschluss vom 18. November 2015 VI ZB 2/15).

Hazard, Leubsdorf e Bassett, *Civil Procedure*, p. 298.

Como bem observa Celso Agrícola Barbi, a assistência é “fator de aumento de despesas e trabalhos, com consequente acréscimo de tempo para o término do processo” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 223).

“Conquanto seja tolerável a intervenção anódina da União plasmada no art. 5.^o da Lei 9.469/1997, tal circunstância não tem o condão de deslocar a competência para a Justiça Federal, o que só ocorre no caso de demonstração de legítimo interesse jurídico na causa, nos termos dos arts. 50 e 54 do CPC/1973. A interpretação é consentânea com toda a sistemática processual, uma vez que, além de não haver previsão legislativa de deslocamento de competência mediante a simples intervenção “anômala” da União, tal

providência privilegia a fixação do processo no seu foro natural, preservando-se a especial motivação da intervenção, qual seja, “esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria” (REsp 1097759/BA, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2009, DJe 01.06.2009).

25

“Intervention as of right is available in the circumstances defined in Rule 24(a) and when a statute confers that right (...). The most important example of a statutory right of intervention is that authorizing the United States to intervene when the constitutionality of an act of Congress is challenged” (Hazard, Leubsdorf e Bassett, *Civil Procedure*, p. 297).

26

O terceiro não se torna parte, nem tampouco *parte acessória*, conceito “vago, impreciso, destituído de significação” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 225). Daí por que “o assistente simples, mesmo depois de admitido a ingressar no processo, não perde a condição de terceiro em face das partes e do litígio. O assistente simples será sempre terceiro em relação ao litígio a ser decidido, uma vez que não é titular da relação jurídica de direito material posta em juízo” (Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 94)

27

„Die allgemeine Rechtsstellung des Nebenintervenienten ist dadurch gekennzeichnet, dass er sich an einem fremden Prozess beteiligt und dort weder Partei noch gesetzlicher Vertreter, sondern Dritter ist. Er wird zum Streithelfer der Partei kraft eigenen Rechts und hat als solcher Anspruch auf rechtliches Gehör“ (Hans-Jörg Schultes, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol 1, p. 453).

28

Lembre-se, como se viu nos comentários ao art. 70, que a legitimidade processual é o direito de conduzir em nome próprio, como demandante ou demandado, um determinado e concreto processo (*Prozessführungsbefugnis*). Em regra, a titularidade deste direito será daquele que alega ser também o titular do direito cuja tutela se pede (legitimidade ordinária); em outros casos, excepcionais, não (legitimidade extraordinária). Embora toda pessoa tenha o direito de pedir em juízo a tutela de um direito que alega ser seu (legitimidade ordinária), apenas aquele a quem a lei ou o próprio titular do alegado direito lhe dá o poder de pedir sua tutela poderá fazê-lo (legitimidade extraordinária).

29

“As condutas omissivas do assistido a que se refere o parágrafo único do art. 121 do CPC pertencem à mesma natureza da revelia (não por acaso a única conduta expressamente mencionada, exatamente para indicar a natureza das demais): são atos-fatos processuais. O trecho ‘de qualquer outro modo, omisso o assistido’ deve ser compreendido como referente a uma omissão não-negocial, omissão como ato-fato processual, à semelhança da revelia. Omissões negociais do assistido estão fora do âmbito de incidência desse parágrafo único. Como negócios processuais dispositivos, subsumem-se, por analogia, à norma extraída do art. 122 do CPC, que vincula o assistente simples à vontade do assistido. Em suma: o assistente

não pode suprir a omissão do assistido se ela for uma omissão negocial” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 492). Sobre este tema, também Leonardo Carneiro da Cunha, A assistência no novo CPC, *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 1088.

30

Neste sentido: “Segundo o entendimento mais condizente com o instituto da assistência simples, a legitimidade para recorrer do assistente não esbarra na inexistência de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual. Assim, in casu, em atendimento à melhor interpretação do dispositivo da norma processual, uma vez constatada a ausência da vontade contrária do assistido, afigura-se cabível o recurso da parte assistente, a qual detém legitimidade para a continuidade da relação processual” (EREsp 1068391/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 29.08.2012, *DJe* 07.08.2013).

31

Mesmo quando o assistido não o interpuser, mas desde que ele não tenha manifestado expressamente a vontade de não recorrer. Neste sentido: “Segundo o entendimento mais condizente com o instituto da assistência simples, a legitimidade para recorrer do assistente não esbarra na inexistência de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual. Assim, in casu, em atendimento à melhor interpretação do dispositivo da norma processual, uma vez constatada a ausência da vontade contrária do assistido, afigura-se cabível o recurso da parte assistente, a qual detém legitimidade para a continuidade da relação processual” (EREsp 1068391/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 29.08.2012, *DJe* 07.08.2013).

32

“As condutas omissivas do assistido a que se refere o parágrafo único do art. 121 do CPC pertencem à mesma natureza da revelia (não por acaso a única conduta expressamente mencionada, exatamente para indicar a natureza das demais): são atos-fatos processuais. O trecho ‘de qualquer outro modo, omisso o assistido’ deve ser compreendido como referente a uma omissão não-negocial, omissão como ato-fato processual, à semelhança da revelia. Omissões negociais do assistido estão fora do âmbito de incidência desse parágrafo único. Como negócios processuais dispositivos, subsumem-se, por analogia, à norma extraída do art. 122 do CPC, que vincula o assistente simples à vontade do assistido. Em suma: o assistente não pode suprir a omissão do assistido se ela for uma omissão negocial” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 492).

33

Neste sentido: “Segundo o entendimento mais condizente com o instituto da assistência simples, a legitimidade para recorrer do assistente não esbarra na inexistência de proposição recursal da parte assistida, mas na vontade contrária e expressa dessa no tocante ao direito de permitir a continuidade da relação processual. Assim, in casu, em atendimento à melhor interpretação do dispositivo da norma processual, uma vez constatada a ausência da vontade contrária do assistido, afigura-se cabível o recurso da parte assistente, a qual detém legitimidade para a continuidade da relação processual” (EREsp

34

O ato dispositivo pode ter por objeto o mérito da demanda, como na renúncia ao direito em que ela se funda, ou dizer respeito apenas à própria demanda enquanto ato mediante o qual o demandante pede ao Estado tutela jurídica, como na desistência.

35

Luiz Fux, *Intervenção de terceiros*, p. 12.

36

Por exemplo: “Esta vinculação recebe o nome de eficácia da intervenção (*Interventionswirkung*) e conceitualmente não se confunde com a coisa julgada. Esta incide exclusivamente sobre a parte decisória da sentença, em que o juiz diz sim ou não ao pedido do autor, e não aos fundamentos pelos quais ele chega a tais conclusões (art. 469). De todo modo, o terceiro que interveio como assistente fica vinculado aos fundamentos da sentença e aos reflexos que eles projetam sobre seus direitos ou obrigações. Se o sujeito não quer correr o risco dessa vinculação, melhor não intervir” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 397).

37

Embora sem desenvolvê-la mais detalhadamente, esta possibilidade é também considerada por Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 151.

38

Para beneficiar ou para prejudicar o assistente, deste modo, diferentemente do que acontece no processo civil alemão, em que a eficácia da intervenção, que não se confunde com a coisa julgada, serve apenas *contra* o interveniente, nunca em seu favor: „nur zu Lasten, nicht aber auch zu Gunsten des Intervenienten“ (Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 259).

39

E esta coisa julgada não vincula apenas assistente e assistido *entre si*, mas também assistente e adversário do assistido, também diferentemente do que ocorre no processo alemão: „Die Wirkung ergriff nur das Verhältnis der Hauptpartei zum Nebenintervenienten; sie tritt dagegen nicht im Verhältnis des Nebenintervenienten oder der Hauptpartei zum Gegner...“ (Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 260).

40

“A nosso ver, somente as relações jurídicas (e.g. paternidade, propriedade, compra e venda) e algumas questões de direito – relacionadas à existência, validade ou eficácia (v.g., validade de um contrato) ou ao

enquadramento/qualificação jurídica da relação (e.g. enquadramento jurídico de um convívio como união estável)” (Bruno Garcia Redondo, Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa julgada no novo CPC, *Revista de Processo*, vol. 248, p. 50).

41

Para mais detalhes: Teresa Arruda Alvim Wambier, O que é abrangido pela coisa julgada no direito processual civil brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de mudança, *Revista de Processo*, vol. 230, p. 75.

42

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 548.

43

Em momento no qual a postulação da prova já não era mais admissível.

44

“São alegações ou atos praticados pelo assistido que poderão impedir o assistente de postular prova contrária, por exemplo a confissão, o reconhecimento do pedido, a transação, a admissão do fato em que se funda a demanda, como se o assistido, sendo demandado, admitisse como verdadeiros os fundamentos da ação, limitando-se a oferecer reconvenção” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 302).

45

Este dispositivo exige do assistente “que a prova cuja produção lhe fora impossível seja suscetível de influir na sentença. O pressuposto tem, sem dúvida, uma considerável carga de subjetividade, porquanto casos haverá em que o tribunal poderá recusar a defesa oposta pelo assistente – réu na segunda ação – sob a consideração de que, no conjunto de provas que serviram de fundamento para a sentença, não se poderá dizer que aquela não produzida seria capaz de influir no raciocínio lógico do julgado, a ponto de mudar o sentido da sentença” (Hélio Tornaghi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 303).

46

“Os motivos do item II são mais amplos porque abrangem alegações e provas, e não somente provas, como no item I. São necessários dois requisitos: a) que o assistente desconhecesse a existência de alegações, ou provas; b) que o assistido não tenha se valido desses elementos por dolo ou culpa. A expressão ‘alegações’ refere-se a fatos jurídicos, e não a normas legais ou assentadas pela jurisprudência, porque, em relação às regras de direito, tem lugar o princípio *jura novit cúria*. Note-se, ainda, que não basta a falta destas alegações ou provas; é necessário que elas fossem suscetíveis de influir na sentença, como também no caso do item I. Caberá ao assistente demonstrar a importância que esses elementos poderiam ter na sentença” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 232).

Sobre o conceito de terceiro, confirmam-se as notas introdutórias a este título.

“Nebenintervention ist die Beteiligung eines Dritten an der Führung eines fremden Rechtsstreits im eigenen Interesse zur Unterstützung einer partei, der sogenannten Hauptpartei“ (Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 252); “Intervention means essentially what the term implies in ordinary language – a procedure by which one who was not originally a party to an action can enter into litigation commenced between others. By doing so, interveners can protect their interests against the possible adverse effect of a judgment” (Hazard, Leubsdorf e Bassett, *Civil Procedure*, p. 296).

Guilherme Recena Costa, *Partes e terceiros na arbitragem*, p. 198.

A assistência não se confunde ainda com a intervenção do *amicus curiae*, como se verá mais adiante.

“A má redação de dispositivos do Código de Processo Civil [esta má redação se repete no CPC] dá a entender que o assistente litisconsorcial não seja um assistente e sim um litisconsorte, mas essa ideia é inteiramente falsa. A locução *considera-se litisconsorte*, contida no art. 54 [atual 124], significa somente que as possibilidades de atuação desse assistente serão tantas quantas as de uma parte principal, ou seja, tantas quanto as de um litisconsorte. Esse dispositivo tem somente o efeito de definir o tratamento destinado ao interveniente nos casos em que a assistência é qualificada por uma proximidade maior entre sua própria situação jurídica e a pretensão que o autor trouxera para julgamento. O assistente litisconsorcial, tanto quanto o simples, não traz ao processo demanda alguma a ser julgada, nem em face dele foi proposta qualquer demanda a ser julgada na sentença de mérito. A procedência da demanda inicial não lhe atribuirá bem algum nem ele sofrerá uma condenação ou alteração em alguma situação jurídico-substancial. Em suma, prepondera o substantivo assistência sobre o adjetivo litisconsorcial e o assistente é sempre assistente, ainda quando a lei o qualifica como litisconsorcial” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 400).

“Por tal motivo, pode o assistente litisconsorcial agir no processo, e conduzir sua atividade, sem subordinar-se à orientação tomada pelo assistido: pode contraditar a testemunha que o assistido teve por idônea; pode requerer o julgamento antecipado da lide, embora o assistido pretenda a produção de provas em audiência; pode impugnar a sentença, não obstante o assistido haja renunciado à faculdade de recorrer (Athos Gusmão Carneiro, *Intervenção de terceiros*, p. 206).

Esta regra não vale, no entanto, para a confissão: “No tocante à confissão, é falsa a aparente restrição de

sua eficácia, pretendida pelo art. 350 do Código de Processo Civil [art. 391 do CPC] ao dizer que ela ‘faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, os litisconsortes’. Lido no contexto do sistema do Código, esse dispositivo mostra-se inócuo, porque ao juiz é dado o poder de formar livremente seu convencimento sobre fatos (art. 131) [art. 371 do CPC; sem a alusão expressa ao “livremente”, embora esta alteração não desnature o princípio do livre convencimento motivado] e não tem importância alguma a origem dos elementos de convicção em que se fundamenta; é indiferente que a prova haja sido feita por uma das partes, por outra, ou que tenha vindo ao processo de qualquer outro modo (princípio da aquisição da prova). Por isso, as conclusões a que chegar serão eficazes perante todos, sem importar se houve confissão de um, de outro ou de nenhum, até porque seria um absurdo mandar que o juiz cindisse seu julgamento em dois, reconhecendo a ocorrência de dado fato em relação a um dos litisconsortes (o confitente) e negando-o quanto aos demais. A confissão, que não passa de uma declaração de conhecimento de fatos adversos, feita por uma das partes, será apreciada pelo juiz, com eficácia para o julgamento da causa como um todo, a partir do seu poder de livremente convencimento” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 355).

54

Para mais detalhes: José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 5, p. 384.

55

Sobre legitimidade processual, confirmam-se os comentários ao art. 70.

56

Para mais detalhes sobre a relação entre adquirente e alienante da coisa litigiosa, confirmam-se os comentários ao art. 109.

57

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 496.

58

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 143.

59

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 387.

60

Sobre o conceito de *forum non conveniens*: Renato Beneduzzi, *Forum non conveniens*, *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 799.

62

61

A preocupação em se evitarem repetições desnecessárias, em reduzir custos e em assegurar maior segurança jurídica (Hans-Jörg Schultes, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol. 1., p. 453).

63

A perspectiva norte-americana é também interessante: “Modern party-joinder practice seeks to maximize the ability of the court to meet the distinctive needs of particular controversies” (Friedenthal, Kane e Miller, *Civil procedure*, p. 334).

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

CAPÍTULO II - DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE

Art. 125. É admissível a denúncia da lide, promovida por qualquer das partes:

I – ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denúncia sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denúncia, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Direito anterior – art. 70 do CPC/1973.

Direito comparado – § 72 da ZPO alemã, art. 106 do c.p.c. italiano, art. 330 do CPC português e Rule 14 dos FRCP norte-americanos.

1. Denúnciação da lide

A denúncia da lide é uma modalidade coata (não-voluntária) de intervenção de terceiros em que uma parte (denunciante), autor ou réu, deduz contra um terceiro (denunciado), no mesmo processo em que litiga contra seu adversário, uma demanda (eventual) cujo mérito deve ser julgado apenas se a demanda originária (principal) vier a ser decidida contra ele, o denunciante. Como resume Barbosa Moreira, trata-se de uma “ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante”.^{1.2.3} Ela não será, no entanto, sempre cabível. “É vedada a denúncia da lide nas relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC”.^{4.5}, e em certos procedimentos especiais, como naquele regulado pela Lei dos Juizados Especiais, cujo art. 10 dispõe que “não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência”. Sobre o momento adequado à formulação do pedido de denúncia e o cabimento da “ação autônoma” (parágrafo primeiro), confirmam-se os comentários ao art. 126. Sobre as características da denúncia quando autor o denunciante, os comentários ao art. 127. Quando réu o denunciante, os comentários ao art. 128. Sobre o julgamento da denúncia, os comentários ao art. 129.

2. Denúnciação da lide e evicção

A evicção consiste, como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na “perda da coisa, determinada em regra por sentença judicial⁶, que a atribui a outrem, por direito anterior ao contrato aquisitivo. Gera, contra o alienante, responsabilidade civil que se funda no mesmo princípio de garantia que o vincula em face dos vícios redibitórios”⁷. Será também evicção a “perda judicial do crédito, proferida a sentença posteriormente à cessão, mas por uma causa a ela anterior”⁸. Com a extensão e as características desta responsabilidade, não se ocupa a lei processual, mas, sim, a legislação civil (cf. arts. 447 e seguintes do Código Civil). Materialmente

falando, esta pretensão reparatória nasce apenas com a perda *efetiva* da coisa ou do crédito. Não basta a mera *pendência* de um litígio judicial, cujo resultado é ainda incerto, entre o alienante e um terceiro que verse sobre a coisa ou o crédito alienados.

Enquanto a procedência de uma “ação autônoma” deduzida pelo adquirente evicto pressupõe a perda efetiva da coisa ou do crédito, serve-lhe a denúncia da lide prevista no inciso I como um verdadeiro *atalho* processual para a eventualidade de sua sucumbência na demanda principal. Com a denúncia, assim, antecipa-se o exercício pelo adquirente desta pretensão fundada na responsabilidade do alienante pela evicção (em caráter eventual, dependente da perda futura e incerta, neste processo, da coisa ou do crédito). É neste sentido que se diz que a denúncia da lide é uma demanda (eventual) cujo mérito deve ser julgado, apenas, se a demanda originária (principal) vier a ser decidida contra ele, o denunciante. Temendo perder a coisa ou o crédito para um terceiro⁹ que contra ele litiga em juízo (evicção), em outras palavras, o adquirente deduz contra o alienante uma demanda eventual, no mesmo processo em que litiga contra o reivindicante, cujo mérito deverá ser julgado apenas se o mérito da demanda principal vier a ser decidido contrariamente aos interesses do adquirente.¹⁰ A denúncia da lide será admissível, em síntese, quando existir o *risco* de evicção no processo em curso da coisa ou do crédito litigiosos. Não se exige a efetiva e prévia perda.

O adquirente, em perigo de ser evicto, terá contra o alienante *sempre* o direito de denunciar-lhe a lide, independentemente da conveniência ou inconveniência instrutórias que esta modalidade de intervenção de terceiros puder trazer para o processo (diferentemente do que ocorre na hipótese tratada no inciso II deste mesmo artigo, como se verá no próximo item). Mas o adquirente não terá *nunca* o dever, do ponto de vista material, de fazê-lo (facultatividade da denúncia da lide). O não exercício do direito *processual* de denunciar, deste modo, em nada prejudica o exercício autônomo da pretensão *material* à reparação dos prejuízos causados pela evicção¹¹. Neste caso, o adquirente terá, apenas, de aguardar a perda efetiva da coisa ou do crédito, para então deduzir esta pretensão em demanda própria. É exatamente por este motivo que “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida” (parágrafo primeiro).

Para evitar tumultos e exagerada complexidade instrutória, entretanto, a lei limita o direito de denunciar do adquirente a lide ao seu “alienante imediato” (inciso I)¹². Não se permite, assim, a denúncia *per saltum* de nenhum outro alienante na cadeia sucessória da coisa ou do crédito¹³. Trata-se de uma limitação de natureza puramente *processual*, que não compromete o direito material que o adquirente possa ter contra os demais alienantes na cadeia sucessória. Para o exercício desta pretensão contra os demais, a lei processual limita-se apenas a não oferecer ao adquirente o *atalho* da denúncia da lide. Sobra-lhe apenas a via da demanda própria. É exatamente por este mesmo motivo (o objetivo de evitar excessiva complexidade instrutória) que a lei, embora permitindo a denúncia da lide pelo denunciado a seu antecessor imediato (denúncia sucessiva)¹⁴, proíbe ao denunciado sucessivo “promover nova denúncia, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma” (parágrafo segundo). Proíbe-se deste modo, consequentemente, também a denúncia coletiva a “todos os antecessores na cadeia dominial”.¹⁵

3. Denúncia da lide e direito de regresso

Ao contrário do que acontece quando a denúncia da lide se funda na ocorrência de evicção, em que o denunciante tem o *direito* de denunciar o alienante imediato, dependerá, sempre, a admissão da denúncia da lide “àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo” (inciso II) do reconhecimento pelo juiz de que a intervenção forçada do terceiro é, à luz das particularidades de cada caso concreto, processualmente conveniente. A expressão “ação regressiva” deve ser interpretada, assim, de modo extensivo, de maneira a atingir qualquer pretensão que tenha, por fundamento, a responsabilidade do denunciado pela indenização ao denunciante dos prejuízos que sua eventual condenação¹⁶ puder vir a lhe causar¹⁷, mas a denúncia só será admissível se ela não for processualmente *inconveniente* e, apenas, quando não for caso de chamamento ao

processo (em que não há, a rigor, exercício pelo chamante de uma pretensão regressiva contra o chamado¹⁸⁻¹⁹).

O controle do juiz em relação à admissibilidade da denúncia deve limitar-se, deste modo, à questão *processual* de sua conveniência. Daí por que a denúncia “não deve ser deferida quando [puder] suscitar tumulto processual”²⁰. Será o juiz, casuisticamente, no legítimo uso da discricionariedade que a lei lhe reconhece (discricionariedade, não arbitrariedade), que deverá avaliar se o aumento potencial da complexidade do processo que decorreria da denúncia a torna inconveniente²¹ de modo a recomendar que se deixe o exercício da pretensão regressiva para uma futura e eventual “ação autônoma”²². A mera circunstância de que demanda principal e demanda eventual reclamam, cada uma delas, “o conhecimento de fatos diversos e não necessariamente conciliáveis”²³ não inviabiliza, por si só, a denúncia, embora o juiz deva levar esta realidade em consideração ao avaliar a potencial *confusão* processual que este fato poderia vir a ocasionar e, conseqüentemente, a conveniência ou inconveniência da intervenção. A denúncia da lide é, assim, apenas um *atalho* processual²⁴ para a eventualidade de sucumbência do denunciante na demanda principal, razão pela qual é no *processo*, não na natureza mesma da pretensão do denunciante à luz do direito material, que se deve investigar o cabimento da denúncia da lide. Este parece, aliás, ser o equívoco central das teses restritiva e ampliativa que se desenvolveram para explicar o maior ou menor cabimento da denúncia da lide²⁵: argumentam *processualmente* para concluir *materialmente* pela interpretação ampliativa ou restritiva do que se deva entender por “direito de regresso”.²⁶

A discricionariedade do juiz é limitada apenas pela regra segundo a qual “admite-se uma única denúncia sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denúncia, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma” (parágrafo segundo). Trata-se de uma limitação de natureza puramente processual, que não compromete o direito material que o segundo denunciado possa ter contra o eventual responsável por indenizá-lo. Sem o atalho da denúncia sucessiva, sobra-lhe apenas a via da demanda própria. Mas o titular da pretensão regressiva não terá *nunca* o dever, do ponto de vista material, de denunciar a lide ao responsável (facultatividade da denúncia da lide). O não exercício do direito *processual* de denunciar, deste modo, em nada prejudica o exercício autônomo da pretensão *material* regressiva. Neste caso, o prejudicado terá, apenas, de aguardar a sua condenação e a concretização do prejuízo para então deduzir esta pretensão contra o responsável em demanda própria. É exatamente por este motivo que “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denúncia da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida” (parágrafo primeiro).

Art. 126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.

Direito anterior – art. 126 do CPC/1973.

Direito comparado – § 73 da ZPO alemã, art. 106 do c.p.c. italiano, art. 331 do CPC português e Rule 14 dos FRCP norte-americanos.

1. Denúnciação da lide, momento para seu requerimento e “ação autônoma”

A denúncia da lide será, sempre, em qualquer de suas hipóteses de cabimento, uma *opção* do denunciante. Será ele que decidirá livremente, à luz de suas conveniências pessoais, se tira proveito deste *atalho* processual ou não (facultatividade da denúncia da lide). O não exercício do direito *processual* de denunciar, deste modo, em nada prejudica o exercício autônomo da pretensão *material* de que eventualmente titular o denunciante contra o denunciado. Neste caso, o prejudicado terá, apenas, de aguardar a sua condenação e a concretização do prejuízo para, então, deduzir sua pretensão contra o responsável em demanda própria. É exatamente por este motivo, segundo dispõe o art. 125, § 1.º, que “o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando

a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

A denunciação da lide poderá ser requerida pelo próprio autor, caso em que ele deverá fazê-lo na própria petição inicial sob pena de *perder* o direito de denunciar (sem prejuízo, obviamente, de poder deduzir depois em demanda autônoma sua pretensão contra quem entenda como responsável pelos prejuízos que sofrer). Este pedido, no entanto, será *condicional*. O mérito da denunciação da lide deve ser julgado, apenas, se o juiz decidir o mérito da demanda principal contra o denunciante²⁷. Como resume Barbosa Moreira, “é como se o denunciante formulasse este pedido: ‘se eu, afinal, acabar vencido, peço desde já que o denunciado seja condenado a pagar-me indenização a que eu porventura tenha direito’²⁸. Se a denunciação da lide for requerida pelo réu, ele deverá fazê-lo na própria contestação; não *no prazo* para contestar, em petição apartada, mas *na própria* contestação²⁹. Também sob pena de perder o direito de denunciar a lide, e também sem prejuízo de poder deduzir depois em demanda autônoma sua pretensão contra quem entenda como responsável pelos prejuízos que vier a sofrer.

Art. 127. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.

Direito anterior – art. 74 do CPC/1973.

Direito comparado – § 74 da ZPO alemã, art. 106 do c.p.c. italiano, art. 330 do CPC português e Rule 14 dos FRCP norte-americanos.

1. Denunciação da lide pelo autor

A denunciação da lide, como se viu nos comentários ao artigo anterior, poderá ser requerida pelo autor, caso em que ele deverá fazê-lo na própria petição inicial sob pena de *perder* o direito de denunciar (sem prejuízo, obviamente, de poder deduzir depois em demanda autônoma sua pretensão contra quem entenda como responsável pelos prejuízos que possa vir a sofrer). Este pedido, no entanto, será *condicional*. O mérito da denunciação da lide deve ser julgado apenas se o juiz decidir o mérito da demanda principal contra o denunciante.³⁰ Como resume Barbosa Moreira, “é como se o denunciante formulasse este pedido: ‘se eu, afinal, acabar vencido, peço desde já que o denunciado seja condenado a pagar-me indenização a que eu porventura tenha direito’”.³¹

2. Incidente de denunciação da lide

Quando a denunciação da lide é pedida pelo autor, na própria petição inicial, o denunciado deverá ser citado em primeiro lugar. Instala-se assim, antes da citação do réu ou dos réus, um *incidente* de denunciação da lide. O juiz poderá indeferi-la, liminarmente, quando manifesta sua inadmissibilidade (mas, sempre, observado o princípio da cooperação). Citado o denunciado, ele terá a oportunidade de contestar a denunciação (não se realiza, neste incidente, a audiência de que trata o art. 334) e mesmo de pedir o indeferimento de sua intervenção. Integrado o contraditório, o juiz deverá decidir se a denunciação é admissível (se admissível, não se procedente), à luz dos requisitos explicados nos comentários ao art. 125 e das demais condições de admissibilidade do julgamento do mérito das demandas (art. 485)³². Desta decisão, que defere ou indefere a intervenção, caberá agravo de instrumento (art. 1.015, IX). Mas a cassação em grau de recurso da decisão que decide mal sobre a admissão não deve implicar a anulação de atos processuais praticados, quando, equivocadamente, aceita a denunciação, ou, ainda, a sua admissão tardia, se ela tiver sido indevidamente indeferida, “quando já adiantado o estado do processo”³³. Preserva-se, assim, a própria economia processual que serve de fundamento para a existência desta modalidade de intervenção de terceiros. Decidido o incidente de denunciação da lide, enfim, passa-se à citação do réu ou dos réus conforme a regra geral (arts. 334 e 335).

3. Posição e poderes do denunciado

O denunciado, admitida a sua intervenção, torna-se demandado na demanda eventual contra ele ajuizada pelo autor, cujo mérito deverá ser julgado apenas se o juiz decidir o mérito da demanda principal contra o denunciante (para mais detalhes sobre a natureza desta demanda, confirmam-se os comentários ao art. 126; sobre seu julgamento, os comentários ao art. 129). Na demanda principal, ao contrário do que pode sugerir uma primeira leitura do *caput* deste dispositivo, o denunciado não se torna litisconsorte do denunciante, porque ele, a rigor, nada pede contra o adversário do denunciante, nem contra ele nada é pedido por este adversário. Com a denunciação, o denunciado torna-se *assistente* do denunciante na demanda principal³⁴, simples ou litisconsorcial a depender da existência de um vínculo jurídico material direto entre ele³⁵, assistente, e o adversário do assistido. É neste sentido que se diz que o denunciado poderá “acrescentar novos argumentos à petição inicial”. Sobre os poderes do assistente, e os limites que lhe impõe a lei, em suas duas modalidades, confirmam-se os comentários, respectivamente, aos arts. 121, 122 e 124.

Pense-se na hipótese do proprietário de um imóvel que deduz uma demanda declaratória contra uma pessoa que lhe acusa de ter adquirido fraudulentamente um imóvel de um terceiro (a tradicional *actio negatoria* do direito romano). Esta pessoa afirma ser o *verus dominus*. Contra o reivindicante, o proprietário pede a declaração de sua propriedade (demanda principal). Temeroso de ver negado seu pedido, no entanto, pode o proprietário em sua petição inicial também denunciar a lide ao terceiro que lhe alienou o bem, com fundamento em sua responsabilidade pelo risco de evicção da coisa. O mérito desta demanda condicional só deverá ser julgado se improcedente o pedido formulado na principal. Na denunciação, o denunciado é demandado. Na demanda principal, ele é assistente litisconsorcial do autor, não seu litisconsorte, por força da natureza *erga omnes* do direito de sequência de que o adversário do assistido alega ser titular³⁶. Em razão desta natureza é que se pode dizer existir um vínculo jurídico entre o alienante denunciado e o adversário do denunciante, que alega ser o *verus dominus*. Daí por que *litisconsorcial*, neste exemplo, a assistência.

Art. 128. Feita a denunciação pelo réu:

I – se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;

II – se o denunciado for revel, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva;

III – se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso.

Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva.

Direito anterior – art. 75 do CPC/1973.

Direito comparado – § 74 da ZPO alemã, art. 106 do c.p.c. italiano, art. 330 do CPC português e Rule 14 dos FRCP norte-americanos.

1. Denunciação da lide pelo réu

A denunciação da lide, como se viu nos comentários ao artigo 126, poderá ser requerida pelo réu, caso em que ele deverá fazê-lo na sua contestação (não em petição apartada, como na vigência do CPC/1973, mas *na própria* contestação), sob pena de *perder* o direito de denunciar (sem prejuízo, obviamente, de poder deduzir depois em demanda autônoma sua pretensão contra quem entenda responsável pelos prejuízos que possa vir a sofrer). Este pedido, no entanto, será *condicional*. O mérito da denunciação da lide deve ser julgado apenas se o juiz decidir o mérito da demanda principal contra o denunciante³⁷. Como resume Barbosa Moreira, “é como se o denunciante

formulasse este pedido: ‘se eu, afinal, acabar vencido, peço desde já que o denunciado seja condenado a pagar-me indenização a que eu porventura tenha direito’³⁸.

2. Incidente de denunciação da lide

Quando a denunciação da lide é pedida pelo réu, em sua contestação, instala-se um *incidente* de denunciação da lide. O juiz poderá indeferi-la, liminarmente, quando manifesta sua inadmissibilidade (mas sempre observado o princípio da cooperação). Não sendo caso de indeferimento liminar, a instauração deste incidente determina a *suspensão* do trâmite da demanda principal até a sua solução³⁹. Citado o denunciado, ele terá a oportunidade de contestar a denunciação (não se realiza, neste incidente, a audiência de que trata o art. 334). Integrado o contraditório, o juiz deverá decidir se a denunciação é admissível (se admissível, não se procedente), à luz dos requisitos explicados nos comentários ao art. 125 e das demais condições de admissibilidade do julgamento do mérito das demandas (art. 485)⁴⁰. Desta decisão, que defere ou indefere a intervenção, caberá agravo de instrumento (art. 1.015, IX). Mas a reforma em grau de recurso da decisão que decide mal sobre a admissão não deve implicar a anulação de atos processuais praticados, quando equivocadamente aceita a denunciação, ou ainda a sua admissão tardia, se ela tiver sido indevidamente indeferida, “quando já adiantado o estado do processo”⁴¹. Preserva-se assim a própria economia processual que serve de fundamento para a existência desta modalidade de intervenção de terceiros.

3. Posição e poderes do denunciado

O denunciado, admitida a sua intervenção, torna-se demandado na demanda eventual contra ele ajuizada pelo réu, cujo mérito deverá ser julgado apenas se o juiz decidir o mérito da demanda principal contra o denunciante (para mais detalhes sobre a natureza desta demanda, confirmam-se os comentários ao art. 126; sobre seu julgamento, os comentários ao art. 129). Na demanda principal, ao contrário do que pode sugerir uma primeira leitura deste dispositivo, o denunciado não se torna litisconsorte do denunciante, porque ele, a rigor, nada pede contra o adversário do denunciante nem contra ele nada é pedido por este adversário. Com a denunciação, o denunciado torna-se *assistente* do denunciante na demanda principal⁴², simples ou litisconsorcial a depender da existência de um vínculo jurídico material direto entre ele⁴³, assistente, e o adversário do assistido.

Pense-se na hipótese em que alguém reivindica de outro a propriedade um imóvel. Em sua contestação, o réu denuncia a lide à pessoa que lhe teria alienado o imóvel com fundamento na sua responsabilidade pelo risco de evicção. O mérito desta demanda condicional só deverá ser julgado se procedente o pedido formulado na principal. Na denunciação, o denunciado é demandado. Na demanda principal, no entanto, ele é assistente litisconsorcial do réu, não seu litisconsorte, porque ele nada pede nem nada é pedido contra nele na demanda principal. Por força da natureza *erga omnes* do direito de sequência de que se reveste o direito real de propriedade⁴⁴ é que se pode dizer existir um vínculo jurídico entre reivindicante, adversário do denunciante, e denunciado. Daí por que *litisconsorcial*, neste exemplo, a assistência. Na denunciação da lide do segurador pelo segurado, diferentemente, a assistência será apenas simples, porque não existe um vínculo jurídico material entre denunciado e adversário do denunciante. E é justamente porque não existe este vínculo jurídico direto, aliás, que “descabe ação do terceiro prejudicado ajuizada direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”⁴⁵ o que não impede a vítima, como se explicará mais adiante, de dar cumprimento à sentença, quando houver denunciação da lide, diretamente contra o segurador, por *força* da lei processual. Sobre os poderes do assistente e os limites que lhe impõe a lei, em suas duas modalidades, confirmam-se os comentários, respectivamente, aos arts. 121, 122 e 124. A distinção entre as duas assistências é relevante, com efeito, porque, em cada uma delas, são diferentes os limites impostos aos poderes do assistente. No primeiro caso, de assistência litisconsorcial, por exemplo, o reconhecimento pelo denunciante da procedência do pedido na demanda principal exigirá o consentimento do denunciado; no segundo, de assistência simples, não.

4. As reações possíveis do denunciado

Os incisos deste artigo descrevem três reações possíveis do denunciado, quando processualmente admissível a denúncia: a) contestar a denúncia, e tornar-se, com isso, assistente do denunciante na demanda principal; assistente, simples ou litisconsorcial, conforme o caso, mas não litisconsorte, porque o denunciado nada pede nem nada é pedido contra ele na demanda principal (inciso I); b) nada fazer, tornando-se revel⁴⁶ (inciso II); e c) confessar os fatos alegados pelo autor na demanda principal e concentrar sua defesa na denúncia da lide. Sendo este o caso, o denunciado não se torna assistente do denunciante na demanda principal (e a confissão é ineficaz em relação às partes da demanda principal). Sem a assistência do denunciado, o denunciante poderá optar por “prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso” (inciso III).

5. Cumprimento de sentença diretamente contra o denunciado

Se contra o denunciado nada é pedido na demanda principal, não se permite ao juiz, a rigor, *condenar* o denunciado nesta demanda principal, mas apenas na demanda eventual. Seguindo-se este raciocínio, não se deveria permitir ao autor executar a sentença condenatória diretamente contra o denunciado. A ordem correta seria a execução do réu pelo autor e, em seguida, após este primeiro pagamento, a execução do denunciado pelo denunciante. Esta solução, no entanto, deixa o autor exageradamente desprotegido, especialmente, se insolvente o denunciante e solvente o denunciado. Por que não se deveria permitir a execução *direta* do denunciado pelo autor?

O novo CPC, generalizando a solução encontrada pelo Superior Tribunal de Justiça, passou a permitir a execução direta em todos os casos de denúncia ao dispor que “procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva” (parágrafo único). Este dispositivo não passa a autorizar, como poderia sugerir a fundamentação de alguns precedentes do STJ, a condenação *direta e solidária* do denunciado⁴⁷. Se o denunciado não é parte da demanda principal, e se nada foi pedido pelo autor contra ele, violaria o princípio da demanda permitir a sua condenação direta. O que ocorre, na verdade, é a vinculação do denunciado, assistente do denunciante, à justiça da decisão proferida entre denunciante e seu adversário (art. 126) *por força* do que dispõe o parágrafo único do art. 128. E é exatamente esta extensão *ex vi legis* – esta vinculação tem natureza exclusivamente processual, não material, porque não existe nenhum vínculo jurídico entre a vítima e o segurador – ao assistente da coisa julgada material (justiça da decisão) que permite o cumprimento de sentença pelo autor diretamente contra o denunciado, embora apenas “nos limites da condenação deste na ação regressiva” (parágrafo único). Os limites da responsabilidade do denunciado serão fixados, à luz do direito material (por exemplo, no contrato de seguro, pelos limites fixados na apólice⁴⁸) no julgamento da demanda eventual.

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denúncia da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denúncia não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Direito anterior – art. 76 do CPC/1973.

Direito comparado – § 74 da ZPO alemã, art. 106 do c.p.c. italiano, art. 332 do CPC português e Rule 14 dos FRCP norte-americanos.

1. Julgamento da denúncia da lide

A denúncia da lide é uma modalidade coata (não-voluntária) de intervenção de terceiros em que uma parte (denunciante), autor ou réu, deduz contra um terceiro (denunciado), no mesmo processo em que litiga contra seu adversário, uma demanda (eventual) cujo mérito deve ser

julgado apenas se a demanda originária (principal) vier a ser decidida contra ele, o denunciante. Como resume Barbosa Moreira, trata-se de uma “ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante”⁴⁹⁻⁵⁰⁻⁵¹. É por isso, segundo o disposto no *caput*, que “se [se, e apenas se] o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide”. Se o denunciante for vencedor na demanda principal, diferentemente, “a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado” (parágrafo único).

2. Honorários na denunciação da lide

Por se tratar de demanda autônoma, ainda que eventual (condicionada ao resultado da demanda principal), também na denunciação da lide deve o juiz condenar aquele que deu causa ao processo ao pagamento das verbas da sucumbência (segundo as regras explicadas nos arts. 82 e 85). Esta fixação ocorrerá não apenas quando o mérito da denunciação da lide vier a ser julgado, mas, ainda, quando não o for porque o resultado da demanda principal é inteiramente favorável ao denunciante de modo a tornar *desnecessário* para ele, denunciante, o julgamento da denunciação⁵². É por isso que “se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado” (parágrafo único).

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Carlos Barbosa Moreira, *Estudos sobre o novo Código de Processo Civil*, p. 87.

2

“A natureza da denunciação da lide é de verdadeira ação de regresso eventual, podendo ser oferecida tanto pelo autor quanto pelo réu da demanda originária, ensejando o ingresso de um terceiro na lide, o qual poderá ser condenado a indenizar o denunciante por prejuízos de que era responsável em virtude de lei ou do contrato” (REsp 1304398/PR, 2ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08.09.2015, *DJe* 21.09.2015.).

3

“A denunciação tem assim três finalidades principais: propiciar economia processual (instruir e julgar conjuntamente a ação principal e a ação regressiva), evitar julgados contraditórios e qualificar o contraditório (mediante o eventual acréscimo, pelo denunciado de subsídios instrutórios relevantes para a ação principal)”. (Wambier/Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. 1, p. 367).

4

AgRg no REsp 1288943/SP, 3ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15.09.2015, *DJe* 21.09.2015.

6

Diz-se *em regra*, corretamente, porque a evicção nem sempre ocorre por força de sentença. Basta, com

efeito, “que o adquirente fique dela [da coisa ou do crédito] privado por ato legítimo de autoridade” (*Athos Gusmão Carneiro*, Intervenção de terceiros, p. 111). Neste sentido: “O direito de demandar pela evicção não supõe, necessariamente, a perda da coisa por sentença judicial. A autoridade administrativa aduaneira, que decretou o perdimento do bem, em razão da ilegal circulação de veículo importado no país, equipara-se a autoridade policial para fins do exercício da evicção, porquanto exerce o mesmo poder de apreensão” (REsp 1047882/RJ, 4ª Turma, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, (Desembargador Convocado do TJ/AP), julgado em 03.11.2009, *DJe* 30.11.2009).

7

REsp 873.165/ES, 3ª Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 18.05.2010, *DJe* 07.06.2010).

8

Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 2, p. 369.

9

Do ponto de vista do direito material, o reivindicante da coisa ou do crédito é um terceiro em relação a alienante e adquirente. Processualmente, no entanto, ele é *parte*, porque reivindica no processo a coisa ou o crédito. Terceiro, processualmente falando, será o alienante denunciado.

10

Para mais detalhes sobre o julgamento da denunciação, confirmam-se os comentários ao art. 129.

11

Marcelo José Magalhães Bonizzi, Evicção e denunciação da lide no novo CPC brasileiro, *Revista de Processo*, vol. 258, 2016, item 3.

12

“Como todo instrumento processual, a denunciação da lide é técnica que, se bem utilizada, contribui para a solução eficiente de litígios em um mesmo procedimento. A ocorrência de denunciações sucessivas, porém, pode levar a resultado oposto” (José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 221).

13

Em sentido contrário, escrevendo embora ainda na vigência do CPC de 1973, de cujo art. 70, I, não constava a restrição “alienante imediato” que hoje consta do art. 125, I, e antes da revogação do art. 456 do Código Civil: “Pelo disposto no art. 456 do Código Civil no trato da evicção, ‘o adquirente notificará o alienante imediato ou qualquer dos anteriores’, ou seja, denunciará a lide a qualquer um deles. Este dispositivo tem, em um primeiro plano, o significado jurídico-substancial de estabelecer a responsabilidade civil por evicção de toda a cadeia de alienantes perante aquele cujo direito sobre o bem adquirido venha a ser posto em crise em um processo – seja porque outro sujeito lhe move ação negando

esse seu direito, seja porque ele próprio vem a juízo postulando a declaração de ser realmente titular desse direito. Como consequência de ser potencialmente credor de qualquer dos alienantes diretos ou indiretos, esse sujeito que está no processo como autor ou como réu tem a faculdade de denunciar a lide a todos ou cada um, conforme sua própria vontade e conveniência. Tal é a denúncia da lide per saltum” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 2, p. 416).

14

Como explica Agrícola Barbi, neste caso, “o alienante da coisa em litígio, uma vez denunciado, virá a juízo requerer a denúncia àquele de quem houve a coisa e assim sucessivamente” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 267).

15

Sobre o ponto: Athos Gusmão Carneiro, *Intervenção de terceiros*, p. 145.

16

Do denunciante, não do denunciado.

17

“Na conceituação mais ampla possível envolveria: direito a indenização, direito a reembolso, direito decorrente de sub-rogação, direito à garantia (própria ou imprópria), direito à repetição de pagamento indevido, direito à indenização por locupletamento ou enriquecimento ilícito” (Sidney Sanches, *Denúnciação da lide no direito processual civil brasileiro*, p. 116).

18

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

20

AgRg no Ag 692.603/PR, 3ª Turma, rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 25.05.2010, *DJe* 10.06.2010.

21

“Like the other joinder devices under discussion, impleader is aimed at settling in a single lawsuit as many aspects of a controversy as possible. And again, as in the case of other joinder rules, protection against undue trial confusion and prejudice is afforded by judicial discretion to order separate trials of issues rather than by arbitrary limitations on the dimensions of actions” (Hazard/Leubsdorf/Bassett, *Civil Procedure*, p. 303).

22

“Não há vedação legal expressa, isso é fato; mas o magistrado, aplicando a máxima da proporcionalidade, verificará, no caso concreto, se a admissibilidade da denúncia da lide pode comprometer a duração razoável do processo, a ponto de não valer a pena a economia processual que por ela se busca alcançar; se isso ocorrer, inadmissível, in concreto, a denúncia, restando ao prejudicado exercer por via autônoma a sua ação regressiva” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 513).

23

Em sentido contrário: Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 152.

24

É exatamente por este motivo que se diz que “impleader does not create any substantive right; it is simply an expeditious way to implement the right in the action in which the original defendant’s own liabilities are being determined” (Hazard/Leubsdorf/Bassett, *Civil Procedure*, p. 303).

25

Para uma resenha sobre as duas correntes, confira-se Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 506.

26

Por exemplo, em favor da tese restritiva: “De fato, se admitíssemos a denúncia ante a simples possibilidade de direito de regresso violaríamos a economia processual e a celeridade da justiça, porque num processo seriam citados inúmeros responsáveis ou pretensos responsáveis numa cadeia imensa e infundável, com suspensão do feito primitivo. Assim, por exemplo, numa demanda de indenização por dano decorrente de acidente de veículo, poderia ser chamado o terceiro, que o réu afirma ter também concorrido para o acidente, a fábrica que montou no carro peça defeituosa, a Prefeitura que não cuidou do calçamento, cabendo, também, à fábrica de automóvel chamar a fábrica de peças e esta, por sua vez, o fornecedor do material. E isso tudo em prejuízo da vítima, o autor primitivo, que deseja a reparação do dano e a aplicação de justiça, mas que teria de aguardar anos até a citação final de todos. Violar-se-ia, também, como se vê, o princípio da singularidade da ação e da jurisdição, como verdadeira denegação de justiça” (Vicente Greco Filho, *Intervenção de terceiros*, p. 90). Com razão o autor, ao afirmar inconveniente a denúncia neste seu exemplo. Mas esta inconveniência é de natureza *processual* e é nela que se deve encontrar o fundamento para a inadmissão, *neste caso concreto*, da denúncia.

27

Para mais detalhes sobre o julgamento da denúncia da lide, confirmam-se os comentários ao art. 129, segundo o qual “se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denúncia da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denúncia não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

28

29

Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 153.

30

Para mais detalhes sobre o julgamento da denunciação da lide, confirmam-se os comentários ao art. 129, segundo o qual “se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

31

José Carlos Barbosa Moreira, *Estudos sobre o novo Código de Processo Civil*, p. 88.

32

“Se o denunciado for a União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal, desloca-se a competência do processo para a Justiça Federal, caso esse já lá não tramite (art. 109, I, da CF/1988; art. 45 do CPC). A decisão sobre a admissibilidade da denunciação caberá ao juiz federal, que devolverá o processo à Justiça Estadual ou do DF, em caso de inadmissão (art. 45, § 3.º, do CPC, Súm. 150, do STJ)” (Wambier/Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. 1, p. 367).

33

“A denunciação da lide só tem cabimento se respeitados os princípios da economia processual e da celeridade. Há casos em que o estado avançado do processo – após a prolação de sentença de mérito, por exemplo – não recomenda o deferimento do pedido de denunciação da lide sob pena de afronta aos mesmos princípios que o instituto busca preservar. Quando já adiantado o estado do processo, não se justifica, nesta instância especial, ainda que a denunciação da lide tenha sido porventura mal indeferida pelas instâncias ordinárias, a anulação de atos processuais com o retrocesso da marcha processual, porque a finalidade do instituto estaria, nesse caso, sendo contrariada” (REsp 1243346/SP, 3ª Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 01.12.2015, *DJe* 09.12.2015)

34

Similarmente, aliás, ao que ocorre na denunciação da lide no processo alemão (*Streitverkündung*): o denunciado assume, na demanda principal, a posição de *Nebenintervnient* (assistente) do denunciante, não de *Streitgenosse* (litisconsorte). É o que diz explicitamente o § 74 (1) da ZPO, segundo o qual „wenn der Dritte dem Streitverkünder beitriff, so bestimmt sich sein Verhältnis zu den Parteien nach den Grundsätzen über die Nebenintervention“. Para mais detalhes, por exemplo: Hans-Jörg Schultes, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol 1, p. 523).

Não necessariamente simples, nem tampouco necessariamente litisconsorcial.

“Os direitos reais são providos da prerrogativa de acompanharem a coisa (ambulatoriedade), autorizando o titular a exercê-los contra quem quer que com ela se encontre (sequela)” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 4).

Para mais detalhes sobre o julgamento da denunciação da lide, confirmam-se os comentários ao art. 129, segundo o qual “se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado”.

José Carlos Barbosa Moreira, *Estudos sobre o novo Código de Processo Civil*, p. 88.

“Ainda a respeito do tema, destaco que o CPC de 2015, diferentemente do de 1973, nada traz sobre a suspensão do processo enquanto é citado o denunciado. A despeito do silêncio, é correto entender que o processo fica suspenso para que a citação seja realizada, sem o que não há sentido em se admitir a denunciação da lide que, em última análise, é forma de viabilizar o cúmulo objetivo em um mesmo processo. Entendimento contrário conspiraria contra o princípio da eficiência processual, que anima todas as intervenções de terceiros” (Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 153).

“Se o denunciado for a União Federal, autarquia, fundação ou empresa pública federal, desloca-se a competência do processo para a Justiça Federal, caso esse já lá não tramite (art. 109, I, da CF/1988; art. 45 do CPC). A decisão sobre a admissibilidade da denunciação caberá ao juiz federal, que devolverá o processo à Justiça Estadual ou do DF, em caso de inadmissão (art. 45, § 3.º, do CPC, Súm. 150, do STJ)” (Wambier/Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. 1, p. 367).

“A denunciação da lide só tem cabimento se respeitados os princípios da economia processual e da celeridade. Há casos em que o estado avançado do processo – após a prolação de sentença de mérito, por exemplo – não recomenda o deferimento do pedido de denunciação da lide sob pena de afronta aos mesmos princípios que o instituto busca preservar. Quando já adiantado o estado do processo, não se justifica, nesta instância especial, ainda que a denunciação da lide tenha sido porventura mal indeferida pelas instâncias ordinárias, a anulação de atos processuais com o retrocesso da marcha processual, porque a finalidade do instituto estaria, nesse caso, sendo contrariada” (REsp 1243346/SP, 3ª Turma, rel.

42

Similarmente, aliás, ao que ocorre na denunciação da lide no processo alemão (*Streitverkündung*): o denunciado assume, na demanda principal, a posição de *Nebenintervenient* (assistente) do denunciante, não de *Streitgenosse* (litisconsorte). É o que diz explicitamente o § 74 (1) da ZPO, segundo o qual „wenn der Dritte dem Streitverkünder beitriff, so bestimmt sich sein Verhältnis zu den Parteien nach den Grundsätzen über die Nebenintervention“. Para mais detalhes, por exemplo: Hans-Jörg Schultes, *Münchener Kommentar zur ZPO*, vol 1, p. 523).

43

Não necessariamente simples, nem tampouco necessariamente litisconsorcial.

44

“Os direitos reais são providos da prerrogativa de acompanharem a coisa (ambulatoriedade), autorizando o titular a exercê-los contra quem quer que com ela se encontre (sequela)” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 4).

45

REsp 962.230/RS, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08.02.2012, *DJe* 20.04.2012.

46

Lembre-se que os efeitos da revelia, nesta demanda eventual, não incidirão se aplicável alguma das exceções previstas nos incisos do art. 345.

47

“Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (REsp 925.130/SP, 2ª Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08.02.2012, *DJe* 20.04.2012).

48

“Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (REsp 925.130/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08.02.2012, *DJe* 20.04.2012).

49

José Carlos Barbosa Moreira, Estudos sobre o novo Código de Processo Civil, p. 87.

50

“A natureza da denunciação da lide é de verdadeira ação de regresso eventual, podendo ser oferecida tanto pelo autor quanto pelo réu da demanda originária, ensejando o ingresso de um terceiro na lide, o qual poderá ser condenado a indenizar o denunciante por prejuízos de que era responsável em virtude de lei ou do contrato” (REsp 1304398/PR, 2ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08.09.2015, *DJe* 21.09.2015).

51

“A denunciação tem assim três finalidades principais: propiciar economia processual (instruir e julgar conjuntamente a ação principal e a ação regressiva), evitar julgados contraditórios e qualificar o contraditório (mediante o eventual acréscimo, pelo denunciado de subsídios instrutórios relevantes para a ação principal)” (Wambier/Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. 1, p. 367).

52

“No segundo, de a denunciação da lide ficar prejudicada, é pertinente a lembrança do §10 do mesmo art. 85, ao menos em relação aos honorários advocatícios. Como quem deu causa à denunciação foi o denunciante, é ele que deve suportar aquele custo. Máxime porque, cabe lembrar, no CPC de 2015, a obrigatoriedade da denunciação da lide deixou de existir em qualquer uma de suas hipóteses. É essa a razão de ser da parte final do parágrafo único do art. 129 (Cássio Scarpinella Bueno, *Manual de direito processual civil*, p. 153).

5

Para mais detalhes: Sandro Gilbert Martins, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier/Didier Jr./Talamini/Dantas), p. 443.

19

Para mais detalhes sobre o chamamento, confirmam-se os comentários ao art. 130.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

CAPÍTULO III - DO CHAMAMENTO AO PROCESSO

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

Direito anterior – art. 77 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 329 do CPC português.

1. Chamamento ao processo. O chamamento ao processo é uma modalidade coata (não voluntária) de intervenção de terceiros em que o réu, e apenas ele (chamante), *chama* um terceiro, ao contestar, para que com ele integre o polo passivo da demanda na qualidade de litisconsorte (chamado). No chamamento ao processo, ao contrário do que acontece na denúncia da lide, em que denunciante e denunciado relacionam-se por um vínculo de mera responsabilidade regressiva, aquele que se afirma credor (o autor) pode exigir o pagamento da dívida *simultaneamente* do chamante e do chamado,¹ não de apenas um deles, ainda que cada um dos devedores possa estar obrigado a um título próprio.²⁻³ Mas o chamamento só será admissível se o chamante, pagando, puder sub-rogar-se nos direitos do credor (inc. I) ou se puder cobrar do chamado a sua quota-parte (incs. II e III).

Embora o direito material, em outras palavras, reconheça ao credor o direito de cobrar a dívida *integralmente* de apenas um devedor (solidariedade passiva), permite a lei, nas situações descritas nos incisos deste artigo, em nome da economia processual, desde que esta intervenção não se revele processualmente inconveniente,⁴ *chamar* os demais obrigados ao processo, mesmo contra a vontade do credor,⁵ de modo a formar um litisconsórcio passivo facultativo simples entre eles.⁶ O chamante não deduz, tecnicamente, uma nova demanda contra o chamado, diferentemente do que ocorre na denúncia da lide.⁷ O que a lei processual faz, como observou Barbosa Moreira, é retirar “*com a mão esquerda aquilo que o legislador material deu ao credor com a direita, suprimindo, na prática, o benefício que a lei civil lhe concede*”.⁸ Por esta razão, aliás, ao malferir o princípio da demanda, este instituto de origens lusitanas é de duvidosa constitucionalidade. Sobre o incidente de chamamento ao processo e sobre a posição processual do chamado, confirmam-se os comentários ao art. 131. Sobre o seu julgamento, os comentários ao art. 132.

2. As duas figuras do chamamento ao processo. Segundo o inc. I, admite-se o chamamento ao processo “*do afiançado, na ação em que o fiador for réu*”. Excluído o benefício de ordem, afiançado e fiador são solidariamente obrigados ao pagamento da dívida garantida pela fiança. Embora, assim, o credor pudesse ter escolhido litigar apenas contra o fiador, à luz do direito material, permite-lhe a lei *processual* chamar ao processo o afiançado. E isso ao fundamento de que, se pagasse a dívida, o chamante poderia sub-rogar-se nos direitos do credor contra o chamado.⁹ É exatamente por este motivo que o inverso não é possível: réu apenas o afiançado, não se lhe permite chamar ao processo o fiador, porque o pagamento da dívida não lhe conferiria nenhum direito contra o fiador omitido. Existente o benefício de ordem, o chamamento torna-se ainda mais importante para o fiador demandado porque é com fundamento nele que se lhe permite invocar o benefício e, assim, exigir “*que sejam primeiro executados os bens do devedor*” (art. 827, do CC).¹⁰

As situações descritas nos incs. II e III podem ser reunidas em uma única figura: a um devedor solidário, de quem se pode exigir o pagamento integral da dívida, reconhece-se, com o pagamento, o direito de cobrar dos demais devedores as respectivas quotas-parte; caso não apenas do cofiador (art. 829, do CC¹¹), mas de todo coobrigado solidário (art. 283, do CC).¹² Nesta hipótese, ainda que o credor pudesse cobrar a dívida integralmente de cada um dos devedores solidários, permite a lei processual o chamamento ao processo do obrigado solidário omitido pelo obrigado solidário demandado. O chamamento ao processo serve aqui essencialmente para *facilitar*, nas relações internas entre os devedores solidários, a cobrança judicial das respectivas quotas-partes.

Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.

Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de 2 (dois) meses.

Direito anterior – art. 78 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 329 do CPC português.

1. Incidente de chamamento ao processo. O chamamento ao processo deve ser requerido pelo réu, em sua contestação (não em petição apartada, mas *na própria* contestação¹³), sob pena de *perder* o direito de chamar (sem prejuízo, obviamente, de poder deduzir depois em demanda autônoma sua pretensão contra o afiançado, os demais fiadores ou os demais devedores solidários). O chamamento só é admissível, deste modo, na fase de conhecimento do processo e apenas quando de natureza condenatória o pedido formulado na demanda,¹⁴ independentemente da natureza material da prestação cobrada (pecuniária, de entregar coisa, de fazer ou não fazer).

O pedido de intervenção pode ser liminarmente indeferido, quando manifesta sua inadmissibilidade (mas observado sempre o princípio da cooperação). Não sendo caso de indeferimento liminar, a instauração deste incidente determina a *suspensão* do trâmite da demanda principal até sua solução. Citado o chamado, ele terá a oportunidade de contestar (não se realiza, neste incidente, a audiência de que trata o art. 334). Integrado o contraditório, o juiz deverá decidir se o chamamento é admissível (se admissível, não se procedente), à luz dos requisitos explicados nos comentários ao art. 130. Desta decisão, que defere ou indefere a intervenção, caberá agravo de instrumento (art. 1.015, IX).

2. Chamamento e conveniência processual. O chamamento ao processo será admissível, como se viu, se a pretensão do chamante tiver por fundamento, em tese, alguma das situações previstas nos incisos do art. 131. Mas ele só será admissível se não se revelar *processualmente* inconveniente. Será o juiz, casuisticamente, no legítimo uso da discricionariedade que a lei lhe reconhece (discricionariedade, não arbitrariedade), que deverá avaliar se o aumento potencial da complexidade do processo que decorreria do chamamento ao processo o torna inconveniente de modo a recomendar que se deixe o exercício da pretensão material do chamante contra o chamado para outro processo. É assim à luz da conveniência *processual* do chamamento, não da natureza *material* da prestação reclamada (se pecuniária, de fazer ou não fazer etc.), que se deve avaliar a admissibilidade do chamamento. Este “teste de conveniência processual” vem sendo recomendado, acertadamente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal¹⁵ e do Superior Tribunal de Justiça.¹⁶

Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.

Direito anterior – art. 80 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 328 do CPC português.

1. Sentença e execução no chamamento ao processo. O chamamento ao processo, como se viu nos comentários aos arts. 130 e 131, não é uma demanda eventual deduzida pelo réu contra o terceiro. Admitida a sua intervenção, o chamado torna-se *litisconsorte* passivo, autêntico réu ao lado do chamante, ainda que contra o ele o autor não tenha formulado pedido algum.¹⁷ Por este motivo, o chamado poderá ser *condenado* ao lado do chamante. Antes de decidir se julga ou não procedente o pedido condenatório formulado pelo autor, no entanto, o juiz deverá decidir a questão prejudicial relativa à condição do chamado: ele é realmente afiançado, cofiador ou devedor solidário, e, se o for, de toda a dívida cobrada?¹⁸

Se sim, o pedido condenatório será julgado *também* contra ele. Se não, será julgado apenas parcialmente procedente ou mesmo improcedente em relação a ele, independentemente da sorte do chamante. Reconhecida embora a responsabilidade do chamado, ele não será assim *automaticamente* obrigado ao pagamento de toda a dívida. Neste aspecto, o direito material é fértil em possibilidades. Pense-se, por exemplo, na oposição de exceção pessoal por um dos devedores solidários (art. 281, do CC).¹⁹ Neste caso, o resultado final será diverso para cada um dos devedores, ainda que a sentença tenha reconhecida a existência de solidariedade passiva entre eles. Este o motivo, em síntese, por que *simples* o litisconsórcio passivo: a sorte de um litisconsorte não está necessariamente vinculada a do outro. Reconhecida a responsabilidade do chamado, integral ou parcialmente em relação à prestação cobrada originariamente apenas do chamante, enfim, a decisão que julgar o mérito da demanda constituirá título executivo não apenas contra o réu chamante, se se entender que também ele é obrigado, mas simultaneamente contra ele e o chamado.²⁰ Esta é a consequência natural de sua condição de litisconsortes.

Realizado o pagamento por um dos executados, no cumprimento de sentença, será preciso avaliar ainda se o direito material lhe faz sub-rogar-se nos direitos do credor (inc. I) ou se lhe reconhece o direito de cobrar de outro executado sua quota-parte (incs. II e III). O fiador que paga toda a dívida, por exemplo, sub-roga-se nos direitos do credor e pode *executá-la* nos próprios autos contra o afiançado. O devedor solidário, chamante ou chamado, que paga mais do que sua quota-parte, diferentemente, tem o direito de executar do outro apenas o que sobejar sua quota-parte.²¹

NOTAS DE RODAPÉ

1

Diferentemente do que acontece na denúncia da lide.

2

Enquanto a situação jurídica dos cofiadores é a mesma (coresponsáveis pelo pagamento de uma obrigação do afiançado), será diferente a do afiançado e do fiador. E isso porque “o contrato principal, entre o credor e o afiançado, constitui outra relação jurídica” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 432). Para mais detalhes, confirmam-se o próximo item dos comentários a este artigo.

4

Sobre este requisito, confirmam-se os comentários ao art. 131.

5

“Um aspecto que impressiona desfavoravelmente é o de fazer o credor demandar contra devedores com

os quais ele pode ter variados motivos para não litigar, quais sejam, outras relações de negócios, de parentesco, de amizade etc. Pode mesmo acontecer que a insolvabilidade de um devedor, ou a dúvida que o credor tenha quanto à sua assinatura no documento, desaconselhem a ação do credor. No entanto, estará ele coagido a agir contra essa pessoa, sujeitando-se aos riscos de derrota, que traz despesas judiciais e de honorários de advogado do vencedor, além dos reflexos negativos pelo insucesso em uma demanda que o credor não pretendia estender a outras pessoas. Acresce, ainda, que a inovação constitui uma exceção ao princípio tradicional, que nos vem desde o direito romano, de que ninguém deve ser coagido a pleitear direito em juízo. Tudo isso nos leva a não aplaudir a inovação, apesar dos bons propósitos que inspiraram o legislador” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 275).

6

“...configurando-se o chamamento ao processo, teremos a formação de litisconsórcio entre o chamante e o chamado, ambos situados na posição de réus perante o credor originário, sendo igualmente atingidos pela coisa julgada material. Daí termos a ampliação subjetiva da relação processual, antes constituída por um autor e um réu, e a partir do chamamento ao processo constituída de um autor e mais de um réu (o réu primitivo e o (os) chamado (s))” (Flávio Cheim Jorge, *Chamamento ao processo*, p. 38).

7

“Temos sustentado que não há, no caso, ação condenatória do chamante em relação ao chamado. É que, sobrevindo sentença condenatória, a mesma servirá de título executivo do credor em face de qualquer dos réus condenados, e não necessariamente em face do chamante, para que este, cumprindo a obrigação, exercite seu direito de regresso contra o outro devedor. Por isso, o chamante não tem pretensão *contra* o chamado, mas apenas quer que ele também seja responsabilizado, em caso de condenação” (José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 224).

8

José Carlos Barbosa Moreira, *Estudos sobre o novo Código de Processo Civil*, p. 87.

9

“Assim, o fiador, em consequência da sua sub-rogação nos direitos do credor – e como é próprio desta figura jurídica – tem o direito de exigir do devedor tudo o que por ele pagou (capital, juros, despesas, penas convencionais). Ainda em consequência de ficar sub-rogado, a partir do cumprimento, nos direitos do credor, assiste ao fiador a faculdade de reclamar ao devedor os juros a que o credor teria direito, desde essa data, caso a prestação não houve sido efetuada” (Mário Júlio de Almeida Costa, *Direito das obrigações*, p. 899).

10

“Não tendo havido renúncia ao benefício de ordem e tendo sido demandado apenas o fiador, o chamamento ao processo se tornar (para o fiador) ainda mais importante, já que será essencial para que se forme título executivo em face de ambos (fiador-chamante e afiançado-chamado). Só assim será viável ao fiador, executado, invocar em seu favor o benefício de ordem e exigir que a execução incida primeira sobre os bens do afiançado (art. 827, CC). É que se o chamamento ao processo não tiver sido feito não

haverá título executivo contra o afiançado, motivo pelo qual não será possível que sobre seu patrimônio incida qualquer atividade executiva” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 94).

11

“A solidariedade entre os co-fiadores, ou seja, entre os fiadores que se obrigaram cada um pelo total do débito, pode ser afastada quando, expressamente, ficar estabelecido o benefício da divisão. Esse benefício ocorre quando ficar ressalvado, expressamente, no contrato, que cada fiador será responsável apenas pela parte que, proporcionalmente, lhe cabe no pagamento, de sorte que não será responsável pela dívida por inteiro, mas somente pela parte que expressamente assumiu, conforme estabelecido no parágrafo único” (Tepedino, Barboza, Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 2, p. 645).

12

“O devedor solidário que houver satisfeito o crédito do credor, além da parte que lhe competia no débito comum, goza do direito de regresso contra cada um dos condevedores pela quota respectiva (-.). Uma coisa é a responsabilidade dos devedores nas relações externas, ou seja, perante o credor; outra, a sua responsabilidade nas relações internas, na roda dos condevedores. Na falta de convenção ou de disposição em contrário, as quotas de cada um dos condevedores solidários nas relações internas presumir-se-ão iguais” (João de Matos Antunes Varela, *Das obrigações em geral*, vol. 1, p. 638).

13

“O chamamento ao processo deve ser realizado dentro do prazo sob pena de preclusão temporal. A comparação entre o art. 131, *caput*, do Novo CPC, e o art. 78 do CPC/1973 mostra uma pequena, mas significativa modificação. O artigo revogado previa que o chamamento ao processo deveria ser feito no prazo para contestar, enquanto o novo dispositivo prevê que o chamamento será requerido pelo réu na contestação. Não existe dúvida de que contestar e chamar ao processo são espécies diferentes de resposta do réu diante de sua citação, mas, pretendendo o réu se valer de ambas, deverá fazê-lo num mesmo momento procedimental, incluindo o chamamento ao processo como tópico da contestação” (Daniel Amorim Assumpção Neves, *Manual de direito processual civil*, p. 301).

14

“É incabível sua formulação na fase de cumprimento de sentença, no processo autônomo de execução ou nos embargos de executado” (Wambier e Talamini, *Curso avançado de processo civil*, p. 370).

15

“o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida” (RE 607.381 AgR, 1.^a Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, *DJ* 17.6.2011).

16

“Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no

art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde” (REsp 1203244/SC, 1.ª Seção, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 09.04.2014, DJe 17.06.2014).

17

Esta razão, aliás, por que de duvidosa constitucionalidade o instituto do chamamento ao processo, como se explicou nos comentários ao artigo anterior.

18

Segundo do disposto no art. 822 do Código Civil, “não sendo limitada, a fiança compreenderá todos os acessórios da dívida principal, inclusive as despesas judiciais, desde a citação do fiador” e ainda, agora segundo o art. 823, também do Código Civil, que “a fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas, e, quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até ao limite da obrigação afiançada”.

19

“O art. 281 do novo Código [civil] alude, entretanto, a toda espécie de defesa, hábil a ilidir a pretensão do credor. Cumpre-lhe alegar os meios de defesa comuns a todos, como seria a nulidade do ato, por defeito de forma, por vício de consentimento, por falta de liceidade de objeto; a prescrição do direito creditório; o pagamento, a irregularidade da via escolhida etc. Tem, mesmo, o dever de levantá-las, sob pena de responder aos coobrigados por perdas e danos, alcançam a relação obrigacional, e podem ter por efeito reduzir ou extinguir as responsabilidades, tal como preceitua o Código Federal suíço das obrigações. Pode e há aqui uma faculdade, não um dever, opor as exceções que lhe sejam pessoais (compensação, confusão, remissão). Mas não tem o direito de invocar exceções pessoais pertinentes a outro devedor (como sejam a existência de termo ou condição, os defeitos relativos do negócio jurídico, a confusão da obrigação etc), porque somente a este interessa, e não atingem o seu dever de prestar” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 2, p. 96).

20

“Importa não esquecer, aqui, que o chamamento não representa exercício de ação regressiva do chamante contra o chamado, mas apenas convocação para a formação do litisconsórcio passivo. A ação ‘regressiva’ será apenas uma mera possibilidade, para o caso de ser o chamante quem venha a pagar a dívida, e possa, tendo em vista a relação de direito material, reaver do chamado, no todo ou em parte, aquilo que pagou. Por isso, a rigor, a sentença de procedência é ‘por si’ título executivo apenas em favor do autor, como qualquer outra sentença condenatória; mas, somada ao comprovante de pagamento (feito ao autor), também será título executivo em favor daquele que efetuou tal pagamento, se e na medida em que esse réu tiver direito de reembolso em face dos demais litisconsortes” (Athos Gusmão Carneiro, *Intervenção de terceiros*, p. 185).

21

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 105.

“Diferentemente da denúncia da lide, o chamamento ao processo não visa ao exercício do direito de regresso, o que só eventualmente pode acontecer na futura execução em favor daquele que pagou a mais do que sua responsabilidade. O chamado, se deve, deve ao credor, autor da ação, e não àquele que o chamou ao processo. Somente no caso de que o que chamou pagar a mais é que nasce o direito o direito de regresso” (Vicente Greco Filho, *Intervenção de terceiros*, p. 90).

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO III - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS

CAPÍTULO IV - DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, processualmente falando¹, é uma modalidade coata (não-voluntária) de intervenção de terceiros mediante a qual se pede o reconhecimento, em certos casos autorizados pelo direito material²⁻³, da extensão a alguém que não é parte da legitimidade passiva à execução forçada neste processo, atual ou futura e eventual⁴. Trata-se, assim, de uma demanda incidental ao processo em curso cujo mérito é o pedido de extensão da responsabilidade executiva a um terceiro⁵. Fora deste incidente, não se permite a desconsideração incidental da personalidade jurídica em caso algum⁶.

2. Legitimidades ativa e passiva. Terá legitimidade ativa para pedir a desconsideração da personalidade jurídica a parte interessada na extensão da responsabilidade patrimonial de seu adversário ao terceiro⁷ e, se intervir na qualidade de *custos iuris*, também o Ministério Público por expressa vontade da lei (*caput*). Não se permite, em nenhuma hipótese, o deferimento *ex officio* da desconsideração, ainda quando se tratar de relação de consumo⁸, e nem mesmo a mera instauração deste incidente sem requerimento do interessado⁹ (com fundamento no princípio da demanda¹⁰). A legitimidade passiva será, na desconsideração da personalidade jurídica tradicional, caso em que a sociedade é o adversário no processo do requerente, do sócio ou do administrador. Na desconsideração inversa, da própria sociedade (parágrafo segundo)¹¹.

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, como se viu nos comentários ao art. 133, pressupõe a instauração e julgamento de uma

demanda incidental ao processo, o “*incidente de desconconsideração, que demanda contraditório específico e prova igualmente específica sobre a ocorrência dos pressupostos legais que a autoriza*”¹². Este incidente poderá ser provocado pelo interessado “*em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial*” (caput)¹³, sua instauração deverá ser “*imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas*” (parágrafo primeiro) e sua procedência dependerá da demonstração pelo requerente do “*preenchimento dos pressupostos legais específicos [à luz do direito material] para desconconsideração da personalidade jurídica*” (parágrafo quarto). Sobre legitimidade ativa e passiva neste incidente, confirmam-se os comentários ao art. 133. Sobre a defesa do terceiro, os comentários ao art. 135. Sobre seu julgamento, os comentários ao art. 136.

Embora o parágrafo terceiro disponha, em termos gerais, que “*a instauração do incidente suspenderá o processo*”, é mais correto interpretar este dispositivo restritivamente, no sentido de que não se realizarão atos executivos contra o terceiro até que o incidente venha a ser julgado. Não seria razoável, por exemplo, suspender com a instauração deste incidente a prática de atos executivos contra os executados originários¹⁴.

2. Incidente de desconconsideração e pedido autônomo. O conceito processual de desconconsideração, enquanto modalidade de intervenção de terceiros, não se confunde com o seu conceito material, embora este sirva de fundamento para o deferimento daquele. Processualmente falando, a desconconsideração não atua no plano, material, da *dívida* e da *responsabilidade* (na tradicional dicotomia *Schuld* e *Haftung*)¹⁵, embora o tenha por pressuposto, mas no plano propriamente processual da responsabilidade executiva, servindo para estendê-la a alguém que não é parte.

Mas nada impede o autor de pedir em sua petição inicial a condenação de alguém que ele entende responsável pelo cumprimento de determinada prestação com fundamento na desconconsideração da personalidade jurídica. Materialmente, o fundamento pode ser até o mesmo. Processualmente, no entanto, não se trata, tecnicamente, de uma modalidade de intervenção de terceiros, mas de uma cumulação subjetiva de demandas. O réu, neste caso, não é um terceiro a quem se pede a extensão da responsabilidade executiva, mas o *litisconsorte* contra quem se pede sua *condenação* ao lado do alegado obrigado originário. É exatamente por este motivo, segundo o parágrafo segundo deste dispositivo, que se dispensa “*a instauração do incidente se a desconconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica*”.

3. Tutela de urgência na desconconsideração da personalidade jurídica. A criação pelo CPC de 2015 do incidente *processual* de desconconsideração da personalidade jurídica é uma clara reação do legislador à forma por ele percebida como exageradamente livre com que o “redirecionamento da execução” vinha sendo utilizado na praxe forense brasileira nos últimos anos de sua vigência¹⁶. Daí a preocupação central que a lei deposita no contraditório *prévio* como requisito da desconconsideração.

Esta exigência não torna inadmissível, no entanto, o deferimento **no** incidente de desconconsideração de tutela de urgência em benefício do requerente, com contraditório diferido, mediante realização imediata de constrição sobre bens do terceiro¹⁷. Mas a desconconsideração, em si, enquanto decisão de natureza cognitiva sobre a qual incide a imutabilidade da coisa julgada¹⁸, dependerá sempre da citação dos sócios. Esta a razão por que incompatível com o novo CPC a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão consolidada na vigência do CPC de 1973¹⁹.

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Defesa e instrução no incidente de desconconsideração da personalidade jurídica. O contraditório *prévio*, como se viu nos comentários ao art. 134, é um *requisito indispensável* da desconconsideração da personalidade jurídica, ainda que esta exigência não proíba a concessão pelo

juiz de tutela de urgência em benefício do requerente antes do julgamento final do incidente²⁰. Não indeferida liminarmente sua instauração, assim, o juiz deve determinar a citação do requerido (sócio, administrador ou a pessoa jurídica, conforme as regras materiais aplicáveis). Diz-se citação porque, não sendo ele *parte* do processo, não basta a sua mera intimação.

O terceiro terá um prazo comum de quinze dias para defender-se e para requer a produção das provas que entender necessárias²¹. Sua defesa deverá restringir-se à questão do cabimento ou não da desconsideração, sem se confundir com a eventual impugnação ao cumprimento de sentença ou com os embargos à execução que ele poderá vir depois a oferecer caso venha a se tornar executado com fundamento no acolhimento da desconsideração. Embargos de terceiro, por este motivo, não serão nunca cabíveis. Ou ele continuará terceiro, com a rejeição da desconsideração, e não poderá ser atingido pela execução, ou ele se tornará parte legítima à execução forçada, caso em que deixará de ser terceiro. O ônus da prova, enfim, será, em princípio, do requerente²².

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.

Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Julgamento e recorribilidade. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um *incidente* do processo, não um *processo* incidente, no qual se julga uma *demanda* incidental. Por isso, será interlocutória a decisão que o decide, da qual cabe agravo de instrumento (art. 1.015, IV), salvo se ele vier a ser julgado na própria sentença que põe fim à fase de conhecimento. Neste caso, o recurso cabível será a apelação (art. 1.009). Da decisão proferida monocraticamente por juiz integrante de órgão colegiado, por sua vez, caberá agravo interno (parágrafo único)²³. Terão legitimidade para interpor recurso desta decisão não apenas as partes originárias do processo, caso venham a ser prejudicadas por ela, mas também o terceiro a quem ela estende a legitimidade executiva. Se o executado originário, por exemplo, é o sócio, também a sociedade terá legitimidade para impugnar a decisão que defere a desconsideração²⁴. A decisão que julga o incidente deve condenar o vencido ao pagamento de honorários e custas, exceto quando sua instauração se dever à iniciativa do Ministério Público. Neste caso, não se pode dizer que o vencido tenha dado *causa* ao incidente. Sobre a distribuição dos custos no processo e a regra da causalidade, confirmam-se os comentários ao art. 82.

2. Natureza da decisão, coisa julgada e ação rescisória. A decisão, que acolhe ou rejeita a desconsideração da personalidade jurídica, é uma decisão, fundada em cognição exauriente, que julga o *mérito* do incidente de desconsideração (julgando procedente ou improcedente uma demanda incidental cujo objeto é o pedido de extensão da legitimidade executiva passiva a um terceiro). Ainda quando se tratar de uma decisão interlocutória. Por isso, como qualquer decisão de mérito, ainda que o mérito do incidente não se confunda com o mérito da demanda em cujo processo se instaurou o incidente, ela é atingida pela imutabilidade da coisa julgada material naquilo, obviamente, que foi explicitamente decidido²⁵. Deste modo, as partes do incidente não poderão futuramente, no mesmo processo ou ainda em outro qualquer, recolocar eficazmente em discussão a questão da extensão ao terceiro da responsabilidade executiva decidida no incidente (efeito positivo da coisa julgada material)²⁶. Por este mesmo motivo, a decisão que julga o mérito do incidente, ao transitar em julgado, é impugnável mediante ação rescisória²⁷.

Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, processualmente falando²⁸, como se viu com mais detalhes nos comentários ao art. 133, é uma modalidade coata (não voluntária) de intervenção de terceiros mediante a qual se pede o reconhecimento, em certos casos autorizados pelo direito material²⁹⁻³⁰, da extensão a alguém que

não é parte da legitimidade passiva à execução forçada neste processo, atual ou futura e eventual³¹. Trata-se, assim, de uma demanda incidental ao processo em curso cujo mérito é o pedido de extensão da responsabilidade executiva a um terceiro³².

2. Fraude de execução e ineficácia de atos dispositivos ou de oneração. Fraude de execução, como se sabe, “*consiste na realização de um ato de disposição ou oneração de coisa ou direito depois de instaurado um processo cujo resultado poderá ser impossível sem lançar mão deste bem*”³³. A sanção jurídica aplicável à alienação em fraude à execução é a sua ineficácia em relação ao prejudicado (art. 792, § 1º). Ao contrário, assim, do que possa sugerir seu nome, a fraude de execução não pressupõe, necessariamente, uma execução pendente; basta a prática em um processo pendente de um dos atos tipificados em lei como fraudulentos (art. 792). Segundo define o *caput* do art. 137, um destes atos é exatamente a alienação ou a oneração de bens “*a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar*” (art. 792, § 3º). Sendo este o caso, o ato será ineficaz em relação ao requerente a partir do momento em que o terceiro é citado, se a desconsideração vier a ser deferida. Mas o reconhecimento da fraude, de todo modo, como expressamente ressalva o disposto no art. 792, § 4º, exigirá sempre a intimação prévia do adquirente para defender-se, “*que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias*”. Esta é a solução, adequada, encontrada pela lei para conciliar a tutela da vítima da alienação com a do terceiro que possa estar de boa-fé.

NOTAS DE RODAPÉ

1

O conceito *processual* de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com o conceito *material* que lhe serve de fundamento. Neste sentido, por exemplo, Flávio Luiz Yarshell, Comentários ao novo Código de Processo Civil (Cabral/Cramer), p. 230, e Marcelo Abelha, *Manual de direito processual civil*, p. 280.

2

É neste sentido que se diz que “o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei” (parágrafo primeiro).

4

Sobre o momento para a formulação do pedido de desconsideração, confirmam-se os comentários ao art. 134.

5

Independentemente da natureza da prestação executada ou eventualmente a ser executada, se pecuniária ou não. Sobre o conceito de *responsabilidade pessoal*, em contraposição àquela sobre o patrimônio: José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 937.

6

“O instituto tem como objetivo viabilizar o que a prática forense consagrou com o nome de

‘redirecionamento’ da execução ou, de forma mais precisa, criar condições para que, ao longo do processo (de forma incidental, portanto, daí o nome ‘incidente’), sejam apuradas as razões pelas quais o direito material autoriza a responsabilização de pessoas naturais por atos praticados por pessoas jurídicas. O CPC de 2015 vai além e admite também o emprego do mesmo incidente para a hipótese de querer responsabilizar pessoa jurídica por atos praticados pelas pessoas naturais que a controlam ou comandam (...). O que o CPC de 2015 exige, destarte, é que as razões de direito material que justificam a responsabilização do sócio pela pessoa jurídica (e vice-versa, no caso da ‘desconsideração inversa’) sejam apuradas (e decididas) em amplo e prévio contraditório. Típico caso de transporte escorregio das realidades materiais para dentro do processo” (Cássio Scarpinella Bueno, Manual de direito processual civil, p. 158).

7

Com a ressalva de que “outra questão debatida em doutrina concerne à possibilidade de invocação defensiva da desconsideração pela própria pessoa jurídica demandada. Na desconsideração mínima (teoria menor), em que há responsabilidade tão somente subsidiária do sócio, e na desconsideração média, em que sócio e sociedade são materialmente uma só pessoa (de modo que, embora formalmente figurem como devedores solidários, afasta-se o regresso), por certo não há utilidade à pessoa jurídica na aplicação da *disregard*. Na desconsideração máxima, por sua vez, visto que tem o condão de imputar exclusivamente ao sócio o débito contraído através da personalidade jurídica, vislumbra-se potencial interesse da sociedade na invocação da teoria, com vistas a afastar a responsabilidade patrimonial” (Dalla / Fonseca, O incidente de desconsideração da personalidade jurídica no novo Código de Processo Civil, in: Coleção novo CPC (doutrina selecionada), vol. 1, p. 708 e p. 957).

8

O art. 28 do CDC, ao afirmar que o juiz *poderá* desconsiderar a personalidade jurídica, não lhe permite fazê-lo *ex officio*.

9

Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, p. 309.

10

Lembre-se que o pedido de desconsideração é uma *demanda incidental*.

11

Como esclarece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador. É possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva” (REsp 1236916/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.^a Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013).

12

Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 106.

13

Mas não em grau recursal. Os tribunais só deverão processar e julgar o incidente quando originária a sua competência. Neste sentido: Eduardo Vieira de Almeida; Gustavo Fávero Vaughn, A instauração do incidente de desconconsideração da personalidade jurídica em grau recursal, *Revista de Direito Privado* 85 (2018), item 5.

14

José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 228.

15

“Vogando nas águas de Brinz, cuja doutrina Savigny longamente expõe e critica, o qual a princípio não encontrou senão opositores, e que só mais tarde logrou a compreensão de Isay, Bekker, Perozzi, Carnelutti, irmãos Mazeaud, Serpa Lopes, Orosimbo Nonato, Pellete (e muito mais), a doutrina moderna exerga na obrigação um débito (*Schuld*) e uma garantia (*Haftung*). O primeiro é o dever de prestar, que facilmente se identifica, mas que não deve ser confundido com o objetivo da obrigação. Este *debitum* (*Schuld*) mora na sua essência mesma, e exprime o dever que tem o sujeito passivo da relação obrigacional de prestar, isto é, de realizar uma certa atividade em benefício do credor, seja ela um *dare*, um *facere* ou um *non facere*. Fundamentamente traduz o dever jurídico que impõe ao devedor um pagamento, e que se extingue se esta prestação é executada espontaneamente. Em contraposição, o sujeito ativo tem a faculdade de reclamar dos réus *debendi* a prestação daquela atividade ou de exigir o pagamento e mobilizar as forças cogentes do Estado no sentido de assegurar o cumprimento da obrigação. Nesta existe, portanto, um princípio de responsabilidade que o integra (*Haftung*) e permite ao credor carrear uma sanção sobre o devedor...” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 2, p. 181). Também Orosimbo Nonato, *Curso de obrigações*, vol. 1, p. 113.

16

“Importante, ainda, é registrar que este incidente vem assegurar o pleno respeito ao contraditório e ao devido processo legal no que diz respeito à desconconsideração da personalidade jurídica. É que sem a realização desse incidente o que se via era a apreensão de bens de sócios (ou da sociedade, no caso de desconconsideração inversa) sem que fossem eles chamados a participar, em contraditório, do processo de formação da decisão que define sua responsabilidade patrimonial, o que contraria frontalmente o modelo constitucional de processo brasileiro, já que admite a produção de uma decisão que afeta diretamente os interesses de alguém sem que lhe seja assegurada a possibilidade de participar com influência na formação do aludido pronunciamento judicial (o que só seria admitido, em caráter absolutamente excepcional, nas hipóteses em que se profere decisão concessiva de tutela provisória, e mesmo assim, somente nos casos nos quais não se pode aguardar pelo pronunciamento prévio do demandado)” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 95).

Também *José Miguel Garcia Medina*, *Direito processual civil moderno*, p. 311.

Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 136.

É por isso que “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrigli, 3.^a Turma, j. 03.08.2017, *DJe* 10.08.2017).

Desde que verificados, naturalmente, os requisitos exigidos pela lei (“a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, como enuncia o art. 300).

Com a ressalva de que “a parte que seria beneficiária da desconconsideração (normalmente o autor da ação) também terá o direito de produzir provas e participar ativamente da instrução jurídica e probatória, mesmo quando a instauração do incidente não houver decorrido de pleito seu” (*Wambier/Talamini*, *Curso avançado de processo civil*, p. 376).

“Segue-se aqui a regra geral; quem alega, prova (art. 134, § 4º). Inexistindo prova das alegações que permitem a desconconsideração, tem-se que julgar de acordo com as regras do ônus da prova (art. 373). Qualquer das partes do incidente pode se valer de todo e qualquer meio de prova legalmente admitido para prova das respectivas alegações” (*Marinoni/Arenhart/Mitidiero*, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 107).

O que ocorrerá apenas, como se viu nos comentários ao artigo 134, quando se tratar de decisão proferida por relator de processo de competência originária do tribunal. Caso contrário, o pedido de desconconsideração deve ser formulado perante o juízo de 1.^a instância.

“O interesse na desconconsideração ou, como na espécie, na manutenção do véu protetor, podem partir da própria pessoa jurídica, desde que, à luz dos requisitos autorizadores da medida excepcional, esta seja capaz de demonstrar a pertinência de seu intuito, o qual deve sempre estar relacionado à afirmação de sua autonomia, vale dizer, à proteção de sua personalidade. Assim, é possível, pelo menos em tese, que a pessoa jurídica se valha dos meios próprios de impugnação existentes para defender sua autonomia e

regular administração, desde que o faça sem se imiscuir indevidamente na esfera de direitos dos sócios/administradores incluídos no polo passivo por força da desconsideração” (REsp 1421464/SP, Rel. Ministra Nancy Andrichi, 3.^a Turma, julgado em 24.04.2014, *DJe* 12.05.2014).

25

Neste sentido: “É possível, também, cogitar coisa julgada material decorrente de decisões proferidas em incidentes processuais. O incidente processual é procedimento que também tem o seu objeto litigioso (mérito), que, uma vez resolvido em cognição exauriente, poder dar ensejo à coisa julgada” (*Didier Jr./Braga/Oliveira*, Curso de direito processual civil, vol. 2, p. 545). A decisão do incidente de desconsideração, assim, “resolve um pedido. Como tal, é decisão de mérito, apta à coisa julgada e a à ação rescisória” (*Fredie Didier Jr .*, Curso de direito processual civil, vol. 1, p. 528). Este o motivo por que equivocado o entendimento de que “o ato que determina a desconsideração da personalidade jurídica em caráter incidental no curso de processo de execução não faz coisa julgada, por possuir natureza de decisão interlocutória” (REsp 1.572.655/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3.^a Turma, j. 20.03.2018, *DJe* 26.03.2018).

26

“A decisão de improcedência do pedido declara a impossibilidade de desconsiderar-se a personalidade jurídica (efeito declaratório negativo). A decisão de procedência declara o direito à desconsideração (efeito declaratório positivo) e desconstitui a eficácia da personalidade jurídica da sociedade, para o fim de atingir-se o patrimônio dela (na desconsideração invertida) ou o do sócio (na desconsideração em sentido estrito), no processo em curso. A decisão de procedência da desconsideração opera seus efeitos relativamente ao processo em curso (e eventualmente a outros, entre as mesmas partes, que versem sobre causas que estejam em relação de prejudicialidade com a ação principal daquele processo). A desconsideração ali decretada, portanto, não é ampla e genérica. Até porque os pressupostos justificadores da desconsideração variam conforme o contexto da relação jurídico-material e as circunstâncias concretas. Por exemplo, um sócio que se utilizou em caráter abusivo e em desvio de finalidade de sua sociedade para lesar o fisco pode não ter feito o mesmo relativamente aos consumidores que adquiriram produtos dessa sua empresa. Em suma, a decisão determinando a desconsideração de personalidade jurídica num dado caso concreto não tem como genericamente ser utilizada em outros casos (ainda que a prova ali produzida possa vir a ser aproveitada em outros processos e incidentes em que se busque o reconhecimento da desconsideração para outros fins)” (*Wambier/Talamini*, Curso avançado de processo civil, p. 377).

27

José Miguel Garcia Medina, Direito processual civil moderno, p. 229.

28

O conceito *processual* de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com o conceito *material* que lhe serve de fundamento.

29

É neste sentido que se diz que “o pedido de desconconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei” (art. 133, § 1º).

31

Sobre o momento para a formulação do pedido de desconconsideração, confirmam-se os comentários ao art. 134.

32

Independentemente da natureza da prestação executada ou eventualmente a ser executada, se pecuniária ou específica.

33

Cândido Dinamarco, Instituições de direito processual civil, vol. 4, p. 440.

3

Sobre as hipóteses de cabimento da desconconsideração da personalidade jurídica, a bibliografia é copiosa. Para uma resenha sobre as diversas teorias: *Calixto Salomão Filho*, O novo direito societário, p. 232.

30

Sobre as hipóteses de cabimento da desconconsideração da personalidade jurídica, a bibliografia é copiosa. Para uma resenha sobre as diversas teorias: *Calixto Salomão Filho*, O novo direito societário, p. 232.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018**TÍTULO III - DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS****CAPÍTULO V - DO AMICUS CURIAE**

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1.º A intervenção de que trata o *caput* não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3.º.

§ 2.º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3.º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – Rule 37 das Supreme Court Rules norte-americanas.

1. *Amicus curiae*. O *amicus curiae* é uma figura típica do *common law* ¹ a que o direito brasileiro vem, ao menos desde meados da década de 1960, dando cada vez mais relevância. ² Ao contrário do que fazia o Código de Processo Civil de 1973, que não o regulava, procurou o Código de Processo Civil de 2015 não apenas dar tratamento sistemático a este instituto, mas a generalizar sua aplicação antes prevista apenas fragmentadamente na legislação especial. ³ E o fez em seu art. 138, incluindo o *amicus curiae* expressamente entre as diversas modalidades de intervenção de terceiros.

O *amicus curiae* é um terceiro que se torna sujeito do processo, mas não parte, ⁴ voluntariamente, a convite ou por iniciativa própria, ⁵ intervindo não para defender uma posição jurídica de que alega ser titular ou sobre a qual possa ter algum interesse jurídico, ⁶ mas para fornecer ao juízo ⁷ subsídios, interessada ou desinteressadamente, que possam ser úteis para o julgamento da causa ou do recurso quando esta causa ou recurso se revestir de uma relevância especial que justifique a intervenção.

2. Cabimento. A intervenção do *amicus curiae* é admissível em qualquer momento do processo e em qualquer procedimento ⁸. Poderá intervir no processo, na qualidade de *amicus curiae*, qualquer “pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada” quando o justificar “a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”. Estes pressupostos não devem ser interpretados literalmente. Será o juiz, em cada caso concreto, se não estiver obrigado a admitir a intervenção com fundamento em algum dispositivo especial, ⁹ que decidirá se a natureza e a complexidade da controvérsia justificam a intervenção, se o momento em que ela é requerida é ainda adequado e oportuno (elemento objetivo) e se as qualidades e o histórico do potencial *amicus curiae* sugerem que sua contribuição pode se revelar útil de alguma maneira para o julgamento (elemento subjetivo). ¹⁰ A natureza do processo, em outras palavras, se objetiva ou subjetiva, na distinção que faz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não determina, *em tese*, a admissibilidade ou não da intervenção do terceiro como *amicus curiae*. Ela é antes um fator que o julgador deve levar em consideração, concretamente, ao avaliar a conveniência da intervenção naquele processo

específico em que ele decidirá¹¹. Esta dimensão discricionária da decisão sobre a admissão do *amicus curiae* torna-se ainda mais evidente quando se verifica que a lei a tornou irrecurável, independentemente se positiva ou negativa (*caput*)¹². Trata-se, afinal, de um *amicus curiae*, não de um *amicus partis*. Em resumo: “consoante o *caput* do art. 138, do CPC/2015, o ingresso no processo como *amicus curiae* deve ser avaliado pelo julgador, o qual, em decisão irrecurável, apreciará a necessidade e utilidade da participação do requerente na demanda, tendo como elementos de formação da convicção a relevância da matéria, especificidade do tema ou repercussão social da controvérsia”¹³.

A lei não impõe um limite máximo ao número de pessoas que podem intervir no processo na qualidade de *amici curiae*.¹⁴ Mas o juiz deve estar atento, ao decidir sobre sua admissão, ao tumulto processual que a intervenção de um número exagerado de pessoas pode causar ao bom andamento do processo. Deve também preocupar-se em manter um equilíbrio razoável entre o número de *amici curiae* interessados na vitória de cada um dos lados. Um número exageradamente maior de um lado criará uma sensação artificial de maioria ou mesmo unanimidade que compromete indevidamente a garantia da paridade de armas (*Waffengleichheit*).¹⁵

Não se exige do *amicus*, no entanto, imparcialidade. Sua intervenção, com efeito, pode dar-se tanto *interessadamente*, na esperança de contribuir para a vitória de uma das partes, quanto *desinteressadamente*, apenas para dar ao juízo subsídios úteis ao julgamento. No primeiro caso, frequentemente, mas nem sempre, o próprio terceiro requererá sua intervenção (por exemplo, uma associação dedicada à defesa de determinada bandeira). No segundo, na maioria das vezes, o terceiro será convidado pelo próprio juiz para manifestar-se (por exemplo, um professor universitário especializado na matéria controvertida). Por este motivo, as regras sobre impedimento e suspeição não se aplicarão nunca ao *amicus curiae*.

3. Posição e poderes do *amicus curiae*. O *amicus curiae*, como se explicou, torna-se sujeito do processo ao intervir, mas não parte.¹⁶ Ele, a rigor, não demanda nem contra ele é demandado. Por isso, não se submete aos efeitos da sentença que vier a ser proferida no processo nem tampouco se vincula à coisa julgada material nele formada. A lei não estabelece, em relação a ele, qualquer exceção à regra geral segundo a qual “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros” (art. 506). Para falar nos autos, ademais, não se exige do *amicus curiae* que esteja representado por advogado. Para interpor recursos, todavia, falta-lhe capacidade postulatória para fazê-lo sem a devida representação.

Caberá ao juiz ou ao relator, “na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*” (§ 2.º), embora em relação à sua extensão existam limites mínimos e máximos. A lei garante ao *amicus curiae*, minimamente, o direito de manifestar-se por escrito em quinze dias (*caput*). O oferecimento de um *amicus brief*, aliás, é justamente o papel típico do *amicus curiae*. Mas a lei lhe garante também legitimidade para opor embargos de declaração de decisões proferidas nos processos em que intervém (§ 1.º) e, ainda, legitimidade para interpor recursos de acórdãos proferidos em julgamentos repetitivos (no incidente de resolução de demandas repetitivas e, analogicamente, também no julgamento de recursos repetitivos, conforme o § 3.º¹⁷). Estes direitos dizem respeito, diretamente, à função do *amicus curiae*, que é a de contribuir com subsídios úteis para o julgamento do mérito da demanda ou do recurso.

Permite-se ao juiz ainda ir além deste limite mínimo, reconhecendo ao *amicus*, por exemplo, o poder de “juntar documentos, elaborar quesitos para serem respondidos por peritos, fazer sustentação oral perante o tribunal, participar de audiências públicas etc.”.¹⁸ O que não se permite, no entanto, é que estes poderes *desnaturem* o papel do *amicus curiae*, de maneira a transformá-lo em litisconsorte ou assistente de uma das partes. Embora irrecurável a decisão que defere ou indefere a intervenção, esta irrecorribilidade não se estende ao capítulo da decisão que tratar dos poderes do *amicus curiae*. Ultrapassados os limites mínimos e máximos, cabe recurso em relação a este ponto.

Ao decidir, o juiz não se encontra, obviamente, vinculado à opinião oferecida pelo *amicus* em

suas manifestações. O que ele não pode fazer, no entanto, é ignorar os argumentos por ele expostos, deixando de enfrentá-los ao julgar. Esta exigência é bem resumida no enunciado n. 128 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis, segundo o qual “no processo em que há intervenção do *amicus curiae*, a decisão deve enfrentar as alegações por ele apresentadas, nos termos do inciso IV do § 1.º do art. 489”.

4. *Amicus curiae* e competência. Pondo fim à controvérsia existente na vigência do CPC de 1973, o CPC de 2015 é explícito ao determinar que “a intervenção de que trata o *caput* não implica alteração de competência” (§ 1.º). Embora uma modalidade de intervenção de terceiros, a intervenção do *amicus curiae* não determina o deslocamento *ratione personae* de competência. Não incide neste caso, desta maneira, a regra segundo a qual compete aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho” (art. 109, I, CF/1988). E isso porque, embora eventualmente interessado em um determinado resultado, o *amicus curiae* não será nunca um sujeito *parcial* do processo.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Para um apanhado histórico detalhado: Cássio Scarpinella Bueno, *Amicus curiae no processo civil brasileiro*, p. 87.

2

“Diversas regras contidas em leis esparsas preveem hipóteses de intervenção que se enquadram na moldura geral do *amicus curiae*: art. 32 da Lei 4.726/1965 (Junta Comercial); Lei 6.385/1976 (Comissão de Valores Mobiliários – CVM); art. 7.º, § 2.º, da Lei 9.868/1999 (ADI); art. 6.º, § 1.º, da Lei 9.882/1999 (ADPF); art. 14, § 7.º, da Lei 10.259/2001 (Súmula vinculante); art. 118 da Lei 12.529/2011 (Cade); art. 896-C, § 8.º, da CLT, acrescido pela Lei 13.015/2014 (recursos de revista repetitivos)” (Wambier/Talamini, *Curso avançado de processo civil*, p. 379).

3

Neste sentido se diz que “nosso Código de Processo Civil resolveu acertadamente tornar *atípica* a possibilidade de intervenção a título de *amicus curiae* no processo civil brasileiro” (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 98).

4

O *amicus curiae* não se torna parte porque ele a rigor nada pede nem contra ele nada é pedido. Ele não deduz nem contra ele é deduzida uma pretensão processual.

5

Nunca coativamente. O *amicus curiae* só intervém se quiser fazê-lo, ainda quando for convidado para ingressar. Mas seu ingresso depende da autorização do juiz, conforme explicado mais adiante.

6

Por isso, a figura do *amicus curiae* não se confunde com a do assistente.

7

Daí por que *amigo da corte*.

8

“A atuação do *amicus curiae*, dada sua limitada esfera de poderes (e, conseqüentemente, sua restrita interferência procedimental), é cabível inclusive em procedimentos especiais em que se veda genericamente a intervenção de terceiros – sobretudo naqueles que são regulados por leis anteriores ao CPC. O veto deve ser interpretado como aplicável apenas às formas de intervenção em que o terceiro torna-se parte ou assume subsidiariamente os poderes da parte. Assim, cabe ingresso de *amicus* em processo do juizado especial, bem como no mandado de segurança” (Eduardo Talamini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas), p. 468).

9

Segundo o art. 31 da Lei 6.385/1976, por exemplo, “nos processos judiciais que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação”. Este é um caso em que a CVM tem a prerrogativa *ex lege* de intervir na qualidade de *amicus curiae*, se quiser, independentemente da conveniência processual concreta desta intervenção aos olhos do juiz.

10

“Nas sandálias de Hermes, sabemos que o *amicus curiae* pode trazer informações desnecessárias ou até inverídicas, movido mesmo por interesses meramente econômicos de duvidosa idoneidade. Cabe, assim, ao magistrado, estar atento à relevância da matéria trazida a lume pelo amigo da Corte e, ao mesmo tempo em que permitir a participação social mediante o processo, não deixar que a intervenção do *amicus* represente um estorvo para a prestação jurisdicional, um descompasso procedimental que possa importar, por exemplo, em injustificada demora” (Antônio do Passo Cabral, *Pelas asas de Hermes: a intervenção do amicus curiae, um terceiro especial. O amicus e o Vertreter des öffentlichen Interesses. Revista de Processo*, vol. 117, p. 39).

11

“A orientação jurisprudencial da 1.^a Seção deste Sodalício é no sentido de que o ingresso de *amicus curiae* é previsto para as ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a ser proferido. Não é admitido o ingresso quando a pretensão é dirigida para tentar assegurar resultado favorável a uma das partes envolvidas” (AgInt na PET no REsp 1.700.197/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.^a Turma, j. 19.06.2018, DJe 27.06.2018).

12

“A interpretação atribuída ao [art. 138 do CPC/2015](#) é no sentido de que é irrecurível ‘qualquer decisão a respeito da intervenção de terceiro como *amicus curiae*’” ([AgInt na PET no REsp 1.700.197/SP](#), rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.^a Turma, j. 19.06.2018, *DJe* 27.06.2018).

13

AgInt na PET no [AREsp 1.139.158/MG](#), rel. Min. Sérgio Kukina, 1.^a Turma, j. 12.06.2018, *DJe* 19.06.2018).

14

Fredie Didier Jr., Curso de direito processual civil, vol. 1, p. 530.

15

Max Vollkommer, Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess, in: *FS Schwab*, p. 503.

16

Paulo César Pinheiro Carneiro, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral; Cramer), p. 250.

17

“Em razão da existência de um microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928 CPC), a permissão de interposição de recursos deve estender-se ao julgamento de recursos especiais ou extraordinários repetitivos” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 530).

18

Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 108.

TÍTULO IV - DO JUIZ E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

1. Sujeito do processo é todo aquele que, no processo, pratica um ato processual (um ato destinado a produzir efeitos no processo). Todo sujeito do processo realiza atos processuais (mais de um, ou mesmo apenas um¹), mas nem todo ato processual é praticado por um sujeito do processo (quando um ato, embora processual, é realizado fora do processo – por exemplo, na eleição de foro²). Classificam-se os sujeitos do processo em sujeitos *parciais* e sujeitos *imparciais*. A distinção é relevante, por exemplo, para a definição de sobre quem incidem os efeitos das decisões proferidas no processo e ainda de quem se exige imparcialidade para nele figurar como um de seus sujeitos.

2. Serão sujeitos parciais não apenas aquele que deduz uma demanda e aquele contra quem a demanda é deduzida (partes, isoladamente ou em litisconsórcio³), mas também aqueles que intervêm no processo para coadjuvar uma das partes (assistentes). Parcialidade aqui é expressão empregada em sentido mais restrito, que não esgota as situações em que um sujeito do processo possa querer que uma das partes vença. É o caso, por exemplo, do advogado de uma das partes ou do *amicus curiae*; eles são sujeitos do processo, interessados (o advogado necessariamente, o *amicus curiae* apenas eventualmente) na vitória de uma delas, mas não sujeitos parciais do processo⁴.

3. Serão sujeitos *imparciais* do processo, por seu turno, o juiz, que apresenta o Estado *imparcialmente* no processo, e os auxiliares da justiça, que prestam auxílio ao juiz *desinteressadamente*⁵ no exercício da função jurisdicional. Com o papel e os poderes do juiz no processo, ocupa-se o capítulo I deste título (arts. 139 a 143); com as regras sobre impedimento e suspeição, o capítulo II (arts. 144 a 148). No capítulo III, trata a lei das diversas espécies de auxiliares da justiça (arts. 149 a 175).

4. Nem todo sujeito será *parcial* ou *imparcial*, no sentido estrito em que estas expressões são aqui empregadas. O advogado que representa uma das partes, por exemplo, não demanda nem é demandado. Por isso não é um sujeito parcial do processo. Mas dele também não se exige, obviamente, imparcialidade. Por isso não é tampouco um sujeito imparcial. A classificação dos sujeitos do processo em parciais e imparciais, assim, útil embora à solução de diversos problemas práticos⁶, não é exaustiva. *Tertium datur*.

NOTAS DE RODAPÉ

1

O autor pratica inúmeros atos, a começar pela demanda. O juiz substituto, que profere apenas uma única decisão nas férias do titular, pratica apenas um ato processual.

2

Na eleição de foro, o agente só se tornará sujeito do processo se um vier depois a existir, mas a eleição de foro é um ato – *rectius*, um negócio – genuinamente processual porque seus efeitos destinam-se a se produzir em um processo, ainda que futuro e eventual. A parte do contrato que contém uma cláusula de eleição de foro não será, necessariamente, parte do eventual processo. Suponha-se que, dos três contratantes, apenas dois litiguem entre si. O terceiro terá realizado o ato processual, mas não será sujeito do processo.

3

E não necessariamente desde o início do processo. O denunciado à lide, por exemplo, é demandado, motivo pelo qual é parte e, consequentemente, também um sujeito *parcial* do processo.

4

No caso do *amicus curiae*, seu eventual interesse na vitória de uma das partes não será propriamente jurídico, como se viu nos comentários ao art. 138. Por isso ele não se confunde com a figura do assistente.

5

No sentido de que se exige dos auxiliares da justiça a mesma imparcialidade que se exige do juiz.

6

Por exemplo, como se disse, para a definição de sobre quem incidem os efeitos das decisões proferidas no processo e de quem se exige imparcialidade para nele figurar como um de seus sujeitos.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO IV - DO JUIZ E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

CAPÍTULO I - DOS PODERES, DOS DEVERES E DA RESPONSABILIDADE DO JUIZ

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I – assegurar às partes igualdade de tratamento;

II – velar pela duração razoável do processo;

III – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

V – promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais;

VI – dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito;

VII – exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais;

VIII – determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso;

IX – determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

X – quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5.º da Lei 7.347, de 24.07.1985, e o art. 82 da Lei 8.078, de 11.09.1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.

Parágrafo único. A dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular.

Direito anterior – art. 125 do CPC/1973

Direito comparado – arts. 3.º e 3A do CPC português

1. O papel do juiz no processo

Como ensina Barbosa Moreira, “uma das coordenadas que definem qualquer sistema judicial é a posição do juiz na dinâmica do processo”¹. O processo civil brasileiro, no regime do CPC de 1973, caracterizava-se por um evidente protagonismo do juiz, julgador do fato e do direito a quem se reconhecia quase absoluto poder para determinar como o processo deveria desenrolar-se. Neste sistema, o processo assemelha-se muito mais a uma “comunidade de trabalho” (*Arbeitsgemeinschaft*)² ordenada e presidida por um burocrata do que a um duelo protagonizado pelos contendores no qual a função precípua do juiz é a de zelar pela observância das regras do

jogo. O CPC de 2015 não fez do juiz brasileiro, obviamente, seu congênere norte-americano; retirou-lhe, no entanto, muito do exacerbado protagonismo característico do “publicista” CPC de 1973³.

Inegavelmente, o legislador brasileiro foi sensível à influência do pensamento a que Barbosa Moreira, com boa dose de ironia, escolheu chamar de “neoprivatismo no processo civil”⁴. Esta opção da lei por retirar do juiz parte da centralidade que a legislação anterior lhe reconhecia deve, assim, servir de norte interpretativo na aplicação dos dispositivos legais que tratam dos poderes do juiz. Continua a lhe caber, em suma, *dirigir* o processo (*caput*), que, aliás, “se desenvolve por impulso oficial” (art. 2.º), mas sempre cooperativamente (art. 6.º) e sem ultrapassar os limites (por exemplo, aqueles autorizados pelo art. 190) que lhe são impostos por um Código manifestamente mais *privatista* que o anterior.

2. Igualdade de tratamento (paridade de armas)

O direito constitucional ao juiz natural não significa apenas que as partes têm o direito de serem julgadas por um juiz competente e imparcial⁵. E isso porque a Constituição não exige do juiz apenas seu desinteresse *subjetivo* sobre quem vai ganhar demanda ou não, mas lhe exige ainda que conduza o processo de modo *objetivamente* desinteressado. O juiz natural, em outras palavras, não é apenas aquele que não *quer* em seu íntimo que uma das partes vença, mas aquele que ao conduzir o processo se *comporta* como se não o quisesse. A este direito das partes, expresso no disposto no art. 7.º do CPC, segundo o qual “é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”, *corresponde o dever do juiz de “assegurar às partes igualdade de tratamento”* (inciso I).

O respeito a esta igualdade formal de tratamento (*formelle Waffengleichheit*) não dispensa o juiz – muito ao contrário – de observar também a igualdade material de tratamento (*materielle Waffengleichheit*)⁶. O juiz deve assim tratar as partes de modo desigual, desde que alguma razão especial justifique este tratamento e desde que a desigualdade no tratamento seja proporcional à desigualdade que ela tem por fundamento⁷. É por este motivo, por exemplo, que a Constituição tolera a regra segundo a qual “a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais” (art. 183) e também por que as regras sobre gratuidade de justiça aplicam-se apenas a algumas partes, não a todas (art. 83), mas não o tratamento exageradamente benéfico ao Poder público em juízo representado pela extensão do prazo para o ajuizamento de ação rescisória⁸. Mas o tratamento desigual não dependerá necessariamente de prévia e expressa autorização legal. Permite-se ao juiz, por exemplo, levar em consideração a desigualdade entre as partes ao decidir sobre *forum non conveniens*. A exigência constitucional de proporcionalidade, entretanto, é indispensável.

3. Duração razoável do processo

A Constituição Federal reconhece expressamente em seu art. 5.º, LXXVIII, na redação que lhe deu a Emenda 45, de 2004, a garantia à “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”⁹. Os contornos deste direito são melhor delineados pelo art. 4.º do CPC, segundo o qual “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. A este direito corresponde o dever do juiz de “velar pela duração razoável do processo” (inciso II)¹⁰. Sua violação ocorrerá, por exemplo, quando o juiz fizer uso exagerado e desnecessário de seu poder de determinar de ofício a realização de provas (abuso de seus poderes instrutórios) ou ainda quando descumprir certos prazos que a lei lhe assinala em caráter peremptório¹¹. O descumprimento deste dever pode ser encarado sob o prisma da *responsabilidade* do Estado (objetiva) e do próprio juiz (subjetiva)¹² pela reparação dos prejuízos que a duração não razoável de um processo possa ter causado a um litigante. Pode ser também encarado *intraprocessualmente*, no sentido, por hipótese, de tornar nula uma decisão (a que defere, por exemplo, uma terceira perícia sobre o mesmo objeto em um mesmo processo) ou ainda

de determinar a substituição de um julgador por outro (quando ocorrer, por exemplo, atraso na devolução de processo ou recurso em “vista” por integrante de órgão colegiado¹³).

4. Dever de zelar pelo bom andamento do processo

Incumbe também ao juiz, segundo o disposto no inciso III, “prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias”. A tutela processual da dignidade da justiça, com efeito, como se viu nos comentários ao artigo 77, serve ao juiz como instrumento que lhe permite dissuadir ou punir condutas que de algum modo obstruam, tumultuem ou prejudiquem o bom andamento do processo. Seu escopo é, por isso, a tutela de um interesse público (a administração da justiça¹⁴), e é também por este motivo que o juiz não tem apenas o poder de prevenir ou reprimir a prática do *contempt*, mas também o dever de fazê-lo. Este dever deve ser compreendido como uma concretização do dever mais amplo de *zelar pelo bom andamento do processo*. Por isso, não deve o juiz omitir-se quando sua intervenção for necessária para evitar a desordem ou para reestabelecer a ordem no desenrolar do processo. É também por este motivo que ele tem o dever de indeferir postulações meramente protelatórias que para nada servem, senão criar tumulto e delongas desnecessárias.

5. Atipicidade dos meios executivos

Um dos sintomas da radical evolução por que passou e ainda tem passado a execução no processo civil brasileiro¹⁵ é a crescente preocupação da lei em propiciar ao exequente, quando esta execução *específica* for possível e quando ele a quiser, a restauração *direta do interesse sacrificado* e não apenas da *utilidade que o bem sacrificado representava* mediante execução tradicional por expropriação (inespecífica, ou pecuniária, sobre o patrimônio do executado)¹⁶. Concebida na vigência do Código de Processo Civil de 1973 apenas para a execução específica, a aplicação do princípio da *atipicidade dos meios executivos* veio a ser generalizada pelo novo CPC a todas as espécies de execução, inclusive à pecuniária¹⁷. Compete assim ao juiz, segundo o inciso IV, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Conforme esclarece o art. 536, § 1.º, em caráter exemplificativo, “o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

A atipicidade dos meios executivos prevista neste dispositivo tem servido como campo fértil para a criatividade de advogados e juízes. Entendeu-se já possível, por exemplo, a suspensão do passaporte ou da carteira de motorista do executado, embora o tema seja ainda extremamente controverso¹⁸, tanto na doutrina¹⁹ quanto na jurisprudência²⁰. Nada há de inconstitucional, *em si*, na atipicidade, que deve ser interpretada e aplicada, no entanto, nos limites impostos pela Constituição. E ela deve sê-lo, mais especificamente, à luz da *patrimonialidade* da execução²¹. A ideia é a de que, para a tutela de um direito de natureza patrimonial, apenas direitos de natureza *também* patrimonial – mas não necessariamente apenas o patrimônio do executado – devem poder ser atingidos na execução, e, mesmo assim, desde que respeitada a dignidade do executado.

É por isso, por exemplo, que para a execução de um crédito (natureza patrimonial²²) não se pode limitar o direito do executado a *votar, viajar, dirigir, sair de casa quando quiser*, manter seu CPF. Mas há direitos patrimoniais cuja limitação revela-se razoável, sem que se ofenda de modo intolerável a dignidade do executado: por exemplo, o direito de ter e usar cartões de crédito, de contrair empréstimos em instituições como o BNDES, ou ainda o direito de participar de licitações e contratar com o poder público. É razoável, por exemplo, a suspensão da linha de telefone celular do executado, mas não seu acesso à rede de água e esgoto, ou à de energia elétrica (dignidade do executado como limitador).

O juiz deve levar em conta ao decidir, de todo modo, a existência de indícios de que o executado *pode cumprir*, mas que se recusa a fazê-lo não apenas de modo a frustrar a satisfação da pretensão

executada, mas também de modo a desafiar a autoridade da Justiça²³. A regra, em outras palavras, não deixa de continuar a ser o uso das medidas típicas e o de medidas atípicas a exceção²⁴.

Em relação à execução pecuniária, a atipicidade dos meios executivos passa a permitir a aplicação pelo juiz de *astreintes*, sem prejuízo da incidência da multa de 10% e de honorários de que trata o art. 523, § 1.º Mas sempre à luz do entendimento, fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento repetitivo, de que a sua função é a de “desestimular a inércia injustificada do sujeito passivo em cumprir a determinação do juízo, mas sem se converter em fonte de enriquecimento do autor/exequente. Por isso que a aplicação das *astreintes* deve nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”²⁵. Por este motivo, ao contrário do que ocorre com a multa do art. 523, § 1.º, cuja incidência decorre *do simples fato* do inadimplemento, independentemente de qualquer outra consideração, a fixação de *astreintes* na execução pecuniária é algo excepcional e deve ser sempre devidamente fundamentada. O mero inadimplemento não autoriza sua cominação; exige-se a comprovação, ao menos indiciariamente, de que o executado *pode* pagar, mas se recusa abusivamente a fazê-lo. A imposição de multa contra um devedor de boa-fé, mas sem recursos, violaria sua dignidade e não deve ser tolerada²⁶.

6. Estímulo à autocomposição

As partes têm o direito constitucional de verem sua pretensão processual julgada pelo Poder Judiciário (art. 5.º, XXXV, da CF), desde que preenchidas as condições de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda. Por este motivo, não poderão nunca ser *coagidas* a chegarem a uma solução consensual para o litígio. Viola esta garantia constitucional o juiz que, abusando de sua prerrogativa de estimular a solução consensual do litígio, constrange as partes a transacionarem ou que as pune por recusarem-se a fazê-lo. A recusa a uma proposta de acordo, ainda que imotivada, é assim um *direito* das partes. Trata-se de uma escolha *não sindicável* pelo juiz, a quem não se permite julgar se correta, adequada ou abusiva a recusa.

A circunstância de que as partes não podem ser constrangidas a chegarem a uma solução consensual para o litígio não faz com que o juiz não possa, se entender conveniente, determinar a elas, no curso do processo²⁷, que *tentem* chegar a uma solução consensual. Daí, por exemplo, a opção do CPC pela realização quase obrigatória da audiência de conciliação ou mediação de que trata o art. 334²⁸. Esta audiência é um momento *típico* para a tentativa de solução consensual, mas não o único. Permite-se ao juiz, com efeito, *em qualquer momento do processo*, se entendê-lo conveniente, determinar às partes que *tentem* chegar a uma solução consensual para o litígio. Poderá fazê-lo pessoalmente, em audiência com as partes, ou ainda mediante a determinação da remessa dos autos do processo a um mediador ou conciliador devidamente habilitado. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários aos artigos 165 e seguintes.

7. Adequação (jurisdicional) do processo

O CPC de 2015 optou, no espírito *privatista* que o anima, por dar às partes maior liberdade para moldar o processo conforme suas preferências pessoais (mediante a celebração de negócios jurídicos processuais) do que o permitia o *publicista* CPC de 1973. Por este mesmo motivo, entendeu por bem o legislador restringir as possibilidades de flexibilização procedimental por iniciativa do juiz debatidas durante o processo legislativo que levou à promulgação do novo Código²⁹. Rejeitou-se ao final, assim, a adoção do método do *case management*³⁰. A despeito disso, é ainda possível falar-se de um *princípio da adequação (jurisdicional) do processo* no direito brasileiro, princípio este que se manifesta tanto em hipóteses típicas, como aquela prevista no inciso VI, quanto atipicamente, sem a “intermediação de regras que o concretizem”³¹.

Segundo o inciso VI, assim, permite-se ao juiz “dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito”. A possibilidade de alteração pelo juiz da ordem de produção dos meios de prova não representa nenhuma novidade. Será o caso, por exemplo, quando o juiz optar por ouvir antes as testemunhas para apenas depois autorizar o início da perícia. Esta solução

pode contribuir para reduzir o escopo da prova pericial e torná-la menos demorada e custosa. De todo modo, apenas o caso concreto e suas particularidades dirão se esta inversão é oportuna. O juiz, enquanto destinatário da prova, goza de considerável discricionariedade para decidir sobre a ordem de sua realização.

A permissão *geral* para que o juiz dilate prazos processuais independentemente de qualquer autorização específica, diferentemente, consiste em uma grande inovação do CPC de 2015. Segue em boa hora a experiência do direito comparado³². São agora prorrogáveis todos os prazos, não apenas na hipótese de que trata o artigo 222³³, inclusive aqueles fixados pela lei (prazos legais) e tradicionalmente classificados como inalteráveis mesmo pela vontade do juiz (peremptórios). Prazo peremptório passa agora a significar o prazo que o juiz não pode reduzir sem a anuência das partes (art. 222, § 1.º), mas que pode ser por ele prorrogado à luz das particularidades do caso concreto³⁴. Sempre observados, necessariamente, a igualdade das partes, o contraditório e a razoabilidade. Suponha uma causa ambiental ou de engenharia de elevada complexidade. O autor tem meses para preparar a petição inicial. Instrui sua petição com dezenas, centenas ou mesmo milhares de páginas de documentos. Nada mais razoável que o juiz possa dilatar o prazo para o protocolo da contestação, independentemente da concordância do autor. A permissão para a dilação de prazos não autoriza o juiz, no entanto, a relevar a perda de prazos já consumados. É neste sentido o disposto no parágrafo único, segundo o qual “a dilação de prazos prevista no inciso VI somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo regular”.

8. Poder de polícia

Compete também ao juiz, segundo o inciso VII, “exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns e tribunais”. A expressão “poder de polícia” é empregada pela legislação processual em sentido um pouco diverso, embora obviamente conexo, em relação ao significado específico que lhe dá o direito administrativo³⁵. Seu sentido *no processo* é explicitado nos incisos do art. 360, segundo o qual o “juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe” manter “a ordem e o decoro na audiência” (inciso I), “ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente” (inciso II), “requisitar, quando necessário, força policial” (inciso III), “tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo” (inciso IV) e “registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência” (inciso V).

A ideia é a de que, ao exercer *no processo* a autoridade *administrativa* que a investidura lhe confere, o juiz deve zelar pelo seu bom andamento, durante a audiência ou em qualquer outra oportunidade em que tiver contato pessoal com as partes ou seus advogados. Ele deve, assim, “evitar qualquer desordem, indecência, má educação (o decoro), na audiência e em qualquer ato que então se pratique”³⁶. Permite-lhe assim a lei que determine a partes, advogados, testemunhas, peritos, e demais sujeitos do processo que se retirem da sala de audiência, provisória ou mesmo definitivamente, se se comportarem de modo inconveniente. Para manter ou reestabelecer a ordem, admitem-se até mesmo a requisição e o emprego de força policial. Faça-se apenas a ressalva de que, mesmo quando justificada, a expulsão de alguém não pode redundar na violação de direitos processuais, especialmente o contraditório e a ampla defesa. A audiência de instrução e julgamento deve ser suspensa, por exemplo, se se determinar a retirada da sala de audiência do único advogado de uma das partes. O exercício do poder de polícia, por fim, independe da competência do juiz, para punir a litigância de má-fé e a prática de atos contrários à dignidade da justiça. Antes serve para complementá-la.

9. Interrogatório das partes

Não embora sem algumas hesitações, adota o processo civil brasileiro o princípio da oralidade³⁷. E é com fundamento nele que se permite ao juiz “determinar, a qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso” (inciso VIII). Este *interrogatório* das partes, determinável *ex officio* e

em qualquer momento do processo, mesmo em fase recursal, não se confunde com o eventual depoimento pessoal da parte em audiência. Não se trata, a rigor, de um *meio de prova*, mas de um instrumento à disposição do juiz que lhe permite estabelecer um contato pessoal com as partes quando este contato lhe parecer útil ou necessário, independentemente da fase em que se encontrar o processo³⁸. Mesmo fora, portanto, da fase instrutória. A oralidade e a imediatidade permitem-lhe assim uma leitura mais precisa e direta da realidade dos fatos, sem o intermédio do *filtro* que as petições escritas redigidas por advogados representam. Suponha-se, por exemplo, demanda em que o autor pede a concessão de tutela de urgência. Se confusos os fatos, é razoável que o juiz determine o interrogatório da parte, de modo a esclarecer os pontos que não lhe parecem claros antes de decidir. Lamenta-se o fato de que os juízes brasileiros pouco ou quase nenhum uso façam deste poder que a lei lhes reconhece. Por não se tratar de um meio de prova propriamente dito, no entanto, não se admite no interrogatório a confissão ficta. Mas “nada impede que, durante o interrogatório a que se refere o art. 139, VIII, do CPC, ocorra, também, a confissão, que, no entanto, deverá ser expressa, não se admitindo confissão ficta, neste caso”³⁹.

10. Suprimento de defeitos processuais

Vem a doutrina sustentando, na vigência do CPC de 2015, a existência de um assim chamado princípio da primazia da decisão de mérito⁴⁰. Por força dele, o juiz *deve* esforçar-se para, na medida do possível, julgar o mérito da demanda, evitando a extinção do processo ou o não conhecimento de um recurso por motivos exclusivamente formais. É por esta exata razão que a lei diz incumbir ao juiz “determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais” (inciso IX). Trata-se de um autêntico dever do juiz, que lhe proíbe de sancionar um defeito processual qualquer, de extinguir o processo ou de não conhecer de um recurso, com fundamento em vícios *corrigíveis*, sem antes dar ao interessado a possibilidade de corrigi-lo⁴¹. A este dever de cooperar para a correção de vícios soma-se outro, o dever de julgar o mérito, *desde que possível*, a despeito da existência de um defeito e mesmo sem sua correção, quando a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria o eventual reconhecimento deste defeito (art. 488).

11. Intimação do legitimado ao ajuizamento da demanda coletiva

O CPC de 1973 nasceu em uma época em que ainda se concebia o processo civil apenas como um instrumento para a solução de litígios entre pessoas individualmente consideradas⁴². A extraordinária massificação dos litígios vivenciada no Brasil nas últimas décadas acabou, no entanto, por transformar radicalmente este panorama. O CPC de 2015 incorpora, por isso, embora não regule de modo sistemático o processo coletivo, inúmeras soluções tendentes a enfrentar este problema; por exemplo, o julgamento repetitivo de recursos excepcionais ou ainda os incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Vetou-se, no entanto, uma das grandes novidades da nova lei, a “conversão da ação individual em ação coletiva” por iniciativa do juiz de que trataria o art. 333.

Sem que se permita ao juiz, deste modo, *converter* uma demanda individual em coletiva, reconhece-lhe a lei ao menos incumbir o poder de “quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei 7.347, de 24.07.1985, e o art. 82 da Lei 8.078, de 11.09.1990, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva” (inciso X). Não se trata, obviamente, de uma demanda *ex officio*. O juiz apenas *dá ciência* a eventuais legitimados da situação que lhe parece recomendar solução coletiva. São eles, os legitimados, que decidirão livremente se optam ou não por litigar.

Art. 140. O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico.

Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.

Direito anterior – arts. 126 e 127 do CPC/1973

Direito comparado – art. 113 do CPC italiano

1. Proibição do *non liquet* (ou do *sibi non liquere*)

A Constituição assegura a todos o *direito de ação*, ou seja, o direito de pedir ao Estado tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, CF). A este direito corresponde o *dever* do Estado de dar uma resposta a este pedido, ainda que para dizer que não julgará o mérito da pretensão deduzida pelo autor por lhe faltar algum dos requisitos de admissibilidade de seu julgamento. A Lei, fundamentalmente, mas também a jurisprudência, definem quais são eles. A fixação destes requisitos, entretanto, submete-se a um controle de proporcionalidade, razão pela qual o requisito desproporcional torna-se inconstitucional com fundamento na proibição do exagero (*Übermaßverbot* ⁴³). O pagamento de custas, por exemplo, é um requisito legítimo de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda ou do recurso. Sua fixação em patamares exageradamente altos viola, no entanto, a Constituição. A recusa em julgar o mérito da demanda com fundamento em um requisito constitucionalmente ilegítimo de admissibilidade e também a decisão equivocada sobre o preenchimento de um deles são, assim, a primeira das manifestações, em sua acepção contemporânea, da proibição do *non liquet*, ou do *sibi non liquere*, expressões surgidas no direito romano para designar as situações em que se permitia ao juiz, legitimamente, recusar-se a julgar com fundamento na sua indecisão ⁴⁴.

Mas o *non liquet* pode manifestar-se também no julgamento do mérito da demanda. Neste sentido, aliás, é sua acepção mais tradicional. São três, com efeito, os momentos *lógicos* de todo julgamento: a) a identificação do direito material aplicável; b) a determinação de como ocorreram os fatos relevantes para o julgamento; e c) a utilização do direito aplicável, corretamente, nos fatos como eles realmente aconteceram ⁴⁵. O ordenamento jurídico tolera, até certo ponto, o fenômeno indesejado, embora ocasionalmente inevitável, da sentença injusta. Toleram-se, em outras palavras, a identificação equivocada pelo juiz do direito aplicável, a determinação equivocada dos fatos, e mesmo a aplicação equivocada aos fatos do direito aplicável. Não se permite, no entanto, que o juiz se recuse a julgar, ao fundamento de que não conseguiu identificar o direito material aplicável ⁴⁶, ou que não consegue decidir-se sobre como ocorreram os fatos sobre os quais incide o direito, ou ainda que se recuse a julgar, ao fundamento de que não sabe como fazer incidir o direito aplicável aos fatos.

2. Julgamento por equidade

São muitas as definições possíveis de *equidade*, e variadas ao longo da história, desde o direito grego ⁴⁷, passando pelo romano ⁴⁸ e pelo direito comum ⁴⁹ até chegar aos dias de hoje. *Equity*, aliás, é um conceito ainda hoje fundamental no *common law* ⁵⁰. De comum, em todas estas definições, encontra-se sempre a ideia de um justo *natural*, que se manifesta e se revela quando se percebe que a aplicação de uma regra jurídica qualquer a um determinado caso concreto produziria um resultado flagrantemente injusto. Decidir por equidade significa assim decidir por aquilo que, *racionalmente* ⁵¹, parece ser justo, que parece ao julgador a solução mais correta, sem a necessidade de se encontrar fundamento para esta decisão em uma regra jurídica qualquer (natural ou positiva). Frequentemente, a decisão por equidade tem uma função *corretiva* ⁵²: a de evitar que a aplicação do direito aplicável ao caso concreto produza um resultado flagrantemente injusto (*summum ius summa iniuria*) ⁵³.

O século XX não foi um século favorável, ao menos nos ordenamentos jurídicos pertencentes à família romano-germânica, ao conceito de equidade. Seu uso foi repudiado por variadas escolas de pensamento ao longo deste período. A própria ideia de supremacia da Constituição acaba, aliás, por dar a autênticos *juízos de equidade*, travestidos de controle de constitucionalidade, uma roupagem positiva e *intrasistema* ⁵⁴. O direito brasileiro confere assim à equidade, ao menos a chamando expressamente pelo nome, um papel exclusivamente marginal, recusando-lhe expressamente a função corretiva que lhe era típica (antes reserva esta função ao controle de

constitucionalidade das leis). Daí por que “o juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei” (parágrafo único). É neste sentido, por exemplo, que dispõe o art. 2.º da Lei de Arbitragem, segundo o qual “a arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes”⁵⁵. Neste caso, o árbitro é liberado pelas partes da estrita aplicação das normas jurídicas⁵⁶ em sua busca pela solução mais justa para o litígio. É também neste sentido que o art. 85, § 8.º, do CPC, determina a fixação “por apreciação equitativa” dos honorários de sucumbência “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”. Neste caso, quer dizer a lei que, faltando qualquer parâmetro legal que possa servir de referência à fixação dos honorários, o juiz deve determinar o que lhe parecer mais justo.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Direito anterior – art. 128 do CPC/1973

Direito comparado – § 308 da ZPO alemã, art. 112 do CPC italiano art. 3.º do CPC português

1. Princípios da demanda e da correlação

É o autor quem decide, livremente, contra quem litigará, o que pedirá contra seu adversário e, ainda, com fundamento em qual causa de pedir deduzirá sua demanda (princípio da demanda). A ênfase com que o processo civil brasileiro encara este princípio é uma das heranças mais longevas da filosofia liberal que tanto marcou a processualística romano-germânica na segunda metade do século XIX. Consequentemente, e agora se está a falar do princípio da correlação (ou da congruência), não se permite ao juiz dar ao autor contra o réu mais do que ele pediu (*sentença ultra petita*)⁵⁷, algo diverso do que ele pediu (*sentença extra petita*)⁵⁸, ou deixar de julgar o pedido ou um dos pedidos (*sentença citra petita*)⁵⁹, embora possa o juiz dar ao autor menos do que ele pediu (*sentença infra petita*)⁶⁰. Também não se permite, analogamente, o julgamento *ultra, extra* ou *citra causam petendi*^{61 -62}.

Não viola estes dois princípios a regra segundo a qual a “interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2.º). Nada mais razoável, aliás, considerando-se que o pedido nada mais é do que uma declaração de vontade⁶³. De todo modo, o princípio da cooperação exige do juiz que exorte o autor a esclarecer seu pedido, se ele lhe parecer confuso. Esta providência contribui para evitar debates desnecessários no futuro sobre a extensão do que foi pedido e, ao mesmo tempo, resguarda o direito do demandado de saber exatamente o que contra ele se pede de modo a defender-se adequadamente (tutela do contraditório). O que esta regra não permite é a *substituição* da vontade do autor por aquela do juiz, a quem a lei não autoriza julgar o que, segundo sua opinião, o autor *poderia* ou *deveria* ter pedido, mas não o fez, ou ainda o que ele próprio pediria se estivesse em seu lugar. Se o autor, por exemplo, optou por cobrar apenas os danos materiais, mas não os danos morais, esta é uma escolha sua que deve ser respeitada pelo juiz, ainda que ele pudesse tê-lo feito de modo diverso. Também não viola estes princípios a existência dos assim chamados “pedidos implícitos”. Por exemplo, a condenação ao pagamento de correção monetária e juros independentemente de pedido expresso. A rigor, não se trata uma postulação implícita, mas sim de um *consectário* legal da condenação. Em razão de seu caráter acessório, sua imposição é uma mera *consequência periférica* do julgamento, não a decisão sobre um pedido *implicitamente* formulado pelo autor.

Estas vedações incidem, de todo modo, apenas quando o juiz julgar o mérito da demanda (ou do recurso). Para tanto, deverá antes, em regra, verificar se preenchidos os requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito. Faltando um deles, extingue-se a relação processual sem o seu julgamento. É por este motivo que a sentença que julga extinto o processo com fundamento no não recolhimento de custas pelo autor – e, assim, que não julga os pedidos por ele formulados – não pode ser entendida como uma sentença *citra petita*. Façam-se, por fim, apenas duas ressalvas. Estes requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito subordinam-se, em primeiro lugar, ao controle constitucional de sua proporcionalidade⁶⁴ (lembre-se da proibição do exagero – *Übermaßverbot*⁶⁵). Em segundo, o juiz deverá julgar o mérito, mesmo se faltar um dos requisitos

de seu julgamento, nas condições de que trata o art. 488, segundo o qual “desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485” (princípio da primazia do julgamento do mérito)⁶⁶.

2. Decisão sobre questões e a iniciativa do juiz. Os princípios da demanda e da correlação, como se antecipou no item anterior, dizem respeito apenas aos elementos da demanda, não às questões relevantes para o seu julgamento. Em relação a elas, aplica-se a segunda parte do disposto no art. 141, segundo o qual ao juiz é “vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. O fundamento desta vedação, é verdade, é o mesmo dos princípios da demanda e da correlação: o valor nuclear da liberdade. Nesta acepção, no entanto, o termo “questão” não deve ser confundido com mérito. Antes significa, na tradicional lição de Carnelutti⁶⁷, o ponto de fato ou de direito, duvidoso, de que dependa uma decisão⁶⁸. Trata-se aqui, em outras palavras, das questões que devem ser decididas *incidenter tantum* (na fundamentação), não aquelas que devem sê-lo *principaliter* (no mérito). A imprecisão terminológica é frequente, e dela padece a própria lei⁶⁹, mas é necessário distinguir os dois casos também por motivos práticos. E isso porque o juiz poderá conhecer de ofício de algumas questões *incidenter tantum* (questão na acepção carnellutiana), mas nunca conhecer de questões *principaliter* (pedidos) sem que exista demanda em relação a elas.

A regra geral é a iniciativa da parte. Por isso, o juiz deve conhecer de ofício das matérias apenas quando a ordem jurídica o autorizar a fazê-lo, embora não necessariamente de modo expreso na lei processual. É por isso, por exemplo, que o art. 485, ao tratar das hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, dispõe em seu parágrafo terceiro que “o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”. Ou ainda por que “antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu” (art. 63, § 3.º) e também por que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (art. 370).

O critério, em princípio, é o do interesse público. Com fundamento nele se distingue a exceção, por exemplo, da objeção (processuais ou materiais⁷⁰). Mas esta diferenciação acaba por ser mais arbitrária e casuística do que propriamente científica. Segundo o art. 493, por exemplo, “se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”. Mesmo algumas questões de fato, assim, podem ser enfrentadas pelo juiz independentemente de requerimento, o que em princípio não se pensaria razoável admitir (embora o juiz, de todo modo, nunca deixe de estar vinculado à causa de pedir⁷¹ – vedação do julgamento *extra causam petendi*). Na dúvida, no entanto, exige-se a iniciativa da parte.

É à luz desta distinção que se deve interpretar a segunda parte do disposto no art. 141, segundo o qual ao juiz é “vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. Se a lei (*rectius*, a ordem jurídica) exige a iniciativa da parte, o juiz não pode conhecer da questão de ofício. Faça-se apenas uma ressalva final. Independentemente se cognoscíveis ou não *ex officio*, pontos *irrelevantes* para o julgamento não precisam ser enfrentados pelo juiz, razão pela qual a decisão não estará defeituosamente fundamentada se a questão omitida não for capaz “de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, IV).

Art. 142. Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as penalidades da litigância de má-fé.

Direito anterior – art. 129 do CPC/1973

Direito comparado – art. 456 do CPC português

1. Litígio aparente e extinção do processo sem julgamento do mérito

O processo judicial é um instrumento que a Constituição, ao proibir a autotutela, põe à disposição das partes para que possam solucionar um litígio entre elas de modo civilizado e ordenado. O Estado não promete, nem pode fazê-lo, a tutela efetiva de direitos violados; o fenômeno da sentença injusta, como já se explicou nos comentários ao art. 141, embora sumamente indesejado, é inevitável, ao menos episodicamente. Mas o Estado terá *sempre* o dever de decidir o litígio, desde, no entanto, que exista *realmente* um litígio entre as partes e desde que reunidas as demais condições, positivas e negativas, de admissibilidade do julgamento do mérito da demanda.

A existência de um litígio meramente *aparente* é, assim, também uma condição de admissibilidade (negativa) do julgamento do mérito da demanda, exatamente porque, se não existe um litígio real entre as partes, não há o que se julgar. A lei não tolera, em outras palavras, o falso litígio, a situação em que as partes aparentam estar litigando quando, em verdade, agem em conluio para atingir determinado fim estranho à tutela jurisdicional concretamente pedida no processo. Por isso, mais importante do que distinguir processo simulado de processo fraudulento (estas são as expressões empregadas pela lei)⁷²⁻⁷³, é compreender que a colusão entre as partes, quando há apenas um litígio *aparente* entre elas, não um litígio *real*, deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Esta é a *mens* do art. 142, o significado *processual* que se lhe deve dar. Se não existe um litígio real entre as partes, não há o que se julgar. O processo, inexoravelmente, deve ser extinto sem julgamento do mérito. Esta extinção é a única solução concebível que se possa definir como uma “decisão que impeça os objetivos das partes” e tem por fundamento o próprio art. 142 (e não algum dos incisos do art. 485)⁷⁴. Esta conduta das partes é tão grave, aliás, que a lei eleva a existência de um litígio aparente à categoria de vício rescisório em seu art. 966, III. Pense-se, por exemplo, no caso em que as partes, uma querendo pagar a outra, vantagens derivadas da prática de corrupção, valem-se do processo para simular a existência de um crédito de origem lícita entre elas. Corrompido pede a condenação do corruptor a pagar uma dívida (lícita) inexistente, que confessa e passa a ter contra si um título executivo que justifique, perante acionistas, autoridades públicas, empresas de auditoria e mesmo o público em geral, o pagamento ilícito que nunca deixou de querer fazer a seu adversário *aparente*⁷⁵.

Além de extinguir o processo, sem julgamento do mérito, deve o juiz em caso de litígio aparente também punir as partes pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, porque o falso litígio perverte a função jurisdicional, desperdiça o tempo de juízes e consome inutilmente recursos do Poder Judiciário, ele próprio já congestionado por milhões de litígios reais a serem resolvidos em tempo razoável. Por isso se equivoca a lei ao falar em “litigância de má-fé”. A que parte, com efeito, se poderia destinar o pagamento da multa imposta às partes pela litigância de má-fé⁷⁶? Tutela-se, na repressão ao litígio aparente, o interesse público no bom funcionamento da justiça. Sua função não é a de reparar uma parte pela prática de uma conduta processual antijurídica por outra.

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I – no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

II – recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte.

Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias.

Direito anterior – art. 133 do CPC/1973

Direito comparado – art. 34 da Lei Fundamental alemã, § 839 do BGB e art. 55 do CPC italiano (revogado em 1987)

1. Responsabilidade civil direta ou regressiva do juiz. O juiz é *civilmente* responsável (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa

ou penal) por indenizar os prejuízos que, no exercício de sua função⁷⁷, causar às partes do processo⁷⁸. Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o juiz com fundamento no disposto no art. 927 do Código Civil e no art. 49 da Lei Orgânica da Magistratura; ou b) regressiva, deduzida contra o juiz pelo Estado com fundamento no disposto no *caput* do artigo 143, autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada com fundamento, por sua vez, no disposto no art. 37, 6.º, da Constituição Federal⁷⁹.

Embora o tema mereça tratamento mais aprofundado, que se deixa para outra ocasião, o ponto central é de que a o art. 37, § 6.º, da Constituição não exclui a responsabilidade civil direta do agente público, apenas regulamenta a sua responsabilidade regressiva no caso em que o Estado venha a ser demandado pelos danos causados por seu agente. A função deste dispositivo constitucional, com efeito, não é o de *limitar* o direito do prejudicado à indenização, mas sim de dar-lhe a alternativa de seguir o caminho menos tortuoso da responsabilidade objetiva do Estado fundada na doutrina do risco administrativo. Diz-se “menos tortuoso” porque a responsabilidade direta exige a comprovação do elemento subjetivo que se dispensa na demanda contra Estado. Esta *mens* mostra-se ainda mais evidente quando se lembra de que a responsabilidade objetiva se estende também às pessoas de “direito privado prestadoras de serviços públicos”, porque não haveria sentido algum em considerá-las imunes à responsabilidade direta. O CPC não elimina nem veda, portanto, a responsabilidade direta do juiz⁸⁰, apenas regulamenta ao seu lado a sua responsabilidade regressiva⁸¹ (em termos mais restritivos, aliás, do que aqueles constantes do art. 37, § 6.º, da Constituição, porque exclui o direito de regresso nos casos de mera culpa). Tampouco permite àquele que se considera prejudicado deduzir sua pretensão no mesmo processo em que alega ter sofrido o prejuízo.

2. Sentença injusta, responsabilidade objetiva do Estado e responsabilidade pessoal do juiz

O Estado não promete, nem pode fazê-lo, a tutela efetiva de direitos violados; promete apenas *decidir* o litígio. O fenômeno da sentença injusta, assim, como já se explicou nos comentários ao art. 141, embora indesejado, é inevitável, ao menos episodicamente. A ordem jurídica tolera, em outras palavras, a identificação equivocada pelo juiz do direito aplicável, a determinação equivocada dos fatos, e mesmo a aplicação equivocada aos fatos do direito aplicável, motivo pelo qual nem o Estado nem o próprio juiz podem ser responsabilizados se ocorrer alguma destas situações. Por isso, como ensina Celso Agrícola Barbi, é que “pela boa ou má interpretação que der a um artigo de lei, não pode o juiz ser civilmente responsabilizado”⁸².

O Estado é objetivamente⁸³ responsável por indenizar a parte, no entanto, se se estiver diante de caso de *erro judiciário*⁸⁴, fenômeno cuja ocorrência não se limita apenas às causas criminais⁸⁵, ou de processo cuja duração final não possa ser considerada razoável⁸⁶⁻⁸⁷. Ocorrerá erro judiciário quando o equívoco do juiz na identificação do direito aplicável, na determinação dos fatos ou na aplicação equivocada aos fatos do direito aplicável ultrapassar os *limites do razoável*. Esta análise, obviamente, é casuística. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, entendeu responsável o Estado pela reparação com fundamento na responsabilidade objetiva de que trata o art. 37, § 6.º, da Constituição dos prejuízos causados em razão da “ocorrência de bloqueio de valores em contas bancárias do demandante, sem qualquer determinação judicial para tanto”⁸⁸. E isso, agora segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao fundamento de que a “tese da irresponsabilidade do Estado por erros judiciários [encontra-se] superada pela doutrina e jurisprudência atuais”⁸⁹. Também o reconhecimento da violação do direito à duração razoável do processo dependerá de uma análise casuística das circunstâncias concretas do processo⁹⁰. Nestes dois casos, a responsabilidade do Estado pela reparação *integral* do dano independerá *sempre* da demonstração de dolo ou culpa do juiz. Basta que a conduta do magistrado ou a duração final do processo possam ser entendidas, *objetivamente falando*, como não razoáveis, como flagrantemente contrárias àquilo que normalmente se esperaria em situações análogas. O elemento subjetivo será pressuposto *apenas* da fixação da responsabilidade civil, regressiva, do próprio juiz, nunca da responsabilidade do Estado, ela sempre objetiva. A responsabilidade do Estado, em síntese, “pode existir ainda que não exista a responsabilidade do juiz”⁹¹.

Em relação à responsabilidade direta do juiz, também subjetiva, vale a regra geral: ela pressupõe a comprovação do dolo ou da culpa. Pense-se no caso em que o juiz, sabedor de que se encontra impedido, omite o fato deliberadamente, para julgar em favor de seu parente. Ou ainda na situação em que o juiz decide contra uma figura pública, por quem nutre antipatia, apenas porque não gosta dela. *Comprovado* o elemento subjetivo, é razoável que o juiz indenize diretamente os prejuízos que causar à parte prejudicada. E é bom que seja assim, porque a responsabilidade direta desestimula a prática de abusos de um modo que a responsabilidade meramente regressiva não é capaz de fazer. Se infundada a demanda contra o juiz, ou mesmo se apenas destinada a constrangê-lo, o sistema processual tem remédios adequados, ao lado da própria improcedência e da condenação em honorários, para reprimir a prática da litigância de má-fé (art. 79).

Quanto à responsabilidade regressiva, os incisos do art. 143 contêm disposição especial. Em regra, o juiz será responsável apenas quando “proceder com dolo ou fraude” (inciso I). Como esclarece Carnelutti, a referência à fraude é desnecessária, é “sovrabbondante”⁹². Basta a demonstração do “dolo” para a configuração da responsabilidade regressiva. Dolo, neste contexto, e se socorre novamente do magistério de Carnelutti, não é apenas a consciência (*consapevolezza*), mas antes a intenção do ilícito (*intenzione dell'illecito*)⁹³. Mas basta o dolo de prejudicar a parte, “não sendo necessário que o seja para beneficiar o adversário, ou em proveito próprio ou de terceiro, ou mesmo se apenas pelo simples desejo de causar o mal. Esta última hipótese pode ocorrer, para satisfazer o intuito de vingança ou de mero capricho, decorrente de antipatia”⁹⁴.

Caso particular de responsabilidade civil regressiva do juiz ocorrerá quando ele, ainda que apenas culposamente, “recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte” (inciso II). O prejuízo, para fins de configuração da responsabilidade, é o mero atraso que a conduta do juiz vier a causar. A extensão do dano sofrido pela parte servirá, por seu turno, para a definição do *quantum* que lhe deverá ser pago a título de indenização. Mas as hipóteses previstas neste inciso II “somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias” (parágrafo único). A culpa em não dar regular andamento ao processo pressupõe, naturalmente, a falta de um *motivo justo*. Por exemplo, o excesso de serviço, do próprio juiz ou de seu cartório. A responsabilidade do juiz dependerá, conseqüentemente, da comprovação, à luz das circunstâncias do caso concreto, de que ele agiu com culpa, nas suas duas modalidades (culpa consciente, “leviandade, precipitação, desleixo ou incúria”, ou culpa inconsciente, “imprevidência, descuido, imperícia ou inaptidão”⁹⁵). Será o caso, por exemplo, se o juiz não aparecer para trabalhar, frequente e injustificadamente, e por este motivo deixar acumular trabalho na serventia em que atua (fazendo ocorrer, assim, alguma das hipóteses previstas no inciso II).

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Carlos Barbosa Moreira, *Reformas processuais e poderes do juiz*. In: Temas de direito processual (oitava série), p. 53.

2

Para mais detalhes: Antonio do Passo Cabral, Teoria das nulidades processuais no direito contemporâneo, *Revista de Processo*, vol. 255, p. 79. Também Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 72.

Como ilustra a autêntica revolução representada pelo art. 190 do CPC.

José Carlos Barbosa Moreira, O neoprivatismo no processo civil. In: *Temas de direito processual* (nona série), p. 87.

“Uma das garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal é a do direito fundamental ao juiz natural. Trata-se de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: o que proíbe juízo ou tribunal de exceção e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente (incisos XXXVII e LIII do art. 5.º da CF/1988). Trata-se essa garantia de uma conquista moderna” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 183).

Para mais detalhes: Max Vollkommer, Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess. In: *FS Schwab*, p. 520.

No sentido de que “a igualdade perante o juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei, como garantia constitucional indissolúvelmente ligada à democracia. O princípio da igualdade jurisdicional ou perante o juiz apresenta-se, portanto, sob dois prismas: 1) como interdição ao juiz de fazer distinção entre situações iguais, ao aplicar a lei; 2) como interdição ao legislador de editar leis que possibilitem tratamento desigual a situações iguais ou tratamento desigual a situações desiguais por parte da justiça” (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 218).

“Plausibilidade, ademais, da impugnação da utilização de medidas provisórias para alterar a disciplina legal do processo, à vista da definitividade dos atos nele praticados, em particular, de sentença coberta pela coisa julgada. A igualdade das partes é imanente ao procedural *due process of law*; quando uma das partes é o Estado, a jurisprudência tem transigido com alguns favores legais que, além da vetustez, tem sido reputados não arbitrários por visarem compensar dificuldades da defesa em juízo das entidades públicas; se, ao contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da proporcionalidade, caracterizam privilégios inconstitucionais: parece ser esse o caso na parte em que a nova medida provisória insiste, quanto ao prazo de decadência da ação rescisória, no favorecimento unilateral das entidades estatais, aparentemente não explicável por diferenças reais entre as partes e que, somadas a outras vantagens processuais da Fazenda Pública, agravam a consequência perversa de retardar sem limites a satisfação do direito do particular já reconhecido em juízo. No caminho da efetivação do *due process of law* – que tem particular relevo na construção sempre inacabada do Estado de direito democrático – a tendência há de ser a da gradativa superação dos privilégios processuais do Estado, à custa da melhoria de suas instituições de defesa em juízo, e nunca a da ampliação deles ou a da criação de outros, como – é preciso

dizê-lo – se tem observado neste decênio no Brasil” (ADI 1910 MC, relator(a): Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 22.04.2004, DJ 27.02.2004, p. 19 ementa, vol. 2141-02 p. 408).

9

Para mais detalhes: Alexandre Freitas Câmara, O direito à duração razoável do processo: entre eficiência e garantias, *Revista de Processo*, vol. 223, p. 39. Também José Rogério Cruz e Tucci, Garantia do processo sem dilações indevidas. In: *Garantias constitucionais do processo civil*, p. 234.

10

Em países em que a Justiça é percebida como lenta, maior é a atenção dada pela doutrina e pela jurisprudência à duração razoável do processo. Neste sentido: “Cappelletti, in più occasioni aveva denunciato la scarsa ‘operatività’ della disposizione dell’art. 175 c.p.c. nella parte in cui afferma che ‘il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del procedimento’⁹⁴ Oggi la giurisprudenza insegna che ‘il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c. di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicitare i suoi effetti” (Nicolò Trocker, Processo e Costituzione nell’opera di Mauro Cappelletti: elementi di una moderna “teoria” del processo, *Revista de Processo Comparado*, vol. 2, p. 260).

11

Este dever de observar prazos é concretizado, por exemplo, pelo art. 940, segundo o qual “o relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 (dez) dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução”.

12

Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 143.

13

Neste sentido, os parágrafos do art. 940: § 1.º Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo juiz prorrogação de prazo de no máximo mais 10 (dez) dias, o presidente do órgão fracionário os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído; § 2.º Quando requisitar os autos na forma do § 1.º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado a votar, o presidente convocará substituto para proferir voto, na forma estabelecida no regimento interno do tribunal.

14

“Its underlying objective is to empower the court to prevent or punish conduct which may tend to obstruct, prejudice or abuse the administration of justice” (Jack Jacob, *The fabric of English civil justice*, p. 206).

15

Para mais detalhes sobre esta evolução histórica: Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 682.

16

Sobre a distinção, baseada no magistério de Mandrioli: Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 4, p. 509.

17

Para mais detalhes: Marcelo Abelha Rodrigues, O novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (parte 1), *Revista de Processo*, vol. 244, p. 109. Também Benedito Cerezo Pereira Filho, A evolução da tutela executiva da obrigação de pagar quantia certa: do Código de Processo Civil de 1973 ao de 2015. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 5, p. 407.

18

Para um panorama geral: Eduardo Talamini, Poder geral de adoção de medidas executivas e sua incidência nas diferentes modalidades de execução, in: *Grandes Temas do novo CPC*, vol. 11 (2018), p. 27.

19

Araken de Assis cogita até de sua inconstitucionalidade (Araken de Assis, Cabimento e adequação dos meios executórios “atípicos”, in: *Grandes Temas do novo CPC*, vol. 11 (2018), p. 128.

20

O Superior Tribunal de Justiça tem sido levado a enfrentar questões decorrentes da atipicidade dos meios executivos no julgamento de recursos em *habeas corpus* impetrados ao fundamento de que certas medidas atípicas violam o direito de ir e vir do paciente, mas não parece até o momento existir uma jurisprudência consolidada sobre o assunto (julho de 2018). Em 10 de maio de 2018, por exemplo, o ministro Luiz Felipe Salomão determinou monocraticamente a cassação de ordem de suspensão de passaporte e carteira de habilitação do paciente (Recurso em *habeas corpus* 97.876/SP).

21

Alexandre Freitas Câmara, O princípio da patrimonialidade da execução e os meios executivos atípicos: lendo o art. 139, V, do CPC, in: *Grandes Temas do novo CPC*, vol. 11 (2018), p. 236.

22

A possibilidade de prisão do devedor de alimentos, diferentemente, mostra que, quando o ordenamento jurídico reputa sensível o direito cuja tutela se pede, pode se permitir uma intervenção mais enérgica do Estado na vida de seus cidadãos.

23

Por exemplo, quando o executado, embora pareça não ter bens em seu nome, ostenta uma vida de luxo.

24

Neste sentido: Thiago Rodovalho, O necessário diálogo entre doutrina e jurisprudência na concretização do NCPC, art. 139, inc. IV (atipicidade dos meios executivos), in: *Grandes Temas do novo CPC*, vol. 11 (2018), p. 722.

25

REsp 1112862/GO, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, j. 13.04.2011, *DJe* 04.05.2011.

26

Para mais detalhes, por exemplo: Luciano Vianna Araújo, A atipicidade dos meios executivos na obrigação de pagar quantia certa, *Revista de Processo* 270 (2017), p. 123.

27

Será inconstitucional a exigência de que as partes, antes do processo, tentem chegar a uma solução amigável para o litígio, com fundamento na mesma garantia da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.º, XXXV, da CF), ainda que ninguém “coloque em dúvida a valia, sob o ângulo da preservação da paz social, do entendimento direto entre os titulares dos direitos envolvidos na relação jurídica. Esforços devem ser direcionados no sentido da solução dos conflitos que se apresentem, sem chegar-se ao litígio, à formalização de demanda, aos ares que indubitavelmente, levam ao acirramento de ânimos, passando, por vezes, o réu a ver no autor um inimigo, quando este simplesmente aciona direito inerente à cidadania...” (ADI 2139 MC, relator(a): Min. Octavio Gallotti, relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 13.05.2009).

28

Para mais detalhes: Thiago Rodovalho, A viragem da mediação no NCPC e no marco legal da mediação no Brasil. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 395.

29

Sobre flexibilidade por iniciativa do juiz: Guilherme Peres de Oliveira, *Adaptabilidade judicial: a modificação do procedimento pelo juiz no processo civil*, p. 111. Para mais detalhes sobre a questão no novo CPC: Cambi; Neves, Flexibilização procedimental no novo Código de Processo Civil. In: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 634.

Neil Andrews, Relações entre a corte e as partes na era do case management, *Revista de Processo*, vol. 217, p. 181.

“Mas o princípio da adequação do processo pode atuar diretamente, sem a intermediação de regras que o concretizem. Permite-se ao magistrado que corrija o procedimento que se revele inconstitucional, por ferir um direito fundamental processual, como o contraditório (se um procedimento não prever o contraditório, dever o magistrado determiná-lo, até mesmo *ex officio*, como forma de efetivação deste direito fundamental)” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 120).

A lei processual alemã, por exemplo, estabelece frequentemente prazos *mínimos* para a prática de atos processuais (como o protocolo de contestação), de modo semelhante ao que já fazia o antigo art. 491 do CPC/1973 em relação ao prazo para o protocolo de contestação na ação rescisória. Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 89.

Art. 222. Na comarca, seção ou subseção judiciária onde for difícil o transporte, o juiz poderá prorrogar os prazos por até 2 (dois) meses.

“Na definição clássica, prazos dilatórios eram os que poderiam ser alterados pela vontade das partes e também pelo juiz. Peremptórios eram os prazos inalteráveis, seja pelas partes, seja pelo juiz. Não há mais prazos peremptórios nesse sentido. Nos termos do art. 222, § 1.º, do CPC, peremptórios são os prazos que apenas não podem ser reduzidos pelo juiz sem anuência das partes. Isso significa que mesmo o prazo peremptório: (a) pode ser reduzido pelo juiz com a concordância das partes (art. 222, § 1.º, do CPC, a *contrario sensu*); (b) pode ser ampliado ou diminuído por iniciativa consensual das próprias partes, com a chancela do juiz (art. 191 do CPC); (c) pode ser ampliado pelo juiz, independentemente de assentimento das partes (art. 139, VI, do CPC)” (Wambier; Talamini, *Curso avançado de processo civil*, p. 580).

“A expressão poder de polícia comporta dois sentidos, um amplo e um estrito. Em sentido amplo, poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Sobreleva neste enfoque a função do Poder Legislativo, incumbido da criação do *ius novum*, e isso porque apenas as leis, organicamente consideradas, podem delinear o perfil dos direitos, elasticendo ou reduzindo o seu conteúdo. É princípio constitucional o de que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5.º, II, CF)’. Em sentido estrito, o poder de polícia se configura como atividade administrativa que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder restringir e condicionar a liberdade e a propriedade” (José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 76).

36

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. V, p. 11.

37

Recentemente: Michel Roberto Oliveira de Souza, Novas perspectivas sobre a oralidade no processo, *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal*, vol. 2 (2015), p. 145.

38

Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 330.

39

José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 624.

40

Por exemplo: “O CPC consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada – seja ela a demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda incidental” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 137). Este princípio é também aplicável no julgamento dos recursos. Neste sentido: “No âmbito do sistema recursal o princípio da primazia do julgamento do mérito recursal tem aplicação ainda mais contundente. Está arraigado no espírito do CPC...” (Pedro Miranda de Oliveira, *Novíssimo sistema recursal conforme o CPC*, p. 84).

41

É por esta razão, por exemplo, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (art. 932, parágrafo único).

42

Para um panorama histórico: Teori Albino Zavascki, *Processo coletivo*, p. 13.

43

Ferreira Mendes; Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 225.

44

“Não estando subordinado a qualquer estrutura hierárquica, o *iudex* que não lograsse formar convicção a respeito de determinada causa, poderia simplesmente declarar *sibi non liquere* (não me parece claro),

ensejando que as partes retornassem ao magistrado para a escolha de novo julgador” (Tucci; Azevedo, *Lições de história do processo civil romano*, p. 59).

45

Para mais detalhes: Karl Engisch, *Einführung in das juristische Denken*, p. 41.

46

“Direito aplicável” não se confunde com “ato normativo aplicável”. A lei pode ser obscura, e pode mesmo existir nela uma lacuna (*Lücke*), que ocorre quando faltar uma disposição legal expressa onde fosse de se esperar que ela não faltasse (sobre o ponto: Larenz, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, p. 283). Mas o ordenamento jurídico dá sempre uma solução, ainda que o faça ao reconhecer *força criativa* ao juiz (*Rechtsfortbildung*). Sobre *Rechtsfortbildung*: Zippelius, *Juristische Methodenlehre*, p. 63.

47

Helmut Ridder, *Aequitas und Equity*, AcP, vol. 39, p. 186.

48

“Auch aequitas bedeutet in der klassischen Zeit die Gerechtigkeit, besonders die, die der Prätor anwendet, wenn er die Härten des ius civile mit seinem Honorarrecht überwindet“ (Kaser; Knütel, *Römisches Privatrecht*, p. 29).

49

Norbert Horn, *Aequitas in den Lehren des Baldus*, p. 9.

50

“Equity signifies equality of justice, and when the word is used in general works on jurisprudence it is sometimes defined as ‘the correction of that wherein the law, by reason of its universality, is deficient’. In the system of the Common Law, however, it denotes certain remedial processes by which relief can be afforded in cases whose peculiar circumstances place them beyond the reach of the ordinary courts” (Maitland; Montague, *A sketch of English Legal History*, p. 219). Para uma obra mais recente: Sarah Worthington, *Equity*, p. 3.

51

Esta ressalva é fundamental. A equidade provém da razão, não de sentimentos, e é exclusivamente a razão que a legitima.

52

Der Entstehungsgrund von aequitas und Equity ist derselbe: das Notleiden des Rechts in Bezug auf die Gerechtigkeit“ (Helmut Ridder, *Aequitas und Equity*, AcP, vol. 39, p. 184).

53

“Considerado o sistema de direito positivo, ainda ocorre a presença da equidade, como a ideia de amenização do rigor da lei. Equiparada ou aproximada ao conceito de justiça ideal, a equidade impede que o rigor dos preceitos se converta em atentado ao próprio direito, contra o que Cícero já se insurgia ao proclamar ‘summus ius, summa iniuria’” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 63).

54

O tema – o quanto há de *equidade* no controle de constitucionalidade – merece tratamento mais aprofundado, que se reserva para outra oportunidade. Mas basta pensar na função corretiva dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para identificar a evidente correlação.

55

A equidade é hoje frequentemente percebida, equivocadamente, como um sinônimo de arbitrariedade. Neste sentido: “Numa visão francamente realista, não se pode deixar de notar que a arbitragem *ex aequo et bono* submete as partes a sérios riscos, pois o que parece justo a elas pode não parecer ao árbitro (e vice-versa) Assim, podendo ser negligenciadas limitações legais e regras de direito material, a decisão assemelha-se a um verdadeiro barril de pólvora, sobre o qual placidamente resolvem sentar-se as partes” (Carlos Alberto Carmona, *Arbitragem e processo*, p. 67).

56

« Dans l'arbitrage, la résolution au fond du litige peut être effectuée de deux manières. À cet égard, les articles 1511 e 1512 du Code de procédure civile permettent de distinguer l'arbitrage en droit, par lequel le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit, et l'arbitrage en amiable composition ou dit ‘en équité’, qui met au premier plan le souci de rendre une décision juste, ne résultant pas forcément d’une stricte application de la loi (...). L'arbitre amiable compositeur peut s'écarter, dans sa décision, des conséquences que commanderait l'application rigoureuse des règles de droit si elles lui apparaissent inéquitable en l'espèce » (Seraglini; Ortscheidt, *Droit de l'arbitrage interne et international*, p. 795).

57

Se o autor pedir contra o réu, por exemplo, o pagamento de cem mil reais a título de danos morais, não pode o juiz o condená-lo a pagar cento e um mil reais. A sentença ultra petita é, assim, aquela que dá àquele que pede *mais do mesmo*.

58

Não constitui exceção a esta limitação o caso da tutela possessória. E isso porque, em razão do caráter extremamente dinâmico da posse, o que se pede contra o réu é a sua tutela (da posse, não especificamente do esbulho, da turbção ou da ameaça). Nestas três hipóteses, tutela-se exatamente o mesmo bem jurídico (a posse) e dá-se a mesma tutela (tutela possessória). Ainda que a forma exata com que esta tutela é efetivada possa ser diversa conforme a situação fática no exato momento de sua efetivação. É neste

sentido que se fala da *fungibilidade da proteção possessória* com fundamento no art. 554, segundo o qual “a propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados”.

59

Embora defeituosa, por outros motivos, não será *citra petita* a sentença que deixar de decidir *questões* relevantes para o julgamento do mérito, mas apenas aquela que deixar de decidir o mérito ou parte dele. Para mais detalhes, confira-se o próximo item dos comentários a este artigo.

60

Se o autor pediu a condenação do réu ao pagamento de indenização de cem mil reais, por exemplo, nada proíbe o juiz de julgar parcialmente procedente o pedido de modo a condenar o réu a pagar ao autor apenas trinta mil reais.

61

Para mais detalhes sobre a incongruência entre sentença e causa de pedir: Vallisney de Souza Oliveira, *Nulidade da sentença e o princípio da congruência*, p. 265.

63

Para mais detalhes: Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 596.

64

É legítimo exigir do autor que recolha custas para distribuir sua demanda. Mas a cobrança de custas em patamar excessivo compromete seu direito constitucional à jurisdição.

65

Ferreira Mendes; Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 225.

66

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 137.

67

“In quanto una affermazione, compresa nella ragione (della pretesa o della contestazione), possa gerare un dubbio e così debba essere verificata, diventa una questione. Perciò la questione si può definire un punto dubbio, di fatto o di diritto, e la sua nozione è correlativa a quella di affermazione” (Francesco Carnelutti, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. 1, p. 353).

68

Como explica Barbosa Moreira: “A palavra ‘questão’ vê-se empregada em dois sentidos diversos na linguagem da lei. Ela serve primeiro para designar qualquer ponto duvidoso, de fato ou de direito, de que dependa o teor do pronunciamento judicial. Nessa acepção, dir-se-á com propriedade que a solução das ‘questões’ é o meio de que se vale o juiz para julgar: a ‘questão’ não constitui, em si, objeto de julgamento, mas, uma vez resolvida, insere-se entre os fundamentos da decisão, entre as razões de decidir. Assim, por exemplo, a questão consistente em saber se ocorreu ou não o fato constitutivo alegado pelo autor, ou o fato extintivo alegado pelo réu; a questão relativa à vigência ou à constitucionalidade da regra jurídica cuja incidência se afirma etc. (...). Outras vezes, ‘questão’ é o próprio *thema decidendum*, ou ao menos cada uma das partes em que ele se fraciona. Se alguém, v.g., pleiteia a resolução da promessa de compra e venda e a reintegração de posse do imóvel, dir-se-á, neste outro sentido, que o juiz deve julgar duas ‘questões’, a da resolução contratual e a possessória. Existe aí manifesta correspondência entre ‘questão’ e pedido; havendo mais de um pedido, ou – o que afinal é o mesmo – compondo-se o pedido de mais de um item, estarão subpostas à cognição judicial tantas ‘questões’ quanto forem os pedidos, ou os itens do pedido” (José Carlos Barbosa Moreira, Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. In: *Temas de direito processual* (segunda série), p. 243).

69

Segundo o art. 489, III, por exemplo, é elemento essencial da sentença “o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem”.

70

Sobre o ponto, por exemplo: Wambier; Talamini, *Curso avançado de processo civil*, p. 256.

71

A causa de pedir é o evento da vida, despidido de qualquer qualificação jurídica (*Lebenssachverhalt*), com fundamento no qual o autor pede tutela. Para mais detalhes: Rosenberg; Schwab; Gottwald, *Zivilprozessrecht*, p. 506. Musielak; Voit aludem ao complexo fático (*Tatsachenkomplex*) a partir do qual o autor deriva a consequência jurídica que fundamenta seu pedido (Musiellak; Voit, *Grundkurs ZPO*, p. 99). Também Thomas; Putzo, *Kommentar zur ZPO*, p. 7. Segundo Barbosa Moreira, ademais, “cada fato ou conjunto de fatos suscetível de produzir, por si, o efeito jurídico pretendido pelo autor constitui uma *causa petendi*” (José Carlos Barbosa Moreira, *O novo processo civil brasileiro*, p. 17).

72

Na distinção de Barbosa Moreira: “...enquanto neste [processo simulado] as partes não têm, verdadeiramente, a intenção de aproveitar-se do resultado do pleito, nem, pois, real interesse na produção dos respectivos efeitos jurídicos, a não ser como simulacro para prejudicar terceiros, naquele [processo fraudulento], ao contrário, o resultado é verdadeiramente querido, e as partes valem-se do processo justamente porque ele se lhes apresenta como o único meio utilizável para atingir um fim vedado em lei” (José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 5, p. 126).

74

O ponto não passou despercebido a Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo civil*

75

São também exemplos, resumidamente: “São exemplos tradicionalmente dados pela doutrina de processo simulado: ação possessória com alegação de posse longa para futura utilização em ação de usucapião; ação de despejo para se provar posse indireta do autor que não existe, para futura utilização em futura ação possessória ou de usucapião. São exemplos de processo fraudulento: (a) invenção de dívida para preservar o patrimônio do pseudodevedor diante terceiros; (b) separação e divórcio somente para resguardar o patrimônio de um dos cônjuges” (Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo civil comentado artigo por artigo*, p. 237).

76

Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 96, segundo o qual “o valor das sanções impostas ao litigante de má-fé reverterá em benefício da parte contrária, e o valor das sanções impostas aos serventuários pertencerá ao Estado ou à União”.

77

A ressalva ao “exercício da função” não é sem razão. Este dispositivo regula a responsabilidade do juiz pelos atos que praticar enquanto juiz. Se ele se envolve num acidente de trânsito com uma das partes, não se aplicarão ao caso as regras previstas neste art. 143.

78

Sobre os requisitos para a configuração desta responsabilidade, confirmam-se os próximos itens dos comentários a este artigo.

79

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

80

O art. 93, aliás, é expresso em reconhecer uma hipótese de responsabilidade direta ao dispor que “as despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição”.

81

Para um resumo dos argumentos contrário, por exemplo: Rogério Sampaio Contreiras de Almeida, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas), p. 492.

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 418.

“O mais importante, no que tange à aplicação da teoria da responsabilidade objetiva da Administração, é que, presentes os devidos pressupostos, tem esta o dever de indenizar o lesado pelos danos que lhe foram causados sem que se faça necessária a investigação sobre se a conduta administrativa foi, ou não, conduzida pelo elemento culpa” (José dos Santos Carvalho Filho, *Manual de direito administrativo*, p. 561).

Segundo o art. 5.º, LXXV, da Constituição Federal, “o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”.

Sobre o ponto: Augusto do Amaral Dergint, Responsabilidade do Estado por atos judiciais, *Revista dos Tribunais*, vol. 710, p. 228.

Segundo o art. 5.º, LXXVIII, da Constituição Federal, “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. INEGÁVEL DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação recursal em face da sentença que estabelece o dever de indenizar pelo Estado do Rio de Janeiro pela ocorrência de bloqueio de valores em contas bancárias do demandante, sem qualquer determinação judicial para tanto, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Erro judiciário caracterizado. Responsabilidade civil do demandado na forma do artigo 37, par. 6.º da Constituição Federal. Dano moral caracterizado de forma *in re ipsa* pela incontroversa hipossuficiência do demandante, privado de seus parcos recursos. Valor fixado que atende ao contexto fático, verificando-se proporcional inclusive considerando o valor bloqueado e a duração do bloqueio pelo demandante. Fixação dos índices de juros e de correção monetária na forma do atual entendimento das Cortes Superiores sobre a aplicação do artigo 1.º F da Lei 9494/1997. Recursos conhecidos e aos quais se nega provimento na forma do artigo 557, *caput* do Código de Processo Civil, perfazendo, segundo o enunciado sumular 161 deste Tribunal, pequena modificação em relação aos índices de juros e de correção monetária” (Apelação 0120630-29.2013.8.19.0001, rel. Des. Cezar Augusto Rodrigues Costa, 8.ª Câmara Cível, j. 04.03.2016, *DJe* 09.03.2016).

“Bloqueio judicial de R\$ 1.515,57 de pessoa que não era parte no processo. Indisponibilidade do recurso

por 139 dias, que acarretou dificuldades e transtornos para pessoa idosa e de modesta condição econômica. Cabimento de indenização a título de dano moral. Responsabilidade objetiva do Estado por falha do serviço judiciário que causou dano a pessoa estranha ao processo. Tese da irresponsabilidade do Estado por erros judiciários superada pela doutrina e jurisprudência atuais. Precedentes. Demanda procedente. Indenização que se reduz de dez para três mil reais porque o bloqueio se restringiu à quantia referida, sem incidir sobre outros recursos que vieram a transitar pela corrente da autora e sem impedir o seu uso. Honorários advocatícios reduzidos para oitocentos reais, de forma mais condizentes com o valor da indenização, com a regra e critérios do artigo 20, § 4.º, do CPC, para causas de pequeno valor e condenação da Fazenda Pública. Recurso parcialmente provido” (Apelação 0009412-10.2011.8.26.0053/SP, j. 12.05.2015, 12.ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Edson Ferreira, *DJe* 12.05.2015).

90

“A jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos desenvolveu critérios para aferição da duração razoável do processo. Em sua primeira formulação, a Corte erigiu como critérios: (i) a complexidade da causa; (ii) o comportamento das partes e (iii) o comportamento do juiz na condução do processo. Hoje, além desses três clássicos parâmetros, a Corte vem apreciando igualmente a razoabilidade da duração do processo a partir da relevância do direito reclamado em juízo para vida do litigante prejudicado pela duração excessiva do processo – critério da posta *in gioco*, que determina redobrada atenção do Estado nos casos em que o litígio versa sobre responsabilidade civil por contágio de doenças, status pessoal e que ameacem a liberdade pessoal do réu no processo penal. Vale dizer: a importância da decisão da causa na vida do litigante adquire significativa importância para análise da razoabilidade da duração do processo. Esses parâmetros são perfeitamente aplicáveis no direito brasileiro para fins de aferição da concretização do direito à duração razoável do processo. A complexidade da causa, sua importância na vida do litigante, o comportamento das partes e o comportamento do juiz – ou de qualquer de seus auxiliares – são critérios que permitem aferir racionalmente a razoabilidade da duração do processo” (Marinoni; Arenhart; Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 1, p. 265).

91

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 222.

92

“L’art. 55 n. 1 ha adottato, senza alcuna ragione, una vecchia formula da un lato difettosa, dall’altro sovrabbondante, la quale va rettificata mediante ‘interpretazione. Sono superflue le parole frode o concussione, le quali alludono a requisiti causali o formali dell’illecito indifferenti ai fini della responsabilità civile; necessario e sufficiente è che l’inosservanza dell’obbligo sia dolosa” (Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184).

93

Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184.

94

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 417.

As expressões são de João de Matos Antunes Varela, *Das obrigações em geral*, vol. 1, p. 449.

Sobre a relação entre causa de pedir e a regra *iura novit curia*: José Rogério Cruz e Tucci, *A causa petendi no processo civil*, p. 207.

A doutrina brasileira, ao tratar desta matéria, costuma ter por ponto de partida as lições de Carnelutti, para quem “la figura dell’atto simulato ha particolare importanza nel campo del processo, tanto che è prevista da particolari disposizioni della legge processuale: non quella, se intende, dell’atto processuale compiuto a scopo di esercizio didattico o di burla, il quale, sebbene non sia del tutto raro, non dà luogo, che io sappia, a questioni di diritto, bensì dell’atto simulato causa fraudis. La frode, il cui concetto è stato già chiarito a proposito della volontà, particolarmente temibile nel campo del processo, ivi non sempre opera da sola, sebbene spesso, se non per lo più, si accompagna alla simulazione; questa seconda ipotesi si avvera quando le parti non hanno reale interesse alla produzione degli effetti giuridici del processo e così alla cosa giudicata o al provvedimento satisfattivo; se, malgrado cioè, esse ricorrono al processo, così fanno perché la causa dei loro atti si realizza mediante la forma indipendentemente dagli effetti, che la legge vi collega, cioè mediante la apparenza degli effetti medesimi” (Francesco Carnelutti, *Sistema di diritto processuale civile*, vol. 2, p. 408).

Para mais detalhes: Alexandre Freitas Câmara, O direito à duração razoável do processo: entre eficiência e garantias, *Revista de Processo*, vol. 223, p. 39.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO IV - DO JUIZ E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

CAPÍTULO II DOS IMPEDIMENTOS E DA SUSPEIÇÃO

Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I – em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II – de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III – quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV – quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V – quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI – quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII – em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII – em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX – quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

§ 1.º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.

§ 2.º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz.

§ 3.º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Direito anterior – art. 134 do CPC/1973.

Direito comparado – § 41 da ZPO alemã, art. 51 do CPC. italiano, art. L111-6 do Code de l'organisation judiciaire francês e art. 122 do CPC português.

1. Juiz natural e imparcialidade. O direito constitucional ao juiz natural significa que as partes têm o direito de serem julgadas por um juiz simultaneamente competente e imparcial.¹ Mas a Constituição não exige do juiz apenas seu desinteresse *subjetivo* sobre quem ou não vai ganhar a demanda, mas lhe exige ainda que conduza o processo de modo *objetivamente* desinteressado.² O juiz natural, em outras palavras, não é apenas aquele que não *quer* em seu íntimo que uma das partes vença, mas aquele que ao conduzir o processo se *comporta* como se não o quisesse e cuja

imparcialidade não *possa* objetiva e razoavelmente ser colocada em dúvida. Não basta à mulher de César ser honesta, é preciso que ela também *pareça* ser honesta. Por isso, ao tratar das hipóteses de impedimento e suspeição, a lei tutela a *aparência de imparcialidade*, não a rigor a *efetiva e concreta* imparcialidade. Independentemente se parcial ou não em seu íntimo, deste modo, o juiz impedido ou suspeito não deve julgar a demanda em razão da mera *impressão de parcialidade* que sua relação com uma parte ou seu advogado pode *razoavelmente* suscitar.³⁻⁴

2. Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição são as duas espécies do gênero parcialidade, sendo a diferença entre elas mais o resultado de uma opção do legislador do que propriamente algo que decorra da natureza das coisas.⁵ O impedimento, de todo modo, é reputado pela lei uma versão mais grave de parcialidade, e por isso ele recebe dela tratamento mais rigoroso. Em ambas as hipóteses, no entanto, a exclusão do juiz não exige a comprovação no caso concreto de sua parcialidade. Basta o *perigo de imparcialidade*, maior no impedimento e menor na suspeição.⁶ Sobre as consequências práticas desta distinção para cada uma das espécies do gênero parcialidade (cognoscibilidade de ofício, preclusão etc.), confirmam-se os comentários aos arts. 146 e 147.

A preocupação da lei com a tutela da moralidade não retira do impedimento e da suspeição, de todo modo, seu caráter excepcional. O juiz não deve ser tratado como parcial até que demonstre não ser este o caso. Ao contrário, presume-se a sua imparcialidade até que o interessado comprove a parcialidade. Ao intérprete não se permite, assim, criar hipótese nova de impedimento ou suspeição não contemplada pela lei.⁷ Este o motivo por que a manifestação pública do juiz sobre o caso concreto que julgará, embora reprovável, e mesmo proibida pela Lei Orgânica da Magistratura,⁸ não deve ser considerada hipótese atípica de impedimento.⁹ Não existem hipóteses atípicas de impedimento. A situação é um pouco menos rígida na suspeição, como se melhor explicará nos comentários ao art. 145, porque em relação a ela a lei emprega tipos mais abertos, como o conceito jurídico indeterminado de “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes” (art. 145, IV).

Não é por outra razão, aliás, que “é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz” (§ 2.º). Proíbe-se, deste modo, a criação de impedimento *após* a definição do juiz natural. Trata-se de norma salutar, porque evita que a parte possa escolher – ainda que limitadamente – quem julgará a demanda; o impedimento, caso contrário, poderia vir a ser empregado como uma espécie de “poder de veto”. De certa maneira, inverte-se aqui o sentido do impedimento: aquele que dá causa ao impedimento é que fica *impedido* de atuar no processo, não o juiz.¹⁰ Mas e se a causa superveniente do impedimento decorrer do concurso de vontades entre a parte e o próprio magistrado – por exemplo, se uma parte contratar o juiz para lecionar em seu quadro de professores?¹¹ Neste caso, não se pode simplesmente “proibir” a parte de ser parte, como se faria com ele se seu advogado tivesse dado causa ao impedimento. O impedimento superveniente não ocorrerá, por expressa determinação legal, mas o juiz deve recusar-se com fundamento em sua suspeição. A arguição de impedimento e suspeição não deve transformar-se, em resumo, num instrumento de chicana e nem tampouco em um instrumento para a seleção de quem julgará a causa.

3. Intervenção anterior em outra função. O juiz estará impedido para officiar no processo “em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha” (inciso I). Presume a lei que a atuação *parcial* pretérita do juiz em benefício de uma das partes – na qualidade de seu mandatário – compromete inexoravelmente sua isenção para julgar. Por mandatário se quer dizer que o juiz representou a parte na qualidade de advogado ou estagiário naquele mesmo processo (não em qualquer outro) ou ainda que redigiu parecer sobre a causa a pedido de uma das partes. Opiniões manifestadas em trabalhos doutrinários, mesmo que favoráveis em tese a um dos litigantes, não são suficientes para justificar o perigo de parcialidade.¹² Estará também impedido o juiz que tenha atuado anteriormente, naquele mesmo processo, na qualidade de perito (também de assistente técnico) ou testemunha. Neste caso de impedimento, preocupa-se a lei em evitar que o juiz decida a demanda com fundamento em seu conhecimento privado dos fatos, o que não se permite.¹³ Também estará impedido o juiz que tenha atuado no processo na qualidade de membro do

Ministério Público – como *custos iuris* ou parte. O perigo de imparcialidade nasce aqui da radical independência entre as duas funções que o direito brasileiro, ao contrário de outros, como o francês, consagra.¹⁴ Para a configuração do impedimento do membro do Ministério Público, basta a mera participação em sessão de julgamento, “ainda que ausente manifestação expressa”.¹⁵

4. Julgamento anterior no mesmo processo. A lei reconhece também o perigo de parcialidade na situação em que um juiz – como relator ou vogal – deve julgar recurso – em qualquer dos graus de jurisdição – interposto de decisão proferida no *mesmo* ¹⁶ processo *judicial* ¹⁷ no qual ele já proferiu decisão; decisão interlocutória ou sentença, com “conteúdo decisório” (mas não necessariamente relativa ao mérito da demanda). Não basta a prática de atos de mero impulso oficial.¹⁸ Tutela-se também, neste caso de impedimento, o princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura às partes o direito de serem julgadas por pessoas diferentes em cada um dos graus da jurisdição. Por isso, o impedimento pressupõe necessariamente a existência, nos termos empregados pela lei, de um “outro grau de jurisdição”. O juiz, por exemplo, que se torna desembargador, está impedido de julgar a apelação interposta de sentença que ele mesmo proferiu. Mas o inverso também é possível. O juiz, convocado para atuar no Tribunal e que participa do julgamento de um agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória proferida em um determinado processo, estará impedido de officiar como juiz neste mesmo processo quando retornar para a 1.a instância. Pelo mesmo motivo, a exigência do “outro grau de jurisdição” para a configuração do impedimento, o desembargador não estará impedido de julgar os embargos de declaração opostos de decisão por ele próprio proferida, nem o ministro de participar do julgamento de agravo interno, interposto de decisão monocrática de sua própria lavra. Nestes dois casos, porque o grau de jurisdição é o mesmo.

5. Parentesco com o representante da parte ou com membro do Ministério Público. Estará também impedido o juiz para officiar no processo “quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público [ou ainda como advogado público; a lei disse aqui *minus quam voluit*], seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive”.¹⁹(inciso III). Nestes casos, o perigo de parcialidade advém das relações de parentesco entre o juiz e o representante judicial das partes ou o membro do Ministério Público. O dispositivo, como de modo geral todas as normas relativas a impedimento, deve ser interpretado à luz da presunção de imparcialidade de que gozam os juízes. Por isso, segundo o parágrafo primeiro, “o impedimento só se verifica quando o defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz”. Proíbe-se, deste modo, a criação *artificial* de impedimento, como se explicou nas notas introdutórias aos comentários deste artigo.²⁰ Inverte-se aqui o sentido do impedimento: aquele que dá causa ao impedimento é que fica *impedido* de atuar no processo, não o juiz.²¹

Não basta para a ocorrência do impedimento que o advogado conste da procuração outorgada pela parte sem nunca ter atuado no processo. A lei fala em “postular” e usa o tempo verbal presente. Por isso, apenas o advogado que *está postulando* em juízo torna impedido o juiz com quem tem relação de parentesco; não aquele que postulou mas não mais postula²² no momento em que o juiz passa a nele officiar. Pelo mesmo motivo, a atuação do parente na qualidade de estagiário não faz surgir o impedimento. A situação não é análoga a dos *profissionais* que representam ou apresentam a parte, e que são remunerados para isso. O estagiário é um mero aprendiz. Se quisesse, a lei poderia tê-lo incluído na lista deste inciso III. Se não o fez, é porque não quis fazê-lo. Mas se o estagiário se forma e se torna advogado, e após tornar-se advogado postula em nome da parte, ocorre evidentemente o impedimento superveniente. A interpretação *não expansiva* que se deve fazer na definição do impedimento não equivale, de todo modo, a dizer que, em todas estas situações, o juiz não terá comprometida sua imparcialidade. Se não se tratar de impedimento, poderá ser caso de suspeição como se verá nos comentários ao art. 145.

Este impedimento previsto no inciso III, por fim, “também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo” (§ 3.º). O dispositivo esclarece uma lacuna existente no regime do Código de Processo Civil de 1973, criando uma exceção à regra geral segundo a qual é a efetiva postulação no processo

em que o juiz oficia que dá causa ao impedimento. Neste caso, aquele que dá causa ao impedimento do juiz não postula, não intervém “diretamente no processo”. Para a lei, não importa. Se um advogado (não estagiário) de um escritório de advocacia (sócio, associado, celetista, desde que advogado) enquadrar-se em uma das situações de impedimento por parentesco, este impedimento “propaga-se” para todos os membros do escritório. A lógica, moralizadora e eficaz na repressão a abusos, é de que por ser membro do escritório o advogado tem um evidente interesse financeiro, ainda que indireto, no resultado da causa patrocinada por um de seus colegas e julgada por um parente seu. Não é absurdo exigir do juiz que saiba de quais escritórios seus parentes próximos são membros, e que identifique o impedimento ainda que não veja na petição a assinatura de seu familiar.²³ *De lege ferenda*, talvez fosse melhor tratar este caso como de suspeição, não de impedimento. Mas esta foi a opção do legislador.

6. Juiz em causa própria e parentesco com a parte. O inciso III trata dos casos em que existe relação de parentesco entre o juiz e o representante das partes ou do Ministério Público. O inciso IV, diferentemente, trata dos casos em que o próprio juiz ou um de seus familiares é parte. O juiz estará assim impedido “quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive”. Se o juiz é parte, ele não é sequer um terceiro, quanto menos um terceiro imparcial²⁴. Mas é também evidente o perigo de parcialidade na situação em que a própria parte é parente próximo do juiz (apenas se se tratar de parente próximo).

7. Sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica. A Lei Orgânica da Magistratura proíbe ao juiz, em seu art. 26, § 1.º, “o desempenho de função de direção administrativa ou técnica de estabelecimento de ensino”. O art. 36, II, também da Loman, interdita-lhe ainda “exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de classe, e sem remuneração”. Por isso se dizia, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, serem raros os casos em que incidiria a hipótese de impedimento de que trata o atual art. 144, V.²⁵ Acontece que existe uma diferença relevante em sua redação atual em relação ao dispositivo correspondente no antigo Código de Processo Civil: a alusão à qualidade de “sócio” da pessoa jurídica, situação que a Loman não proíbe o magistrado de ostentar. Por isso, sempre que o juiz for sócio, ou quotista, de uma sociedade, ou exercer a função de membro de direção ou de administração (na hipótese autorizada pela Loman – direção ou administração de associação de classe – ou mesmo em alguma outra em desconformidade com a proibição), estará sempre impedido de julgar. Pouco importa, aliás, a natureza da pessoa jurídica, se de direito público ou privado, se tem fins econômicos ou filantrópicos, se sociedade anônima ou não etc. O perigo de parcialidade decorrerá em todos estes casos da proximidade do juiz aos interesses sociais da pessoa jurídica a que ele é vinculado. Daí o impedimento.

8. Herdeiro presuntivo, donatário ou empregador. O perigo de parcialidade do juiz verifica-se também nas situações em que ele for herdeiro presuntivo, donatário (mesmo que onerosa a doação) ou empregador de uma das partes.²⁶ (inciso VI). Herdeiro presuntivo é aquele que, *presumidamente*, herdará na sucessão legítima ou testamentária – que herdará, em outras palavras, se nada mudar até a abertura da sucessão.²⁷ Mesma vedação aplica-se ao legatário, porque a causa que dá origem ao impedimento é rigorosamente a mesma. Se empregador da parte apenas o cônjuge do juiz, no entanto, o impedimento não ocorrerá. Será caso de suspeição.²⁸

9. Instituição privada de ensino. Estará impedido também o juiz no processo “em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços” (inciso VII). Basta a relação *atual* de emprego ou a existência *atual* de contrato de prestação de serviços, independentemente do número de horas trabalhadas e de sua regularidade. Também estará impedido, por isso, o juiz que leciona apenas uma vez por semestre na pós-graduação da instituição de ensino. A limitação, no entanto, não atinge o magistério em universidades públicas.

10. Cliente de escritório advocacia de cônjuge, companheiro ou parente. O impedimento atinge também o juiz em processo “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu

cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório” (inciso VIII). Esta novidade do Código de Processo Civil de 2015, bem-intencionada embora, é polêmica, e vem merecendo a censura da doutrina em razão de seu exagerado rigor.²⁹ Sobretudo porque não é possível exigir do juiz que conheça o nome de todos os clientes de seus parentes advogados. Sem a assinatura de seu parente nem o timbre do escritório de que ele é parte na petição, exatamente porque a parte é representada no processo por outra pessoa e outro escritório com a qual seu parente não tem nenhuma vinculação, exigir do juiz que conheça a situação de impedimento é exigir dele algo desproporcional. A constitucionalidade desse dispositivo é debatida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade [5.953/DF](#), ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros e de que é relator o ministro Edson Fachin. Até o momento, sem liminar (julho de 2018).

Por estes motivos, enquanto a norma existir e for eficaz, e ao contrário do que acontece nos demais casos de impedimento, em que é razoável presumir o conhecimento pelo juiz da situação fática que lhe faz estar impedido, o impedimento na hipótese do inciso VIII, excepcionalmente, só surge a partir do momento em que o juiz passa, comprovadamente, a ter ciência da causa de seu impedimento. Por exemplo, quando informado, mediante petição da parte interessada, de que uma parte é representada por seu parente em outro processo. Antes disso, não há “perigo de parcialidade” exatamente em razão da ignorância do magistrado – que se presume – sobre a relação existente entre seu cônjuge, companheiro, ou parente, e a parte. Esta circunstância excepcional autoriza, como se melhor explicará nos comentários ao art. 146, a “modulação” dos efeitos do reconhecimento do impedimento³⁰.

Este dispositivo cria ainda uma complicação suplementar. Em sua literalidade, ele parece atingir apenas escritórios de advocacia. Exige o princípio da isonomia, no entanto, que se dê o mesmo tratamento à advocacia pública e ao Ministério Público. Se o objetivo da norma é “evitar favorecimentos, que poderiam ser ocultados pela não participação formal no processo da pessoa próxima ao juiz”,³¹ a mesma lógica que se aplica aos advogados aplica-se a procuradores e promotores; aqueles ligados ao juiz por vínculos familiares, da mesma forma que advogados, poderiam “despachar” na intimidade do lar e da família em benefício de seus colegas de corporação e dos mesmos interesses que representa – exata situação que a lei visa a coibir. Ou se proíbe para todos, ou não se proíbe para nenhum.

11. Existência de litígio judicial entre o juiz e a parte ou seu advogado. Ocorrerá também impedimento na situação em que o juiz “promover ação contra a parte ou seu advogado” (inciso IX). Não é razoável, com efeito, exigir isenção do juiz que litiga contra a parte ou seu advogado em processo *judicial* de qualquer natureza [mas não em processo administrativo; aí será caso de suspeição]. Faltar-lhe-á a *aparência razoável de imparcialidade* que se exige de todo julgador. O impedimento ocorre, no entanto, não apenas na situação em que o magistrado demanda, mas também naquela em que ele é *demandado* pela parte ou seu advogado. E isso porque, nos dois casos, o perigo de imparcialidade é rigorosamente o mesmo.³² Com a ressalva, obviamente, do disposto no § 2.º desse dispositivo, que proíbe a criação do impedimento *após* a definição do juiz natural. Se não fosse assim, bastaria à parte, insatisfeita com o juiz de seu processo para torná-lo impedido, demandar contra ele pedindo, por exemplo, sua condenação por qualquer motivo ao pagamento de danos morais.

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1.º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2.º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I – houver sido provocada por quem a alega;

II – a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Direito anterior – art. 135 do CPC/1973.

Direito comparado – § 42 da ZPO alemã, art. 51 do CPC italiano, art. L111-6 do Code de l'organisation judiciaire francês e art. 127 do CPC português.

1. Juiz natural e imparcialidade. O direito constitucional ao juiz natural significa que as partes têm o direito de serem julgadas por um juiz simultaneamente competente e imparcial.³³ Mas a Constituição não exige do juiz apenas seu desinteresse *subjetivo* sobre quem ou não vai ganhar a demanda, mas lhe exige ainda que conduza o processo de modo *objetivamente* desinteressado.³⁴ O juiz natural, em outras palavras, não é apenas aquele que não *quer* em seu íntimo que uma das partes vença, mas aquele que ao conduzir o processo se *comporta* como se não o quisesse e cuja imparcialidade não *possa* objetiva e razoavelmente ser colocada em dúvida. Não basta à mulher de César ser honesta, é preciso que ela também *pareça* ser honesta. Por isso, ao tratar das hipóteses de impedimento e suspeição, a lei tutela a *aparência de imparcialidade*, não a rigor a *efetiva e concreta* imparcialidade. Independentemente se parcial ou não em seu íntimo, deste modo, o juiz impedido ou suspeito não deve julgar a demanda em razão da mera *impressão de parcialidade* que sua relação com uma parte ou seu advogado pode *razoavelmente* suscitar.³⁵ ³⁶

2. Impedimento e suspeição. Impedimento e suspeição são as duas espécies do gênero parcialidade, sendo a diferença entre elas mais o resultado de uma opção do legislador, do que propriamente algo que decorra da natureza das coisas.³⁷ O impedimento, de todo modo, é reputado pela lei uma versão mais grave de parcialidade, e por isso ele recebe dela tratamento mais rigoroso. Em ambas as hipóteses, no entanto, a exclusão do juiz não exige a comprovação no caso concreto de sua parcialidade. Basta o *perigo de imparcialidade*, maior no impedimento e menor na suspeição.³⁸ Sobre as consequências práticas desta distinção para cada uma das espécies do gênero parcialidade (cognoscibilidade de ofício, preclusão etc.), confirmam-se os comentários aos art. 146 e 147.

A preocupação da lei com a tutela da moralidade não retira do impedimento e da suspeição, de todo modo, seu caráter excepcional. O juiz não deve ser tratado como parcial até que demonstre não ser este o caso. Ao contrário, presume-se a sua imparcialidade até que o interessado comprove a parcialidade. Ao intérprete não se permite criar hipótese nova de impedimento ou suspeição não contemplada pela lei. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido, “o rol do art. 135 do CPC [atual 145] é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes”.³⁹ De todo modo, porque a lei reputa a suspeição menos grave do que o impedimento, os tipos previstos no art. 145 são mais abertos do que no art. 144, dando maior margem ao intérprete para qualificar determinada situação como criadora de suspeição.

Exatamente porque as regras sobre suspeição não devem ser interpretadas de modo expansivo, a lei considera ilegítima a alegação de suspeição quando ela “houver sido provocada por quem a alega” (§ 2.º, I) ou ainda quando “a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido” (§ 2.º, II). Suponha-se, por exemplo, que a parte adquira de uma instituição financeira, mediante cessão de crédito, uma dívida contraída pelo juiz ou por um familiar próximo dele para o financiamento de um veículo ou de um imóvel. Tornando-se *credora* do juiz ou de seu familiar, a parte alega em seguida sua suspeição com fundamento no inciso III. A alegação deve ser rejeitada, porque provocada a situação de suspeição exatamente por quem a

alega.⁴⁰ A segunda hipótese de “ilegitimidade” da arguição de suspeição não se confunde, por sua vez, com a preclusão temporal de que trata o art. 146. Ela ocorrerá quando o interessado realizar algum ato processual *durante* o prazo de quinze dias para arguir a suspeição, que se inicia apenas com a ciência do fato que dá causa a ela (art. 146), incompatível com a posterior alegação de suspeição (preclusão lógica). Por exemplo, participar da sessão de julgamento, nada falar sobre a suposta suspeição de que já tinha conhecimento, e suscitá-la, tempestivamente embora, apenas após perder o julgamento do recurso. Este dispositivo concretiza a cláusula geral de boa-fé expressa no art. 5.º do CPC.⁴¹

3. Motivo de foro íntimo. A regra, segundo a Constituição Federal, é a de que todas as decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX). Excepcionalmente, no entanto, a lei processual a dispensa, ao permitir ao juiz, com fundamento na proteção que a Constituição também dá à sua intimidade (art. 5.º, X, da CF), “declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões”. Caso se exigisse a fundamentação, com efeito, o juiz poderia vir a ser constrangido, de modo desnecessário, a revelar publicamente detalhes de sua vida privada, alguns eventualmente embaraçosos. A solução dada pela lei é proporcional e adequada, razão pela qual é flagrantemente ilegal a Resolução. 82, de 2009, do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual, nos casos de suspeição por motivo de foro íntimo, o magistrado deverá “fazer esta afirmação nos autos e, em ofício reservado, imediatamente expor as razões desse ato à Corregedoria Nacional de Justiça” (arts. 1.º e 2.º).⁴²

Embora a suspeição por motivo de foro íntimo produza seus efeitos típicos apenas no processo em que a sua declaração é feita, sem tornar o juiz automaticamente suspeito para officiar em qualquer outro, mesmo que entre as mesmas partes,⁴³ esta circunstância não deve deixar de ser levada em consideração, enquanto *indício de suspeição*, se esta questão vier a ser suscitada em outro processo. É equivocado o entendimento, todavia, de que “as causas ensejadoras da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo podem ser reavaliadas pelo magistrado, a quem compete averiguar se elas persistem ou não”.⁴⁴ E isso porque esta declaração de suspeição é motivo, por si só, para se colocar razoavelmente em dúvida a imparcialidade do juiz. Sua indecisão, no mesmo processo, acabaria por criar uma indesejável impressão de parcialidade – poderia mesmo sugerir uma motivação escusa para a mudança de opinião – que se deve evitar mediante o reconhecimento da *irrevogabilidade* da declaração.

4. Amigo íntimo ou inimigo da parte ou de seus advogados. Será também suspeito o juiz para officiar no processo quando “amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados” (inciso I). O Código de Processo Civil de 1973 falava apenas da amizade entre juiz e uma das partes, não entre juiz e um dos advogados. A expressão “qualquer das partes ou de seus advogados”, de todo modo, deve ser interpretada à luz da exigência constitucional de isonomia, no sentido de abarcar todos os sujeitos parciais do processo, representantes e presentantes das partes e os membros do Ministério Público (ainda quando atuam na qualidade de *custos iuris*). Quer-se evitar, neste caso de suspeição, a *impressão de parcialidade* que a existência de um vínculo emocional *forte* – positivo ou negativo – entre o juiz e um dos sujeitos do processo pode sugerir. Por isso a lei fala em amizade *íntima*⁴⁵ e em *inimizade*,⁴⁶ não apenas em *amizade* e em *antipatia*. A distinção é relevante, porque a suspeição ocorre apenas quando parecer razoável que o elemento afetivo existente seja forte o suficiente para perturbar a imparcialidade do juiz;⁴⁷ não exatamente aquela do juiz cuja suspeição concretamente se questiona, eventualmente menos [ou mais] suscetível do que seus colegas em geral, mas de um *iudex medius*, se se permite o uso da expressão.

Mas é preciso diferenciar, em relação ao rigor com que as expressões *amigo íntimo* e *inimigo* devem ser interpretadas, a relação entre o juiz e uma das partes daquela entre o juiz e um outro profissional do direito que atue no processo. E isso porque juízes, advogados, defensores, procuradores e promotores convivem proximamente, não raro diariamente, desde os bancos escolares. Não existe uma formação universitária para cada uma das profissões jurídicas. Este convívio inevitável forja relações pessoais que não sugerem a mesma impressão de parcialidade que igual proximidade entre juiz e uma das partes poderia insinuar. O *standard* exigido em cada um dos casos para a configuração da suspeição, em síntese, não é, e nem deve ser o mesmo. A circunstância de que o juiz e a parte são “amigos” em uma rede social, por exemplo, é um indício

maior de parcialidade do que a mesma circunstância entre juiz e advogado. De todo modo, esta análise deverá sempre considerar as particularidades do caso concreto.

A “afeição amorosa”,⁴⁸ o namoro, o noivado e o compadrio, em relação à parte e aos outros profissionais do direito indistintamente, suscitarão sempre o perigo de imparcialidade⁴⁹. Mesma coisa, por exemplo, no caso em que o juiz e a parte ou o juiz e outro sujeito do processo dividem um apartamento. Mas o tratamento deve ser diferente em casos menos evidentes. Se o juiz, amigo da parte, frequenta sua casa ou com ele faz viagens em família, verifica-se a suspeição. Se foi seu colega de colégio durante muitos anos, provavelmente também. Não talvez se fizeram juntos apenas um curso de inglês por período curto de tempo. A distinção entre a amizade e a amizade “íntima” será sempre um trabalho casuístico.

Mas a situação é diferente entre juiz e outro profissional jurídico, em razão da inevitável proximidade que a formação comum e o mesmo espaço de trabalho ocasionam. Não basta que tenham sido colegas de turma, na faculdade ou em uma pós-graduação. Não basta que lecionem na mesma instituição de ensino ou que tenham escrito um livro ou um artigo em coautoria. Não basta que tenham participado juntos de um congresso no estrangeiro. Não bastam que sejam vistos almoçando ou praticando esportes juntos. Não basta tampouco que tenham a mesma religião, frequentem a mesma paróquia ou igreja ou sejam membros de uma mesma sociedade filosófico-religiosa (maçonaria, positivismo etc.). Não basta ainda que tenham sido colegas de magistratura, ainda que membros do mesmo colegiado, antes da aposentadoria de um deles. Estas circunstâncias podem denotar a existência de uma relação social próxima entre eles, ou mesmo de amizade, mas não necessariamente de amizade *íntima*. Esta pressupõe uma relação mais estreita, a “estreita solidariedade”⁵⁰ a que alude Pontes de Miranda, objetivamente capaz de perturbar a isenção do juiz. A realização habitual de viagens de lazer ou em família (mas não de viagens profissionais, como para congressos) ou a saída para jantares também em família (não para jantares profissionais) podem, por exemplo, sugerir a existência desta relação mais estreita, mas não necessariamente demonstrá-la cabalmente. Um jantar oferecido na residência de um advogado em homenagem a um magistrado, obviamente, não é por si só sinal de amizade íntima. Tudo depende da análise das particularidades de cada caso, que deve sempre partir da premissa de que a imparcialidade é a regra e a parcialidade a exceção. Na dúvida, decide-se pela imparcialidade, não o contrário.

A inimizade, por seu turno, é algo mais forte do que a simples antipatia, embora não precise se tratar de uma inimizade *capital*. Ela pressupõe a existência de algum *sinal exterior* de inimizade. A existência de litígio judicial entre o juiz e a parte ou seu representante, como se viu nos comentários ao art. 144, é causa de *impedimento* do juiz, não de suspeição. Mas esta inimizade, mesmo sem a existência de litígio judicial, pode ser detectada de outras maneiras. Por exemplo, mediante a troca pública de insultos ou mesmo de agressões físicas. A existência de litígios *administrativos* entre o juiz e a parte ou seus representantes (por exemplo, a existência de representações contra o juiz nas corregedorias dos tribunais ou no Conselho Nacional de Justiça) não ocasiona, *automaticamente*, a suspeição. Mas é um indício de suspeição. De todo modo, é preciso evitar que a arguição de suspeição com fundamento na inimizade se transforme em um instrumento ilegítimo de seleção de juízes. Tal expediente viola a cláusula geral de boa-fé prevista no art. 5.º do CPC e deve ser rechaçada com fundamento no disposto no § 2.º, inciso I, segundo o qual a exceção será improcedente quando “houver sido provocada por quem a alega”.⁵¹

5. Presentes, conselhos e financiamento das despesas do litígio. Será suspeito também o juiz que “receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio” (inciso II). Os presentes, neste caso, deverão ter alguma expressão econômica (joias, passagens aéreas, estadias em hotéis, carros etc.); meros “brindes” não bastam (canetas, agendas etc.). Também o recebimento de comendas, medalhas e homenagens não se subsume no tipo legal. Um jantar em homenagem a um magistrado, por isso, não o torna suspeito para julgar uma demanda em que a parte é representada por seu anfitrião. A suspeição não se verificará, de todo modo, se o juiz recusar o presente ou devolvê-lo pouco tempo depois de recebê-lo; não, obviamente, se o fizer apenas depois de denunciada a suspeição. O aconselhamento

das partes a que se refere este dispositivo é aquele realizado antes ou fora do processo, por escrito (através de *legal opinion* ou parecer, por exemplo) ou mesmo informalmente (através de conselhos ministrados oralmente a um vizinho, por exemplo, nas dependências do condomínio em que moram). Não será caso de suspeição, no entanto, a defesa em textos doutrinários ou palestras de tese jurídica favorável a uma das partes. “O conselho dado a ambas as partes em audiência pelo juiz, especialmente na tentativa de se chegar a um acordo, também não enseja o reconhecimento da suspeição”.⁵² Mas desde que este aconselhamento não possa ser considerado, objetivamente, um constrangimento abusivo ou tendencioso. Se o juiz tenta convencer uma parte, de modo imoderado, exageradamente incisivo, a celebrar com outra um acordo, suscita inaceitável impressão de parcialidade que deve ser reprimida mediante o reconhecimento de sua suspeição, ainda que em seu íntimo tenha agido de boa-fé. Subministrar meios para atender às despesas do litígio significa, por fim, “financiar” diretamente uma das partes, ainda que por razões caritativas.⁵³ O emprego do advérbio “diretamente” é relevante porque se quer dizer que a suspeição não ocorrerá, por exemplo, se o juiz investir recursos em uma instituição financeira que, por seu turno, financia uma das partes (*third party funding* ⁵⁴).

6. Credor ou devedor da parte. A circunstância de que o juiz ou um de seus familiares próximos é credor ou devedor da parte cria também uma ameaça objetiva à sua imparcialidade. Daí por que ocorrerá a suspeição do juiz “quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive” (inciso III).

7. Cláusula aberta do interesse. Em razão do caráter excepcional da parcialidade, que não se presume, entende com razão o Superior Tribunal de Justiça que “o rol do art. 135 do CPC [atual 145] é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes”.⁵⁵ O inciso IV do art. 145 estabelece, no entanto, um “tipo aberto” de suspeição, ao considerar suspeito o juiz “interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”. Mas de que interesse se trata exatamente? Não é possível defini-lo previamente e em abstrato. Sua identificação será sempre uma tarefa casuística. Haverá suspeição, com efeito, quando o interesse do juiz – não necessariamente econômico – vier a colocar razoavelmente em dúvida a sua imparcialidade.⁵⁶ Convicções políticas, ideológicas, religiosas e mesmo jurídicas comuns entre juiz e uma das partes ou seus advogados não o tornam inexoravelmente suspeito. Mas podem vir a fazê-lo, a depender de outras circunstâncias concretas. Por exemplo, um histórico de ativa militância em favor de uma das partes do litígio. O interesse não deve ser também exageradamente tênue. O juiz não é necessariamente suspeito para julgar uma demanda que verse sobre um desastre ambiental ocorrido na cidade onde mora; mas se este desastre ocorrer na mesma rua onde tem sua residência, talvez esteja. A circunstância de que o juiz é parte em um processo em que se debate questão jurídica que lhe é posta a decidir em outro não o torna também necessariamente suspeito. Mas não deixa de ser um indício de suspeição que deve ser levado em consideração à luz das demais particularidades do caso concreto.⁵⁷

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.

§ 1.º Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal.

§ 2.º Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:

I – sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;

II – com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente.

§ 3.º Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal.

§ 4.º Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.

§ 5.º Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão.

§ 6.º Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.

§ 7.º O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição.

Direito anterior – art. 138 do CPC/1973.

Direito comparado – § 44 da ZPO alemã, art. 52 do CPC italiano, art. 342 a 345 do CPC francês e arts. 128 a 136 do CPC português.

1. Alegação de impedimento ou de suspeição. Impedimento e suspeição são defeitos cujo reconhecimento determina a substituição do juiz excluído por seu substituto legal e que tornam nulos os atos decisórios por ele praticados no curso do processo.⁵⁸ O interessado, “nestas duas hipóteses de parcialidade”, tem por força do disposto no *caput* o prazo preclusivo de quinze dias, a contar do conhecimento do fato que dá causa à parcialidade, para suscitá-la. Esta é uma grande inovação do Código de Processo Civil de 2015⁵⁹. A novidade é salutar, porque coíbe a prática contrária à cláusula geral de boa-fé prevista no art. 5.º da “nulidade guardada”, problema mais grave hoje do que na vigência do Código de Processo Civil de 1973 em razão da ampliação considerável pelo legislador das hipóteses de impedimento e suspeição.⁶⁰

Como resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com efeito, “o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma ‘carta na manga’, para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse”.⁶¹ E este entendimento deve aplicar-se, também segundo o STJ, mesmo quando se tratar de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas.⁶² Trata-se, enfim, de caso típico de *Verwirkung* (ou *suppressio*), porque ocorre aqui “a perda do direito da parte de alegar nulidade, em razão do lapso de tempo transcorrido, que fez surgir a confiança de que não mais alegaria a nulidade”.⁶³

A preclusão da arguição de parcialidade exige a comprovação de que o interessado teve *efetiva ciência* do fato que deu origem ao impedimento ou à suspeição, não apenas de que ele *poderia ter tido* conhecimento do fato e que nada fez. O silêncio do interessado, que comprovadamente sabe da situação de imparcialidade e mantém-se inerte, equivale à perda do direito de pedir a exclusão do juiz (*waiver*). Este *waiver* não impede o juiz, no entanto, de dar-se depois por impedido ou suspeito e afastar-se do processo. É aconselhável mesmo que o faça, até para preservar sua reputação entre seus pares e na própria comunidade jurídica. Apenas o próprio interessado é que não poderá, após o transcurso do prazo, arguir eficazmente a parcialidade do juiz.

A lei reputa o impedimento, de todo modo, uma versão mais grave de parcialidade, razão pela qual ele recebe tratamento mais rigoroso do que a suspeição. Por isso, o impedimento é um defeito que pode ser conhecido de ofício (desde que não tenha ocorrido o *waiver*), enquanto a suspeição não o pode (não, obviamente, pelo próprio juiz cuja imparcialidade se questiona, porque ele poderá sempre afastar-se, mas sim por outros juízes em grau de recurso). Pelo mesmo motivo, a ocorrência de impedimento, não de suspeição, (desde que não tenha também ocorrido o *waiver*) é um dos fundamentos da ação rescisória (art. 966, II). Não faria sentido algum permitir que o interessado “guardasse” a nulidade de que tem pleno conhecimento “em seu bolso”, ou na sua “algibeira” conforme expressão empregada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,⁶⁴

na expectativa de usá-lo em uma ação rescisória futura apenas caso venha a perder a demanda. A ação rescisória será cabível apenas se o interessado tiver conhecimento do impedimento após o trânsito em julgado.

2. Incidente processual de parcialidade. A parcialidade, em suas duas modalidades, deve ser arguida pelo interessado “em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas” (*caput*). O emprego do adjetivo “específica” sugere que o interessado deve deduzir sua arguição em petição própria (não, por exemplo, nas razões da apelação). Mas se trata de mera recomendação. O Código de Processo Civil de 2015 extinguiu, aliás, a exceção “ritual” de impedimento e suspeição com o exato objetivo de tornar menos formalista e complexo o processamento da arguição. Com o mero protocolo da “arguição de impedimento ou de suspeição” suspende-se o processo (art. 313, III).⁶⁵ Duas são então as possibilidades. Se o juiz reconhecer o impedimento ou a suspeição, “ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal” (§ 1.º). Caso contrário, “determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal” (parágrafo único). Para tanto, o próprio juiz terá capacidade postulatória. Não precisará constituir advogado para representá-lo.⁶⁶ O adversário do excipiente, ademais, não deve ser ouvido.⁶⁷ Neste incidente, são partes apenas o excipiente, que argui a parcialidade, e o excepto, cuja imparcialidade é questionada. Sendo parte, ao juiz não se permite julgar o incidente. Ele deve apenas processá-lo e remetê-lo ao órgão competente.⁶⁸

Distribuído o incidente para o órgão regimentalmente competente para julgá-lo, o relator pode rejeitá-lo liminarmente, se entendê-lo manifestamente improcedente. Se não o fizer, deverá decidir sobre os efeitos em que admite o seu processamento. “Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr” (parágrafo segundo, inciso primeiro); “com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente” (§ 2º, II). A competência para decidir sobre tutela de urgência, na pendência do incidente, não será nunca de seu relator. Sem efeito suspensivo, será do próprio juiz impugnado; com efeito suspensivo, ou antes de o relator decidir sobre os efeitos, de seu substituto legal (§ 3.º). Passa-se em seguida à instrução probatória, se o relator a entender necessária (depoimento pessoal, prova testemunhal etc.). O incidente será julgado pelo colegiado competente. Acolhida a alegação, “tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal” (§ 5.º). Vencido o excipiente, será ele o responsável pelo pagamento das custas. O juiz terá legitimidade para interpor recurso desta decisão (§ 5.º), não o adversário do excipiente.⁶⁹

3. Efeitos do julgamento do incidente de parcialidade. A procedência da alegação de impedimento ou suspeição produz dois efeitos principais. Em primeiro lugar, a determinação de que a demanda deve ser julgada pelo substituto legal do juiz impugnado. Este é o efeito típico do reconhecimento de parcialidade. Em segundo, é preciso que se decida sobre a validade dos atos processuais praticados pelo juiz até o momento em que o incidente é julgado. A questão não é simples, porque o reconhecimento do impedimento ou da suspeição não conduz “necessariamente” à invalidação de todos os atos praticados pelo juiz impedido ou suspeito. O tribunal deve obrigatoriamente fixar o “momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado” (§ 6.º), para que se possam determinar precisamente quais atos do juiz deverão ser atingidos pela invalidação. Em princípio, apenas os atos do juiz de conteúdo decisório poderão sê-lo. Mas nem sempre. Se o juiz impedido ou suspeito inquiriu testemunhas em audiência, por exemplo, é razoável que também o resultado desta prova venha a ser invalidado. E isso porque paira, à primeira vista, inaceitável “perigo de parcialidade” sobre a maneira com que o juiz formulou perguntas e conduziu a oitiva. Diz-se à primeira vista porque a extensão da invalidação deve ser sempre avaliada casuisticamente, de modo a atingir apenas os atos praticados sob a “impressão de parcialidade” e no espírito de preservar o que puder ser preservado.⁷⁰

É exatamente à luz desta ideia que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que “a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição”.⁷¹ Preserva-se o que não foi atingido pelo defeito. Diz-se, também

segundo o STJ, que “a participação de Ministro impedido em julgamento em órgão colegiado não anula o julgado se o seu voto não tiver sido decisivo para o resultado”.⁷² Em princípio, talvez, mas é preciso ter-se cuidado com generalizações. Não é inconcebível que a participação do ministro ou desembargador impedido tenha sido decisiva para o resultado. Por exemplo, por ser ele o relator, cujo voto seus colegas apenas acompanharam. Neste caso, o julgamento deve ser invalidado.

É com fundamento no disposto no § 1.º, ademais, segundo o qual “o tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição”, que se permite ao tribunal “modular” os efeitos do reconhecimento da parcialidade, de modo a evitar a consumação de resultados desproporcionais. Pense-se no exemplo dado por Alexandre Câmara para demonstrar o exagero com o que o Código de Processo Civil de 2015 trata algumas hipóteses de impedimento.⁷³ Se, se entender que o juiz “não tinha conhecimento” do fato gerador do impedimento ou da suspeição, até determinado momento do processo, ou que “não fosse razoável que ele tivesse”, deve-se considerar inválidos “apenas” os atos realizados posteriormente à ciência.

Art. 147. Quando 2 (dois) ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará, remetendo os autos ao seu substituto legal.

Direito anterior – art. 136 do CPC/1973.

Direito comparado – art. 124 do CPC português.

1. Parentesco entre juízes e impedimento. O art. 147 estabelece uma outra hipótese de impedimento, fora daquelas descritas no rol do art. 144. Segundo este dispositivo, quando dois ou mais juízes – independentemente se de mesmo grau de jurisdição ou se de grau diverso⁷⁴ – “forem parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue”. Justifica-se a existência de impedimento nestes casos, porque da relação de parentesco próxima advém o perigo de que o segundo juiz poderá não se sentir inteiramente isento para decidir como lhe mandam o direito e sua consciência. Trocará impressões sobre a causa com seu parente no espaço privado da família? Sentir-se-á incomodado de decidir em sentido contrário à maneira com que ele decidiu? A substituição do segundo juiz, nesta hipótese, revela-se razoável.

A expressão “conhecer do processo”, neste contexto, significa simplesmente “oficiar” no processo, não necessariamente nele proferir uma decisão. Se o juiz apenas participou da sessão de julgamento em que decidido um recurso, presidindo-a ou não, sem ter votado, não há impedimento. E isso porque, neste caso, ele não terá sequer oficiado no processo. A arguição do impedimento deve seguir a regra geral estabelecida no art. 146. Também se aplica aqui tudo que se disse lá sobre os efeitos do reconhecimento da parcialidade sobre os atos anteriormente praticados pelo juiz impedido.

Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

I – ao membro do Ministério Público;

II – aos auxiliares da justiça;

III – aos demais sujeitos imparciais do processo.

§ 1.º A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos.

§ 2.º O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária.

§ 3.º Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1.º será disciplinada pelo regimento interno.

§ 4.º O disposto nos §§ 1.º e 2.º não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunha.

Direito anterior – art. 138 do CPC/1973.

Direito comparado – § 406 da ZPO alemã, art. 73 do CPC italiano e art. 125 do CPC português.

1. Impedimento e suspeição dos demais sujeitos imparciais do processo. O Código de Processo Civil trata detalhadamente, como se viu nos comentários aos arts. 144 a 147, dos casos de impedimento e suspeição dos juízes. Não é apenas deles, no entanto, que se exige imparcialidade. Também os demais *sujeitos imparciais* do processo, todos eles, só poderão atuar no processo se não estiverem impedidos ou suspeitos.⁷⁵ A lei foi redundante, ao falar em “auxiliares da justiça” (inciso II) e “demais sujeitos imparciais do processo” (inciso III), mas fez isso para não correr o risco de dizer menos do que queria. Rigorosamente todos aqueles de quem se espera imparcialidade no processo sujeitam-se às regras sobre impedimento e suspeição. A eles se aplicam, no que couber, os tipos de impedimento previstos no art. 144 e de suspeição previstos no art. 145.

O art. 149 descreve, de modo exemplificativo, quais são estes sujeitos: “são auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias”. Diz-se *de modo exemplificativo* porque este dispositivo não esgota, intencionalmente, as espécies concebíveis de auxiliar da Justiça. É o caso em alguns estados, por exemplo, do contador judicial.⁷⁶ O perito submete-se às regras de impedimento e suspeição, porque dele se exige a *impressão de parcialidade* (sobre o ponto, confirmam-se os comentários ao arts. 156 e seguintes), mas não o assistente técnico, escolhido pela parte exatamente em função da relação de confiança existente entre elas. Sobre a arguição de parcialidade do perito, quando se tratar de pessoa jurídica, confirmam-se os comentários ao art. 156. As regras previstas neste art. 148 não se aplicam, ademais, à impugnação de testemunhas (§ 4.º). E isso porque se exige *alguma* imparcialidade delas, mas com certos temperamentos que justificam a existência de um regime próprio de “contradita” (art. 457).

Da mesma forma como faz em relação aos juízes, a lei exige dos auxiliares da justiça não apenas seu desinteresse *subjetivo* sobre quem ou não vai ganhar demanda, mas ainda que pratiquem os atos processuais que lhe incumbem de modo *objetivamente* desinteressado. Por isso, ao tratar das hipóteses de impedimento e suspeição, a lei tutela a *aparência de imparcialidade*, não a rigor a *efetiva e concreta* imparcialidade. Independentemente se parcial ou não em seu íntimo, deste modo, os sujeitos impedidos ou suspeitos não devem atuar no processo em razão da mera *impressão de parcialidade* que sua relação com uma parte ou seu advogado pode *razoavelmente* suscitar.

A impressão de parcialidade que justifica o reconhecimento do impedimento ou da suspeição é aquela entre o auxiliar da justiça e a parte ou seu advogado, não entre ele e o juiz. Não há parcialidade porque não há vinculação a um sujeito *parcial* do processo. Não, obviamente, que esta proximidade não seja indesejável. Não é adequado que um juiz, por exemplo, nomeie seu filho como perito em um processo aos seus cuidados. Mas este é um problema de natureza administrativa. Normas outras é que devem proibir o nepotismo nas relações entre juízes e seus auxiliares, não aquelas relativas a impedimento e suspeição. Controverso embora na doutrina,⁷⁷ este parece ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.⁷⁸

2. Impedimento e suspeição do membro do Ministério Público. A análise da parcialidade do membro do Ministério Público dependerá da função por ele exercida no processo. Na qualidade de *custos iuris*, com efeito, o Ministério Público deve ser imparcial. Nesta hipótese, aplicam-se a seus membros as regras gerais sobre impedimento e suspeição dos sujeitos imparciais do processo. Se parte, no entanto, o Ministério Público, apresentado por seu membro, torna-se um sujeito parcial do processo, de quem não se espera, naturalmente, indiferença em relação ao resultado da demanda.

Por isso, as regras sobre parcialidade do Ministério Público ganham uma feição especial

quando sua atuação no processo se dá na qualidade de parte. O Ministério Público, obviamente, terá interesse na vitória da pretensão por ele próprio deduzida na demanda. Mas seu representante não poderá ter um *interesse pessoal* nesta vitória. As regras de impedimento e suspeição de seu membro, em outras palavras, devem ser sempre interpretadas à luz do princípio constitucional da *impessoalidade* (ou da finalidade⁷⁹).⁸⁰ E porque “o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros”.⁸¹ As vedações previstas nos arts. 144 e 145 aplicam-se ao membro do Ministério Público, assim, de modo a evitar a “impressão de pessoalidade” que eventual relação entre ele e a demanda puder vir a suscitar. A função do Ministério Público é defender em juízo o “interesse público”, não os interesses particulares de seus membros. Se estas duas coisas parecerem confundir-se, justifica-se a substituição.

3. Incidente de impedimento ou de suspeição. Como as consequências da parcialidade do auxiliar da justiça ou do membro do Ministério Público, ainda que obviamente danosas, são menos graves do que a parcialidade do juiz, processam-se de modo diferente os respectivos incidentes de reconhecimento. O incidente de impedimento ou de suspeição de um auxiliar da justiça ou do membro do Ministério Público se processa, com efeito, “em separado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando a produção de prova, quando necessária” (§ 2.º). Nos tribunais, conforme dispuser o respectivo regimento interno (§ 3.º). A arguição deve ser feita pelo interessado “na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos” (§ 1.º) a partir do momento – e apenas a partir deste momento – em que o interessado toma conhecimento do motivo do impedimento ou da suspeição. Regra especial é aquela aplicável à impugnação do perito. Neste caso, o prazo é de quinze dias “contados da intimação do despacho de nomeação do perito” (art. 465, § 1.º, I), desde, obviamente, que o interessado já tenha conhecimento do motivo do impedimento ou da suspeição. Se posterior a este momento a ciência, a preclusão só ocorrerá se a parcialidade não vier a ser arguida na primeira oportunidade em que couber ao interessado falar nos autos após a ciência.

São dois também os efeitos do reconhecimento da parcialidade. Em primeiro lugar, a substituição do sujeito afastado por seu substituto legal. Em segundo, a invalidação dos atos processuais viciados pela parcialidade. Neste ponto, é preciso ter-se enorme cuidado. A decretação de nulidade deve observar sempre a máxima *pas de nullité sans grief* e o princípio do aproveitamento dos atos defeituosos.⁸² O laudo produzido por um perito impedido, por exemplo, deve ser, obviamente, invalidado. O impedimento do escrivão, diferentemente, não determinará, na grande maioria dos casos, a invalidação dos atos por ele praticados. Tudo depende de uma análise casuística das circunstâncias particulares da demanda e dos atos concretamente praticados pelo sujeito, de modo a que se possa determinar se houve ou não prejuízo para o interessado.

NOTAS DE RODAPÉ

1

“Uma das garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal é a do direito fundamental ao juiz natural. Trata-se de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: o que proíbe juízo ou tribunal de exceção e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente (incisos XXXVII e LIII do art. 5.º da CF/88). Trata-se essa garantia de uma conquista moderna” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 183).

2

“Outra coisa é pretender que o juiz seja neutro, no sentido de indiferente ao êxito do pleito. Ao magistrado

zeloso não pode deixar de interessar que o processo leve a desfecho justo; em outras palavras, que saia vitorioso aquele que tem melhor direito. Em semelhante perspectiva, não parece correto afirmar, *sic et simpliciter*, que para o juiz ‘tanto faz’ que vença o autor ou que vença o réu. A afirmação só se afigura verdadeira enquanto signifique que ao órgão judicial não é lícito preferir a vitória do autor ou a do réu, e menos que tudo atuar de modo a favorecê-la, por motivos relacionados com traços e circunstâncias pessoais de um ou de outro; porque o autor é X, simpático, ou porque o réu é Y, antipático, ou vice-versa” (José Carlos Barbosa Moreira, Reflexões sobre a imparcialidade do juiz, in: *Temas de direito processual* (sétima série), p. 29).

3

Neste sentido a doutrina alemã: „Maßgebend ist nicht, ob der Richter wirklich befangen ist oder sich selbst (...) für befangen befangen hält, sondern ob vom Standpunkt der betreffenden Partei aus genügende objektive Gründe vorliegen, die in den Augen eines vernünftigen Menschen geeignet sind, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu erregen“ (Stein;Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 893).

5

“A distinção entre as hipóteses de impedimento e de suspeição, assim, resulta simplesmente de opção de política legislativa e não é informada por um critério lógico” (José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 277).

6

Também Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 584.

7

Neste sentido: AgRg no REsp 1124107/PR, j. em 24.04.2014, 2.^a Turma rel. Min. Og Fernandes, *DJe* 20.05.2014.

8

Art. 36 – É vedado ao magistrado: III – manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério.

9

Para uma análise profunda das implicações da manifestação pública de juizes sobre causas em que officiam: Claudia Gerdes, *Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit aufgrund von Meinungsäußerungen des Richters*, p. 56.

10

“Descabe o ingresso do advogado no processo depois que os respectivos autos foram distribuídos para

órgão colegiado de que faça parte magistrado com o qual o causídico possui relação de parentesco. Caso contrário, estar-se-ia, em tese, legitimando a criação de impedimento superveniente não aleatório de integrante que, originariamente, já compunha o órgão competente para o julgamento da questão. Inteligência dos arts. 134, parágrafo único, c/c 137, ambos do Código de Processo Civil” (HC 300.629/BA, j. em 28.04.2015, 5.ª Turma, rel. Mi. Felix Fischer, *DJe* 15.05.2015).

11

Suponha-se, neste exemplo, que o juiz concorde com sua contratação: “Não se admite a criação proposital de fato superveniente que produza impedimento, como se daria, por exemplo, no caso de uma instituição de ensino querer contratar um magistrado para seu corpo docente com o intuito de torná-lo impedido para uma causa” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 113).

12

Também André Vasconcelos Roque, in Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* p. 498.

13

Sobre a questão: Volker Lipp, *Das private Wissen des Richters* (1995), p. 49 e ss.

14

Para mais detalhes: Alexander Araujo de Souza, Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou, *Revista dos Tribunais*, vol. 951, p. 227.

15

“O artigo 134, II, do Código de Processo Civil [de 1973] dispõe que é defeso ao juiz, dentre outras vedações, atuar em processo no qual tenha funcionado como órgão do Ministério Público. A participação de membro do Ministério Público Federal em sessão de julgamento, ainda que ausente manifestação expressa do representante do parquet, configura o exercício da função de agente ministerial (art. 20 da LC 75/93)” (REsp 529.771/PR, j. em 03.02.2005, 1.ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, *DJ* 11.04.2005, p. 179).

16

Por isso não ocorre impedimento, com fundamento neste dispositivo, quando o julgador da ação rescisória tiver proferido decisão no processo em que prolatada a decisão rescindenda. Trata-se de uma nova demanda e de um novo processo. Neste sentido: “Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo. Inteligência da Súmula 252 do STF” (EDcl no AgRg na AR 5.656/DF, j. em 13.04.2016, 1.ª Seção, rel. Min. Gurgel De Faria, *DJe* 20.04.2016).

17

Não administrativo. Neste sentido: “O Superior Tribunal de Justiça adotou posicionamento no sentido de que a regra de impedimento prevista no art. 134, III, do CPC, somente se aplica nos casos em que o

magistrado tenha participado em outro grau de jurisdição em um mesmo processo judicial, e não quando a sua participação anterior tenha ocorrido na esfera administrativa” (RMS 18.099/PR, j. em 02.05.2006, 5.^a Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, *DJ* 12.06.2006, p. 500).

18

“Consoante o disposto no artigo 134, III, do CPC, a prática de atos de impulso oficial em primeira instância não acarreta o impedimento de magistrado à participação no julgamento de apelação relativa ao mesmo processo” (STJ, REsp 649.062/ES, j. em 28.06.2005, 4.^a Turma, rel. Mini. CESAR Asfor Rocha, *DJ* 10.10.2005, p. 379).

19

“Destaque-se que, nos termos do art. 1.595, § 1.º do CC/2002, não há parentesco por afinidade além do segundo grau na linha colateral, não se caracterizando o impedimento. Em relação ao parentesco na linha reta, assim como no CPC/1973, não há limitação de grau, seja por consanguinidade ou afinidade. Dessa forma, estão impedidos de atuar no processo, filhos, pais, netos, avós, bisnetos, bisavós (parentes por consanguinidade), assim como genro ou nora, sogros, padrasto, madrasta ou enteados (parentes por afinidade). A dissolução do casamento ou união estável extingue o parentesco por afinidade na linha colateral, mas não na linha reta (art. 1.595, § 2.º, do CC/2002), persistindo o impedimento daí decorrente” (André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 501).

20

As partes não têm assim um virtual “poder de veto” sobre a escolha do juiz que julgará a demanda. Neste sentido: “Se na relação jurídica processual já estava o juiz quando o advogado se apresentou para sua função, ilegal é a atitude do advogado, criaria impedimento do juiz. Se isso fosse permitido, qualquer parte que tivesse interesse em afastar o juiz empregaria uma das causas de impedimento...” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 424).

21

“Descabe o ingresso do advogado no processo depois que os respectivos autos foram distribuídos para órgão colegiado de que faça parte magistrado com o qual o causídico possui relação de parentesco. Caso contrário, estar-se-ia, em tese, legitimando a criação de impedimento superveniente não aleatório de integrante que, originariamente, já compunha o órgão competente para o julgamento da questão. Inteligência dos arts. 134, parágrafo único, c/c 137, ambos do Código de Processo Civil” (HC 300.629/BA, j. em 28.04.2015, 5.^a Turma, rel. Min. Felix Fischer, *DJe* 15.05.2015).

22

O que se comprova mediante a existência de instrumento de revogação da procuração ou de renúncia aos poderes outorgados anteriores ao momento em que o juiz passa a officiar.

23

Não se pode dizer o mesmo sobre todos os clientes do escritório de advocacia do qual seu parente é membro, como melhor se explicará quando se tratar da hipótese prevista no inciso VIII.

24

Com razão Pontes de Miranda, acentuando a obviedade do dispositivo, em dizer que esta hipótese “prescinde de análise. Nunca se poderia admitir que a relação jurídica processual fosse entre A e A (juiz) ou entre A (juiz) e B” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 421).

25

Por exemplo: Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 426.

26

Em todos os casos em que o juiz for empregador da parte, não apenas naqueles tipicamente lembrados pela doutrina: “Empregador” é o juiz que tem a parte como secretário, ou empregado doméstico, ou motorista, ou como encarregado de qualquer serviço para o juiz” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 426).

27

Naturalmente, “a presunção de herança cessa, por outro lado, se existem pessoas mais próximas a excluir o magistrado da sucessão” (André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 503).

28

“Em sentido contrário: Surge o problema de se saber se o art. 135, III, 3.a parte [atual art. 144, VI, 3.a parte] apanha o empregado do cônjuge, para serviços só de cônjuge (e.g., a mulher do juiz mantém como costureira a parte, o marido da juíza tem secretário ou secretária que é parte na ação). A resposta tem de ser afirmativa, se o laço do empregado é permanente e não apenas para alguns dias, paga por diária, ou por horas de serviço, ou pelo que se executa” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 426).

29

“Não se pode deixar de registrar aqui o exagero desta situação de impedimento. Em primeiro lugar, é preciso considerar a existência de grandes firmas de advocacia com atuação em número muito grande de lugares, tendo em alguns casos filiais em diversos Estados da Federação. Imagine-se, então, o caso de um juiz estadual do Rio Grande do Sul que tenha um sobrinho advogado que atue em um escritório de advocacia no Amazonas (do que sequer é um dos sócios). Considere-se, agora, que o sobrinho do juiz seja um advogado especializado em tributos federais, só atuando perante a Justiça Federal. Pois se o escritório em que atua o sobrinho do juiz tiver, no Mato Grosso, entre seus clientes, uma instituição financeira (como um banco, por exemplo), ficará aquele juiz do Rio Grande do Sul impedido de atuar nos processos em que aquele mesmo banco é parte. Haveria aí alguma ligação entre o juiz e a parte capaz de causar sua parcialidade? Certamente não!” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 112).

30

Neste sentido: Olavo de Oliveira Neto, *Comentários ao Código de Processo Civil* (Scarpinella Bueno), vol. 2, p. 649.

31

André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 502.

32

Neste mesmo sentido: Daniel Amorim Assumpção Neves, *Novo Código de Processo civil comentado artigo por artigo*, p. 243.

33

“Uma das garantias decorrentes da cláusula do devido processo legal é a do direito fundamental ao juiz natural. Trata-se de garantia fundamental não prevista expressamente, mas que resulta da conjugação de dois dispositivos constitucionais: o que proíbe juízo ou tribunal de exceção e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade competente (incisos XXXVII e LIII do art. 5.º da CF/88). Trata-se essa garantia de uma conquista moderna” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 183).

34

“Outra coisa é pretender que o juiz seja neutro, no sentido de indiferente ao êxito do pleito. Ao magistrado zeloso não pode deixar de interessar que o processo leve a desfecho justo; em outras palavras, que saia vitorioso aquele que tem melhor direito. Em semelhante perspectiva, não parece correto afirmar, *sic et simpliciter*, que para o juiz ‘tanto faz’ que vença o autor ou que vença o réu. A afirmação só se afigura verdadeira enquanto signifique que ao órgão judicial não é lícito preferir a vitória do autor ou a do réu, e menos que tudo atuar de modo a favorecê-la, por motivos relacionados com traços e circunstâncias pessoais de um ou de outro; porque o autor é X, simpático, ou porque o réu é Y, antipático, ou vice-versa” (José Carlos Barbosa Moreira, Reflexões sobre a imparcialidade do juiz, in: *Temas de direito processual* (sétima série), p. 29).

35

Neste sentido a doutrina alemã: „Maßgebend ist nicht, ob der Richter wirklich befangen ist oder sich selbst (...) für befangen befangen hält, sondern ob vom Standpunkt der betreffenden Partei aus genügende objektive Gründe vorliegen, die in den Augen eines vernünftigen Menschen geeignet sind, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu erregen“ (Stein;Jonas, *Kommentar zur ZPO*, vol. 1, p. 893).

37

“A distinção entre as hipóteses de impedimento e de suspeição, assim, resulta simplesmente de opção de

política legislativa e não é informada por um critério lógico” (José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 277).

38

Também Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 584.

39

AgRg no Ag 1422408/AM, j. em 05.02.2013, 4.^a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJe* 21.03.2013.

40

“Não se admite que alegue suspeição do juiz aquele que lhe tenha dado causa (assim, por exemplo, a parte que, no curso do processo, manda um presente para o gabinete do juiz e em seguida alega sua suspeição)” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 113).

41

Este tema merece ser tratado também monograficamente. Neste sentido, por exemplo: Brunela Vieira de Vincenzi, *A boa-fé no processo civil*, p. 157. Também Viana; Gagliano, Boa-fé objetiva processual – reflexões quanto ao atual CPC e ao projeto do novo Código, *Revista Forense*, vol. 416, p. 521.

42

A constitucionalidade destas normas é objeto de impugnação no Supremo Tribunal Federal.

43

“A afirmação de suspeição por motivo de foro íntimo em determinado processo não impede o exercício da jurisdição em outros feitos, distribuídos ao magistrado por força de prevenção” (REsp 202.914/RS, j. em 17.10.2000, 6.^a Turma, rel. Min. Vicente Leal, *DJ* 20.11.2000, p. 319).

44

REsp 1109148/RJ, j. em 24.08.2010, 2.^a Turma, rel. Min. Eliana Calmon, *DJe* 03.09.2010.

45

Como resume Pontes de Miranda, “íntima diz-se a amizade quando há laços afetivos, notórios ou não, mas verificáveis por fatos de estreita solidariedade, que possam influir no julgamento pela determinação psicológica, consciente ou não” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 425).

46

O CPC não fala mais em “inimizade capital”, como fazia o CPC/1973.

47

E não se esqueça da advertência de Calamandrei: “A amizade pessoal entre o juiz e o advogado não é, ao contrário do que julgam os profanos, um elemento que possa ser útil ao cliente, pois se o juiz é escrupuloso, tem tanto medo que a amizade possa inconscientemente levá-lo a ser parcial a favor do amigo que é naturalmente levado, por reação, a ser injusto com ele. Para um juiz honesto, que tenha de decidir uma causa entre um amigo e um indiferente, é preciso maior força para dar razão ao amigo do que para lhe negar; é preciso maior coragem para se ser justo, arriscando-se a parecer injusto, do que para ser injusto, ainda que fiquem salvas as aparências da justiça” (Piero Calamandrei, *Eles, os juizes, vistos por nós, os advogados*, p. 211).

48

“Não apenas a amizade, mais frequente entre pessoas do mesmo sexo, se inclui no conceito, mas também a afeição amorosa, que, por ser, em geral, de natureza mais intensa, tem maior probabilidade de quebrar a imparcialidade do juiz” (Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 430).

49

Neste sentido: Araken de Assis, *Processo civil brasileiro*, vol. 2, item 967.3.

50

Como resume Pontes de Miranda, “íntima diz-se a amizade quando há laços afetivos, notórios ou não, mas verificáveis por fatos de estreita solidariedade, que possam influir no julgamento pela determinação psicológica, consciente ou não” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 425).

51

Neste sentido, também André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 505.

52

Também André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 506.

53

“Tampouco pode o juiz dar meios a qualquer das partes para atender a despesas – quaisquer que sejam – do litígio. Mesmo se a parte se encontra em estado de miséria. O seu dever de justiça, que é na dimensão social do Direito, tem de passar à frente e por sobre da caridade, que é na dimensão da Moral e na da Religião” (Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 428).

54

Litigation funding pode ser definido como um “contractual arrangement whereby a third party pays the cost of litigation and in return, if the cases succeeds, receives a percentage of the proceeds” (Legg; Park; Turner; Travers, *The Rise and Regulation of Litigation Funding in Australia*, 38 N. Ky. L. Rev., p. 625).

55

AgRg no Ag 1422408/AM, j. em 05.02.2013, 4.^a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, *DJe* 21.02.2013.

56

Embora a lógica aplicável ao impedimento e à suspeição de árbitros não seja exatamente a mesma do juiz estatal, porque eles são escolhidos pelas partes, o caráter objetivo desta impressão de parcialidade é bem acentuado pelas Guidelines on conflicts of interests publicados pela International Bar Association: “Doubts are justifiable if a reasonable third person, having knowledge of the relevant facts and circumstances, would reach the conclusion that there is a likelihood that the arbitrator may be influenced by factors other than the merits of the case as presented by the parties in reaching his or her decision” (p. 4).

57

Para mais detalhes: Francesco Luiso, *Diritto processuale civile*, vol. 1, p. 149.

58

Sobre os efeitos do reconhecimento da nulidade praticados pelo juiz, confira-se mais adiante o item “efeitos do julgamento do incidente” dos comentários a este mesmo artigo.

59

Em sentido contrário, por exemplo: “A doutrina afasta a preclusão para as situações de impedimento, dado o caráter absoluto da nulidade, capaz de comprometer de modo irremediável o processo, por reconhecido imparcialidade. Segundo este entendimento, o prazo de quinze dias teria por objetivo apenas a formalização por meio de exceção, uma vez que pode inclusive ser reconhecido de ofício, pelo juiz” (Mirna Cianci, in: Cabral; Cramer, *Comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 272).

60

Por exemplo, no caso de impedimento do juiz para officiar em processo “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório” (art. 144, VIII). Sobre ela: “Não se pode deixar de registrar aqui o exagero desta situação de impedimento. Em primeiro lugar, é preciso considerar a existência de grandes firmas de advocacia com atuação em número muito grande de lugares, tendo em alguns casos filiais em diversos Estados da Federação. Imagine-se, então, o caso de um juiz estadual do Rio Grande do Sul que tenha um sobrinho advogado que atue em um escritório de advocacia no Amazonas (do que sequer é um dos sócios). Considere-se, agora, que o sobrinho do juiz seja um advogado especializado em tributos federais, só atuando perante a Justiça Federal. Pois se

o escritório em que atua o sobrinho do juiz tiver, no Mato Grosso, entre seus clientes, uma instituição financeira (como um banco, por exemplo), ficará aquele juiz do Rio Grande do Sul impedido de atuar nos processos em que aquele mesmo banco é parte. Haveria aí alguma ligação entre o juiz e a parte capaz de causar sua parcialidade? Certamente não!” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 112).

61

Pet 9.971/DF, j. em 17.12.2013, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJe* 03.02.2014. Para mais detalhes: João Roberto de Sá Dal’Col, Algumas notas sobre a chamada ‘nulidade guardada’, in: *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 1467.

62

“A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade” (REsp 1439866/MG, j. em 24.04.2014, 6.^a Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, *DJe* 06.05.2014).

63

Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 114. Faça-se apenas a ressalva de que o autor não se vale deste raciocínio para sustentar a possibilidade de perda da arguição de impedimento.

64

“A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada “nulidade de algibeira ou de bolso”” (EDcl no REsp 1424304/SP, j. em 12.08.2014, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrigli, *DJe* 26.08.2014).

65

Sobre a fluência de prazos atingidos em seu curso pela suspensão do processo, dispõe o art. 221 do CPC o seguinte: “Suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do art. 313, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação”.

66

“Note que o magistrado tem capacidade postulatória para fazer a sua defesa no incidente, não precisando de advogado. Para Nelson Nery Jr. e Rosa Nery, essa capacidade postulatória do magistrado o habilita, inclusive, a subscrever recursos para o STJ e STF, caso seja derrotado no julgamento da exceção, sem a necessidade de representação judicial por advogado. Não se encampa esse último posicionamento, pela falta de amparo legal, tendo em vista que a capacidade concedida ao magistrado foi apenas a de elaborar a sua defesa” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 689).

“Por consectário lógico, somente aquele de quem se poderia exigir isenção e imparcialidade pode ser apontado como suspeito e, assim, ter legitimidade para reconhecer ou refutar as alegações, considerando-se as hipóteses de suspeição previstas 135 do CPC [atual art. 145]” (REsp 909.940/ES, j. em 17.09.2013, 4.^a Turma, rel. Min. Raul Araújo, *DJe* 04.08.2014).

“Trata-se, excepcionalmente, de prazo próprio para o juiz [o prazo de quinze dias previsto no parágrafo primeiro], cujo descumprimento acarreta preclusão. A parte contrária ao suscitante não necessita ser ouvida porque este incidente se instaura apenas entre a parte interessada e o juiz alegadamente impedido ou suspeito. Por isso mesmo, não pode o próprio magistrado julgar o incidente, nem indeferi-lo de plano e muito menos condenar a parte que o suscitou como litigante de má-fé. Não concordando com as razões que lhe foram apresentadas, somente resta ao juiz ordenar a remessa do incidente ao tribunal, com ou sem suas razões, para que a instância superior proceda ao julgamento” (André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 510).

“Sem gravame não há recurso e gravame é o prejuízo (jurídico) que advirá para a parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Se o juiz se afirma suspeito, de ofício, e remete o processo para seu substituto legal, nenhum prejuízo jurídico ocasiona à parte, porque o foro e o juízo competente não se alteram, somente ocorrendo a modificação física da pessoa do juiz. Por igual no caso de impedimento. O foro e o juízo perduram; muda-se o juiz pessoa física, no caso concreto. Único gravame possível só o de ser suspeito ou impedido o substituto legal, mas neste caso o modo correto de afastar o gravame (prejuízo em sentido lato) é o oferecimento da exceção adequada para recusa deste segundo juiz. E se o substituto nem é impedido, nem é suspeito, ele é subjetivamente capaz, nada sendo lícito à parte reclamar. Admitir-se recurso nessas hipóteses seria aceitar-se a existência de um direito da parte a ser julgada por determinado juiz (pessoa física) e não pelo juiz competente e compatível, que é a garantia assegurada em lei” (José Joaquim Calmon de Passos, *Comentários ao Código de Processo Civil*, v. 3, p. 334).

Por exemplo, no que concerne à aplicação da máxima *pas de nullité sans grief*: “A doutrina tem chamado de princípio da transcendência àquele de que se origina a regra de que, para que a nulidade seja declarada, é necessário que esta produza prejuízo. Do contrário, não se deve decretar a nulidade” (Teresa Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, p. 170). Também em relação ao princípio do aproveitamento dos atos defeituosos: “Somente se deve nulificar um ato do procedimento ou o próprio procedimento se não for possível aproveitá-lo – do mesmo modo que a invalidação deve restringir-se ao mínimo necessário, mantendo-se incólumes partes do ato que possam ser aproveitadas, por não terem sido contaminadas. O magistrado deve tentar aproveitar o ato processual ou o procedimento defeituoso. Eis o princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos, que se aplica sempre, pouco importa o grau do defeito do ato ou do procedimento” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 412).

72

EResp 1008792/RJ, j. em 09.02.2011, 2.^a Seção, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJe* 29.04.2011.

73

Por exemplo, no caso de impedimento do juiz para officiar em processo “em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório” (art. 144, VIII). Sobre ela: “Não se pode deixar de registrar aqui o exagero desta situação de impedimento. Em primeiro lugar, é preciso considerar a existência de grandes firmas de advocacia com atuação em número muito grande de lugares, tendo em alguns casos filiais em diversos Estados da Federação. Imagine-se, então, o caso de um juiz estadual do Rio Grande do Sul que tenha um sobrinho advogado que atue em um escritório de advocacia no Amazonas (do que sequer é um dos sócios). Considere-se, agora, que o sobrinho do juiz seja um advogado especializado em tributos federais, só atuando perante a Justiça Federal. Pois se o escritório em que atua o sobrinho do juiz tiver, no Mato Grosso, entre seus clientes, uma instituição financeira (como um banco, por exemplo), ficará aquele juiz do Rio Grande do Sul impedido de atuar nos processos em que aquele mesmo banco é parte. Haveria aí alguma ligação entre o juiz e a parte capaz de causar sua parcialidade? Certamente não!” (Alexandre Freitas Câmara, *O novo processo civil brasileiro*, p. 112).

74

“O Código de Processo Civil de 2015 não contém a limitação à atuação do tribunal, de maneira que, à luz do novo sistema, a proibição imposta pela lei opera também em relação a juízes que mantenham parentesco entre si e atuem em graus de jurisdição diferentes. Assim, por exemplo, caberá ao desembargador designado relator do recurso remeter o processo ao seu substituto, se, em 1.^o grau de jurisdição, um juiz parente seu tiver proferido decisão” (Arruda Alvim Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 289).

75

Sobre impedimento e suspeição dos membros do Ministério Público, confirmam-se os comentários mais adiante.

76

Sobre o ponto: André Vasconcelos Roque, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 510).

77

Por exemplo: “Não parece apropriado, p. ex., que o juiz nomeie seu irmão para atuar como perito, já que, em tese, tal circunstância pode influenciar a apreciação do laudo pericial (cf. art. 479 do CPC). Note-se, ademais, que, consoante estabelece o art. 147 do CPC, há restrições à atuação de juízes parentes, quando

um deles já tiver atuado no feito. O princípio que embasa tal disposição serve, também, a que se restrinja a nomeação de parente como auxiliar, pelo juiz da causa” (José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 282).

78

Segundo o precedente citado pelos julgamentos posteriores (as referências legislativas são ainda ao Código de Processo Civil de 1973: “O legislador, ao definir as hipóteses de suspeição e impedimento, atentou apenas para as possíveis relações existentes entre o juiz e as partes do processo, ou, conforme o art. 138, III, do CPC, entre as partes e o perito, nada dispondo acerca de eventuais vínculos, seja de que natureza for, entre o juiz e os seus auxiliares (peritos, serventuários, intérpretes etc). Uma vez nomeado para officiar nos autos, o perito, sendo irmão do juiz que o nomeou, poderia até mesmo – o que seria uma atitude louvável – declarar a sua suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do parágrafo único do art. 135 acima transcrito. Tratando-se, todavia, de hipótese de suspeição, esta deve ser argüida em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 138, § 1.º). Assim, conquanto não constitua exemplo de ética profissional, não há na lei processual civil nada que impeça o juiz de nomear o seu próprio irmão para officiar nos autos como seu assistente, não sendo causa suficiente, portanto, para se declarar, de ofício, a nulidade do julgamento” (REsp 906.598/MT, j. em 19.06.2007, 1.ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, DJ 02.08.2007, p. 407).

79

“O princípio da impessoalidade, referido na Constituição/88 (art. 37, *caput*), nada mais é do que o clássico princípio da finalidade, o qual impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal (...). E a finalidade terá sempre um objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo: o interesse público. Todo ato que se apartar desse objetivo sujeitar-se à invalidação por desvio de finalidade...” (Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 95).

80

“Corolário do princípio republicano, a impessoalidade manifesta-se como expressão de não protecionismo e de não perseguição, realizando, no âmbito da Administração Pública [e também do Ministério Público, obviamente], o princípio da igualdade, previsto na Constituição Federal em seu art. 5.º, *caput*. Em razão do princípio da impessoalidade, não há relevância jurídica na posição pessoal do administrador ou servidor público, pois a vontade do Estado independe das preferências subjetivas do servidor ou da própria Administração” (Ferreira Mendes; Gonet Branco, *Curso de direito constitucional*, p. 859).

81

Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 95.

82

Por exemplo, no que concerne à aplicação da máxima *pas de nullité sans grief*: “A doutrina tem chamado de princípio da transcendência àquele de que se origina a regra de que, para que a nulidade seja declarada, é necessário que esta produza prejuízo. Do contrário, não se deve decretar a nulidade” (Teresa

Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, p. 170). Também em relação ao princípio do aproveitamento dos atos defeituosos: “Somente se deve nulificar um ato do procedimento ou o próprio procedimento se não for possível aproveitá-lo – do mesmo modo que a invalidação deve restringir-se ao mínimo necessário, mantendo-se incólumes partes do ato que possam ser aproveitadas, por não terem sido contaminadas. O magistrado deve tentar aproveitar o ato processual ou o procedimento defeituoso. Eis o princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos, que se aplica sempre, pouco importa o grau do defeito do ato ou do procedimento” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 412).

4

Embora a lógica aplicável ao impedimento e à suspeição de árbitros não seja exatamente a mesma do juiz estatal, porque eles são escolhidos pelas partes, o caráter objetivo desta impressão de parcialidade é bem acentuado pelas *Guidelines on conflicts of interests* publicados pela International Bar Association: “Doubts are justifiable if a reasonable third person, having knowledge of the relevant facts and circumstances, would reach the conclusion that there is a likelihood that the arbitrator may be influenced by factors other than the merits of the case as presented by the parties in reaching his or her decision” (p. 4). Para mais detalhes: Gary Born, *International Commercial Arbitration*, vol. 2, p. 1760.

36

Embora a lógica aplicável ao impedimento e à suspeição de árbitros não seja exatamente a mesma do juiz estatal, porque eles são escolhidos pelas partes, o caráter objetivo desta impressão de parcialidade é bem acentuado pelas *Guidelines on conflicts of interests* publicados pela International Bar Association: “Doubts are justifiable if a reasonable third person, having knowledge of the relevant facts and circumstances, would reach the conclusion that there is a likelihood that the arbitrator may be influenced by factors other than the merits of the case as presented by the parties in reaching his or her decision” (p. 4). Para mais detalhes: Gary Born, *International Commercial Arbitration*, vol. 2, p. 1760.

Comentários ao CPC - v. II - Marinoni - Ed. 2018**TÍTULO IV - DO JUIZ E DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA****CAPÍTULO III - DOS AUXILIARES DA JUSTIÇA**

Art. 149. São auxiliares da Justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Direito anterior – art. 139 do CPC/1973.

1. Auxiliares da Justiça. A jurisdição é exercida no Brasil, salvo em casos excepcionalíssimos previstos expressamente na Constituição,¹ por servidores públicos que integram o Poder Judiciário (juízes). A prestação deste serviço público que é a administração da justiça não se esgota, no entanto, no *decidir* do juiz. Para que ele decida adequadamente, é às vezes mais eficiente e às vezes mesmo necessário que ele conte com o *apoio* de auxiliares. Não é inconcebível, por exemplo, que os juízes pudessem eles próprios autuar os processos e atender partes e advogados nos balcões das serventias judiciais. Mas não seria eficiente. A presença de um intérprete na audiência em que se ouvirá uma testemunha estrangeira que não domina o idioma português, diferentemente, não é apenas útil, mas sim indispensável. Sem ele, o juiz *não pode* interrogar a testemunha.

Auxiliares da justiça são assim “*peçoas a quem o sistema do processo atribui o encargo de realizar os serviços complementares à jurisdição, sob a autoridade do juiz*”.² São eles, conforme o rol exemplificativo do art. 149, “*o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias*”. Diz-se apenas *exemplificativo* o rol porque a lei permite, expressamente, que as normas de organização judiciária criem outras funções de apoio aos juízes.³ A lei exige de todos os auxiliares da justiça, ademais, independentemente se *permanentes* (por exemplo, os oficiais de justiça) ou *eventuais* (por exemplo, os intérpretes), se servidores públicos (por exemplo, os escrivães) ou não (por exemplo, os peritos), se pessoas físicas ou jurídicas (em casos especiais como o do perito ou do administrador judicial), que atuem com imparcialidade. Para mais detalhes sobre a arguição de impedimento e suspeição dos auxiliares da justiça, confirmam-se os comentários ao art. 148. O auxiliar da justiça é ainda *civilmente* responsável (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que causar às partes do processo.⁴ Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o auxiliar com fundamento no disposto no art. 927 do CC; ou b) regressiva, deduzida contra o auxiliar pelo Estado com fundamento em diversos dispositivos espalhados pelo CPC (por exemplo, pelo art. 155, que trata da responsabilidade regressiva dos escrivães e oficiais de justiça) e, em última análise, com fundamento no próprio art. 37, 6.º, da CF.

Embora o tema mereça tratamento mais aprofundado, que se deixa para outra ocasião, o ponto central é de que o art. 37, § 6.º, da Constituição não exclui a responsabilidade civil direta do agente público, apenas regulamenta a sua responsabilidade regressiva no caso em que o Estado venha a ser demandado pelos danos causados por seu agente. A função deste dispositivo constitucional, com efeito, não é o de *limitar* o direito do prejudicado à indenização, mas sim de dar-lhe a alternativa de seguir o caminho menos tortuoso da responsabilidade objetiva do Estado fundada na doutrina do risco administrativo. Diz-se “menos tortuoso” porque a responsabilidade direta exige a comprovação do elemento subjetivo que se dispensa na demanda contra Estado.⁵ Esta *mens* mostra-se ainda mais evidente, aliás, quando se lembra que a responsabilidade objetiva se estende também às pessoas de “*direito privado prestadoras de serviços públicos*”. Não haveria

sentido algum em considerá-las imunes à responsabilidade direta.

Seção I Do escrivão, do chefe de secretaria e do oficial de justiça

Art. 150. Em cada juízo haverá um ou mais ofícios de justiça, cujas atribuições serão determinadas pelas normas de organização judiciária.

Direito anterior – art. 140 do CPC/1973.

1. Ofícios de justiça. Juízos são órgãos jurisdicionais. Alguns são unipessoais, como as varas de 1ª instância, outros colegiados, como as câmaras dos tribunais estaduais ou as turmas dos tribunais regionais federais e dos tribunais superiores. Todos, em conjunto, formam a *Justiça*.⁶ O funcionamento de cada juízo não seria possível, no entanto, sem a existência de uma estrutura burocrática a ele vinculada (às vezes mais de uma, especialmente em comarcas menores): o ofício de justiça, que não se confunde com os *oficiais de justiça* de que trata o art. 151.⁷ Trata-se de uma repartição pública, a que se dá o nome de cartório ou secretaria. Nela trabalham, sob a autoridade e a supervisão do juiz, os *escreventes*, chefiados por um *diretor* – normalmente chamado de escrivão, secretário ou chefe de secretaria. Sua função típica, embora não a única, como se verá nos comentários ao art. 152, é “*a de documentar os atos processuais e a de movimentar a relação processual*”.⁸

Art. 151. Em cada comarca, seção ou subseção judiciária haverá, no mínimo, tantos oficiais de justiça quantos sejam os juízos.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Oficiais de justiça. O oficial de justiça, auxiliar permanente da Justiça, é a *longa manus* do juiz. São “*executores judiciais: intimam, notificam, citam e realizam as execuções*”.⁹ Suas competências estão previstas no art. 154. Entre o juiz e o oficial de justiça deve existir uma relação de confiança, porque sua função é a de levar a autoridade do juiz aonde ele próprio não vai pessoalmente. Este o motivo por que, tradicionalmente, a cada juízo vinculam-se um ou mais oficiais de justiça determinados, familiarizados pelo hábito com a maneira com que cada juiz trabalha. Recentemente, no entanto, normas de organização judiciária têm reunido oficiais de justiça em *grupos*, desvinculando-os das respectivas varas. A inovação não parece acertada, porque enfraquece a relação de confiança e proximidade que cada juiz deve ter com aquele que lhe serve de *longa manus*. A impessoalidade, neste caso, dificulta a fiscalização e supervisão do trabalho destes auxiliares permanentes e indispensáveis da justiça. A lei, de todo modo, não veda a criação destes grupos nem tampouco torna obrigatória a substituição do sistema tradicional; exige apenas que o *número total* de oficiais de justiça em uma comarca ou tribunal não seja *menor* que o número total de juízos.

Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

I – redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;

II – efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;

III – comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo;

IV – manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:

a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;

b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;

c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;

d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;

V – fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;

VI – praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.

§ 1.º O juiz titular editará ato a fim de regulamentar a atribuição prevista no inciso VI.

§ 2.º No impedimento do escrivão ou chefe de secretaria, o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato.

Direito anterior – art. 141 do CPC/1973.

1. Competências do escrivão e do chefe de secretaria. Sem o apoio de uma estrutura burocrática a ele vinculada, não seria possível ao juiz exercer adequadamente a função jurisdicional que lhe incumbe exercer, como se explicou nos comentários ao art. 151. Daí a importância do *cartório* e dos auxiliares da justiça a ele funcionalmente ligados para a prestação deste serviço público que é a boa administração da justiça. O primeiro destes auxiliares permanentes da justiça é o diretor do cartório, que a lei denomina escrivão ou chefe de secretaria. A eles se aplicam as regras gerais sobre impedimento e suspeição relativas aos auxiliares da justiça, nos termos do disposto no art. 148. Reconhecida a parcialidade, esclarece este dispositivo, “o juiz convocará substituto e, não o havendo, nomeará pessoa idônea para o ato” (parágrafo segundo).

Suas competências, que ele pode delegar aos escreventes a ele subordinados, sob a direção e fiscalização do juiz, são descritas em caráter exemplificativo no art. 152. Elas terão sempre caráter administrativo, nunca jurisdicional.¹⁰ Entre elas, destacam-se a de secretariar o juiz nas audiências,¹¹ de realizar o atendimento ao público nos balcões das serventias, de guarda e conservação dos autos dos processos, de autuá-los e numerá-los, de documentar – nos respectivos autos ou em livros e registros próprios – os atos processuais realizados, de redigir mandados, ofícios, cartas e demais documentos e de lavrar certidões. Esta última competência – a de lavrar certidões – é de considerável relevância prática e não raro fonte de desavenças na prática forense. A certificação pelo escrivão, a quem a lei reconhece fé pública, de algo que ocorreu ou que deixou de ocorrer no curso do processo é uma providência que o interessado tem o direito de pedir diretamente a ele, independentemente de qualquer determinação específica do juiz; ainda, obviamente, que mediante o pagamento de custas para a realização do ato.

Em relação à competência de “manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório” (inc. IV) é preciso apenas lembrar que este dispositivo deve ser interpretado em consonância com o direito dos advogados à vista e carga dos autos, conforme explicado nos comentários ao art. 107. Sua lógica é a de que os autos – físicos, obviamente – do processo devem deixar o cartório apenas quando estritamente necessário, precaução esta que contribui para minimizar os riscos de extravio e de ocorrência de danos. Com a digitalização e virtualização dos processos, de todo modo, os riscos passam a ser outros (desaparecimento e manipulação do arquivo digital em que salvo o processo¹²). O escrivão tem também competência para “praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios” (inc. VI).¹³ Atos meramente ordinatórios, com efeito, são “atos de puro e simples impulso processual”¹⁴ despidos de qualquer conteúdo decisório.¹⁵ Trata-se de uma exceção, razoável, à regra de que os pronunciamentos judiciais devem ser praticados apenas pelo próprio juiz. Nada proíbe o juiz, aliás, de despachar pessoalmente, se assim preferir, nem o escrivão de delegar esta competência para um escrevente. Mas deve existir alguma espécie de regulamentação de natureza administrativa que defina, em termos abstratos, como e em quais casos esta competência deve ser exercida (parágrafo primeiro). Ressalva-se também, sempre, a possibilidade de *revisão* do ato pelo juiz (art. 203, § 4.º).

A situação em que às partes é assinalado prazo para se manifestarem exige, no entanto, atenção especial. Será ato meramente ordinatório apenas quando se tratar de prazo *legal*, nunca quando se tratar de prazo *judicial*. A ressalva é mais relevante hoje do que o era na vigência do CPC/1973 exatamente porque se permite agora ao juiz, omissa a lei, determinar “os prazos em consideração à

complexidade do ato” (art. 218, § 1.º) e mesmo “*dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito*” (art. 139, VI). Nestes casos, a fixação ou dilatação do prazo têm evidente conteúdo decisório, o que torna privativa do juiz a prática destes atos.

Art. 153. O escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais. (Redação dada pela Lei 13.256/2016)

§ 1.º A lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública.

§ 2.º Estão excluídos da regra do *caput*:

I – os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado;

II – as preferências legais.

§ 3.º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-ão a ordem cronológica de recebimento entre os atos urgentes e as preferências legais.

§ 4.º A parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 (dois) dias.

§ 5.º Constatada a preterição, o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Ordem cronológica no processamento dos feitos. Embora menos polêmica do que em relação à prolação de sentenças e acórdãos,¹⁶ a exigência de observância da ordem cronológica no processamento dos feitos pelo cartório foi também objeto de reforma legislativa pouquíssimo tempo antes da entrada em vigência do CPC/2015. O texto “*o escrivão ou chefe de secretaria deverá obedecer à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais*”, conforme a redação original do art. 153, deu lugar ao atual, segundo o qual “*o escrivão ou o chefe de secretaria atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais*”. A justificativa para as duas mudanças foi a mesma, mas sem razão.

A situação do juiz é completamente diversa daquela do escrivão, cujo trabalho, em razão de seu caráter essencialmente burocrático, não demanda a mesma *maturação* intelectual que poderia vir a justificar a prolação de uma sentença antes de outra.¹⁷ Nada explicaria o tratamento desigual, no processamento dos autos, de um caso em detrimento de outro, salvo nas exceções previstas em lei: “*os atos urgentes, assim reconhecidos pelo juiz no pronunciamento judicial a ser efetivado*” (§ 2.º, I) e “*as preferências legais*” (§ 2.º, II).¹⁸ O emprego do advérbio “preferencialmente” no *caput* deste dispositivo, todavia, clara opção do legislador por temperar os rigores da redação original do dispositivo, não deve ser ignorado pelo intérprete. Admite-se assim o descumprimento da ordem cronológica, desde que este descumprimento possa ser considerado razoável e inocente à luz da própria dinâmica de trabalho do cartório. Casos patológicos devem ser reprimidos.¹⁹

Serão assim duas assim as listas: a primeira dos processos sem prioridade, ordenados cronologicamente, e a segunda dos processos com prioridade, ordenados também cronologicamente. Mas não haverá *prioridades* dentro da lista de prioridades, conforme esclarece o parágrafo terceiro. A ordem nesta segunda lista deverá ser estritamente cronológica. Também não é obrigatório que o escrivão esgote a lista de prioridades, antes de ocupar-se do processamento dos feitos constantes da primeira. Ele precisará encontrar uma solução equilibrada na distribuição de trabalho entre os escreventes de modo a não sacrificar, de modo imoderadamente gravoso, o direito das partes envolvidas – todas elas, com ou sem prioridade – à

duração razoável do processo.

Como a transparência é o melhor instrumento para a fiscalização da ordem cronológica e para a identificação de casos patológicos, o parágrafo primeiro determina que *“a lista de processos recebidos deverá ser disponibilizada, de forma permanente, para consulta pública”*. A existência destas listas poderá, aliás, contribuir também para que os próprios funcionários do cartório tenham noção mais exata da duração dos processos em curso perante sua serventia e, com isso, possam melhor identificar gargalos e consertá-los mais eficientemente. É altamente recomendável, de todo modo, especialmente em tempos de processo eletrônico, que os sistemas de informática dos tribunais organizem e alimentem as listas automaticamente. Não é razoável que a administração destas listas consuma tempo exagerado do escrivão e dos escreventes, impedindo-lhes de desempenharem satisfatoriamente suas demais funções.

2. Preterição. Porque o advérbio “preferencialmente” não torna inócua a ordem cronológica, mas apenas tempera o primitivo rigor do texto, casos patológicos deverão ser reprimidos pelo juiz. Por este motivo, *“a parte que se considerar preterida na ordem cronológica poderá reclamar, nos próprios autos, ao juiz do processo, que requisitará informações ao servidor, a serem prestadas no prazo de 2 (dois) dias”* (parágrafo quarto). Confirmada a preterição, *“o juiz determinará o imediato cumprimento do ato e a instauração de processo administrativo disciplinar contra o servidor”* (parágrafo quinto).

Art. 154. Incumbe ao oficial de justiça:

I – fazer pessoalmente citações, prisões, penhoras, arrestos e demais diligências próprias do seu ofício, sempre que possível na presença de 2 (duas) testemunhas, certificando no mandado o ocorrido, com menção ao lugar, ao dia e à hora;

II – executar as ordens do juiz a que estiver subordinado;

III – entregar o mandado em cartório após seu cumprimento;

IV – auxiliar o juiz na manutenção da ordem;

V – efetuar avaliações, quando for o caso;

VI – certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber.

Parágrafo único. Certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso VI, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa.

Direito anterior – art. 143 do CPC/1973.

1. Competências do oficial de justiça. O oficial de justiça, auxiliar permanente da Justiça, é a *longa manus* do juiz. São *“executores judiciais: intimam, notificam, citam e realizam as execuções”*.²⁰ Entre ele e o juiz deve se estabelecer uma relação de confiança, porque sua função é a de levar a autoridade do juiz aonde ele próprio não vai pessoalmente. É neste sentido amplo que se diz que ele deve *“executar as ordens do juiz a que estiver subordinado”* (inc. II). A eles incumbe, precipuamente, a realização de *“diligências processuais externas, a serem realizadas fora do recinto do fórum e no local onde se encontrem as pessoas ou bens em relação aos quais ele deve atuar”*.²¹ Entre estas diligências, as mais comuns são aquelas relativas ao cumprimento de atos de comunicação processual (como citações e intimações pessoais) e de atos de constrição (como a penhora, o arresto, o sequestro, etc). Mas a elas soma-se a competência para efetuar avaliações, quando a avaliação não depender de conhecimento técnico especializado (inc. V)²² e ainda para *“auxiliar o juiz na manutenção da ordem”* (IV). O desempenho desta última competência vem sendo cada vez menos comum, sobrevivendo ainda especialmente em comarcas menores onde não existem núcleos de oficiais de justiça desvinculados das respectivas varas.

2. Mandado. A ordem dada pelo juiz ao oficial de justiça é corporificada no mandado (de *mandar*, daí por que *mandado*, não *mandato*). É através dele que o juiz determina exatamente qual diligência o oficial de justiça deve cumprir e em quais condições. Por isso, cumprido ou não cumprido, o mandado deve sempre ser devolvido ao cartório pelo oficial de justiça encarregado, o mais brevemente possível, com a indicação do que de relevante aconteceu em seu cumprimento (inc. III). Por exemplo, no cumprimento de um mandado de citação, com o registro de que a diligência foi infrutífera porque o citando não foi encontrado no endereço indicado. Aquilo que o oficial de justiça certifica é dotado de fé pública, da qual decorre a presunção *relativa* de sua veracidade²³ independentemente ou não da assinatura das duas testemunhas a que alude o inc. I. Elas servem apenas como um *reforço* de que aquilo que o oficial de justiça certificou realmente aconteceu, não como requisito de validade do cumprimento da diligência.

O CPC de 2015 acrescentou ainda às competências do oficial de justiça, no espírito de estímulo à conciliação que o permeia, a regra segundo a qual lhe incumbe “*certificar, em mandado, proposta de autocomposição apresentada por qualquer das partes, na ocasião de realização de ato de comunicação que lhe couber*” (inc. VI). A ideia deste dispositivo é criar uma nova oportunidade para que as partes possam durante o processo chegar a uma solução negociada do litígio. Por isso, segundo o parágrafo único, “*certificada a proposta de autocomposição prevista no inciso VI, o juiz ordenará a intimação da parte contrária para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa*”.

Art. 155. O escrivão, o chefe de secretaria e o oficial de justiça são responsáveis, civil e regressivamente, quando:

I – sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados;

II – praticarem ato nulo com dolo ou culpa.

Direito anterior – art. 144 do CPC/1973.

1. Responsabilidade civil do diretor do cartório²⁴ e do oficial de justiça. O diretor do cartório e o oficial de justiça serão *civilmente* responsáveis (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que causar às partes do processo. Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o diretor do cartório ou o oficial de justiça com fundamento no disposto no art. 927 do Código Civil; ou b) regressiva, deduzida pelo Estado com fundamento no disposto no *caput* do art. 143, autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada com fundamento, por sua vez, no disposto no art. 37, § 6.º, da CF.²⁵

Embora o tema mereça tratamento mais aprofundado, que se deixa para outra ocasião, o ponto central é de que a o art. 37, § 6.º, da Constituição não exclui a responsabilidade civil direta do agente público, apenas regulamenta a sua responsabilidade regressiva no caso em que o Estado venha a ser demandado pelos danos causados por seu agente. A função deste dispositivo constitucional, com efeito, não é o de *limitar* o direito do prejudicado à indenização, mas sim de dar-lhe a alternativa de seguir o caminho menos tortuoso da responsabilidade objetiva do Estado fundada na doutrina do risco administrativo. Diz-se “menos tortuoso” porque a responsabilidade direta exige a comprovação do elemento subjetivo que se dispensa na demanda contra Estado.

Esta *mens* mostra-se ainda mais evidente quando se lembra que a responsabilidade objetiva se estende também às pessoas de “*direito privado prestadoras de serviços públicos*”. Não haveria sentido algum, com efeito, em considerá-las imunes à responsabilidade direta. O CPC não elimina nem veda, portanto, a responsabilidade direta do diretor do cartório ou do oficial de justiça,²⁶ apenas regulamenta ao seu lado a sua responsabilidade regressiva. Tampouco permite àquele que se considera prejudicado deduzir sua pretensão no mesmo processo em que alega ter sofrido o prejuízo.

Em relação à responsabilidade direta, subjetiva, vale a regra geral: ela pressupõe a comprovação do dolo ou da culpa. Quanto à responsabilidade regressiva, no entanto, os incisos do art. 155 contêm disposição especial, mais restritiva. Ela deverá ocorrer apenas quando o diretor do cartório ou o oficial de justiça “*sem justo motivo, se recusarem a cumprir no prazo os atos impostos pela lei ou pelo juiz a que estão subordinados*” (inc. I) ou quando “*praticarem ato nulo com dolo ou culpa*” (inc. II). No primeiro caso, exige-se o descumprimento culposo ou doloso do prazo do prazo assinalado pela lei ou pelo juiz. Se razoável a escusa, não há responsabilidade. No segundo, ao dolo ou culpa soma-se outro requisito: o diretor do cartório ou o oficial só serão responsabilizados se praticarem ato que venha a ser invalidado. Não basta a nulidade do ato, porque *pas de nullité sans grief*; a responsabilidade só se configurará se se causar efetivo *dano*, e este dano é a invalidação do ato viciado.

Seção II Do perito

Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1.º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado.

§ 2.º Para formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados.

§ 3.º Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados.

§ 4.º Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade.

§ 5.º Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia.

Direito anterior – art. 145 do CPC/1973.

Direito comparado – § 404 da ZPO alemã, art. 335 da ley de enjuiciamiento civil espanhola e art. 568 do CPC português.

1. Perito. A garantia das partes do processo ao contraditório exige, como se sabe, que o juiz decida a demandasem valer-se do seu conhecimento privado dos fatos relevantes para o julgamento.²⁷ Esta vedação manifesta-se em dois momentos. Em primeiro lugar, quando o juiz teve algum *contato direto prévio* com os fatos – desde que estes fatos não possam ser entendidos como notórios. Por exemplo, quando ele presenciou casualmente o acidente de trânsito sobre o qual depois os envolvidos passaram a litigar. Em segundo, o juiz não deve julgar a demanda com fundamento em conhecimentos técnicos especializados que eventualmente possa também ter. É por isso que se diz que “*onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções judiciais, ali começa a das perícias*”.²⁸ Se o litígio versar sobre um acidente em uma barragem, por exemplo, e o juiz for também um engenheiro especialista na matéria, não lhe se permite dispensar a realização de prova pericial.

O juiz será assim “*assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico*” (*caput*). O perito é um auxiliar *eventual* da justiça, porque sua atuação é necessária apenas quando o justificar a complexidade técnica da prova. Ele não é, ademais, um *juiz de fato*.

Não *decide* as questões de fato debatidas no processo, ainda que tecnicamente complexas; apenas dá ao juiz *subsídios* técnicos para que ele, o juiz, possa decidi-las. Por isso se diz que “o juiz não está adstrito a nenhum laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a devida fundamentação”.²⁹ Suas opiniões sobre o direito aplicável ao fato são também irrelevantes.³⁰ O perito não é tampouco uma testemunha qualificada, que fala em juízo em defesa de uma das partes, como ocorre em países como os Estados Unidos (*expert witness*). Ele é antes um *auxiliar da justiça*, ainda que eventual, que deve exercer com independência e imparcialidade um múnus público. Seu compromisso não é com os interesses das partes, mas com a prestação da justiça.

2. Nomeação do perito. O perito ou os peritos, no caso de perícia complexa,³¹ deverão ser nomeados “entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado” (§ 1.º).³² Peritos não cadastrados só poderão ser nomeados nas comarcas em que não existirem peritos habilitados para a realização da perícia inscritos no cadastro disponibilizado pelo tribunal (§ 5.º).³³ A escolha do perito, em princípio, é do próprio juiz (art. 465). A ideia é a de que, se o juiz é o destinatário da prova, o perito deve ser alguém de sua confiança, não alguém de confiança das partes.³⁴ Esta é a regra geral, tradicional no direito brasileiro. A lei permite, no entanto, e esta é uma das novidades do CPC/2015, que as partes indiquem em conjunto um perito (art. 471).³⁵ Neste caso, a “perícia consensual substitui, para todos os efeitos, a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz” (art. 471, § 3.º) e a escolha das partes vale mesmo contra a vontade do juiz. Não se trata, com efeito, de uma sugestão conjunta que as partes dão ao juiz, mas sim de uma nomeação conjunta a que o juiz está vinculado.³⁶ O perito pode escusar-se, não aceitando a sua nomeação, sem que precise justificar sua recusa. Ele pode ser também recusado pelas partes, se estiver impedido ou suspeito, se lhe faltarem conhecimentos técnicos especializados para a realização da perícia ou se seu nome não constar da lista administrada pelo Tribunal. Sobre a arguição de impedimento e suspeição dos peritos, confirmam-se os comentários aos arts. 148 e 467.

O perito, tradicionalmente, deve ser uma pessoa (física). Inova o CPC/2015, no entanto, ao permitir expressamente a nomeação como perito de “órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”. Não, como poderia parecer em uma primeira leitura, apenas de pessoas ligadas a estes órgãos, mas dos próprios órgãos. Não é por outro motivo que, segundo o parágrafo quarto, “para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos arts. 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade”. O impedimento e a suspeição, neste caso, são do próprio órgão, não dos profissionais a ele vinculados que realizarão o trabalho em seu nome. Por isso, aliás, este parágrafo quarto diz menos do que deveria. Não são apenas os profissionais que participação da atividade que poderão dar causa à parcialidade do órgão. Se um pesquisador, por exemplo, é contratado por uma empresa para lhe prestar assessoria, que paga pelo serviço ao instituto a que o pesquisador é filiado, este instituto não pode ser nomeado perito para atuar em processo no qual a empresa é parte. Ainda que o pesquisador não seja um dos profissionais a conduzir a perícia.

A impressão de parcialidade que justifica o reconhecimento do impedimento ou da suspeição é aquela entre o perito e a parte ou seu advogado, não entre ele e o juiz. Não há parcialidade aqui porque não há vinculação a um sujeito *parcial* do processo. Não, obviamente, que esta proximidade não seja indesejável. Não é adequado que um juiz, por exemplo, nomeie seu filho como perito em um processo aos seus cuidados. Mas este é um problema de natureza administrativa. Normas outras é que devem proibir o nepotismo nas relações entre juízes e seus auxiliares, não aquelas relativas a impedimento e suspeição. Controverso embora na doutrina,³⁷ este parece ser o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.³⁸ De modo a assegurar a lisura e a impessoalidade do processo de seleção de especialistas para a formação das listas de cadastro, ademais, a lei determina que “os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, a conselhos de classe, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Ordem dos Advogados do Brasil, para a indicação de profissionais ou de órgãos técnicos

interessados” (§ 2.º). Estatui ainda que “os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para manutenção do cadastro, considerando a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados” (§ 3.º).

Todas as regras explicadas nos comentários a este artigo valem também para a perícia simplificada de que trata o parágrafo segundo do art. 464. E isso porque “o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento” (art. 464, § 4.º) não deixa de ser um perito, apenas porque simplificado o seu trabalho. O processo civil brasileiro não adotou, com este dispositivo, a figura do *expert witness* da tradição do *common law*.

Art. 157. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda sua diligência, podendo escusar-se do encargo alegando motivo legítimo.

§ 1.º A escusa será apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la.

§ 2.º Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento.

Direito anterior – art. 146 do CPC/1973.

Direito comparado – § 408 da ZPO alemã, art. 105 da ley de enjuiciamiento civil espanhola e art. 570 do CPC português.

1. Nomeação e escusa do perito. O perito não será *nunca* obrigado a aceitar a sua nomeação, que ele sempre poderá recusar sem a necessidade de explicitar os motivos que o levaram a escusar-se.³⁹ Mas a escusa submete-se a um prazo preclusivo de quinze dias, contados da decisão que *confirma* a nomeação (parágrafo primeiro). A nomeação, com efeito, não serve por si só de início deste prazo. Nada mais razoável, porque até sua confirmação o perito não sabe ainda quais serão os honorários e nem tampouco se sua nomeação será impugnada por uma das partes. Se entender baixos os honorários ao final fixados, o perito pode legitimamente recusar-se a assumir o encargo. Encerrado o prazo, no entanto, a preclusão só deverá ser relevada se o juiz considerar razoável a explicação oferecida pelo perito para a escusa tardia. Será o caso, por exemplo, se o perito passar em um concurso público que não lhe permita desempenhar o encargo. Ou se estiver impedido ou suspeito.

Uma vez aceito o encargo, o perito tem o dever de desempenhá-lo com “*toda sua diligência*” (*caput*). Este dever desdobra-se em vários outros: de agir com imparcialidade,⁴⁰ de falar a verdade,⁴¹ de observar as normas técnicas aplicáveis, de observar o prazo definido para a realização da perícia,⁴² de dar aos assistentes técnicos das partes oportunidade de participar de diligências,⁴³ de levar em consideração suas ponderações, de responder aos quesitos formulados pelas partes,⁴⁴ de redigir um laudo bem fundamentado ao final do trabalho⁴⁵ e de prestar esclarecimentos sobre o laudo por escrito⁴⁶ ou em audiência⁴⁷ se a isso determinado pelo juiz. Terá o dever, em síntese, de cumprir “*escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso*” (art. 466).

Todas as regras explicadas nos comentários a este artigo valem também, *mutatis mutandis*, para a perícia simplificada de que trata o parágrafo segundo do art. 464, porque o “o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento” (art. 464, § 4.º) é também um perito. Diz-se *mutatis mutandis* porque esta prova “consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico” (art. 464, § 3.º). Não se realizarão, por isso, diligências, nem será necessária a redação de um laudo pericial.

2. Distribuição equitativa das nomeações para perito. A mesma razão que levou o legislador a tornar obrigatória a existência de um cadastro de peritos administrado pelos tribunais – tutela da impessoalidade e da transparência – explica por que “será organizada lista de peritos na vara ou na

secretaria, com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo, observadas a capacidade técnica e a área de conhecimento” (§ 2.º). Esta norma dá transparência às nomeações realizadas por cada um dos juízos, e contribui para evitar a escolha de pessoas sem conhecimento técnico especializado ou ainda a nomeação sucessiva das mesmas pessoas em detrimento da distribuição equitativa a que alude o dispositivo.

Art. 158. O perito que, por dolo ou culpa, prestar informações inverídicas responderá pelos prejuízos que causar à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis.

Direito anterior – art. 147 do CPC/1973.

1. Responsabilidade civil do perito. O perito é *civilmente* responsável (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que causar às partes do processo. Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o perito com fundamento no disposto no art. 927 do CC e no art. 158 do CPC; ou b) regressiva, deduzida contra ele pelo Estado com fundamento no disposto no art. 37, § 6.º, da CF,⁴⁸ autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada.

Para fins do disposto no art. 37, § 6.º, da Constituição, com efeito, o perito deve ser considerado um agente público. E isso porque ele é um auxiliar da justiça, ainda que eventual. Por isso, o Estado é objetivamente responsável por indenizar o prejudicado pelos prejuízos que o perito lhe tiver causado. Mas o perito é também *diretamente* responsável por indenizar o prejudicado, responsabilidade esta, no entanto, que é subjetiva. Em ambos os casos, a pretensão do prejudicado deve ser deduzida em demanda própria.

O *caput* do art. 158 não deve ser interpretado no sentido de restringir a responsabilidade do perito à hipótese em que ele presta informações inverídicas. A diferença é que ao dever de indenizar comum a todos os casos de responsabilidade civil, se soma, nesta hipótese determinada, uma outra sanção: o perito “ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis”. A imposição desta sanção, no entanto, diferentemente do que ocorre no reconhecimento da responsabilidade civil, deve ocorrer *no próprio processo* em que o juiz presta as informações inverídicas, no julgamento de incidente processual específico em que se assegure ao perito o direito de defender-se adequadamente, inclusive mediante a produção de prova.

Seção III Do depositário e do administrador

Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

Direito anterior – art. 148 do CPC/1973.

1. Depositário e administrador. Depositário e administrador são ambos auxiliares eventuais da justiça cujas funções, embora semelhantes, não se confundem. Seus serviços são necessários quando se determinar o desapossamento de bens de alguém no curso do processo, o que comumente ocorre mediante a realização de penhora, arresto, sequestro e arrecadação.⁴⁹ A eles cabe a guarda e a conservação do bem constricto (*caput*).

Ao depositário, no entanto, a quem se dá a posse do bem, incumbe *apenas* a sua guarda e conservação. Será o caso quando não se pretender dar ao bem destinação econômica enquanto perdurar a constrição. Por exemplo, quando se tratar de constrição de bem imóvel ou de obras de arte. O administrador, diferentemente, deve não apenas conservar o bem, mas também *administrá-lo*, isto é, geri-lo economicamente.⁵⁰ A administração só será possível, assim, se o bem

constrito admitir exploração econômica. Por exemplo, quando se tratar de penhora de “*plantações ou edifícios em construção*”.⁵¹ A nomeação de administrador judicial é também frequente em litígios societários, em que a administração da empresa passa *cautelamente* ao administrador. Nestes casos, ele deverá prestar contas da sua administração.

Prefere-se a nomeação de depositário ou administrador ao envio do bem aos sempre abarrotados depósitos públicos, onde as chances de deterioração são consideravelmente maiores. Mas esta nomeação só será necessária quando ocorrer efetivo *desapossamento*. Se o próprio proprietário do bem constrito for escolhido seu depositário, não haverá obviamente necessidade de nomeação de um terceiro como depositário ou administrador.⁵² Lembre-se apenas que, em certos casos, permite-se também que o adversário da parte desapossada torne-se o depositário do bem constrito.⁵³ Depositário e administrador, por fim, não deverão nunca ser constrangidos a assumir o encargo. Permite-lhes a lei recusar, mesmo que imotivadamente, sua nomeação (conforme o enunciado 319 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Uma vez aceito o encargo, no entanto, a desistência deve ser justificada.⁵⁴

Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução.

Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador.

Direito anterior – art. 149 do CPC/1973.

1. Remuneração do depositário e do administrador. Enquanto auxiliares *eventuais* da justiça, depositário e administrador devem ser remunerados pelo exercício deste encargo. Esta remuneração, de todo modo, deve ser adequada à complexidade do trabalho. É neste sentido que se diz que o juiz fixará a remuneração “*levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução*” (caput). Mas a remuneração do administrador, porque maiores suas responsabilidades⁵⁵, deve ser proporcionalmente superior àquela do mero depositário. Reconhece-se ao depositário, ademais, e ao administrador, nos casos em que lhe for confiada a posse de um bem determinado⁵⁶, o direito de reter a coisa depositada até o seu pagamento, exatamente porque “*o particular que aceita exercer o múnus público de depositário judicial tem o direito de reter o depósito até que sejam ressarcidas as despesas com armazenagem e conservação do bem guardado e pagos os seus honorários*”.⁵⁷

2. Nomeação de preposto. O parágrafo único deste dispositivo permite ao juiz ainda “*nomear um ou mais prepostos por indicação do depositário ou do administrador*”. A regra seria inútil, se a remuneração do preposto incumbisse ao próprio depositário ou administrador. Sua razão de ser é exatamente a de eximir o depositário ou o administrador do pagamento de despesas que o exercício do seu múnus demandaria. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro dá um exemplo de situação em que a contratação do preposto é adequada. Realizada a penhora do faturamento de uma empresa,⁵⁸ o juiz deve nomear administrador, “*o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida*” (art. 866, § 2.º). No caso de que trata este precedente, autorizou-se a contratação do preposto para proceder especificamente à arrecadação.⁵⁹

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.

Direito anterior – art. 150 do CPC/1973.

1. Responsabilidade civil do depositário e do administrador. O depositário e o administrador são *civilmente* responsáveis (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que causarem às partes do processo. Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o depositário ou administrador com fundamento no disposto no art. 927 do CC e no art. 161 do CPC; ou b) regressiva, deduzida contra ele pelo Estado com fundamento no disposto no art. 37, § 6.º, da CF,⁶⁰ autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada.

Para fins do disposto no art. 37, § 6.º, da Constituição, com efeito, o depositário e o administrador devem ser considerados agentes públicos. E isso porque eles são auxiliares da justiça, ainda que apenas em caráter eventual. Por isso, o Estado é objetivamente responsável por indenizar o prejudicado pelos prejuízos que um deles lhe tiver causado. Mas o depositário e o administrador são também *diretamente* responsáveis por indenizar o prejudicado, responsabilidade esta, no entanto, que é subjetiva. Em ambos os casos, a pretensão do prejudicado deve ser deduzida em demanda própria. Reconhecida a responsabilidade do depositário ou do administrador, devem eles perder a remuneração que lhes foi paga. Sem prejuízo da reparação dos prejuízos causados, porque esta perda tem natureza sancionatória, não reparatória. A lei faz apenas a ressalva, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do proprietário do bem, de que, mesmo neste caso, o depositário ou o administrador “*tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo*” (*caput*). O advérbio *legitimamente* indica que não são compensáveis todas as despesas, mas apenas aquelas entendidas pelo juiz como razoáveis e efetivamente destinadas à conservação e guarda da coisa. Esta quantia deve ser *compensada* daquilo que o depositário ou o administrador tiver de pagar.

2. Depositário infiel. Depositário infiel é aquele que se recusa, deliberadamente, a cumprir a ordem judicial de restituição da coisa confiada à sua custódia. Não basta a culpa. Não basta a sua incúria na guarda e conservação da coisa.⁶¹ Se a coisa se perde, por exemplo, em razão de sua deterioração causada por armazenamento inadequado, o depositário deverá indenizar o prejudicado, mas não terá sido infiel. A infidelidade do depositário consiste, com efeito, em ato atentatório à dignidade da justiça, que deverá ser reprimido de acordo com as regras explicadas nos comentários ao art. 77.

O Supremo Tribunal Federal decidiu, de todo modo, pela inconstitucionalidade da prisão do depositário infiel.⁶² Sem razão, aliás, embora este assunto mereça tratamento mais detalhado, que se deixa para outra oportunidade. O art. 7.º, § 7.º, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) não proíbe a prisão do depositário infiel, mas sim a *prisão por dívida*, salvo quando se tratar de obrigação alimentar.⁶³ Ocorre que a prisão do depositário infiel não tem por fundamento imediato a existência de uma dívida, mas sim o flagrante desrespeito pela autoridade judiciária consubstanciado na sua recusa deliberada em cumprir a ordem judicial de restituição (*contempt of court*). São coisas diversas.

Seção IV Do intérprete e do tradutor

Art. 162. O juiz nomeará intérprete ou tradutor quando necessário para:

I – traduzir documento redigido em língua estrangeira;

II – verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional;

III – realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado.

Direito anterior – art. 151 do CPC/1973.

Direito comparado – § 142 da ZPO alemã, arts. 143 e 144 da ley de enjuiciamiento civil

espanhola e arts. 139 e 140 do CPC português.

1. Obrigatoriedade da língua portuguesa. Segundo dispõe o art. 192 do CPC, “*em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa*”. É irrelevante, por isso, que partes, advogados e juiz dominem perfeitamente um idioma estrangeiro e que prefiram usá-lo, ou ainda que o idioma estrangeiro, por sua proximidade, possa ser compreendido por um falante do português sem grandes dificuldades (por exemplo, o espanhol⁶⁴). O uso do vernáculo é obrigatório para a realização de todos os atos do processo, seja ele realizado por escrito ou oralmente, e esta é uma exigência que nem o consenso das partes nem a vontade do juiz podem derrogar.

Por *atos do processo* se quer dizer os atos praticados *no* processo, como a redação de petições, a formulação de perguntas a testemunhas em audiência e a sustentação oral nos tribunais. Estes devem ser sempre em português. Situação diversa é aquela dos *documentos* redigidos em língua estrangeira e juntados aos autos do processo. Aqui, o rigor deve ser menor, porque o juiz deve levar em consideração, ao avaliar a obrigatoriedade de que cada documento venha acompanhado de tradução “*para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado*” (art. 192, parágrafo único), os elevados custos de tradução, a complexidade de sua realização e o tempo que a tradução inevitavelmente consome. A falta de tradução será sempre um vício corrigível, e seu reconhecimento dependerá da comprovação de efetivo prejuízo.⁶⁵ Para mais detalhes sobre esta questão, confirmam-se os comentários ao art. 192.

A tradução de documentos redigidos em língua estrangeira é assim um ônus da parte interessada, que deve providenciá-la *fora* do processo e, preferencialmente, antes mesmo de seu início. Pode existir, no entanto, controvérsia entre as partes ou dúvida do juiz sobre o resultado da tradução de um documento juntado aos autos. Neste caso, permite-se ao juiz nomear um *tradutor*, auxiliar eventual da justiça, para esclarecer o ponto duvidoso da tradução ou, se o juiz entender necessário, até mesmo para retraduzir o documento (inc. I). O tradutor, em síntese, ocupa-se da tradução de *documentos*.

Em relação aos atos do processo propriamente ditos, como se disse, o uso do vernáculo é obrigatório. *Quid iuris*, quando um dos sujeitos do processo não consegue se expressar em português? O intérprete é um auxiliar eventual da justiça, cuja função é “*verter para o português as declarações das partes e das testemunhas que não conhecerem o idioma nacional*” (inc. II). Embora a Língua Brasileira de Sinais não deva ser entendida, obviamente, como uma língua estrangeira, a lógica é a mesma quando mudo o sujeito do processo. Neste caso, o intérprete deve “*realizar a interpretação simultânea dos depoimentos das partes e testemunhas com deficiência auditiva que se comuniquem por meio da Língua Brasileira de Sinais, ou equivalente, quando assim for solicitado*” (inc. III).

Assim com em relação ao resultado da perícia, o juiz também não está vinculado à tradução sugerida pelo intérprete ou pelo tradutor. Mas terá de *fundamentar* a divergência de entendimento.⁶⁶

Art. 163. Não pode ser intérprete ou tradutor quem:

I – não tiver a livre administração de seus bens;

II – for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo;

III – estiver inabilitado para o exercício da profissão por sentença penal condenatória, enquanto durarem seus efeitos.

Direito anterior – art. 152 do CPC/1973.

1. Recusa do intérprete ou do tradutor. Intérprete e tradutor são auxiliares eventuais da justiça, que não devem estar inabilitados para exercer o encargo por força de sentença penal condenatória (inc. III) e que estejam na livre administração de seus bens (inc. I),⁶⁷ de quem se exige proficiência em uma língua estrangeira. Estarão qualificados para desempenhar este múnus

o tradutor juramentado, o intérprete comercial e o portador de formação acadêmica específica (por exemplo, graduação em letras português-inglês), mas não apenas eles. Dispensa-se a formação, por exemplo, se o intérprete ou tradutor for natural de país onde se fala a língua estrangeira, desde que ele comprove conhecer também a língua portuguesa. As circunstâncias concretas podem levar o juiz, com efeito, a ter de ser mais flexível. Por exemplo, se incomum a língua e não existirem na comarca pessoas formalmente habilitadas a traduzi-la. Neste caso, não há alternativa senão admitir que alguém que a fale possa servir de intérprete ou tradutor, mesmo sem a habilitação formal. Duvidando da aptidão do intérprete ou do tradutor, em todo caso, permite-se sempre às partes impugnar a sua nomeação.

O intérprete e o tradutor podem ser também recusados pelas partes em razão de sua parcialidade. Em relação, assim, ao reconhecimento de seu impedimento ou suspeição, aplicam-se as regras explicadas nos comentários ao art. 148. O inc. II do art. 163 dá apenas dois exemplos de incidência da regra geral. Se arrolado como testemunha ou se funcionar como perito, o intérprete e o tradutor não terão isenção para desempenhar suas tarefas.

Art. 164. O intérprete ou tradutor, oficial ou não, é obrigado a desempenhar seu ofício, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 157 e 158.

Direito anterior – art. 153 do CPC/1973.

1. Exercício do ofício. O intérprete ou tradutor não será *nunca* obrigado a aceitar a sua nomeação, que ele sempre poderá recusar sem a necessidade de explicitar os motivos que o levaram a escusar-se.⁶⁸ Mas a escusa submete-se a um prazo preclusivo de quinze dias, contados da decisão que *confirma* a nomeação (art. 157, § 1.º). A nomeação, com efeito, não serve por si só de início deste prazo. Nada mais razoável, porque até sua confirmação o perito não sabe ainda quais serão os honorários e nem tampouco se sua nomeação será impugnada por uma das partes. Se entender baixos os honorários ao final fixados, o perito pode legitimamente recusar-se a assumir o encargo. Encerrado o prazo, no entanto, a preclusão só deverá ser relevada se o juiz considerar razoável a explicação oferecida pelo intérprete ou tradutor para a escusa tardia. Será o caso, por exemplo, se ele passar em um concurso público que não lhe permita desempenhar o encargo. Ou se estiver impedido ou suspeito. Uma vez aceito o encargo, enfim, o perito tem o dever de desempenhá-lo com “*toda sua diligência*” (art. 157, *caput*).

2. Responsabilidade civil do intérprete ou do tradutor. O intérprete e o tradutor são *civilmente* responsáveis (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que causarem às partes do processo. Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o perito com fundamento no disposto no art. 927 do CC e nos arts. 158 e 164 do CPC; ou b) regressiva, deduzida contra ele pelo Estado com fundamento no disposto no art. 37, § 6.º, da CF,⁶⁹ autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada.

Para fins do disposto no art. 37, § 6.º, da Constituição, com efeito, o intérprete e o tradutor devem ser considerados agentes públicos. E isso porque ele é um auxiliar da justiça, ainda que eventual. Por isso, o Estado é objetivamente responsável por indenizar o prejudicado pelos prejuízos que o intérprete e o tradutor lhe tiverem causado. Mas eles são também *diretamente* responsáveis por indenizar o prejudicado, responsabilidade esta, no entanto, que é subjetiva. Em ambos os casos, a pretensão do prejudicado deve ser deduzida em demanda própria. O erro na tradução pode causar graves prejuízos às partes, e mesmo levá-las a perder a demanda. Pense-se no exemplo em que o tradutor, traduzindo uma certidão redigida em língua estrangeira, troca uma frase afirmativa por uma negativa. O “permitido” pode tornar-se “não permitido” e assim sucessivamente. Daí a extrema gravidade do múnus exercido por intérpretes e tradutores, que se reflete na sua responsabilidade, e também do Estado, pelos equívocos que cometerem.

Seção V Dos conciliadores e mediadores judiciais

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciais de solução consensual de conflitos,

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição.

§ 1º A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.

§ 3º O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – § 1 da Mediationsgesetz alemã e art. 2º da Lei de Mediação portuguesa.

1. Estímulo à solução consensual dos litígios. O CPC/2015 realizou uma *opção preferencial* pelo estímulo à solução consensual dos litígios, como ilustra o seu art. 2.º, § 3.º, ao estatuir que “a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Com isto não se quer dizer, obviamente, que as partes passaram a ter o *dever* de resolver consensualmente o litígio. Ninguém é obrigado a fazer um acordo contra a sua vontade, e ninguém poderá ser punido por se recusar a fazê-lo, ainda que imotivadamente.⁷⁰ Tampouco permite a Constituição que se condicione o acesso à justiça estatal à realização de uma tentativa extrajudicial prévia de conciliação.⁷¹ A função da conciliação e da mediação não é, e nem pode ser, a de desafogar a Justiça a qualquer preço. Mas a lei reconhece, e com razão, que a sentença judicial nem sempre é a maneira mais *adequada* para a solução de litígios.⁷² O juiz tem assim o dever, em qualquer momento em que achar esta tentativa oportuna, de estimular a solução consensual dos litígios, nos casos em que a negociação direta for permitida.⁷³ E mesmo fora dos momentos *típicos* que a lei reserva à conciliação e à mediação (a audiência de que trata o art. 334 é um dos exemplos de momento típico). O juiz fará isso, pessoalmente, em audiência, ou mediante o encaminhamento do processo ao centro judiciário de solução consensual de conflitos vinculado ao respectivo tribunal.

2. Centros judiciários de solução consensual dos litígios. A experiência na vigência do CPC/1973 de realização das audiências de conciliação nos próprios juízos em que tramitavam os processos não se revelou exitosa.⁷⁴ Sem atingir os resultados esperados, esta opção acabou também por desfigurar a própria audiência preliminar no procedimento ordinário, que deveria servir também para o saneamento do processo.⁷⁵ Esta realidade acabou levando o Conselho Nacional de Justiça, ainda em 2010, a determinar a criação de centros para a prática da conciliação em mediação, que *concentrariam* a sua administração e evitariam, assim, a *dispersão* do modelo então em vigor. O novo CPC aprofunda este conceito, ao determinar que “os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição” (*caput*). Esta norma é reproduzida no art. 24 da Lei de Mediação.⁷⁶ Os tribunais, observadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, terão competência para regulamentar o funcionamento destes centros (§ 1.º),⁷⁷ regra esta que o art. 24, parágrafo único, da Lei de Mediação repete.

3. Conciliação e mediação. Alheia às críticas que às vezes se faz a esta distinção, procura a lei estreitar a conciliação da mediação, conceituando-as tendo por critério diferenciador principal o *papel* do terceiro que auxilia as partes.⁷⁸ No primeiro caso, atribui-se ao terceiro um papel mais ativo, no sentido de que lhe é permitido *sugerir* alternativas para a solução do litígio. No segundo, seu papel é o de “condutor do diálogo”.⁷⁹ Por isso, “o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio,

sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem” (§ 2.º), enquanto o mediador, “*que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos*” (§ 3.º).⁸⁰

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.

§ 1.º A confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes.

§ 2.º Em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.

§ 3.º Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição.

§ 4.º A mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – §§ 2,3 e 4 da Mediationsgesetz alemã e art. 3º da Lei de Mediação portuguesa.

1. Princípios informadores da conciliação e da mediação. A conciliação e a mediação são informadas por certos princípios, que a lei processual enuncia sem a pretensão de ser exaustiva.⁸¹ São eles os princípios “*da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada*” (*caput*), que devem ser interpretados em harmonia com as demais regras do Código de Processo Civil. E isso porque a conciliação e a mediação, embora tenham particularidades que as distinguem dos demais “*dispute resolution mechanisms*”,⁸² não são uma ilha isolada infensa aos princípios gerais aplicáveis a todos os meios de solução de litígios (justiça civil).⁸³

O princípio da autonomia da vontade é talvez o princípio *estruturante* da conciliação e da mediação, “*inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais*” (§ 4.º). Ninguém poderá ser constrangido à autocomposição, nem poderá ser punido (por exemplo, pela prática de litigância de má-fé ou de ato atentatório à dignidade da justiça) por se recusar a celebrar um acordo. Mas esta autonomia não é, obviamente, ilimitada. Por isso a lei cria momentos *típicos* ao longo do processo para a *tentativa* de autocomposição em que o comparecimento das partes (e apenas o comparecimento, não a celebração de um acordo) é obrigatório, como a audiência de que trata o art. 334. Também se permite ao juiz, em qualquer fase de seu trâmite, e se entender oportuno, determinar o encaminhamento do processo para o centro judiciário de solução de conflitos. Se não pode constranger as partes a chegar a uma solução consensual para o litígio, permite-se ao juiz ao menos *estimular* a realização de um acordo mediante a criação de momentos *atípicos* para que se realize uma tentativa.⁸⁴ Correlato ao princípio da autonomia da vontade é o princípio da decisão informada. Por força dele, as partes devem ser detalhadamente instruídas sobre as regras do procedimento a que se submeterão e as consequências da realização de um acordo. É neste contexto que se define a presença de um advogado como *obrigatória* em todas as sessões de conciliação ou mediação (art. 334, § 9.º). Sem ele, qualquer transação será nula por falta de capacidade postulatória (para mais detalhes sobre as consequências da falta de capacidade postulatória, confirmam-se os comentários ao art. 103).

O conciliador e o mediador devem ser, obrigatoriamente, um terceiro imparcial. Deles não se

exige apenas que não *queiram* em seu íntimo que uma das partes vença, mas que se *comportem* como se não o quisessem e cuja imparcialidade não *possa* objetiva e razoavelmente ser colocada em dúvida. A ele se aplicam, por isso, as regras explicadas no art. 148 relativas a impedimento e suspeição (princípio da imparcialidade). É também por este motivo, segundo dispõe o art. 5.º, parágrafo único, da Lei de Mediação, que *“a pessoa designada para atuar como mediador tem o dever de revelar às partes, antes da aceitação da função, qualquer fato ou circunstância que possa suscitar dúvida justificada em relação à sua imparcialidade para mediar o conflito, oportunidade em que poderá ser recusado por qualquer delas”*. Este terceiro imparcial deve ter também independência para conduzir seus trabalhos (princípio da independência). Esta independência manifesta-se tanto em relação às autoridades judiciárias, de quem ele não deve receber instruções sobre como conduzir concretamente a conciliação ou a mediação em um determinado caso concreto,⁸⁵ quanto em relação às partes, porque se lhe reconhece o direito, mesmo contra a vontade delas, de *“recusar, suspender ou interromper a sessão, se ausentes as condições necessárias para seu bom desenvolvimento”*⁸⁶ e ainda o de abster-se de dar o seu beneplácito a acordo ilegal ou inexequível. É neste sentido que se diz que se admite *“a aplicação de técnicas negociais, com o objetivo de proporcionar ambiente favorável à autocomposição”* (§ 3.º).

A conciliação e a mediação deverão ser conduzidas de modo informal, sem a necessidade de observância de um procedimento fixo previamente estabelecido e das formalidades que caracterizam o linguajar e o gestual das audiências presididas por magistrados (princípio da informalidade). A informalidade é estimulada ainda pelo princípio segundo o qual a sessão de conciliação ou de mediação deve desenvolver-se de modo essencialmente oral (princípio da oralidade). Verbalmente, as pessoas expressam-se de modo mais livre e dinâmico, sem o temor de deixar registradas suas impressões. A conversa torna mais fácil ao mediador ou conciliador compreender as angústias, preocupações e aspirações das partes, e auxiliá-las a se entenderem. Faça-se apenas a ressalva de que o termo final da conciliação ou mediação deverá *sempre* ser escrito, embora ele não deva ser confundido com uma ata de audiências. Do termo não deve constar o resumo ou transcrição daquilo que tenha sido dito pelas partes durante a sessão, como exigem os princípios da informalidade e da confidencialidade.

Ao contrário do processo, em regra público, a conciliação e a mediação serão em regra confidenciais (princípio da confidencialidade). Sem ela, as partes não se sentiriam à vontade para a troca mais franca possível de ideias e de posições indispensável ao sucesso da autocomposição, especialmente da mediação, o que feriria de morte a sua utilidade prática. Este princípio manifesta-se de dois modos diversos. Em relação às partes, *“a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes”* (§ 1.º).⁸⁷ As declarações dadas pelas partes durante o procedimento de conciliação e mediação não poderão nunca ser tratadas como confissão ou levadas em consideração no momento da valoração pelo juiz da prova produzida no processo.⁸⁸ A sentença que o fizer será nula, pelo defeito em sua fundamentação. Em relação aos conciliadores, mediadores e seus assistentes, vige a regra segundo a qual *“em razão do dever de sigilo, inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação”* (§ 2.º), com a ressalva apenas de que *“a regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput prestarem informações à administração tributária após o termo final da mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do art. 198 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional”* (art. 30, § 4.º, da Lei de Mediação).

Art. 167. Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional.

§ 1.º Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de

tribunal regional federal.

§ 2.º Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional.

§ 3.º Do credenciamento das câmaras e do cadastro de conciliadores e mediadores constarão todos os dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de processos de que participou, o sucesso ou insucesso da atividade, a matéria sobre a qual versou a controvérsia, bem como outros dados que o tribunal julgar relevantes.

§ 4.º Os dados colhidos na forma do § 3º serão classificados sistematicamente pelo tribunal, que os publicará, ao menos anualmente, para conhecimento da população e para fins estatísticos e de avaliação da conciliação, da mediação, das câmaras privadas de conciliação e de mediação, dos conciliadores e dos mediadores.

§ 5.º Os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções.

§ 6.º O tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste Capítulo.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – § 5.º da Mediationsgesetz alemã e art. 24 da Lei de Mediação portuguesa.

1. Informalidade e autonomia da vontade e o risco de burocratização da conciliação e da mediação judiciais. As normas sobre conciliação e mediação constantes do CPC e da Lei de Mediação devem ser sempre interpretadas à luz dos princípios da informalidade e da autonomia da vontade, de modo a prevenir a inevitável *burocratização* que decorreria do excesso de regulamentação deste mecanismo consensual de solução de controvérsias cujo sucesso depende exatamente de sua capacidade de mostrar-se flexível e dinâmico.

Trata-se, ademais, de algo novo. Alguns anos serão ainda necessários para que a conciliação e a mediação judiciais venham a ser integralmente incorporadas à estrutura judiciária brasileira. É necessário ainda saber, com efeito, como os órgãos competentes – Conselho Nacional de Justiça e tribunais – regulamentarão exatamente a matéria e, talvez ainda mais importante, como este emaranhado de leis e regulamentos será concretamente aplicado pelos operadores do direito. Por este motivo, as explicações que se darão nos próximos itens não deixam de ser apenas um esboço, que deve ser revisado à medida que amadurecer a prática da conciliação e da mediação no Brasil.

2. Habilitação e lista de conciliadores e mediadores. Ainda que de modo pouco claro, o CPC e a Lei de Mediação optaram por estabelecer uma distinção entre a *habilitação* para o exercício da função de conciliador ou mediador judiciais, habilitação esta que é comprovada pela inscrição nos cadastros nacional e dos tribunais, e a inscrição nas *listas* daqueles aptos (ou *credenciados*) em cada comarca ou seção judiciária a serem sorteados quando as partes não escolherem consensualmente o conciliador ou mediador.

A primeira etapa é a *habilitação* como conciliador ou mediador judiciais. Quis a lei, ao optar por valorizar a conciliação e a mediação, *profissionalizar* o seu desempenho. Pretendeu-se superar, assim, a figura do conciliador amador que tanto mal causou, na vigência do CPC/1973, à imagem da autocomposição como método legítimo e sério de solução de litígios. Daí a exigência de formação específica, regulada pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, para a habilitação do conciliador e do mediador judiciais.⁸⁹⁻⁹⁰ Esta formação específica permite ao interessado ser registrado nos cadastros nacional e dos tribunais locais,⁹¹ com a indicação de sua área de atuação profissional (família, conflitos societários etc.) e de outras informações relevantes para o desempenho do encargo. Apenas os conciliadores e mediadores

cadastrados poderão ser indicados, por distribuição alternada e aleatória ou pelas partes, consensualmente, para o exercício do encargo. Mas também a uma câmara privada de conciliação e mediação se permite o cadastro, de modo a atestar sua qualificação para a administração de conciliação e mediação judiciais. Faça-se apenas a ressalva de que, para a sua habilitação como conciliador ou mediador, não se exige do interessado a inscrição nos quadros da OAB e nem tampouco o bacharelado em direito. Andou bem o legislador ao optar por franquear o desempenho da conciliação e da mediação a pessoas de outros *backgrounds* acadêmicos e profissionais.⁹²

A habilitação, que o cadastro atesta, não se confunde com as *listas* de conciliadores e mediadores à disposição para a distribuição alternada e aleatória quando não existir consenso entre as partes. O habilitado pode muito bem não requerer seu credenciamento nestas listas, e optar por exercer o múnus apenas quando nomeado pelas partes. Mas apenas os conciliadores e mediadores inscritos nas listas é que poderão ser sorteados para conduzir a conciliação ou a mediação quando não houver consenso entre as partes quanto à nomeação. O acesso a estas listas pode ser dar, em tese, por livre nomeação (como ocorre, por exemplo, com os peritos), pela aprovação em exame (como ocorre, por exemplo, com os tradutores juramentados) ou ainda mediante concurso.⁹³ Nos dois primeiros casos, o conciliador ou mediador são auxiliares da justiça que não integram de modo permanente a estrutura funcional da Justiça; no terceiro, diferentemente, ele é um servidor público. Cada tribunal, observadas as diretrizes fixadas pelo CNJ, decidirá como agir.

Quis a lei claramente evitar, no entanto, a nomeação de conciliadores e mediadores *ad hoc* pelos juízes – em sentido justamente contrário ao da praxe durante a vigência do CPC/1973 na nomeação aos peritos. Ou as partes escolhem em conjunto, e escolhem qualquer um dentre aqueles habilitados (e basta a habilitação, comprovante pelo cadastro), ou o conciliador ou mediador deverão ser *sorteados* entre aqueles integrantes da lista da respectiva “*comarca, seção ou subseção judiciária*”⁹⁴ (§ 2.º). Escolhida uma câmara privada pelas partes, o seu cadastro já basta para atestar sua habilitação para administrar a conciliação e a mediação. Quem ela seleciona para conduzir a conciliação ou a mediação são uma questão *interna corporis*, que não se submete às exigências de habilitação e inscrição previstas no art. 167. O que não inibe, obviamente, a atividade fiscalizadora dos tribunais sobre a qualidade dos serviços prestados pelas câmaras privadas.

3. Impedimento do conciliador ou mediador advogado. Segundo dispõe o parágrafo quinto, um dos dispositivos mais polêmicos do novo CPC no que se refere à conciliação e à mediação, “os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções”. Como norma que restringe direitos, este dispositivo deve ser interpretado de modo restritivo. O *mero cadastro* não é causa de impedimento, nem tampouco o desempenho do ofício pelo conciliador ou mediador judiciais escolhidos pelas partes do processo. Estarão impedidos apenas aqueles que integram a lista de conciliadores ou mediadores judiciais (não extrajudiciais) credenciados nos limites da competência territorial do centro a que estiverem vinculados. A ideia é a de que, se o conciliador ou o mediador *opta* por participar da distribuição alternada e aleatória, não pode continuar a exercer a advocacia nos limites da competência do centro a que vinculado. Se escolhe disputar o *mercado* da conciliação e da mediação, sem o conforto que o constar da lista lhe garantiria, não está impedido. A limitação, de todo modo, desconhecida no direito comparado, serve apenas à criação de ineficiente reserva de mercado, que nenhuma utilidade teria senão a de estimular a burocratização da conciliação e da mediação que tanto se quer evitar. *De lege ferenda*, deve ser abolida.

Art. 168. As partes podem escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação.

§ 1.º O conciliador ou mediador escolhido pelas partes poderá ou não estar cadastrado no tribunal.

§ 2.º Inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre

aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação.

§ 3.º Sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – § 2.º da Mediationsgesetz alemã e art. 17 da Lei de Mediação portuguesa.

1. Escolha do conciliador e do mediador. O princípio da autonomia da vontade⁹⁵ garante às partes o direito de escolher, de comum acordo, o conciliador, o mediador ou a câmara privada que deverão conduzir a conciliação ou a mediação *judiciais* – aquelas, assim, cuja realização se der no curso do processo (em contraposição, assim, à mediação extrajudicial de que trata o art. 9.º da Lei de Mediação). O conciliador ou mediador judicial, no entanto, deverá ser escolhido entre aqueles *habilitados*,⁹⁶ mas não necessariamente entre aqueles que integram a *lista*, na respectiva “*comarca, seção ou subseção judiciária*”,⁹⁷ de conciliadores e mediadores aptos a serem escolhidos por sorteio. E isso porque o disposto no art. 12 da Lei de Mediação,⁹⁸ lei especial, prevalece sobre o disposto no parágrafo primeiro do art. 168 do CPC. De todo modo, o art. 25 da Lei de Mediação⁹⁹ deve ser interpretado à luz do princípio da autonomia da vontade. Ele só será aplicável quando não houver acordo entre as partes quanto à nomeação. Sem a escolha consensual das partes, consequentemente, “*haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação*” (§ 2.º). A distribuição por sorteio deverá, segundo o disposto no parágrafo segundo do art. 167, ser “*alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional*”.

Os regulamentos dos tribunais e das câmaras privadas, por fim, dirão como se aplicará a regra segundo a qual “*sempre que recomendável, haverá a designação de mais de um mediador ou conciliador*” (§ 3.º), sempre no espírito de evitar a burocratização da conciliação e da mediação e seu engessamento em razão de excesso de regulação (comediação).¹⁰⁰

Art. 169. Ressalvada a hipótese do art. 167, § 6º, o conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

§ 1.º A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal.

§ 2.º Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Remuneração do conciliador e do mediador. Salvo quando servidores, investidos após aprovação em concurso público de provas e títulos (art. 167, § 6.º), conciliadores e mediadores serão auxiliares eventuais da Justiça que deverão receber emolumentos ou honorários. Esta remuneração será “*prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça*” (*caput*) e não deverá nunca estar condicionada, ainda que apenas em parte, ao êxito da conciliação ou da mediação. E isso porque o terceiro que a conduz não deve ter nenhum interesse pessoal em seu resultado. Admite-se também a realização *pro bono* da conciliação ou da mediação, conforme autoriza o parágrafo primeiro.¹⁰¹ Mas ninguém poderá ser constrangido a aceitar gratuitamente o encargo, exceto na hipótese de que trata o parágrafo segundo: embora não se possa exigir das câmaras privadas o pagamento de mensalidades ou qualquer outra remuneração pelo cadastro e pelo credenciamento, elas deverão, em contrapartida, realizar gratuitamente um percentual das audiências que que lhe forem distribuídas, “*com o fim de atender aos processos em que deferida gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento*”.¹⁰²

Art. 170. No caso de impedimento, o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de

preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição.

Parágrafo único. Se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Redistribuição dos autos em razão de impedimento ou suspeição do conciliador ou do mediador. Reconhecendo estar impedido ou suspeito para atuar no feito, “o conciliador ou mediador o comunicará imediatamente, de preferência por meio eletrônico, e devolverá os autos ao juiz do processo ou ao coordenador do centro judiciário de solução de conflitos, devendo este realizar nova distribuição” (caput). Rejeitada a alegação da parte pelo conciliador ou mediador, a questão da parcialidade deve ser decidida, preferencialmente, no âmbito administrativo do centro. Novamente rejeitada, no entanto, não se pode subtrair ao prejudicado o direito de levar a questão ao juiz da causa, porque a decisão sobre impedimento e suspeição dos auxiliares da justiça tem, em última análise, natureza jurisdicional. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 148. Isso tudo com a ressalva de que “se a causa de impedimento for apurada quando já iniciado o procedimento, a atividade será interrompida, lavrando-se ata com relatório do ocorrido e solicitação de distribuição para novo conciliador ou mediador” (parágrafo único).

Art. 171. No caso de impossibilidade temporária do exercício da função, o conciliador ou mediador informará o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Impossibilidade temporária para o exercício da função. Dos integrantes das listas de conciliadores e mediadores credenciados para serem escolhidos por sorteio – esta regra não se aplica àqueles que constam apenas dos cadastros de profissionais habilitados – se exige, no caso de sua impossibilidade temporária justificada para o exercício da função, que informe “o fato ao centro, preferencialmente por meio eletrônico, para que, durante o período em que perdurar a impossibilidade, não haja novas distribuições” (caput).

Art. 172. O conciliador e o mediador ficam impedidos, pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – § 3 da Mediationsgesetz alemã.

1. Quarentena. O conciliador e o mediador, como se viu nos comentários ao art. 167, não devem ter, e nem aparentar ter, nenhum interesse pessoal no resultado da conciliação e da mediação (tutela-se assim não apenas a sua imparcialidade, mas a sua *aparência* de imparcialidade). Com este objetivo, o art. 172 determina que “o conciliador e o mediador ficam impedidos [rectius, proibidos], pelo prazo de 1 (um) ano, contado do término da última audiência em que atuaram, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes” (caput). Esta norma é reproduzida pelo art. 6.º da Lei de Mediação. A violação desta regra não torna inválida a conciliação ou a mediação, mas sujeita o infrator às sanções administrativas aplicáveis¹⁰³ e ainda à responsabilidade civil pelos prejuízos que sua conduta puder vir a causar.

Art. 173. Será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que:

I – agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do art. 166, §§ 1º e 2º;

II – atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito.

§ 1.º Os casos previstos neste artigo serão apurados em processo administrativo.

§ 2.º O juiz do processo ou o juiz coordenador do centro de conciliação e mediação, se houver, verificando atuação inadequada do mediador ou conciliador, poderá afastá-lo de suas atividades por até 180 (cento e oitenta) dias, por decisão fundamentada, informando o fato imediatamente ao tribunal para instauração do respectivo processo administrativo.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Responsabilidade administrativa do conciliador, do mediador e da câmara privada de conciliação e mediação. A exclusão do cadastro de conciliadores, mediadores e câmaras privadas é uma punição de natureza *administrativa* ao descumprimento das normas que regem a atividade. Em regra, a exclusão tem por pressuposto a demonstração de que o infrator agiu com dolo ou culpa. Por exemplo, quando o conciliador induz uma das partes a celebrar um acordo que lhe é desvantajoso de modo a favorecer a outra. Ou ainda quando o mediador sugere abertamente às partes os termos de um acordo, extrapolando os limites permitidos para sua atuação. Ou também quando ele “*atuar em procedimento de mediação ou conciliação, apesar de impedido ou suspeito*” (inc. I). Excepcionalmente, esta responsabilidade administrativa é objetiva. Será o caso quando ocorrer a violação dos deveres de confidencialidade e sigilo (inc. I). A exclusão, de todo modo, não é a única punição concebível ao infrator, conciliadores, mediadores ou câmaras privadas. Os respectivos regulamentos poderão prever a existência de outras espécies de sanção, como a advertência ou a suspensão temporária. Estas regras valem também para a exclusão das câmaras privadas. Não basta, no entanto, que um único conciliador ou mediador vinculado à câmara viole um de seus deveres. A exclusão da câmara exige a demonstração de que existem falhas consideráveis no processo de seleção de seus colaboradores, na fiscalização de suas atividades e na repressão das faltas por eles cometidas.

A ocorrência de infração deve ser apurada em processo administrativo, em que se assegure ao acusado o exercício do contraditório e da ampla defesa (parágrafo primeiro). Este procedimento pode ser instaurado mediante provocação da parte ou de qualquer outro sujeito que tenha participado do procedimento ou ainda *ex officio*, pelo juiz competente para julgar o processo a que vinculada a conciliação ou a mediação ou pelo órgão competente do centro judiciário em cujo âmbito a conciliação ou a mediação se realizarem. A lei autoriza expressamente, ademais, a suspensão cautelar do conciliador, do mediador ou da câmara privada, pelo prazo de até cento e oitenta dias, mediante decisão fundamentada (parágrafo segundo).

2. Responsabilidade civil do conciliador, do mediador e da câmara privada de conciliação e mediação. O conciliador e o mediador são *civilmente* responsáveis (esta responsabilidade não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que causar às partes do processo. Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado contra o conciliador ou mediador com fundamento no disposto no art. 927 do CC; ou b) regressiva, deduzida contra ele pelo Estado com fundamento no disposto no art. 37, § 6.º, da CF,¹⁰⁴ autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada.

Para fins do disposto no art. 37, § 6.º, da Constituição, com efeito, o conciliador e o mediador judiciais, porque auxiliares da justiça, devem ser considerados agentes públicos. Por isso, o Estado é objetivamente responsável por indenizar o prejudicado pelos prejuízos que eles lhe tiverem causado. Mas eles são também *diretamente* responsáveis por indenizar o prejudicado, responsabilidade esta, no entanto, que é subjetiva. Em ambos os casos, a pretensão do prejudicado deve ser deduzida em demanda própria.

Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como:

I – dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública;

II – avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública;

III – promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Interesse público e solução extrajudicial de litígios que envolvam a Administração pública. O novo CPC, em boa hora, é explícito em afastar-se da concepção, hoje cada vez menos defendida, segundo a qual a tutela do interesse público impediria a administração de solucionar de modo consensual os litígios em que se envolvesse. Com efeito, “*não há, para o Estado, nenhuma exigência de resolver seus conflitos unicamente através da intervenção jurisdicional*”.¹⁰⁵⁻¹⁰⁶ De acordo com este novo paradigma, serão passíveis de solução consensual “*todos os interesses públicos com expressão patrimonial*”.¹⁰⁷ Por este motivo, a lei *determina* (não apenas permite) que “*a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo*”. Esta matéria é regulada mais detalhadamente nos art. 32 e ss. da Lei de Mediação.

As câmaras servirão, com efeito, para a solução de litígios *intra-administração*, entre seus órgãos internos, e também litígios *entre* a administração e particulares. São situações diversas, que merecem tratamento diverso. As regras, no primeiro caso,¹⁰⁸ serão naturalmente mais flexíveis do que no segundo. É por isso que o art. 35 da Lei de Mediação fala em “transação por adesão”, no sentido de que a celebração da transação entre a administração e o particular pressupõe a existência de uma regulamentação administrativa prévia de seus termos e condições que respeite os princípios da igualdade e da impessoalidade.¹⁰⁹

A determinação para a criação destas câmaras de conciliação e mediação não deve ser entendida, no entanto, no sentido de excluir a possibilidade de celebração de transações entre a administração e particulares por outros órgãos, desde que autorizada por lei, mediante “termos de ajustamento de conduta” e de “acordos de leniência”. Estas previsões, espalhadas pela legislação extravagante, permanecem em vigor. É o que faz, por exemplo, o art. 86 da Lei do Cade.

Art. 175. As disposições desta Seção não excluem outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica.

Parágrafo único. Os dispositivos desta Seção aplicam-se, no que couber, às câmaras privadas de conciliação e mediação.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Conciliação e mediação judiciais e extrajudiciais. As regras descritas nos artigos anteriores (seção V – arts. 165-175) aplicam-se apenas, como indica o seu próprio título (“Dos Conciliadores e Mediadores Judiciais”), à conciliação e à mediação *judiciais*, cuja realização é determinada pelo juiz e que se desenvolve no âmbito judiciário. Elas não excluem, assim, “*outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais vinculadas a órgãos institucionais ou realizadas por intermédio de profissionais independentes, que poderão ser regulamentadas por lei específica*”. A Lei de Mediação, neste sentido, regula a figura do “mediador extrajudicial” (arts. 9.º e 10) e também o procedimento de mediação extrajudicial (arts. 21 a 23). E com razão, porque a conciliação e a mediação não devem ser *confundidas* com a sua modalidade judicial, que é apenas *uma* de suas formas possíveis. O espaço extrajudicial, aliás, menos regulado e menos burocrático, não deixa ser mais propício ao sucesso da solução consensual de litígios. Ele deve ser estimulado, e não visto com desconfiança, pelo Poder Judiciário. A mediação extrajudicial, aliás, é possível mesmo *no curso* do processo judicial. Lembre-se que, segundo dispõe o art. 313, II, do CPC, suspende-se o processo “*pela convenção das partes*”. E elas podem fazê-lo exatamente para tentarem a mediação extrajudicial.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Sobre a competência jurisdicional excepcional do senado: José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 522.

2

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 537.

3

Existe no Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a figura do *contador* judicial. Para mais detalhes: André Vasconcelos Roque, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 510).

4

Sobre os requisitos para a configuração desta responsabilidade, confirmam-se os próximos itens dos comentários a este artigo.

5

Para mais detalhes sobre este debate: Steffen Detterbeck, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, p. 403.

6

“O conjunto das instituições judiciárias do país, ou seja, dos responsáveis pelo exercício da jurisdição estatal, compõe o que tradicionalmente se chama Justiça” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 537).

7

Como adverte Lúcio Delfino, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 518.

8

José Frederico Marques, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 199.

9

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 446.

10

Sobre a competência excecional do escrivão para a prática de atos ordinatórios, sem conteúdo decisório, confira-se mais adiante.

11

Embora esta função seja normalmente exercida pelo secretário particular do juiz.

12

Mas a guarda destes arquivos digitais é confiada à administração do Tribunal, não a cada escrivão individualmente.

13

Neste sentido também o disposto no art. 203, § 4.º, segundo o qual “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

14

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 5, p. 246.

15

“A norma menciona “atos (...) como a juntada e a vista obrigatória”. Trata-se de indicação exemplificativa. Outros atos também se inserem nessa categoria, como, por exemplo, a remessa dos autos ao Ministério Público, nos feitos em que tem participação obrigatória; a expedição de carta precatória, quando o juiz deferiu providência a ser realizada em outra comarca; a determinação do pregão das partes para a abertura da audiência; a vista à parte sobre um documento juntado; a intimação das testemunhas arroladas, quando o meio de prova foi deferido; a entrega dos autos ao perito, entre outros” (Wambier e Talamini, *Curso avançado de processo civil*, vol. 1, p. 502).

16

Em sua versão original, o art. 12 do CPC estabelecia que “os juízes e os tribunais deverão obedecer à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão”. A redação atual acrescentou o advérbio “preferencialmente” ao dispositivo, alterando-se substancialmente o significado: “os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão”. Para mais detalhes sobre este debate: Castro Mendes e Silva, Os impactos do novo CPC na razoável duração do processo, *Revista de Processo*, vol. 241, p. 19.

17

Este, aliás, é um dos principais argumentos desenvolvidos pelos críticos da ordem cronológica para a prolação de sentenças: “O segundo problema é o da regra aumentar o mal que exatamente visa combater:

a morosidade. Pois não há como se negar que, com a novel disposição, o aporte para julgamento de causas mais complexas (v.g. uma ação societária, uma ação civil pública ou de improbidade administrativa) impedirá o julgamento de questões mais simples, cuja rápida solução é de manifesto interesse social (causas previdenciárias, que envolvam alimentos, execuções, despejos e procedimentos de jurisdição voluntária em geral, tais como interdições, alvarás para levantamento de valores etc.). Ainda que o § 2.º do art. 12 estabeleça exceções ao julgamento por ordem cronológica; 7 e que no estertor dos debates na Câmara tenha sido inserida uma louvável exceção genérica (IX – a causa que exija urgência no julgamento, 8 assim reconhecida por decisão fundamentada); elas podem não ser suficientes para contornar o eventual mal provocado pela disposição. Só quem efetivamente milita no foro sabe o que representa para o jurisdicionado a rápida solução de certos conflitos de menor complexidade não contemplados pelas exceções legais. E tudo sem contar que no estabelecer o julgamento por cronologia, o legislador projetista desconsidera – por completo –, que há causas a merecer reflexão mais demorada do magistrado, bem como outras que a própria postergação da intervenção judicial é necessária para que as partes reflitam melhor sobre o conflito e, muitas vezes, alcancem a autocomposição” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Pontos e contrapontos sobre o projeto do novo CPC, *Revista dos Tribunais*, vol. 950, p. 21).

18

Por exemplo, a preferência do idoso conforme o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, segundo o qual “é assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância”.

19

E isso porque “tal regra procura promover a impessoalidade e a moralidade na atuação do escrivão ou do chefe de secretaria” (Marco Antonio Rodrigues, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 279).

20

Pontes de Miranda, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 446.

21

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 865.

22

Neste sentido o disposto no art. 870, segundo o qual “a avaliação será feita pelo oficial de justiça”, com a ressalva de que “se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo (parágrafo único)”.

23

“As certidões lavradas por Oficiais de Justiça têm fé pública de acordo com o disposto nos artigos 364 e 365 do CPC, contando, portanto, com presunção de legitimidade e veracidade, razão pela qual, qualquer alegação em sentido contrário deve apresentar robusta comprovação” (HC 128.593/SE, 5.^a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.08.2009, *DJe* 14.09.2009).

24

Lembre-se que “escrivão” e “chefe de secretaria” são maneiras diferentes de denominar a mesma função, a de diretor do cartório. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 152.

25

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

26

O art. 93, aliás, é expresso em reconhecer uma hipótese de responsabilidade direta ao dispor que “as despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição”.

27

Sobre a questão, detalhadamente: Volker Lipp, *Das private Wissen des Richters* (1995), p. 49 e ss.

28

Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 3, p. 865.

29

AgRg no AREsp 851.533/SP, 4.^a Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 19.04.2016, *DJe* 29.04.2016.

30

“Ao perito não cabe intrometer-se na tarefa hermenêutica, opinando sobre questões jurídicas, interpretando lei ou citando jurisprudência ou doutrina jurídica. Sua atuação é eminentemente técnica e recai, tão somente, sobre fatos” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 273).

31

“Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito, e a parte, indicar mais de um assistente técnico” (art. 475).

Esta limitação é algo que deve ser repensado, mas apenas *de lege ferenda*.

“A nomeação de forma livre e desprendida de quaisquer cadastros e habilitações prévios passa a ser exceção ao regime geral de nomeação restrita àqueles devidamente cadastrados como auxiliares da justiça” (Paulo Magalhães Nasser, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 283).

Com a ressalva apenas de que “quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico-legal, o perito será escolhido, de preferência, entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame” (art. 478).

Desde que as partes “sejam plenamente capazes” (art. 471, I) e desde que “a causa possa ser resolvida por autocomposição” (art. 471, I).

Em sentido contrário: Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Curso de processo civil*, vol. 2, p. 399.

Por exemplo: “Não parece apropriado, p. ex., que o juiz nomeie seu irmão para atuar como perito, já que, em tese, tal circunstância pode influenciar a apreciação do laudo pericial (cf. art. 479 do CPC). Note-se, ademais, que, consoante estabelece o art. 147 do CPC, há restrições à atuação de juízes parentes, quando um deles já tiver atuado no feito. O princípio que embasa tal disposição serve, também, a que se restrinja a nomeação de parente como auxiliar, pelo juiz da causa” (José Miguel Garcia Medina, *Direito processual civil moderno*, p. 282).

Segundo o precedente citado pelos julgamentos posteriores (as referências legislativas são ainda ao CPC/1973: “O legislador, ao definir as hipóteses de suspeição e impedimento, atentou apenas para as possíveis relações existentes entre o juiz e as partes do processo, ou, conforme o art. 138, III, do CPC, entre as partes e o perito, nada dispondo acerca de eventuais vínculos, seja de que natureza for, entre o juiz e os seus auxiliares (peritos, serventuários, intérpretes etc.). Uma vez nomeado para officiar nos autos, o perito, sendo irmão do juiz que o nomeou, poderia até mesmo — o que seria uma atitude louvável — declarar a sua suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do parágrafo único do art. 135 acima transcrito. Tratando-se, todavia, de hipótese de suspeição, esta deve ser arguida em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão (CPC, art. 138, § 1.º). Assim, conquanto não constitua exemplo de ética profissional, não há na lei processual civil nada que impeça o juiz de nomear o seu próprio irmão para officiar nos autos como seu

assistente, não sendo causa suficiente, portanto, para se declarar, de ofício, a nulidade do julgamento” (REsp 906.598/MT, 1.ª Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, j. 19.06.2007, DJ 02.08.2007, p. 407).

39

Contra: Lúcio Delfino, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 540.

40

“O perito pode escusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição” (art. 467).

41

O Código Penal define o crime de falsa perícia nos seguintes termos: Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 158.

42

“O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo” (art. 465).

43

“O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias” (art. 466, parágrafo segundo). Além disso, “as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova” (art. 474).

44

Segundo o inc. IV do art. 473, o laudo deverá conter “resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”.

45

“Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho” (art. 465, parágrafo quinto).

46

Neste sentido o disposto no parágrafo segundo do art. 477, segundo o qual “o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II – divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte”.

47

“Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos” (art. 477, parágrafo terceiro).

48

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

49

“Lembre-se que “os bens arrecadados destinam-se a alienação em leilão falimentar, os arrestados podem vir a ser objeto de penhora, os penhorados alienados em hasta pública, os sequestrados ou apreendidos serão entregues ao titular” (Cândido Dinamarco, *Instituições de direito processual civil*, vol. 1, p. 869).

50

As referências são ao CPC/1973, mas permanecem atuais: “De fato, o Código Buzaid prevê situações em que o depositário, para além da guarda e conservação, assume as funções de administrador quando se trata de bens economicamente produtivos (CPC, arts. 677-678), isto é, o auxiliar da justiça também tem o múnus de gerir e fomentar o bem objeto de apreensão, fazendo jus a remuneração, bem como a indenização pelas despesas inerentes ao negócio – o credor adiantará, mas, ao final, as despesas recairão sobre o executado (CPC, art. 19) –, além do dever de prestar contas” (REsp 1117644/MS, 4.^a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.09.2014, *DJe* 07.10.2014).

51

“Quando a penhora recair em estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes, plantações ou edifícios em construção, o juiz nomeará administrador-depositário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias o plano de administração” (art. 862).

52

“Os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente” (art. 840, parágrafo segundo).

53

Segundo o art. 840, serão preferencialmente depositados “os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial” (inc. II). Com a ressalva de que “no caso do inc. II do *caput*, se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente” (parágrafo primeiro).

“A Súmula 319 do STJ dispõe que: “O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.”, por isso que o mesmo tratamento deve ser conferido ao depositário que assume o encargo e, posteriormente, de forma justificada, pleiteia exonerar-se do *munus* posto não poder mais suportar referido ônus” (REsp 1120403/SP, 1.^a Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 03.12.2009, *DJe* 02.02.2010).

Como se viu nos comentários ao art. 159.

Por isso, esta regra não se aplica ao administrador nomeado para administrar uma empresa.

As referências legislativas são ainda ao CPC/1973, mas o entendimento permanece atual: “Não há dúvida de que a pessoa física ou jurídica que aceita o encargo de se tornar depositária de coisa ou bem apreendido em juízo tem o direito de ser ressarcida das despesas que efetuou, além de perceber uma remuneração pelo exercício do encargo público (honorários), nos precisos termos do art. 149 do CPC. Ademais, não há vedação à aplicação do direito de retenção previsto no art. 644 do CC também aos depósitos judiciais. Além disso, não obstante decorrer de ordem judiciária, é importante relembrar que o depositário deve anuir expressamente à nomeação ou, querendo, recusar o *múnus* (Súmula 319 do STJ: “O encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado”) ou, para resguardar seu direito, requerer que lhe seja dada caução. Relembre-se que toda execução corre por conta do exequente. Aliás, como regra geral, o CPC estabelece que cabe às partes “prover as despesas dos atos que realizam ou requerem no processo, antecipando-lhes o pagamento desde o início até sentença final” (art. 19), bem como daqueles determinados pelo juízo (art. 19, § 2.º). Nessa linha, não há dúvida alguma de que o particular que aceita exercer o *múnus* público de depositário judicial tem direito à remuneração pelo seu trabalho e ao ressarcimento das despesas que precisou efetuar para a guarda e conservação. Desse modo, quando não for prestada caução nem forem adiantadas quaisquer despesas, o depositário tem direito de reter parte do produto enquanto não for ressarcido, pois todas as regras acima devem ser analisadas em conjunto” (REsp 1300584/MT, 3.^a Turma, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, j. 03.03.2016, *DJe* 09.03.2016).

O fundamento desta decisão, no atual CPC, seria o disposto no art. 866, segundo o qual “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.

“Verifica-se que o 2º Depositário Judicial havia solicitado verba para colocação de preposto para proceder à arrecadação, tendo sido requerido, portanto, o arbitramento de diária do preposto, a ser paga pela executada. Ocorre que o magistrado a quo deixou de atender ao requerimento da exequente, e optou por nomear sua patrona depositária e arrecadante. Deve prevalecer, contudo, aquele requerimento da

exequente, impondo-se a reforma da decisão a quo para que seja autorizada a nomeação de preposto pelo 2º Depositário Judicial, na forma do parágrafo único do art. 149 CPC” (Agravado de instrumento 0029187-05.2010.8.19.0000, Rel. Des. Cristina Teresa Gáulia, 5.ª Câmara Cível, j. 05.10.10, *DJe* 16.11.2010).

60

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

61

Neste sentido: “Constitui dever do depositário prover a guarda e a conservação do bem” (REsp 967.649/RS, 2.ª Turma, Rel. Ministro Castro Meira, j. 18.10.2007, *DJ* 05.11.2007, p. 259).

62

“A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu art. 7.º, § 7.º, vedou a prisão civil do depositário infiel, ressalvada a hipótese do devedor de alimentos. Contudo, a jurisprudência pátria sempre direcionou-se no sentido da constitucionalidade do art. 5.º, LXVII, da Carta de 1.988, o qual prevê expressamente a prisão do depositário infiel. Isto em razão de o referido tratado internacional ter ingressado em nosso ordenamento jurídico na qualidade de norma infraconstitucional, porquanto, com a promulgação da constituição de 1.988, inadmissível o seu recebimento com força de emenda constitucional. Nesse sentido confirmam-se os seguintes julgados da Suprema Corte: RE 253071 – GO, 1ª Turma, Rel. Ministro Moreira Alves, *DJ* 29.06.2006 e RE 206.482 – SP, Rel. Ministro Mauricio Corrêa, Tribunal Pleno, *DJ* 05.09.2003. A edição da EC 45/2004 acresceu ao art. 5.º da CF/1988 o § 3.º, dispondo que “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”, inaugurando novo panorama nos acordos internacionais relativos a direitos humanos em território nacional. Deveras, “a ratificação, pelo Brasil, sem qualquer reserva do pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, (art. 7.º, 7), ambos do ano de 1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da constituição, porém acima da legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de ratificação. Assim ocorreu com o art. 1.287 do Código civil de 1916 e com o Dec.-lei 911/1969, assim como em relação ao art. 652 do novo Código Civil (Lei 10.406/2002).” (voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, na sessão de julgamento do Plenário da Suprema Corte em 22 de novembro de 2006, relativo ao Recurso Extraordinário 466.343 – SP, da relatoria do Ministro CEZAR PELUSO)” (REsp 914.253/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 02.12.2009, *DJe* 04.02.2010).

63

“Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar”.

“Embora seja, depois do galego, a língua mais próxima do português, o idioma castelhano tem idiossincrasias que a fazem traiçoeira para o leigo, falante de portunhol. Bem por isso, só é permitido o ingresso de documento escrito em espanhol, quando “acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado” (CPC, Art. 157) (REsp 606.393/RJ, 3.^a Turma, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. 19.05.2005, *DJ* 01.08.2005, p. 444).

Embora as referências legislativas sejam ainda ao CPC/1973, este precedente é ainda atual: “1. A dispensabilidade da tradução juramentada de documento redigido em língua estrangeira (art. 157, CPC) deve ser avaliada à luz da conjuntura concreta dos autos e com vistas ao alcance da finalidade essencial do ato e à ausência de prejuízo para as partes e(ou) para o processo (arts. 154, 244 e 250, CPC). O indeferimento da petição inicial, quer por força do não preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC). Precedentes. “A exigência de apresentação de tradução de documento estrangeiro, consubstanciada no art. 157 do CPC, deve ser, na medida do possível, conjugada com a regra do art. 284 da mesma lei adjetiva, de sorte que se ainda na fase instrutória da ação ordinária é detectada a falta, deve ser oportunizada à parte a sanção do vício, ao invés de simplesmente extinguir-se o processo, obrigando à sua repetição” (REsp 434.908/AM, 4.^a Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, *DJ* 25.08.2003)” (REsp 1231152/PR, 3.^a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 20.08.2013, *DJe* 18.10.2013).

Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 470.

Por exemplo, os menores de dezoito anos não enquadrados em nenhuma das exceções do parágrafo único do art. 5.º do CC.

Contra: Celso Agrícola Barbi, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 1, p. 474.

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Em resumo, “deve-se mediar e conciliar para encontrar uma composição dos interesses, não para evitar que processos sejam julgados. Há uma grande diferença entre o entrelaçamento construtivo, que pressupõe diálogo e alternativas e a massificação que ocorre em muitos ‘mutirões de conciliação”

(Leonardo Carneiro da Cunha, *Mediação e conciliação no Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil*, *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 390).

71

Como o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de decidir. Neste sentido: ADI 2139 MC, Rel.(a): Min. Octavio Gallotti, Rel.(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 13.05.2009.

72

Para mais detalhes: Wilson Pimentel, O CPC de 2015, mediação e arbitragem: um sistema geral de solução de conflitos, In: Campos Melo e Beneduzi, *A Reforma da Arbitragem*, p. 339.

73

O art. 17, § 1.º, da Lei 8.429/1992, que regula a improbidade administrativa, dispõe, por exemplo, que “é vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações de que trata o *caput*”.

74

Por muitas razões, entre elas o despreparo dos conciliadores e a exagerada ênfase que seu deu à conciliação como um instrumento para desafogar o Poder Judiciário.

75

Realizada, no entanto, por um conciliador, não pelo juiz, a audiência preliminar deixou de servir também ao saneamento (cooperativo) do processo, transformando-se numa “mera” audiência de conciliação.

76

Sobre as dificuldades que a Lei de Mediação representa para a interpretação das normas do CPC que tratam de conciliação e arbitragem, confira-se Zulmar Duarte de Oliveira Júnior, *A difícil conciliação entre o Novo CPC e a Lei de Mediação*, disponível em: [<http://jota.uol.com.br/a-dificil-conciliacao-entre-o-novo-cpc-e-a-lei-de-mediacao>], acesso em: 15.07.16).

77

Para mais detalhes: Fernanda Tartuce, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 554.

78

“De todo modo, a diferença entre a conciliação e a mediação é sutil – e talvez, em um pensamento analiticamente mais rigoroso, inexistente, ao menos em seu aspecto substancial. A doutrina costuma considerá-las como técnicas distintas para a obtenção da autocomposição” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 274).

79

Fernanda Medina Pantoja, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 291.

80

Para mais detalhes, por exemplo: Galvão e Galvão Filho, *Mediação e conciliação na definição do novo CPC, A mediação no novo Código de Processo Civil*, p. 73.

81

O próprio art. 2.º da Lei de Mediação, com efeito, os descreve de modo ligeiramente diverso: I – imparcialidade do mediador; II – isonomia entre as partes; III – oralidade; IV – informalidade; V – autonomia da vontade das partes; VI – busca do consenso; VII – confidencialidade; VIII – boa-fé.

82

Sttefek e Unberath (orgs.), *Regulating dispute resolution* (2013), p. 15.

83

Neil Andrews chama este sistema em seu *On civil processes de civil justice*, de que principais espécies, mas não as únicas, a adjudicação judicial, a arbitragem, a mediação e a autocomposição não mediada (Neil Andrews, *On civil processes*, vol. 1, p. 5).

84

“Por evidente, chegar a um acordo não é obrigatório, o que, aí, sim, seria inconstitucional. De igual sorte, não se obriga a ‘permanecer’ num procedimento de mediação. Nesse contexto, o que, de fato, é obrigatório nos dado pela própria Lei de Mediação. Essa obrigatoriedade recai apenas e tão somente no ‘dever’ de participar da ‘primeira’ sessão de mediação” (Thiago Rodovalho, *A viragem da mediação no NCPC e no marco legal da mediação no Brasil, Coleção novo CPC* (doutrina selecionada), vol. 1, p. 398).

85

O que não impede o juiz, no entanto, de decidir se se deve realizar conciliação ou mediação.

86

Fernanda Medina Pantoja, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 291.

87

Neste sentido também o disposto no art. 30 da Lei de Mediação, segundo o qual “toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido

pela mediação”.

88

Neste sentido o disposto no art. 30, § 2.º, da Lei de Mediação, segundo o qual “a prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial”. Por isso, “a prova deverá ser reputada ilícita por violar o ordenamento e os princípios processuais” (Fernanda Tartuce, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 559).

89

“Preenchendo o requisito da capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça, o conciliador ou o mediador, com o respectivo certificado, poderá requerer sua inscrição no cadastro nacional e no cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal” (parágrafo primeiro).

90

O art. 11 da Lei de Mediação prevê ainda, especificamente em relação aos mediadores judiciais, a exigência de que esteja graduado “a há pelo menos dois anos em curso de ensino superior de instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e que tenha obtido capacitação em escola ou instituição de formação de mediadores, reconhecida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM ou pelos tribunais, observados os requisitos mínimos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça em conjunto com o Ministério da Justiça”.

91

“Os conciliadores, os mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em cadastro nacional e em cadastro de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, que manterá registro de profissionais habilitados, com indicação de sua área profissional” (*caput*). Neste sentido, também o art. 12 da Lei de Mediação, segundo o qual “os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial”.

92

Fernanda Medina Pantoja, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 298.

93

Para o preenchimento das listas, “o tribunal poderá optar pela criação de quadro próprio de conciliadores e mediadores, a ser preenchido por concurso público de provas e títulos, observadas as disposições deste Capítulo” (parágrafo sexto).

94

“Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional” (parágrafo segundo).

95

Sobre este princípio, confirmam-se os comentários ao art. 166.

96

Sobre a habilitação, os cadastros nacional e dos tribunais e sobre a distinção entre cadastro e lista, confirmam-se os comentários ao art. 167.

97

“Efetivado o registro, que poderá ser precedido de concurso público, o tribunal remeterá ao diretor do foro da comarca, seção ou subseção judiciária onde atuará o conciliador ou o mediador os dados necessários para que seu nome passe a constar da respectiva lista, a ser observada na distribuição alternada e aleatória, respeitado o princípio da igualdade dentro da mesma área de atuação profissional” (art. 167, parágrafo segundo).

98

“Os tribunais criarão e manterão cadastros atualizados dos mediadores habilitados e autorizados a atuar em mediação judicial”.

99

“Na mediação judicial, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, observado o disposto no art. 5.º desta Lei”.

100

Para mais detalhes: Fernanda Medina Pantoja, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 299.

101

“A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação do tribunal”.

102

“Os tribunais determinarão o percentual de audiências não remuneradas que deverão ser suportadas pelas câmaras privadas de conciliação e mediação, com o fim de atender aos processos em que deferida

gratuidade da justiça, como contrapartida de seu credenciamento.”

103

Para mais detalhes, confirmem-se os comentários ao art. 173.

104

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

105

Schwind e Kukiela, Câmaras de conciliação e mediação pública: comentários ao art. 174 do novo Código de Processo Civil, *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 10, p. 329.

107

Fernanda Medina Pantoja, *Comentários ao novo Código de Processo Civil* (Cabral e Cramer), p. 302.

108

Neste sentido o disposto no art. 36 da Lei de Mediação, segundo o qual “no caso de conflitos que envolvam controvérsia jurídica entre órgãos ou entidades de direito público que integram a administração pública federal, a Advocacia-Geral da União deverá realizar composição extrajudicial do conflito, observados os procedimentos previstos em ato do Advogado-Geral da União”.

109

Neste sentido o disposto no art. 35, segundo o qual “as controvérsias jurídicas que envolvam a administração pública federal direta, suas autarquias e fundações poderão ser objeto de transação por adesão, com fundamento em: I – autorização do Advogado-Geral da União, com base na jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais superiores; ou II – parecer do Advogado-Geral da União, aprovado pelo Presidente da República; § 1.º Os requisitos e as condições da transação por adesão serão definidos em resolução administrativa própria; § 2.º Ao fazer o pedido de adesão, o interessado deverá juntar prova de atendimento aos requisitos e às condições estabelecidos na resolução administrativa; § 3.º A resolução administrativa terá efeitos gerais e será aplicada aos casos idênticos, tempestivamente habilitados mediante pedido de adesão, ainda que solucione apenas parte da controvérsia; § 4.º A adesão implicará renúncia do interessado ao direito sobre o qual se fundamenta a ação ou o recurso, eventualmente pendentes, de natureza administrativa ou judicial, no que tange aos pontos compreendidos pelo objeto da resolução administrativa, § 5.º Se o interessado for parte em processo judicial inaugurado por ação coletiva, a renúncia ao direito sobre o qual se fundamenta a ação deverá ser expressa, mediante petição dirigida ao juiz da causa, § 6.º A formalização de resolução administrativa destinada à transação por adesão não implica a renúncia tácita à prescrição nem sua interrupção ou suspensão”.

Sobre a arbitrabilidade dos litígios envolvendo a administração pública: Paulo Osternack Amaral, *Arbitragem e administração pública: Aspectos processuais, medidas de urgência e instrumentos de controle*, p. 53.

© desta edição [2018]

TÍTULO V - DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis.

Direito anterior – sem correspondência.

Direito comparado – art. 421 do *Code de Procédure civile* francês.

1. O status constitucional do Ministério Público e suas competências no processo civil. A Constituição Federal de 1988 deu ao Ministério Público lugar destacado na organização do Estado, definindo-o como “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado” a que incumbe “a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, *caput*). Este dispositivo é transcrito, quase *ipsis litteris*, pelo art. 176 do CPC.¹

Desfazendo-se o “bifrontismo que sempre existiu no Ministério Público Federal, cujos membros exerciam cumulativamente as funções de Ministério Público de Procuradores da República no exercício da advocacia da União”², atribuiu-se ao Ministério Público, mediante o uso de tipos frequentemente abertos, um feixe vasto de competências (confira-se, neste sentido, o rol do art. 129 da Constituição, rol este que o Supremo Tribunal Federal entende não ser exaustivo).³ Sua extensão, aliás, ao menos no cível, é singular no direito comparado. Na França, por exemplo, estas competências são bem mais restritas (confirmam-se os arts. 422 e 423 do *Code de Procédure Civile*).⁴ Na Alemanha, o Ministério Público não tem rigorosamente nenhuma competência cível.⁵

A atuação do Ministério Público no processo civil ao longo da vigência da Constituição de 1988 reflete, e o novo CPC não alterará esta realidade, a opção do constituinte por alargar as suas competências. Embora conserve a sua tradicional função de *custos iuris* (sobre esta função, confirmam-se os comentários ao art. 178), o Ministério Público tem cada vez mais se tornado *parte* de demandas judiciais. Este crescente protagonismo é especialmente visível no processo coletivo⁶, em que o papel do Ministério Público é exageradamente exacerbado em relação ao dos demais legitimados.⁷ Realidade muito distinta daquela das *class actions* norte-americanas.⁸ Ele terá também consequências sobre a responsabilidade civil dos membros do Ministério Público, como se verá nos comentários ao art. 181.

Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais.

Direito anterior – art. 81 do CPC/1973.

Direito comparado – arts. 422 e 423 do *Code de Procédure civile* francês.

1. O princípio da legalidade e a atuação do Ministério Público. As competências do Ministério Público, como se viu nos comentários ao art. 176, são enunciadas de modo *não taxativo* pelo art. 129 da CF e previstas de modo esparso na legislação extravagante. Estas competências, aliás, são frequentemente definidas mediante o emprego de tipos abertos, o que contribui para lhes dar

uma abrangência ainda maior.

Esta realidade não exige o Ministério Público, no entanto, de observar em sua atuação o princípio da legalidade.⁹ Por este motivo, sem norma que autorize sua atuação, será ilegal a intervenção do Ministério Público no processo na qualidade de *custos iuris* e lhe faltará legitimidade para ser parte quando pretender atuar nesta qualidade. Se demandado, a situação é diversa, porque sua legitimidade passiva não dependerá de autorização legal; aplicam-se as regras gerais sobre legitimidade (passiva) explicadas nos comentários ao art. 70. Será o caso, por exemplo, na ação rescisória de sentença proferida em processo no qual o Ministério Público tenha sido parte.¹⁰

A extensão do rol de competências do Ministério Público e o uso frequente de tipos abertos para defini-la acabam criando, inevitavelmente, controvérsias sobre os limites desta atuação. Por este motivo, a determinação exata destes limites dependerá sempre da análise da situação jurídica particular. Colhem-se, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inúmeros exemplos de hipóteses controversas, entre eles os seguintes: “nos termos delineados pela jurisprudência do STJ, o Ministério Público possui legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública cujo objeto se relaciona à tutela de mutuários do sistema financeiro de habitação”,¹¹ “o Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura de ação civil pública destinada à defesa de direitos individuais homogêneos de consumidores, ainda que disponíveis, pois se está diante de legitimação voltada à promoção de valores e objetivos definidos pelo próprio Estado”, porque “a tutela efetiva de consumidores possui relevância social que emana da própria Constituição Federal (arts. 5.º, XXXII, e 170.º, V)”,¹² “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para atuar em causas que tratem de danos causados ao meio ambiente”,¹³ “o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública com o intuito de discutir a cobrança de taxas supostamente abusivas em contratos bancários”,¹⁴ “o Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente. A legitimidade do Ministério Público independe do exercício do poder familiar dos pais, ou de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca”,¹⁵ e assim sucessivamente.

Embora se reconheça capacidade postulatória para o Ministério Público *como um todo* para agir em juízo, sem a representação de advogado, a capacidade de seus membros é limitada pelas leis de organização do Ministério Público. O promotor de justiça, por exemplo, não tem capacidade postulatória para atuar nos órgãos de segunda instância. A apresentação do Ministério Público, neste caso, deve ser feita pelos procuradores de justiça, conforme disposto no art. 31 da Lei Orgânica do Ministério Público.¹⁶ A citação do Ministério Público, ademais, deve ser feita por meio eletrônico, conforme exige o disposto nos arts. 1.050 e 246, § 2.º, do CPC. Sobre as regras aplicáveis ao impedimento e à suspeição dos membros do Ministério Público, confirmam-se os comentários ao art. 148.

Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

- I – interesse público ou social;
- II – interesse de incapaz;
- III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.

Parágrafo único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público.

Direito anterior – art. 82 do CPC/1973.

Direito comparado – arts. 424 e 425 do *Code de Procédure civile* francês.

1. A intervenção do Ministério Público na qualidade de fiscal da ordem jurídica (*custos iuris*). Enquanto guardião (*custos*) da ordem jurídica (*iuris*), a intervenção desinteressada do Ministério Público no processo é obrigatória nos casos em que algum interesse especial justificar esta intervenção. Diz-se *desinteressada* a intervenção porque, nestes casos, o Ministério Público não é um sujeito parcial do processo; tecnicamente, ele nada pede e nada contra ele é pedido, no sentido de que ele não deduz no processo uma pretensão processual nem contra ele uma pretensão processual é deduzida. Sua função, a rigor, é precipuamente a de *opinar*,¹⁷ ainda que, ao opinar, faça-o em sentido favorável a uma parte e desfavorável a outra. Sobre a exigência de imparcialidade da atuação do Ministério Público no processo na qualidade de fiscal da ordem jurídica, e as hipóteses de impedimento e suspeição, confirmam-se os comentários ao art. 148.

2. Casos de intervenção obrigatória. Mas quais seriam estes interesses sensíveis que justificariam a intervenção do Ministério Público no processo civil na qualidade de fiscal da ordem jurídica? Certos dispositivos são deliberadamente vagos ao definir estes limites, de modo a conferir à intervenção do Ministério Público maior flexibilidade e, ao mesmo tempo, mais racionalidade. Permitem, deste modo, a intervenção em casos em que ela é necessária, mas que não foram expressa e nominalmente contemplados por lei, e permitem também que o Ministério Público se recuse a intervir quando a sua intervenção, ainda que admissível em tese, não se mostrar concretamente necessária. Por isso a lei fala, em termos gerais, em “interesse público ou social” (inc. I) e em “interesses de incapaz” (inc. II).¹⁸

A ideia, no primeiro inciso, é a de que a intervenção é necessária quando os efeitos potenciais do julgamento da demanda transbordarem os interesses imediatos das partes do litígio e puderem atingir terceiros de modo considerável. A lei, em certos casos, presume este interesse. Por exemplo, ao estatuir que a intervenção é necessária nos processos que envolvam “litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana” (inc. III); ou ainda no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 976, § 2.º).¹⁹ Em outros, a lei opta por esclarecer que a intervenção *não* é necessária. Por exemplo, ao dizer que “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público” (parágrafo único).²⁰ Esta solução *negativa* é também visível, por exemplo, nos litígios falimentares, em que se vetou o dispositivo da lei que tornaria obrigatória a intervenção do Ministério Público.²¹ Mas a porta deve estar sempre aberta à avaliação casuística sobre a necessidade concreta de sua intervenção. Daí, aliás, por que o parágrafo único emprega cautelosamente a expressão “por si só”.

A função do Ministério Público, de todo modo, não é a de zelar pelos interesses da administração pública, que não se confundem com o interesse público que justifica a sua intervenção na qualidade de *custos iuris*,²² nem tampouco pelo “puro e simples interesse da sociedade no correto exercício da jurisdição como tal – que também é uma função pública –, porque dessa atenção estão encarregados os juízes, também agentes estatais eles próprios”.²³

O inc. II, por seu turno, reflete a ideia de que a intervenção é necessária quando o litígio envolver pessoas em situação de vulnerabilidade, como crianças e adolescentes.²⁴ Mas esta intervenção não decorrerá em todo e qualquer caso, apenas em vista da qualidade pessoal das partes. Não será em todo processo em que parte um idoso, por exemplo, que esta intervenção será necessária,²⁵ nem tampouco em todos aqueles que envolverem interesses de menores de idade.²⁶ Também aqui a avaliação concreta do Ministério Público é indispensável.

3. Intimação do Ministério Público para dizer se deseja intervir. O Ministério Público só deverá intervir no processo nos casos em que lhe for permitido fazê-lo, em obediência ao princípio da legalidade. Por isso, o juiz deve indeferir a intervenção se entendê-la incabível.²⁷ De todo modo, quando esta intervenção lhe parecer oportuna, ele deve determinar a intimação do Ministério Público, de ofício ou após requerimento de uma das partes, para esclarecer se deseja ou não intervir (*caput*). Ainda que ele não esteja convencido em um sentido ou em outro, esta providência, deferência justificada que o juiz deve à opinião do Ministério Público sobre os limites de sua própria atuação, contribuirá também para minorar os riscos de alegações futuras de nulidade. O que ele não pode fazer, no entanto, é *constranger* o Ministério Público a intervir contra a sua vontade. Nada há, no processo, que o juiz possa fazer contra a recusa do Ministério Público

com a qual não concorda.²⁸

Intimado, o Ministério Público terá o prazo *preclusivo* de trinta dias para manifestar-se (*caput*). Este prazo não deverá ser contado em dobro, por força do disposto no art. 180, § 2.º. Não se trata apenas de prazo para que o Ministério Público esclareça se tem interesse em se manifestar, mas para *oferecer* a sua manifestação. Encerrado este prazo, “sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo” (art. 180, § 1.º). Esta norma é salutar, porque contribui para salvaguardar a garantia constitucional das partes à duração razoável do processo. Também não vulnera os interesses tutelados pela intervenção, porque não a proíbe em um momento posterior do processo. Só não será possível ao Ministério Público arguir a invalidade dos atos praticados sem sua intervenção em razão do caráter preclusivo deste prazo de 30 dias. Isso, obviamente, apenas se regular a sua intimação.

Segundo o art. 279, “é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”. Por isso, “se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado” (art. 289, parágrafo primeiro). Esta regra, no entanto, é temperada pela ressalva que faz o § 2.º do art. 279, segundo o qual “a nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo” e, sobretudo, pela exigência de que a decretação da nulidade tenha por fundamento a ocorrência de *efetivo* prejuízo.²⁹ Mesmo havendo prejuízo, aliás, a nulidade pode ser coonestada pelo pronunciamento posterior do Ministério Público.³⁰ E isso porque “a falta de intervenção do Ministério Público em primeiro grau pode ser suprida pela atuação da Instituição perante o colegiado em segundo grau”.³¹ A ideia é de que a invalidação dos atos processuais e a *marcha a ré* que ela ocasiona são algo extremamente gravoso, cujo reconhecimento deve ser interpretado no espírito de preservar o que puder ser preservado.³²

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:

I – terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo;

II – poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.

Direito anterior – art. 83 do CPC/1973.

1. Poderes do Ministério Público quando intervém na qualidade de custos iuris. Quando intervém na qualidade de *custos iuris*, o Ministério Público, como se viu nos comentários ao art. 178, não se torna parte do processo, porque tecnicamente nada pede e nada contra ele é pedido, no sentido de que ele não deduz no processo uma pretensão processual nem contra ele uma pretensão processual é deduzida. Sua função é precipuamente a de *opinar*, ainda que, ao opinar, faça-o em sentido favorável a uma parte e desfavorável a outra. Exatamente para que possa desempenhar adequadamente esta função é que se assegura ao Ministério Público a prerrogativa de ter “vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo” (inc. II).³³

Para a tutela eficaz do interesse sensível³⁴ que a intervenção do Ministério Público visa a assegurar, no entanto, não basta apenas a prerrogativa de manifestar-se oportunamente a cada ato do processo. Por isso, a ele se reconhece também o poder de “produzir provas,³⁵ requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer³⁶” (inc. III). Ainda que contra a vontade das partes.³⁷ A expressão “requerer as medidas processuais pertinentes” empregada pelo inc. II, com efeito, é deliberadamente vaga, de modo a não restringir imoderadamente a atuação do Ministério Público. É por isso que se lhe reconhece, por exemplo, o poder de requerer a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 977), requerimento este que não consiste nem em “produção de provas” nem em “interposição de recursos”. O Ministério Público poderá fazê-lo independentemente ou mesmo contra a vontade das partes.

Art. 180. O Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1.º.

§ 1.º Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará andamento ao processo.

§ 2.º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público.

Direito anterior – art. 188 do CPC/1973.

1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Embora a previsão pela lei de prazos privilegiados para certas partes em juízo³⁸ seja controversa na doutrina, o CPC/2015 optou por manter-se fiel a esta tradição. Fez isso, aliás, melhor e mais sistematicamente do que o CPC/1973, ao dar tratamento homogêneo à contagem de prazos para o Ministério Público (art. 180), para a Fazenda Pública (art. 183) e para a Defensoria Pública (art. 186). Eliminou-se, desta maneira, o exagerado prazo *em quádruplo* para contestar do código revogado, estabelecendo-se a regra mais equilibrada segundo a qual “o Ministério Público gozará de prazo em dobro para manifestar-se nos autos” (*caput*).

Esta regra vale para todas as manifestações do Ministério Público no processo,³⁹ inclusive a interposição de recursos e o protocolo de contrarrazões, salvo apenas “quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o Ministério Público” (§ 2.º). Será o caso, por exemplo, do prazo de 30 dias para a sua manifestação na qualidade de *custos iuris* previsto no art. 179. Esta exceção não incidirá, entretanto, quando o prazo tiver natureza judicial; nas hipóteses em que a lei atribui ao juiz o poder de fixar o prazo, sem indicar-lhe nenhum parâmetro (art. 218, § 1.º), quando lhe dá balizas dentro das quais permite a fixação do prazo (como no prazo para contestar a ação rescisória, conforme art. 970) e ainda nos casos em que o juiz prorroga prazo peremptório com fundamento no disposto no art. 139, VI. Se o juiz, em outras palavras, fixar por qualquer motivo um prazo para a prática de ato processual pelo Ministério Público, ele deverá ser contado em dobro.⁴⁰

A contagem dos prazos para o Ministério Público inicia-se, ademais, de sua intimação pessoal, que se fará “*por carga, remessa ou meio eletrônico*” (art. 183, § 1.º). A preferência, no entanto, é pela intimação eletrônica (art. 270, parágrafo único), sendo irrelevante o momento em que o presentante do Ministério Público apõe o seu “ciente” nos autos,⁴¹ Sobre as consequências da ausência de manifestação tempestiva do Ministério Público quando oficiar na qualidade de *custos iuris* (art. 180, § 1.º), confirmam-se os comentários ao art. 178.

Art. 181. O membro do Ministério Público será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.

Direito anterior – art. 85 do CPC/1973.

Direito comparado – Art. 34 da Lei Fundamental alemã e § 839 do BGB.

1. *Quis custodiet ipsos custodes?* A Constituição de 1988, como se viu nos comentários ao art. 176, deu ao Ministério Público um protagonismo inédito na história constitucional do Brasil. Este protagonismo exige dos membros do Ministério Público, no entanto, responsabilidade. Pense-se no exemplo da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, cujas consequências podem ser destrutivas para homens e mulheres públicos; ou nas ações civis públicas para a tutela de direitos coletivos *lato sensu*, que podem, não raro, levar uma empresa à falência. A gama de competências do Ministério Público é vasta, e é bom que seja assim. Mas, como dizia Montesquieu, “*c’est une experience eternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le dirait! La vertu même a besoin de limites*”.⁴² A tendência a abusar dos poderes que lhe são conferidos é inata a todas as pessoas, mesmo àquelas honestas e bem-intencionadas. Por este motivo, o exercício *abusivo* do direito de ação pelo Ministério Público (art. 177) deve ser reprimido. Pelo mesmo motivo, aliás, é o Poder Judiciário, não o próprio Ministério Público, que deve decidir em última análise sobre a admissibilidade de sua intervenção no processo na qualidade de *custos iuris* e sobre a sua legitimidade para pedir em juízo a tutela de direitos alheios.

2. Responsabilidade objetiva do Estado. O Estado será *objetivamente* responsável, em primeiro lugar, pelo exercício abusivo do direito de ação pelo Ministério Público, conforme art. 37, 6.º, CF. E isso porque, como já se explicou nos comentários ao art. 80, demandar é um direito cujo exercício a cláusula geral da boa-fé processual não permite ser *abusivo*.⁴³ Esta ideia – de que não se admite o exercício abusivo de direitos – permeia, com efeito, todo o ordenamento jurídico.⁴⁴ Seu reconhecimento, conseqüentemente, não exige a demonstração subjetiva de má-fé do agente, da vontade consciente de cometer o abuso (*animus nocendi*).⁴⁵ Basta que a conduta do Ministério Público, *presentado* por um de seus membros, possa ser *objetivamente* definida como abusiva, que viole aquilo “que legitimamente é esperado de cada parte”.⁴⁶ E isso porque “a aferição de abusividade no exercício de um direito deve ser exclusivamente objetiva, ou seja, deve depender tão somente da verificação de desconformidade concreta entre o exercício da situação jurídica e os valores tutelados pelo ordenamento civil-constitucional”.⁴⁷ O que se exige, como bem resume a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é justamente a obediência “a um padrão de conduta que razoavelmente se espera de qualquer pessoa em uma relação jurídica impedindo a conduta abusiva e contrária à equidade”.⁴⁸ Será o caso, por exemplo, quando o Ministério Público valer-se da ação civil pública por ato de improbidade com *desvio de finalidade*, de modo a fazer dela um instrumento de controle judicial de políticas públicas e não de punição de administradores ímprobos. Independentemente da verificação do elemento subjetivo de seus agentes, o Estado deverá reparar o prejudicado pelos prejuízos que esta conduta lhe causar.

3. Responsabilidade civil dos membros do Ministério Público. O membro do Ministério Público, por seu turno, será também *civilmente* responsável (responsabilidade esta que não se confunde, portanto, com a sua eventual responsabilidade administrativa ou penal) por indenizar os prejuízos que, no exercício de sua função,⁴⁹ causar às partes do processo.⁵⁰ Esta responsabilidade pode ser de duas naturezas: a) direta, deduzida em demanda própria pelo prejudicado com fundamento no disposto no art. 927 do CC; ou b) regressiva, deduzida contra o membro do Ministério Público pelo Estado com fundamento no disposto no *caput* do art. 181, autonomamente ou no próprio processo em que o Estado é demandado pela parte prejudicada com fundamento, por sua vez, no disposto no art. 37, 6.º, CF.⁵¹

Embora o tema mereça tratamento mais aprofundado, que se deixa para outra ocasião, o ponto central é de que o art. 37, § 6.º, da Constituição, não exclui a responsabilidade civil direta do agente público, apenas regulamenta a sua responsabilidade regressiva no caso em que o Estado venha a ser demandado pelos danos causados por seu agente. A função deste dispositivo constitucional, com efeito, não é o de *limitar* o direito do prejudicado à indenização, mas sim de dar-lhe a alternativa de seguir o caminho menos tortuoso da responsabilidade objetiva do Estado fundada na doutrina do risco administrativo. Diz-se “menos tortuoso” porque a responsabilidade direta exige a comprovação do elemento subjetivo que se dispensa na demanda contra Estado. Esta *mens* mostra-se ainda mais evidente quando se lembra que a responsabilidade objetiva se estende também às pessoas de “direito privado prestadoras de serviços públicos”, porque não haveria sentido algum em considerá-las imunes à responsabilidade direta. O CPC não elimina nem veda, portanto, a responsabilidade direta do membro do Ministério Público,⁵² apenas regulamenta ao seu lado a sua responsabilidade regressiva⁵³ (em termos mais restritivos, aliás, do que aqueles constantes do art. 37, § 6.º, da Constituição, porque exclui o direito de regresso nos casos de mera culpa). Tampouco permite àquele que se considera prejudicado deduzir sua pretensão no mesmo processo em que alega ter sofrido o prejuízo.

Em relação à responsabilidade direta do membro do Ministério Público, subjetiva, vale a regra geral: a responsabilidade direta pressupõe a comprovação do dolo ou da culpa. Pense-se no caso em que o membro do Ministério Público ajuíza uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra um desafeto seu, sabendo da inocência deste. Ou que o faça movido por paixões ideológicas ou políticas, consciente de que sua demanda não tem embasamento algum. *Comprovado* o elemento subjetivo, é razoável que o agente indenize diretamente os prejuízos que causar à parte prejudicada. E é bom que seja assim, porque a responsabilidade direta desestimula a prática de arbitrariedades de um modo que a responsabilidade meramente regressiva não é capaz de fazer. Se infundada a demanda contra o membro do Ministério Público, ou mesmo se esta é destinada apenas a constrangê-lo, o sistema processual tem remédios adequados, ao lado da

própria improcedência e da condenação em honorários, para reprimir a prática da litigância de má-fé (art. 79).

Quanto à responsabilidade regressiva, o art. 181 contém disposição especial. Em regra, o membro do Ministério Público será responsável apenas quando “proceder com dolo ou fraude”. Como esclarece Carnelutti, ainda que tratando da responsabilidade do juiz, mas a lógica é a mesma, a referência à fraude é desnecessária, é “*sovrabbondante*”.⁵⁴ Basta a demonstração do “dolo” para a configuração da responsabilidade regressiva. Dolo, neste contexto – e se socorre novamente do magistério de Carnelutti –, não é apenas a consciência (*consapevolezza*), mas antes a intenção do ilícito (*intenzione dell'illecito*).⁵⁵

NOTAS DE RODAPÉ

1

Sobre a “adaptação processual do Ministério Público à Constituição”, confira-se Robson Renault Godinho, O Ministério Público no novo Código de Processo Civil: alguns tópicos, in: *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 6, p. 63. Sobre a posição do Ministério Público na ordem constitucional brasileira: Gregório Assagra de Almeida, O Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na Constituição de 1988 e no novo CPC para o Brasil, in: *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 6, p. 140.

2

José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 605.

3

“O rol de atribuições conferidas ao Ministério Público pelo art. 129 da CF não constitui *numerus clausus*. O inc. IX do mesmo artigo permite ao Ministério Público “exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas” (ADI 3463, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. em 27.10.2011).

4

“Alors qu’il n’as pas de intérêt direct e personnel, le ministère public, est habilité par la loi, dans certaines hypothèses, à agir dans l’intérêt général. Il faut rappeler que les membres du ministère public sont les agents du pouvoir exécutif (Ord. 22 déc. 1958, art. 5) et ne peuvent donc, jouir de la même protection que les magistrats du siège. La question peut être discutée de savoir s’il est opportun que le ministère public puisse agir comme une véritable partie dans les procès civils. En matière pénale, la solution se comprend aisément dans e la mesure où l’État aller monopole de la répression. Mais en matière civile, les litiges opposent des particuliers relativement à des droits subjectifs. Il peut apparaître contestables, dans ces conditions, qu’un magistrat puisse s’immiscer au nom de la société dans des rapports d’intérêt privés pour par exemple, faire annuler un contrat ou pour contester la reconnaissance d’un enfant naturel contre le gré des intéressés eux-mêmes” (Cadiet/Jeuland, Droit judiciaire privé, p. 264).

5

Para mais detalhes: Renato Beneduzi, *Introdução ao processo civil alemão*, p. 62.

6

Hermes Zaneti Jr., *O Ministério Público e o novo processo civil*, p. 26.

7

Sobre a questão: José Carlos Barbosa Moreira, La iniciativa en la defensa judicial de los intereses difusos y colectivos, in: *Temas de direito processual* (quarta série), p. 165.

8

Para um panorama geral: Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, *Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos no direito comparado e nacional*, p. 63.

9

Ao Ministério Público também se aplica a regra segundo a qual “na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘pode fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim’” (Hely Lopes Meirelles, *Direito administrativo brasileiro*, p. 91).

10

Para mais detalhes: Didier Jr. e Godinho, Questões atuais sobre as posições do Ministério Público no novo CPC, in: *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 6, p. 26.

11

AgInt nos EDcl no REsp 1507476/PR, 2.^a Turma, rel. Min. Mauro Campbell Marques, , j. em 16.06.2016, *DJe* 23.06.2016.

12

REsp 1254428/MG, 3.^a Turma, rel. Min. João Otávio De Noronha, j. em 02.06.2016, *DJe* 10.06.2016.

13

AgRg no REsp 1356449/TO, 2.^a Turma, rel. Min. Herman Benjamin, j. em 03.05.2016, *DJe* 25.05.2016.

14

AgRg no REsp 1540148/AM, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 17.03.2016, *DJe* 31.03.2016.

15

REsp 1327471/MT, 2.^a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 14.05.2014, *DJe* 04.09.2014.

16

Neste sentido: Marcos Stefani, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas), p. 582.

17

Sobre os exatos poderes do Ministério Público quando intervém no processo na qualidade de *custos iuris*, confirmam-se os comentários ao art. 179.

18

Para uma análise aprofundada deste problema: Hermes Zaneti Jr., Código de Processo Civil 2015: Ruptura do Paradoxo entre o Ministério Público da legalidade e o Ministério Público constitucional, in: *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 6, p. 54.

19

“Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono”.

20

Neste sentido: “O Ministério Público Federal não tem legitimidade para substituir-se ao particular na defesa de interesse patrimonial deste, o de não submeter-se a uma exigência fiscal; também não tem interesse processual à vista da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça que considera desnecessária sua intervenção em execução fiscal” (AgRg no AgRg no REsp 1173499/PE, 1.^a Turma, rel. Min. Ari Pargendler, j. em 17.09.2013, *DJe* 14.10.2013).

21

“O art. 4.^o da Lei n. 11.101/2005, que previa ampla participação do Parquet nos processos de falência e recuperação de empresas, foi vetado pela Presidência da República. Assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes” (AgRg no Ag 1328934/GO, 4.^a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. em 04.11.2014, *DJe* 14.11.2014).

22

Daí a utilidade da distinção entre interesses primários e interesses secundários do Estado. Para mais detalhes: Celso Antônio Bandeira de Mello, *Curso de direito administrativo*, p. 65.

“Compete ao Ministério Público, a teor do art. 201, III e VIII, da Lei n. 8.069/1990 (ECA), promover e acompanhar o processo de destituição do poder familiar, zelando pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes. Nas ações de destituição do poder familiar, figurando o Ministério Público em um dos polos da demanda, pode ainda atuar como fiscal da lei, razão pela qual se dispensa a nomeação de curador especial” (AgRg no REsp 1497113/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. João Otávio De Noronha, j. em 09.06.2015, *DJe* 11.06.2015).

“Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que é desnecessária a participação do Ministério Público na qualidade de *custos legis* em demanda de cunho individual, ante o simples fato de nela figurar pessoa idosa, sendo certo que o Estatuto do Idoso somente torna inafastável a ouvida do “Parquet” nas demandas, regidas por aquele diploma, que envolvam direitos coletivos ou situação de risco aos idosos, hipótese que não se verifica *in casu*” (AgRg nos EDcl nos EREsp 1267621/DF, Corte Especial, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 20.08.2014, *DJe* 28.08.2014).

“Cinge-se a controvérsia a saber se na ação de reintegração de posse, objetivando a desocupação do bem em que a autora reside com filhos menores, a intervenção do Ministério Público é obrigatória, a fim de salvaguardar o interesse de incapazes, e conseqüentemente apta a ensejar a desconstituição da sentença rescindenda. Nos termos do inciso I do artigo 82 do CPC, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve diligenciar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo. Na hipótese, a ação de reintegração de posse foi ajuizada tão somente contra a genitora dos menores, não veiculando, portanto, pretensão em desfavor dos incapazes, já que a relação jurídica subjacente em nada tangencia os menores, os quais não são parte no negócio jurídico de arrendamento residencial do imóvel cujo agente financeiro pretende reaver a posse. A simples possibilidade de os menores virem a ser atingidos pelas consequências fáticas oriundas da ação de reintegração de posse não justifica a intervenção no Ministério Público no feito como *custos legis*. No caso, o interesse dos menores é meramente reflexo. Não são partes ou intervenientes no processo, tampouco compuseram qualquer relação negocial. Concretamente, não evidenciado o interesse público pela qualidade das partes, a atuação do Ministério Público importaria na defesa de direito disponível, de pessoa maior, capaz e com advogado constituído, situação não albergada pela lei” (REsp 1243425/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 18.08.2015, *DJe* 03.09.2015).

Em sentido contrário, por exemplo: Humberto Dalla Bernardina de Pinho, O Ministério Público e o papel de fiscal da ordem jurídica no CPC, in: *Coleção Repercussões do Novo CPC*, vol. 6, p. 127.

Em resumo: “Somente quando as duas instituições (Magistratura e MP) quiserem e estiverem de acordo é que se dará a intervenção. Caso uma das duas não queira, não intervirá o MP. A nenhuma delas cabe, sozinha, decidir se haverá intervenção do MP. Se só o MP quiser, o juiz poderá indeferir sua intervenção, que será definitiva se o tribunal negar provimento a eventual recurso. Se só o juiz quiser, não poderá ele, tampouco o tribunal, ordenar que o MP intervenha no processo, dada a independência jurídica e funcional do órgão do MP” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade Nery, *Comentários ao Código de Processo Civil*, art. 178, item 8).

29

“A jurisprudência desta Corte já assentou entendimento de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, a não ser que se demonstre o efetivo prejuízo para as partes, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgRg no AREsp 720.764/SE, 3.^a Turma, rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 22.09.2015, *DJe* 06.10.2015). Neste mesmo sentido: “O Superior Tribunal de Justiça consolidou que a ausência de intimação do Ministério Público como fiscal da lei só gera nulidade diante da presença de prejuízo. Havendo manifestação do parquet na instância ordinária e ausência de demonstração de prejuízo ante a falta de intimação do *custos legis* (fiscal da lei) na instância superior, aplica-se o princípio *pas de nullité sans grief* (não há nulidade sem prejuízo)” (AgRg na PET no REsp 1066996/DF, 6.^a Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 28.04.2015, *DJe* 11.05.2015).

30

Debatendo a questão, confira-se o seguinte precedente do STJ: REsp 1324693/MS, 2.^a Turma, rel. Ministro Castro Meira, j. em 10.09.2013, *DJe* 19.09.2013.

31

EDcl no AREsp 611.134/RJ, 3.^a Turma, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 23.02.2016, *DJe* 03.03.2016.

32

Por exemplo, no que concerne à aplicação da máxima *pas de nullité sans grief*: “A doutrina tem chamado de princípio da transcendência àquele de que se origina a regra de que, para que a nulidade seja declarada, é necessário que esta produza prejuízo. Do contrário, não se deve decretar a nulidade” (Teresa Arruda Alvim Wambier, *Nulidades do processo e da sentença*, p. 170). Também em relação ao princípio do aproveitamento dos atos defeituosos: “Somente se deve nulificar um ato do procedimento ou o próprio procedimento se não for possível aproveitá-lo – do mesmo modo que a invalidação deve restringir-se ao mínimo necessário, mantendo-se incólumes partes do ato que possam ser aproveitadas, por não terem sido contaminadas. O magistrado deve tentar aproveitar o ato processual ou o procedimento defeituoso. Eis o princípio do aproveitamento dos atos processuais defeituosos, que se aplica sempre, pouco importa o grau do defeito do ato ou do procedimento” (Fredie Didier Jr., *Curso de direito processual civil*, vol. 1, p. 412).

33

É por exato motivo que, na audiência de instrução e julgamento, “finda a instrução, o juiz dará a palavra

ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz” (art. 364).

34

Sobre a natureza do interesse que justifica esta intervenção, confirmam-se comentários ao art. 178.

35

É por este motivo que o Ministério Público pode *arrolar* testemunhas (art. 455, § 4.º, IV).

36

Neste mesmo sentido o disposto no art. 996, segundo o qual “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”.

37

“Nos termos da Súmula 99/STJ: ‘O Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte’, inclusive nas causas relativas a direitos individuais disponíveis” (RMS 27.455/DF, 5.ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 03.11.2011, *DJe* 21.11.2011).

38

Por exemplo: Ives Gandra da Silva Martins, O princípio da isonomia e os privilégios processuais da fazenda pública, *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, vol. 5, p. 21.

39

E apenas a prazos de natureza endoprocessual. Esta norma não atinge, conseqüentemente, prazos como aquele decadencial para o ajuizamento de ação rescisória (cf. art. 975). Sobre esta última questão: Sérgio Shimura, Prazo para a ação rescisória, *Revista de Processo*, vol. 209, p. 204.

40

Neste sentido também: Marco Antonio Rodrigues, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 76,

41

“Para o Ministério Público, o termo inicial da contagem do prazo para recorrer é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, independentemente da aposição de ciência em mandado encaminhado ao membro do Parquet, sem a efetiva remessa do feito” (AgRg nos EDcl no AgRg no HC 146.809/SC, 6.ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 15.10.2015, *DJe* 21.03.2016).

Montesquieu, De l'esprit des lois, in: *Oeuvres de Montesquieu*, vol. 1, p. 259.

“A aplicação geral do instituto do abuso do direito no campo do Direito processual civil surge, hoje, indiscutível. Nenhuma posição jurídico-subjectiva está imune a uma sindicância, no momento do seu exercício, feita à luz dos valores fundamentais do ordenamento em causa. Não há alternativa: o direito subjectivo imune ao sistema – e, como tal, susceptível de um exercício ilimitado – acabaria por se colocar fora do próprio ordenamento, tornando-se irreconhecível” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má fé, abuso do direito de acção e culpa* ‘in agendo’, p. 85).

“O abuso do direito constitui uma fórmula tradicional para exprimir a ideia do exercício disfuncional de posições jurídicas, isto é: do exercício concreto de posições jurídicas que, embora correcto em si, acabe por contundir com o sistema jurídico na sua totalidade. Antecipamos pois que, mau grado o seu alcance vocabular imediato, não há, no abuso do direito, nem ‘abuso’ nem, necessariamente, um direito subjectivo: apenas uma auctuação humana estritamente conforme com as normas imediatamente aplicáveis, mas que, tudo visto, se apresenta ilícita por contrariedade ao sistema, na sua globalidade” (Antonio Menezes Cordeiro, *Litigância de má fé, abuso do direito de acção e culpa* ‘in agendo’, p. 33).

“Não importa, na caracterização do uso ilícito do direito a deliberação de malfazer – *animus nocendi*” (Caio Mário da Silva Pereira, *Instituições de direito civil*, vol. 1, p. 578).

“Por outro lado, a chamada boa-fé objetiva é baseada em padrões de conduta social, voltada para a proteção às expectativas de que os demais membros do conjunto social nutrem de todos nós. Vale dizer, protegem-se os interesses do alter, a confiança de que todos pautem suas condutas de acordo com as convenções sociais, aquilo que legitimamente é esperado de cada parte. É a ideia de um “arquétipo moral”, passando a proteção processual da boa-fé, nos dias de hoje, da tradicional e insuficiente tutela subjectiva da vontade para a necessária tutela objetiva da confiança. Permite-se, portanto, com a sedimentação do conceito de boa-fé processual objetiva, a responsabilização por atos contrários à boa-fé processual sem qualquer consideração quanto à má-fé e ao dolo das partes e seus procuradores” (Antonio do Passo Cabral, O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva, *Revista de Processo*, vol. 126, p. 79).

Tepedino; Barboza; Bodin de Moraes, *Código civil interpretado*, vol. 1, p. 346.

49

A ressalva ao “exercício da função” não é sem razão. Este dispositivo regula a responsabilidade do membro do Ministério Público pelos atos que praticar enquanto membro do Ministério Público. Se ele se envolve num acidente de trânsito com uma das partes, não se aplicarão ao caso as regras previstas neste art. 181.

50

Sobre os requisitos para a configuração desta responsabilidade, confirmam-se os próximos itens dos comentários a este artigo.

51

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

52

O art. 93, aliás, é expresso em reconhecer uma hipótese de responsabilidade direta ao dispor que “as despesas de atos adiados ou cuja repetição for necessária ficarão a cargo da parte, do auxiliar da justiça, do órgão do Ministério Público ou da Defensoria Pública ou do juiz que, sem justo motivo, houver dado causa ao adiamento ou à repetição”.

53

Neste sentido: Arruda Alvim Wambier; Lins Conceição; Silva Ribeiro; Torres de Mello, *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 332. Para um resumo dos argumentos contrários, por exemplo: Rogério Sampaio Contreiras de Almeida, in: Wambier; Didier Jr.; Talamini; Dantas, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*, p. 492.

54

“L’art. 55 n. 1 ha adottato, senza alcuna ragione, una vecchia formula da un lato difettosa, dall’altro sovrabbondante, la quale va rettificata mediante ‘interpretazione. Sono superflue le parole frode o concussione, le quali alludono a requisiti causali o formali dell’illecito indifferenti ai fini della responsabilità civile; necessario e sufficiente è che l’inosservanza dell’obbligo sia dolosa” (Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184).

55

Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184.

TÍTULO VI - DA ADVOCACIA PÚBLICA

Art. 182. Incumbe à Advocacia Pública, na forma da lei, defender e promover os interesses públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por meio da representação judicial, em todos os âmbitos federativos, das pessoas jurídicas de direito público que integram a administração direta e indireta.

Direito anterior – Sem correspondência.

1. O status constitucional da Advocacia Pública. Superando a situação de confusão entre as duas funções vigente até a sua promulgação, a Constituição de 1988 optou por distinguir radicalmente a defesa em juízo dos interesses da administração pública, que incumbe à *Advocacia Pública*, da guarda do interesse público confiada ao *Ministério Público* conforme o seu art. 127¹ (sobre as atribuições do Ministério Público, confirmam-se os comentários ao art. 176).² A Advocacia Pública, assim, em todos os seus níveis (federal, estadual e municipal), foi elevada à condição de *função essencial à Justiça*. Sobre a representação judicial das diversas pessoas jurídicas de direito público, confirmam-se os comentários ao art. 75.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

§ 2º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público.

Direito anterior – art. 188 do CPC/1973.

1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Controversa embora na doutrina a previsão pela lei de prazos privilegiados para certas partes em juízo,³ optou o CPC/2015 por manter-se fiel a esta tradição. Fez isso, aliás, melhor e mais sistematicamente do que o CPC/1973, ao dar tratamento homogêneo à contagem de prazos para o Ministério Público (art. 180), para a Fazenda Pública (art. 183) e para a Defensoria Pública (art. 186). Eliminou-se, desta maneira, o exagerado prazo “em quádruplo” para contestar do código revogado, estabelecendo-se a regra mais equilibrada segundo a qual “*a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais*” (*caput*).

Esta regra vale para todas as manifestações das pessoas jurídicas de direito público (em todos os seus níveis, federal, estadual ou municipal) no processo,⁴ independentemente se apresentadas por procuradores ou representadas por advogados⁵ e independentemente da posição que ocuparem na relação jurídica processual (autor, réu, terceiro interveniente), inclusive para a interposição de recursos e o protocolo de contrarrazões. Excepciona-se apenas a situação em que “*a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente público*” (parágrafo segundo). Será o caso, por exemplo, do prazo de quinze dias para a impugnação aos embargos à execução fiscal

prevista no art. 17 da Lei 6.830/1980. Esta exceção não incidirá, entretanto, quando o prazo tiver natureza judicial; nas hipóteses em que a lei atribui ao juiz o poder de fixar o prazo, sem indicá-lhe nenhum parâmetro (art. 218, § 1.º), quando lhe dá balizas dentro das quais permite a fixação do prazo (como no prazo para contestar a ação rescisória, conforme art. 970) e ainda nos casos em que o juiz prorroga prazo peremptório com fundamento no disposto no art. 139, VI. Se o juiz, em outras palavras, fixar por qualquer motivo um prazo para a prática de ato processual para a Fazenda Pública, ele deverá ser contado em dobro.⁶

A contagem dos prazos para a Fazenda Pública inicia-se, quando apresentada por advogado público, de sua intimação pessoal, que se fará “*por carga, remessa ou meio eletrônico*” (art. 183, § 1.º). É por isso que se determina que “*a intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial*” (art. 269, § 3.º). A preferência, no entanto, é pela intimação eletrônica (art. 270, parágrafo único), sendo irrelevante o momento em que o presentante da Fazenda Pública apõe o seu “*ciente*” nos autos. Se representada a Fazenda Pública por advogado, diferentemente, aplicam-se as regras gerais sobre intimação (arts. 269 e ss.).

Art. 184. O membro da Advocacia Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.

Direito anterior – sem correspondência.

1. Responsabilidade civil do membro da Advocacia Pública. Embora a responsabilidade civil dos advogados públicos tenha recebido tratamento aparentemente idêntico àquela dos juízes e dos membros do Ministério Público, sua situação particular no processo exige alguma atenção do intérprete. E isso porque os advogados públicos, em todos os níveis (federal, estadual e municipal), defendem em juízo os *interesses* da administração pública, sem a mesma isenção que se exige do juiz e mesmo do Ministério Público. Sua atuação, neste sentido, assemelha-se mais à dos advogados privados do que propriamente à do juiz e dos membros do Ministério Público.

O art. 184 não trata, portanto, dos danos que o advogado público vier a causar *diretamente* à Fazenda Pública na defesa de seus interesses. Por exemplo, quando perde o prazo para interpor um determinado recurso. O dano, de que trata este dispositivo, é aquele causado pelo advogado público no exercício de suas funções⁷ contra um *terceiro*. Por isso, esta responsabilidade confunde-se com a responsabilidade das próprias partes por dano processual de que trata os arts. 79, segundo o qual “*responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente*”, e 80, que dá exemplos da prática de litigância de má-fé.

Se o Estado, em outras palavras, for condenado a indenizar uma parte por danos que ela tiver sofrido no processo – condenado em processo autônomo ou no próprio processo em que o dano tiver sido causado – poderá cobrar do advogado público que a apresentou em juízo o reembolso do que tiver de pagar quando ele tiver agido dolosamente (*caput*). Como esclarece Carnelutti, ainda que tratando da responsabilidade do juiz, mas a ideia é a mesma, a referência à fraude que faz o *caput* é desnecessária, é “*sovrabbondante*”.⁸ Basta a demonstração do “dolo” para a configuração da responsabilidade regressiva. Dolo, neste contexto, e se socorre novamente do magistério de Carnelutti, não é apenas a consciência (*consapevolezza*), mas antes a intenção do ilícito (*intenzione dell’illecito*).⁹

O advogado público, de todo modo, como também o juiz e o membro do Ministério Público, pode ser também diretamente responsabilizado pelos prejuízos que causar à parte, com fundamento no art. 927 do CC¹⁰. Esta responsabilidade, entretanto, é subjetiva, exigindo a comprovação do dolo ou da culpa. Pense-se, por exemplo, no procurador que ajuíza uma execução fiscal contra alguém, que sabe nada dever, movido por paixões ideológicas ou políticas. Nestes casos excepcionais é bom que seja assim, porque a responsabilidade direta desestimula a prática de arbitrariedades de um modo que a responsabilidade meramente regressiva não é capaz de fazer. Se infundada a demanda contra o advogado público, ou mesmo se apenas destinada a constrangê-lo, o sistema processual tem remédios adequados, ao lado da própria improcedência e

da condenação em honorários, para reprimir a prática da litigância de má-fé (art. 79).

Embora o tema mereça tratamento mais aprofundado, que se deixa para outra ocasião, é preciso lembrar que a o art. 37, § 6.º, da Constituição não exclui a responsabilidade civil direta do agente público, apenas regulamenta a sua responsabilidade regressiva no caso em que o Estado venha a ser demandado pelos danos causados por seu agente. A função deste dispositivo constitucional, com efeito, não é o de *limitar* o direito do prejudicado à indenização, mas sim de dar-lhe a alternativa de seguir o caminho menos tortuoso da responsabilidade objetiva do Estado fundada na doutrina do risco administrativo. Diz-se “menos tortuoso” porque a responsabilidade direta exige a comprovação do elemento subjetivo que se dispensa na demanda contra Estado. Esta *mens* mostra-se ainda mais evidente quando se lembra que a responsabilidade objetiva se estende também às pessoas de “*direito privado prestadoras de serviços públicos*”, porque não haveria sentido algum em considerá-las imunes à responsabilidade direta. O CPC não elimina nem veda, portanto, a responsabilidade direta do advogado público, apenas regulamenta ao seu lado a sua responsabilidade regressiva (em termos mais restritivos, aliás, do que aqueles constantes do art. 37, § 6.º, da Constituição, porque exclui o direito de regresso nos casos de mera culpa). Tampouco permite àquele que se considera prejudicado deduzir sua pretensão no mesmo processo em que alega ter sofrido o prejuízo.

NOTAS DE RODAPÉ

1

“O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.

2

É neste sentido que se alude ao desfazimento do “bifrontismo que sempre existiu no Ministério Público Federal, cujos membros exerciam cumulativamente as funções de Ministério Público de Procuradores da República no exercício da advocacia da União” (José Afonso da Silva, *Curso de direito constitucional positivo*, p. 605).

3

Por exemplo: Ives Gandra da Silva Martins, O princípio da isonomia e os privilégios processuais da fazenda pública, *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, vol. 5, p. 21.

4

E apenas a prazos de natureza endoprocessual. Esta norma não atinge, conseqüentemente, prazos como aquele decadencial para o ajuizamento de ação rescisória (cf. art. 975). Sobre esta última questão: Sérgio Shimura, Prazo para a ação rescisória, *Revista de Processo* 209, p. 210.

5

“A duplicação do prazo é benefício atribuído à parte – União, Estados Distrito Federal, Municípios e suas

respectivas autarquias e fundações –, e não meramente aos advogados públicos. Isso significa que, se o ente da Fazenda Pública atuar no processo representado por um advogado privado (especificamente contratado para tal atuação, em hipótese excepcional), também vigorará a regra geral do art. 183, *caput*. É o que se extrai do teor literal da norma – e é também a única conclusão extraível da sua *ratio*: as dificuldades burocráticas que justificam o prazo em dobro concernem a estrutura interna da Administração Pública como um todo, e não apenas à sua Procuradoria Jurídica” (Danielle Coutinho Talamini, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 600).

6

Neste sentido também: Marco Antonio Rodrigues, *A Fazenda Pública em juízo*, p. 76,

7

A ressalva ao “exercício da função” não é sem razão. Este dispositivo regula a responsabilidade do advogado público pelos atos que praticar na defesa do Estado em juízo. Se ele se envolve num acidente de trânsito com uma das partes, não se aplicarão ao caso as regras previstas neste artigo.

8

“L’art. 55 n. 1 ha adottato, senza alcuna ragione, una vecchia formula da un lato difettosa, dall’altro sovrabbondante, la quale va rettificata mediante ‘interpretazione. Sono superflue le parole frode o concussione, le quali alludono a requisiti causali o formali dell’illecito indifferenti ai fini della responsabilità civile; necessario e sufficiente è che l’inosservanza dell’obbligo sia dolosa” (Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184).

9

Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184.

10

Neste sentido, por exemplo: Mirna Cianci/Rita de Cassia Conte Quartieri, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 721.

TÍTULO VII - DA DEFENSORIA PÚBLICA

Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita.

Direito anterior – Sem correspondência.

1. O status constitucional da Defensoria Pública . A Constituição Federal, em seu art. 134, elevou a Defensoria Pública à condição de função essencial à Justiça, ao dispor que *“a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5.º desta Constituição Federal”*.¹ Trata-se de uma solução tipicamente brasileira para o problema universal do acesso dos mais necessitados à Justiça. Diz-se tipicamente brasileira, com efeito, porque esta solução passa pela *estatização* da assistência judiciária, fenômeno em que o Brasil não imitou os sistemas jurídicos que normalmente lhe servem de referência.

A solução usual, no direito comparado, é o *financiamento* pelo Estado da representação e assistência jurídica dos necessitados. Salvo melhor juízo, a Defensoria Pública, enquanto instituição pública destinada à *“orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”* (*caput*),² a quem se reconhece inclusive legitimidade para o ajuizamento de ações coletivas,³ é um *unicum* no mundo, embora não se deva esquecer que seus contornos gerais lembram aqueles da antiga *avvocatura dei poveri* piemontesa extinta logo após a unificação da Itália.⁴ A evolução por que tem passado a Defensoria Pública nos últimos anos, de todo modo, testemunha o acerto de sua adoção no Brasil. Seu sucesso na promoção da assistência jurídica dos mais necessitados é inegável, a despeito das restrições orçamentárias que prejudicam o seu trabalho. O direito brasileiro, aliás, foi ainda mais longe, reconhecendo à Defensoria Pública legitimidade extraordinária para agir em nome próprio na defesa de certos interesses, interesses estes cuja amplitude a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça interpreta de modo bastante generoso.⁵

2. Outras formas de assistência jurídica. Talvez uma das razões que explique o sucesso da Defensoria Pública no Brasil seja sua capacidade de conviver – ainda que esta convivência não se revele sempre pacífica – com outras formas de assistência jurídica aos necessitados. Entre elas destacam-se os escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, organizações não governamentais e, residualmente, mesmo o financiamento pelo Estado da representação privada de pessoas necessitadas. A Defensoria Pública, em outras palavras, integra um *sistema* de assistência jurídica aos necessitados do qual ela é protagonista, mas no qual ela não é o único ator.

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1.º O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183,

§ 1.º.

§ 2.º A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3.º O disposto no *caput* aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4.º Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.

Direito anterior – Sem correspondência.

1. Prazo em dobro para manifestar-se nos autos. Controversa embora na doutrina a previsão pela lei de prazos privilegiados para certas partes em juízo,⁶ optou o CPC por manter-se fiel a esta tradição. Fez isso, aliás, melhor e mais sistematicamente do que o CPC/1973, ao dar tratamento homogêneo à contagem de prazos para o Ministério Público (art. 180), para a Fazenda Pública (art. 183) e para a Defensoria Pública (art. 186). Eliminou-se, desta maneira, o exagerado prazo “em quádruplo” para contestar do código revogado, estabelecendo-se a regra mais equilibrada segundo a qual “a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais” (*caput*). Mas com a ressalva de que se exige “a cientificação prévia do juízo antes do decurso do respectivo lapso temporal”.⁷ Com isso se quer dizer que a contagem em dobro do prazo para a primeira manifestação da parte após a assunção de seu patrocínio pela Defensoria Pública dependerá da comunicação deste fato ao juiz antes da consumação do prazo simples. A solução é razoável, porque evita que a representação pela Defensoria Pública se transforme em um modo de burlar as consequências da preclusão temporal.

O prazo em dobro vale para todas as manifestações *no processo*⁸ das partes representadas pela Defensoria Pública, por “*escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei*” (parágrafo terceiro) e ainda por “*entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública*” (parágrafo terceiro), inclusive para a interposição de recursos e o protocolo de contrarrazões⁹. Excepciona-se apenas a situação em que a “*lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública*” (parágrafo quarto), analogamente ao que se faz em relação ao Ministério Público e aos advogados públicos. Salvo engano, ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro norma que defina prazo próprio especificamente para a Defensoria Pública. Esta exceção não incidirá, de todo modo, quando o prazo tiver natureza judicial; nas hipóteses em que a lei atribui ao juiz o poder de fixar o prazo, sem indicar-lhe nenhum parâmetro (art. 218, § 1.º), quando lhe dá balizas dentro das quais permite a fixação do prazo (como no prazo para contestar a ação rescisória, conforme art. 970) e ainda nos casos em que o juiz prorroga prazo peremptório com fundamento no disposto no art. 139, VI. Se o juiz, em outras palavras, fixar por qualquer motivo um prazo para a prática de ato processual para a parte, ele deverá ser contado em dobro. A contagem dos prazos para a parte representada pela Defensoria Pública ou pelas pessoas a ela equiparadas inicia-se, ademais, de sua intimação pessoal (§ 1.º), que se fará “*por carga, remessa ou meio eletrônico*” (art. 183, § 1.º). A preferência, no entanto, é pela intimação eletrônica (art. 270, parágrafo único), sendo irrelevante o momento em que o defensor público apõe o seu “*ciente*” nos autos.

2. Intimação pessoal da parte patrocinada. Interessante novidade do CPC é a regra segundo a qual “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada” (parágrafo segundo). Se bem interpretada, a norma é positiva à luz das dificuldades por que passam os defensores públicos para contactar seus assistidos e deles obter informações ou documentos necessários ao processo nos prazos assinalados pela lei ou pelo juiz. Diz-se se bem interpretada, entretanto, porque não é aceitável que cada momento do processo em que se revele necessária a intimação pessoal se transforme em uma oportunidade para a parte ocultar-se e frustrar assim o regular andamento do processo. É razoável, por este

motivo, generalizar a aplicação da regra constante do art. 513, § 2.º, II, segundo o qual a intimação pessoal da parte representada pela Defensoria Pública se dará “*por carta com aviso de recebimento*”, presumindo-se o sucesso da intimação se ela for entregue no endereço indicado pela parte. Encontra-se assim um ponto de equilíbrio entre as duas preocupações do legislador.

Art. 187. O membro da Defensoria Pública será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.

Direito anterior – Sem correspondência.

1. Responsabilidade civil do Defensor Público. Embora a responsabilidade civil do membro da Defensoria Pública tenha recebido tratamento aparentemente idêntico àquela dos juízes e dos membros do Ministério Público e da Advocacia Pública, as particularidades de sua atuação no processo exigem alguma atenção do intérprete. E isso porque os defensores podem atuar tanto na qualidade de representantes de partes desassistidas (fazendo as vezes, neste caso, de um advogado privado) quanto na de representantes da própria Defensoria Pública nos casos em que se reconhece a ela legitimidade extraordinária para agir em nome próprio na defesa de certos interesses¹⁰ (em situação análoga à atuação do Ministério Público em juízo na qualidade de parte). No que interessa à responsabilidade civil, são situações que merecem tratamento diverso.

Quando o seu membro atua em juízo na qualidade de representante da própria Defensoria Pública, sua responsabilidade assemelha-se àquela do membro do Ministério Público quando sua atuação se dá na qualidade de parte. Sobre esta responsabilidade, confirmam-se os comentários do art. 181. Se o defensor público atua em juízo na qualidade de representante de uma parte, diferentemente, sua responsabilidade se assemelhará mais, *mutatis mutandis*, à de um advogado privado.

Se o Estado for condenado a indenizar uma parte por danos que ela tiver sofrido no processo – condenado em processo autônomo ou no próprio processo em que o dano tiver sido causado – poderá cobrar do defensor público que representou a vítima,¹¹ o causador do dano¹² ou que apresentou a Defensoria Pública¹³ o reembolso do que tiver de pagar quando ele tiver agido dolosamente (*caput*). Como esclarece Carnelutti, ainda que tratando da responsabilidade do juiz, mas a ideia é a mesma, a referência à fraude que faz o *caput* é desnecessária, é “*sovrabbondante*”.¹⁴ Basta a demonstração do “dolo” para a configuração da responsabilidade regressiva. Dolo, neste contexto, e se socorre novamente do magistério de Carnelutti, não é apenas a consciência (*consapevolezza*), mas antes a intenção do ilícito (*intenzione dell'illecito*).¹⁵

Embora o tema mereça tratamento mais aprofundado, que se deixa para outra ocasião, é preciso lembrar, no entanto, que a o art. 37, § 6.º, da Constituição não exclui a responsabilidade civil direta do agente público, apenas regulamenta a sua responsabilidade regressiva no caso em que o Estado venha a ser demandado pelos danos causados por seu agente.¹⁶ A função deste dispositivo constitucional, com efeito, não é o de *limitar* o direito do prejudicado à indenização, mas sim de dar-lhe a alternativa de seguir o caminho menos tortuoso da responsabilidade objetiva do Estado fundada na doutrina do risco administrativo. Diz-se “menos tortuoso” porque a responsabilidade direta exige a comprovação do elemento subjetivo que se dispensa na demanda contra Estado. Esta *mens* mostra-se ainda mais evidente quando se lembra que a responsabilidade objetiva se estende também às pessoas de “*direito privado prestadoras de serviços públicos*”, porque não haveria sentido algum em considerá-las imunes à responsabilidade direta. O CPC não elimina nem veda, portanto, a responsabilidade direta do defensor público, apenas regulamenta ao seu lado a sua responsabilidade regressiva (em termos mais restritivos, aliás, do que aqueles constantes do art. 37, § 6.º, da Constituição, porque exclui o direito de regresso nos casos de mera culpa). Tampouco permite àquele que se considera prejudicado deduzir sua pretensão no mesmo processo em que alega ter sofrido o prejuízo.

Em relação à responsabilidade direta do membro da Defensoria Pública, assim, subjetiva, vale a regra geral: ela pressupõe a comprovação do dolo ou da culpa. Pense-se no caso em que ele ajuíza uma ação civil pública contra alguém movido por paixões ideológicas ou políticas, consciente de que sua demanda não tem embasamento algum. *Comprovado* o elemento subjetivo, é razoável que

o agente indenize diretamente os prejuízos que causar à parte prejudicada. E é bom que seja assim, porque a responsabilidade direta desestimula a prática de arbitrariedades de um modo que a responsabilidade meramente regressiva não é capaz de fazer. Se manifestamente infundada a demanda, o sistema processual tem remédios adequados, ao lado da própria improcedência e da condenação em honorários, para reprimir a prática da litigância de má-fé (art. 79).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Para mais detalhes: José Augusto Garcia de Souza, *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil* (Wambier, Didier Jr., Talamini e Dantas), p. 605.

2

O rol do art. 4.º da Lei Complementar 80, de 1994, é extenso.

3

“A Defensoria Pública é um órgão voltado não somente à orientação jurídica dos necessitados, mas também à proteção do regime democrático e à promoção dos direitos humanos e dos direitos individuais e coletivos. A pertinência subjetiva da Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de interesses transindividuais está atrelada à interpretação do que consiste a expressão ‘necessitados’ (art. 134 da CF) por ‘insuficiência de recursos’ (art. 5.º, LXXXIV, da CF). Deve ser conferido ao termo ‘necessitados’ uma interpretação ampla no campo da ação civil pública para fins de atuação inicial da Defensoria Pública, de modo a incluir, para além do necessitado econômico (em sentido estrito), o necessitado organizacional, ou seja, o indivíduo ou grupo em situação especial de vulnerabilidade existencial” (REsp 1449416/SC, 3.ª Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.03.2016, *DJe* 29.03.2016).

4

Para mais detalhes: Piero Calamandrei, *Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, Opere Giuridici*, vol. 4, p. 505.

5

Neste sentido, por exemplo: “A Defensoria Pública, instituição altruísta por natureza, é essencial à função jurisdicional do Estado, nos termos do art. 134, *caput*, da Constituição Federal. A rigor, mormente em países de grande desigualdade social, em que a largas parcelas da população – aos pobres sobretudo – nega-se acesso efetivo ao Judiciário, como ocorre infelizmente no Brasil, seria impróprio falar em verdadeiro Estado de Direito sem a existência de uma Defensoria Pública nacionalmente organizada, conhecida de todos e por todos respeitada, capaz de atender aos necessitados da maneira mais profissional e eficaz possível. O direito à educação legitima a propositura da Ação Civil Pública, inclusive pela Defensoria Pública, cuja intervenção, na esfera dos interesses e direitos individuais homogêneos, não se limita às relações de consumo ou à salvaguarda da criança e do idoso. Ao certo, cabe à Defensoria

Pública a tutela de qualquer interesse individual homogêneo, coletivo stricto sensu ou difuso, pois sua legitimidade ad causam, no essencial, não se guia pelas características ou perfil do objeto de tutela (= critério objetivo), mas pela natureza ou status dos sujeitos protegidos, concreta ou abstratamente defendidos, os necessitados (= critério subjetivo). Ao se analisar a legitimação ad causam da Defensoria Pública para a propositura de Ação Civil Pública referente a interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos, não se há de contar nos dedos o número de sujeitos necessitados concretamente beneficiados. Basta um juízo abstrato, em tese, acerca da extensão subjetiva da prestação jurisdicional, isto é, da sua capacidade de favorecer, mesmo que não exclusivamente, os mais carentes, os hipossuficientes, os desamparados, os hipervulneráveis. ‘É imperioso reiterar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a *legitimatío ad causam* da Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de interesses transindividuais de hipossuficientes é reconhecida antes mesmo do advento da Lei 11.448/07, dada a relevância social (e jurídica) do direito que se pretende tutelar e do próprio fim do ordenamento jurídico brasileiro: assegurar a dignidade da pessoa humana, entendida como núcleo central dos direitos fundamentais’ (REsp 1.106.515/MG, 1.^a Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, *DJe* 2.2.2011)” (AgInt no REsp 1573481/PE, 2.^a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 26.04.2016, *DJe* 27.05.2016).

6

Por exemplo: Ives Gandra da Silva Martins, O princípio da isonomia e os privilégios processuais da fazenda pública, *Revista Tributária e de Finanças Públicas*, vol. 5, p. 21.

7

REsp 401.979/MG, 6.^a Turma, Rel. Ministro Paulo Gallotti, j. 19.09.2002, *DJ* 11.11.2002, p. 304.

8

E apenas a prazos de natureza endoprocessual. Esta norma não atinge, consequentemente, prazos como aquele decadencial para o ajuizamento de ação rescisória (cf. art. 975). Sobre esta última questão: Sérgio Shimura, Prazo para a ação rescisória, *Revista de Processo* 209, p. 210.

9

E nada há de inconstitucional no § 3.º deste artigo (neste sentido, por exemplo: Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 735). E isso porque a lógica desse dispositivo é precisamente a de facilitar a defesa em juízo de pessoas necessitadas nas situações adversas, embora nem sempre exatamente as mesmas, em que atuam defensores públicos, escritórios de prática jurídica e demais entidades mencionadas. Se a lei optou por estender o prazo em dobro para as partes assistidas por escritórios de prática jurídica, à luz das dificuldades (financeiras, de pessoal, logísticas) que eles quotidianamente vivenciam, deve o intérprete conformar-se com a vontade do legislador. A Defensoria Pública, protagonista embora deste sistema, não tem e nem deve ter o *monopólio* da assistência jurídica no Brasil.

10

Por exemplo: “A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em

nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras” (AgRg no REsp 1572699/MT, 4.ª Turma, Rel. Ministro Marco Buzzi, j. 17.05.2016, *DJe* 24.05.2016. O art. 187 não trata, no entanto, dos danos que o defensor público puder vier a causar *diretamente* a seu constituinte em sua defesa. Por exemplo, se perder o prazo para interpor um determinado recurso. O dano, de que trata este dispositivo, é aquele causado pelo defensor público no exercício de suas funções contra um *terceiro*).

11

Será o caso, por exemplo, quando o defensor perder o prazo para interpor um recurso.

12

Se a parte é condenada pela prática de litigância de má-fé, por exemplo, pode reclamar do Estado indenização pelos prejuízos que esta condenação lhe causar.

13

Neste caso, os exemplos são similares àqueles mencionados quando se falou da responsabilidade civil do Ministério Público. Por hipótese, o ajuizamento de ação civil pública com desvio de finalidade. Para mais detalhes, confirmam-se os comentários ao art. 181.

14

“L’art. 55 n. 1 ha adottato, senza alcuna ragione, una vecchia formula da un lato difettosa, dall’altro sovrabbondante, la quale va rettificata mediante ‘interpretazione. Sono superflue le parole frode o concussione, le quali alludono a requisiti causali o formali dell’illecito indifferenti ai fini della responsabilità civile; necessario e sufficiente è che l’inosservanza dell’obbligo sia dolosa” (Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184).

15

Francesco Carnelutti, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, vol. 1, p. 184.

16

Neste sentido, por exemplo: Mirna Ciani; Rita de Cassia Conte Quartieri, *Comentários ao Código de Processo Civil*, vol. 2, p. 721.

Referências Bibliográficas

ABREU, Rafael Sirangelo de. O problema dos custos do processo e sua regulamentação pelo novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

ALMEIDA, Gregório Assagra de. O Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na Constituição de 1988 e no novo CPC para o Brasil. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 6.

ALMEIDA, Rogério Sampaio Contreiras de. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

ALVES E SILVA, Ticiano. O benefício da justiça gratuita no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 1.

AMARAL, Paulo Osternack. *Arbitragem e administração pública: Aspectos processuais, medidas de urgência e instrumentos de controle*. Belo Horizonte: Fórum, 2013.

AMERICANO, Jorge. *Comentários ao Código de Processo Civil do Brasil*. São Paulo: Saraiva, 1960. vol. 3.

ANDREWS, Neil. *On civil processes*. Cambridge: Intersentia, 2013. vol. 1.

_____. Relações entre a Corte e as partes na era do *case management*. *Revista de Processo*. vol. 217.

ARAÚJO, Luciano Vianna. Sucumbência parcial: o fim da anômala compensação entre credores distintos. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.

ARAÚJO, Nádia de. Medidas de cooperação interjurisdicional no Mercosul. *Revista de Processo*. vol. 123.

AROCA, Juan Montero. *El Proceso Civil*. Los Procesos Ordinarios de Declaración y de Ejecución (Tratados, Comentarios y Practicas Procesales). Valência: Blanch, 2014.

ARRUDA ALVIM; ASSIS, Araken de; ARRUDA ALVIM, Eduardo. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2012.

ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel de. Deveres das partes e dos procuradores no direito processual civil brasileiro (a lealdade no processo). *Revista de Processo*. vol. 69.

ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa. O que é abrangido pela coisa julgada no direito processual civil brasileiro: a norma vigente e as perspectivas de mudança. *Revista de Processo*. vol. 230.

- _____. *Os agravos no CPC brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- _____. Da ação rescisória. In: ____; WAMBIER, Luiz Rodrigues. *Temas essenciais do novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; MELLO, Rogerio Licastro Torres de. *Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- ASSIS, Araken de. Suprimento da incapacidade processual e da incapacidade postulatória. *Revista Forense*, vol. 354.
- BAPTISTA, Ovídio A. *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2005. vol. 1.
- BARBI, Celso Agrícola. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2010. vol. 1.
- BARBOSA; MAGNANI. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.
- BAUMBACH, Adolf; LAUTERBACH, Wolfgang; ALBERS, Jan; HARTMANN, Peters. *Zivilprozessordnung*. Munique: Beck, 2009.
- BAUR; STÜRNER. *Sachenrecht*. Munique: Beck, 2009.
- BEDAQUE, José Roberto dos Santos. In: MARCATO, Antonio Carlos (coord.). *Código de Processo Civil interpretado*. São Paulo: Atlas, 2006.
- BENEDUZI, Renato. *Introdução ao processo civil alemão*. Salvador: JusPodivm, 2015.
- _____. Forum non conveniens. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de, PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.
- _____. Legitimidade extraordinária convencional. *Revista Brasileira de Direito Processual*. vol. 86.
- _____. Notificação e citação na ação civil pública por ato de improbidade administrativa. In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos; COSTA, Eduardo José da Fonseca; COSTA, Guilherme Recena (coord.). *Improbidade administrativa* (aspectos processuais da Lei n. 8.429/92). São Paulo: Atlas, 2015.
- _____. *Prozessurteile e materielle Rechtskraft*: sentenças terminativas e coisa julgada material no processo civil alemão. *Revista de Processo*. vol. 229.
- _____. *Substantiierung, Notice-Pleading e Fact-Pleading*: A relação entre escopo das postulações e função da prova nos processos alemão, americano e inglês. *Revista dos Tribunais*. vol. 245.
- BECKER, Eberhard. *Münchener Kommentar zur ZPO*. Munique: Beck, 2013. vol. 1.
- BERALDO, Maria Carolina Silveira. Litigância de má-fé no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de, PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre (org.). *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.
- BERMUDES, Sergio. Capacidade processual e citação de réu morto. In: *Direito processual civil* (estudos e pareceres). 2 série. São Paulo: Saraiva, 1994.
- BEVILÁQUA, Clóvis. *Direito da família*. Recife: Contemporanea, 1905.
- BONFIM, Daniela Santos. A legitimidade extraordinária de origem negocial. In: DIDIER

- JR., Fredie (coord. geral); NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa; CABRAL, Antonio do Passo (coord. do vol. 1). *Coleção Grandes Temas do Novo CPC* (negócios processuais). Salvador: JusPodivm, 2016.
- BONJEAN, L.B. *Traité des actions*. Paris: Videcoq, 1845. vol. 2.
- BORN, Gary. *International Commercial Arbitration*. Londres: Wolters Kluwer, 2014. vol. 2.
- BUENO, Cássio Scarpinella. *Amicus curiae no processo civil brasileiro*. São Paulo: Saraiva, 2008.
- _____. *Manual de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- CABRAL, Antonio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. *Revista de Processo*. vol. 126.
- _____. *Nulidades no processo moderno*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.
- _____. Pelas asas de Hermes: a intervenção do *amicus curiae*, um terceiro especial. *Revista de Processo*. vol. 117.
- _____. Teoria das nulidades processuais no direito contemporâneo. *Revista de Processo*. vol. 255.
- CADIET, Loïc; JEULAND, Emmanuel. *Droit judiciaire privé*. Paris: LexiNexis, 2011.
- _____; NORMAND, Jacques; MEKKI, Soraya Amrani. *Théorie générale du procès*. Paris: PUF, 2010.
- CAHALI, Yussef Said. *Honorários advocatícios*. São Paulo: Ed. RT, 2011.
- CALAMANDREI, Piero. Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice. In: *opere giuridiche*. Nápoles: Morano, 1970. vol. 4.
- _____. *Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados*. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2015.
- CÂMARA, Alexandre Freitas. *O novo processo civil brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015.
- _____. Honorários de sucumbência recursal. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.
- _____. O direito à duração razoável do processo: entre eficiência e garantias. *Revista de Processo*. vol. 223.
- CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. Os honorários advocatícios pela sucumbência recursal. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.
- _____. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- CAMBI; NEVES. Flexibilização procedimental no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de, PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.
- CARMONA, Carlos Alberto. *Arbitragem e processo*. São Paulo: Atlas, 2009.
- CARNEIRO, Athos Gusmão. *Intervenção de terceiros*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- CARNEIRO, Paulo César Pinheiro. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.).

Comentários ao novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

CARNELUTTI, Francesco. *Sistema di diritto processuale civile*. Pádua: Cedam, 1938. vol. 1.

_____. *Sistema di diritto processuale civile*. Pádua: Cedam, 1936. vol. 2.

_____. *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*. Roma: Foro italiano, 1942. vol. 1.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. São Paulo: Atlas, 2013.

CHIOVENDA, Giuseppe. *Istituzioni di diritto processuale civile*. Nápoles: Jovene, 1936. vol. 2.

_____. *Principii di diritto processuale civile*. Nápoles: Jovene, 1920.

CIANCI, Mirna. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

COELHO, Fábio Ulhoa. *Comentários à nova lei de falências e de recuperação judicial*. São Paulo: Saraiva, 2010.

CORDEIRO, Antonio Menezes. *Litigância de má fé, abuso do direito de ação e culpa “in agendo”*. Coimbra: Almedina, 2014.

COSTA, Guilherme Recena. *Partes e terceiros na arbitragem*. Tese de doutorado, São Paulo, Faculdade de Direito da USP, 2015).

COSTA, Mário Júlio de Almeida. *Direito das obrigações*. Coimbra: Almedina, 2012.

COSTA E SILVA, Paula. *A transmissão da coisa ou direito em litígio*. Contributo para o estudo da substituição processual. Coimbra: Coimbra Editora, 1992.

CUNHA, Leonardo Carneiro da. A assistência no novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

_____. *A Fazenda Pública em juízo*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

_____. Mediação e conciliação no Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

CRAMER, Ronaldo. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia do processo sem dilações indevidas. In: _____. *Garantias constitucionais do processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

_____. *A causa petendi no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2009.

_____. AZEVEDO, Luiz Carlos de. *Lições de história do processo civil romano*. São Paulo: Ed. RT, 2001.

DAL'COL, João Roberto de Sá. Algumas notas sobre a chamada “nulidade guardada”. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

DANELUZZI, Maria Helena Marques Braceiro; MATHIAS, Maria Ligia Coelho. Repercussão do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) nas legislações civil e processual civil. *Revista de Direito Privado*. vol. 66.

DELFINO, Lúcio. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno. *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

DERGINT, Augusto do Amaral. Responsabilidade do Estado por atos judiciais. *Revista dos Tribunais*, vol. 710.

DETTERBECK, Steffen. *Allgemeines Verwaltungsrecht*. Munique: Beck, 2016.

DIDIER JR., Fredie. *Curso de direito processual civil*. Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

_____. Fonte normativa da legitimação extraordinária no Novo Código de Processo Civil: a legitimação extraordinária de origem negocial. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

_____; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. *Curso de direito processual civil*. Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 2.

_____; GODINHO, Robson Renault. Questões atuais sobre as posições do Ministério Público no novo CPC. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 6.

DINAMARCO, Cândido Rangel. *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Malheiros, 2016. vol. 1.

_____. _____. São Paulo: Malheiros, 2009. vol. 2.

_____. _____. São Paulo: Malheiros, 2009. vol. 3.

EID, Elie Pierre. *Litisconsórcio unitário: fundamentos, estrutura e regime*. Dissertação de mestrado, São Paulo, Faculdade de Direito da USP, 2016.

ENGISCH, Karl. *Einführung in das juristische Denken*. Stuttgart: Kohlhammer, 2005.

ESPÍNOLA, Eduardo. *A família no direito civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Gazeta Judiciária, 1954.

FAZZALARI, Elio. *Istituzioni di diritto processuale*. Pádua: Cedam, 1996.

FERRARI NETO, Luiz Antonio. Honorários advocatícios nas ações de indenização por ato ilícito. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 2.

FERREIRA MENDES, Gilmar; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. *Curso de direito constitucional*. São Paulo: Saraiva, 2015.

FOX, John. *The history of contempt of court*. Nova York: OUP, 1927.

FRIEDENTHAL, Jack H.; KANE, Mary Kay; MILLER, Arthur Rafael. *Civil procedure*. St. Paul: Thomson/West, 2007.

FUX, Luiz. *Intervenção de terceiros*. São Paulo: Saraiva, 1990.

_____; FUX, Rodrigo. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

GAJARDONI, Fernando da Fonseca. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____. *No novo CPC, demandar contra precedente é litigância de má-fé?* Disponível em: [http://jota.uol.com.br/no-novo-cpc-demandar-contra-precedente-e-litigancia-de-ma-fe]. Acesso em: 15.02.2015.

_____. Pontos e contrapontos sobre o projeto do novo CPC. *Revista dos Tribunais*. vol. 950.

GALVÃO, Fernanda Koeler; GALVÃO FILHO, Mauricio Vasconcelos. Mediação e conciliação na definição do novo CPC. In: *A mediação no novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

GERDES, Claudia. *Die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit aufgrund von Meinungsäußerungen des Richters*. Frankfurt: Peter Lang, 1992.

GODINHO, Robson Renault. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

_____. O Ministério Público no novo Código de Processo Civil: alguns tópicos. In: DIDIER JR., Fredie; GODINHO, Robson Renault; COSTA, Susana Henriques da. *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 6.

GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. *Direito de empresas*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

GOMES, Orlando. *Direitos reais*. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

_____. *Sucessões*, Rio de Janeiro: Forense, 2012.

GRECO FILHO, Vicente. *Intervenção de terceiros*. São Paulo: Saraiva, 1991.

GREGER, Reinhart. *Zivilprozessordnung* (Zöller). Colônia: Otto Schmidt, 2014.

GUIMARÃES, Luiz Machado. Processo autoritário e regime liberal. In: _____. *Estudos de direito processual civil*. Rio de Janeiro: Jurídica Universitária, 1969.

_____. As três figuras do litisconsórcio. In: *Estudos de direito processual civil*. Rio de Janeiro: Jurídica Universitária, 1969.

HAZARD, Geoffrey C.; LEUBSDORF, John; BASSETT, Debra Lyn. *Civil Procedure*. Nova York: Foundation Press, 2011.

HORN, Norbert. *Aequitas in den Lehren des Baldus*. Colônia: Böhlau, 1969.

JACOB, Jack. *The fabric of English civil justice*. Londres: Stevens, 1987.

JAUERNIG, Othmar; HESS, Burkhard. *Zivilprozessrecht*. Munique: Beck, 2011.

JORGE, Flávio Cheim. *Chamamento ao processo*. São Paulo: Ed. RT, 1999.

KASER, Max. *Zivilprozessrecht*. Munique: Beck, 1966.

KASER, M.; KNÜTEL, R. *Römisches Privatrecht*. Munique: Beck, 2008.

KIPP; WOLFF. *Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts*. Marburg: Braun, 1931. vol. 4.

KLEFFMANN, Norbert. *Unbekannt als Parteibezeichnung*. Frankfurt: Peter Lang, 1983.

KONZEN, Horst. *Rechtsverhältnisse zwischen Prozessparteien*. Berlim: Duncker und Humblot, 1976.

LAMY; RESCHKE. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

- LARENZ, Karl. *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*. Berlim: Springer, 2014.
- LEGG, Michael; PARK, Edmond; TURNER, Nicholas; TRAVERS, Louisa. The Rise and Regulation of Litigation Funding in Australia. *Northern Kentucky Law Review*. vol. 38.
- LIPP, Volker. *Das private Wissen des Richters*. Heidelberg: Müller, 1995.
- LOBO, Jorge. In: TOLEDO, Paulo Fernando Campos Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique. *Comentários à lei de recuperação de empresas e falência*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- LÔBO, Paulo Luiz Netto. *Código Civil comentado*. São Paulo: Atlas, 2003. v. 16.
- LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Os honorários recursais no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.
- LOPES DA COSTA, Alfredo de Araújo. *Direito processual civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 1959. vol. 3.
- LUCON, Paulo Henrique dos Santos. A advocacia no CPC de 2015. In: DIDIER JR., Fredie et al. (coord.) *Novo Código de Processo Civil: impactos na legislação extravagante e interdisciplinar*. São Paulo: Saraiva, 2015.
- LUISO, Francesco. *Diritto processuale civile*. Milão: Giuffrè, 2009. vol. 1.
- MAITLAND, Frederic W.; MONTAGUE, Francis C. *A sketch of English Legal History*. Nova York: G. P. Putnam's Sons, 1915.
- MARINONI, Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. *Curso de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. 2.
- MARQUES, José Frederico. *Ensaio sobre a jurisdição voluntária*. São Paulo: Saraiva, 1959.
- MARTINS, Ives Gandra da Silva. O princípio da isonomia e os privilégios processuais da fazenda pública. *Revista Tributária e de Finanças Públicas*. vol. 5.
- MARTINS, Sandro Gilbert. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- MARTINS-COSTA, Judith. *Comentários ao novo Código Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2009. vol. 5. T. 2.
- MEDICUS, Dieter. *Allgemeiner Teil des BGB*. Munique: Beck, 2010.
- _____. LORENZ, Stephan. *Schuldrecht I*. Munique: Beck, 2015.
- MEDINA, José Miguel Garcia. *Direito processual civil moderno*. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- MEIRA, Sílvio. *Instituições de direito romano*. São Paulo: Max Limonad, 1968.
- MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito administrativo brasileiro*. São Paulo: Malheiros, 2013.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de direito administrativo*. São Paulo: Malheiros, 2010.
- MELLO, Celso Duvivier de Albuquerque. *Curso de direito internacional público*. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.
- MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. *Ações coletivas e meios de resolução coletiva de conflitos*

no direito comparado e nacional. São Paulo: Ed. RT, 2012.

_____.; SILVA, Larissa Clare Pochmann da. Os impactos do novo CPC na razoável duração do processo. *Revista de Processo*. vol. 241.

MITIDIERO, Daniel. *Colaboração no processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

MONTEIRO BARBOSA; ALBUQUERQUE MAGNANI. In: DIDIER JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.

MONTESQUIEU. De l'esprit des lois. in *Ouevres de Montesquieu*. Paris: François Bastien, 1788. vol. 1.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *O novo processo civil brasileiro*. Rio de Janeiro: Forense, 2010.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2010. vol. 5.

_____. *Estudos sobre o novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1974.

_____. *Litisconsórcio unitário*. Rio de Janeiro: Forense, 1972.

_____. A responsabilidade das partes por dano processual no direito brasileiro. In: *Temas de direito processual*. São Paulo: Saraiva, 1977.

_____. Item do pedido sobre o qual não houve decisão. Possibilidade de reiteração noutro processo. In: *Temas de direito processual* (segunda série). São Paulo: Saraiva, 1988.

_____. La iniciativa en la defensa judicial de los intereses difusos y colectivos. In: *Temas de direito processual* (quarta série), São Paulo: Saraiva, 1989.

_____. Sobre pressupostos processuais. In: *Temas de direito processual* (quarta série). São Paulo: Saraiva, 1989.

_____. O direito à assistência jurídica: evolução no ordenamento brasileiro de nosso tempo. In: *Temas de direito processual* (quinta série). São Paulo: Saraiva, 1994.

_____. Reflexões sobre a imparcialidade do juiz. In: *Temas de direito processual* (sétima série). São Paulo: Saraiva, 2001.

_____. Reformas processuais e poderes do juiz. In: *Temas de direito processual* (oitava série). São Paulo: Saraiva, 2004.

MUSIELAK; VOIT. *Grundkurs ZPO*. Munique: Beck, 2016.

NADER, Paulo. *Curso de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2016. vol. 5.

NASSER, Paulo Magalhães. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de direito processual civil*. Salvador: JusPodivm, 2016.

NONATO, Orosimbo. *Curso de obrigações*. Rio de Janeiro: Forense, 1959. vol. 1.

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. *Alienação da coisa litigiosa*. Rio de Janeiro: Forense, 1986.

OLIVEIRA, Guilherme Peres de. *Adaptabilidade judicial: a modificação do procedimento pelo juiz no processo civil*. São Paulo: Saraiva, 2013.

OLIVEIRA, Pedro Miranda de. *Novíssimo sistema recursal conforme o CPC/2015*. Florianópolis:

Conceito, 2015.

OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

OLIVEIRA, Vallisney de Souza. *Nulidade da sentença e o princípio da congruência*. São Paulo: Saraiva, 2009.

OLIVEIRA JÚNIOR, Zulmar Duarte de. *A difícil conciliação entre o Novo CPC e a Lei de Mediação*. Disponível em: [http://jota.uol.com.br/a-dificil-conciliacao-entre-o-novo-cpc-e-a-lei-de-mediacao] Acesso em: 15.07.2016.

PANTOJA, Fernanda Medina. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

PASSOS, José Joaquim Calmon de. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2005. vol. 3.

PEIXOTO, Ravi. As restrições à atuação processual dos cônjuges previstas no art. 73 do CPC/2015 e as influências operadas pelo Código Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de direito civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2010. vol. 1.

_____. _____. Rio de Janeiro: Forense, 2010. vol. 2.

_____. _____. Rio de Janeiro: Forense, 2010. vol. 5.

PEREIRA FILHO, Benedito Cerezzo. A evolução da tutela executiva da obrigação de pagar quantia certa: do Código de Processo Civil de 1973 ao de 2015. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 5.

PICÓ I JUNOY, Joan. El principio de la buena fe procesal y su fundamento constitucional. *Revista de Processo*. vol. 196.

PIMENTEL, Wilson Fernandes. O CPC de 2015, mediação e arbitragem: um sistema geral de solução de conflitos. In: MELO, Leonardo de Campos; BENEDUZI, Renato Resende. *A Reforma da Arbitragem*. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. O Ministério Público e o papel de fiscal da ordem jurídica no CPC/2015. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 6.

PINHO; FONSECA. O incidente de desconconsideração da personalidade jurídica no novo Código de Processo Civil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

PISANI, Andrea Proto. *Lezioni di diritto processuale civile*. Nápoles: Jovene, 2010.

PONTES DE MIRANDA, Francisco. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2001. vol. 1.

_____. *Comentários ao Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 1998. vol. 2.

REDONDO, Bruno Garcia. Questões prejudiciais e limites objetivos da coisa julgada no novo CPC. *Revista de Processo*. vol. 24.

REDONDO; MÜLLER. Negócios processuais relativos a honorários advocatícios. In: DIDIER

JR., Fredie (coord. geral); CAMARGO, Luiz Henrique Volpe; COELHO, Marcus Vinicius Furtado (coord. do vol. 2). *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.

RIBEIRO, Diogo Albaneze Gomes. O pagamento dos atos processuais requeridos pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública – art. 91 do novo CPC In: DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo. *Coleção Repercussões do Novo CPC* (Processo e Administração Pública). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 10.

RICCI, Gian Franco. *Diritto processuale civile*. Turim: Giappichelli, 2012. vol 1.

RIDDER, Helmut. Aequitas und Equity. *Archiv für die civilistische Praxis*. vol. 39.

RODOVALHO, Thiago. A viragem da mediação no NCPC e no marco legal da mediação no Brasil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

RODRIGUES, Marcelo Abelha. O novo CPC e a tutela jurisdicional executiva (parte 1). *Revista de Processo*. vol. 244.

RODRIGUES, Marco Antonio. *A Fazenda Pública em juízo*. São Paulo: Atlas, 2016.

_____. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

RODOVALHO, Thiago. A viragem da mediação no NCPC e no marco legal da mediação no Brasil. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

ROQUE, André Vasconcelos. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl; GOTTWALD, Peter. *Zivilprozessrecht*. Munique: Beck, 2010.

SALOMÃO FILHO, Calixto. *O novo direito societário*. São Paulo: Malheiros, 2011.

SANCHES, Sidney. *Denúnciação da lide no direito processual civil brasileiro*. São Paulo: Ed. RT, 1984.

SCHILKEN, Eberhard. *Zivilprozessrecht*. Munique: Vahlen, 2010.

SCHULTES, Hans-Jörg. *Münchener Kommentar zur ZPO*. Munique: Beck, 2013. vol 1.

SCHWIND; KUKIELA. Câmaras de conciliação e mediação pública: comentários ao art. 174 do novo Código de Processo Civil. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 10.

SERAGLINI, Christophe; ORTSCHIEDT, Jérôme. *Droit de l'arbitrage interne et international*. Paris: Montchrestien, 2013.

SHIMURA, Sérgio. Prazo para a ação rescisória. *Revista de Processo*. vol. 209.

SICA, Heitor Vitor Mendonça. O advogado e os honorários sucumbenciais no novo CPC. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.

SILVA, José Afonso da. *Curso de direito constitucional positivo*. São Paulo: Malheiros, 2012.

SILVA SANTOS, Silas. *Litisconsórcio eventual, alternativo e sucessivo*. São Paulo: Atlas, 2013.

SIMÃO, José Fernando. *Estatuto da Pessoa com Deficiência causa perplexidade* (Parte 2). Disponível em: [http://www.conjur.com.br/2015-ago-07/jose-simao-estatuto-pessoa-deficiencia-traz-mudancas#author] Acesso em: 09.01.2016.

SOUSA, José Augusto Garcia de. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

SOUZA, Alexander Araujo de. Ministério Público: de onde vim, quem sou, para onde vou. *Revista dos Tribunais*. vol. 951.

SOUZA, Michel Roberto Oliveira de. Novas perspectivas sobre a oralidade no processo. *Revista Iberoamericana de Derecho Procesal*. 2015. vol. 2.

STEFANI, Marcos. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

STEIN, F.; JONAS, M. *Kommentar zur ZPO*. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. vol. 1.

STOLZE, Pablo. O Estatuto da pessoa com deficiência e o sistema jurídico de incapacidade civil. *Revista Síntese de Direito Civil*. vol. 99.

STTEFEK; UNBERATH (org.). *Regulating dispute resolution*. Oxford: Hart, 2013.

TALAMINI, Danielle Coutinho. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

TALAMINI, Eduardo. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

TARTUCE, Fernanda. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coord.). *Breves comentários ao novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016.

_____; DELLORE, Luiz. Gratuidade de justiça no novo CPC. In: DIDIER JR., Fredie; MACÊDO, Lucas Buril de; PEIXOTO, Ravi; FREIRE, Alexandre. *Coleção novo CPC* (doutrina selecionada). Salvador: JusPodivm, 2016. vol. 1.

TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina. *Código civil interpretado*. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. vol. 1.

TERTO E SILVA, Marcello. Honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública é parte. In: *Coleção Grandes Temas do novo CPC* (honorários advocatícios). Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 2.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *A insolvência civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

TROCKER, Nicolò. Processo e Costituzione nell'opera di Mauro Cappelletti: elementi di una moderna "teoria" del processo. *Revista de Processo Comparado*. vol. 2.

TORNAGHI, Hélio. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 1976. vol. 1.

TORRES, Ricardo Lobo. *Curso de direito financeiro e tributário*. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

VARELA, João de Matos Antunes. *Das obrigações em geral*. Coimbra: Almedina, 1973. vol. 1.

VIANA, Salomão; Stolze, Pablo. Boa-fé objetiva processual – reflexões quanto ao atual CPC e ao projeto do novo Código. *Revista Forense*. vol. 416.

- VINCENZI, Brunela Vieira de. *A boa-fé no processo civil*. São Paulo: Atlas, 2003.
- VOLLKOMER, Max. *Zivilprozessordnung* (Zöller). Colônia: Otto Schmidt, 2014.
- _____. Der Grundsatz der Waffengleichheit im Zivilprozess. *Festschrift Schwab*. Munique: Beck, 1990.
- WAGNER, Claus. *Münchener Kommentar zur ZPO*. Munique: Beck, 2013. vol. 1.
- WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. *Curso avançado de processo civil*. São Paulo: Ed. RT, 2016. vol. 1.
- _____. O *contempt of court* na recente experiência brasileira – anotações a respeito da necessidade premente de se garantir efetividade às decisões judiciais. *Revista dos Tribunais*. vol. 119.
- WORTHINGTON, Sarah. *Equity*. Oxford: OUP, 2006.
- YARSHELL, Flávio Luiz. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). *Comentários ao novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- ZANETI JR., Hermes. Código de Processo Civil 2015: Ruptura do paradoxo entre o Ministério Público da legalidade e o Ministério Público constitucional. In: *Coleção Repercussões do Novo CPC*. Salvador: JusPodivm, 2015. vol. 6.
- ZANZUCCHI, Marco Tullio. *Diritto processuale civile*. Milão: Giuffrè, 1946. vol. 1.
- ZAVASCKI, Teori Albino. *Processo coletivo*. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- ZEISS, Walter. *Die arglistige Prozesspartei*. Berlim: Duncker und Humblot, 1967.
- ZIMMERMANN, Walter. *Zivilprozessordnung*. Münster: LexNexis, 2008.
- ZIPPELIUS, Reinhold. *Juristische Methodenlehre*. Munique: Beck, 2012.
- ZUCKERMAN, Adrian. *On civil procedure*. Croydon: Thomson Reuters, 2013.

Índice Alfabético-remissivo

- Abuso do direito de demanda ou de defesa, 77, 5; 80, 3, 7
- Administrador, 75, 4, 5; 110, 1; 133, 2; 135, 1; 148, 1, 2; 149, 1; 159, 1; 160, 1, 2; 161, 1; 181, 2
- Advocacia em causa própria, 106, 1
- Afinidade de interesses, 113, 1, 2
- Alienação da coisa litigiosa, 109, 2, 3
- Amicus curiae*, 138, 1, 2, 3, 4
- Assistência, 71, 1; 76, 3; 94, 1; 98, 1; 99, 1; 100, 2; 101, 1; 102, 1; 106, 1; 109, 3; 111, 2; 120, 1; 121, 1, 2, 3; 122, 1, 2; 124, 1, 2, 3, 4; 125, 1; 127, 3; 198, 3, 4; 185, 1, 2; 186, 1
- Assistência judiciária, 98, 1; 99, 1; 100, 1; 101, 1; 102, 1; 185, 1
- Assistência litisconsorcial, 94, 1; 109, 3; 119, 1; 121, 1; 124, 1, 2, 3, 4; 128, 3
- Assistente simples, 94, 1; 121, 2, 3; 122, 1, 2; 123, 1; 124, 2; 128, 4
- Auxiliares da justiça, 82, 1; 83, 1; 84, 1; 86, 1; 87, 1; 90, 1; 91, 1; 93, 1; 94, 1; 98, 1, 4; 148, 1; 149, 1; 152, 1; 161, 1; 167, 2; 173, 2
- Boa-fé processual objetiva, 77, 1, 3; 79, 2
- Capacidade de ser parte, 70, 1, 4, 5, 6, 7; 75, 1, 2, 3, 4; 76, 1, 2; 103, 1
- Capacidade postulatória, 70, 1; 103, 1, 2; 104, 1, 2; 111, 2; 112, 3; 138, 3; 146, 2; 166, 1; 177, 1
- Capacidade processual, 70, 1, 5, 6, 7; 71, 1; 73, 2; 76, 2, 3; 103, 1
- Carga dos autos, 107, 3; 152, 1
- Casamento, 73, 1, 2, 4
- Cautio pro expensis, 83, 1, 3
- Centros judiciários de solução consensual, 165, 2
- Chamamento ao processo, 76, 3; 111, 2; 125, 3; 130, 1, 2; 131, 1, 2; 132, 1
- Citação, 70, 3; 72, 1, 2; 75, 5; 90, 1; 105, 1; 108, 1; 109, 1; 114, 1; 115, 1; 126, 1; 127, 2; 131, 1; 134, 3; 135, 1; 137, 2; 141, 2; 177, 1
- Coisa julgada material, 81, 1; 83, 3; 92, 1; 109, 3; 123, 1, 2; 124, 2; 128, 5; 136, 2; 138, 3
- Composse, 73, 2, 4; 114, 1, 2

Comunhão de interesses, **113**, 2

Conciliadores, **165**, 1; **166**, 1; **167**, 2, 3; **168**, 1; **319**, 1; **171**, 1; **172**, 1; **173**, 1; **175**, 1

Conexão de interesses, **113**, 2

Cônjuge (s), **73**, 1, 2, 3, 4; **74**, 1, 2, 3; **75**, 4; **76**, 4; **114**, 1, 2; **144**, 5, 6, 8, 10; **145**, 6

Contempt of court, **77**, 1, 2, 3; **78**, 1; **96**, 2, 3; **97**, 1; **98**, 4; **100**, 2; **161**, 1

Curador, **70**, 5; **71**, 1; **72**, 1, 2, 3; **75**, 4; **76**, 3

Curatela especial, **72**, 1, 2

Depositário, **77**, 2; **148**, 1; **149**, 1; **159**, 1; **160**, 1, 2; **161**, 1, 2

Depositário infiel, **77**, 2; **161**, 2

Desconsideração da personalidade jurídica, **133**, 1, 2; **134**, 1, 2, 3; **135**, 1; **136**, 1, 2; **137**, 1

Desistência, **90**, 1, 2; **122**, 2; **159**, 1

Dever de falar a verdade, **77**, 3, 4; **79**, 2; **80**, 5

Dever de urbanidade, **78**, 1

Direito de regresso, **125**, 3; **143**, 1; **181**, 3; **184**, 1

Duração razoável do processo, **139**, 3; **143**, 2; **153**, 1; **178**, 3

Eleição de foro, **141**, 2

Escrivão, **148**, 1, 3; **149**, 1; **150**, 1; **152**, 1; **153**, 1; **155**, 1

Estados estrangeiros, **75**, 3

Evicção, **125**, 2, 3; **127**, 3; **128**, 3

Extensão subjetiva da coisa julgada material, **123**, 2

Gratuidade da Justiça, **82**, 1, 95, 1; **98**, 2; **99**, 1; **169**, 1

Honorários de sucumbência, **75**, 6; **82**, 1, 3, 4, 5; **83**, 1; **85**, 1, 2, 3, 4, 5; **86**, 1; **87**, 1; **88**, 2; **90**, 1; **93**, 1; **94**, 1; **98**, 1, 4; **99**, 1; **140**, 2

Honorários recursais, **85**, 4

Incidente de impedimento ou de suspeição, **148**, 3

Interdição, **70**, 5; **71**, 1; **88**, 1, 2

Intérprete, **84**, 1; **98**, 3; **144**, 2; **145**, 2; **148**, 1; **149**, 1; **153**, 1; **162**, 1; **163**, 1; **164**, 1, 2; **184**, 1; **187**, 1

Interrogatório das partes, **139**, 9

Intervenção de terceiros, **83**, 1; **120**, 1; **125**, 1, 2; **127**, 2; **128**, 2; **129**, 1; **130**, 1; **133**, 1; **134**, 2; **137**, 1; **138**, 1, 4

Intervenção litisconsorcial voluntária, **124**, 4

Juízos divisórios, **89**, 1, 3

Jurisdição voluntária, 74, 2; 88, 1, 2
 Justiça da decisão, 123, 1; 124, 2; 128, 5
 Legitimidade extraordinária, 70, 7; 73, 2; 108, 1; 109, 3; 114, 1; 116, 1; 185, 1; 187, 1
 Legitimidade ordinária, 70, 7; 73, 2
 Legitimidade processual, 70, 7; 73, 2; 75, 3; 76, 4; 114, 1; 115, 1; 124, 3
 Litigância de má-fé, 77, 1, 2, 3; 79, 2; 80, 1, 2, 6; 81, 1, 2; 85, 2; 95, 2; 96, 1, 2, 3; 97, 1; 98, 4; 100, 2; 139, 8; 142, 1; 143, 2; 166, 1; 181, 3; 184, 1; 187, 1
 Litígio aparente, 142, 1
 Litisconsórcio facultativo, 113, 1, 2, 3; 114, 1; 115, 1
 Litisconsórcio necessário, 73, 3; 113, 1; 114, 1, 2, 3; 115, 1, 2, 3; 116, 1
 Litispendência, 80, 3; 109, 1
 Mandato, 75, 3; 104, 1; 105, 1; 111, 1, 2; 112, 1, 2, 3; 144, 5; 154, 2
 Nascituro, 70, 4
 Nome de guerra, 70, 3
Non liquet, 140, 1
 Oficial de justiça, 148, 1; 149, 1; 150, 1; 151, 1; 154, 1, 2; 155, 1
 Ordem cronológica, 153, 1, 2
 Organismos internacionais, 75, 3
 Outorga conjugal, 73, 2, 5
 Parentesco entre juízes, 147, 1
 Perito, 82, 2; 84, 1; 91, 2; 93, 1; 95, 2; 98, 3; 139, 8; 144, 3; 148, 1, 3; 149, 1; 156, 1, 2; 157, 1, 2; 158, 1; 163, 1; 164, 1, 2; 167, 2
 Personalidade jurídica, 70, 4; 75, 1, 3, 4; 98, 2; 99, 1, 133, 1, 2; 134, 1, 2, 3; 135, 1; 136, 1, 2; 137, 1
 Pessoa jurídica estrangeira, 75, 5
 Pessoa jurídica nacional, 75, 5
 Poder de polícia, 139, 8
 Poder Público em juízo, 75, 3; 139, 2
 Apresentação, 75, 2, 3, 4, 5, 6; 103, 1; 177, 1
 Preterição, 153, 2
 Primazia do julgamento do mérito, 76, 4; 141, 1
 Princípio da correlação, 141, 1
 Princípio da demanda, 81, 1; 115, 1; 128, 5; 130, 1; 133, 2; 141, 1

Princípio da sucumbência, **82**, 1, 3; **85**, 1

Quarentena, **172**, 1

Reconhecimento do pedido, **90**, 1

Remuneração do perito, **82**, 2; **91**, 2; **95**, 2

Representação, **71**, 1; **72**, 1; **75**, 2, 4, 6; **76**, 2, 3; **103**, 1, 2; **104**, 1, 2; **105**, 1; **106**, 1; **111**, 1, 2; **112**, 1, 2, 3; **138**, 3; **177**, 1; **182**, 1; **183**, 1; **185**, 1, 2; **186**, 1

Responsabilidade civil

 direta ou regressiva do juiz, **143**, 1

 do Defensor Público, **187**, 1

 do membro da Advocacia Pública **184**, 1

 dos membros do Ministério Público **176**, 1; **181**, 3

Responsabilidade civil processual, **79**, 1; **81**, 1

Revelia, **70**, 6; **72**, 3; **76**, 3; **103**, 2; **104**, 2; **106**, 1; **111**, 2

Sentença citra, extra ou ultra petita, **141**, 1

Solidariedade, **73**, 3; **77**, 3; **79**, 2; **87**, 1, 2; **130**, 1; **132**, 1; **145**, 4

Substituição processual, **108**, 1; **109**, 3, 4; **124**, 3

Sucessão processual, **108**, 1; **109**, 4

Sucumbência

 em parte mínima, **86**, 2

 parcial (ou recíproca), **86**, 1

Tradutor, **98**, 3; **148**, 1; **149**, 1; **162**, 1; **163**, 1; **164** 1, 2; **167**, 2

Transação, **90**, 2; **122**, 2; **166**, 1; **174**, 1

União estável, **70**, 2; **73**, 5

Vista dos autos, **107**, 2, 3; **179**, 1